

محاضرات في قانون المرافعات

مقارنة بالفقه الإسلامي

دكتور

عبدالله عبدالحى الصاوي

أستاذ قانون المرافعات المساعد

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

الأستاذ الدكتور

حامد محمد أبو طالب

أستاذ قانون المرافعات بجامعة الأزهر

العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

٢٠٢٤/٢٠٢٥ م



مقدمة

الحمد لله .. الحاكم العادل .. القاضى بالقسط يوم الفصل..نحمده سبحانه وتعالى ونشكره .. ونسأله أن يبسط لنا الاعتراف بفضله، ويقبض لسان الدعوى.. وأن يحسم مادة الشكوى ...، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشاهد والبشير والناذير... المنزل عليه قول الله تعالى: قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (الآية ٦٥ من سورة النساء). وأشهد أن لا إله إلا الله القاضى بالعدل بين الخصوم، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، الشاهد بالحق على العموم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بقية الشهود.

فهذا موجز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفَقْهاً لأحدث تعديلاته^(١)، وهو "مؤلف مشترك"، قد جاء في شكل محاضرات متتالية مقارنة بالفقه الإسلامي، وهو عندنا الآن بمثابة النواة التي ندعو الله - عز وجل - أن يمكننا من النسج حولها، والبناء فوقها، حتى يليق هذا العمل بعظمة هذا الركن العتيق - الأزهر الشريف - ومكانته العلمية في العالم كله، وذلك وفق ما يناسب ذاتية الدراسة في كلية الشريعة والقانون وعلومها الأصيلة.

هذا، ولقد جمعنا في هذا المؤلف بين شرح قانون المرافعات وأحكام الفقه الإسلامي، حتى يكون لمؤلفات هذا الصرح العلمى طابعها المتميز، ولبحوثه مذاقها الفريد من حيث التأصيل والمعاصرة، مع مراعاة الإيجاز الذي لا يخل بحقيقة المقصود من هذه الدراسة: تحصيلاً لقواعدها، وإحاطة بفروعها ومسائلها.

والله - سبحانه وتعالى- نسأل أن يغفر لنا زلاتنا ' وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يتغمدنا بواسع رحمته، وأن ينفع القارئ الكريم بما يقرأ إنه سميع مجيب.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نهمس في أذن القارئ الصديق بقول الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (سورة البقرة: من الآية رقم ٢٨٢).

ويحضرنا أن نذكّره أيضاً بقول الإمام الشافعي (رضي الله عنه):

شَكُوتُ إِلَى وَكَيْعٍ سُوءِ حِفْظِي فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي
وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يَهْدِي لِعَاصِي

هذا وبالله التوفيق...

(١) وآخرها القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤م، الجريدة الرسمية العدد ٢٧ مكرر (د) في ١٠/٧/٢٠٢٤، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨م.

تمهيد

تختلف نفوس البشر ونزاهتهم، وتباين أهواؤهم ورغباتهم، ولا يستطيع إنسان أن يعيش منفرداً ومنعزلاً عن مجتمعه، فلا بد من بقائه مع مجتمعه يأخذ منه ويعطي، ومن ثم ينتج من ذلك اختلاف حتمي في وجهات النظر بين الناس، مما يؤدي إلى التشاحن والتباغض والتحاقد والتحاسد، لذا فإن الحاجة ماسة إلى وجود قواعد تبين حقوق الأفراد وواجباتهم، لتلبي بذلك حاجاتهم ولقد وجدت القوانين الموضوعية، كالقانون المدني والقانون التجاري وغيرهما، لتبين حقوق الأفراد، وكيف تنشأ هذه الحقوق، وكيف تستعمل، وكيف تنقضي.

ولكن لا يكفي وجود القوانين الموضوعية التي تبين حقوق الأفراد، وواجباتهم، بل لابد من وجود قواعد تبين كيفية حماية هذه الحقوق، ورد ما يوجه إليها من اعتداءات، وترسم الطريق لصاحب الحق للحصول على الحماية اللازمة لحقه، وتحقيقاً لهذه الغاية وجدت قوانين المرافعات المتعاقبة.

تعريف قانون المرافعات:

يطلق "قانون المرافعات" ويراد به علم أو فقه المرافعات، ويمكن تعريفه بهذا المعنى بأنه : علم يدرس شئون القضاة والتقاضى من أصول وأوضاع، وعلى ذلك فهذا العلم يهتم بدراسة النظام القضائي ومبادئه، وقواعد الاختصاص ومشاكله، وإجراءات التقاضي وعوارضه، ولا يدخل في هذه الدراسة ما يتعلق بتنفيذ الأحكام أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى، وإنما تتم دراسة أحكام التنفيذ وطرقه وإجراءاته في مادة مستقلة هي مادة التنفيذ الجبري.

كما يطلق ذات التعبير "قانون المرافعات" ويراد به مجموعة القواعد التي تنظم التداعي أمام المحاكم، وقواعد التنفيذ وطرقه، وبعض الخصومات الأخرى.

ويمكن تعريف قانون المرافعات بهذا المعنى بأنه : "مدونة قانونية تحدد اختصاص المحاكم، وتبين الإجراءات التي تتبع أمام المحاكم المدنية، وترسم إجراءات التنفيذ الجبري وطرقه"^(١).

وقانون المرافعات بهذا المعنى لا يشتمل من مادة المرافعات إلا قواعد التداعي أمام المحاكم، ويشتمل على الإجراءات وبعض قواعد الاختصاص وهو ما ورد في الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ م . ومن ناحية أخرى فهو يشتمل على الأحكام العامة في التنفيذ وطرقه وإجراءاته، وقد وردت هذه الأحكام في الكتاب الثاني من القانون سالف البيان ولا تنفرد هذه الأحكام بمدونة خاصة أو تشريع مستقل^(٢).

(١) انظر تعريفات أخرى غير هذا لأستاذنا الدكتور/ عبد الباسط جميعي في مبادئ المرافعات، ص : ٤ ، وللدكتور/ أحمد الصاوي في الوجيز في قانون المرافعات ص : ٦ ، ومبادئ قانون القضاء المدني للدكتور/ فتحي والي ، ص ٥ .

(٢) أصول المرافعات للدكتور / أحمد مسلم ، ص ٧ - ١٠ .

وأما الكتاب الثالث والأخير من قانون المرافعات فهو يشتمل على إجراءات وخصومات متنوعة (العرض والإيداع ، ومخاصمة القضاة وأعضاء النيابة).

موضوع قانون المرافعات : تشتمل دراسة قانون المرافعات على ما يلي:

أولاً : قواعد النظام القضائي:

وهي تشمل القواعد المتعلقة بترتيب الجهاز القضائي وبيان محاكمه وتشكيلاته. وكذلك القواعد المتعلقة بالقضاة وأعاونهم من حيث شروط تعيينهم، وقواعد ترقيةهم وإعازتهم، ونقلهم وحقوقهم، وواجباتهم إلى غير ذلك من القواعد، كما أنها تنظم عمل أعوان القضاة، وهم المحامون والكتّاب والمحضرون والمترجمون .

ثانياً : قواعد الاختصاص:

وهي مجموعة القواعد التي تحدد سلطات القضاة ووظائفهم، وهي على ثلاث فئات : الأولى تبين ولاية كل جهة قضائية - عند تعدد جهات القضاء، والثانية تبين اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية، والثالثة تبين اختصاص كل محكمة من محاكم الدرجة الواحدة إقليمياً طبقاً للتوزيع الجغرافي أو المحلي.

ثالثاً : إجراءات التقاضي:

وهي مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها في رفع الخصومات إلى القضاء، ووسائل الدفاع أمام المحاكم، وما يجب على المحاكم مراعاته عند الفصل في الخصومات، وكيفية إصدار الأحكام، وطرق الطعن فيها وكيفية تنفيذها، وما يثور بشأنها عند تنفيذها من عقوبات وطريقة تدليلها.

والإجراءات بمعناها العام تشمل الإجراءات التي تتبع أمام جميع المحاكم، سواء كانت محكمة مدنية أم تجارية أم جنائية أم إدارية أم غير ذلك، وإذا أطلقت هذه الكلمة "الإجراءات" انصرف معناها إلى الإجراءات الواجبة الاتباع أمام المحاكم المدنية والتجارية بخلاف غيرها من المحاكم، فهي تختص بقوانين تنظم الإجراءات التي تتبع أمامها، ولكن هذه الإجراءات دائماً تقيد ولا تطلق، كالإجراءات الجنائية وهكذا.

ومن الملاحظ أن هذه المجموعات من القواعد (النظام القضائي، الاختصاص، الإجراءات) تتصل ببعضها اتصالاً وثيقاً، فمثلاً تشكيل المحاكم - وهو من قواعد النظام القضائي - يتصل اتصالاً وثيقاً بقواعد اختصاص كل محكمة، وأيضاً قواعد الاختصاص للصيقة الإجراءات، وذلك لأن قواعد الإجراءات تتضمن الجزاء على مخالفة قواعد الاختصاص^(١).

(١) المرافعات المدنية والتجارية ، للدكتور/ محمد حامد فهمي ص ٤ ، ٥، شرح قانون المرافعات الليبي للدكتور/ عبد العزيز عامر ص ٦ ، شرح قانون المرافعات للدكتورين/ عبد المنعم الشرقاوي ، عبد الباسط جميعي ص ٦ ، ٧.

أهمية قانون المرافعات :

لا يكفي تعيين القضاة وتخصيصهم للفصل في المنازعات، مع إطلاق الحرية لهم في تسيير الخصومات والحكم فيها بغير أوضاع معينة وإطلاق الحرية للخصوم يتخذون ما يريدون من إجراءات، بل لا مناص لحسن سير القضاء من وجود قواعد مختصرة ميسرة تؤدي إلى سرعة الوصول إلى الحق، وتوضح إجراءات التقاضي وأشكالها ومواعيدها، لأن القاضي في بحثه عن الحقيقة بين أقوال الخصوم وادعاءاتهم يقوم بعمل دقيق وخطير، فلا بد من قواعد ثابتة تحميه من التحكم، وأيضاً فإن حق الدفاع يتطلب اتباع إجراءات معينة معلومة سلفاً، ومراعاة مواعيد محددة معلومة، تحول دون المفاجآت وتحمي الخصوم من اغتيال حقوقهم.

ولا شك أن وضع قواعد للإجراءات محدودة مختصرة ميسرة لتؤدي إلى سرعة وصول صاحب الحق إلى حقه من أسهل طريق وفي أقصر وقت وبأقل النفقات، وهذا هو الهدف والفرض.

ولكن المبالغة في تعقيد الإجراءات وتطويلها، وتوسيع مواعيدها بحجة السعي إلى توفير الضمانات لتحقيق العدل، يؤدي إلى عكس المطلوب، فيصعب الطريق، ويطول وقته، وتتضاعف نفقاته، ويثقل عبؤه، وقد قيل "إن العدل البطيء الغالي الثمن إنما هو نوع من الظلم"^(١).

طبيعة قانون المرافعات :

نقصد بطبيعة قانون المرافعات تحديد مكانه بين أقسام القانون، أي هل : يعتبر من القانون الخاص أم من القانون العام؟.

إذا نظرنا إلى القواعد التي يشملها قانون المرافعات بمعناه الواسع نجد أن من بين هذه القواعد ما يعتبر من القانون العام، كالقواعد المتعلقة بالنظام القضائي، وغالبية قواعد الاختصاص، ذلك أن هذه القواعد تنظم تكوين واختصاصات السلطة القضائية، وهي سلطة عامة، وعلى هذا تعتبر هذه القواعد من القانون العام^(٢).

كذلك نجد القواعد المتعلقة بإجراءات الخصومة، وهذه تبدل القول فيها، فبينما كان الفقه القديم يرى أن هذه القواعد من القانون الخاص، تأسيساً على أن هذه القواعد تتعلق بحقوق

(١) المرافعات المدنية والتجارية للدكتور / محمد حامد فهمي ص ٥ ، ٦ ، شرح قانون المرافعات للدكتورين / عبد المنعم الشرقاوي ، عبد الباسط جمعي ص ٧ .

(٢) يقصد بالقانون العام مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان ، أما القانون الخاص فيقصد به مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات التي لا تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السيادة ، سواء أكانت هذه العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض أم كانت الدولة طرفاً فيها ، ولكن باعتبارها شخصاً اعتبارياً عادياً وليس باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان .

ومصالح الأشخاص الخاصة، فهي تكفل لهم ممارسة حقوقهم الخاصة على قدم المساواة بينهم، ويؤيد هذا النظر تسمية هذه القواعد بقانون المرافعات المدنية والتجارية، لكن هذا الاتجاه بدأ في الانحسار واتجه بعض الشراح إلى القول بأن هذه القواعد تعتبر من القانون العام، بالرغم من أنها ترمي في النهاية إلى حماية مصالح خاصة، إلا أنها إجراءات لازمة لأداء مرفق القضاء لوظيفته، فهي قواعد وضعت لأداء سلطة عامة لعملها^(١)، وينتهي هذا الفريق من الشراح إلى القول بأن قانون المرافعات فرع من القانون العام.

وتوسط كثير من الشراح^(٢) ورأي أن قانون المرافعات له طبيعة خاصة، وفي منزلة وسط بين القانون العام والقانون الخاص، حيث قد جمع هذا القانون بين قواعد من القانون العام وأخرى من القانون الخاص، كما سبق القول .

ونحن نؤيد هذا النظر، ذلك أن قانون المرافعات تضمن قواعد تهم المصلحة العامة، فتتصل بالقانون العام، ومن هذه القواعد قواعد النظام القضائي، وقواعد الاختصاص المتعلق بالولاية، وقواعد علانية الجلسات وإشهار الأحكام، وطرق الطعن وإجراءات التنفيذ الجبري. كما أن قانون المرافعات تضمن قواعد لا تهم غير الخصوم، فلهم تركها والاتفاق على غيرها، ومن ثم تتصل هذه القواعد بالقانون الخاص، ومن أمثلتها: قواعد الاختصاص المحلي وبعض قواعد الإجراءات.

التسميات المختلفة لقانون المرافعات :

تعدد الموضوعات التي يتناولها قانون المرافعات بمعناه العام على ما سبق القول، وكان هذا التعدد سبباً في اختلاف المقننين، وكذلك الفقهاء في الاسم الذي يطلق على مجموعة القواعد القانونية المنظمة لسلطة القضاء وطريقة الالتجاء إليه، ولا يزال الفقهاء والمقننون حائرين أشد الحيرة في اختيار اسم مناسب لقانون المرافعات^(٣)، والكل يجتهد في اختيار اسم يكون واضح الدلالة على الموضوعات التي ينظمها هذا القانون، ونلقي نظرة سريعة على بعض هذه التسميات فيما يلي:

(١) الدكتور / فتحي والي في مبادئ قانون القضاء المدني ، بند (٤) والدكتورة أمين النمر في قوانين المرافعات ف "٢٢".

(٢) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ص ٢٠ ، الدكتور / محمد العشماوي في قواعد المرافعات ف"٩" الدكتوران / عبد المنعم الشرقاوي وعبد الباسط جميعي في شرح قانون المرافعات ف"٤" ، الدكتور / أحمد الصاوي في الوجيز ف"٧" .

(٣) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات فقرة "٣" .

أ - التسميات التشريعية :

يطلق المقتن المصري والسوداني والليبي والعراقي والكويتي على هذه المجموعة من القواعد القانونية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)، بينما المقتنان السوري واللبناني يطلقان عليها (أصول المحاكمات المدنية والتجارية) والمقتن المغربي يطلق عليها (المسطرة المدنية). والمقتن التونسي والجزائري والفرنسي والإيطالي يطلقون عليها (قانون الإجراءات المدنية والتجارية).

ب- التسمية الفقهية :

يطلق بعض الشراح على مجموعة القواعد القانونية المنظمة لسلطة القضاء وطريقة الالتجاء إليه "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" وقد انتقدت هذه التسمية على أساس أن الإجراءات موضوع من الموضوعات التي تعالجها هذه المجموعة، فهو اسم قاصر عن الدلالة على بقية الموضوعات.

وأطلق كثير من الشراح^(١) على هذه المجموعة اسم "قانون المرافعات المدنية والتجارية" وقد انتقد بعض الشراح^(٢) هذه التسمية تأسيساً على قصورها في الدلالة، ذلك أن المرافعات هي بعض صور الإجراءات، وإذا كانت كلمة الإجراءات وهي الكل قاصرة في الدلالة فما بالك بالمرافعات وهي الجزء. وبذلك يرى تسمية هذه المجموعة باسم "قانون القضاء المدني" ولكن هذه التسمية أيضاً منتقدة، ذلك أن هذه القواعد لا تهتم فقط بالمسائل المدنية، وإنما تهتم أيضاً بمسائل القانون التجاري وقانون العمل والقانون الزراعي والأحوال الشخصية، فهو يهتم بعلاقات الأفراد في نطاق القانون الخاص، ولذلك اقترح تسميته باسم "قانون القضاء الخاص" ولكن هذه التسمية تثير في ذهن - عند إطلاقها - تصور نظام القضاء الخاص الذي لا تتولاه الدولة كما هو الحال في التحكيم^(٣).

وعندنا أن أفضل هذه التسميات في الدلالة على الموضوعات التي تعالجها هذه القواعد هو اسم (قانون القضاء المدني) فهو أكثر دلالة من غيره على هذه الموضوعات.

ومع هذا فلا مانع يمنع من استعمال اسم "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ذلك أنه من الناحية التشريعية يدل دلالة شاملة على مجموعة القواعد التي يشملها، فهو يشتمل على المسائل الإجرائية والاختصاص والدعوى، ولم يعالج التنظيم القضائي، ومن الناحية الفقهية

(١) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ف ٢، الدكتوران عبد المنعم الشراوي وعبد الباسط

جميبي في شرح قانون المرافعات ف ٧، الدكتور أمينة النمر في قوانين المرافعات ص ١١ .

(٢) الدكتور / فتحي والي في مبادئ قانون القضاء المدني ف ٣ .

(٣) الوجيز في شرح قانون المرافعات للدكتور / أحمد الصاوي ف ٤ .

يمكن توجيه إطلاق هذه الاسم "قانون المرافعات" على هذه الموضوعات على اعتبار أنها تسمية لكل باسم الجزء^(١).

علاقة قانون المرافعات بقوانين الإجراءات الأخرى:

تعدد القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي، فإلى جانب قانون المرافعات المدنية والتجارية، يوجد قانون الإجراءات الجنائية، وهناك أيضاً إجراءات التقاضي في المنازعات الإدارية، وإجراءات التقاضي في الضرائب بين الفرد والدولة، وغير ذلك.

ومع تنوع الإجراءات تبعاً لتنوع القوانين الموضوعية، إلا أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر الشريعة العامة في شأن التقاضي أياً كان نوعه مدنياً أم جنائياً، أم إدارياً أم غير ذلك.

ومعنى هذا أن الأصول والمبادئ التي يتضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية، كحرية الدفاع، وقواعد مخاصمة القضاة، ونظام إدارة الجلسات وولاية المحاكم في تصحيح الأحكام وتفسيرها، هذه المبادئ والأصول واجبة الاحترام عند التقاضي في المسائل المدنية أو الجنائية أو الإدارية أو غيرها، ما دامت لا تتعارض مع القوانين الموضوعية أو الإجرائية الخاصة بذلك.

وينبغي على كون قانون المرافعات هو الشريعة العامة في التقاضي سواء كان مدنياً أم جنائياً أم إدارياً أم غير ذلك أنه يتعين الرجوع إلى هذا القانون عند ظهور نقص أو إهمال أو غموض في القوانين الإجرائية الأخرى، وهذا ما نص عليه المقنن المصري صراحة في المادة (٣) من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون مجلس الدولة، حيث قال "...وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي"^(٢).

ومع كون قانون المرافعات هو الشريعة العامة، إلا أن هذا القانون لا يطبق على دعاوى الجنائية أو الإدارية إذا كانت القاعدة متعارضة مع القانون الجنائي أو الإداري أو لا تحقق أهدافهما بصورة مرضية^(٣).

(١) انظر: قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ف ٣ ، قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمر ص ٩ ، ١٠ ، أصول المرافعات للدكتور / أحمد مسلم ف ٥ ، مبادئ قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي ف ٣ .

(٢) وهذا النص ورد بالقوانين السابقة التي كانت تنظم مجلس الدولة أرقام ١١٢ لسنة ١٩٤٦ ، ٩ لسنة ١٩٤٩ ، و ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ، ٥٥ لسنة ١٩٥٩ . انظر: بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بدوي ص ١٥ في هامش ٢ .

(٣) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ص : ٢٣ ، الدكتورة أمينة النمر في قوانين المرافعات ف ٢١ ، الدكتور / أحمد مسلم في أصول المرافعات ف ١٢ ، الدكتور / أحمد الصاوي في الوجيز ف ٤ .

خصائص قانون المرافعات :

تتميز قواعد قانون المرافعات . في مجموعها . بأنها قواعد أمرة وشكلية وفورية التطبيق .

أولاً : قواعد أمرة^(١) :

قواعد قانون المرافعات في جملتها قواعد أمرة ؛ لأنها وضعت لتنظيم مرفق عام من مرافق الدولة وهو مرفق القضاء، ولا يعقل أن يترك للخصوم حق اختيار الجهة القضائية التي يعرضون عليها نزاعهم، أو تترك لهم حرية رفع دعاوهم بالطريقة التي تحلو لهم، ومن ثم كانت غالبية قواعد قانون المرافعات قواعد أمرة، ومن هذه القواعد : القواعد التي تتعلق بالنظام القضائي، ومعظم قواعد الاختصاص والقواعد التي ينص القانون صراحة على عدم جواز مخالفتها . ولئن كانت غالبية قواعد قانون المرافعات قواعد أمرة بلا شبهة كما سبق إلا أن هناك قواعد يثور الخلاف على ما إذا كانت تعتبر من القواعد الأمرة^(٢)، أم هي من القواعد المقررة، ولتحديد ذلك يتعين النظر إلى كل قاعدة على انفراد والبحث في الهدف من وضعها، والغاية التي قصدها المقنن من ورائها، فإذا كانت وضعت لتحقيق مصلحة عامة فهي أمرة، وإن كتبت وضعت لتحقيق مصلحة خاصة فهي مقررة^(٣) .

ثانياً : قواعد شكلية :

قانون المرافعات قانون شكلي^(٤)، فهو يجمع قواعد - في جملتها قواعد شكلية ؛ لأنها تلزم الأشخاص باتباع إجراءات معينة، ومراعاة مواعيد محددة عند اللجوء إلى القضاء، فهي تنظم الإجراءات والأشكال التي يتعين اتخاذها، وتحدد المواعيد الواجب مراعاتها عند اللجوء للقضاء، وهذه القواعد قواعد شكلية ؛ لأنها تتعلق بالشكل ولا تتعلق بموضوع الحقوق المطلوب حمايتها. والهدف من هذه الشكلية صيانة حقوق الخصوم من اغتيالها في غفلة منهم ومنع كيد بعضهم لبعض، فهي تمكن المدعى عليه من تحضير دفاعه، وتعطي المدعي فرصة للوقوف على

(١) تنقسم القواعد القانونية بحسب قوتها إلى قواعد أمرة وقواعد مقررة ، القاعدة القانونية الأمرة : هي القاعدة القانونية التي لا يجوز للأشخاص الاتفاق على ما يخالفها ، والقاعدة المقررة أو المفسرة هي القاعدة التي يجوز للأشخاص الاتفاق على ما يخالفها .

(٢) الدكتور أمينة النمر في قوانين المرافعات ف ١٦ .

(٣) شرح قانون المرافعات للدكتورين / عبد المنعم الشراوي ، وعبد الباسط جميعي ف ٦ ، بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بديوي ص ٣ ، شرح قانون المرافعات الليبي للدكتور / عبد العزيز عامر ف ٥ .

(٤) القانون الشكلي : هو مجموعة القواعد المنظمة للإجراءات التي تتبع لتطبيق القانون الموضوعي ، والقانون الموضوعي : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونية بين الأشخاص ، وتقرر الحقوق والواجبات وتحدد وسائل نشأتها ونطاقها وأثارها .

هذا الدفاع والرد عليه وتمكن القاضي من دراسة القضية وتضع حدوداً للقضاة في مباشرة وظائفهم لا يتعدونها، حتى يكون الخصوم في مأمن من تحكم القضاة .
وإذا كان للشككية أهميتها كضمانة من ضمانات العدالة، ينبغي عدم المغالاة فيها حتى لا تتعقد الإجراءات ويصعب الطريق ويطول الوقت وتزداد النفقات، وتضيع الحقوق لمجرد مخالفات شكلية لا ضرر منها^(١)، " وذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطية ذلولاً، لعدل سهل المنال، مأمون الطريق، لا يحتفل " بالشكل " ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون به حقاً أو يرد به باطلاً، عدل حريص على سد الذرائع الي يتسلل منها المبطلون، محترفي الكيد، وتجار الخصومة"^(٢) .

ثالثاً: فورية التطبيق:

قواعد قانون المرافعات فورية التطبيق، بمعنى أنها عند تغيير هذه القواعد؛ فإن القواعد الجديدة تسرى من وقت العمل بها على الدعاوى والإجراءات وأعمال التنفيذ القائمة أمام القضاء دون القواعد القديمة.

والعلة في ذلك أن قواعد المرافعات وضعت لتنظيم مرفق القضاء وبيان طريقة اللجوء إليه والإجراءات المتبعة في ذلك؛ فإذا رأى المقتن أن يغير هذه القواعد أو يعدل فيها فلأنه قدر أن القواعد الجديدة أكثر ملائمة وتحقيقاً للعدالة من القواعد القديمة، مما يستدعي تطبيقها فوراً على الدعاوى القائمة أمام القضاء، ولأن قواعد المرافعات لا تنظم - كقاعدة - الحقوق الموضوعية للخصوم وأيضاً لا توجد مصلحة - مشروعة - لأحد الخصوم في نظر دعواه وفقاً لإجراءات معينة أو أمام محكمة دون أخرى^(٣) .

هذا هو الأصل - فورية تطبيق قواعد المرافعات - وعلى هذا الأصل ترد بعض الاستثناءات نوجز الحديث فيها فيما يلي :

١- القوانين المعدلة للاختصاص:

استثنى المقتن من فورية التطبيق "القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى"^(٤) .

(١) الدكتور أحمد الصاوي في الوجيز بند ٩ ، وانظر قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمر بند ٤ بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بديوي ص ٤ .

(٢) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الجديد ١٣ لسنة ١٩٦٨م

(٣) الدكتور / عبد العزيز بديوي في قواعد المرافعات ص : ٤ ، ٥ .

(٤) المادة ١ / ١ مرافعات .

وعلى ذلك إذا كانت هذه الدعوى لا تزال متداولة أمام المحكمة لم يقفل فيها باب المرافعة الجديدة تطبق بأثر فوري، ويجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها وفقاً للقانون الجديد، وأما إذا كانت الدعوى قد أقفل باب المرافعة فيها، وحجزت للحكم فإن القانون القديم هو الذي يسري، وتظل المحكمة مختصة بهذه الدعوى رغم أن القواعد الجديدة جعلت مثل هذه الدعوى من اختصاص محكمة أخرى، وسواء كان حجزها للحكم مع الإذن بتقديم مذكرات أو بدونه؛ لأن حجزها للحكم دليل على أنها قد تهيأت لإصدار الحكم فيها ولو لم تقدم المذكرات المأذون في تقديمها^(١).

والحكمة من هذا الاستثناء أن الأصوب والأوفق هو أن تبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التي حققتها، وسمعت المرافعة فيها حتى تهيأت الدعوى للحكم فيها، وليس من الصواب في شيء إحالة هذه الدعوى، وقد بلغت هذه الدرجة إلى محكمة أخرى، فتعيد الإجراءات من جديد، مما يطيل أمد الخصومة ويضاعف نفقاتها لمجرد تعديل الاختصاص.

وجدير بالذكر أن هذا الاستثناء لا يسري إذا كانت القواعد الجديدة لم تقتصر على تعديل الاختصاص، وإنما ألغت محكمة أو جهة قضاء، ففي هذه الحالة تنفذ القواعد الجديدة بأثر فوري، وتنتقل الدعوى إلى جهة الاختصاص وفقاً للقواعد الجديدة حتى ولو كانت الدعوى قد أقفل باب المرافعة فيها^(٢).

٢- مواعيد المرافعات:

استثنى المقتن من فورية التطبيق "القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها" المادة ١ / ٢ مرافعات .

وعلى هذا إذا حدث تعديل في القواعد المنظمة للمواعيد^(٣)، فإن هذا التعديل لا يسري بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل تاريخ العمل بالقواعد الجديدة، وإنما يسري بالنسبة لهذا الميعاد القواعد السابقة التي بدأ الميعاد في ظلها^(٤).

(١) الدكتور / عبد العزيز بديوي في قواعد المرافعات ص ٥ .

(٢) الدكتور / عبد العزيز عامر في شرح قانون المرافعات الليبي ص : ١٥ .

(٣) المراد بقواعد المواعيد ، القواعد المنظمة للأجال والمهل ، من حيث قدر الميعاد واحتسابه وبدايته ونهايته، وامتداد الميعاد وأثره ، وانظر: قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمرف ٤٤

(٤) فمثلاً إذا كان ميعاد الطعن ستين يوماً، وبعد بدء الميعاد عدل إلى أربعين يوماً، فإن الميعاد الذي بدأ يظل محكوماً بالقانون القديم، ولا ينقضي إلا بانقضاء ستين يوماً كاملة، وإذا كان الميعاد أربعين يوماً وبعد بدئه عدل إلى ستين فإن هذا الميعاد ينقضي بانقضاء أربعين يوماً، سواء صدر القانون الجديد قبل انقضاء الميعاد القديم أو بعده.

والعبرة ببداية الميعاد وإن كان قد بدأ في ظل القواعد القديمة سرت القواعد القديمة، وإن لم يبدأ إلا في ظل القواعد الجديدة سرت القواعد الجديدة^(١).

وهذا الاستثناء يقصد به القوانين التي تعدل ميعاداً كان منصوصاً عليه في قانون سابق من قوانين الإجراءات، وأما ما لم يكن منصوصاً عليه من المواعيد فإنه لا يسري عليه هذا الاستثناء، ولو كان الميعاد قد قرره الفقه أو القضاء بغير نص عليه في القانون لأن التعديل بقانون لا يرد إلا على نص موجود^(٢).

والعلة في هذا الاستثناء أنه متى بدأ الميعاد في ظل قانون معين، فمن الأوفق والأعدل أن يتم الميعاد وفقاً للقانون نفسه، حتى لا يتبعض الميعاد أو يضطرب حساب بدايته ونهايته^(٣).

٣- طرق الطعن في الأحكام:

استثنى المقتن من قاعدة فورية سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى، أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، "القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق" المادة ٣/١ مرافعات .

وعلى ذلك فالأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد، لا يسري عليها القانون الجديد فيما يتعلق بالطعن متى كان هذا القانون ألغى أو أنشأ طريقاً من طرق الطعن، وإنما يسري عليها القانون القديم الذي صدرت هذه الأحكام في ظله.

والعلة في ذلك هي احترام الحقوق المكتسبة للأشخاص، ذلك أن إلغاء طريق للطعن في حكم كان قابلاً للطعن وفقاً للقانون الذي صدر في ظله، يمس حق المحكوم عليه في حرية الحصول على الحماية القضائية، وأيضاً إنشاء طريق للطعن في حكم كان غير قابل للطعن، وفقاً للقانون الذي صدر في ظله، يمس حق المحكوم له في استقرار مركزه القانوني^(٤).

(١) العبرة في بدء الميعاد باتخاذ الإجراء الذي يبدأ منه حساب الميعاد، كما حدده القانون الذي بدأ الميعاد في ظله، مثلاً إذا كان ميعاد الاستئناف لا يجري إلا من وقت حصول الإعلان ولم يحصل الإعلان إلا بعد العمل بالقانون الجديد، فإن القانون الجديد هو الذي يحدد مدة الاستئناف ولا عبرة ببداية الحق في الاستئناف.

(٢) انظر الطعن رقم ٤٢٩ لسنة ٣٤ ق، جلسة ٢٣ / ٥ / ١٩٦٨، س ١٩، ص: ١٠٠٨.

(٣) شرح قانون المرافعات للدكتورين عبد المنعم الشرقاوي، عبد الباسط جمعي ف ١.

(٤) انظر قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمرف ٤٦.

تقسيم : هذا وسوف نقسم الدراسة في هذا المؤلف إلى قسمين على النحو التالي :

القسم الأول: النظام القضائي ونظرية الاختصاص:

الباب الأول : النظام القضائي، ويشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول : المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام القضاء .

الفصل الثاني : ترتيب المحاكم وتشكيلها .

الفصل الثالث : العاملون بالقضاء .

الباب الثاني : نظرية الاختصاص والإحالة، ويشتمل على ستة فصول :

الفصل الأول : الاختصاص الولائي .

الفصل الثاني : الاختصاص النوعي .

الفصل الثالث : الاختصاص القيمي .

الفصل الرابع : الاختصاص المحلي .

الفصل الخامس : مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام .

الفصل السادس : الإحالة .

القسم الثاني: نظرية الدعوى وإجراءات التقاضي:

الباب الأول: الدعوى القضائية.

الفصل الأول: عناصر الدعوى وشروط قبولها.

الفصل الثاني: تقسيمات الدعاوى.

الباب الثاني: إجراءات التقاضي بوسيلة الدعوى.

الفصل الأول: رفع الدعوى وقيدها وانعقاد الخصومة.

الفصل الثاني: إجراءات نظر الدعوى.

الفصل الثالث: عوارض الخصومة.

الباب الثالث: التقاضي بوسيلة العريضة.

الفصل الأول: الأوامر على العرائض.

الفصل الثاني: أوامر الأداء.

الباب الرابع: الحكم القضائي وطرق الطعن فيه.

الفصل الأول: الحكم القضائي وقواعده وآثاره.

الفصل الثاني: طرق الطعن في الحكم القضائي.

القسم الأول

النظام القضائي ونظرية الاختصاص

الباب الأول

النظام القضائي

ويشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول : المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام القضاء .

الفصل الثاني : ترتيب المحاكم وتشكيلها .

الفصل الثالث : العاملون بالقضاء .

الفصل الأول

المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام القضاء

هناك مجموعة من المبادئ والأسس المهمة لا بد من توافرها لأي نظام قضائي عادل، وذلك لأن هذه المبادئ والأسس تعتبر سوج^(١) متينة تحمي العدالة وضمانات هائلة لحسن سير القضاء، ولأهمية هذه المبادئ تهتم بها الأمم، ومن ثم فقد تنص على بعض منها في دساتيرها، وتورد بعضها في القوانين الخاصة بالهيئة القضائية، بل قد تتكرر القواعد المقررة لها في أكثر من موضع، مما يشير إلى اهتمام المقتن بها. وفيما يلي نتناول هذه المبادئ مخصصين مبحثاً لكل مبدأ وذلك على النحو التالي :

المبحث الأول

استقلال القضاء

مفهوم استقلال القضاء:

وظيفة القضاء فصل الخصومات بين الناس، والتهوض بهذه الوظيفة على أكمل وجه يستلزم أن يكون القاضي بمنأى عن كل تأثير، أو تدخل يؤدي إلى ميل ميزان العدالة في يده أو انحرافه في إمساكه بحياد ونزاهة، ولذلك كان مبدأ استقلال القضاء من أهم المبادئ التي يقوم عليها أي نظام قضائي عادل.

ويقصد باستقلال القضاء أن يكون في مأمن من تدخل غير رجاله فيه، فلا يجوز للسلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في القضاء أو التأثير عليه، كما لا يجوز للقضاء أيضاً أن يتدخل في مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعلى هذا يمتنع على السلطة التشريعية أن تتصدى للفصل في الخصومات بين الناس أو أن تصدر تشريعاً يهدف إلى تحديد وجه الفصل في نزاع معين معروض أمام القضاء ، أو تعدل حكم أصدره القضاء في نزاع بعينه، أو إيقاف تنفيذ حكم معين، كما يمتنع على السلطة التنفيذية أن تصدر إلى القضاء أية توجيهات أو أوامر فيما يتعلق بوظيفة القضاء، بل وعليها المعاونة في تنفيذ الأحكام القضائية، ولو باستعمال القوة عند اللزوم. كما يعني استقلال القضاء أيضاً أن يكون رجاله أنفسهم أمنين على مقومات حياتهم، يعيشون في مأمن من تعسف الإدارة أو أفرادها^(٢).

(١) سوج جمع سياج، وهو ما أحيط به على الكرم ونحوه من شوك ونحوه، والجمع أسوجة وسوج بضمين مثل: كتاب وكتب، لكنه أمكن استقلاً للضمة على الواو. المصباح المنير ١/٣٤٧ طبع الأميرية.

(٢) التنظيم القضائي الإسلامي د/ حامد أبو طالب، ص: ٤٥.

هذا ولقد اهتمت الدساتير المتتالية في مصر بهذا المبدأ، ولا تجد دستوراً منها أغفل النص عليه، بل وتكاد العبارة واحدة منذ دستور ١٩٢٣ حتى دستور ٢٠١٤ وقد أورد الأخير هذا النص حيث قال: "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات"^(١).

وعلى ذلك فالسلطة القضائية في مصر مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وينبغي على ذلك أن المقنن لا يملك سلطة الفصل في الخصومات، ولا أن يصدر قانوناً يبين فيه وجه الفصل في نزاع معين، كما لا يملك تعديل حكم أصدره القضاء، وأيضاً لا تملك السلطة التنفيذية سلطة الفصل في الخصومات، ولا أن تصدر إلى القضاة أية توجيهات أو أوامر فيما يتعلق بوظيفة القضاء، كما لا تملك الاعتراض على تنفيذ حكم أصدره القضاء. ومن ناحية أخرى تلتزم السلطة القضائية بتطبيق القوانين التي يصدرها المقنن ولا تستطيع أن تتدخل في شئون الإدارة أو في أعمال السلطة التنفيذية.

وحماية للقضاة وضماناً لاستقلالهم جعل المقنن التدخل في القضاء لصالح أحد الخصوم أو للإضرار به جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة سواء كان التدخل بأمر أو طلب أو رجاء أو توصية^(٢)، ومن ثم فليس لأي فرد أن يملّي على قاض ما يحكم به في أية قضية من القضايا، ولو كان هذا الفرد رئيس المحكمة التابع لها القاضي أو رئيس هيئة قضائية، ولو كانت أعلى من المحكمة التابع لها القاضي، أو حتى وزير العدل نفسه باعتباره عضو الوزارة المسئول عن القضاء^(٣).

ومع هذا فاستقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس استقلالاً كاملاً، فالسلطة التشريعية تبين القوانين وتطبقها السلطة القضائية، وتملك الأخيرة الامتناع عن تطبيق قانون يخالف الدستور، والسلطة التنفيذية تعين القضاة وترقيهم وتنقلهم، كما أنها تسهم في تنفيذ الأحكام تحت إشراف قاضي التنفيذ^(٤).

استقلال القضاء في النظام القضائي الإسلامي :

منذ أن فصل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه القضاء عن الولاية، وخصص لبعض الولايات قضاة، أصبح القضاة مستقلين عن السلطة التنفيذية، وأصبحت وظيفة الفصل في

(١) المادة ١٨٦ من الدستور الحالي، وقد نصت المادة ١٨٤ منه على أن "التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم..." راجع الدستور الحالي لسنة ٢٠١٤ المعدل.

(٢) انظر المادة ١٢٠ عقوبات.

(٣) المرافعات المدنية والتجارية للدكتور / محمد حامد فهد ف ٢٤.

(٤) شرح قانون المرافعات للدكتورين عبد المنعم الشرقاوي وعبد الباسط جمعي ف ٩٠.

الخصومات من اختصاص القضاة، وظل القضاة في الإسلام مستقلين عن كل مؤثر، سواء كان من رجال السلطة التنفيذية أو غيرهم منذوي النفوذ أو الأقارب، وقد أورد المؤرخون كثيراً من الحوادث التي تشهد بذلك^(١).

المبحث الثاني

مجانية القضاء

المقصود بهذا المبدأ:

يقصد بمجانية القضاء أن القضاة لا يتناولون أجراً من الخصوم مقابل الفصل في منازعاتهم، وإنما يؤديون مهمتهم لقاء مرتبات تدفعها لهم الدولة شأنهم في ذلك شأن سائر العاملين في الدولة.

فالقضاة في مصر لا يتقاضون أجوراً على قضائهم من الخصوم، وإنما يحصلون على رواتبهم من خزينة الدولة، وتحصل الخزانة رسوماً من المتقاضين مقابل التجائهم إلى المحاكم، ويدفع المدعي هذه الرسوم في البداية، وإذا كسب الدعوى حكم بالمصروفات على خصمه فيستردها منه، وأما إذا خسر المدعي دعواه فإنه يتحمل الرسوم وحده.

وقد نادى بعض الشراح^(٢) بتقرير مبدأ مجانية القضاء بكل معنى الكلمة تمكيناً للأشخاص من الحصول على الحماية القانونية؛ لأنه لا ينبغي أن تكون الأعباء المالية سبباً في نكوص الدولة عن القيام بأخص وظائفها. وأياً ما كان الحال، فقد قصد بإلزام المدعين بدفع رسوم، التقليل من الخصومات الكيدية.

وأما الفقير الذي لا يملك مصاريف المطالبة بحقه، فقد راعاه المقتن وقرر إعفاءه من الرسوم القضائية، وحتى لا ينتهز الفقراء منحة الإعفاء ويكثر من الدعاوى بحق وبدون حق، اشترط القانون للإعفاء من الرسوم إلى جانب ثبوت عجزه عن الدفع، احتمال كسب الدعوى.

مجانية القضاء في النظام القضائي الإسلامي :

القضاء في الإسلام قضاء مجاني بكل معنى الكلمة، فالقاضي لا يأخذ أجراً من المتقاضين لقاء الفصل بينهم، وإنما يحصل على راتبه من بيت مال المسلمين فهو من عمال المسلمين وأجل

(١) انظر من تفصيل ذلك التنظيم القضائي الإسلامي د/ حامد أبو طالب، ص ٥، أخبار القضاة لوكيع ١٠٥، تاريخ القضاء في الإسلام للشيخ عرنوس ص: ١٢، الولاة والقضاة للكندي ص: ٤٢٧، رفع الإصر عن قضاة مصر ١/٢١، مبادئ التنظيم القضائي في العراق أ. ضياء شيت ص ٢٤.

(٢) الدكتور أمين النمر في قوانين المرافعات ف ٣١.

عمالهم، وهو قائم بمصالحهم، فعليهم رزقه، ومن يعاونه في أداء مهمته. بل يرى فقهاء المسلمين أن يفرض للقاضي من الراتب ما يجعله يحيا حياة كريمة، تليق برفعة المنصب العلي والمكان الجلي، فيفرض للقاضي ما يكفيه ويوسع عليه، حتى لا يتطلع إلى أموال الخصوم أو غيرهم^(١). ولا يتحمل الخصوم أية نفقات، فكل ما يحتاج إليه القاضي للنهوض بمهمته من أدوات كتابية أو غيرها، فهي أو ثمنها من بيت مال المسلمين، لكونها لازمة للقيام بمصالحهم^(٢).

المبحث الثالث

المساواة أمام القضاء

المقصود بهذا المبدأ:

يقصد بمبدأ المساواة أمام القضاء المساواة التامة بين جميع الأشخاص في حماية حقوقهم المشروعة، وإعطاء كل إنسان الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقه ودفع ما يقع عليه من اعتداء، ويكون هذا الحق مقرا لجميع فرق في ذلك بنى غنى وفقير أو كثير وصغير أو أمير وخفير، فعلاً تمييز بين الناس في حق اللجوء إلى القضاء بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة فالكل أمام القضاء سواء.

وتنص المادة (٩٧) من الدستور الحالي ٢٠١٤ على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".

وعلى ذلك فلجميع الأشخاص على السواء الحق في الحماية القانونية لا فرق في استعمال هذا الحق بين شخص وآخر مهما تفاوتت منازلهم، ولا مختلف اختصاص المحاكم إلا بسبب قيمة الدعوى، أو نوع النزاع دون النظر لأشخاص المتقاضين^(٣).

(١) وفي هذا المجال تجد في الفقه الإسلامي قلاند في جبين الدهر، وقل أن وجود الزمان بمثلها، فهذا كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، رضي الله عنهما، حين بعثهما إلى الشام كتب يقول: "... أن انظروا رجلاً من أهل العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم في الرزق ليكون لهم قوة وعليهم حجة". انظر: روضة القضاء للسمناني ١ / ٨٦. وهذا كتاب على بن أبي طالب إلى الأشتر النخعي واليه على مصر، كتب يقول: "... ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيته .. وافسح له في البذل ما يزيل عنه، وتقل معه حاجته إلى الناس" نص تاريخ القضاء في الإسلام للشيخ عرنوس ص: ١٧.

(٢) روضة القضاة للسمناني ١ / ٨٧.

(٣) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور/ عبد الباسط جميعي، ص ١٨١، قوانين المرافعات د. أمينة النمر، ف ٢٦.

المساواة أمام القضاء في النظام القضائي الإسلامي:

لا يوجد نظام قضائي في العالم اهتم بمبدأ المساواة بمثل ما اهتم به النظام القضائي الإسلامي فقد جعل هذا النظام حق اللجوء إلى القضاء حقاً مكفولاً للجميع بل وأوجب على القاضي مراعاة هذا المبدأ في كل شيء حتى ولفظه ومجلسه ودخول الخصوم عليه^(١).

ومن الثابت أن لجميع الأشخاص الحق في رفع دعاويهم أمام القضاء ويجب على القاضي أن يسمع الدعوى من أي مدعى على أي إنسان ، ولا يجوز للقاضي أن يمنع أحداً من اللجوء إلى القضاء حماية الحق له اعتدى عليه سواء كان المدعى عليه غنياً أم فقيراً ، جليلاً أم حقيراً ، فللسوقة العامي أن يدعى على السلطان القاهرة^(٢).

وتحدث الفقهاء المسلمون حديثاً طويلاً مفصلاً عن مبدأ المساواة وخالصة قولهم أن "إطلاقه يعم الصغير والكبير، والخلفية والرعية والدنى والشريف والأب والابن والمسلم والكافر"^(٣).

المبحث الرابع

علانية الجلسات

المقصود بعلانية الجلسات:

أن تكون المرافعة في الدعوى حتى النطق بالحكم في جلسات مفتوحة مسموح بدخولها لكل من أراد متابعة ما يحدث في المحكمة من إجراءات وتحقيقات وما يصدر فيها من أحكام^(٤).

والقاعدة العامة في جلسات المحاكم أن تعقد بصفة علنية، يباح فيها لمن يشاء من الأفراد حضورها دون عائق يحول دون هذا الحق، ومتى انعقدت الجلسة بمثل هذه الصورة؛ فإن ذلك أمر يكفي لإسباغ صفة العلانية عليها حتى ولو لم يحضر هذه الجلسة غير خصوم الدعوى^(٥).
ويحقق هذا المبدأ هدف مهم؛ هو بث الطمأنينة في نفوس المتقاضين والجمهور مما يشيع جو الثقة في القضاة ويشعر الناس بعدالتهم، ويؤدي أيضاً إلى إسباغ نوع من الرقابة للجمهور على أعمال القضاة بما يؤدي إلى دفع القضاة نحو بذل العناية اللازمة لتحقيق العدالة^(٦).

(١) معين الحكام للطرابلسي، ٢٠، حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٥ ، السلطة القضائية وأطوارها ص ٤٩، عبد الصمد عبد الحليم سالم، رسالة لنيل العالمية مع إجازة القضاء الشرعي، سنة ١٩٣٧م، بمكتبة كلية الشريعة برقم ٤٧٤ .

(٢) نظرية الدعوى د / محمد نعيم عبد السلام ٢ / ٩ ، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٩٢.

(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٥ ، حاشية الدسوقي ٤ / ١٤٢ ، شرح فتح القدير ٧ / ٢٤٧.

(٤) قانون المرافعات. د. الأنصاري حسن النيداني، ج ٢ / ١٨.

(٥) المستشار. سيد حسن البغال، المطول مرجع سابق، ص ٧٠٦ .

(٦) أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٤٠ .

أهمية المبدأ:

ينال مبدأ علنية الجلسات أهمية بالغة من الناحية الدستورية والقانونية، ونظرا لهذه الأهمية فإن المشرع لم يكتف بالنص عليه في قانون المرافعات بل حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على النص على هذا المبدأ. ذلك أن هذا المبدأ يؤدي إلى حسن الأداء لرسالة القضاء من جانب القضاة، مما يؤكد حيادهم ويعظم نزاهتهم ويحفظ هيبتهم، حيث يتم التقاضي على رؤوس الأشهاد، فيكون القاضي أبعد ما يكون عن التهمة بالميل أو التقصير.

كما أن علانية الجلسات تبعث بالثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين، حيث تكفل لهم حقوق الدفاع المقررة لهم قانوناً، كما أن علانية الجلسات تطلع الجمهور على مدى اهتمام القضاء بأعمالهم وعنايتهم بها، ونزاهتهم في أحكامهم، مما يزيد احترام الجمهور للقضاة وبيعث على الثقة فيهم^(١)، مما يمتنع معه تحكم القاضي في الخصومة^(٢) محل التقاضي.

وتأكيداً على أهمية العلانية في الجلسات، قرر المقتن في المادة "١٨٧" من الدستور المصري أن: "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية". وجاءت المادة "١٨" من قانون السلطة القضائية لتؤكد ذات المبدأ، حيث نص فيها المقتن على أن: "تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية، مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية"^(٣). كما نص على أهمية مبدأ العلانية في المادة (١٠١) مرافعات^(٤) "تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً، محافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب، أو لحرمة الأسرة"، وعليه فإن الأصل هو العلانية في التقاضي والمحاكمات إلا ما استثناه المقتن بنص خاص.

والأصل في المواد المدنية والتجارية أنها نظرت في جلسة علنية. ولم يوجب المشرع على المحكمة أن تضمن محضر الجلسة أو ورقة الحكم بيان يفيد نظر الدعوى في جلسة علنية؛ فإذا خلا محضر الجلسة أو ورقة الحكم مما يفيد ذلك؛ فإن ذلك لا يؤثر في صحة الحكم؛ إلا إذا ورد فيه بيان يفيد أن الدعوى نظرت في غرفة المشورة؛ فإنه يكون باطلاً؛ لأن مخالفة مبدأ علنية الجلسات يعد مخالفة لقاعدة دستورية ترتب بطلان الحكم.

(١) الدكتور / محمد حامد فهد في المرافعات المدنية والتجارية ف ٢.

(٢) المرافعات ، د/محمد حامد فهدى ، بند : ٣٤ ، ص ٣٣. قوانين المرافعات، د/ أمينة النمر، بند ٣٢، ص ٦٤، مبدأ علانية الجلسات في ضوء قانون الإجراءات الجنائية، د/ محمود عبد ربه القبلاوى.

(٣) المادة " ١٨ " من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ م .

(٤) قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، والتعديلات الواردة عليه.

حدود مبدأ العلانية:

يلاحظ أن تحقق العلانية لا يعنى بالضرورة السماح لجميع الناس بالدخول في قاعات الجلسات بالمحاكم، حيث قد يسبب ذلك ازدحاماً بقاعة الجلسة، مما يخل بنظامها، فيؤدى إلى التشويش على القاضى، أو إثارة الشغب بين الناس في حضور القاضى، وهذا يعد إساءة للقضاء وهيئته، لذا يجوز أن يقصر الدخول في القاعة على عدد محدود من الجمهور، بحيث يتناسب وحجم القاعة المخصصة لنظر الدعوى أو تجعل الدخول ببطاقات محددة سلفاً. كما هو شأن القضايا الهامة أو الخطرة. ولا يعد هذا خروجاً أو مخالفة لمبدأ العلانية المنصوص عليه قانوناً^(١).

ومن هنا يمكن القول بأن مبدأ العلانية مبدأ أصيل في التقاضى، ويحقق الرقابة الشعبية على عمل القاضى والسلطة القضائية، ولا يجوز بحال مخالفته إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً، كما هو الشأن في الحالات التي رأى المقتن أنها تمس النظام العام أو الآداب العامة أو كيان الأسرة. أما الحد من العلانية عند وجود المسوغ القانونى لذلك فلا يعد مخالفة لهذا المبدأ في جوهره وأصوله.

الاستثناء من قاعدة علنية الجلسات:

إذا كانت القاعدة العامة هي علنية الجلسات؛ فإنه استثناء من ذلك قدر المشرع أن هناك اعتبارات معينة قد تتصل بالحفاظ على الروابط الأسرية و اسرار العائلات، وقد تتصل بأسرار الدولة، أو بالآداب العامة، تقتضى فرض السرية على ما يدور في الجلسة، صيانة للأسرة، أو حماية لأسرار الدولة، أو محافظة على الآداب العامة أو رعاية للأخلاق، فأجاز للمحكمة نظر بعض الدعاوى في جلسات سرية^(٢).

بعض المسائل التي تنظر في غرفة المشورة :

التظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوى، حيث يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة (١٨٩) مرافعات، وينظر التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام (مادة ١٩٠ مرافعات). كذلك فإن للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب- في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق بالأحكام

(١) الوسيط، د/فتحي والى، بند: ٢٧٢، ص ٥٢٢، مبدأ علانية الجلسات، د/محمود عبد ربه القبلاوى، ص ٢٦.

(٢) المستشار. سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص ٨٠٧ - د. وجدى راغب، مرجع سابق، ص ٥٣٤.

والقرارات في جلسة علنية^(١). كما يجب أن تنظر الدعاوى المتعلقة بالضرائب والتي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية^(٢).

بطلان الحكم إذا خالف ما أوجبه المشرع من نظر الدعوى في جلسة سرية :

إذا أوجب القانون على المحكمة نظر الدعوى في سرية؛ فإنه يتعين عليها نظرها في غرفة المدولة بحضور الخصوم ومحاميهم، ويبطل الحكم إذا نظرت الدعوى في جلسة علنية في حالة من هذه الحالات. ولم يوجب المشرع على المحكمة أن تورد في محضر الجلسة أو في ورقة الحكم بيان يفيد انعقاد الجلسة في هذه الحالات في سرية؛ ومن ثم فلا بطلان إذا لم يرد مثل هذا البيان في الحكم؛ إذ الأصل في هذه الدعاوى أنها عقدت في سرية، وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات صحة ما يدعيه.

وتجدر الإشارة إلى أن: النطق بالحكم يجب أن يتم في جلسة علنية، وذلك في جميع الأحوال حتى مع حالات الاستثناء من العلانية الواردة بنص القانون، فإذا خالفت المحكمة ذلك، فنطقت بالحكم في جلسة سرية، ولو كانت الدعوى واردة في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانوناً كان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً؛ لمخالفته الصريحة لنص القانون، وبهذا يمكن القول بأن النطق بالحكم يجب أن يكون علانية ولا يقبل الاستثناء لأي سبب بالغاً ما بلغ^(٣).

علانية الجلسات في الفقه الإسلامي:

لقد حرص الفقه الإسلامي على إجراء التقاضي والمحاكمة في صورة علنية، وبعد القضاء في المسجد مظهراً من مظاهر علانية التقاضي في الفقه الإسلامي^(٤)، وبالرغم من اختلاف الفقهاء حول استحباب القضاء في المسجد، باعتباره أعدل المجالس وأقربها إلى تحقيق العدالة القضائية^(٥)، أو كراهية ذلك تنزيهاً للمساجد التي بنيت لأجل الذكر والصلاة^(٦)، إلا أن القضاء قد جرى فيها بغير نكير^(٧)، وفي مختلف القضايا، وهذا يؤكد على إجراء الجلسات القضائية في

(١) المادة (٥) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠.

(٢) المادة (٩٤) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١.

(٣) أصول المرافعات د/أحمد مسلم، بند ٤٦، ص ٤٧، قوانين المرافعات د / أمينة النمر، بند ٣٢، ص ٦٥، مبدأ علانية الجلسات، د/ محمود عبد ربه القبلاوي ص ٤١.

(٤) نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، د / عبد الناصر موسى أبو البصل ص: ٣٨٦، علانية جلسات التقاضي في المملكة العربية السعودية، د/ ناصر ابن محمد الجوفان، ص ١٨.

(٥) كشاف القناع، للمهوتي ٣١١/٦، نظرية الحكم القضائي، د/عبد الناصر أبو البصل ص ٣٨١.

(٦) الحاوي الكبير، للماوردي ٢٠ / ٨٢.

(٧) شرح فتح القدير، لابن الهمام ٦ / ٣٧٠، الكافي، لابن عبد البر، ص ٤٩٩.

أماكن علنية يشهدها جميع من أرادها من الناس ولو لم يكن مسلماً^(١)، وذلك دفعاً للتهمة عن القاضى لو أنه قضى في جلسات سرية^(٢)، فكانت العلانية محققة في قضاء المسجد، ولها ثمارها في حفظ هيبة القاضى، وتحقيق الرقابة الشعبية على أحكامه وقضائه^(٣). كما عرف الفقه الإسلامى علانية التقاضى والقضاء في غير المسجد من الأماكن البارزة التى يشهدها جميع الناس، فاستحسنوا لذلك أن يقضى القاضى في أماكن تجتمع فيها العامة، ليشهدوا قضاءه وحكمه بين الخصوم^(٤)، على وجه يحقق تقريب القضاء من الخصوم دون كلفة أو مشقة^(٥).

المبحث الخامس

حصول الإجراءات فى مواجهة الخصوم

المقصود بهذا المبدأ

يقصد بحصول الإجراءات فى مواجهة الخصوم، أن كل إجراء من إجراءات الخصومة يتخذه أحد الخصوم يجب أن يكون فى مواجهة الطرف يتمكن من الرد على خصمه حماية لمصلحته. ويعطى هذا المبدأ للخصم فرصة للرد على كل طلب بوجه إليه إن كان لديه رد كما يكمل حقه فى مناقشة الخصم فى دفاعه، ومن ثم فلا يؤخذ خصم على غرة وهو أمام القضاء. ومبدأ حصول الإجراءات فى مواجهة الخصوم، من المبادئ الأساسية فى النظام القضائى المصرى، ولذلك يوجب القانون إعلان المدعى عليه بالطلبات الموجهة إليه، ومنع المدعى من إبداء طلبات جديدة، أو تحقيق الطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى، فى الجلسة التى يتخلف فيها خصمه، وكذلك منع المدعى عليه من إبداء طلبات فى غيبة المدعى، ويوجب القانون تمكين كل خصم من الاطلاع على الأوراق التى يقدمها خصمه تأييداً لدعواه. كما يوجب القانون على القاضى أن يمتنع بعد إقفال باب المرافعة عن سماع أي أقوال من أحد طرفي الخصومة فى غيبة الطرف الآخر، ومن قبول أية ورقة لم يتطلع عليها خصمه^(٦).

(١) المغنى ومعه الشرح الكبير، لابن قدامة ١١ / ٣٨٨ .

(٢) تبين الحقائق ، للزليعى ٤/ ١٧٨ .

(٣) مواهب الجليل، للخطاب ٦ / ١١٤، نظرية الحكم القضائى، د/ عبد الناصر أبو البصل، ص ٣٨٧.

(٤) المجموع، للنووى ٢٠ / ١٣٢ .

(٥) المغنى ومعه الشرح الكبير، لابن قدامة ١١ / ٣٨٨ .

(٦) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور عبد الباسط جيمع ص ١٨٩ وراجع فى الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٤٦ ق جلسة ٢٠/٤/١٩٧٨، ص ٢٩، ١٠٥٣ "لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة ١٦٨ من قانون المرافعات أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً وهذا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أصل من أصول المرافعات ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد

غير أن هذا المبدأ لا يمنع المحكمة من السير في إجراءات نظر الدعوى بالرغم من غياب المدعي عليه، متى ثبت علمه بالدعوى بوصول الإعلان الصحيح إليه. واستثناءً من هذا المبدأ يجيز القانون اتخاذ إجراءات في غير مواجهة الخصوم كاستصدار أمر على عريضة أو أمر أداء^(١).

حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم في النظام القضائي الإسلامي:

الأصل في الفقه الإسلامي أن يتخذ الإجراء في مواجهة الخصم، ولا يجوز للقاضي أن يسير في إجراءات نظر الدعوى مع غيبة أحد الخصوم عن مجلس القضاء، مع حضوره في البلد وعدم علمه بالدعوى، ويمتنع على القاضي أن يسمع بينة في غيبة الخصم، ولا يجوز له أن يصدر حكمه بناءً على هذه البينة؛ لأن ذلك نوع من القضاء على الغائب^(٢)، بل لا يجوز للقاضي أن يقرأ كتاب قاض آخر يتضمن شهادة على مدعي عليه إلا بحضوره، لأن ذلك بمنزلة أداء الشهادة، فلا بد من حضوره^(٣). هذا هو الأصل، ولكن إذا امتنع المدعي عليه من الحضور أمام القضاء نعتاً ولدداً في الخصومة جاز للقاضي النظر فيها، حتى وإن ظل المدعي عليه غائباً^(٤).

المبحث السادس

حرية الدفاع والمناقشة

المقصود بهذا المبدأ:

يقصد بهذا المبدأ: حرية الدفاع والمناقشة. إعطاء كل خصم فرصة كافية لإبداء وجهة نظره أمام القضاء فيما قدمه هو أو قدمه خصمه من ادعاءات. ويعتبر هذا المبدأ ضماناً هاماً من ضمانات العدالة ذلك أن القاضي إذا تأني في إصدار حكمه، حتى يسمع كل كلام الخصوم، فهو أحرى أن يتبين له وجه القضاء. وهذا المبدأ: حرية الدفاع والمناقشة، أوسع وأشمل من المبدأ السابق، حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم، ويكمّله، فالأخير يتطلب حضور المدعي عليه أو نائبه، ليكون على علم بما يتخذ ضده من إجراءات، بينما الأول: حرية الدفاع، يتطلب إعطاء الخصم بعد حضوره فرصة لإبداء وجهة نظره وأسانيدها.

أذنت للطاعنة بإيداع مذكرتها بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها.

(١) قوانين المرافعات د / أمينة النمرف ١٤ .

(٢) شرح فتح القدير ٧ / ٢٨٦ ، المغني لابن قدامة ١٠ / ٩٧ .

(٣) الهداية وشرح العناية عليهما ضمن شرح فتح القدير ٧ / ٢٩٣ .

(٤) نظرية الدعوى للدكتور / محمد نعيم عبد السلام ٢ / ٣١ .

وتنص المادة "٩٨" من الدستور الحالي المعدل في ٢٠١٤م على أن: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع وتضمن الدولة لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم". وتنص المادة ١٠٢ مرافعات على أنه: "يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى، أو مقتضيات الدفاع فيها، ويكون المدعي عليه آخر من يتكلم".

وعلى ذلك يجب على القاضي أن يستمع إلى أقوال الخصوم خلال المرافعة، ولا يقاطعهم أثناء إبداء طلباتهم أو دفوعهم، إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى، أو تجاوزوا حدود الدفاع المقررة، أو وجه بعضهم لبعض سباً أو طعن بعضهم في حق شخص أجنبي عن الدعوى. وينبغي على ذلك وجوب إمهال الخصوم للحصول على أوراق أو مستندات تكون منتجة في الدعوى إذا طلب أحدهم ذلك. ويقتصر حق الخصم في الدفاع والمناقشة على إعطائه الفرصة للكلام وإظهار وجهة نظره وأدلته، فإن امتنع عن الكلام أو قصر في تقديم أدلته استمرت المحكمة في نظر الدعوى والحكم بما تنتهي إليه.

حرية الدفاع والمناقشة في النظام القضائي الإسلامي:

مبدأ حرية الدفاع والمناقشة بمعناه المتقدم من المبادئ الأساسية الهامة في النظام القضائي الإسلامي، فلكل خصم من الخصوم حق إبداء وجهة نظره أمام القضاء، والإدلاء بأدلته وأسانيده، سواء كانت تثبت ما اتجه إليه أو تنفي مزاعم خصمه، ولا يجوز للقاضي أن يحكم قبل سماع ما يريد أن يقوله كل خصم^(١). ويجب على القاضي أن يمهّل الخصم لإحضار بينته إذا ادعى أن معه بينة، ولكنها غير حاضرة وطلب إمهاله لإحضارها^(٢). ويقتصر حق الخصم في الدفاع والمناقشة على إتاحة الفرصة له ليتكلم ويبدي وجهة نظره وأدلته، فإن هو أصر على عدم الكلام أو قصر في إبداء أدلته أو كان خصمه ألحن بحجته، قضى القاضي وفقاً لما انتهى إليه^(٣).

(١) تطبيقاً لحديث رسول الله ﷺ لعلي بن أبي طالب حين بعثه قاضياً إلى اليمن: "إن الله سهيدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضي حتى تسمع كلام الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. انظر: روضة القضاء للسمناني ٢٧٧/١، مطالب أولي النهى ٥٠٨/٦.

(٢) المغني لابن قدامة ١٠ / ٢٠١، روضة القضاء للسمناني ٢٩٣/١.

(٣) الشرح الكبير للدردير ٤ / ١٥١، كشاف القناع ٦ / ٣٣٤.

والهدف من إهمال الخصم لإحضار البيئة هو إحضارها، فإن أساء خصم استعمال حقه في ذلك واستعمله للتسويق والمماثلة كيداً لخصمه كان للقاضي أن يفوت عليه غرضه، ويحكم عليه^(١).

ولا يجوز للقاضي أن يمنع خصماً من الكلام طالما كان كلامه في الموضوع، أما إذا خرج عنه، أو أساء للخصوم أو للقاضي أو لغيرهم منعه القاضي وزجره^(٢).

المبحث السابع

تعدد القضاة والقاضي الفرد

المقصود بهذا المبدأ:

يقصد بتعدد القضاة أن تنظر الخصومة أمام محكمة مشكلة من عدد فرد من القضاة يدرسونها ويحققونها ويفصلون فيها. وأما نظام القاضي الفرد فيقصد به أن تنظر الخصومة أمام محكمة مشكلة من قاض واحد، يقوم بمفرده بدراستها وتحقيقها والفصل فيها. ولكل واحد من النظامين، تعدد القضاة والقاضي الفرد، مزاياه التي تعتبر بالتالي عيوباً في النظام الآخر.

مزايا تعدد القضاة:

١- يمثل ضماناً من ضمانات العدالة، ذلك أن هذا النظام يعطي الفرصة لدراسة الموضوع دراسة متأنية ومن وجهات نظر متعددة تمكن من إدراك جميع جوانبه، وبالتالي يصدر الحكم بعد البحث، والتمحيص أقرب ما يكون إلى الصواب، بينما في نظام القاضي الفرد لا يدرس الموضوع إلا من وجهة نظر قاضي واحد، وقد تغيب عنه بعض جوانبه.

٢- تعدد القضاة ينفي احتمال التحيز، وذلك لأنه إذا أمكن تصور تحيز القاضي لشخص ما، فلا يتصور تحيز مجموعة من القضاة لذات الشخص، وكذلك إذا مال أحد القضاة لخصم، فإن بقية الهيئة ستكون ضده في الرأي، فضلاً عن أن مراقبة زملائه تمنعه من ذلك، بخلاف القاضي الفرد، فلن يختلف معه أحد في الرأي، ولن يمنعه من تحيزه مراقبة أحد. إذا تصور إمكان التحيز.

٣- تعدد القضاة يسهم في تحقيق استقلال القضاء، ذلك أن الحكم يصدر باسم الهيئة وينسب إليها مجتمعة، فلا يعرف ما إذا كان قاضي معين مؤيداً للحكم أو معارضاً له مما يجعل القاضي لا يتأثر بالمؤثرات الخارجية، ومن ثم يكون في أمان وحرية في إبداء رأيه. بخلاف نظام القاضي

(١) حاشية الدسوقي ٤/١٥٠.

(٢) معين الحكام للطرابلسي ص: ٢١، المغني لابن قدامة ٤٠/١٠.

الفرد ، فالحكم فيه ينسب لقاض معين مما يجعله هدفاً للضغط عليه وإرهابه، وقد يتأثر بالمؤثرات الخارجية ويخاف منها فيمتز ميزان العدالة في يده.

مزايا نظام القاضي الفرد :

١- نظام القاضي الفرد يشعر القاضي بمكانته ومسئوليته، فهو الذي يصدر الحكم، ويتحمل مسئوليته، وينسب إليه مما يدعوه إلى الاجتهاد في بحث الموضوع، والتروي في إصدار الحكم. بخلاف الحال في نظام تعدد القضاة ، حيث ينسب الحكم إلى هيئة لا إلى فرد، مما يدعو كل واحد منهم إلى الاعتماد على غيره.

٢- نظام القاضي الفرد يقلل من تكاليف القضاء ويحقق سرعة الفصل في المنازعات، ذلك أن هذا النظام يمكن من توزيع القضاة ونهوض كل واحد منهم بعدد معقول من القضايا. بخلاف تعدد القضاة حيث لا يمكن توزيعهم، وإنما يجتمعون في مكان واحد، وينهضون جميعاً بعدد محدود من القضايا، مما يؤدي إلى تراكم القضايا وتأخير الفصل فيها وإطالة مدة التقاضي^(١).

موقف المقتن المصري من تعدد القضاة والقاضي الفرد:

رأينا أن لكل من النظامين مزاياه وله عيوبه، ولذلك حاول المقتن المصري الاستفادة من مزايا النظامين مع العمل على تفادي العيوب، ومن ثم فقد أخذ بنظام تعدد القضاة. كقاعدة. فالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، تتكون دوائرها جميعاً من عدد فردي من القضاة. وإلى جانب هذا جمع المقتن مجموعة من الدعاوى يمكن وصفها بالبسيطة لكونها ضئيلة القيمة أو عديمة التعقيد، أو لا تحتاج إلى خبرة قانونية عميقة ، أو لا يمس الحكم فيها أصل الحق، وجعل هذه الدعاوى من اختصاص محكمة مكونة من قاض واحد.

وبذلك يتمكن المقتن من الاستفادة بمزايا النظامين، فالقضايا البسيطة التي تحتاج إلى سرعة ينظرها قاض فرد، أما القضايا الكبيرة الخطيرة المعقدة فهي تحتاج إلى خبرة قانونية عميقة، وهي جديرة بأن تنظر أمام محكمة مشكلة من عدد من القضاة.

تعدد القضاة والقاضي الفرد في النظام القضائي الإسلامي:

لقد تحدث الفقهاء المسلمون في نظامي تعدد القضاة والقاضي الفرد واتفقوا على أنه يجوز لولى الأمر أن يعين شخصاً واحداً في بلد واحد يتولى مهمة الفصل بين الناس في الخصومات وهو

(١) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي ص ١٨٦ ، المرافعات المدنية والتجارية للدكتور/

محمد حامد فهمي ف ٤٢، أصول المرافعات للدكتور / أحمد مسلم ، ف٥٨، قانون المرافعات للدكتور محمد عبد

الخالق عمر ص ١٠٠.

نظام القاضي الفرد^(١). ثم اختلفوا في جواز تعيين عدد من القضاة، يتولون مجتمعين مهمة الفصل بين الناس في الخصومات^(٢).

والراجح جواز تعدد القضاة لا سيما في عصرنا الحاضر. لأن الخلاف في القضاة المجتهدين وقضاة العصر مقلدون، والقضاء الآن مخصص بالزمان والمكان والنصاب.

المبحث الثامن

التقاضي على درجتين

المقصود بهذا المبدأ:

يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين: حق الاستئناف أن كل نزاع يعرض أمام محكمة أول درجة وبعد الفصل فيه، يمكن عرضه من جديد على محكمة أعلى (محكمة الدرجة الثانية) لإعادة نظره والفصل فيه، وتعرف المحكمة الأولى بمحكمة أول درجة، والثانية بمحكمة الدرجة الثانية، أو المحكمة الاستئنافية. بخلاف مبدأ "التقاضي على درجة واحدة" حيث لا يمكن عرض النزاع مرة ثانية بعد الفصل فيه، ويقتصر عرضه على محكمة واحدة. ولكل من النظامين مزاياه التي تعتبر بالتالي عيوباً في النظام الآخر:

مزايا التقاضي على درجتين :

لنظام التقاضي على درجتين مزايا متعددة، أهمها ما يلي:

أولاً: نظام التقاضي على درجتين يعطي فرصة لتدارك ما قد تقع فيه محكمة الدرجة الأولى من أخطاء، أو ما يشوب أحكامها من عيوب، لا سيما وأن النصوص كثيراً ما تكون غير قطعية الدلالة على المطلوب، ومن ثم تختلف فيها الأفهام، والقاضي معرض للوقوع في الخطأ، ولذلك وجب الاحتياط من مثل هذا الخطأ بتقرير التقاضي على درجتين، حيث تتكون محكمة الدرجة الثانية من قضاة أكثر عدداً، وأوفر خبرة من قضاة محكمة الدرجة الأولى.

ثانياً: هذا النظام يبعث قضاة محاكم الدرجة الأولى على الاهتمام بدراسة الموضوع، وتدقيق الأسباب، والتأني في إصدار الأحكام، لأن القاضي حين يعلم أن حكمه يمكن أن يعاد فيه النظر، وأن تناقش حيثياته ومنطوقه يهتم بدراسة الموضوع ويدقق الأسباب، ويتأني في الحكم^(٣).

(١) مطالب أولي النهي ٦ / ٤٦٨.

(٢) المغني لابن قدامة ٩٢/١٠، حاشية الدسوقي ١٣٤/٤، روضة القضاة للسمناني ٨١/١، ٨٢.

(٣) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور/عبد الباسط جميعي ص ١٨٤، المرافعات المدنية والتجارية للدكتور محمد حامد فهي في ٣٧، مبادئ قانون القضاء المدني د. فتحي والي في ١٣٢.

ثالثاً: هذا النظام يعطي الخصم فرصة لتعديل مسار دفاعه إذا تبين له أن خصمه كان ألحن بحجته منه، ولتكملة ما فاتته من نقص في الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.

رابعاً: هذا النظام يبعث على الثقة في القضاء والرضا بقراره أياً ما كان، ذلك أنه إذا حسب الخصم عدد القضايا الذين نظروا قضيته سيجدهم يتراوحون بين أربعة إلى ستة قضايا، وهذا يبعث الثقة في القضاء، حيث لا يعقل أن يتواطأ هذا العدد ضده، وفي الدرجتين، وفضلاً عن ذلك فهذا العدد يجعله راضياً بالحكم حتى ولو كان ضده^(١).

مزايا التقاضي على درجة واحدة :

لنظام التقاضي على درجة واحدة عدد من المزايا أهمها ما يلي :

أولاً: يؤدي إلى سرعة الفصل في المنازعات وتقصير مدة الخصومة، وتوفير النفقات، وذلك لأن النزاع سينتهي بصدر الحكم من المحكمة، ولن تكون هناك فرصة لتجديده مرة ثانية أمام محكمة أخرى مما يؤدي إلى سرعة إنهاء المنازعات، وتقصير مدة الخصومة وتوفير النفقات.

ثانياً: هذا النظام يبعث الثقة في نفوس الناس في أحكام المحاكم، ذلك أن عرض النزاع على محكمة ثانية من شأنه أن يزعزع ثقة الناس في الحكم الأول، لا سيما إذا اختلفت آراء القضاة واتجاهاتهم.

ثالثاً: قصر التقاضي على درجة واحدة يجعل المتقاضين في وضع متكافئ من يقدر منهم على نفقات المحاكم المتعددة، ومن لا يقدر، حيث لا يسمح بعرض النزاع مرة ثانية أمام محكمة أعلى لا يتمكن من الوصول إليها إلا من يقدر على نفقاتها.

وتعرض المنازعات في القضاء المصري على درجتين للتقاضي، حيث ترفع الدعوى إلى محكمة تفصل فيها أول مرة ، ثم يكون للخصم المقضي عليه حق الطعن في الحكم بالاستئناف إلى محكمة أعلى ، يطرح عليها النزاع لتحكم فيه من جديد.

وإذا كان القانون المصري قد أخذ بنظام التقاضي على درجتين كقاعدة، إلا أن هناك حالات رجح فيها المقتن بعض الاعتبارات العملية على مقتضى العدل المطلق، ومستلزمات حسن القضاء^(٢)، استثنائها من قاعدة التقاضي على درجتين من ذلك الدعاوى ضئيلة القيمة، والتي لا تزيد قيمتها عن مبلغ معين، لا تحتل نفقات العرض على درجتين، وكذلك الحالات التي يجيز المقتن فيها للخصوم الالتجاء إلى محكمة الدرجة الثانية رأساً دون أن يكون قد سبق عرض النزاع على محكمة الدرجة الأولى، ومثال ذلك طلب رد قضاة المحكمة الابتدائية الذي يعرض

(١) قانون المرافعات للدكتور محمد عبد الخالق عمر ص ٢٩٤ .

(٢) الدكتور / محمد حامد فهي في المرافعات المدنية والتجارية ف ٤١ .

على محكمة الاستئناف^(١)، وكذلك الأجور والفوائد والمرتببات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، يجوز إضافتها للطلب الأصلي أمام محكمة الدرجة الثانية أثناء نظر الاستئناف، وبذلك تكون هذه الطلبات قد اقتصر نظرها على محكمة الدرجة الثانية.

قصر التقاضي على درجتين:

إذا كان التقاضي على درجتين له مزايا متعددة توجب الأخذ به، إلا أنه ينبغي أن يقتصر التقاضي على هاتين الدرجتين، فلا يستأنف حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة أعلى، فلو أطلق حق الطعن في الأحكام، لأدى ذلك إلى تأييد الخصومات وتخليدها، واستنفاد أموال المتقاضين في مصاريف التقاضي، وزعزعة المراكز القانونية وعدم استقرارها.

وقصر التقاضي على درجتين لا يتنافى مع جواز الطعن بالتماس إعادة النظر والطعن بالنقض، وذلك لأن التماس إعادة النظر يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ولأن الطعن بالنقض لا يطرح موضوع النزاع أمام محكمة النقض، ثم إن الطعن بهذين الطريقتين لا يجوز إلا لأسباب معينة، وفي حالات محددة ولذلك وصفا بأنهما من طرق الطعن غير العادية^(٢).

التقاضي على درجتين في النظام القضائي الإسلامي:

يجوز في الفقه الإسلامي عرض الحكم الصادر من القاضي حتى ولو كان عادلاً عالماً على قاض آخر^(٣)، سواء كان هذا العرض بقصد تنفيذ الحكم الصادر من القاضي الأول^(٤)، أو

(١) قوانين المرافعات للدكتورة أمين النمر ف ٢٨ .

(٢) قد يقال أن احتمال الخطأ الذي جعل التقاضي على درجتين لتداركه، لا يزال قائماً بعد نظر النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية؛ لأن قضاة الدرجة الثانية قد يخطئون أيضاً، فمن العدل المطلق تمكين الخصوم من الطعن مرة ثانية، بل وإطلاقه. والأفضل أن يقف التقاضي عند هذا الحد، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قد توافر لها من الضمانات ما يجعل وقوعها في الخطأ قليل الاحتمال، وعلى كل حال فاحتمال وقوع الخطأ في بعض القضايا أقل ضرراً على حسن سير القضاء من فتح باب الطعن في الأحكام إلى ما لا نهاية. انظر: المرافعات المدنية والتجارية للدكتور / محمد حامد فهد، ف: ٣٩، مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور عبد الباسط جميعي ص ١٨٦.

(٣) وهذا الذي ذكرناه في المتن بالرغم من أن هناك عبارات للفقهاء قد يفهم من إطلاقها عدم جواز عرض الحكم الصادر من القاضي على قاض آخر، من هذه العبارات قولهم " لا يجوز للقاضي أن ينظر في أقضية غيره " معين الحكام للطرابلسي، ص ٣٠، " ليس على الحاكم تتبع قضايا من كان قبله " ابن قدامة في المغني ١٠ / ٥٢، " حكم القاضي العدل لا يتعقب " الدردير في الشرح الكبير ٤ / ١٥٣، " على القاضي ألا يتعرض لقضية أمضاها الأول إلا على وجه التحرير لها إن عرض فيها عارض بوجه خصومة، فأما على وجه الكشف لها والتعقيب عليها فلا، وإن سأله الخصم ذلك " الطرابلسي في معين الحكام ص ٣٠، ومع هذا فالعبارات المذكورة لا تمنع من عرض أحكام

لظهور جوره وحيفه في أحكامه كلها أو بعضها، أو لأن هذا القاضي لا يصلح للقضاء^(١)، أو لأن أحد الخصوم لم يقتنع بالحكم.

وإذا أعيد عرض الموضوع مرة ثانية أمام قاض آخر، فإن كان الحكم الأول صحيحاً وفقاً لما تقتضيه النصوص والإجماع، فيجب على القاضي الثاني تأييده وتنفيذه، بل يجب ذلك على جميع من يعرض عليه هذا الحكم بعد ذلك^(٢).

وإن كان الحكم مخالفاً نبحت في المخالفة، فإن كان مخالفاً لنص في الكتاب أو السنة، أو مخالفاً للإجماع أو للقياس الجلي (وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع بالأصل) فيجب نقض الحكم، ولا يصح تنفيذه، لأنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه^(٣).

وأما إذا كان حكم القاضي الأول مخالفاً لاجتهاد مجتهد فلا ينقض القاضي الثاني حكم الأول، حتى ولو كان القاضي الثاني لا يرى ما ذهب إليه القاضي الأول، لأن الأول حكم باجتهاده، والثاني سيحكم باجتهاده، واجتهاد الثاني كاجتهاد الأول، في أن كلا منهما يحتمل الخطأ، وقد ترجع الأول باتصال القضاء به، فلا ينقض بما هو دونه درجة، وهو ما لم يتصل القضاء به^(٤).

وكذلك ينقض الحكم إذا كان مخالفاً للقواعد الشرعية في نظر الدعوى، كما لو صدر الحكم من قاض عرف بالجور أو الحكم بالهوى، أو لا يصلح للقضاء، لعدم توفر شروط تولي القضاء فيه، أو صدر الحكم في غير ما يختص به^(٥).

القضاة حتى ولو كانوا معروفين بالعدل على قضاة آخرين، فهي تمنع القضاة اللاحقين من العرض لأحكام القضاة السابقين من تلقاء أنفسهم، ولكن يجوز عرض أحكام هؤلاء القضاة من الخصوم على قضاة آخرين، وذلك إذا وقع نزاع حول هذه الأحكام، أو تبين وجه فسادها (انظر الشرح الكبير للدردير ٤ / ١٥٣، الفواكه البدرية لابن الغرس ص ١٥٥، معين الحكام للطرابلسي ص ٣٠).

(١) الفواكه البدرية لابن الغرس ص ٢٣.

(٢) المغني لابن قدامة ١٠ / ٥٣.

(٣) المغني لابن قدامة ١٠ / ٥٠، الهداية ضمن شرح فتح القدير ٧ / ٢٠٠.

(٤) شرح المحلى على منهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة ٣٠٤ / ٤ الشرح الكبير للدردير ٤ / ١٥٣.

(٥) المغني لابن قدامة ١٠ / ٥١، شرح فتح القدير ٧ / ٣٠٤.

(٦) المغني لابن قدامة ١٠ / ٥٣، الشرح الكبير للدردير ٤ / ١٥٢، وانظر تفصيل الموضوع في التنظيم القضائي الإسلامي د / حامد أبو طالب ص ٦١ - ٦٧.

الفصل الثاني

ولاية القضاء ودرجات المحاكم وتشكيلها

المبحث الأول

المقصود بولاية القضاء والسلطة المختصة بها

ولاية القضاء هي سلطة الفصل في الخصومات، وهي مسندة أصلاً إلى الدولة، وهي وظيفة من وظائفها، وحق من حقوقها، ومظهر من مظاهر سيادتها، وسلطة من سلطاتها، تمارسها عن طريق ما تنشئه من هيئات تخولها سلطة الفصل في الخصومات، بعد أن ألغت نظام القضاء الخاص، ولذلك لا يملك فرد من الأفراد أو هيئة من الهيئات أن تباشر ولاية القضاء؛ إلا إذا منحتها الدولة جزء من ولاية القضاء.

وتمارس الدولة هذه الولاية عن طريق السلطة القضائية، والتي اختصتها الدولة بهذه الولاية دون غيرها من سلطات التشريع والإدارة.

التفرقة بين الاختصاص والولاية القضائية:

الولاية أعم من الاختصاص، فالولاية تعنى سلطة الحكم المقررة بمقتضى القانون، والتي تمنح لكافة محاكم الدولة^(١). بينما الاختصاص القضائي معناه نصيب كل محكمة من هذه الولاية؛ نتيجة لتعدد المحاكم^(٢).

وتبدو أهمية هذه التفرقة في مجال العمل القضائي؛ فالقاضي صاحب الولاية القضائية المقررة بمقتضى القواعد الإجرائية له سلطة إصدار الأحكام في نطاق ولايته في الجهة القضائية التي يتبعها، فإذا جاوز حدود هذه الولاية بأن أصدر حكماً خارجاً عن حد اختصاصه - المحلى أو النوعى أو القيمي - ولكنه يدخل في نطاق ولايته القضائية؛ فإن حكمه هذا يصدق عليه أنه صادر من قاض ذى ولاية، ومن ثم يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضى أمام محاكم هذه الجهة^(٣)؛ بيد أن هذا الحكم يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص^(٤)، ويوصف بكونه غير صحيح، ومن ثم فيكون محلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف المقرر قانوناً، وفي الوقت المحدد لرفع الطعن، فإذا لم يطعن عليه خلال تلك المدة المحددة صار الحكم نهائياً وصحيحاً^(٥).

(١) اختصاص المحاكم الدولي والولائي د/احمد مليجي. بند ١ ص ٣ ط/دار النهضة.

(٢) أصول وقواعد المرافعات. د/ أحمد ماهر زغلول. بند ٢٦٦ ص ٥٤١.

(٣) الوجيز. د/عبد المنعم الشرقاوي. بند ١٨٦ ص ٢٥٢.

(٤) النظرية العامة للعمل القضائي. د/وجدى راغب ص ٦٠٠.

(٥) نظرية الاختصاص. د/عبد الباسط جميعي. ص ٩، ص ١١. أصول علم القضاء. د/عبد الرحمن عباد. ص ٢٤٦.

بينما إذا صدر الحكم من قاض ليست له ولاية قضائية، فالحكم في هذه الحالة يكون منعماً لا وجود له في الواقع، ومن ثم فلا يتمتع بأية قيمة قانونية^(١)، كما لو أصدر القاضي حكماً في عمل من أعمال السيادة^(٢)، فهذا الحكم معدوم الوجود والأثر؛ لصدوره عن قاض لا ولاية له على هذه الأعمال.

ثالثاً: توزيع ولاية القضاء في الدولة:

الولاية القضائية في النظام القضائي المصري موزعة على جهتين كبيرتين^(٣) هما:

- ١- جهة القضاء العادي: وتمثلها المحاكم، وهذه الجهة هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات، إلا ما أخرجه المقتن عن ولايتها بنص خاص^(٤).
- ٢- جهة القضاء الإداري: وتمثلها محاكم مجلس الدولة. وهي الجهة ذات الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإدارية دون غيرها من المنازعات الأخرى^(٥).

وفي الدستور المصري الحالي، الصادر في ٢٠١٤م، زاد المشرع الدستوري علي هاتين الجهتين جهتين أخريتين؛ هما: جهة القضاء الدستوري، حيث جعل المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها، وجهة القضاء العسكري، حيث جعل القضاء العسكري أيضاً جهة قضائية مستقلة، هذا فضلاً عن الجهات القضائية المخصصة التي سبق وأن خصها المقتن-نظراً لمواجهة ظروف معينة- بنوع من الولاية القضائية المحدودة، بحيث تتولى هذه الجهات الفصل في قضايا محددة على سبيل الحصر، ولا يتعدى نظرها إلى ما عداها، وهذه الجهات المخصصة ليست جهات قضائية بالمعنى الفني الدقيق، وإنما هي أشبه بالكيانات القانونية المخصصة لمواجهة ظروف معينة ومنازعات محددة، وإطلاق اسم الجهة عليها إنما هو من قبيل الاستعمال المجازي دون الحقيقي، ويطلق على هذه الجهات: القضاء الاستثنائي أو جهات التقاضي ذات الولاية المحدودة.

ونتناول الحديث عن جهات القضاء الأصلية في النظام القضائي المصري وجهات القضاء الأخرى ذات الولاية المحدودة والاستثنائية، ثم حدود ولاية قضاء الدولة، وذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل.

(١) الوجيز. د / عبد الفتاح السيد بك . بند ٨٤٥ ص ٧٣٦ .

(٢) أصول المرافعات . د/ أحمد مسلم . بند ١٦٧ . ص ١٧٣ .

(٣) راجع : الدستور المصري الحالي، الصادر في ٢٠١٤م.

(٤) نظرية الاختصاص د/عبد الباسط جمعي ص ٦ .

(٥) قانون القضاء المدني د / محمود هاشم. بند ٨٩. ص ١٦٣ .

المبحث الثاني

جهات القضاء

المطلب الأول

القضاء العادى والولاية العامة

القضاء العادى هو الجهة القضائية التى تتمتع بالولاية العامة على كافة المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ولا يخرج عن ولايتها؛ إلا ما استثناه المقتن بنص خاص، كما هو الشأن فى إخراج المنازعات الإدارية عن ولاية المحاكم العادية^(١)، وقد نص المقتن على ذلك فى المادة (١٥) من قانون السلطة القضائية، والتى جاء فيها أن المحاكم تختص بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص^(٢).

ولما كانت المنازعات التى ينعقد الاختصاص فيها لجهة القضاء العادى تتنوع وتختلف من حيث القيمة والأهمية، تدخل المقتن فعند إلى تقسيم القضاء العادى إلى طبقات من المحاكم، وقام بتوزيع الولاية القضائية على هذه الطبقات المتعددة على أساس نوع الدعوى أو قيمتها، محدداً بذلك نصيب كل طبقة من هذه الطبقات، فيقال مثلاً أن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم الجزئية، وتلك من اختصاص المحاكم الابتدائية، وهو ما عرف فى النظام القضائى بالاختصاص النوعى أو القيمى^(٣).

ونظراً لانتشار المحاكم فى كافة أنحاء الجمهورية فقد رسم المقتن لكل محكمة دائرة اختصاص إقليمى، وجعل محكمة الإقليم تختص محلياً بما يثار فى دائرتها من منازعات وهذا ما عرف بالاختصاص المحلى^(٤).

إذا فالمحاكم الجزئية المنتشرة فى كل مركز من مراكز الجمهورية تختص إقليمياً بنظر المنازعات التى تقع فى دائرة اختصاصها الإقليمى؛ ما لم ينص القانون على غير ذلك، مع مراعاة قواعد الاختصاص النوعى والقيمى، وفقاً لما سيأتى بيانه.

هذا، ويضاف إلى طبقات المحاكم المدنية - الجزئية والابتدائية - محاكم الاستئناف التى ينعقد لها الاختصاص بكافة الطعون عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية؛ وذلك باعتبارها محكمة أول درجة^(٥).

(١) أصول وقواعد المرافعات. د / أحمد ماهر زغلول بند ٢٦٦. ص ٥٤١.

(٢) قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ م.

(٣) الوسيط. د / أحمد السيد صاوي. بند ١٨٠. ص ٢٥٩.

(٤) الوسيط. د / أحمد السيد صاوي. بند ١٨٠. ص ٢٥٩.

هذا، فضلاً عن وجود محكمة النقض بمقر العاصمة. القاهرة. وهي ليست درجة من درجات التقاضي وإنما ينعقد لها الاختصاص بالإشراف على تطبيق صحيح القانون، كما ينعقد لها الاختصاص بنظر الطعون في الأحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في الحالات التي ينص عليها القانون م٢٤٨ مرافعات.

وبهذا يتضح أن القضاء العادي، ممثلاً في طبقاته المختلفة هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى من ذلك بنص صريح .

المطلب الثاني

جهة القضاء الإداري (محاكم مجلس الدولة)

"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"^(١).

وعلي هذا: يمكن القول بأن اختلاف طبيعة المنازعات الإدارية يعد الأصل القانوني الذي استند إليه المشرع في منح القضاء الإداري وتمثله محاكم مجلس الدولة بطبقاتها المختلفة، الولاية القضائية لنظر كافة المنازعات الإدارية.

وبناءً على هذا: عمد المقتن بما له من سلطة مستمدة من الدستور إلى عقد اختصاص القضائي بنظر المنازعات الإدارية للقضاء الإداري^(٢)، وقد نص على ذلك في المادة رقم ١٥ من قانون السلطة القضائية.

وفضلاً عما ورد النص عليه في المادة (١٩٠) من الدستور المصري؛ فإن محاكم مجلس الدولة وفقاً لنص المادة (١٠) من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م، تختص دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولاً: الطعون الانتخابية. ثانياً: منازعات مرتبات ومعاشات ومكافآت الموظفين.

ثالثاً: الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو بمنع العلاوات.

(١) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٢٧٥ . ص ٣١٧ .

(٢) المادة ١٩٠ من الدستور المصري الحالي، الصادر في ٢٠١٤م.

(٣) الوسيط. د/أحمد السيد صاوي. بند ١٨٠ . ص ٢٥٩ .

رابعاً: طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي.

خامساً: طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية.

سادساً: طعون منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون.

سابعاً: دعاوى الجنسية.

ثامناً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات الاختصاص القضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

تاسعاً: طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية.

حادى عشر منازعات عقود الالتزام، والأشغال العامة أو التوريدات أو أى عقد إدارى آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .

ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين في القطاع العام في الحدود المقررة

قانوناً. رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

وتعد محاكم مجلس الدولة وفقاً لهذا الاختصاص: صاحبة الولاية العامة، بالفصل في

كافة المنازعات الإدارية.

المطلب الثالث

جهات القضاء ذات الولاية المحدودة

رأى المقنن في بعض الحالات، ضرورة إسناد الاختصاص القضائي في نظر منازعات معينة إلى جهة قضائية خاصة، وذلك لما لهذه المنازعات من طبيعة خاصة، أو لتعلقها بفئة معينة من الأشخاص، بحيث تكون لهذه الجهات ولاية قضائية جزئية، تستقل بموجبها بنظر تلك المنازعات دون غيرها من جهات القضاء الأخرى، وتباشر الدعوى أمامها وفقاً لقواعد إجرائية تختلف عن تلك المتبعة أمام القضاء العادي؛ ومن ثم تكون لأحكامها طبيعة خاصة مختلفة عن أحكام القضاء العادي. ومن هذه الجهات:

١- جهة القضاء الدستوري:

فالمحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة بذاتها، حيث نصت عليه المادة (١٩١) من الدستور الحالي علي أن: "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة

الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة".

وحددت المادة (١٩٢) اختصاصات هذه المحكمة بنصها على أنه: "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.

٢- جهة القضاء العسكري :

"القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"(١).

٣- محاكم أمن الدولة :

وهي المحاكم التي تحمي مصالح خاصة ذات وصف محدد، وتتعلق بفئة معينة من الأشخاص(٢). وينظم هذه المحاكم القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ م، ومن ثم يحدد اختصاصها،

(١) المادة ٢٠٤ من الدستور المصري الحالي.

(٢) قانون القضاء المدني د / فتحي والي . بند ١٦٧ ص ٣٩٤ د / عزمي عبد الفتاح . ص ٣٢٥.

وكيفية تشكيلها ، والإجراءات التي تتبع أمامها^(١) ، هذا وتنقسم الأحكام التي تصدر عن محاكم أمن الدولة العليا بأنها أحكام نهائية لا تقبل الطعن إلا بطريق النقض وإعادة النظر^(٢) ، أما الأحكام التي تصدر عن محاكم أمن الدولة الجزئية^(٣) فهي تقبل الطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة، والتي يطعن في أحكامها بالنقض وإعادة النظر^(٤).

٤- الهيئات واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي:

تتعدد الهيئات واللجان الإدارية التي منحها المقتن الولاية القضائية المحدودة بمنازعات معينة، تختص بالفصل فيها دون غيرها من الجهات القضائية الأخرى، وذلك وطبقاً للقواعد الدستورية والقانونية المعتبرة في هذا الشأن^(٥).

وذلك نظراً لطبيعة هذه المنازعات، وما يستلزمه الفصل فيها من توافر خبرات فنية، قد لا تتوافر في قضاة الجهات القضائية الأصلية^(٦)، فضلاً عن الحاجة إلى سرعة الفصل في هذه المنازعات، على نحو تتحقق بمقتضاه المرونة الحقة في العمل القضائي، وتُبَسَّط معه الإجراءات، وتقل فيه النفقات^(٧).

ومن أمثلة هذه الهيئات واللجان : هيئات التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين شركات القطاع العام أو بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام، ولجان فض المنازعات، ولجان الفصل في المنازعات الزراعية، ولجان شئون الضباط ، واللجنة المختصة بتقدير أتعاب المحامي، وغير ذلك من اللجان الأخرى، التي ينشئها المقتن، ويمنحها سلطة الحكم القضائي بقواعد وشروط مخصصة.

(١) وقد صدر هذا القانون في ٢٠ مايو سنة ١٩٨٠م ، ونشر بالجريدة الرسمية في العدد "٢٢" ، مكرر في ٣١ مايو ١٩٨٠.

(٢) قانون القضاء المدني . د / محمود هاشم . بند ١١٧ . ص ٢٠٥ .

(٣) حيث تنشأ في مقرر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر.

(٤) قانون القضاء المدني . د / محمود هاشم . بند ١١٧ . ص ٢٠٥ .

(٥) الدفع بعدم الاختصاص أ/علي حسن عوض. ص ٢٤ .

(٦) تحديد نطاق الولاية القضائية . د/أحمد مليجي . ص ٥١٤ .

(٧) قانون القضاء المدني. د / عزمي عبد الفتاح ص ٣٢٥ .

المطلب الرابع

حدود ولاية قضاء الدولة

خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء في القانون:

يخرج عن ولاية القضاء بجميع جهاته التي سبق الحديث عنها، نوعاً من الأعمال، لا يخضع بحكم القانون لرقابة القضاء، وهي تلك التي تعرف بـ "أعمال السيادة".

ولم يضع المقنن تعريفاً محدداً لأعمال السيادة؛ لذا يجتهد الفقه والقضاء في بيان المقصود منها، وقد جاء عنهما أن المقصود بأعمال السيادة، ومن ذلك تعريفها بأنها: تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها المهيمنة على مصالح الدولة العليا، وتتصل بالسيادة العليا للدولة^(١). أو هي الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية . الحكومة . باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة^(٢).

هذا ويعد من الأعمال التي ينطبق عليها الوصف بأنها أعمال سيادية الأعمال التالية: ما تقوم به السلطة التنفيذية من إبرام المعاهدات، وإعلان الحرب، وإبعاد بعض الأجانب عن إقليم الدولة. لسبب قام لديها يقتضى ذلك، ودعوة المجلس للانعقاد أو فض دورته البرلمانية، والعفو الشامل^(٣).

هذا فضلاً عما قرره المقنن أيضاً انتفاء ولاية القضاء المصري عن الدعاوى المقامة ضد الدول الأجنبية، أو رؤسائها، أو ممثليها، أو الهيئات والمنظمات الدولية وممثليها السياسيين ممن يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية^(٤).

عدم اختصاص القضاء المصري ولائياً بنظر أعمال السيادة:

عمد المقنن إلى إخراج أعمال السيادة عن ولاية القضاء بجهاته المختلفة، وقد نص على ذلك صراحة في قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢م، حيث نصت المادة (١٧) من هذا القانون على أنه: "ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة"^(٥). كما نص أيضاً على هذا المنع في قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م، حيث نصت المادة

(١) أعمال السيادة في القانون المصري المقارن . د / حافظ هريدي . بند ١٣٣ . ص ٩٥.

(٢) نظرية أعمال السيادة . د / عبد الفتاح ساير.

(٣) المرافعات. د/أحمد أبو الوفا. بند ٢٣٢ . ص ٢٦٦ .

(٤) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا بند ٢٣٥ . ص ٢٦٧ .

(٥) المادة " ١٧ " من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢م .

(١١) منه على أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في المسائل المتعلقة بأعمال السيادة"^(١).

وبناء على هذه النصوص أخرج المقتن أعمال السيادة من رقابة القضاء عموماً، فلا يجوز للمحاكم المدنية أو الإدارية أن تنظر عملاً سيادياً بعد تحقق وصفه، وإلا عد هذا خروجاً عن حدود اختصاصها الولائي، ومن ثم لا تحوز أحكامها التي تصدر بشأن الأعمال السيادية أية حجية قانونية، لانعدام ولايتها القضائية^(٢).

بل يتعين عليها قانوناً إذا رفعت إليها دعوى تتعلق بعمل من الأعمال السيادية أن تقضى فيها بعدم الاختصاص، ولا تأمر بالإحالة على أى من الجهات القضائية الأخرى، حيث إن أعمال السيادة لا تخضع لرقابة أية جهة قضائية أياً كان نوعها، ومن ثم فلا مجال لأمر الإحالة عند القضاء بعدم الاختصاص بنظر الأعمال السيادية.

وبناءً على ما تقدم:

لا تملك أية محكمة. أياً كانت درجتها. أن تنظر في دعوى تتعلق بطلب إلغاء عمل سيادي، أو أمر يتوافر فيه هذا الوصف، أو دعوى بطلب إيقاف تنفيذه أو تعويض الضرر الناشئ عنه، وذلك لانعدام ولاية المحاكم عموماً في نظر تلك الأعمال^(٣)؛ فإذا التزمت هذه المحاكم بنص القانون قضت في الدعاوى المتعلقة بالأعمال السيادية بعدم الاختصاص، وهذا القضاء لا يتوقف على طلب صاحب المصلحة بل تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يطلب منها ذلك؛ لتعلقه بالنظام العام^(٤). ومن ثم فيجوز التمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، ولا يسقط الحق في إبداء الدفع بالزول عنه، أو التصالح عليه^(٥).

هذا ويلاحظ أن المقتن عندما نص على منع جهات القضاء المختلفة من نظر الأعمال السيادية لم يرد حرمان القضاء مطلقاً من البحث في هذه الأعمال، وإنما جعل هذا المنع مقصوراً على ذات العمل السيادي بعد تحقق وصفه. أما البحث في أعمال السيادة لمعرفة ما إذا كان العمل المعروض على القضاء عملاً سيادياً أم لا ينطبق عليه هذا الوصف، فهذا مما أخضعه المقتن لرقابة القضاء^(٦).

(١) المادة رقم " ١١ " من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ م .

(٢) المرافعات. د/أحمد أبو الوفا. بند ٢٣٢

(٣) نظرية الاختصاص. د/عبد الباسط جميعي. ص ١١٩، الوسيط. د/عاشور مبروك. بند ٢٣٣ ص ٢٦٤ .

(٤) المرافعات. د / محمد حامد فهبي. بند ٢٩٥. ص ٣٢١، ٣٢٢ .

(٥) الوسيط. د / أحمد السيد صاوي. بند ١٨١. ص ٢٦٢ .

(٦) نظرية الاختصاص. د/عبد الباسط جميعي. ص ١١٩. الوسيط. د / أحمد السيد صاوي. بند ١٨١. ص ١٦٢ .

المبحث الثاني

درجات المحاكم (طبقاتها) وتشكيلها

تأخذ مصر بمبدأ التقاضي على درجتين؛ كقاعدة؛ ولذلك توجد فيها طبقتان من المحاكم: محاكم الدرجة الأولى أو الابتدائية، ومحاكم الدرجة الثانية أو الاستئنافية، ولكل طبقة منهما محاكمها، وفوق هاتين الطبقتين توجد محكمة النقض.

أولاً: محاكم الدرجة الأولى:

محاكم الدرجة الأولى هي المحاكم التي ترفع إليها الدعاوى لأول مرة، ونظراً لاختلاف الدعاوى بحسب الصعوبة والأهمية، فقد رأى المقنن أن يحدد محاكم من محاكم الدرجة الأولى هي المحاكم الجزئية، تشكل تشكيلاً يتناسب والدعاوى البسيطة السهلة، وقرر أن تكون هذه المحاكم قريبة من الخصوم، أما الدعاوى المعقدة وذات القيمة الكبيرة، فقد حدد لها المقنن محاكم أخرى من محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم الابتدائية (الكلية) وتشكل هذه المحاكم تشكيلاً يتناسب وأهمية الدعاوى التي تنظرها، وعلى ذلك تتنوع محاكم الدرجة الأولى إلى نوعين هما: المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية (الكلية).

١- المحاكم الجزئية: هي أدنى طبقات المحاكم في النظام القضائي المصري، وهي منتشرة في جميع أنحاء البلاد، حيث توجد - كقاعدة - محكمة جزئية في كل مركز أو بندر أو قسم، وذلك حتى تكون قريبة من مكان النزاع، ومحل إقامة الخصوم. وتمارس المحكمة الجزئية نشاطها داخل دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية المكاني، ويكون إنشاءها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل^(١).

وتنعقد المحكمة الجزئية في مقرها المحدد في قرار إنشائها من وزير العدل، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة^(٢).

ويجيز القانون لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، محاكم جزئية ويخصصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقرر كل محكمة ودائرة اختصاصها^(٣).

(١) المادة ١١ / ١ من قانون السلطة القضائية .

(٢) المادة ١١ / ٢ من قانون السلطة القضائية .

(٣) المادة ١٣ من قانون السلطة القضائية .

وقد أصدر الوزير قراراتين بإنشاء محكمتين جزئيتين تجاريتين في القاهرة والإسكندرية، كما أصدر عدة قرارات بإنشاء محاكم لشئون العمال في القاهرة والإسكندرية، وبعض المدن الأخرى، وهذه المحاكم المتخصصة لها اختصاص نوعي محدد بنوع معين من الدعاوى، ولا يجوز لها نظر غير هذا النوع من الدعاوى ويجوز الدفع أمامها بعدم الاختصاص النوعي، إذا كانت الدعوى المرفوعة أمامها من غير هذا النوع، ذلك أن هذا ليس مجرد تقسيم للعمل مما يدخل في التنظيم الإداري، كما هو الأمر بالنسبة للدوائر المختصة لنظر نوع معين من الدعاوى^(١).

وتشكل المحكمة الجزئية من قاض واحد، نظراً لكثرة الدعاوى التي ينظرها مع بساطتها وضآلة قيمتها، والأخذ بنظام القاضي الفرد هنا يتناسب وظروف مصر وجهازها القضائي، وما يعانيه من عجز في الأعضاء والوسائل والإمكانات، مع وجود كم هائل من القضايا يتزايد ويتضاعف ويتكاثر.

وكذلك تتشكل محكمة الأمور المستعجلة من قاض فرد لأن الدعاوى المستعجلة في حاجة إلى إجراءات سريعة ومختصرة، وكذلك تتشكل محكمة التنفيذ من قاض فرد؛ لأن طبيعة عمل هذه المحكمة وهو الإشراف على عمل التنفيذ، يتطلب أن يكون المشرف شخصاً واحداً، حتى يكون الإشراف أكثر فاعلية^(٢).

٢ - المحاكم الابتدائية:

هي المحاكم التي تنظر الدعاوى ذات القيمة الكبيرة، والدعاوى المعقدة لأول مرة، أي: بصفة مبتدأة، ومن هنا يطلق عليها عملاً اسم المحاكم الكلية على اعتبار أنها المحاكم صاحبة الاختصاص الكلي الشامل أصلاً^(٣).

ويكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية^(٤)، كقاعدة ، ويجوز إنشاء محاكم ابتدائية أخرى ، وتعين دائرة اختصاصها المحلي ، وتعديل هذا الاختصاص بقانون^(٥)، ولذلك فقد توجد في المحافظة الواحدة أكثر من محكمة كلية، كما هو الحال في محافظة القاهرة، حيث قسمت محكمتها الابتدائية إلى محكمتين، إحداها سميت بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والثانية محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

(١) قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ص ١٣٦ ، مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور / عبد الباسط جمعي ص ٢٠١ ، قانون القضاء المدني للدكتور / محمود هاشم ف ٩٣ .

(٢) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ، ف ١٣٠ .

(٣) أستاذنا الدكتور / عبد الباسط جمعي في مبادئ المرافعات ص ١٩٨ .

(٤) المادة ٩ / ١ من قانون السلطة القضائية .

(٥) المادة ١٠ من قانون السلطة القضائية .

ومع هذا "يجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة".

تشكيل المحاكم الابتدائية:

أخذ المقتن المصري في تشكيل المحاكم الابتدائية بمبدأ (تعدد القضاة) فتشكل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة، هم رئيس الدائرة وعضوان، وقد راعى المقتن أن المحكمة الابتدائية تنظر الدعاوى كبيرة القيمة، والتي تحتاج إلى خبرة قضائية عميقة؛ نظراً لأهميتها أو لصعوبتها.

ثانياً: محاكم الدرجة الثانية:

ترتيباً على جعل التقاضي على درجتين، فقد جعل المقتن محاكم تستأنف إليها الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بمعنى أن محاكم هذه الدرجة لا ترفع أمامها دعاوى مبتدأة - كقاعدة - وتختلف هذه المحاكم بحسب نوع الحكم المستأنف، فالحكم الصادر من المحكمة الجزئية ويقبل الاستئناف، ينظر أمام المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة من محاكم الدرجة الثانية، أما الحكم الصادر من محكمة ابتدائية ويقبل الاستئناف فإنه ينظر أمام محكمة الاستئناف، ولذلك فمحاكم الدرجة الثانية هي المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

أ- المحاكم الابتدائية (الكلية):

للمحاكم الابتدائية في نظامنا القضائي وضعان؛ أولهما: اعتبارها من محاكم الدرجة الأولى، حيث ترفع إليها الدعاوى المبتدأة، وهو الوضع الذي ذكرناه حالاً، أما الوضع الثاني للمحاكم الابتدائية: فهو اعتبارها من محاكم الدرجة الثانية، حيث ترفع إليها الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية، ذلك أن المقتن تبعاً لتقديره السابق في بساطة الدعاوى الجزئية، قرر أن يكون استئنافها إلى المحكمة الابتدائية.

تشكيل المحاكم الابتدائية ببيئة استئنافية:

لا يختلف تشكيل المحاكم الابتدائية باعتبارها محكمة درجة ثانية عن تشكيلها باعتبارها محكمة درجة أولى، فهي تشكل من ثلاثة قضاة هم: رئيس الدائرة وعضوان؛ نظراً لأن الدعاوى المستأنفة في حاجة إلى الأناة والتروي، وتشكيل المحكمة من ثلاثة أدعى إلى تحقيق ذلك.

ب- محاكم الاستئناف:

وهي محاكم تختص بنظر الطعون المرفوعة في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، باعتبارها محكمة أول درجة، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة ثاني درجة، فلا تستأنف؛ لأن التقاضي يقف عند درجتين.

وتسمى محكمة الاستئناف هذه- في العمل- محاكم الاستئناف العليا تمييزاً لها عن المحاكم الابتدائية باعتبارها محكمة استئنافية.

ويكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا ، ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف^(١). ويجوز إنشاء محاكم استئناف أخرى، وتعيين دائرة اختصاصها المحلي وتعديل هذا الاختصاص بقانون^(٢).

ونظراً لأن بعض محاكم الاستئناف يشمل اختصاصها المكاني أكثر من محافظة، فقد أجاز المقتن تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الاستئنافية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف^(٣).

تشكيل محكمة الاستئناف:

تشكل محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة^(٤)، يطلق عليهم نظراً لسمو مركزهم لفظ (مستشارين)^(٥). وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين.

وتشتمل كل محكمة من محاكم الاستئناف على عدد كاف من الدوائر، يرأس كلاً منها رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد المستشارين، وتقسيم المحكمة إلى دوائر، وتوزيع العمل بها هو مسئولية الجمعية العمومية للمحكمة، وهو عمل إداري لا يترتب عليه أي اختصاص نوعي^(٦).

محكمة النقض

تأتي محكمة النقض على رأس القضاء العادي، وهي أعلى من محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الدرجة الثانية، ولكنها لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي؛ لأن الطعن أمامها لا يجوز لخطأ متعلق بالوقائع، وإذا هي نقضت حكماً لخطئه في القانون، فالأصل أن تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم^(١)، وإذا حكمت

(١) المادة ٣ من قانون السلطة القضائية .

(٢) المادة ١٠ من قانون السلطة القضائية .

(٣) المادة ٦ / ٤ من قانون السلطة القضائية .

(٤) المادة ٢/٦ من قانون السلطة القضائية .

(٥) الدكتور/ أحمد مسلم في أصول المرافعات ف ١١٢ .

(٦) الدكتور/ محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ص ١٤٠ .

(١) المادة ٢٦٩ / ٢ مرافعات.

المحكمة في الموضوع- في الحالات التي يجوز فيها ذلك- فلا يعدو عملها مجرد تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه، أما تقدير ثبوت الوقائع فلا رقابة عليه لمحكمة النقض^(١). ووظيفة هذه المحكمة الإشراف على صحة تطبيق القانون أمام المحاكم، وسلامة تفسيره وتأويله، وتعمل على توحيد أحكام القضاء. والهوض بهذه المهمة - توحيد تفسير القانون وتطبيقه- يستدعي أن تكون القائمة بهذه المهمة محكمة واحدة، حتى لا تتعدد الاتجاهات، ومن ثم كانت محكمة النقض محكمة واحدة، مقرها مدينة القاهرة^(٢)، وقد أنشئت هذه المحكمة في عام ١٩٣١ م.

تشكيل محكمة النقض:

تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين، وتحتوي هذه المحكمة على نوعين من التشكيلات القضائية هي الدوائر، وهيئتان عامتان:

أ- تشكيل الدوائر:

توجد بمحكمة النقض دوائر لنظر المواد الجنائية، ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية ودوائر الأحوال الشخصية ودوائر للمواد الاقتصادية "القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الأخرى. وتشكل كل دائرة من خمسة مستشارين، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها^(٣).

وترتيب وتأليف الدوائر، وتوزيع القضايا على الدوائر المختصة تختص به الجمعية العامة لمحكمة النقض^(٤).

ب- تشكيل الهيئتين :

وفقاً لنص المادة (٤) من قانون السلطة القضائية، تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة، إحداهما للمواد الجنائية، والثانية للمواد المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية وغيرها. وتشكل كل هيئة من الهيئتين من أحد عشر مستشاراً، برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه، وتختص بالنظر في العدول عن مبدأ قانوني قرره أحكام سابقة صادرة من

(١) أستاذنا الدكتور/ عبد الباسط جمعي في مبادئ المرافعات ص ١٩٦ ، الدكتور / محمد حامد فهي في المرافعات المدنية والتجارية ف ١٤٨ .

(٢) المادة ٢ من قانون السلطة القضائية ، ولم يشر القانون إلى جواز عقدها خارج هذا المقر. الدكتور / عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ص ١٤٠ .

(٣) المادة (٣) من قانون السلطة القضائية .

(٤) الفقرتان أ، ب من المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية .

الدوائر التابعة لذات الهيئة ، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خاصة هي أغلبية سبعة أعضاء على الأقل^(١).

وأما إذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قرره أحكام سابقة، صادرة من دوائر تابعة لهيئة أخرى، كأن ترى دائرة مدنية العدول عن مبدأ قرره الدوائر الجنائية، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، كهيئة واحدة تشكل من اثنين وعشرين مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم نوابه، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل^(٢).

المحكمة الدستورية العليا:

أنشأ المقتن المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩م؛ لتحل محل المحكمة العليا، التي كانت قد أنشئت بالقانون ٨١ لسنة ١٩٦٩م . ولقد أصبحت المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة بذاتها، حيث نصت المادة " ١٩١ " من دستور ٢٠١٤م علي أن : "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة".

كما نصت المادة "١٩٢" من ذات الدستور علي اختصاصات هذه المحكمة بقولها : " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.

كما نصت المادة "١٩٥" من ذات الدستور أيضا علي إلزامية الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة بنصها: " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة

(١) المادة ٢/٤ من قانون السلطة القضائية .

(٢) المادة ٣/٤ من قانون السلطة القضائية، وانظر قانون المرافعات للدكتور/ محمد عبد الخالق عمر ص ١٤٠،

١٤١، الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور/ فتحي والي ف ١٣٠ .

الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار".
وعلي هذا: فإن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، فهي لا تتبع جهة القضاء العادي، كما أنها لا تتبع جهة القضاء الإداري، وإنما هي جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.

تشكيل المحكمة الدستورية العليا:

"تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون" (المادة ١٩٣ من الدستور).

درجات المحاكم في النظام القضائي الإسلامي:

تعدد درجات المحاكم في أي نظام قضائي أو عدم تعددها، يعتمد أساساً على مدى قابلية الأحكام للطعن في هذا النظام، فإن كانت الأحكام قابلة للطعن تتعدد درجات المحاكم، وأما إذا كانت الأحكام لا تقبل الطعن فلا وجود للتعدد.

وقد تحدثنا فيما سبق عن مدى قابلية الأحكام للطعن في الفقه الإسلامي، وحق الخصوم في عرض الحكم الصادر من قاض على قاض آخر.

وخلاصة القول أنه وإن كانت للأحكام حجية واجبة الاحترام من الجميع، ويفترض فيها الصحة، وأنها عنوان الحقيقة، إلا أنه يجوز عرض النزاع مرة ثانية على قاض آخر، لوقوع نزاع في الحكم، أو لظهور جور القاضي الذي أصدره وحيفه في أحكامه كلها أو بعضها، أو لأن القاضي لا يصلح للقضاء، أو لأن أحد الخصوم لم يقتنع بالحكم.

وعلى هذا يمكن القول بأن تعدد درجات المحاكم لا يصطدم وقواعد النظام القضائي الإسلامي، بل هو يساير هذا النظام، وذلك تأسيساً على أن لولي الأمر الحق في تخصيص القضاء، وتقييده وحقه في ذلك إنما هو ثابت بمقتضى الشرع^(١).

(١) المغني لابن قدامة ١ / ٩٢ ، شرح فتح القدير ٧ / ٢٥٦ ، حاشية ابن عابدين ٥ / ٤١٩ ، مجلة الأحكام الشرعية للقاري ص ٥٩٩ ، أدب القاضي للماوردي ١ / ١٢٣ ، القضاء في الإسلام رسالة الدكتور / محمود مفتاح ص ١٩٠ .

الفصل الثالث

العاملون بالقضاء

نتحدث في هذا الفصل عن الأشخاص الذين تناط بهم أعمال القضاء والقائم بأعمال القضاء أصلاً هم القضاة، وهناك أشخاص آخرون لا غنى للقضاء عن خدماتهم، فهم يؤدون خدمات للقضاء على قدر من الأهمية، وهؤلاء الأشخاص هم أعضاء النيابة، والكتاب، والمحضرون، والخبراء.

وفيما يلي نتحدث عن القضاة في المبحث الأول

ثم عن أعضاء النيابة العامة في المبحث الثاني

ثم عن أعوان القضاء في المبحث الثالث

المبحث الأول

القضاة

القضاة هم أهم العناصر البشرية التي تظهر في العملية القضائية، وهم مصابيح مضاءة تنير طريق الحق، وسوج متينة تحبس الظلم وتكبتة، وهم ملجأ الناس وملاذهم حين تُظلم الدنيا بالظلم، وكثير منهم قضى نحبه فداءً للحق وكتباً للظلم، ومنهم من تغلب عليه الظلم وقتله مظلوماً، فمن هم القضاة ؟

كلمة القضاة كلمة عامة تشمل كل من له ولاية القضاء في الدولة أياً كانت درجته الوظيفية . ونظراً لما لو وظيفة القضاء من أهمية، فإن الأنظمة القضائية المختلفة تجتهد في وضع القواعد التي تضمن دخول أفضل العناصر المؤهلة لتولي هذه الوظيفة، وتقرر لهم من الضمانات ما يجعلهم آمنين على حاضرهم ومستقبلهم، وما يضمن حسن سير القضاء، ولذلك سنتحدث عن اختيار القاضي وشروطه في مبحث أول، ثم عن ضمانات القاضي في مبحث ثان .

المطلب الأول

اختيار القاضي وشروطه

نتحدث عن اختيار القاضي في الفرع الأول، ثم نبين شروطه في الفرع الثاني

الفرع الأول

اختيار القاضي

يجتهد الفقهاء والمقننون في وضع القواعد التي تكفل وصول أفضل العناصر البشرية لتولي منصب القضاء، وعموماً يدور اجتهادهم حول الأخذ بأحد نظامين، هما : نظام انتخاب القاضي ونظام تعيين القاضي .

أولاً: نظام انتخاب القاضي:

يهدف هذا النظام إلى اختيار القاضي عن طريق الانتخاب، سواء كان انتخاباً عاماً . مباشراً أو غير مباشر - أو كان انتخاباً من هيئات معينة، وقيل في تأييد هذا النظام أنه يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ويؤكد مبدأ الفصل بين السلطات، ويعتبر الناخبين مصدر السلطات جميعاً، ومع ذلك فهو نظام منتقد، فهو يجعل القاضي في حاجة إلى جمهور المتقاضين لانتخابه، فيعمل على إرضائهم حتى يعيدوا انتخابه فيفقد بذلك استقلاله وأيضاً جمهور الناخبين، قد لا يختار الشخص الأكثر كفاءة وإنما يختار الشخص الأكثر شعبية أو قرابة أو مداراة لهم^(١).

ثانياً : نظام تعيين القاضي:

يهدف هذا النظام إلى اختيار القاضي بواسطة السلطة التنفيذية وتعيينه في منصب القضاء، ذلك أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة تنهض بها عن طريق السلطة القضائية، فيكون من الطبيعي أن تتولى الحكومة تعيين من يتولى الوظائف العامة، ومنها الوظيفة القضائية، ولا شك أن الدولة أقدر على حسن اختيار القضاة من الجمهور . ولا محل للخوف من قيام الحكومة بتعيين القضاة، وخضوعهم للحكومة التي عينتهم، وذلك لأن تعيين الحكومة للقضاة ليس مطلقاً، وإنما يخضع لتوافر شروط موضوعية حددها القانون إلى جانب النص على الضمانات التي تكفل استقلال القضاة، وتجعلهم في مأمن من سلطان الحكومة^(٢).

(١) الوسيط للدكتور/فتحي والي ف ٩٥، المرافعات المدنية والتجارية للدكتور/ محمد حامد فهي ف ٢٧

(٢) قانون القضاء المدني للدكتور/ محمود هاشم ف ١٢٢، الوسيط/ للدكتور فتحي والي ف ٩٦ .

وقد أخذ نظام القضاء المصري بنظام تعيين القضاة عن طريق السلطة التنفيذية، ولكن سلطتها في ذلك ليست مطلقة، وإنما تخضع لشروط موضوعية يجب توافرها فيمن عين قاضياً^(١).

ويجب على الحكومة أن تراعي تحقق الشروط فيمن تختارهم لمنصب القضاء وأن تبتعد عن المؤثرات السياسية قدر الإمكان. وأن تنأى بهذا المنصب عن اعتباره مكافأة عن خدمات سابقة، أو للانتماء للحزب الحاكم أو للعمل في فصائل أو منظمات معينة، وتعبير آخر يجب أن يكون هذا منصب بعيد عن تطبيق فكرة " أهل الثقة أولى من أهل الخبرة " يكون القضاء بعيداً عن معترك الحياة الحزبية بما تحمله من أخطار يهدد استقلال القضاء^(٢).

اختيار القاضي^(٣) في التنظيم القضائي الإسلامي:

وظيفة القاضي في الإسلام وظيفة شرعية، ومنزلة رفيعة، لا منزلة فوقها من المنازل، ولا رتبة أوفى منها، فهي منصب جلي، ومكان عليّ، ولذلك فقد أولاها الفقهاء اهتمامهم، وتناولوها بالبحث والدراسة العميقة، وحددوا طريقة اختيار القاضي، ووضعوا شروطاً ثقيلة ينبغي توافرها فيمن يكون جديراً بهذا الوصف، ويتولى منصب القضاء .

وفي اختيار القاضي يأخذ التنظيم القضائي الإسلامي بنظام تعيين القاضي عن طريق ولي الأمر، ولم يأخذ بنظام الانتخاب عن طريق الرعية، وذلك لأن القاضي نائب عن ولي الأمر لمصلحة المسلمين، فضلاً عن أن هذا الطريق يجعل للقاضي حاجة عند الناس، وقد يعمل على إرضائهم للحصول على هذه الوظيفة، مما يؤثر على سير العدالة .

ويجوز لولي الأمر في اختياره للقاضي أن يعين شخصاً يعرفه، ويعلم توافر الشروط فيه، وأما إذا كان لا يعرفه، فيكون له أن يعتمد على السؤال عنه، وجمع المعلومات حوله، فإن رضيه عينه، وإلا فالأمر منوط به، وكذلك يجوز لولي الأمر أن يعقد اختباراً لمن يرشح لوظيفة القاضي يتولاه ولي الأمر بنفسه، أو من ينبيه في ذلك، وقد اختبر رسول الله ﷺ معاذاً حين بعثه قاضياً على اليمن^(٤).

(١) قوانين المرافعات للدكتورة أمين النمر ٥٨ .

(٢) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ص : ٢٠٨ .

(٣) لفظ (قاضي) اسم مدح يقول السمناني في روضة القضاة في هذا المعنى : "اختلف الناس في أن اسم القاضي أشرف من الحاكم أم هما سواء ، فمنهم من قال أن اسم القاضي أشرف في اللغة ، ومنهم من قال بالعكس من هذا ، ومنهم من قال هما سريان ، ولهذا أضافهما الله تعالى إليه على السواء ، ورأيت كثيراً من القضاة يكره أن يخاطب الناس بالحاكم ويأنس بالقاضي " روضة القضاة ١ / ٥١ .

(٤) المغني لابن قدامة ١٠ / ٣٥ ، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٦ .

الفرع الثاني

شروط تعيين القاضي

لقد أوردت المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الشروط العامة التي يجب توافرها فيمن يولى القضاء، وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية، فليس للأجانب ولاية القضاء في مصر: لأن القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ولا يجوز أن يكون ممثل الدولة في تولي سلطتها إلا من يتمتع بجنسيتها يستوي أن تكون هذه الجنسية جنسية مصرية أصلية أم مكتسبة^(١).

الشرط الثاني: أن يكون كامل الأهلية، ومن ثم فلا يجوز تعيين فاقد الأهلية أو ناقضها قاضياً.

الشرط الثالث: ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محاكم الاستئناف، وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض، وقد افترض المقتن أن من بلغ هذا الحد من عمره يكون قد بلغ حداً من الوعي ونضوج الفكر وقوة الشخصية يؤهله لتولي هذه المراكز.

الشرط الرابع: أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية، أو على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من إحدى كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وذلك بتقدير جيد على الأقل^(٢)، وذلك بناءً على المادة "٦" من قرار رئيس الجمهورية^(٣)، بإصدار القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية، وبناءً على

(١) الوسيط في قانون القضاء المدني د. فتحي والي، ص ٩٧، الجنسية د. إبراهيم أحمد إبراهيم ص ١٤٥.

(٢) انظر: المادة رقم ٣٨ من قانون السلطة القضائية، حيث نصت على أنه: "يشترط فيمن يعين معاوناً للنيابة العامة وفي سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية المشار إليها في المادة الأولى أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق المنصوص عليها في البند "٣" من المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل، وذلك بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون "معدلة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.

انظر: الجريدة الرسمية، العدد "١٨" مكرر "أ" في ٨ مايو سنة ٢٠٠٧ م.

(٣) ونصها: "استثناء من حكم البند ٣ من المادة ٣٨ من القانون المرافق يجوز أن يعين معاوناً بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء، أو الإجازة العالية مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون، والقانون المرافق هو قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ م.

المادة الثانية من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٦م^(١).

ويجوز تعيين من يحصل على شهادة أجنبية معادلة لإجازة الحقوق، بشرط أن ينجح في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .

الشرط الخامس: ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر يخل بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وتقدير الأمر المخل بالشرف متروك لتقدير من بيده أمر التعيين.

الشرط السادس: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، فالقضاء منصب جليّ ومكان عليّ، يجب تنزيهه من ذوي السمعة السيئة والسيرة الذميمة .

الشرط السابع: توافر خبرة سابقة في العمل بالقانون تتناسب مع الدرجة التي سيعين بها قاضياً بالمحكمة الابتدائية أم رئيساً بها، أو مستشاراً بمحكمة الاستئناف أو مستشاراً بمحكمة النقض، وقد حددت المواد من ٣٩ - ٤٣ من قانون السلطة القضائية الخبرة المطلوبة لكل درجة من الدرجات الوظيفية السابقة^(٢).

ويكون شغل الوظائف القيادية سواء بالتعيين أم الترقية بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاريها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة .

أما بالنسبة لمن يعين مستشاراً بمحكمة النقض، فيعين بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض، ويرشح الآخر وزير العدل . ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض .

ويعين رئيس محكمة النقض من بين سبعة من نواب رئيس المحكمة ولمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله^(٣).

(١) في شأن تطوير الدراسة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٩٦٦م ، ونصت المادة الثانية منه على أن: " تمنح جامعة الأزهر خريجي كلية الشريعة والقانون درجة الإجازة العالية في الشريعة والقانون ، ويكون لحاملي هذه الدرجة كافة الحقوق المقررة لحاملي درجة الإجازة العالية في الشريعة ، فضلاً عن الحقوق المقررة لحاملي درجة "الليسانس" في الحقوق من كليات الحقوق في جامعات الجمهورية ... " .

(٢) قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ص ٢١٦ ، الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي ف ٩٧ .

(٣) راجع: المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية، معدلة بموجب القانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩م.

المطلب الثاني

ضمانات القاضي

تهتم الأنظمة القضائية المختلفة بوضع ضمانات تحقق استقلال القاضي وتضمن حيده في اتخاذ القرار.

وقد اهتم نظام القضاء المصري بتقرير هذه الضمانات التي تكفل أن يكون القاضي آمناً في حاضرة مطمئناً على مستقبله، وتجعله بمنحي من بطش ذوي الأيدي القوية من الخصوم أو غيرهم، ولذلك وضع المقتن المصري ضمانات تحمي القاضي من الحكومة، وضمانات تحميه من الخصوم، وضمانات تحميه من نفسه.

وهذه الضمانات لا يقصد بها مصلحة القضاة أنفسهم بقدر ما يقصد بها مصلحة المتقاضين، فالقاضي إذا كان في مأمن حكم وهو مطمئن الفؤاد، ثابت اليد، فلا يهتز ميزان العدالة في يده، وفيما يلي نتعرض لبيان هذه الضمانات من خلال الفروع التالية :

الفرع الأول

ضمانات حماية القاضي من الحكومة

وضع المقتن المصري ضمانات لحماية القاضي من تدخل الحكومة، والتأثير عليه، وهذه الضمانات هي :

أولاً: عدم القابلية للعزل:

يقصد بذلك عدم جواز عزل القاضي، أو وقفه عن العمل، أو إحالته إلى المعاش إلا برضاه، وفي الحدود التي ينص عليها القانون^(١).

ولأهمية هذه الضمانة، فقد نص عليها الدستور في المادة ١٦٨ " القضاة غير قابلين للعزل " كما نص عليها قانون السلطة القضائية في المادة ٦٧ " رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة. غير قابلين للعزل".

(١) راجع : هيبه القضاة ضمانة لاستقلال القضاء "دراسة تأصيلية مقارنة" بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، د/ أحمد خليفة شرقاوي ، بحث منشور في مجلة روح القوانين ، جامعة طنطا ، العدد السابع والخمسون ، إصدار يناير ٢٠١٢م ، ص ١١٥٨ وما بعدها .

وهذه ضمانات هامة، لا سيما بالنسبة لدول العالم الثالث، والدول حديثة العهد بالديمقراطية، فكثيراً ما تلجأ حكومات هذه الدول إلى خنق الحريات، وإسكات الأصوات، ومن ثم تمتد الحكومة يدها لتطول الأحرار، وكل من يبدو منه استقلال في الرأي، ولو كان قاضياً^(١). ولا يعني عدم القابلية للعزل أن القاضي يظل قاضياً طوال حياته، ومهما أتى من تصرفات لا تليق وهذا المنصب، بل إن القاضي يخضع كغيره من موظفي الدولة للإحالة للمعاش إذا بلغ السبعين عاماً^(٢)، "لا يجوز أن يبقى في وظيفة أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة ميلادية".

ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة^(٣). كذلك تجوز إحالة القاضي إلى المعاش إذا لم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمره بعد انقضاء الأجازات المرضية المقررة له في القانون، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، وهنا يحال القاضي إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (المادة ١/١٩١ من قانون السلطة القضائية).

وأيضاً تجوز إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية إذا ظهر في أي وقت أنه فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية^(٤). وكذلك تجوز الإحالة إلى المعاش، أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بالنسبة للرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة، الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متوالين بدرجة أقل من المتوسط^(٥).

(١) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ٩٩ .

(٢) المادة ١/٦٩ من قانون السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، وقد نص في مادته الأولى على أنه " تستبدل عبارة " سبعين عاماً " بعبارة " ثمان وستين سنة " في كل من المواد " ٦٩ " من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية...". الجريدة الرسمية ، العدد " ١٨ " مكرر " أ " في ٨ مايو سنة ٢٠٠٧ ، هذا وقد نص المقتن في المادة ٢/٦٩ من قانون السلطة القضائية على أنه : " ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو ، فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ ، دون أن تحتسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة.

(٣) المادة ٦٩ من قانون السلطة القضائية .

(٤) المادة ١١١ من قانون السلطة القضائية .

(٥) المادة ١١٢ من قانون السلطة القضائية

وقرار الإحالة إلى المعاش أو النقل لوظيفة غير قضائية في الحالتين الأخيرتين يكون من اختصاص مجلس تأديب القضاة^(١) المنصوص عليه في المادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية^(٢).

وجدير بالذكر أن الحالات التي يجوز فيها إحالة القاضي إلى المعاش واردة في القانون على سبيل الحصر، ومن ثم فلا يمكن إحالة أي قاض إلى المعاش إلا إذا انطبقت عليه حالة من الحالات التي ذكرها القانون .

ثانياً: وضع قواعد خاصة لشئون القضاة:

اهتم المقتن المصري بوضع ضمانات خاصة لمختلف الأمور التي تهم القاضي ومن ثم فيشعر القاضي بالاستقرار، ولا يسعى لإرضاء أحد من القائمين على هذه الأمور ومن ذلك:

١- راتب القاضي: لقد حرص المقتن على رعاية القاضي، فقرر له راتباً متميزاً، وخصه بكادر خاص يختلف عن كادر العاملين المدنيين بالدولة، حيث لا ينبغي أن تكون المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر، سبباً في التضيق على القاضي، فإن ذلك يدعوه إلى التطلع إلى ما في أيدي الخصوم أو غيرهم، مما يكون له أخطر الأثر على القضاء^(٣).

وتحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بقانون السلطة القضائية، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية، أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة^(٤).

٢- ترقية القاضي: ترقية القاضي تتم عن طريق السلطة التنفيذية، ولو أطلق الأمر لها في ذلك لتمكنت من نفع من يدهنها ويمالئها، ومن ضرر من يقف لها ويعارضها، وذلك بترقية الأول وتناسي الثاني، وهذا يغدو القاضي الذي يقيم العدالة بين الناس مفتقداً إياها لنفسه، منشغلاً بما يقع عليه من ظلم بدلاً من رفعه ودفعه عن الآخرين^(٥)، وتفادياً لهذا الوضع فقد نظم المقتن ضوابط لترقية القاضي حتى لا يكون أمر ترقيته خاضعاً لما قد يعتري السلطة من أهواء.

وفي هذا الشأن أوردت المادة "٤٩" من قانون السلطة القضائية الأحكام الخاصة بترقية القضاة، وتكون الترقية على أساس الأقدمية مع الأهلية، ويجوز ترقية القاضي للكفاية الممتازة،

(١) ويتكون من رئيس محكمة النقض رئيساً، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف، وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض أعضاء .

(٢) الدكتور / محمود هاشم في قانون القضاء المدني ١ / ١٣٠ .

(٣) قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ١ / ٢٤٤ .

(٤) المادة ٦٨ من قانون السلطة القضائية .

(٥) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ٢٠٠ .

ولولم يحل دوره في الترقية متى أمضي في وظيفته سنتين على الأقل، وبشرط ألا تزيد نسبة القضاة الذين يرقون لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية بينهم .

ومن جهة أخرى يستفاد من نص المادة "٧٩" من قانون السلطة القضائية أنه يجوز تخطي بعض القضاة في الترقية .

وضمناً لحق القاضي في الترقية إن كان لها وجه، وعدم تخطيه إن لم يكن له سبب، يقوم وزير العدل . قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المختصة بثلاثين يوماً على الأقل . بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم، ولم تشملهم الحركة القضائية مع بيان أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم^(١).

ومن الضمانات أيضاً كون الترقية تتم بقرار من رئيس الجمهورية، وبشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى^(٢) .

٣- نقل القاضي أو ندمه أو إعارته : وضع المفرن ضوابط لنقل القاضي من مكان إلى مكان آخر، وذلك لأن المحاكم تنتشر في سائر بلاد الجمهورية، وتختلف هذه البلاد فيما بينها من حيث توافر أسباب المعيشة، وأحوال البيئة ومدى البعد عن العاصمة، ولو ترك الأمر مطلقاً بيد السلطة التنفيذية لأمكنها التنكيل بذي الرأي المستقل من القضاة بنقله إلى المناطق النائية مما يؤثر في استقلال القضاة.

وقد وردت ضوابط النقل و الندب و الإعارة في قانون السلطة القضائية، ولذلك نصت المادة ٥٢ منه على أنه : "لا يجوز نقل القضاة أو ندمهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون"، ثم فصلت المواد "٥٣" وما بعدها قواعد نقل القضاة وندمهم وإعارتهم^(٣).

(١) مبادئ المرافعات للدكتور / عبد الباسط جمعي ص : ٢١٦ .

(٢) المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية .

(٣) هذا وقد نصت المادة رقم " ١٥ " من قانون السلطة القضائية حيث نصت على أنه "تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن أربع سنوات متصلة، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية " ، مستبدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ ، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية .

راجع : المادة الثالثة من هذا القانون ، الجريدة الرسمية العدد "١٨" مكرر "أ" في ٨ مايو سنة ٢٠٠٧ ، كما نصت المادة "٦٦" من قانون السلطة القضائية، على أن : "تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها، أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات، ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجةها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية

٤- تأديب القاضي : يخضع القاضي كغيره من العاملين بالدولة للمساءلة عن خطئه، ولكن نظراً لمكانة القاضي وأهمية وظيفته، فقد أحاطه المقتن بمجموعة من الضمانات عند مساءلته، حتى لا يستغل خطأ القاضي، ويستخدم كوسيلة للتنكيل به وتصفية حسابات قديمة.

ولذلك جعل المقتن تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من سبعة أشخاص من كبار القضاة، وهم رئيس محكمة النقض رئيساً، وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف أعضاء، وعند غياب واحد منهم يحل محله الأقدم من مستشاري محكمته^(١)، وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناءً على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه، أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.

ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاها .

ويخطر مجلس التأديب بالطلب، فإذا لم يقر النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب^(٢)، وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش (المادة ١٠٤ من قانون السلطة القضائية) .

ومحافظة على كرامة القاضي وسمعة القضاء فقد جعل المقتن جلسات المحاكمة التأديبية سرية^(٣) و"يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق" المادة ١٠٧ من قانون السلطة القضائية.

كما حصر المقتن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي في اللوم والعزل^(٤).

بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته ، وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو النذب الإخلال بسير العمل" ، مستبدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ ، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، راجع : المادة الثالثة من هذا القانون ، الجريدة الرسمية ، العدد " ١٨ " مكرر " أ " في ٨ مايو سنة ٢٠٠٧ م .

(١) المادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية .

(٢) المادة ٩٩ من قانون السلطة القضائية .

(٣) المادة ١٠٦ / ١ من قانون السلطة القضائية .

(٤) المادة ١٠٨ من قانون السلطة القضائية .

٥- اتهام القاضي ومحاكمته جنائياً : قد يقع القاضي في الخطأ، ويرتكب فعلاً يعد جريمة بمقتضى القانون، وفي ذلك يخضع القاضي للمساءلة الجنائية كمواطن عادي، ولكن المقنن أحاط القاضي بضمانات حتى في حالة ارتكابه فعلاً يستوجب محاكمته جنائياً وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي:

أ. في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية

ب - وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج عنه بكفالة أو بدونها، وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها .

وتحدد هذه اللجنة مدة الحبس في قرارها بالحبس أو باستمراره، وتراعى هذه الإجراءات كلما رأَت استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررت لها اللجنة.

ج - وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جنابة أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة، وبناءً على طلب النائب العام^(١).

د - واستثناءً من قواعد الاختصاص المكاني تعين اللجنة المنبثقة^(٢) عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبناءً على طلب النائب العام، المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنب أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم^(٣) .

هـ- يجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين^(٤) .

حماية القاضي من الحكومة في النظام القضائي الإسلامي :

لكي ينهض القاضي بواجبه على أحسن وجه، يجب أن يكون آمناً مطمئناً في حاضره ومستقبله، ولذلك يجب أن يكون بمنحى من بطش ذوي الأيدي القوية، مطمئناً على مقومات حياته في الحاضر والمستقبل وعلى هذا الأساس أقيم النظام القضائي الإسلامي .

(١) الفقرات ١، ٢، ٣، ٤، من المادة ٩٦ من قانون السلطة القضائية.

(٢) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ٢٤٦/١ .

(٣) المادة ٩٥ من قانون السلطة القضائية .

(٤) المادة ٩٦ من قانون السلطة القضائية .

أ- راتب القاضي: القاضي عامل من أجل عمال المسلمين، وهو قائم على مصالحهم، ومنقطع لخدمتهم، ومن ثم فنفقته عليهم .

وهذا هو الاتجاه السائد منذ عهد رسول الله ﷺ بل إن الخلفاء الراشدين أوجبوا إجزال العطاء للقاضي والتوسعة عليه، حتى لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. وقد منح رسول الله ﷺ عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة أربعين أوقية في السنة، وأعطى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري ستة آلاف درهم وهو على قضاء البصرة وكذلك على بن أبي طالب أعطى شريحاً القاضي خمسمائة درهم^(١).

ب- حماية القاضي من ذوي السلطة والنفوذ: يجب أن يكون القاضي في مأمن من كيد ذوي السلطة والنفوذ حتى لا يخشى بأسهم ولا يعمل على إرضائهم، وتحقيق رغباتهم، بل يجب أن يكون القاضي بعيداً عن كل مؤثر من قريب أو بعيد . وقد تمتع القضاة المسلمون بهذه الحماية بالرغم من عدم النص عليها في الكتب الفقهية . وهذا على بن أبي طالب يكتب لواليه على مصر أن يجعل للقاضي منزلة لديه لا يطمع فيها غيره، حتى يكون القاضي آمناً من اغتيال رجال السلطة أو النفوذ عند الوالي^(٢).

وبدل على تمتع القاضي المسلم بهذه الحماية أنه لما اختلف معاوية بن أبي سفيان والي فلسطين من قبل عمر بن الخطاب مع قاضيه عبادة بن الصامت، فأغلظ معاوية لعبادة في القول، فقال عبادة لمعاوية: " لا أساكنك بأرض واحدة أبداً " وترك فلسطين ورجع إلى المدينة المنورة، فلما قابلته عمر قال له: ما أقدمك؟ فأخبره بالأمر فقال: ارجع إلى مكانك قبح الله أرضاً لست بها ولا أمثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك على عبادة^(٣)، فكان عبادة أمير نفسه .

(١) روضة القضاة للسمناني ١ / ٨٦ ، التراتيب الإدارية للكتاني ١ / ٢٦٤ ، تاريخ القضاء في الإسلام للشيخ / محمود عرنوس ص ١٧ .

(٢) كتب علي بن أبي طالب إلى الأشتر النخعي واليه على مصريقول له: " ... اختر للحكم بين الناس بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ... وافسح له في البذل ما يزيل علته ، وتقل معه حاجته إلى الناس ، واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك فيأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك . تاريخ القضاء في الإسلام للشيخ / محمود عرنوس، ص: ١٧ .

(٣) أسد الغابة في معرفة الصحابة ٣ / ١٦٠ ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢ / ٨٠٧ ، ٨٠٨ ، مبادئ التنظيم القضائي في العراق ، للأستاذ ضياء شيث خطاب ص: ٢٤ .

الفرع الثاني

ضمانات حماية القاضي من الخصوم

لا يكفي لضمان استقلال القاضي وحيدته أن يضع المقنن ضمانات تحمي القاضي من تسلط الحكومة، بل يجب أيضاً أن يكون القاضي في حماية من عبث المتقاضين أنفسهم ومن كيدهم له ومشاكستهم معه.

وتحقيقاً لذلك وضع المقنن نظاماً خاصاً لمساءلة القاضي أو عضو النيابة، عند مساءلته عن خطئه في أداء وظيفته أو بسببها، وأطلق على هذا النظام "مخاصمة القضاة" ولم يجعل المقنن للأفراد من سبيل لمقاضاة القاضي إلا اتباع هذا النظام، ويمتاز هذا النظام بأن حدد فيه المقنن أسباب المسؤولية وأوردها على وجه الحصر.

ولا يجب اتباع هذا النظام إلا لمساءلة القاضي أو عضو النيابة مدنياً عن خطئه في أداء وظيفته أو بسببها، ومن ثم فلا محل لتطبيقه لمساءلة القاضي جنائياً أو تأديبياً، أو مدنياً متى كانت ناشئة عن ارتباطات تعاقدية أو أخطاء تقصيرية خاصة بحياة القاضي العادية^(١).

وتعتبر مخاصمة القاضي دعوى تعويض، تقام بطريقة خاص، ويجوز الرجوع على الدولة بما قد يحكم به على القاضي من تعويض، على أن تقوم الدولة بالرجوع على القاضي بما تكون قد أوفت به وفقاً للقواعد العامة^(٢).

ويتبع هذا النظام لمخاصمة القاضي أيّاً كانت درجته أو المحكمة التي يعمل بها، كما تجوز مخاصمة الدائرة بأكملها عندما ينسب إليها الخطأ، ولو كانت بمحكمة النقض، ولكن لا تجوز مخاصمة الهيئتين العامتين مجتمعتين بمحكمة النقض؛ لأن القول بجواز ذلك يترتب عليه جعل دعوى المخاصمة بدون محكمة تنظرها^(٣) كما يتبع هذا النظام لمخاصمة أعضاء النيابة العامة^(٤). وإذا توفي القاضي أو عضو النيابة، فإنه يمكن توجيه دعوى المخاصمة إلى ورثته.

أحوال قبول دعوى المخاصمة:

لقد أوردت المادة (٤٩٤) مرافعات) أحوال قبول دعوى المخاصمة على وجه الحصر، وهذه الأحوال على النحو التالي:

(١) د / أمينة النمر في قوانين المرافعات ف ٧٦ ، الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ص ٢٨٠ .

(٢) قانون القضاء المدني د / محمود هاشم ف ١٥٢ ، الدكتور / أمينة النمر ، المرجع السابق وذات الفقرة .

(٣) بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بديوي ص ١٦٤ ، الوسيط للدكتور / فتحي والي ف ١٠٣ .

(٤) المادة ٤٩٤ / ١ مرافعات .

١- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر، أو خطأ مهني جسيم. والغش والتدليس والغدر كلها ألفاظ متقاربة المعنى، ولكنها ليست مترادفة كما ذهب البعض^(١)، وإنما بينها فروق دقيقة^(٢)، وتتفق فيما بينها في أنها وسائل للوصول إلى غرض واحد، وهو البعد عن العدالة عمدا؛ لتحقيق مصلحة للقاضي، أو لأحد الخصوم أو للإضرار به. هذا، ويصعب إثبات الغش أو التدليس أو الغدر، لأن إثبات ذلك يستلزم إثبات سوء النية من قبل القاضي، ولذلك نص المقتن لأول مرة في قانون المرافعات السابق على الخطأ المهني الجسيم باعتباره حالة تجوز فيها مخاصمة القاضي.

ويقصد بالخطأ المهني الجسيم:

تجاوز القاضي للصواب بدرجة كبيرة وملحوظة، نتيجة تفريطه في عمله، وتقصيره في أداء واجباته القضائية وانحرافه عن الوجهة المعتبر لها قانونا، فهو خطأ ظاهر وواضح، لا يقع فيه قاض إلا إذا كان على درجة كبيرة من الإهمال وعدم الحيطة، كما هو شأن إغفاله لوقائع ثابتة في ملف الدعوى، أو الجهل الفاضح بالمبادئ القانونية الأولية، التي لا ينبغي بحال أن يجهلها مثله^(٣).

ولا بد أن يكون الخطأ واضحا بدرجة كبيرة، بحيث يدل على وقوع إهمال جسيم من قبل القاضي، أو جهل فاضح منه، وأما الخطأ غير الجسيم فلا يعتبر من أحوال مخاصمة القاضي، كما هو شأن الخطأ في تقدير ثبوت الوقائع، أو في تفسير القانون على نحو معين، ولو كان مخالفا

(١) الدكتور محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ٢٨٦/١.

(٢) ويقصد بالغش هنا تغيير القاضي للحقيقة عمدا، لتحقيق مصلحة له، أو لأحد الخصوم، أو للإضرار به، كما إذا غير القاضي عمدا أقوال أحد الخصوم، أو الشهود، سواء أكان التغيير في الألفاظ أم في المعاني.

وأما التدليس فهو نوع من الغش، ولكن يزيد عليه أن تغيير الحقيقة فيه يكون باستعمال أساليب وطرق احتيالية؛ لتغطية الغش، فمثلا إذا كلف قاض بكتابة تقرير عن قضية فكتبه محرفا عمدا، بأن وصف مستندا مقدما في القضية بغير ما اشتمل عليه المستند، فهذا غش، وكتابة التقرير بخط رديء أو بعبارات غير قاطعة الدلالة عمدا، لتغطية الغش، يجعل الغش تدليسا، لأنه استعمل وسيلة لتغطية الغش وإخفائه، فالمدّيس أمعن في الغش من الغاش.

وأما الغدر فنعتقد أن المراد به هنا الحكم بالظلم عمدا للأغراض السابقة، وهو يختلف عن الغش، في أن الأخير تغيير لحقيقة، ومنه يصل القاضي إلى غرضه، وأما الغدر فلا يغير الحقيقة، ومع ذلك يحكم بالظلم عمدا، وقد سماه المقتن غدرا؛ مرجع التسمية هنا لأن هذا الفعل يمثل نقضا للعهد واليمين الذي أقسمه بأن يحكم بين الناس بالعدل وأن يحترم الدستور القانون، ونقض العهد هو إنما هو الغدر ذاته. ولذلك فالغادر- فيما نعتقد- إنما هو أفجر من الغاش ومن المدّيس. (انظر قانون القضاء المدني للدكتور محمود هاشم ١٥٤/١، الدكتور فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني (١١١).

(٣) الدكتور فتحي والي، الوسيط ف١٠٢، الدكتور عبد العزيز بديوي، بحوث قواعد المرافعات ص١٦٥.

لإجماع الفقهاء، كما لا يعد خطأ جسيماً أن يجهل القاضي حكماً في القانون لا يعتبر من أسسه أو مبادئه.

٢- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له، أو امتنع عن الفصل في قضية صالحة للحكم فيها.

وتتحقق هذه الحالة ببقاء القاضي ممتنعاً عن ذلك بعد إعداره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض، وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية، وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. هذا، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر إعدار (المادة ٢/٤٩٤ مرافعات).

٣- الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات، كما شأن هو ما نصت عليه المادة (١٧٥) مرافعات، والتي أوجبت إيداع مُسَوِّدَة الحكم المشتملة على أسبابه، موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم، وإلا كان الحكم باطلاً، ويكون المتسبب في البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه.

إجراءات دعوى المخاصمة والمحكمة المختصة بها:

ترفع دعوى المخاصمة بتقرير قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة (المادة ٤٩٥ / ١ مرافعات) معدلة بالقانون ٢٣ لسنة ٩٢، ١٨ لسنة ١٩٩٩ وقياساً على ذلك إذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض^(١) يقدم التقرير إلى كتاب محكمة النقض، ويجب أن يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً. وضماناً لجدية الدعوى أوجب المقتن أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تودع مع التقرير الأوراق المؤيدة لها، وأن يودع عند التقرير مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة.

ثم تبلغ صورة التقرير إلى القاضي المخاصم أو عضو النيابة، وتخبر النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى^(٢)؛ لأن دعاوى المخاصمة من الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة التدخل فيها^(٣). ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة، على أن تكون أول جلسة تعقد بعد الثمانية أيام التالية لتبليغ القاضي المخاصم بالتقرير. (المادة ٤٩٥ مرافعات).

(١) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ١ / ٢٩٠ .

(٢) المادة ٩٢ مرافعات .

(٣) المادة ٨٩ / ٤ مرافعات .

ونظر دعوى المخاصمة على مرحلتين :

المرحلة الأولى : مرحلة النظر في جواز قبول المخاصمة، أى : البحث في مدى صحة الإجراءات المطلوبة، وتوفر أوجه المخاصمة، ويعقد الاختصاص بها لإحدى دوائر محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة - يعينها رئيس محكمة الاستئناف - ما لم يكن القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض، فتختص بالفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة^(١)، وفي كلتا الحالتين يكون نظرها في غرفة المشورة .

وتحكم المحكمة في جواز المخاصمة بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى (المادة ٢٩٦ مرافعات) والحكم في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه، ولا يجوز في هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت مع التقرير^(٢) .

وإذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، فإنها تحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمئة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه (المادة ٤٩٩ / ١ مرافعات معدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م) .

وأما إذا حكم بجواز قبول المخاصمة، حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام المحكمة المختصة وتبدأ مرحلة ثانية، على أن القاضي المخاصم يصبح غير صالح لنظر الدعوى . التي كانت سبباً في المخاصمة . وذلك من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة^(٣) .

المرحلة الثانية : مرحلة النظر في موضوع المخاصمة، وفيها يزيد المقنن من ضمانات القاضي أو عضو النيابة المخاصم، ولذلك عقد الاختصاص بها لهيئات تختلف باختلاف درجة القاضي المخاصم، فإذا كان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها فالاختصاص ينعقد لدائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف يحددها الحكم الصادر بجواز قبول المخاصمة .

وأما إذا كان المخاصم مستشاراً في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام، فإن الاختصاص يكون لدائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . وإذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فإن الاختصاص يكون لدوائر المحكمة مجتمعة .

(١) انظر: بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بديوي ، ص ١٦٨ .

(٢) حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٢١ في جلسة ٥ / ٦ / ١٩٥٢ .

(٣) المادة ٤٩٨ مرافعات .

وفي الجلسة المحددة ينظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية، ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى . وإذا قضت المحكمة برفض المخاصمة فإنها تحكم أيضاً على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمئة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وأما إذا قضت بصحة المخاصمة فإنها تحكم على القاضي أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه.

ومع هذا إذا كان التصرف الذي تريد أن تبطله المحكمة هو حكم صادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة، فلا تحكم المحكمة ببطلانه إلا بعد إعلان ذلك الخصم لإبداء أقواله، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم^(١).

ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض (المادة ٥٠٠ مرافعات) ومن ثم إذا كان صادراً من محكمة النقض فإنه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق: لأن أحكامها لا تقبل الطعن وفقاً للمادة ٢٧٢ مرافعات.

حماية القاضي من الخصوم في النظام القضائي الإسلامي:

لقد أحاطت الشريعة الإسلامية القاضي بعدة ضمانات تجعله في مأمن من كيد الخصوم وعيهم، ومن هذه الضمانات عدم جواز مخاصمة القاضي، وعدم مسئوليته عن خطئه. أ- عدم جواز مخاصمة القاضي : يرى فقهاء المسلمين أن القاضي المأمون في أحكامه، العدل في أحواله البصير بقضائه لا تجوز مخاصمته، ولا تسمع الدعوى عليه فيما يتعلق بأحكامه ؛ لأن سماعها وإجابة طلب المدعي بمخاصمة القاضي يذهب بمهابة القضاء، ويجعل القاضي عرضة لكيد الخصوم، ومن ثم قد يخشى بأسهم ويعمل على إرضائهم اتقاء لشهرهم .

ومع هذا إذا ظهر جور القاضي وتسلفه، واشتهر بالظلم وتظاهرت الشكاية عليه، نظروا في الأمر في أمره، فإن كان حكمه على ما يجب من الصواب نفذ، وإن لم يكن كذلك كأن يعتمد القاضي الخطأ أو الجور عززه ولي الأمر وعزله، لظهور خيانتة فيما هو أمين عليه^(٢) .

وحماية للقاضي أوجب الفقهاء على ولي الأمر ألا يأخذ بمجرد قول الخصم، بل لابد من تقديم البينة، فإن وجدت، نظر في الأمر واستدعى القاضي، وإلا فيرى بعض الفقهاء عدم إحضار القاضي ؛ لأن في إحضاره وسؤاله مهانة له وأعداء القاضي كثير .

(١) المادة ٤٩٩ مرافعات ، معدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

(٢) معين الحكام للطرابلسي ص : ٣٣ ، ٣٤ ، المغني لابن قدامة ١٠ / ٥٦ .

ويرى بعض آخر من الفقهاء حضور القاضي حتى ولو لم تكن هناك بينة ويسأل، فإن اعترف بها وإلا فالقول قوله بلا يمين : لأن قول القاضي مقبول ولو بعد عزله.

ب- عدم مسئولية القاضي عن خطئه : إذا ظهر أن القاضي قد أخطأ في حكمه، وجب إبطال الحكم ورد الحال إلى ما كانت عليه الواقعة متى كان ذلك ممكناً، وأما إذا لم يمكن ذلك، أو أمكن وترتب على ذلك ضرر وجب ضمان ذلك من بيت مال المسلمين ولا يسأل القاضي عن هذا الضمان . أما إذا كان القاضي قد حكم بخلاف الحق عمداً وأقر بتعمده فعليه الضمان في ماله^(١).

الفرع الثالث

ضمانات حماية القاضي من نفسه

القاضي أولاً وأخيراً واحد من البشر، وفيه الجانبان : الخير والشر، ومن هنا تهتم الأنظمة القضائية بوضع الضمانات التي تكفل حماية القاضي من جانب الشرفيه، فقد يطغى هذا الجانب، ويسعى القاضي لتحقيق مصالح لنفسه مستغلاً في ذلك وضعه الوظيفي كقاضي أو يعمل على تحقيق النفع لنفسه أو لأقاربه، أو إيقاع الضرر بعدوه. لذا فقد منع المقتن المصري القاضي من القيام ببعض الأعمال والتصرفات التي من شأنها أن تتعارض مع وظيفة القضاء، وكذلك منعه من التصدي للقضاء في حالات يغلب على الظن أن القاضي قد يخرج فيها عن حياده فيها.

أولاً: منع القاضي من القيام ببعض الأعمال والتصرفات:

محافظة على سمعة القاضي، وضماناً لنزاهته وحيدته، وحفاظاً على استقلاله وكرامته، وبعداً به عن الشبهات، منع القاضي من القيام ببعض الأعمال والتصرفات التي من شأنها أن تتعارض مع واجبات وظيفة القضاء وحسن أدائها، ولذلك:

١- لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته^(٢).

(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤١٨ ، روضة القضاء للسمناني ١ / ١٥٦ ، ١٥٧ .

(٢) ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها (المادة ٧٢ من قانون السلطة القضائية) .

- ٢- يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر كذلك على القضاء الاشتغال بالعمل السياسي، فلا يجوز لهم الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم " المادة ٧٣ من قانون السلطة القضائية".
- ٣- لا يجوز للقاضي أن يكون محكماً ولو بغير أجر، حتى ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وفي حالات مخصوصة.
- لذا يستثنى من هذا الحظر حالة ما إذا كان أحد أطراف النزاع من أقارب القاضي أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة إذا كانت طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم، إلا إذا وافق مجلس القضاء الأعلى، وفي هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي^(١).
- ٤- لا يجوز للقاضي أن يكون وكيلاً عن أحد الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء، حتى ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها القاضي، وإلا كان العمل باطلاً.
- لكن يجوز للقاضي ذلك إذا كان أحد الخصوم يمثله القاضي قانوناً، كالقاصر المشمول بولاية القاضي أو وصايته، أو كان زوجاً للقاضي أو أصلاً له أو فرعاً إلى الدرجة الثانية^(٢) " مادة ٨١ مرافعات".
- ٥- لا يجوز للقاضي أن يشتري باسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه، إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر أعماله في دائرتها، وإلا كان البيع باطلاً " المادة ٤٨١ مدني".
- ٦- لا يجوز للقاضي الذي نظربأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرغة عنها أن يتقدم للمزايدة كمشتري بنفسه أو بطريق تسخير غيره، وإلا كان البيع باطلاً.

ثانياً: اعتبار القاضي غير صالح لنظر الدعوى:

هناك مجموعة من الحالات يغلب على الظن فيها أن القاضي لن يستطيع التغلب على جانب الشرف فيه. كإنسان. ومن ثم قد تضعف نفسه ويخرج عن حياده واستقلاله، وحماية للقاضي، وبعداً به عن الشبهات وارتفاعاً به فوق الظنون ودفعاً للحرج عنه، اعتبره المقتن في هذه الحالات غير صالح لنظر الدعوى، وممنوعاً من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم.

(١) المادة ٦٣ من قانون السلطة القضائية.

(٢) الوسيط للدكتور / فتحي والي ف ١٠٤.

وقد أورد المقنن هذه الحالات على سبيل الحصر، ومن ثم فلا يجوز التوسع في تفسيرها^(١)، ولا القياس عليها^(٢)، لأنها خلاف الأصل، وهذه الحالات هي:

١- إذا كان بين القضاة الذين يجلسون في دائرة واحدة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، وكذلك إذا كان بين ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنهم وبين أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

وحتى لا يتمكن الخصم سيء النية من تنحية قاض معين عن نظر الدعوى وذلك عن طريق توكيل محام تربطه الصلة المذكورة بذلك القاضي أثناء سير الدعوى، نص المقنن على أنه: "لا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى" المادة ٧٥ من قانون السلطة القضائية.

والحكمة من هذه الحالة المحافظة على حيده القاضي وعدم تأثره بأراء قريبه أو صهره.

٢- إذا كان القاضي قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة ذلك أن القرابة أو المصاهرة يغلب على الظن فيها أنها تحمل القاضي على الميل مع أحد الخصوم، وتوافر هذه الحالة حتى بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة، ويستوي أن يكون القاضي قريباً أو صهراً لأحد الخصوم أو لهما معاً^(٣).

٣- إذا كان للقاضي أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته (المادة ١٤٦ / ٢)، ويجب أن تكون الخصومة قائمة وقت رفع الدعوى^(٤)، أما إذا كانت هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو وزوجه بعد قيام الدعوى أمام القاضي فإنها لا تكون سبباً لعدم الصلاحية، حتى لا يتمكن الخصوم من منع القاضي من نظر الدعوى بإثارة خصومة معه أو مع زوجته، ومع ذلك فالخصومة اللاحقة سبب من أسباب رد القاضي وفقاً للمادة " ١٤٨ " مرافعات، وكذلك إذا كانت الخصومة قد انتهت قبل قيام الدعوى أمام القاضي، فلا تعتبر سبباً لعدم الصلاحية، وإن كان يمكن أن تكون سبباً من أسباب رد القاضي^(٥) كما سيأتي بيانه .

(١) الدكتور / فتحي والي ، المرجع السابق ف ١٠٥ .

(٢) المرافعات المدنية والتجارية للدكتورين / عبد المنعم الشرقاوي ، فتحي والي ف ١٠٤ هامش "١".

(٣) الدكتور / رمزي سيف في الوسيط ف ٤٩ ، الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ١٠٥ .

(٤) الطعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٢٠ ق جلسة ٢٦ / ٣ / ١٩٥١ .

(٥) المرافعات المدنية والتجارية للدكتورين عبد المنعم الشرقاوي، فتحي والي ف ١٠٤ هامش "٢"

٤- إذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية، أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له، ذلك أن الوكيل يتصف بالحرص على مصلحة موكله، والوصي أو القيم يتصف بالعطف على المشمول بالوصاية أو القوامة، وهذه الصفات لا تتفق وما ينبغي أن يكون عليه القاضي من عدم التحيز والحيدة المطلقة، والوكالة أو الوصاية أو القوامة التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها هي التي تكون قائمة وقت نظر تلك الدعوى، أما إذا كانت قد انقضت قبل هذا الوقت، فإنها لا تمنع القاضي من نظر الدعوى^(١).

والمقصود بعبارة " مظنونة وراثته له " أن يكون القاضي يمت لأحد الخصوم بسبب من أسباب الإرث ولو وجد من يحجبه عنه أو يحرمه منه، فقد يزول سبب الحجب أو الحرمان^(٢)، وذلك لأن للقاضي المظنونة وراثته لشخص مصلحة في تضخيم ثروة هذا الشخص، أو في استرضائه حتى لا يتعرض للحرمان من الإرث .

٥- إذا كانت للقاضي صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بولي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى وذلك لأن قرابة القاضي أو مصاهرته بنائب أحد الخصوم أو ممثل الشركة المختصة، مدعاة لمظنة قد تقوم في ذهن الخصم الآخر في أن تطمئن نفسه إلى الحكم الذي يصدر في الدعوى^(٣) .

٦- إذا كان للقاضي أو لزوج أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة، وذلك لأن وجود مصلحة للقاضي أو لواحد من المذكورين من شأنه أن يخل بحياد القاضي، ويجب أن تكون المصلحة قائمة بالفعل أثناء الدعوى، ولا عبرة بوقت نشوئها قبل رفع الدعوى أم بعده^(٤). وهذه الحالة تشمل ما قد تقصر عنه سائر الحالات السابقة، فقد لا تكون الدعوى المطروحة أمام القاضي مقامة من أو على قريبه أو زوجه أو صهره، ومع ذلك توجد للقاضي أو لواحد من هؤلاء مصلحة محققة من ورائها، كأن تكون الدعوى مقامة من أحد

(١) الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٣٢ ق ، جلسة ٢٧ / ١٠ / ١٩٦٦ س ١٧ ص ١٥٩٢ .

(٢) الوسيط للدكتور رمزي سيف ، ف : ٤٩ .

(٣) قواعد المرافعات لمحمد العشماوي والدكتور / عبد الوهاب العشماوي ف ١٦٤ .

(٤) الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ١ / ٢٥٥ .

المساهمين في شركة يساهم فيها القاضي أو واحد من هؤلاء، ويكون من شأن موضوع الدعوى أن يحقق لأحد من هؤلاء مصلحة وإن كانت غير ظاهرة^(١).

٧- إذا كان القاضي قد أفتى أو ترفع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها رأياً ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها " المادة ١٤٦ / ٥ مرافعات " .

وذلك لأن القاضي الذي سبق له الإفتاء أو الترفع أو الكتابة في دعوى معينة أو سبق له نظرها بأي وجه من الوجوه، أو أدى شهادة فيها يكون قد كون رأيه وعقيدته عن الدعوى قبل نظرها، ومن ثم فقد يحيله ذلك على التمسك برأيه حتى ولو خالف العدالة .

ولا يعتبر موجباً لعدم الصلاحية أن يكون القاضي قد أبدى رأيه في موضوع قانوني يتفق وموضوع الدعوى، وذلك في مؤلف أو بحث علمي مجرد ولو أثناء توليه القضاء، أو كان قد فصل في عدة دعاوى مشابهة أو أصدر أحكاماً فيها متخذاً اتجاهاً قانونياً معيناً .

والمقصود بسبق القاضي لنظر الدعوى قاضياً أو خبيراً أو محكماً الذي يفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى ذاتها، أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً وصحيحاً.

هذا ويجب أن يكون الإفتاء أو الترفع أو الكتابة أو أداء الشهادة في نفس الدعوى، أما إذا كان ذلك في دعوى أخرى فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية وكذلك إذا وجد اختلاف في أي عنصر من عناصر القضية^(٢).

وغني عن البيان أن عدم الصلاحية ينتفي إذا نص الشارع على أن طريقاً معيناً من طرق الطعن يقدم إلى نفس القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه، (كالتماس إعادة النظر).

(١) قواعد المرافعات لمحمد العشماوي ، والدكتور / عبد الوهاب العشماوي ف ١١٥ .

(٢) نظر القاضي في دعوى النفقة لا يمنعه من نظردعوى التطبيق للفرقة ، لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى، وبالتالي لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية (الطعن رقم ٤ لسنة ٤٠ أحوال شخصية ، جلسة ١٩٧٢/٥/٢٤ س ٢٣ ص ١٠٠٣) .

واشتراك القاضي في إصدار الحكم ببطالان التنفيذ لا يمنعه من نظردعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا التنفيذ ، لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى ، وبالتالي لا يكون سبباً لعدم الصلاحية (الطعن رقم ٥٠ لسنة ٣٩ ق جلسة ١٩٧٦/٦/١ س ٢٧ ص ١٢٤٧ " .

ولا يبطل الحكم أن يكون أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية التي أصدرته قد اشترك في نظر استئناف رفع من محكوم عليهم آخرين في نفس الدعوى : لأن الحكم الذي صدر في ذلك الاستئناف ليس من شأنه أن يقيده بشيء وهو يفصل في الاستئناف الأخير " الطعن رقم ٨ لسنة ١١ ق جلسة ١٩٤١/٤/٢٤ " .

- ٨- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد، أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحية القاضي للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها (المادة ١٦٥ مرافعات) وذلك لأن وجود خصومة بين القاضي والخصم، قد يوغر قلب القاضي ويخرجه عن حياده واستقلاله.
- ٩- إذا رفعت على القاضي دعوى المخاصمة وحكم بجواز قبول المخاصمة فإن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم (المادة ٤٩٨ مرافعات) .
- وينبغي الإشارة إلى أن أحوال عدم الصلاحية تتعلق بالنظام العام، وقد أوجب المقنن امتناع القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، ومن ثم يجوز التمسك بأسباب عدم الصلاحية أو بأحدها لأول مرة أمام محكمة النقض بجميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجب^(١) .
- وينبغي على تعلق أحوال عدم الصلاحية بالنظام العام أن يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .
- وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى (المادة ١٤٧ مرافعات) .

ثالثاً: رد القاضي:

هناك حالات يحتمل فيها أن القاضي قد يخرج فيها عن حياده، ومع أن هذا الاحتمال ضعيف إلا أنه قائم وحماية للقاضي، وتنزيهاً له عن مجرد الشبهات وارتفاعاً بالأحكام عن مواضع الشك والريبة، أورد المقنن مجموعة من الأسباب، وأوجب على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى متى توافر سبب من هذه الأسباب، فإن لم يفعل كان لكل خصم له مصلحة أن يطلب رد القاضي عن نظر الدعوى، فإن لم ينتج القاضي، ولم يطلب رده من قبل الخصوم أو أحدهم فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون صحيحاً، ولا يجوز الطعن فيه لهذا السبب^(٢) .

ومن هنا يتضح الفرق بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد في أن أسباب عدم الصلاحية يترتب على وجود واحد منها أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعاً من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم كما يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في هذه الحالة، ولو تم باتفاق الخصوم حتى ولو كان الحكم صادراً من محكمة النقض - كما سبق القول - أما أسباب الرد الآتي ذكرها، فلا يترتب على مجرد وجود واحد منها منع القاضي من سماع الدعوى، إلا إذا طلب

(١) الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٢٤ ق، جلسة ١٩٥٥/٣/١٤ الطعن رقم ١٣٧١ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٧٩/٦/٢٠.

(٢) الوسيط للدكتور/فتحي والي ف١٠٦ ، قانون المرافعات د/محمد عبد الخالق عمر ٢٦١/١ .

أحد الخصوم رد القاضي عن الحكم وإذا لم يطلب ذلك فإن القاضي يكون صالحاً لنظر الدعوى، ويكون حكمه صحيحاً^(١).

وقد أورد القانون أسباب الرد في المادة "١٤٨" مرافعات على وجه الحصر، ولا يجوز القياس عليها^(٢) وهي :

١- إذا كان للقاضي أو زوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها " المادة ١٤٨ / ١ مرافعات و" المقصود بالتماثل بين الدعويين أن يستند الحكم فيهما إلى نفس المبادئ والقواعد القانونية وعلة الرد في هذه الحالة أن القاضي قد يميل إلى الحكم في الاتجاه الذي يحقق مصلحته أو مصلحة زوجته، وذلك بإرساء سابقة قضائية يعتمد عليها في دعواه^(٣).

٢- إذا حدث للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه (المادة ١٤٨ / ١ مرافعات).

وعلة الرد هنا أن خصومة القاضي أو زوجته لخصم أو لزوجته قد تؤثر على القاضي وتخرجه عن حياده .

ويشترط لتوافر هذه الحالة شرطان، الأول : أن تكون الخصومة قد نشأت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي^(٤). والثاني : ألا يكون المقصود من رفع الخصومة بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المطروحة عليه، حتى لا يتخذ الخصوم من هذا السبب وسيلة للمشاكسة^(٥).

٣- إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد أو لأحد أقارب القاضي أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده (المادة ١٤٨ / ٢ مرافعات).

وعلة الرد هنا أن الخصومة بين أحد المذكورين وأحد الخصوم أو زوجته قد تؤثر على حياد القاضي.

(١) الوسيط للدكتور / رمزي سيف ف ٤٨ .

(٢) الدكتور / أحمد أبو الوفا في التعليق على قانون المرافعات ، المادة ١٤٨ تعليق "٢" .

(٣) ولذلك يشترط بعض الشراح أن تكون دعوى القاضي أو زوجته لا تزال قائمة أمام القضاء أما إذا كانت قد انتهت فلا يعد ذلك سبباً للرد ، الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ١ / ٢٦٢ .

(٤) وأما إذا كانت الخصومة قد نشأت قبل قيام الدعوى المطروحة على القاضي فإن ذلك يعتبر سبباً لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى المطروحة عليه كما قلنا .

(٥) التعليق على قانون المرافعات للدكتور / أحمد أبو الوفا ، المادة ١٤٨ تعليق " ٣ " .

ويستوي أن تكون الخصومة مقامة قبل رفع الدعوى المطروحة على القاضي أو نشأت بعد رفعها^(١)، غاية الأمر أنه إذا كانت الخصومة قد أقيمت بعد رفع الدعوى المطروحة على القاضي، فيشترط ألا تكون قد أقيمت بقصد رد القاضي.

٤- إذا كان أحد الخصوم خادماً للقاضي أو كان القاضي اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها (المادة ١٤٨ / ٣ مرافعات).

وكلمة الخادم تشمل^(٢): المربية والطباخ والسائق والبواب والكاتب والسكرتير والمحصل وناظر الزراعة، ولكن لا تشمل الطبيب أو المهندس أو المقاول أو الحلاق أو المكوي، ويقصد باعتبار مؤاكلة أحد الخصوم: تكرار دعوة كل منهما صاحبه للطعام، وإجابة كل منهما الدعوة عدة مرات، أما الاجتماع العارض على مائدة غيرهما فلا تعد مؤاكلة، ومن ثم فلا تعد سبباً للرد. واعتياد المساكنة أن يسكن كل من القاضي والخصم معاً في مسكن واحد على سبيل الاعتياد، فلا يكفي أن ينزلا ليلة في فندق ولو في حجرة واحدة أو يسكنا معاً في مبنى واحد، وكل منهما في شقة مستقلة^(٣).

وقبول الهدية قبيل رفع الدعوى أو بعده يعتبر سبباً للرد ولو لم توافر فيه جريمة الارتشاء، ويجوز قبول الرد إذا قدمت الهدية لشخص من أقارب القاضي المقيمين معه^(٤). ولكن رفض الهدية قبيل رفع الدعوى أو بعده لا يعتبر سبباً للرد^(٥)، وعلة الرد في هذه الحالات أنها مظنة وجود ود عميق وصداقة بين القاضي وأحد الخصوم، مما قد يؤثر على حياد القاضي. ٥- إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل (المادة ١٤٨ / ٤ مرافعات).

ولا يكفي لتحقيق هذا السبب مجرد وجود عداوة أو مودة، بل يجب أن تكون العداوة أو المودة لها تأثير على القاضي، ويصعب عليه الحكم بغير ميل^(٦).

(١) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ١٠٦ .

(٢) انظر التعليق على قانون المرافعات للدكتور / أحمد أبو الوفا ، المادة ١٤٨ تعليق " ه " .

(٣) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ١٠٦ .

(٤) أستاذنا الدكتور / عبد الباسط جمعي في مبادئ المرافعات ص ٢٢٧ هامش (١) .

(٥) الدكتور / أحمد أبو الوفا في التعليق على قانون المرافعات ، المادة ١٤٨ تعليق (٨) .

(٦) وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضي نفسه ، انظر الطعن رقم ٩٠ لسنة ٣٣ ق ، جلسة ٣ / ١٢ /

١٩٦٦ س ١٧ ص ١٩٥٥ .

ولكن لا يشترط في العداوة أن تكون شديدة تصل إلى حد الخصومة أمام القضاء أو أن تكون المودة وثيقة تصل إلى حد المؤاكلة أو المساكنة أو قبول الهدايا.

وهذا السبب سبب عام يشمل صوراً كثيرة تفيد العداوة أو المودة، ولكن القضاء يتشدد في القول بوجودها .

ويشترط أن تكون العداوة أو المودة سابقة على رفع الدعوى، ولا يعتد بهما إذا افتعلهما الخصم افتعالاً بعد رفع الدعوى ليصل إلى رد القاضي عن هذا الطريق^(١).

إجراءات التنحي الوجوبي :

إذا توافر سبب من أسباب الرد السابق ذكرها، وجب على القاضي أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال^(٢)، بسبب الرد القائم به، وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة " المادة ١٤٩ مرافعات".

والهدف من إخبار المحكمة في غرفة المشورة . وهي ذات الدائرة التي يرأسها القاضي أو يشترك في عضويتها، منعقدة في جلسة غير علنية - مجرد التداول في جدية سبب التنحي، والتأكد من توافره، ومن ثم يؤذن له بالتنحي^(٣).

إجراءات الرد :

إذا توافر سبب من أسباب رد القضية السابق ذكرها، وجب على القاضي التنحي من تلقاء نفسه، وإذا لم يقم القاضي بهذا الواجب من نفسه، فالأمر متروك للخصوم، ولكل واحد منهم يخشي من احتمال انحياز القاضي لقيام سبب من أسباب الرد أن يطلب رد القاضي، وقد أورد المقتن إجراءات رد القضية في المواد من ١٥١ - ١٦٤ مرافعات، وذلك على الوجه الآتي :

ميعاد تقديم الطلب:

يجب على طالب الرد أن يقدم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه^(٤)، على اعتبار أن الخصم قد قبل حكمه وتنازل عن رده ؛ لأن رد القاضي شرع لمصلحة طالب الرد، فله أن يباشره أو يتنازل عنه^(٥).

(١) قانون المرافعات دكتور/ محمد عبد الخالق عمر ١ / ٢٦٥، الوسيط، د/ رمزي سيف ٥٠.

(٢) تخبر المحكمة في غرفة المشورة إذا كان مستشاراً ، ويخبر رئيس المحكمة الابتدائية إذا كان قاضياً . الدكتور / عبد المنعم الشرقاوي في المرافعات المدنية والتجارية ف ١١٤ ، الدكتور أمينة النمر في قوانين المرافعات ف ٧٥ .

(٣) قانون القضاء المدني للدكتور / محمود هاشم ١ / ١٤٤ .

(٤) المادة ١٥١ / ١ مرافعات .

(٥) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي ص ٢٢٨ .

وإذا كان الرد في حق قاض ندبته المحكمة للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق كسماع الشهود أو للمعاينة، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد، وإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلامه بالقرار " المادة ١٥١ / ٢ مرافعات".

ويجوز تقديم طلب الرد بعد هذه المواعيد، إذا حدثت أسبابه بعدها أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بأسبابه إلا بعد مضي تلك المواعيد^(١). ولكن لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ولا يقبل ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى الأصلية المنصوص عليه في المادة ١٦٢ مرافعات^(٢). وبذلك سد المقتن الطريق على العابثين بهذا الحق ويعمدون إلى رد أحد القضاة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها فيطيلون أمد التقاضي ويعرقلون صدور الحكم بعد أن يكون النزاع قد قطع فيه شوطاً طويلاً، وقد كان ذلك ممكناً قبل التعديل^(٣).

طريقة تقديم الطلب:

يقدم طلب الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده^(٤)، يوقعه الطالب بنفسه أو وكيله المفوض في الرد بتوكيل خاص^(٥)، ويرفق التوكيل بالتقرير ويجب أن يشتمل التقرير على أسباب الرد، وأن تكون من الأسباب التي نص عليها القانون على وجه الحصر، ويجب أن يتضمن التقرير تعيين طالب الرد، وتعيين القاضي المطلوب رده، كما يجب أن يرفق بالتقرير ما يوجد من الأوراق المؤيدة له^(٦). وضمناً لجدية الطلب يوجب القانون على طالب الرد أن يودع عند التقرير ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة^(٧).

(١) المادة ١٥٢ / ١ مرافعات .

(٢) المادة ١٥٢ مرافعات معدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

(٣) المذكرة الإيضاحية للقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

(٤) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ٤٣٣ .

(٥) وليس لمحامي الخصم أن ينوب عنه في طلب رد القاضي إلا بتوكيل خاص . انظر الطعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٢٠ ق، جلسة ١٩٥١/٣/٢٦ .

(٦) المادة ١٥٣ / ١، ٢ مرافعات.

(٧) المادة ١٥٣ / ٢ معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ .

وإذا كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم، جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .

ويجب على طالب الرد أن يقيد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي، وإلا سقط الحق فيه (المادة ١٥٤ مرافعات)، ومن ثم فلا يكفي أن يبدي الخصم رغبته في رد القاضي ويثبت ذلك في محضر الجلسة^(١)، بل لابد من تأييد الطلب في قلم كتاب المحكمة التابع لها القاضي في الميعاد المذكور .

أثر تقديم الطلب :

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في الطلب^(٢) وقطعاً لأساليب التلاعب بحق رد القضاة أجاز المقنن لرئيس المحكمة أن يندب قاضياً ليجلس بدلاً من القاضي المطلوب رده، وأن يستمر في نظر الدعوى الأصلية، كما يأخذ طلب الرد طريقه للفصل فيه دون أن يؤثر على استمرار نظر القضية الأصلية باعتبار القاضي المطلوب رده قد أصبح بعيداً عنها . وبذلك لا يؤثر طلب الرد على سير الدعوى، ومن ثم لا يتخذ وسيلة للتعطيل وإطالة أمد التقاضي. وإذا طلب أحد الخصوم رد أحد مستشاري الدائرة التي تنظر طلب الرد، فلا يقبل هذا الطلب، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد^(٣).

وإذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه فلا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناءً على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسرى في هذه الحالة حكم المادة ١٦٢ مرافعات^(٤) .

إجابة القاضي على وقائع الرد وأسبابه :

أوجب المقنن في المادة ١٥٥ مرافعات على قلم كتاب المحكمة أن يرفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة، مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها، ويطلع الرئيس والقاضي المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلى النيابة، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه.

(١) راجع الطعن رقم ١٨٨٧ لسنة ٢٠ ق جلسة ٢٦ / ٣ / ١٩٥١ .

(٢) المادة ١٦٢ مرافعات .

(٣) المادة ١٥٧ / ٨ مرافعات .

(٤) المادة ١٦٢ مكرر من قانون المرافعات .

وإذا أجاز القاضي واعترف بقيام سبب من أسباب الرد، أو لم يجب في الميعاد المحدد، وكانت الأسباب المذكورة في التقرير تصلح قانوناً للرد، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحية القاضي^(١).

وإذا كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى، أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها، وتتلقى جوابه عنها، ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع في شأنه الأحكام المقررة " المادة ١٥٨ مرافعات " .

الاختصاص بطلب الرد :

يختلف الاختصاص بنظر طلب رد القضاة بحسب المحكمة التي يتبعها القاضي وعلى ذلك فإذا كان القاضي من قضاة المحكمة الجزئية أو الابتدائية فيختص بنظر طلب الرد إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي يقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده ، وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف غير الدائرة التي يكون المستشار المطلوب رده عضواً فيها^(٢) .

"ولا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية"^(٣).

نظر طلب الرد والحكم فيه :

إذا أجاز القاضي في الميعاد وأنكر أسباب الرد المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة وكانت الأسباب لا تصلح قانوناً للرد، فإن كان القاضي المطلوب رده أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد^(٤).

ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد – وهو رئيس محكمة الاستئناف إن كان القاضي المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية أو مستشاراً بمحكمة الاستئناف أو رئيس محكمة النقض إذا كان المطلوب رده مستشاراً بمحكمة النقض – يتولى هذا الرئيس تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.

(١) المادة ١٥٦ مرافعات.

(٢) المادة ١٥٣ مرافعات.

(٣) المادة ١٦٤ مرافعات.

(٤) أربعة أيام التالية لاطلاع القاضي على تقرير الرد ، وهذا ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي بطلان .

الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ١ / ٢٧١ .

ويقوم قلم كتاب المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد جديدة. وفي حالة تقديم طلبات رد جديدة قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق فعلى رئيس المحكمة أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد وذلك دون أن تنتظر المحكمة إجابة من القاضي عن وقائع الرد وأسبابه^(١). وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيقه في غرفة المشورة وتحكم فيه في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد وأقوال الخصوم الآخرين. إن كانوا يريدون إبداء طلبات رد خاصة بهم - كما تسمع ملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى.

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين له^(٢)، ويتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وذلك على أساس أن خصومة الرد هي خصومة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها، وإذا قضت المحكمة برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه فإنها تحكم من تلقاء نفسها^(٣) على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمئة جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.

وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على وجود عداوة أو مودة بين أحد الخصوم وبين القاضي يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ستة آلاف جنيه، وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.

ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته^(٤).

وينبغي على الحكم برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، أن تعود الخصومة الأصلية. التي وقفت عند تقديم طلب الرد. إلى السريان أمام القاضي الذي

(١) ١٥٨ مكرر من قانون المرافعات .

(٢) لإحاطة القاضي بضمانات تكفل له الاحترام ، خاصة وأنه في كثير من الحالات يكون توجيه الاستجواب مقصوداً به مجرد الرغبة في إحراج القاضي وتجريحه " المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات .

(٣) الدكتور / أحمد أبو الوفا في التعليق على المادة ١٥٩ تعليق " ٢ " .

(٤) المادة ١٥٩ مرافعات معدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ ، والقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

طلب رده^(١)، إلا إذا كان القاضي قد رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص، فإن هذا يزيل صلاحية هذا القاضي للحكم في الدعوى ويتعين عليه أن يتنحى عن نظرها^(٢) كما سبق القول.

وأما إذا قضت المحكمة بقبول طلب الرد، فإن القاضي يفقد صلاحيته لنظر الدعوى، ويتحمل طالب الرد مصاريفه ولا يتحملها القاضي : لأن القاضي المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في طلب الرد^(٣).

الطعن في الحكم :

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية^(٤)، ذلك أن خصومة الرد هي خصومة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها. وعلى هذا فلا يجوز استئناف الحكم إذا كان صادراً من محكمة لا يجوز الطعن في أحكامها بطريق الاستئناف كمحكمة الاستئناف أو محكمة النقض^(٥).

والحكم في طلب الرد على كل حال لا يقبل الطعن إلا من طالب الرد، ومن ثم فلا يجوز للقاضي أن يطعن في الحكم بالاستئناف : لأنه ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في طلب الرد، ولذلك لا يجوز استجوابه ولا توجيه اليمين إليه^(٦)، ولا يحكم عليه بالمصاريف^(٧)، وقد منحه القانون ضماناً أخرى، فأجاز له رفع دعوى تعويض على طالب الرد.

(١) الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ٤٣٤ .

(٢) المادة ١٦٥ مرافعات .

(٣) انظر: الطعن رقم ٩٦٧ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ٥ / ١ / ١٩٧٨ س ٢٩ ص ٩٦ ، ومن هذا الرأي الدكتور / محمد عبد الخالق عمر في قانون المرافعات ١ / ٢٧٢ ، الدكتور / أحمد أبو الوفا في التعليق على المادة ١٦٠ تعليق "٣" س ٢٣٣ ، وانظر عكس هذا للدكتور فتحي والي ، حيث يرى أن يلزم القاضي بالمصاريف وفقاً للقواعد العامة : لأن الأمر يتعلق بخصومة قضائية حقيقية . انظر: الوسيط ف ٤٣٤ ، وهامش "١" س ٨٨٧ ومن الرأي الأخير الدكتور رمزي سيف في الوسيط ف ٥٥ والدكتور / محمود هاشم في قانون القضاء المدني ١ / ١٤٨ .

(٤) المادة ١٥٧ مرافعات .

(٥) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور / عبد الباسط جميعي ص : ٢٣٢ ، وانظر الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٣٤ ق جلسة ٦ / ٢ / ١٩٦٩ س ٢٠ ص : ٢٦١ .

(٦) بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بديوي ، ص ١٨٣ .

(٧) انظر غير هذا : الدكتور / فتحي والي في الوسيط ف ٤٣٤ ، وهامش " ١ " ص ٨٨٧ الدكتور / أمينة النمري في الوجيز في قوانين المرافعات ف ٧٤ ، الدكتور / محمود هاشم في قانون القضاء المدني ١ / ٤٨ ، والدكتور / رمزي سيف في الوسيط ف ٥٥ .

وكذلك لا يجوز لخصم طالب الرد في الدعوى الأصلية أن يطعن في الحكم الصادر في طلب الرد ؛ لأن الأمر لا يتعلق بنزاع متفرع عن الدعوى الأصلية حتى يكون له الحق في الطعن في الحكم.

التنازل عن دعوى الرد :

ثار خلاف في الفقه والقضاء حول حق طالب الرد في التنازل عن دعواه، فذهب قول^(١) إلى أن دعوى الرد من الدعاوى التي لا يملك رافعها حق التنازل عنها فهي شبيهة بالدعوى العمومية إذا رفعت تعلق بها حق القضاء وحق القاضي المطلوب رده، وعلى ذلك يتعين السير في إجراءاتها حتى يفصل فيها، ولو قرر المدعى تنازله عنها، ولو قبل القاضي المطلوب رده التنازل ؛ لأنه ليس خصماً في الدعوى، وذلك لأن المصلحة العامة تقتضي أن يحكم في موضوعها صيانة للقضاء من الريب والشبهات .

وذهب قول آخر إلى أن للخصم أن يتنازل عن دعواه ؛ لأن رد القاضي حق مقرر للخصم وشرع لمصلحته، له أن يتمسك به أو يتنازل عنه، وليس للمحاكم أن تمنع قاضياً من الحكم لقيام سبب من أسباب الرد، ما لم يكن الخصم صاحب الحق في الرد قد طلبه في ميعاده المناسب له^(٢) .

وقد حسم هذا الخلاف بصدور القانون ٩٥ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وبمقتضاه أضيفت فقرة جديدة للمادة ١٥٩ يفهم منها جواز تنازل الخصم عن دعوى الرد حيث قالت : "وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة"، كما أضاف القانون المذكور المادة ١٦٢ مكرر تفيد نفس المعنى السابق، حيث قالت : "إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب آخر وقف الدعوى الأصلية ...".

(١) الدكتور / عبد المنعم الشرقاوي في المرافعات المدنية والتجارية ف " ١١ " ، الدكتور / أحمد أبو الوفا في التعليق . انظر: تعليق " ٣ " على المادة ١٥٩ ، وقد استند هذا القول إلى حكمين أولهما من محكمة الزقازيق الابتدائية في ١٢ يونية سنة ١٩٤٩ منشور بمجلة القضاة السنة ٣١ ص ٦٠١ ، وثانيهما حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية عدد ٢ ص ١٠٣ ، وانظر: حكم محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم ١٤٨ سنة ١٤ ق بتاريخ ١٩٦٢/١٠/٦ ، ذكره الدكتور/محمد كمال أبو الخير في قانون المرافعات ص ٥٠ .

(٢) من هذا الرأي الدكتور/رمزي سيف في الوسيط ص ٥٤ ، الدكتور / محمود هاشم في قانون القضاء المدني ١٤٦/١ ، الدكتور / محمد كمال أبو الخير في قانون المرافعات ص : ٥٠٢ ، وانظر: حكم محكمة المنصورة الابتدائية في الدعوى رقم ٤٣٦ لسنة ١٩٥٥ ، كلي بتاريخ ١٩٥٥/٩/٢١ ، وحكمها في الدعوى رقم ٦٦٩ ، لسنة ١٩٥٧ بتاريخ ١٩٥٧/١٠/١٩ ذكرهما الدكتور / محمد كمال أبو الخير في المرجع المذكور ، ص ٥٠١ ، ٥٠٣ .

وبعد تعديل المادة ١٥٩ مرافعات بالقانون ٢٢ لسنة ١٩٩٢ نص المقتن صراحة على حق طالب الرد في التنازل عن طلبه، بل وأعفاه من الغرامة إذ تنازل عن طلب الرد في الجلسة الأولى. وهذه النصوص تؤكد أن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد، شأنه في ذلك شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه، ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة ١٤٢ / ١ مرافعات، من أن التنازل لا يتم بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله؛ لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة^(١).

حماية القاضي من نفسه في النظام القضائي الإسلامي:

حماية القاضي من نوازع الشرفية . كإنسان، ومحافظة عليه حتى يكون في المكان اللائق به، منع من بعض التصرفات التي قد تفتح أبواب الشرعية. ومن التصرفات التي يمنع منها القاضي : قبول الهدية من الشخص الذي لم يكن يهديه قبل القضاء، لأن حدوث الإهداء بعد القضاء دليل على استمالته، حتى يصل المهدي إلى ميل قلب القاضي معه ضد خصمه، ومن ثم فلا يجوز قبولها كالرشوة^(٢).

ويمتنع القاضي عن البيع والشراء وما في معناهما بنفسه^(٣) : لأن القاضي يعرف فيحايي فيكون في معنى الهدية أو الرشوة. كما يمنع القاضي من طلب الحوائج من الناس، كقضاء مصلحة له واستعارة سيارة أو ما إلى ذلك. ويمنع القاضي من زيارات الناس إلا الذي ولاه، لأن من دونه رعية^(٤).

ويمتنع على القاضي أن ينظر دعوى لنفسه أو لزوجه أو أقاربه ولكل من لا تقبل له شهادة على القول الراجح، وتنظر دعواه أو دعوى واحد من هؤلاء أمام قاض آخر^(٥). كما يمتنع على القاضي أن ينظر دعوى لعدوله ؛ لأن شهادة العدو على عدوه غير مقبولة، فكذلك القضاء، ويجب عليه أن ينبذ غيره إن كان مأذوناً له في الاستنابة^(٦).

(١) انظر: الطعن رقم ٩٦٧ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ١٩٧٨/١/٥ ، س ٢٩ ص ١٩٦٧ .

(٢) بخلاف ما كان يهديه قبل القضاء ، حيث يقبل القاضي هديته ؛ لأن وجودها قبل القضاء دليل على أنها ليست من أجله.

(٣) لما روى أن عمر بن الخطاب كتب إلى القاضي شريح " لا تسار ولا تضار ولا تبع ولا تشتري في مجلس القضاء .

(٤) معين الحكام للطرابلسي ص : ١٥ ، ١٦ ، المغني لابن قدامة ١٠ / ٦٨ ، ٦٩ .

(٥) الفواكه البدرية لابن العربي ص ١٣٧ ، الأحكام السلطانية للماوردي ص : ٧٥ ، ٧٦ ، المغني لابن قدامة ١٠ / ٩٣ .

(٦) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥٧ ، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٨٦ .

المبحث الثاني

أعضاء النيابة العامة

"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله"^(١).

و"يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، ذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله"^(٢).

أولاً: وظيفة النيابة العامة وتبعية أعضائها:

سلطة التصدي لفصل الخصومات وإصدار الأحكام منوطة بالقضاة، ويعاونهم في النهوض بهذه المهمة مجموعة من الأعوان، يأتي في مقدمتهم أعضاء النيابة العامة، ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم المختلفة -عدا محكمة النقض- النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين، وتكون له جميع اختصاصاته^(٣).

ورجال النيابة لا يتبعون السلطة القضائية، ولكن يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم، وهم جميعاً تابعون لوزير العدل، المادة ٢٦ من قانون السلطة القضائية وأما محكمة النقض فتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لديها نيابة عامة مستقلة، ولها بناء على طلب المحكمة حضور مداوالات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثليها صوت معدود في المداوالات.

(١) المادة ١٨٩ من الدستور المصري الصادر ٢٠١٤م.

(٢) المادة ١١٩ من قانون السلطة القضائية.

(٣) المادة ٢٠١/٢٣ من قانون السلطة القضائية، معدلة بالقانون ١٣٨ لسنة ١٩٨١.

ثانياً: صلة النيابة بالقضاء:

لا يعتبر رجال النيابة من رجال القضاء، وإنما هم من رجال السلطة التنفيذية يمثلونها أمام المحاكم، ومع هذا فالنيابة تعتبر من الجسم القضائي، ورجالها من رجال القانون يعملون على تنفيذه^(١)، ومن هنا جاءت تسميتهم بـرجال القضاء الواقف، وسموه كذلك لأنهم يؤدون أعمالهم وهم وقوف وتميزاً لهم عن القضاة فهم رجال القضاء الجالس، لأنهم يؤدون أعمالهم وهم جلوس، ولذلك يحرص المقنن المصري دائماً على أن يجمع بين رجال النيابة ورجال القضاء في أمور كثيرة، منها وجوب توافر شروط شغل وظيفة القاضي فيمن يعين عضواً بالنيابة، وتعيين أعضاء النيابة في وظائف القضاء، ونقل رجال القضاء إلى وظائف النيابة، وسريان أحكام عدم الصلاحية، والرد والمخاصمة، وألا يكون لعضو النيابة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية بالقاضي الذي ينظر الدعوى^(٢).

ولكن نظراً لطبيعة عملهم وارتباطهم بالسلطة التنفيذية فهم لا يتمتعون بكل مزايا القضاة وضماناتهم، ومن ثم ف ضمانات ترقية رجال النيابة ونقلهم وتأديبهم دون الضمانات المقررة للقضاة^(٣)، وهم تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل^(٤).

والنيابة مستقلة عن المحاكم استقلالاً يكاد يكون تاماً، فلا تملك المحاكم أن تصدر للنيابة أمراً (مع مراعاة حكم المادة ٩٠ مرافعات)^(٥) ولا أن توجه لوماً للنيابة أو لواحد من أعضائها، وليس لرؤساء المحاكم إشراف إداري على أقلام النيابة بحاكمتهم، ومن الجهة الأخرى فليس لأعضاء النيابة أن يتدخلوا في أعمال القضاة، ولا أن يحضروا مداولاتهم (مع مراعاة حكم المادة ١/٢٤ معدلة بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٨١)^(٦).

وللنيابة العامة وظيفة أساسية تتعلق بالدعوى الجنائية، فلها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون خلاف ذلك^(٧)، ولها وظيفة أخرى مدنية، حيث

(١) الدكتور/ مصطفى كوة في قانون المرافعات الليبي ص ١٧٣، ١٧٤.

(٢) قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمرف ٧٩.

(٣) قواعد المرافعات لمحمد العشماوي والدكتور عبد الوهاب العشماوي ف ١٣٨.

(٤) المادة ٢٦ من قانون السلطة القضائية.

(٥) حيث تجيز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، وفي هذه الحالة يكون تدخل النيابة وجوبياً.

(٦) حيث يكون لنيابة النقض بناءً على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثل النيابة صوت معدود في المداولات. (انظر قواعد المرافعات لأستاذنا المرحوم الدكتور عبد الباسط جميعي ص ٢٤٧، قانون المرافعات للدكتور / محمد عبد الخالق عمر ١ / ٣٠٩).

(٧) المادة ٢١ من قانون السلطة القضائية.

أجاز لها أو أوجب عليها أن تتدخل في بعض الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتهمنا وظيفتها الأخيرة.

ثالثاً: وظيفة النيابة العامة أمام القضاء المدني :

تشارك النيابة العامة في الدعاوى المدنية باعتبارها خصماً أصلياً أو طرفاً منضمماً، فإن هي أقامت الدعوى أمام المحكمة، تكون خصماً حقيقياً لمن رفعتها عليه، وتعتبر أنها تعمل بطريق الادعاء، وتوصف بأنها طرف أصلي في الخصومة، أما إذا تدخلت في خصومة قائمة بين طرفين لتدلي برأيها اعتبرت أنها تعمل بطريق إبداء الرأي ووصفت بأنها طرف منضم.

رابعاً: طرق قيام النيابة العامة بوظيفتها في الدعوى المدنية:

تزداد صلة النيابة العامة بالوظيفة القضائية بما منحت إياه من اختصاصات في المسائل والمنازعات المدنية، تخفيفاً ومعوّنة للقضاء من ناحية، واتجاهاً نحو العمومية في بعض المسائل من ناحية أخرى. وعلى الرغم من الدور المحدود للنيابة العامة في الدعوى المدنية، والذي نظمته المشرع في المواد (٨٧-٩٦) مرافعات، فإن ذلك لا ينفي مدى أهمية هذا الدور. والذي تباشره من خلال أحد ثلاث طرق، أولها الادعاء أو الدفاع، وثانيها التدخل في الدعوى، أما الثالث فيتمثل في الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى في حالات معينة^(١)، وذلك على النحو التالي:

الطريق الأول: الادعاء والدفاع (النيابة كطرف أصلي في الدعوى):

قد تباشر النيابة العامة وظيفتها في الدعوى المدنية عن طريق الادعاء أو الدفاع، باعتبارها مدعية أو مدعى عليها، وسواء قامت النيابة بدور الادعاء أو بدور الدفاع، فإنها في الحالتين تعتبر طرفاً في الخصومة ويكون لها ما للخصوم من حقوق.

فالنيابة العامة الحق في رفع دعوى أصلية أو مبتدأة أي أن تكون مدعية بمعنى أنها صاحبة الحق في الدعوى وذلك في بعض الحالات التي نص عليها القانون، أما في غير هذه الحالات فلا يجوز لها أن ترفع الدعوى ولو تعلق الأمر بالنظام العام، إذ نصت المادة (٨٧) مرافعات على أن "للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق".

ومثال ذلك أن ترفع النيابة العامة دعوى شهر إفلاس إعمالاً للمادة (٥٥٢) من القانون التجاري، أو أن ترفع دعوى الحسبة إعمالاً لما نص عليه القانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٦، أو أن

(١) د. أحمد سيد صاوي، ص ١٦٥ - د. أحمد هندي، قانون المرافعات (النظام القضائي)، ص ١٨٠ - م. سيد حسن

البغال، المطول، ج ١/٤٦٤ - د. فتحي والي، ص ٤٠١.

ترفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب، إعمالاً لنص المادة (٦) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠.

وإلى جانب هذه الحالات التي تقف فيها النيابة العامة موقف المدعية: فإنها قد تكون مدع عليها في بعض الدعاوى، وذلك عندما يعترض شخص على قرار اتخذته بموجب سلطتها الولائية، فحينئذ تقوم خصومة مدنية بين المعارض والنيابة تقف فيها موقف المدعى عليها^(١).

وحالما تكون النيابة العامة طرفاً في الخصومة (مدعية أو مدعى عليها)، فإنها تأخذ مركز الخصم ويكون لها ما للخصوم من حقوق، فيكون لها توجيه سير الخصومة وإبداء الطلبات والدفع وتوجيه الحجج وأدلة الإثبات، كما أن لها الطعن في الحكم الذي يصدر على خلاف طلباتها بطريقي الاستئناف والنقض، إذا لم تجب إلى طلباتها، كما يكون عليها ما على الخصوم من واجبات وأعباء^(٢).

الطريق الثاني: التدخل في الدعوى:

قد تتدخل النيابة العامة في دعوى قائمة بالفعل أمام القضاء، وهي إذ تفعل ذلك لا تكون خصماً في الدعوى وإنما مجرد عون للمحكمة، إذ تتولى بحث القضية وإبداء الرأي فيها، ولئن كان رأي النيابة لا يعد حكماً قضائياً ولا تنقيحاً به المحكمة، إلا أنه في الواقع يمهد للحكم القضائي وله قيمة أدبية في نظر المحكمة باعتباره رأياً محايداً لا وجهة نظر خصم معين، ولذلك فإن النيابة في حالة التدخل تمارس نوعاً تمهيدياً من القضاء أو لونا من الفتوى، ولذلك أجاز القانون للخصوم ردها في حالة التدخل، وهو ما لا يجوز حين تكون طرفاً أصلياً^(٣).

والهدف من تدخل النيابة العامة في الدعوى هو ضمان تطبيق القانون، وأن يحدث هذا التطبيق بالنظر إلى المصلحة العامة التي استهدفها القاعدة القانونية المطبقة، باعتبار أن التدخل يهدف إلى معاونته القضاء وتوضيح الجوانب المختلفة للمسألة المعروضة عليه ضماناً لحسن تطبيق القانون. والنيابة إذ تتدخل في الدعوى لا تعتبر خصماً منضمّاً لأحد الخصوم، ومن ثم فلا يصح تسميتها حينئذ بالطرف المنضم لأن الطرف يسعى دائماً -ولو كان منضمّاً- للدفاع عن مصلحة ذاتية، في حين أن النيابة العامة تسعى بتدخلها إلى تطبيق القانون. كما أنها في تدخلها لا تنضم إلى أحد طرفي الخصومة وإنما تمثل المصلحة العامة في خصومة قائمة بين طرفين^(٤).

(١) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٤٠٢.

(٢) المرجع السابق، ص ٤٠٢.

(٣) المستشار. سيد حسن البغال، المطول، مرجع سابق، ج ٤٦٩/١.

(٤) د. أحمد هندي، قانون المرافعات (النظام القضائي)، ص ١٨٢ - د. فتحي والي، الوسيط، ص ٤٠٣.

عدم جواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى المستعجلة:

لا يجوز للنيابة العامة أن تتدخل مطلقا في الدعاوى المستعجلة (المادتان ٨٨، ٨٩) حيث رأى المشرع أنه لا حاجة إلى تدخل النيابة في هذه الدعاوى حتى لا يعوق تدخلها فيها الفصل في الدعوى، فضلا عن أن ما يصدره القضاء المستعجل من قرارات لا يمس أصل الحقوق. ومن ثم فإن الحديث عن تدخل النيابة العامة مقصور على الدعاوى الموضوعية دون المستعجلة.

حالات تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية:

يتخذ تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية إحدى صورتين، فإما أن يكون التدخل وجوبيا بحيث يكون الحكم الصادر في الدعوى باطلا إذا لم تتدخل، وإما أن يكون جوازيا بحيث لا يؤثر عدم تدخلها في صحة الحكم. وذلك على النحو الآتي:

أ- حالات التدخل الوجوبي:

نص المشرع على عدة حالات يجب فيها على النيابة العامة أن تدخل في الدعوى القائمة وإلا كان الحكم باطلا لعدم تدخلها، وسواء كانت الدعوى قد أقيمت بصورة أصلية أو في صورة طلب عارض أو دعوى فرعية. وهذه الحالات ورد النص عليها في المادتين (٨٨ و ٩٠) مرافعات، وتنقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: جميع الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة أن ترفعها بنفسها.

الثاني: الحالات التي ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

الثالث: الطعون والطلبات أمام محكمة النقض.

الرابع: التدخل بناء على أمر المحكمة.

ومن ثم فإنه إذا رفعت إلى المحكمة دعوى من الدعاوى التي يكون للنيابة العامة أن ترفعها بنفسها، كدعوى شهر الإفلاس، فإن عليها أن تتدخل فيها وإلا كان الحكم باطلا. وكذلك الحال إذا كانت الدعوى من الدعاوى التي نص القانون على وجوب تدخل النيابة العامة فيها، ومثالها مانصت عليه المادة (٢/٦) من قانون الأحوال الشخصية من أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.

كما يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الطعون والطلبات أمام محكمة النقض سواء تعلقت بمسألة مدنية أو تجارية أو مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، ذلك أن قضايا النقض تمس الصالح العام بما تثيره من مسائل قانونية عامة يؤدي الفصل فيها إلى حسم خلاف المحاكم بشأنها، إذ تنقيد أدبيا المحاكم الأدنى بالمبدأ القانوني الذي قرره حكم النقض، الأمر

الذي يساعد في النهاية على توحيد القضاء، ومن هنا كانت مساعدة النيابة بما تقدمه من بحث في هذه القضايا يعتبر عوناً ضرورياً ومفيداً^(١).

كما أنه يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبياً (مادة ٩٠ مرافعات). ذلك أن دعوة المحكمة للنيابة العامة بالتدخل هو تسليم منها برغبتها في الاستعانة برأي النيابة في الدعوى وعلى اعتبار أن النيابة هي الممثلة للمصالح العام والأمانة على مصلحة القانون، ولأنه لا يصح حرمان القضاء من عون ضروري سعى هو إلى طلبه تحقيقاً للعدالة وبهذا تتحقق الجدوى من إرسال ملف الدعوى للنيابة^(٢).

ب- حالات التدخل الجوازي:

وفقاً لنص المادة ٨٩ مرافعات، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الدعاوى الآتية:

- ١- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
 - ٢- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.
 - ٣- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
 - ٤- دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
 - ٥- الصلح الواقي من الإفلاس.
 - ٦- الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
 - ٧- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
- وفي كل حالة من الحالات السابقة يجوز للنيابة العامة التدخل أمام درجتي التقاضي سواء كانت المسألة التي تجيز تدخلها قائمة منذ رفع الدعوى أو عرضت أثناء نظرها. وتقدير التدخل من عدمه في الحالات الجوازية متروك للنيابة العامة، فلها أن تتدخل أو لا تتدخل وفقاً لما تراه في هذا الشأن، ولا يؤثر عدم تدخلها في الدعوى في الحالات الجوازية على صحة الحكم الصادر فيها^(٣).

الطريق الثالث: الطعن في الأحكام:

للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك (مادة ٩٦).

(١) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ١٦٧.

(٢) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات.

(٣) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ١٧٠.

وهذا النص له فائدته المحققة في تصويب الأحكام التي تنطوي على مخالفة للنظام العام في الحالات التي لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أو لها التدخل فيها، ففي هذا النص رخصة للنيابة أن تتدارك ما فاتها من التدخل. والنيابة العامة في استعمال هذه الرخصة مقيدة بالمواعيد، وبأن يكون الحكم قابلاً للطعن فيه^(١).

ولا شك أن للنيابة العامة حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى إذا كانت قد رفعتها بنفسها وكان الحكم لم يقض لها بكل طلباتها، وذلك باعتبارها طرفاً أصلياً في هذه الحالة. أما في حالة التدخل فإنها لا تعتبر خصماً في الدعوى، ولا يتصور اعتبارها محكوماً لها أو عليها، ومن ثم يكون الأصل عدم جواز الطعن منها في الحكم الصادر في الدعوى في حالة من حالات التدخل، إلا أنه استثناء من هذا الأصل قرر المشرع منحها سلطة الطعن في الحكم إذا تدخلت في الدعوى، وذلك في حالتين^(٢):

الحالة الأولى: إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام:

وفي هذه الحالة يكون للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إذا كان صادراً في حالة من حالات التدخل الوجوبي أو الجوازي، وسواء تدخلت في الدعوى أو لم تتدخل، إذ يكون لها الطعن في الحكم في حالة من حالات التدخل ولو لم تكن قد تدخلت بالفعل، إذ يعد الطعن في هذه الحالة تداركاً لما فاتها بسبب عدم تدخلها.

الحالة الثانية: إذا نص القانون على تخويل النيابة الطعن في الحكم في حالة معينة:

وفي هذه الحالة لا يشترط أن يكون الحكم مخالفاً لقاعدة من قواعد النظام العام، وإنما يكون للنيابة العامة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى وإن لم يكن مخالفاً لقاعدة من قواعد النظام العام متى كان القانون قد خولها حق الطعن.

فإذا تم رفع الطعن من النيابة العامة أياً كان طريقه، كان لها سلطات وحقوق الطاعن، كما تكون عليها واجباته وأعباءه المختلفة.

إخطار النيابة العامة بالدعوى للتدخل فيها:

في جميع الدعاوى التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبارها كتابة بمجرد قيد الدعوى (مادة ٩٢ مرافعات)، فسواء كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب أو يجوز تدخلها فيها، فإن على قلم الكتاب بمجرد قيد الدعوى أن يخطر

(١) تقرير اللجنة التشريعية.

(٢) د. أحمد مليحي، الموسوعة الشاملة، ج ٢/٥٨.

النيابة كتابة بالدعوى، ثم يرسل لها ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم، وذلك حتى تعلم النيابة العامة بوجود خصومة مما يجب أو يجوز تدخلها فيها، فتقوم بما يقرره القانون حيال ذلك^(١).

يترتب على عدم إخطار النيابة بالدعوى بطلان الحكم، باعتبار أن هذا الإخطار بيان جوهري لصحة الحكم ولو كانت الدعوى في حالة من حالات التدخل الجوازي، إذ في عدم إخبارها في هذه الحالة تفويت لفرصة علمها بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها، وحرمان لها من إبداء الرأي الذي قد يتغير به وجه الحكم في الدعوى. وإذا كان تدخل النيابة العامة مقصودا به حماية مصلحة خاصة بالخصوم، كما هو الحال بالنسبة لقضايا القصر، فإن البطلان هنا بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته. ولا يحكم بالبطلان رغم عدم الإخطار إذا علمت النيابة بقيام الدعوى وتدخلت فيها، وذلك لتحقيق الغرض من الإخطار في هذه الحالة^(٢).

وإذا كان إخطار النيابة العامة واجب على قلم الكتاب في حالة رفع الدعوى ابتداء على النحو السابق، فإنه إذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة من مسائل تدخل النيابة فإن إخطارها يكون بناء على أمر من المحكمة، وهذا الإخطار واجب سواء كانت الدعوى بشأن حالة من حالات التدخل الوجوبي أو الجوازي.

كيفية تدخل النيابة العامة:

حرص المشرع على تمكين النيابة العامة من التفريغ لأداء رسالتها، فنص في المادة (٩١) على أنها تعتبر ممثلة في الدعوى متى قدت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك، وفي جميع الأحوال لا يتعين حضورها عند النطق بالحكم.

وتمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم (مادة ٩٣). ويكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها (مادة ٩٤).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٢/٧٤٤.

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ١٧٣.

المبحث الثالث

أعوان القضاء

أعوان القضاء مجموعة من الأشخاص يعاونون القضاة في النهوض بالوظيفة القضائية ويساعدون المتقاضين في الأعمال القضائية، ويؤدون أعمالاً جوهرية في العملية القضائية، ويسهمون في حسن سير القضاء .

ويمكن تقسيم هؤلاء الأشخاص إلى طوائف بحسب الأعمال المنوطة بكل طائفة، فمنهم الكتاب وأمناء السر، المنوط بهم الأعمال الكتابية، ومنهم المحضرون المكلفون بتسليم الإعلانات والقيام بإجراءات التنفيذ، إلى جانب الخبراء والمترجمين والمحامين فهم يؤدون أعمالاً هامة تعين القضاة وتشاركهم في بيان وجه الحق .

وقد نصت المادة ١٣١ من قانون السلطة القضائية على أن " أعوان القضاة هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتابة والمحضرون والمترجمون "(١). وفيما يلي نتناول كل طائفة من هذه الطوائف مخصصين مطلباً لكل طائفة .

المطلب الأول

الكتاب وأمناء السر

هم طائفة من العاملين بالمحاكم يعاونون رجال القضاء فيما يتعلق بالأعمال الكتابية، وقد نصت المادة ١٣٥ / ١ على أنه " يعين بمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له، وعدد كاف من رؤساء الأقسام والكتاب " .

وكتاب المحكمة قسمان : كتاب القسم المدني ويتبعون كبير الكتاب، ورئيس المحكمة، وكتاب النيابة أو القلم الجنائي، ويتبعون رئيس القلم الجنائي ورئيس النيابة بالمحكمة (٢).

(١) على الرغم من أن النيابة العامة تقدم عوناً مباشراً في العملية القضائية على الوجه سالف الذكر، إلا أن العرف جرى على ضم أعضاء بالنيابة العامة إلى رجال القضاء ، وأفراد بقية أعوان القضاء بهذا العنوان " أعوان القضاء " وتبعاً لهذا العرف أفردنا الفصل الثاني للحديث عن النيابة العامة والفصل الثالث للحديث عن بقية أعوان القضاء ، وقد صار قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على هذا العرف أيضاً . انظر أصول في المرافعات للدكتور أحمد مسلم ف ١٣٣ حاشية ٢ .

(٢) المادتان ١٤٧ ، ١٦٤ من قانون السلطة القضائية ، وانظر أصول المرافعات للدكتور / أحمد مسلم ف ١٣٤ .

وقد أجازت المادة ١٣٩ من قانون السلطة القضائية تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها في وظائف أمناء سر بالمحاكم والنيابة العامة أقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ، وتشجيعاً للحاصلين على المؤهل المذكور على شغل هذه الوظائف أجاز القانون تعيين من يظهر كفاية ممتازة في عمله في وظيفة معاون نيابة^(١).

وتنأط بالكتاب مجموعة أعمال منها :

- ١- تلقي الدعاوى وقيدها في الجدول، وتقدير الرسوم القضائية، وتحصيلها وتحديد مواعيد الجلسات، وإرسال الأوراق إلى قلم المحضرين لإعلانها وإبلاغ النيابة العامة بالدعاوى التي تتدخل فيها .
 - ٢- الحضور مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات، وتدوين المحاضر ولا تصح جلسات المحاكم إلا بحضور الكاتب^(٢)، وكتابة الأحكام والتوقيع عليها وعلى صورها ولا تستكمل الأحكام شكلها إلا بتوقيع الكاتب مع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية " المسودة " ووضع الصيغة التنفيذية على الأحكام، وتسليم الصورة التنفيذية للمحكوم له، وتوقيعها وختمها بخاتم الدولة .
 - ٣- حفظ الملفات والوثائق والسجلات بالمحكمة واستخراج الصور والشهادات منها .
- وقد نظم قانون السلطة القضائية قواعد تعيين الكتاب وترقيتهم وتوزيع الأعمال عليهم في المواد من ١٣٧-١٤٧ .

ويلتزم الكتاب بعدم إفشاء أسرار القضايا، كما يلتزمون بإطلاع من يبيح له القانون أو اللوائح أو التعليمات على القضايا دون غيرهم .

ويلتزمون أيضاً بعدم مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة؛ وإلا كان هذا العمل باطلاً ويتعلق البطلان بالنظام العام^(٣). وغني عن البيان أن الكتاب لا يعتبرون من رجال القضاء، ولا يتمتعون بحقوقهم وضمائماتهم .

(١) بحوث في قواعد المرافعات للدكتور / عبد العزيز بدوي ص ١٤٤ .

(٢) وإلا ترتب على ذلك البطلان وهو يتعلق بالنظام العام . انظر المادة ٣٥ مرافعات .

(٣) الدكتور أمين النمر في قوانين المرافعات ف ٩٥ ، أستاذنا المرحوم الدكتور / عبد الباسط جمعي في مبادئ

المرافعات ص ٢٩٢ ، الدكتور / مصطفى كيرة في قانون المرافعات الليبي ص ١٨١ .

المطلب الثاني

المحضرون

وهم موظفون عموميون بالمحاكم يختصون بتسليم الإعلانات القضائية والقيام بأعمال التنفيذ^(١)، وقد نصت المادة ١٣٥ / ٢ من قانون السلطة القضائية على أنه: "يعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين". ويوجد بالمحكمة الجزئية قلم محضرين يعمل كفرع من قلم المحضرين بالمحكمة الابتدائية. ولا توجد أقلام محضرين بمحاكم الاستئناف أو بمحكمة النقض^(٢).

والمحضر قد يكون محضر إعلان يختص بتسليم الإعلانات القضائية، وقد يكون معاون تنفيذ يختص باتخاذ إجراءات تنفيذ السندات التنفيذية والقيام بالحجوز التحفظية، وقد يجمع المحضر بين الاختصاصين، وتوزيع العمل بهذا الشكل هو توزيع داخلي للعمل لا يترتب على مخالفته جزاء قانوني من بطلان أو سقوط أو نحو ذلك^(٣). وقد نظم قانون السلطة القضائية قواعد تعيين المحضرين وترقيتهم ونقلهم وتوزيع الأعمال عليهم في المواد من ١٤٨ - ١٥٥.

وقد أجازت المادة ٣٩ من قانون السلطة القضائية تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق في وظيفة معاون قضائي بأقلام المحضرين، وأجازت تعيين من يظهر كفاية ممتازة في وظيفة معاون نيابة إذا استوفى الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة.

والمحضر في أداء وظيفته لا يعتبر وكيلاً عن أحد الخصوم، وإنما هو مفوض في قبض الدين عند عرضه عليه، وفي إعطاء المخالصة، وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص "المادة ٢٨٢ مرافعات".

ولا يجوز للمحضر أن يباشر عملاً يدخل في حدود وظيفته في الدعاوى الخاصة به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره للدرجة الرابعة، وإلا كان العمل باطلاً ويتعلق البطلان بالنظام العام^(٤). ولا يعتبر المحضر من رجال القضاء ولا يتمتع بضماناتهم.

(١) المادة ٦ مرافعات.

(٢) الوسيط للدكتور / فتحي والي ف ١٣٣.

(٣) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور / عبد الباسط جمعي ص ٢٩٣.

(٤) انظر المادة ٢٦ مرافعات.

المطلب الثالث

(^١) الترجمان (المترجم)

الترجمان هو المعبر عن حديث بلغة غير لغة المتحدث ويجب أن: "يلحق بكل محكمة العدد (٢) اللازم من المترجمين يعاونون القضاة في التعبير عن أقوال الخصوم أو الشهود باللغة العربية إذا أدلوا بأقوالهم أو شهادتهم بلغة أخرى وذلك لأن "لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحاكم أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون بها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين" (٣).

وقد بين قانون السلطة القضائية قواعد تعيين المترجمين ونقلهم وترجمتهم في المادة ١٥٧ منه. ويقوم الترجمان بعمله شفويًا بالجلسة، أو يترجم مذكرات أو مستندات مكتوبة ويقدم ترجمتها تحريريًا.

ولا يجوز للترجم أن يترجموا أقوالاً أو مذكرات أو مستندات أو غيرها في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أوصيائهم للدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً. ولا يعتبر الترجمان من رجال القضاء ولا يتمتع بشيء من حقوقهم أو ضماناتهم.

المطلب الرابع

الخبراء

الخبراء أشخاص ذوو معارف فنية يستعين بهم القضاء في الأمور التي يستلزم تحقيقها هذه المعارف، كالطب والهندسة والزراعة والخطوط (٤).

وندد الخبراء جوازي للمحكمة، فقد تأمر به من تلقاء نفسها كندب خبير لتقدير قيمة الدعوى المنصبة على عقار لم تربط عليه ضريبة، أو لإجراء معاينة أو لإثبات حالة، وقد تأمر

(١) ترجم فلان كلام فلان إذا بينه وأوضحه، وترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم، واسم الفاعل ترجمان وبه لغات أجودها فتح التاء وضم الجيم والثانية ضمهما معاً بجعل التاء تابعة للجيم والثالثة فتحهما بجعل الجيم تابعة للتاء والجمع تراجم "المصباح المنير ١ / ٩١، طبع الأميرية سنة ١٩٠٦.

(٢) المادة ١٥٦ من قانون السلطة القضائية، وبالرغم من ذلك فالواقع أن الجهاز القضائي يعاني عجزاً شديداً جداً في المترجمين نتيجة ضعف المرتبات المقررة لهم، وقد تظاهرت الشكوى من ذلك حيث تخلو غالبية المحاكم من مترجمين، وقد درجت المحاكم على الاستعانة بترجمان يقدمه أحد الخصوم وحسناً ففعلت.

(٣) المادة ١٩ من قانون السلطة القضائية.

(٤) أستاذنا المرحوم الدكتور / عبد الباسط جميعي في مبادئ المرافعات ص: ٢٩٠.

المحكمة بنذب خبير بناءً على طلب الخصوم، وإذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم^(١).

وفيما عدا هذه الحالة فللمحكمة أن تندب خبيراً واحداً أو ثلاثة خبراء من بين المقبولين أمامها، إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة، وعندئذ يجب على المحكمة أن تبين هذه الظروف في الحكم (المادة ١٣٦ / ٢ من قانون الإثبات).

وعند ندب خبير من غير المقيدين بالجدول وجب أن يحلف أمام قاضي الأمور الوقتية. وبغير ضرورة لحضور الخصوم - يميناً أن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان عمله باطلاً^(٢)، وهو بطلان مقرر لمصلحة الخصوم وليس متعلقاً بالنظام العام^(٣).

وينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة، ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديتهم^(٤) قانون الخبرة رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون ٦٢٦ لسنة ١٩٥٥، كما نظم الشارع الاستعانة بالخبراء في قانون الإثبات ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

وينقسم الخبراء إلى طائفتين :

- ١- خبراء جدول وهم الخبراء المقبولين أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، ويطلق عليهم اسم الخبراء الأهليين، لأنهم ليسوا موظفين.
- ٢- خبراء وزارة العدل، وهم موظفون فنيون تابعون للوزارة المذكورة ينهضون بعبء الخبرة أمام المحاكم.

ويمكن للمحاكم أن تستعين بخبراء خارجين غير خبراء الجدول وخبراء الوزارة، وقد يكون الخبير الخارجي موظفاً، ولكنه ليس من الخبراء المقبولين لدى المحاكم كأساتذة الهندسة والطب وغيرهم، وقد يكون الخبير الخارجي غير موظف، وقد أباح المقنن للمحاكم أن تستعين بمن ترى عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني من غير خبراء الجدول وخبراء وزارة العدل.

ويمكن للخصوم الاستعانة بخبراء خارجيين يقدموا تقارير استشارية، وقد يكون لتقرير الخبير الاستشاري أثره في ترجيح رأي فني على آخر^(٥).

(١) المادة ١٣٦ / ١ من قانون الإثبات

(٢) المادة ١٣٩ من قانون الإثبات

(٣) قوانين المرافعات للدكتورة أمينة النمر ٩٤.

(٤) المادة ١٣٤ من قانون السلطة القضائية.

(٥) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور / عبد الباسط جمبجي ص ١٩١.

وسواء كان الخبير من خبراء الجدول المقبولين أمام المحاكم، أم من خبراء وزارة العدل، أم من غيرهم فرأيه لا يقيد المحكمة^(١).

ورغم أن رأي الخبير استشاري لا يقيد المحكمة، إلا أن لرأيه قيمة أدبية أمام المحكمة وقد يكون محدداً لاتجاهها، ولذلك يجب أن تتوافر فيه الحيدة المطلقة، ومن هنا فقد أجاز المقتن رد الخبير متى توافرت حالة من الحالات التي ذكرتها المادة ١٤١ من قانون الإثبات، وقد جمعت هذه المادة بين بعض أسباب عدم صلاحية القضاة للحكم وبين بعض أسباب ردهم^(٢).

ولكن "لا يقبل من أحد الخصوم رد الخبير المعين بناءً على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه"^(٣). وقد بين قانون الإثبات إجراءات الخبرة، وواجبات الخبير وحقوقه، وأسباب الرد وإجراءاته.

المطلب الخامس

المحامون

المحامون طائفة من المشتغلين بالقانون، يسدون النصح للخصوم، ويصرفون أمورهم القضائية، ويدافعون عنهم أمام القضاء. وهم من شركاء القضاء في تحقيق العدالة القضائية. ذلك أن المحامي إذا قام بدوره على الوجه المطلوب يكون عوينا هاما للقضاء في إظهار وجه الحقيقة في وقت أقصر وبجد أقل، فهو أبين بالحجة وألحن بها من الخصوم العاديين، ومن المؤكد أن جانباً كبيراً من حسن سير العدالة، وتوفيق القضاء في أحكامه يتوقف على قدر ما يبذله المحامون من إخلاص وأمانة في الاضطلاع بعبء مهمتهم^(٤).

والمحامي عوين للخصم أيضاً، فهو يساعده بإبداء النصح له، ويباشر عنه إجراءات الدعوى، ويدافع عنه باللسان والقلم، فهو يقدم للخصم معونة جليلة الشأن، لا يكاد يمكن الاستغناء عنها، ذلك أنه قلما يستطيع الخصم - ولو كان من رجال القانون - أن يستوفي تحضير قضيته بنفسه، ويحسن الدفاع فيها، ويسمح له وقته بأن يباشر إجراءاتها ويحضر بنفسه في كل جلساتها^(٥).

(١) المادة ١٥٦ من قانون الإثبات.

(٢) أصول المرافعات للدكتور / أحمد مسلم ف ١٤٦ حاشية (٢).

(٣) المادة ١٢٤ من قانون الإثبات.

(٤) راجع الدستور المصري الحالي لسنة ٢٠١٤ م.

(٥) المرافعات المدنية والتجارية للدكتور / محمد حامد فهي ف ١٨٠.

ورسالة المحامي رسالة سامية تقوم على الدفاع عن الحق وتصرفه، ومحاربة الظلم وكبته، والتصدي للطغيان وأهله، ونجدة المظلوم وإغاثة .
و"المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم"^(١). وللمحاماة مكانة رفيعة يعمل فيها الطامحون من شباب القانون، ويلوذ بها شيوخ وعلماء الحقوق، ومن رجالها يختار القضاة كما يختار أعضاء النيابة^(٢).

الحضور عن الخصوم :

حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم مقصور على المحامين وحدهم، فلا يجوز لخصم أن يوكل شخصاً للحضور أمام المحاكم من غير المحامين^(٣). وقصر حق الحضور عن الخصوم على المحامين ليس عوضاً بالحضور عنهم أمام الجهات القضائية، وإنما يسرى على غيرها من الجهات التي تتصدى للمنازعات، كالنيابات، وهيئات التحكيم، ودوائر الشرطة واللجان القضائية أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي^(٤).

ومع أن الحضور عن الخصوم مقصور على المحامين وحدهم إلا أن المقنن أجاز " للمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصاً من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة"^(٥).

وقد نصت على ذات الاستثناء أيضاً المادة ٧٢ مرافعات، وعلقت المادتان ١٣٢ من قانون السلطة القضائية ٧٢ مرافعات حضور المذكورين على إذن المحكمة وقبولها حضورهم مما يشير إلى سلطة المحكمة في ذلك، وضرورة موافقتها على هذه الوكالة^(٦).

ويجوز لأحد القضاة أو النائب العام أو أحد وكلائه أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً في الحضور أو المرافعة، سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية^(٧).

(١) المادة ١ / ١ من قانون المحاماة الصادر بالقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ .

(٢) الدكتور / أحمد مسلم في أصول المرافعات ف ١٤٨ .

(٣) المواد ١٣٢ من قانون السلطة القضائية ٧٢ مرافعات ، ٣ محاماة .

(٤) المادة ٣ من قانون المحاماة .

(٥) المادة ١٣٢ من قانون السلطة القضائية .

(٦) الوسيط ، للدكتور / فتحي والي ف ٢٠٠ .

(٧) المادة ٨١ / ٢ مرافعات .

ولا يجوز لواحد منهم أن يكون وكيلاً عن أي شخص آخر، سواء أمام المحكمة التي يعملون بها أم أمام أية محكمة أخرى.

الاستعانة بالمحامين:

قصر الحضور عن الخصوم أمام جهات القضاء على المحامين لا يعني أن الاستعانة بهم حتماً مقضياً، ذلك أن الأصل في الاستعانة بالمحامين أمام القضاء المدني اختيارية^(١)، وليست وجوبية، فللخصم أن يحضر أمام المحكمة بنفسه إن شاء أو يوكل محامياً أو أكثر^(٢) في الحضور عنه. ومع هذا فهناك كثير من الخصومات أصبحت الاستعانة فيها بالمحامين واجبة، ولم يعد للخصم أن يقوم بنفسه ببعض الإجراءات أو يستعين فيها بزوجه أو أقاربه أو أصحابه، وكذلك حضور بعض الخصومات، بل يتعين عليه أن يستعين في ذلك بمحام يوكله الخصم وذلك في الحالات الآتية :

١- أمام محكمة النقض: "لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض، وإلا حكم بعدم قبول الطعن، ولا يجوز لغير هؤلاء المحامين الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام محكمة النقض (المادة ٤١ من قانون المحاماة) .

كما أوجب قانون المرافعات على كل من الطعن والمذكرات وحواظ المستندات التي تودع باسم الخصم موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض^(٣). كما أوجب على كل من الطاعن والمطعون ضده إيداع سند توكيل المحامي الموكل عن كل منهما^(٤).
والحكمة في ذلك أن محكمة النقض لا تنظر إلا في طعون مبنية على أسباب قانونية بحتة، فيجب أن يتولى تقديمها والحضور فيها والمرافعة محام حتى لا تكثر الطعون المرفوعة جزافاً بغير سند قانوني^(٥).

٢- أمام محاكم الاستئناف العليا: لا يجوز قبول صحيفة الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.

(١) المادة ١٨٨ من قانون الإجراءات الجنائية.

(٢) المادة ٧٧ مرافعات "إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل".

(٣) المادتان ٢٥٣ / ١ ، ٢٦١ مرافعات .

(٤) مبادئ المرافعات لأستاذنا الدكتور عبد الباسط جمعي ص ٢٥٩ وانظر المادتين ٢٥٥ ، ٢٥٨ مرافعات

(٥) المرافعات المدنية والتجارية للدكتور / عبد المنعم الشرقاوي ف ١٢٤ .

٣- أمام المحاكم الابتدائية: لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو الاستئناف أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية على الأقل^(١).

٤- أمام المحاكم الجزئية: لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين^(٢).

والحكمة من اشتراط توقيع محام على صحف الاستئناف والدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، ذلك أن إشراف المحامي على تحرير هذه الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي تثور بسبب قيام من لا خبرة له بممارسة هذه الشؤون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن^(٣).

ويلاحظ أنه بالنسبة لمحكمة النقض يمتنع على الخصم القيام بأي إجراء أمامها بنفسه أو عن طريق شخص آخر غير محام، بل يتعين أن يكون ذلك عن طريق محام مقبول أمامها، يحضر مع الخصم، ويترافع عنه ويقدم المذكرات والطلبات.

بخلاف محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية حيث يمتنع على الخصم فقط التوقيع على صحيفة الاستئناف أو الدعاوى، ومن ثم يمكن للخصم الحضور أمامها بأنفسهم^(٤).

جزاء عدم الاستعانة بمحام:

رتب القانون جزاءً خطيراً لعدم الاستعانة بمحام في المواضع التي أوجب القانون الاستعانة به فيها، وهذا الجزاء هو البطلان، وقد نصت على ذلك صراحة المادة ٥٨ / ٥ من قانون المحاماة.

شروط الاشتغال بالمحاماة:

يشترط فيمن يشغل بالمحاماة أمام المحاكم المصرية أن يكون اسمه مقيداً بالجدول العام للمحامين ويجب أن تتوافر الشروط الآتية للقيّد في هذا الجدول العام.

١- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، وقد أجاز القانون للمحامي من رعايا الدول العربية المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي

(١) المادتان ١/٣٧، ٥٨ / ٢ من قانون المحاماة .

(٢) الوسيط للدكتور / فتحي والي ف ٢٠٠ وانظر المادة ٥٨ / ٤٠٣ .

(٣) الطعن رقم ٥١٩ لسنة ٣٥ ق جلسة ٢ / ٥ / ١٩٧٣ سنة ٢٤ ص ٧٠٣ .

(٤) الدكتور فتحي والي في المرجع السابق والفقرة نفسها .

يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده، وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية، وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها، وبشرط المعاملة بالمثل^(١).

٢- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وذلك بأن يكون قد بلغ إحدى وعشرين سنة.

٣- أن يكون حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية^(٢)، أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

٤- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنية، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

٥- ألا يكون عضواً في نقابة مهنية أخرى.

٦- أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام قانون المحاماة.

٧- ألا يجمع بين المحاماة والأعمال الواردة في المادة (١٤) من قانون المحاماة^(٣).

ويجب أن تتوافر هذه الشروط عند القيد، ويجب توافرها كذلك لاستمرار القيد^(٤)، وهناك شروط أخرى يجب توافرها للقيد في الجداول المختلفة الآتي بيانها.

جدول المحامين :

للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارسة المهنة.

ويلحق بكل جدول الجداول الآتية :

١- جدول للمحامين تحت التمرين.

(١) المادة ٤٢ من قانون المحاماة .

(٢) ولحاملي درجة الإجازة العالية في الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر كافة الحقوق المقررة لحاملي درجة " الليسانس " في الحقوق من كليات الحقوق في جامعات الجمهورية بناءً المادة الثانية من القانون ٥٠ لسنة ١٩٦٦ في شأن تطوير الدراسة في جامعة الأزهر.

(٣) وهي:

١- رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى . ٢- منصب الوزارة - ٣- الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام قانون المحاماة ، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها قانون المحاماة ٤- الاشتغال بالتجارة . ٥- شغل مركز رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية . ٦- المناصب الدينية.

(٤) المادة ١٣ من قانون المحاماة .

- ٢- جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية، وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية .
 - ٣- جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وتعتبر محكمة القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف .
 - ٤- جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .
 - ٥- جدول المحامين غير المشتغلين .
- كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها^(١) .

إجراءات القيد بجدول المحامين :

يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة نقيب المحامين أو وكيل النقابة في حالة غيابه، وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً. ويرفق بطلب القيد الأوراق التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة ١٣ من قانون المحاماة والسابق ذكرها والتي يبينها النظام الداخلي بالنقابة^(٢) .

وتنعقد اللجنة المذكورة مرة على الأقل كل شهر ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضائها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة . ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة (المادة ١٧ محاماة).

تتحقق اللجنة من توافر شروط القيد، وتصدر قرارها في خلاف ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا رفضت اللجنة قيد الطلب تعين أن يكون قرارها مسبباً، ويخطر به الطالب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بخطاب مسجل بعلم الوصول^(٣) .

وإذا لم تفصل اللجنة في طلب القيد خلال المدة المذكورة، كان لطالب القيد أن يطعن أمام محكمة استئناف القاهرة^(٤) .

(١) المادة ١٠ من قانون المحاماة .

(٢) راجع المادة ١٦ من قانون المحاماة .

(٣) المادة ١٨ من قانون المحاماة .

(٤) المادة ١٩ / ٢ من قانون المحاماة .

ولطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره برفض طلبه، ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله . وإذا رفض التظلم أو كانت مواعيده قد انقضت، فلطالب القيد أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم، أو برفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال . ولا يجوز تجديد طلب القيد في الحالات السابقة إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد (المادة ١٩ من قانون المحاماة) . وإذا وافقت اللجنة على قيد اسم الطالب بجدول المحاماة فلا يجوز له أن يزاول مهنة المحاماة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون). ويحلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة^(١) .

المحامي تحت التمرين :

عند تقديم طلب القيد بالجدول العام ويقدم معه طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين ويعرض على لجنة القبول وفقًا للأحكام السابقة^(٢)، حيث يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة، إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقه الأخرى، ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (المادة ٢١ محاماة) .

ويجب أن يلتحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة .

وقد ألزم القانون كل محام من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يكون من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل^(٣) .

(١) المادة ٢٠ من قانون المحاماة .

(٢) المادة ٢٣ من قانون المحاماة .

(٣) وإذا كانت ظروف المحامي المقبول أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف لا تسمح له بقبول أي محام تحت التمرين بمكتبه يجوز لمجلس النقابة الفرعية بناءً على طلب المحامي المذكور أن يقرر إعفاءه من ذلك . انظر المادة ٢٩ محاماة .

ويظل المحامي تحت التمرين لمدة سنتين تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى^(١)، ولكن إذا انقضت أربع سنوات على قيده بجدول المحامين تحت التمرين ولم يتقدم بطلب لقيده اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسمه من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول^(٢). وللمحامي تحت التمرين في السنة الأولى أن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي ألحق بها في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري ونحوها^(٣).

وأما في السنة الثانية فله أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية، فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة، وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها، وكذلك له الحضور باسمه في تحقیقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح، وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات. وله الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو المحامي بالإدارة القانونية التي ألحق بها . ويجوز للمحامي تحت التمرين الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر في طلب التأجيل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يقدم فتوى كتابية باسمه أو أن يوقع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ^(٤) . ولا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين (المادة ٢٧ محاماة) .

(١) المادة ٢٤ محاماة ، معدلة بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ م .

(٢) ولمن استبعد اسمه من الجدول في خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الأربع سنوات أن يطلب قيده اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد ، على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام ، بالإضافة إلى رسم القيد أمام المحاكم الابتدائية

وإذا ظل اسمه مستبعداً لمدة سنتين دون أن يطلب إعادة قيده ، فلا يجوز إعادة قيده بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين ، وبعد دفع رسوم القيد من جديد ، ويشترط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين (المادة ٣٠ محاماة) .

(٣) المادة ٢٥ محاماة .

(٤) المادة ٢٦ محاماة .

وقد نص قانون المحاماة على أن: "تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة ويدعي لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحاضرين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبرائه المتخصصون . وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين"^(١).

المحامي أمام المحاكم الابتدائية :

بعد أن يمضي المحامي تحت التمرين مدة التمرين السالف ذكرها يطلب المحامي قيده في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين سالف الذكر، ومجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها ورؤسائها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .

وتقدم طلبات القيد إلى اللجنة المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد^(٢) وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ولن يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار^(٣) .

وأجاز القانون قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة^(١) .

(١) المادة ٢٨ محاماة .

(٢) وهذه الشروط هي :

(أ) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المقررة .

(ب) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها مؤشراً عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها ، ويرفق أيضاً بياناً رسمياً بالجلسات التي يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .

(ج) أن يكون قد وازب على حضور المحاضرات التي تلقي على المحامين تحت التمرين ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات . انظر المادة ٣١ محاماة .

(٣) المادة ٣٣ محاماة .

وإذا قيد اسم المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية جازله أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره، ويكون له الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها، وله أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة . ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسؤوليته .

وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها . ولا يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة^(٢) .

المحامي أمام محاكم الاستئناف :

يشترط للقيد في جداول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة خمسة سنوات^(٣)، على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. ويجوز القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف إذا كان طالب القيد قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة لمدة سبع سنوات . ولكن لا يقبل القيد لأول مرة بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تزيد عن عشر سنوات . وتقدم طلبات القيد في الجدول المذكور إلى لجنة القبول سالفة الذكر، ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .

(١) تعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجدول المحامين الوظائف الفنية في القضاء ، ومجلس الدولة ، والمحكمة الدستورية العليا ، والنيابة العامة ، والنيابة الإدارية ، وإدارة قضايا الحكومة وتدرّس القانون في الجامعات . ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة .

(٢) المادة ٣٤ محاماة .

(٣) ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وتقديم صورة المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي أعدها ، وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها ، وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة . المادة ٣٥ محاماة .

وعلى اللجنة أن تبلغ قرارها بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولن يرفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار^(١).

ومتى قيد المحامي بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف كان له حق الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، وجميع المحاكم عدا محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها، والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى (المادة ٢٧ محاماة).

المحامي أمام محكمة النقض :

يشترط للقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية :

١- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل، وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.

٢- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.

٣- المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية^(٢).

ويقدم طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه، ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة (المادة ٤٠ محاماة).

وللمحامي المقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يحضر ويترافع أمام جميع المحاكم، وله إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها.

(١) المادة ٣٦ محاماة .

(٢) المادة ٣٩ محاماة .

الباب الثاني

نظرية الاختصاص والإحالة

وفيه ستة فصول:

- الفصل الأول : الاختصاص الولائي .
- الفصل الثاني : الاختصاص النوعي .
- الفصل الثالث : الاختصاص القيمي .
- الفصل الرابع : الاختصاص المحلي .
- الفصل الخامس : مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام
- الفصل السادس : الإحالة .

الباب الثاني

نظرية الاختصاص والإحالة

تمهيد وتقسيم :

الاختصاص في النظام القضائي معناه : السلطة التي حولها المشرع هيئة من الهيئات القضائية للفصل في المنازعات؛ فهو يبين المنازعات التي تدخل في سلطة كل محكمة، حيث يتحدد اختصاص محكمة معينة بتمييز القضايا التي لها سلطة نظرها وفقاً للقواعد التي ينص عليها القانون. وقواعد الاختصاص هي التي تبين المنازعات التي تدخل في سلطة كل محكمة، أي تبين نصيب كل محكمة من ولاية القضاء، بحيث تشكل تلك القواعد حدود سلطة القضاء المعترف بها لكل محكمة تابعة لجهة قضائية في مواجهة المحاكم الأخرى التابعة لنفس الجهة؛ فهي معيار داخلي يعمل داخل الجهة القضائية التي تختص بها كل محكمة من المحاكم التابعة لها. وفكرة الاختصاص تختلف عن فكرة الولاية كما سبق القول؛ فالمحاكم جميعاً في الدولة لها ولاية القضاء، وتوزع هذه الولاية بين جهتي القضاء - العادي ، والإداري - إلى جانب ما للمحاكم الاستثنائية من ولاية محددة. أما الاختصاص فإنه "مقدار ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء تبعاً لمقرها أو نوع القضية، وهو نوعي إذا اختص بالموضوع ومحلّي إذا اختص بالمكان"^(١).

وتأسيساً على هذا: يتضح لنا أن مقصود الاختصاص القضائي يعني: السلطة القضائية التي يتمتع بها قاض أو جهة قضائية، ويخول لها القانون حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليها^(٢). وهذا يبني على أن الاختصاص القضائي ينتج عنه الانفراد بولاية القضاء إما عموماً في جميع الأمكنة والحوادث والأزمنة، وإما خصوصاً في زمن معين أو مكان معين، أو حادثة معينة، بناء على تقليد صاحب الولاية العامة، الذي يملك الحق في الإطلاق أو التقييد وذلك وفقاً للأصول الشرعية أو القانونية^(٣).

ولقد حدد شراح القانون الاختصاص في كونه توزيعاً للعمل بين المحاكم وجهات القضاء المختلفة^(٤). وبهذا فإن منشأ الاختصاص القضائي هو تعدد المحاكم والجهات القضائية داخل

(١) المعجم الوسيط ١ / ٢٤٦ ، المعجم الوجيز. ص ١٩٨ .

(٢) التنظيم القضائي. لأستاذنا الدكتور/ حامد محمد أبو طالب . ص ١١٣ .

(٣) الأحكام السلطانية للماوردي . ص ٧٠ ، كشاف القناع للبهوتي ٦ / ٣١١ .

(٤) نظرية الاختصاص د / عبد الباسط جمعي . ص ٣ .

الدولة الواحدة^(١)، الأمر الذي يستلزم توزيع العمل القضائي بين هذه المحاكم، وتلك الجهات إقراراً لمبدأ العدالة بين القضاة في نظر الدعاوى والخصومات^(٢).

التفرقة بين الاختصاص والتوزيع الداخلي للعمل القضائي في محكمة واحدة:

لا يعد التوزيع الداخلي للعمل القضائي في المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة تحديداً للاختصاص، وإنما هو تنظيم إداري لعمل قضائي^(٣)، وإقرار لمبدأ العدالة القضائية بين قضاة المحاكم^(٤).

وتأسس على هذا:

لا يتم التوزيع الداخلي للعمل القضائي بمقتضى نص قانوني، كما هو شأن تحديد الاختصاص القضائي، وإنما يتم ذلك بموجب قرار إداري يصدر عن الجمعية العمومية للمحكمة، يتضمن تحديداً للدوائر داخل المحكمة، وتقسيماً للعمل القضائي، وذلك بتوزيعه على هذه الدوائر^(٥)، كما هو الشأن في تحديد دائرة بعينها لنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأخرى لنظر المواد المدنية والتجارية، وثالثة لنظر المسائل الجنائية، وهكذا.

وأخيراً:

يتنوع الاختصاص القضائي بحسب تنوع قواعده القانونية فالاختصاص القضائي ينقسم إلى^(٦):

١- الاختصاص الوظيفي: وهو الذي يبين نصيب المحاكم المدنية من ولاية القضاء بمصر. حيث يحدد هذا النوع من أنواع الاختصاص، اختصاص كل جهة من جهات القضاء المختلفة، وذلك بتحديد الجهة التي يدخل النزاع في اختصاصها. ولم يتضمن قانون المرافعات نصوصاً خاصة بتحديد الاختصاص الوظيفي تاركاً ذلك لقانون السلطة القضائية، ووفقاً لذلك فإن هناك جهتين للقضاء؛ الأولى: جهة القضاء العادي؛ وتعتبر هذه الجهة صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات، والجرائم؛ فلا يخرج عن اختصاصها إلا ما أدخله المشرع في جهة القضاء الإداري، أو ما قد يخرج المشرع بنص خاص. والثانية: جهة القضاء الإداري؛ وتقتصر ولاية القضاء الإداري على نظر المسائل الإدارية، فكل منازعة

(١) المبسّط في قانون المرافعات. لأستاذنا الدكتور/عبد الحكم أحمد شرف- رحمه الله - ص ١٠٤.

(٢) أصول المرافعات. د/أحمد مسلم. بند ١٧٩. ص ١٩٢.

(٣) أصول المرافعات. د / أحمد ماهر زغلول . بند ٢٦٦ .

(٤) ضوابط الاختصاص. د/عبد الحكم فودة. بند ٢. ص ١٢.

(٥) أصول المرافعات. د / أحمد مسلم . بند ٧٣ . ص ٦٥ ، ٦٦ ، بند ١٧٩ . ص ١٩٢.

(٦) القرائن في قانون المرافعات. د/عبد الله الصاوي، ص ١٩٩، والمراجع التي أشار إليها.

تكتسب وصف الإدارية تخرج عن ولاية القضاء العادي بتشكيلاته المختلفة؛ فلا تنظرها محاكم الموضوع أو المحاكم المستعجلة ولا يختص بها قاضي التنفيذ.

٢- الاختصاص النوعي: ويقصد به توزيع العمل بين المحاكم المختلفة داخل الجهة القضائية الواحدة بحسب نوع القضية، والقضاء المدني مكون من أربع طبقات تبدأ بالمحاكم الجزئية، ثم تليها المحاكم الابتدائية، التي تعلوها محاكم الاستئناف، ثم محكمة النقض وهي أسمى المحاكم. وتحديد قدر ما لكل طبقة من هذه الطبقات من ولاية النظر والفصل في منازعات بعينها هو المقصود بالاختصاص النوعي. ووفقا له يتم توزيع ولاية القضاء بين طبقتي المحاكم الابتدائية والجزئية والقضاء الخاص بالأمر المستعجلة والتنفيذ.

٣- الاختصاص القيمي: ويقصد به مجموعة القواعد التي تستهدف تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى على ضوء قيمتها.

٤- الاختصاص المحلي: وهو النطاق المكاني أو الجغرافي الذي تمارس فيه المحكمة جزء من الاختصاص النوعي للطبقة التي تتبعها، فكل محكمة تختص بما تختص به طبقته ولكن في حدود نطاقها الإقليمي أو المكاني.

وسوف أتناول الحديث في هذا الباب عن بيان أهم أنواع الاختصاص القضائي وذلك من خلال الفصول الستة التالية :

الفصل الأول: الاختصاص الولائي.

الفصل الثاني: الاختصاص النوعي.

الفصل الثالث: الاختصاص القيمي.

الفصل الرابع: الاختصاص المحلي.

الفصل الخامس: مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام.

الفصل السادس: الإحالة.

الفصل الأول

الاختصاص الولائي

أولاً: مفهوم الاختصاص الولائي وأهميته:

الاختصاص الولائي هو :

الاختصاص الذي يتم بمقتضاه توزيع الولاية القضائية على جهات القضاء المختلفة داخل الدولة، ويتحدد على أساسه نوع العمل القضائي الذي تستقل به كل جهة، وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى النحو الذي يقرره القانون^(١).

أهمية الاختصاص الولائي:

يعد الاختصاص الولائي أهم أنواع الاختصاص القضائي؛ حيث تتوزع على أساسه الولاية القضائية بين جهات القضاء المختلفة داخل الدولة الواحدة، وفقاً للمعايير الشرعية التي يحددها ولي الأمر وتلك التي يضعها المقنن. ويعرف هذا النوع بالاختصاص الوظيفي^(٢) أو الاختصاص الولائي؛ حيث تستقل ولاية جهة قضاء معينة بالنظر في منازعات محددة، تخرج بحسب طبيعتها من ولاية جهة قضاء أخرى، ومن ثم فهو اختصاص متعلق بالولاية القضائية. وبهذا يمثل الاختصاص الوظيفي نوعاً من الاختصاص النوعي بمعناه العام؛ لأنه يستند إلى نوع الخصومة، ومن ثم فيتأثر باختلافه، ويأخذ حكمه من جهة تعلقه بالنظام العام.

بيد أن الاختصاص الولائي يختلف عن الاختصاص النوعي بكون الحكم الذي يصدر من محكمة لا ولاية لها على المنازعة ليس له قيمة قانونية، فهو لا يجوز قوة الشيء المقضي به، ولا يحتج به أمام جهة قضائية أخرى، ولا أثر له في حقوق الخصوم، لأن تجاوز المحكمة لحدود ولايتها القضائية يعني سقوط كل قوة للقرار الذي تصدره في الخصومة على اعتبار أن حكمها في هذه الحالة لا وجود له، ومن ثم تنعدم حجتيه^(٣). بيد أن هذا الحكم وإن لم يكن له حجية أمام المحاكم التابعة لجهة قضائية أخرى إلا أنه يتمتع بالحجية القانونية الكاملة أمام محاكم جهة القضاء التي أصدرته^(٤).

(١) أصول المرافعات. د/أحمد مسلم . بند ٧١ . ص ١٧٩ .

(٢) انظر: قانون القضاء المدني د / محمود هاشم . بند ٢٤٨ . ص ٣٨٧ .

(٣) المرافعات د/محمد حامد فهدى. بند ٢٩٥. ص ٣٢٣ .

(٤) المرافعات. د/محمد حامد فهدى. بند ٢٩٦. ص ٣٢٤ .

ثانياً: أنواع الاختصاص الولائي:

الولاية القضائية في النظام القضائي المصري موزعة على جهتين كبيرتين^(١) هما:

- ١- جهة القضاء العادي. وتمثلها المحاكم. وهذه الجهة هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات، إلا ما أخرجه المقتن عن ولايتها بنص خاص^(٢).
- ٢- جهة القضاء الإداري: وتمثلها محاكم مجلس الدولة. وهي الجهة ذات الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإدارية دون غيرها من المنازعات الأخرى^(٣).

وبالإضافة إلى هاتين الجهتين توجد جهات أخرى نص عليها الدستور الحالي (دستور ٢٠١٤)، وتسمى القضاء الاستثنائي أو جهات القضاء ذات الولاية المحدودة، حيث جعل المشرع الدستوري المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها، وجهة القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، هذا فضلاً عن الجهات القضائية التي خصها المشرع بنوع من الولاية القضائية المحدودة، لمواجهة ظروف معينة. بحيث تتولى هذه الجهات الفصل في قضايا محددة على سبيل الحصر، ولا يتعدى نظرها إلى ما عداها، وهذه الجهات المخصصة ليست جهات قضائية بالمعنى الفني الدقيق، وإنما هي أشبه بالكيانات القانونية المخصصة لمواجهة ظروف معينة ومنازعات محددة، وإطلاق اسم الجهة عليها إنما هو من قبيل الاستعمال المجازي.

أ- جهة القضاء العادي (المحاكم):

يتسم القضاء العادي بأنه الجهة القضائية التي تتمتع بالولاية العامة على كافة المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية ولا يخرج عن ولايتها إلا ما استثناه المقتن بنص خاص، كما هو الشأن في إخراج المنازعات الإدارية عن ولاية المحاكم العادية^(٤)، وقد نص المقتن على ذلك في المادة رقم ١٥ من قانون السلطة القضائية، وقد جاء فيها أن المحاكم تختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص^(٥).

وقد نصت المادة (١٨٨) من الدستور علي أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شؤونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته".

(١) راجع: الدستور المصري الحالي، الصادر في ٢٠١٤م.

(٢) نظرية الاختصاص د/عبد الباسط جمعي ص ٦.

(٣) قانون القضاء المدني د / محمود هاشم. بند ٨٩. ص ١٦٣.

(٤) أصول وقواعد المرافعات. د / أحمد ماهر زغلول بند ٢٦٦. ص ٥٤١.

(٥) قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ م.

ولما كانت المنازعات التي يتعقد الاختصاص فيها لجهة القضاء العادى تتنوع وتختلف من حيث القيمة والأهمية، تدخل المقنن فعند إلى تقسيم القضاء العادى إلى طبقات من المحاكم وقام بتوزيع الولاية القضائية على هذه الطبقات المتعددة على أساس نوع الدعوى أو قيمتها، محدداً بذلك نصيب كل طبقة من هذه الطبقات، فيقال مثلاً أن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم الجزئية، وتلك من اختصاص المحاكم الابتدائية، وهو ما عرف في النظام القضائى بالاختصاص النوعى أو القيمى^(١).

ونظراً لانتشار المحاكم فى كافة أنحاء الجمهورية فقد رسم المقنن لكل محكمة دائرة اختصاص إقليمى، وجعل محكمة الإقليم تختص محلياً بما يثار فى دائرتها من منازعات وهذا ما عرف بالاختصاص المحلى^(٢). فالمحاكم الجزئية المنتشرة فى كل مركز من مراكز الجمهورية تختص إقليمياً بنظر المنازعات التى تقع فى دائرة اختصاصها الإقليمى ما لم ينص القانون على غير ذلك، والمحاكم الابتدائية هي المحاكم التى تنظر الدعاوى ذات القيمة الكبيرة، والدعاوى المعقدة لأول مرة، أي: بصفة مبتدأة، ويكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية، ويجوز إنشاء محاكم ابتدائية أخرى، وتعيين دائرة اختصاصها المحلى، وتعديل هذا الاختصاص بقانون^(٣).

والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قد عمد مؤخراً على زيادة المحاكم الابتدائية وقد وسّع من اختصاصها المحلى بحسبان موقعها الإقليمى، نظراً لحاجة الناس إلى ذلك ومواجهة تكاثر الدعاوى، وقد عالج ذلك بمقتضى القرار بقانون " ٩٣ " لسنة ٢٠١٥ م، بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية^(٤).

ويضاف إلى طبقات المحاكم المدنية - الجزئية والابتدائية - محاكم الاستئناف التى يتعقد لها الاختصاص بكافة الطعون عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية باعتبارها محكمة أول درجة^(٥).

(١) الوسيط. د/ أحمد السيد صاوي . بند ١٨٠ . ص ٢٥٩ .

(٢) الوسيط . د / أحمد السيد صاوي . بند ١٨٠ . ص ٢٥٩ .

(٣) المادة ١٠ من قانون السلطة القضائية .

(٤) راجع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم " ٩٣ " لسنة ٢٠١٥ م ، بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية ، الصادر بالجريدة الرسمية ، العدد " ٣٣ " تابع " ب " فى ١٣ أغسطس ، ٢٠١٥ م ، وقد جاء هذا القانون فى سبع عشرة مادة .

(٥) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٢٧٥ . ص ٣١٧ .

هذا، فضلاً عن وجود محكمة النقض بمقر العاصمة – القاهرة – وهي ليست درجة من درجات التقاضي وإنما انعقد لها الاختصاص بالإشراف على تطبيق صحيح القانون، كما انعقد لها الاختصاص بنظر الطعون في الأحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في الحالات التي ينص عليها القانون م٢٤٨ / مرافعات.

وبهذا يتضح أن القضاء العادي، ممثلاً في طبقاته المختلفة هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى من ذلك بنص صريح .

ب- جهة القضاء الإداري (محاكم مجلس الدولة)

ج - جهات القضاء ذات الولاية المحدودة.

وقد سبق الحديث عن ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول، فنحيل إلى ما سبق.

الفصل الثاني

الاختصاص النوعي

المبحث الأول

ماهية الاختصاص النوعي وأهميته

أولاً: ماهية الاختصاص النوعي:

يقصد به توزيع العمل بين المحاكم المختلفة داخل الجهة القضائية الواحدة بحسب نوع القضية، ووفقاً للاختصاص النوعي يتم توزيع ولاية القضاء بين طبقتي المحاكم الابتدائية والجزئية والقضاء الخاص بالأمور المستعجلة والتنفيذ. حيث يعد الاختصاص النوعي الأساس القانوني الذي يتم بمقتضاه توزيع الولاية القضائية بين طبقات المحاكم المختلفة داخل الجهة القضائية الواحدة. ذلك أن المعتبر قانوناً في تحديد اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم المختلفة وفقاً للاختصاص النوعي؛ هو نوع الدعوى دون اعتبار لقيمتها أو مكانها.

وبناءً على هذا: يتحدد اختصاص القاضى نوعياً، فيقال مثلاً اختصاص القاضى بنظر الدعاوى المدنية أو التجارية أو الجنائية، أو الأسرة^(١)، أو الدعاوى المستعجلة، أو اختصاصه بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة بعينها، أو اختصاصه بالمنازعات العمالية، أو التنفيذية. المتعلقة بالتنفيذ الجبري. أو اختصاصه بالإشراف على تطبيق صحيح القانون والمنع من مخالفته. كما هو شأن محكمة النقض. حيث يعد هذا تحديداً للاختصاص القضائي، وفقاً لنوع الدعاوى، وذلك في كل طبقة من طبقات المحاكم المختلفة.

ثانياً: أهمية الاختصاص النوعي:

يحقق الاختصاص النوعي العديد من المزايا التي تؤكد أهميته في النظام القضائي، حيث يترتب عليه تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى، مما يؤدي إلى تسهيل أعمال القضاة وإجراءات التقاضي، ويحقق سرعة الفصل في الدعاوى، ويؤكد على مبدأ احترام قواعد الاختصاص والعمل على عدم مخالفتها^(٢)، حتى لا يقع التضارب في الأحكام، مما يطول معه التخاصم بين المتنازعين لدى القضاة والحكام.

(١) قانون القضاء المدني د/محمود هاشم . بند ٢٣١ ص ٣٦٠.

(٢) المرافعات د/أحمد أبو الوفا بند ٣٥٧ ص ٤٠٤ .

المبحث الثاني

تحديد الاختصاص النوعي

معايير تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم :

لقد حدد المقتن الاختصاص القضائي لمحاكم القضاء المدني وفقاً لنوع الدعوى أو أهميتها، كما أنه أخذ بمعيار طلب الحماية الوقتية بالنسبة للدعاوى المستعجلة، باعتباره الأساس القانوني الذي يتحدد بمقتضاه اختصاص القضاء المستعجل، وبناء على هذين المعيارين فقد وزع المقتن ولاية القضاء على مختلف محاكم القضاء المدني - طبقات المحاكم - بما في ذلك التشكيلات القضائية المتخصصة التي تتبع جهة القضاء المدني^(١).

وتأسيساً على هذا يتحدد الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء المدني المعيارين التاليين :

أ- معيار أهمية موضوع الدعوى:

لقد اتخذ المقتن من أهمية موضوع الدعوى معياراً قانونياً قسّم على أساسه ولاية القضاء المدني بين طبقات المحاكم المختلفة، لذا فقد فرق وهو بصدد تحديد الاختصاص النوعي لكل طبقة من طبقات المحاكم بين الدعاوى ذات الأهمية والأخرى قليلة الأهمية، فخص المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى كبيرة الأهمية دون غيرها، في حين جعل اختصاص المحاكم الجزئية بالدعاوى قليلة الأهمية^(٢).

ولما كان النظام القضائي المصري يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين فسوف أقصر دراسة الاختصاص النوعي على درجتى القضاء المدني، وذلك على النحو التالي:

الاختصاص النوعي لقضاء الدرجة الأولى، ويتمثل فيما يلي:

١- المحاكم الجزئية :

تعد المحاكم الجزئية المنتشرة في جميع مراكز الجمهورية محاكم درجة أولى دائماً^(٣)، وهي تختص نوعياً بالفصل في الدعاوى قليلة الأهمية التي جعلها المقتن من اختصاصها دون غيرها من المحاكم الأخرى، ويعد اختصاص هذه المحاكم بنظر تلك الدعاوى اختصاصاً أصلياً، وهو يتحدد وفقاً لنوع الدعوى بغض النظر عن قيمتها المالية^(٤).

(١) قانون القضاء المدني د / محمود هاشم بند ١٣١ ص ٣٦٠ .

(٢) أصول وقواعد المرافعات. د/ أحمد ماهر زغلول بند ٢٦٦ ، ص ٥٤٢ .

(٣) قانون القضاء المدني . د/ محمود هاشم. بند ٢٣٢ . ص ٣٦١ .

(٤) مبادئ القضاء المدني د / وجدى راغب ، ص ٣٠١ .

هذا وقد قرر المقنن الاختصاص النوعي للأصلى للمحاكم الجزئية بمقتضى المادة (٤٣) من قانون المرافعات، وهذه المادة تؤكد على أن المقنن جعل الولاية القضائية للمحاكم الجزئية ولاية أصيلة محدودة بنوع الدعوى - وهي كونها مدنية أو تجارية- ومن ثم فلا اعتبار لقيمتها المالية؛ لأن القيمة هنا إنما تفيد لمعرفة كون الحكم ابتدائياً أو انتهائياً، وحديثنا هنا إنما هو عن النوع دون القيمة.

وإذا كان المقنن قد حدد الاختصاص النوعي لمحاكم المواد الجزئية فقد منحها أيضاً اختصاصاً نوعياً استثنائياً في نظر بعض الدعاوى، وهذا الاختصاص لا يتقرر لهذه المحاكم إلا بنص خاص^(١)، ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

وبناءً على هذا فقد نص المقنن في المادة ٤٣ على أن: " تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى، وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه^(٢) فيما يلي :

- ١- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف .
- ٢- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
- ٣- دعاوى قسمة المال الشائع .
- ٤- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتببات وتحديدها^(٣) .
- ٥- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها .
- ٦- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى، وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر عمدة الناحية، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية

(١) أصول وقواعد المرافعات . د / أحمد ماهر زغلول . بند ٢٦٨ ، ص ٥٤٤ ، القانون القضائي الخاص د/إبراهيم نجيب سعد . بند ١٧٦ ص ٤٢٨ .

(٢) المادة (٤٣) مرافعات، معدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤م، الجريدة الرسمية العدد ٢٧ مكرر (د) في ٢٠٢٤/٧/١٠.

(٣) بند " ٤ " من المادة " ٤٣ " مضاف بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ م ، الجريدة الرسمية ، العدد ٢٢ مكرر في ١ / ١٩٩٢ / ٦ م .

المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى^(١).

هذا وترجع الحكمة من إسناد الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحاكم الجزئية - على سبيل الاستثناء- أياً كانت قيمتها المالية إلى بساطة هذه الدعاوى وشيوعها، وظهور وجه الحق فيها، وعدم إثارتها للمشاكل القانونية، أو حاجتها إلى مزيد من الخبرات الفنية، فضلاً عن قربها من مواطن الخصوم^(٢).

٢- المحاكم الابتدائية : " بوصفها محكمة درجة أولى " :

تعد المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وبهذا فهي تختص نوعياً بنظر الدعاوى التي جعلها المقتن من اختصاصها، أو بمعنى أوضح يتحدد الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما أخرجها المقتن بنص خاص، وجعل الاختصاص به منعقداً لغيرها من المحاكم الجزئية^(٣).

وبناءً على هذا تختص المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة درجة أولى اختصاصاً أصلياً وفقاً لنوع الدعوى بالحكم ابتدائياً في جمع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتي ألف جنهماً م "٤٧" من قانون المرافعات^(٤).

هذا وقد جعل المقتن لهذه المحاكم اختصاصاً نوعياً بنظر بعض الدعاوى أياً كانت قيمتها المالية ولو كانت أقل من نصابها، وذلك على سبيل الاستثناء، لما رآه المقتن من أهمية لهذه الدعاوى، ودقة ما تثيره من مشاكل قانونية تستلزم ضرورة نظرها أمام قضاة متعددين، وأصحاب خبرة أكثر لذا فقد عقد الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحاكم الابتدائية.

واختصاص هذه المحاكم بنظر تلك الدعاوى هو اختصاص نوعي — يتحدد وفقاً لنوع الدعوى . استثنائي لا يتقرر إلا بنص صريح من القانون .

(١) البندان رقما "٥" ، "٦" من المادة (٤٣) بندان جديان مضافان بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م .حيث نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن : " يضاف إلى المادة " ٤٣ " من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بندان جديان برقيي " ٥ " ، " ٦ " .

(٢) قانون القضاء المدني. د/محمود هاشم. بند ٢٣٢. ص ٣٦١.

(٣) القانون القضائي الخاص. د / إبراهيم نجيب سعد . بند ١٧٥. ص ٤٢٨ ، المرافعات . د / أحمد أبو الوفا. بند ٢٧٦. ص ٣١٨، الوسيط . د/أحمد السيد صاوي . بند ١٩٩ . ص ٢٧٧ .

(٤) المادة (٤٧) مرافعات معدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤م.

وهذا ما أكدته المقنن بمقتضى نص المادة ٤٢ / ٢ من قانون المرافعات التى نصت على: "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون" (١). وبناءً عليه تختص المحاكم الابتدائية دون غيرها بالفصل فى دعاوى الإعسار المدنى، وغير ذلك مما ينص عليه القانون صراحة.

الاختصاص النوعى لقضاء الدرجة الثانية :

يشتمل هذا القضاء على المحاكم التى تنظر الطعن فى الأحكام وهى :

١- المحاكم الابتدائية (بوصفها محكمة استئنافية):

تختص المحاكم الابتدائية نوعياً بالمنعقدة بهيئة استئنافية (٢) بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من محاكم المواد الجزئية فى حدود نصابها الإبتدائي، وكذلك الأحكام الصادرة عن قاضى الأمور المستعجلة (٣).

٢- محاكم الاستئناف العليا :

تعد محاكم الاستئناف العليا محاكم درجة ثانية دائماً (٤)، حيث تختص بنظر الطعون المقدمة إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية. بوصفها محكمة درجة أولى. فى حدود نصابها الإبتدائي المقرر قانوناً، وكذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى دعاوى تسليم العقارات متى رفعت بصفة أصلية (٥).

(١) مستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠م، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨م، الجريدة الرسمية، العدد ٣٦ مكرر "ب" فى ٥ سبتمبر ٢٠٢٠م.

(٢) أصول وقواعد المرافعات. د/ أحمد ماهر زغلول. بند ٢٦٩. ص ٥٤٤، وبهذا يتضح أن المحكمة الإبتدائية لها اختصاصان : أحدهما بإعتبارها محكمة أول درجة تنظر النزاع لأول مرة، والآخر بإعتبارها محكمة ثاني درجة تنظر النزاع لثاني مرة، وتسمى فى هذه الحالة بالمحكمة الإبتدائية الإستئنافية، وتشكيل المحكمة الإبتدائية كمحكمة أول درجة لا يختلف عن تشكيلها كمحكمة ثاني درجة، ففي تلك الحاليتين تتشكل من ثلاثة أعضاء "م ٩ / ٤ من قانون السلطة القضائية"، ويوزع العمل فى المحكمة على دوائر إبتدائية، ودوائر استئنافية، انظر: الوسيط. د / أحمد السيد صاوي. ص ٢٧٧. هامش رقم "٢".

(٣) راجع المادة الأولى من القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠م، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨م، الجريدة الرسمية، العدد ٣٦ مكرر "ب" فى ٥ سبتمبر ٢٠٢٠م.

(٤) المرافعات. د / أحمد أبو الوفا. بند ٢٧٨. ص ٣١٩. الوسيط. د / نبيل إسماعيل عمر. بند ١٤. ص ٨٤.

(٥) المادة "٤٨" من قانون المرافعات، وقد نصت على أن : " تختص محكمة الإستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الإبتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم

ب- معيار طبيعة المنازعة أو الطلب:

عمد المقتن في النظام القضائي المصري على تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم المدنية وفقاً لطبيعة المنازعة أو الطلب محل الدعوى، ويتضح هذا من خلال المنهج الذي سار عليه المقتن في تخصيص قضاء درجتى المحاكم الجزئية والابتدائية، ومن أمثلة التخصيص النوعي لهذه المحاكم ما يلى :

١- اختصاص إدارة التنفيذ التى تنشأ بمقر كل محكمة إبتدائية، أو أحد فروعها التى تنشأ لها بمقتضى قرار وزير العدل بدائرة محكمة جزئية بالإشراف على التنفيذ

وبهذا يتضح أن اختصاص إدارة التنفيذ بالإشراف على مسائل التنفيذ هو اختصاص نوعي محدد وفقاً للقانون طبقاً لمعيار طبيعة المنازعة .

٢- وكذلك اختصاص قاضى التنفيذ نوعياً دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية، والوقتية أياً كانت قيمتها.

٣- وكذلك اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بالفصل فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها^(١).

٤- وكذلك اختصاص قاضى الأمور المستعجلة نوعياً دون غيره بنظر الدعاوى المستعجلة "القضاء المستعجل"؛ لأن المقرر قانوناً أن الاختصاص بنظر الدعاوى المستعجلة ينعقد نوعياً لقاضى الأمور المستعجلة. ونتناول القضاء المستعجل بشيء من التفصيل على النحو الآتى:

القضاء المستعجل:

القضاء المستعجل: هو قضاء عادي يدخل ضمن ولاية القضاء العادي، وليس قضاء مستقلاً وإنما هو من قبيل ولاية القضاء العادي، حيث نصت المادة م(٤٥) مرافعات على أن: "يندب في

الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة ٤٣ من هذا القانون " ، وهذه المادة مستبدلة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م .

(١) المادة " ٢٧٧ " وهي مستبدلة بقانون المرافعات الجديد ، رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م ، وقد نصت وفقاً لهذا القانون على أن : "تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية " ، وبهذا فقد جعل الاختصاص بنظر قضايا الاستئناف التى ترفع عن أحكام قاضى التنفيذ المتعلقة بالتنفيذ ، سواء أكانت منازعات وقتية أم موضوعية للمحكمة الابتدائية . وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي . دون غيرها أياً كانت قيمة المنازعة ، وهذا مما يؤيد فكرة تحديد الاختصاص النوعي طبقاً لمعيار طبيعة المنازعة .

مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها؛ ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت".

فالمنازعة التي تكون في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية يكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.

ويفهم من هذا النص أن المحاكم الجزئية تختص بالدعاوى المستعجلة ولكن هذا الاختصاص لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها تبعاً للدعوى الموضوعية.

ماهية القضاء المستعجل، وبيان ضرورته:

اختصاص القضاء المستعجل ينحصر في الأمور التي يخشى عليها فوات الوقت، ومناطق توافر هذا الاختصاص قيام حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق؛ فإن أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة في أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضي أن يتناول مؤقتاً في نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجدل في المنازعة فإن استبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه^(١).

لذلك فإنه لا حجية للحكم المستعجل في شأن حسم النزاع على أصل الحق، لأن المحكمة المختصة بالنزاع حول أصل الحق هي محكمة الموضوع، ولا ولاية للقضاء المستعجل في هذا الشأن. بل إن الحكم المستعجل لا حجية له أمام القضاء الموضوعي، وتنحصر حجيته فقط أمام القاضي المستعجل، مادامت الظروف التي صدر فيها هي بعينها لم تتغير^(٢).

وعرف بعض الفقه^(٣) القضاء المستعجل بأنه: "الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة، أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين".

ذلك أن صاحب الحق قد يتأخر بعض الوقت في رفع دعواه الموضوعية حتى يستعد لها تمام الاستعداد، وحتى بعد رفعه الدعوى فإن الأمر قد يتطلب منح الخصوم أجلاً للحضور

(١) نقض: الطعن رقم ٢١٨ لسنة ١٨ قضائية - جلسة ١٢/٧/١٩٥٠.

(٢) نقض: الطعن رقم ١٢٥٠ لسنة ٤٩ قضائية - جلسة ٢٠/٢/١٩٨٠ م.

(٣) أستاذنا الدكتور عبد الباسط جميعي - رحمه الله - في مبادئ المرافعات، ص ١٢٩.

والاستعداد للدفاع، كما يستوجب على المحكمة التروى والتأني في فحص الدعوى، وتحقيق وقائنها، وفحص أدلتها، وإصدار الحكم فيها، وقد يطول أمد التقاضي، سواء أكان ذلك بحسن نية أم بسوءها، وفي هذه الأثناء قد تتعرض أدلة الدعوى للزوال، كأن يكون الشاهد مريضاً يخشى موته أو مسافراً يخشى غيابه، أو يزول أثر الاعتداء على الحق بمضى الوقت، كجفاف الأرض التي أغرقت بالمياه ونحو ذلك.

وهكذا فهذه الأمور وأشباهاها تستدعي تدخل القضاء بإجراءات وقتية لفرض حماية مؤقتة وسريعة للمحافظة على الحقوق الظاهرة، لحين الفصل نهائياً في موضوع النزاع الأصيل، حتى لا تضار مصالح الخصوم من طول إجراءات التقاضي؛ لذلك: جعل المقتن بجانب القضاء الموضوعي قضاء مستعجلاً، يمنح صاحب الشأن حماية مؤقتة وعاجلة وفقاً لظاهر الحال كما يبدو من الأوراق إلى أن تحكم المحكمة في الموضوع الأصيل دون أن تتقيد بما صدر من المحكمة بشأن قضائها المستعجل^(١).

المحاكم المختصة بالدعوى المستعجلة:

١- الاختصاص النوعي:

لما كان نص المادة (٤٥) مرافعات يفيد أنه: يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية، فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

وبناء على هذا النص: فإن الدعوى المستعجلة إذا رفعت مستقلة عن الدعوى الموضوعية فإنها ترفع إلى محكمة الأمور المستعجلة، ويختلف الوضع في المدن التي بها مقر المحكمة الابتدائية عن المدن الأخرى على النحو الآتي:

في المدن التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية (عواصم المحافظات) يختص بنظر الدعاوى المستعجلة قاض من قضاة المحكمة الابتدائية، يندب في مقر المحكمة؛ ليحكم دون غيره في الدعاوى المستعجلة الخاصة بالمدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية، ومع ذلك فهي محكمة جزئية وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية (استئناف كلي).

وعلى ذلك ففي عاصمة كل محافظة توجد محكمة للأمور المستعجلة، تختص بنظر المنازعات المستعجلة، التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزئية في هذه المدينة، أما في غير المدن

(١) الوسيط، أ.د. أحمد السيد صاوي، ص ٣٥٢، ٣٥٣.

التي توجد بها مقر المحكمة الابتدائية، فإن الاختصاص بالدعوى المستعجلة ينعقد للمحكمة الجزئية بالمركز. وهذا، إذا رفعت الدعوى المستعجلة مستقلة عن الدعوى الموضوعية.

أما إذا رفعت الدعوى المستعجلة تبعاً للدعوى الموضوعية، فالمحكمة التي تختص بالموضوع تختص بنظر الطلب المستعجل، سواء أكانت محكمة جزئية أم كلية، وسواء أكانت محكمة أول درجة أم محكمة ثاني درجة. كما يستوى أن يرفع الطلب المستعجل في صحيفة الدعوى، أو يقدم كطلب عارض أثناء نظر الدعوى الأصلية.^(١)

وبناء على ذلك يمكن القول أن محكمة الأمور المستعجلة لا تستقل بهذا الاختصاص، وإنما تشاركها محكمة الموضوع.

والخيار هنا لصاحب الشأن، الذي يريد أن يقدم طلباً مستعجلاً، كما هو شأن من يرفع دعوى ملكية مزرعة دواجن، وأثناء سير الدعوى أراد أن يقدم طلباً بوضع المزرعة تحت الحراسة، فهنا يجوز له أن يقدم هذا الطلب للمحكمة التي تنظر الموضوع، كما يجوز له أيضاً أن يقدم هذا الطلب مستقلاً لمحكمة الأمور المستعجلة.

٢- الاختصاص المحلي:

وفقاً لنص المادة (٥٩) مرافعات إذا كانت الدعوى بطلب إجراء وقفي كالحراسة أو إثبات الحالة ينعقد الاختصاص للمحكمة المستعجلة، التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

أما إذا كانت الدعوى عبارة عن منازعة وقتية من منازعات التنفيذ، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها.

التفرقة بين الدعوى المستعجلة والدعوى الموضوعية التي يوجب القانون الفصل

فيها على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال:

هنا يجب عدم الخلط بين الدعوى المستعجلة والدعوى الموضوعية التي قد يوجب القانون نظرها على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال. ذلك أن المقتن قد ينص أحيانا على نظر الدعوى "على وجه السرعة"، أو "على وجه الاستعجال"، تقديراً منه لظروف وطبيعة هذه الدعوى، كما هو شأن ما نصت عليه المادة (٢٥٠) مدني: "يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة"، وأيضاً: ما نصت عليه المادة (٣/٨٩٠) مدني في شأن نظر دعوى المنازعة في صحة الجرد وأنه "تقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال"، وما نصت

(١) الوسيط، د. أحمد السيد صاوي، ص ٣٦٩ وما بعدها.

عليه المادة (٩٤٣) مدني: " ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول، ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة، وإلا سقط الحق فيها، ويحكم في الدعوى على وجه السرعة".

ففي هذه الحالات وأمثالها يوجه المقنن قاضي الموضوع أن يفصل في هذا النزاع على وجه السرعة؛ نظراً لطبيعته، ولكن هذا لا يغيّر من طبيعة الدعوى في أنها دعوى موضوعية، وتسرى عليها أحكام الدعوى الموضوعية، من حيث طريقة رفعها ونظرها وحجية الحكم الصادر فيها، ومن ثم فلا تسرى عليها أحكام الدعوى المستعجلة " التي تخضع لإجراءات ومواعيد خاصة، ويحوز الحكم الصادر فيها حجية مؤقتة، تزول بزوال دواعيه، أو بصدور حكم في موضع النزاع".^(١)

شروط اختصاص القضاء المستعجل:

قد ينص القانون على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر منازعات معينة، من ذلك مثلاً دعوى سماع شاهد، (المادة ٩٦ من قانون الإثبات)^(٢)، ودعوى إثبات الحالة، (المادة ١٣٣ من قانون الإثبات)^(٣)، ودعوى الترخيص بإيداع المعروض من غير النقود بالمكان الذي يعيّنه القاضي (المادة ٤٨٨ مرافعات).^(٤) ففي هذه الحالات وأمثالها تكون الدعوى مستعجلة بنص القانون، وإلى جانب هذه الحالات وأشباهاها جعل المقنن القضاء المستعجل مختصاً بنظر المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت.

(١) الوسيط، أ.د. أحمد السيد صاوي، ص ٣٥٥، ٣٥٦، الوسيط، أ.د. فتحي والي، ص ١٢٨.

(٢) ونصها "يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود".

(٣) وتنص على أنه "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة".

(٤) ونصها: "إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة".

وبمعنى آخر لا يتحدد اختصاص القضاء المستعجل بحسبان رغبة المدعى وحدة أو الخصوم جميعاً في الوصول إلى حكم سريع، وإنما يتحدد الاختصاص بحسب المنازعة، وكونها من المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، كأن يخشى مثلاً أن تضيق معالم الواقعة محل النزاع، أو أن يهلك محل الحق المتنازع عليه، أو أن تفوت فرصة الانتفاع بالحق، أو أن يقع اعتداء يهدد الحق إلى غير ذلك من صور الاستعجال الموضوعي، والذي لا يرجع فيه لمجرد رغبة الخصوم في الحصول على حكم عاجل، وإنما بحسبان ظروف وطبيعة المنازعة محل التقاضي.

فإذا أغرق شخص مثلاً أرض جاره المزروعة أو المعدة للزراعة، أو توقف مقاول عن إتمام بناء تعهد بإتمامه في وقت معين، أو كان النزاع على ملكية عين تحت يد أحد الخصوم، ويخشى أن يبددها نكايته في خصمه، أو رفض مستأجر رد العين المستأجرة رغم انتهاء الإجارة، أو شرع شخص في إقامة جدار على أرضه بقصد حرمان جاره من حق مطّل له عليها، ففي كل هذه الأحوال تعتبر المنازعة مستعجلة، لأن مضي الوقت يضر بصاحب الحق^(١) وحتى يكون القضاء المستعجل مختصاً بالمنازعة يلزم توافر الشروط الآتية:

الشرط الأول: توافر الاستعجال:

وفقاً لنص المادة (٤٥) فإن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق بالمسائل المستعجلة، التي يخشى عليها من فوات الوقت، وعلى ذلك فتوافر الاستعجال شرط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

ويعرف بعض الفقهاء^(٢) الاستعجال بأنه: "الخطر المحدق بالحق أو المصالح، التي يراد المحافظة عليها"، ويتوافر الاستعجال عندما توجد حالة يترتب على فوات الوقت فيها حصول ضرر منها يتعذر تداركه أو إصلاحه.

وللخشية من فوات الوقت مظهران:

أولهما: الخشية من زوال المعالم، كأن يقوم جار بإغراق أرض جاره بالمياه، وفوات الوقت هنا يؤدي إلى جفاف الأرض وزوال معالم الواقعة، التي سيستند إليها صاحب الأرض في دعوى التعويض، ومن ثم يرفع دعوى إثبات الحالة.

ثانيهما: الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق، كأن يتلف المستأجر العين المؤجرة عند تركها بحيث لا تصلح للاستعمال، فمضي الوقت هنا لا يذهب المعالم، ولكن يترتب عليه تفويت حق المؤجر في الانتفاع بالعين أو تأخير الانتفاع بها.

(١) أصول المرافعات، أ.د. أحمد مسلم، ص ٢٤٩.

(٢) أستاذنا الدكتور عبد الباسط جميعي - رحمه الله - في مبادئ المرافعات، ص ١٢٩.

والاستعجال هنا يرجع لطبيعة الدعوى ولا يرجع لرغبة الخصوم؛ لأن اتفاقهم باطل لمخالفته للنظام العام، هذا ويجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يتحقق من توافر شرط الاستعجال فإن لم يكن متوفراً حكم بعدم اختصاصه وأحال المنازعة لقاضي الموضوع إن كان لذلك محل.

والعبرة بتوافر الاستعجال وقت رفع الدعوى، ولكن إذا زال الاستعجال أثناء نظر الدعوى، فالراجع أن ذلك يزيل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، ومن ثم يلزم توافر شرط الاستعجال في الدعوى لحين الحكم فيها.^(١) هذا ويلاحظ أن هناك بعض الحالات^(٢) قد افترض فيها المقنن توافر شرط الاستعجال ومن ثم يعتبر شرط الاستعجال متوفراً، وليس للقاضي سلطة تقدير تحققه، ومن ذلك إشكالات التنفيذ المنصوص عليها بالمادة (٢/٢٧٥) مرافعات، وحالة طلب تقدير مبلغ يودعه الطالب خزانة المحكمة، ويخصص للوفاء بمطلوب الحاجز المنصوص عليها بالمادة (٣٠٣) مرافعات^(٣)، ودعوى قصر الحجز المنصوص عليها بالمادة (٣٠٤) مرافعات^(٤)، وحالة إجراء الترميمات العاجلة المنصوص عليها بالمادة (٨٥٩) مدني^(٥).

الشرط الثاني: أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً أو تحفظياً لا يمس أصل الحق:

وفقاً لنص المادة (٤٥) يشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة أن يكون المطلوب في الدعوى إجراءً وقتياً أو تحفظياً، وقد عبرت المادة عن ذلك بقولها " ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق".

وعلى ذلك فالقاضي المستعجل لا يطلب منه إلا إجراءً وقتي أو تحفظي، مثل طلب تعيين حارس على العين المتنازع عليها لحين صدور حكم في موضوع النزاع الأصلي، وكطلب نفقة وقتية لحين صدور حكم يقرر النفقة الموضوعية المتنازع عليها، وكطلب السماح لطالب بأداء الأمتحان

(١) الوسيط، أ.د. أحمد السيد صاوي، ص ٣٥٩.

(٢) قواعد المرافعات لمحمد العشماوي، د. عبد الوهاب العشماوي ص ٢٥٣ وما بعدها، مبادئ المرافعات، أستاذي الدكتور عبد الباسط جميعي- يرحمه الله- ص ١٢٩ وما بعدها، قانون المرافعات، د. أحمد هندي، ص ٣٢٥ وما بعدها، الوجيز في المرافعات، د. محمد محمود إبراهيم، ص ٣٧١ وما بعدها.

(٣) ونصها: "يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفه مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز...".

(٤) "إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال...".

(٥) ونصها "(١) على صاحب السفلى أن يقوم بأعمال الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. (٢) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفلى، ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة".

مؤقتاً لحين الفصل في النزاع الموضوعي، وهو يدور حول مدى أحقية الطالب في الالتحاق بالكلية، وكطلب وقف قرار فصل طالب لحين الفصل في الموضوع الأصلي، وهو ثبوت واقعة الغش مثلاً، وكطلب وقف التنفيذ على أموال المدين مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى الموضوعية ببطالان التنفيذ؛ لأن الأموال المحجوز عليها لا يجوز الحجز عليها... وهكذا.

أما إذا تضمنت الدعوى التي وصفت بأنها مستعجلة طلباً موضوعياً، كالحكم بالمدونية، أو الملكية، أو الحيازة، أو الصحة، أو البطلان، أو الفسخ، أو سقوط الحق بالتقادم، أو المقاصة أو غير ذلك، فإن قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بنظر مثل هذه الطلبات الموضوعية.

وإذا كان قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بنظر الطلبات التي تمس أصل الحق، وهو ممنوع من التعرض له، ومن ثم فليس له أن يتعمق في بحث المستندات أو أن يقطع في شأنها برأى حاسم أو أن يفسرها، سواء أكانت عقوداً أم أحكاماً، وإنما يتحسس المستندات، ويبحثها بحثاً عرضياً، ويحكم بحسبان ما يبدو له لأول وهلة أو لأول نظرة، بحيث يستقى منها وجه الأمر في هذا الشأن دون تعمق أو إخلال.

كما أنه ليس للقاضي المستعجل أن يبني حكمه على ثبوت الحق أو نفيه، أو على أى اعتبارات تتصل بأصل الحق، ويجب أن يقتصر على ترجيح الاحتمالات دون أن يجزم برأى في أصل الحق.

الفصل الثالث

الاختصاص القيمي

المبحث الأول

ماهية الاختصاص القيمي وأهميته وتحديده

أولاً: ماهية الاختصاص القيمي:

يقصد به: مجموعة القواعد التي تستهدف تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى على ضوء قيمتها. حيث حدد المشرع بهذه القواعد نصاباً مالياً تتحدد على ضوءه المحكمة المختصة بنظر الدعوى جزئية أو ابتدائية^(١)، حيث يتقيد اختصاص المحكمة بالدعوى التي لا تتجاوز قيمتها نصاباً معيناً من المال^(٢)، ومن ثم فإن تحديد قيمة الدعوى أو تقدير هذه القيمة هو الأساس القانوني الذي يتم بمقتضاه يتم تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

ثانياً: أهمية الاختصاص القيمي:

يعد الاختصاص القيمي نوعاً من الاختصاص النوعي يتحدد وفقاً لقيمة الدعوى، حيث تتقيد سلطة المحكمة في نظر الدعوى بالنصاب المعين في كل دعوى^(٣)، ومن ثم فتفصل في الدعوى التي تدخل في نصابها القيمي المحدد لها قانوناً دون غيرها^(٤)، وبهذا يتضح أن الاختصاص القيمي، وإن عد من الاختصاص النوعي، إلا أن الاعتبار فيه هو قيمة الدعوى وليس نوعها. مدنية أو تجارية أو شخصية. أو طبيعتها. موضوعية أو مستعجلة.

وتتضح أهمية هذا التحديد في معرفة ما إذا كان الحكم الصادر من محكمة ما قد صدر في حدود نصابها الانتهائي ومن ثم لا يجوز الطعن فيه، أم صدر في حدود نصابها الابتدائي، فيطعن فيه بطرق الطعن المقررة، وما إذا كانت صحيفة الطعن تحتاج إلى توقيع من محام أم لا تحتاج إلى ذلك^(٥).

(١) الوسيط، أ.د. أحمد السيد صاوي، ص ٤١.

(٢) مبادئ المرافعات. د/عبد الباسط جمعى . ص ١٠٥ ، ١٠٦ ، قانون القضاء المدني د/محمود هاشم . بند ٢١٧ وانظر في هذا المعنى : الأحكام السلطانية للمواردى ص ٢٧ ، ٧٣ .

(٣) المرافعات د / محمد حامد فهمي . بند ١٥٧ ، ص ١٥٧ .

(٤) مبادئ القضاء المدني د/وجدى راغب ص ٢٨١ .

(٥) أصول قانون المرافعات د/أحمد هندی . بند ٧٤ ص ١٩٥ .

والملاحظ أن تحديد الاختصاص المنصوص عليه طبقاً لقيمة الدعوى، لا يكون إلا بالنسبة للدعوى التي تدخل في اختصاص المحكمة النوعي أو القيمي، أما الدعوى التي ترفع إليها على سبيل الخطأ دون أن تنتبه المحكمة لعدم اختصاصها نوعياً أو قيمياً، فإن الحكم الذي يصدر فيها يكون قابلاً للاستئناف، ولو صدر في حدود النصاب الانتهائي لهذه المحكمة، وذلك حرصاً على عدم تفويت درجة على الخصم من درجات التقاضي^(١). كما تظهر أهمية تحديد قيمة الدعوى في معرفة قدر الرسوم القضائية المستحقة عن كل دعوى حيث يختلف هذا القدر باختلاف درجة التقاضي، فضلاً عن اختلافه باختلاف قيمة الدعوى.

ثالثاً: الاختصاص القيمي للمحاكم^(٢):

- ١- تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه.
- ٢- تختص المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة أول درجة بالحكم ابتدائياً في جميع الدعوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتي ألف جنيه.
- ٣- تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية.
- ٤- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف؛ إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو كانت غير مقدرة القيمة.

ولقد عرف الفقه الإسلامي هذا النوع من الاختصاص، ونص على جوازه بناءً على قاعدة تخصيص القضاء بالمكان والزمان والحادث والنصاب المقدر من المال. وبناءً على هذه القاعدة يمكن لى القول بجواز اختصاص القيمي شرعاً في مجال العمل القضائي، ومن ثم فيصبح تقليد القاضي عليه؛ لأن قضاءه استنباطاً عن الإمام فصيح عموماً وخصوصاً كالوكالة^(٣).

ولقد ثبت عن سيدنا عمر- رضي الله عنه- أنه قال لأحد قضاة "رد الناس عني في الدرهم والدرهمين"^(٤). كما جاء عنه أيضاً قوله لأحد القضاة: "اكفني بعض الأمور يعني صغارها"^(٥).

(١) قانون القضاء المدني د / محمود هاشم ، بند ٢١٧ ص ٣٣٩ .

(٢) عدل النصاب القيمي للمحاكم بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ - الجريدة الرسمية، العدد ٢٧ في ١٠/٧/٢٠٢٤ م.

(٣) الأحكام السلطانية للمواردى ص ٧٢ ، درر الحكام أ / على حيدر ٤ / ٥٩٨ .

(٤) سبق تخريجه والحكم عليه ، ص : ٢٦٤ .

(٥) تهذيب التهذيب : لابن حجر ١١ / ٢٨٩ . ط دار الفكر . بيروت . ط الأولى . ط ١٤٠٤ هـ

وهذا يدل على اعتبار قيمة الدعوى كمعيار يتم بمقتضاه تخصيص قضاء القاضي، وقصر ولايته على ما خصص له دون غيره، ويستفاد هذا التخصيص من خطاب التولية الذي يصدر له من الإمام المولى^(١).

المبحث الثاني

تحديد قيمة الدعوى وأثره في تحديد المحكمة المختصة

اتخذ المقتن من القيمة الاقتصادية للدعوى أساساً قانونياً لتوزيع الاختصاص النوعي - المقدر - بين محاكم الدرجة الأولى^(٢)، الأمر الذي استلزم تقرير قواعد عامة نص على ضرورة الالتزام بأحكامها عند تحديد قيمة الدعوى، وذلك لبيان ما يدخل من طلبات الخصم عند تقدير قيمة الدعوى وما يخرج منها، وهذه القواعد تختلف بداهة بحسب ما إذا كانت الدعوى تتضمن طلباً واحداً أم طلبات متعددة^(٣) وقواعد أخرى خاصة جعلها تحكم كيفية تقدير قيمة الدعوى : لما يترتب على هذا التقدير من تحديد للمحكمة المختصة قانوناً بنظرها، ومعرفة مدى قابلية الحكم الذي يصدر منها للاستئناف أو عدم قابليته لذلك^(٤).

وأتناول الحديث عن هذه القواعد بشئ من التفصيل من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: القواعد العامة لتحديد قيمة الدعوى وأثر ذلك في تحديد الاختصاص.
المطلب الثاني: القواعد الخاصة بكيفية تقدير الدعوى.

(١) المغنى ومعه الشرح الكبير لابن قدامة ٣٨٢/١١، القضاء في الإسلام د / محمد سلام مذكور . ص ٢٦.

(٢) المرافعات . د/ عبد الحميد أبو هيف . بند ٥٦٤ . ص ٤٢١ ، نقض مدني . طعن رقم ٨٧ لسنة ٣٤ ق جلسة ٢٩ / ٦ / ١٩٦٧ م ، مجموعة المكتب الفني ص ١٤١٠ مجلة هيئة قضايا الدولة الإلكترونية ، العدد الأول السنة الأولى ، يناير ٢٠٠٧ م ، وجاء فيه " متى كانت الدعوى بحكم الأساس الذي رفعت به والطلبات المطروحة فيها ما يدخل في اختصاص المحاكم فإنه لا يخرج الدعوى من هذا الاختصاص أن يكون الادعاء فيها غير صحيح قانوناً لأن ما يترتب على عدم صحته هو رفض الدعوى لا الحكم بعدم الاختصاص " .

(٣) قانون القضاء المدني . د / محمود هاشم . بند ٢١٨ . ص ٣٤٠ .

(٤) أصول وقواعد المرافعات. د/ أحمد ماهر زغلول. بند ٢٧١. ص ٥٥٢.

المطلب الأول

القواعد العامة في تحديد قيمة الدعوى وأثر ذلك في تحديد الاختصاص

تختلف القواعد العامة التي وضعها المقتن لتحديد قيمة الدعوى بحسب ما إذا كانت دعوى المدعى تتضمن طلباً واحداً أم تتضمن طلبات متعددة، وأوضح هاتين الحالتين بشيء من التفصيل في الفرعين التاليين :

الفرع الأول: قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلب الواحد .

الفرع الثاني : قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلبات المتعددة .

الفرع الأول

قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلب الواحد

إذا تضمنت دعوى المدعى طلباً واحداً؛ فإن المقتن اعتمد في هذه الحالة على مجموعة من القواعد القانونية يتم بمقتضاها تحديد قيمة الدعوى، وتتمثل هذه القواعد فيما يلي:

القاعدة الأولى: العبرة بقيمة الشيء المطلوب الحكم به:

من الواجب القانوني أن تكون الدعوى معلومة القيمة قبل رفعها إلى القضاء، حتى يتمكن الخصم من رفع دعواه أمام المحكمة التي تختص قانوناً بنظرها، ومن ثم فإن معلومية قيمة الدعوى قبل رفعها هي التي تحدد المحكمة التي ترفع إليها، وهنا يجب النظر إلى مطلوب المدعى، الذي يبغى الحكم به، فما يطلبه المدعى هو المعتبر قانوناً في تحديد قيمة الدعوى بغض النظر عما يحكم به القاضي^(١).

وبناءً على هذا فإن القيمة التي يحكم بها القاضي ليست معتبرة في تحديد قيمة دعوى المدعى، وإنما المعتبر في تحديد قيمتها ما يطلبه المدعى . قلَّ ذلك أو كثر.. وهذا يستلزم القول بأن مطلوب المدعى في دعواه هو الأساس القانوني لمعرفة المحكمة المختصة، ومن ثم فإن هذا الطلب هو الذي يحدد طبيعة الحكم الذي يصدر فيها من حيث قابليته للطعن أو عدمه^(٢).

هذا ولقد أحسن المقتن عندما قرر هذه القاعدة وجعلها أساساً لتحديد قيمة الدعوى؛ لأنه ليس من السائغ قانوناً أن تتوقف قواعد تحديد الاختصاص، أو قابلية الحكم للاستئناف على

(١) المرافعات د / محمد حامد فهدى. بند ١٥٧. ص ١٦٦ ، المرافعات د/أحمد أبو الوفا . بند ٣٠٧ . ص ٣٤٦ ، الوسيط . د / أحمد السيد صاوى . بند ٢٠٨ . ص ٢٨٩ .

(٢) المرافعات د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٠٧ . ص ٣٤٦ ، قانون القضاء المدني د/ محمود هاشم بند ٢١٨ ص ٣٤٠ .

إرادة القاضى في حكمه، فقد يبين له من ظروف الدعوى ما يحمله على عدم الحكم بشئ مما يطلبه المدعى^(١)، أو يحكم له بشئ أقل مما يطلبه، وهذا يؤدي إلى اضطراب الدعوى وعدم استقرارها، فضلاً عن أن مسألة الاختصاص يجب أن تكون سابقة على الحكم فى موضوع الدعوى^(٢).

لذا فقد حالف المقنن التوفيق عندما جعل قيمة ما يطلبه المدعى أساساً لتحديد قيمة الدعوى، ومن ثم ينتج ذلك أثره فى تحديد المحكمة المختصة وفى معرفة قابلية الحكم للاستئناف أو عدمه، فضلاً عن استقرار الدعوى من وقت رفعها وعدم تقيدها بإرادة القاضى فى حكمه، وإلا أثر ذلك على قواعد الاختصاص القضائي.

وبناءً على هذا فإن دعوى التعويض الناتجة عن فسخ عقد من العقود تقدر قانوناً وفقاً لمبلغ التعويض الذى يطلبه المدعى، بصرف النظر عن القدر المالى الذي تحكم به المحكمة، أو قيمة الشئ محل التعاقد، ولو بلغت قيمته ما يزيد عن مطلوب الخصم^(٣).

القاعدة الثانية: العبرة بقيمة المطلوب وقت رفع الدعوى:

لتحديد قيمة الدعوى قانوناً يجب النظر إلى ما يطلبه المدعى وقت رفع الدعوى^(٤)، دون غيره، وبهذا فإن قيمة الدعوى تتحدد وقت رفعها إلى القضاء، سواء أكانت الدعوى مدنية أم تجارية، وأما دعاوى الأحوال الشخصية فتختص بها نوعياً محكمة الأسرة أياً كانت قيمتها^(٥).

ويرجع اعتبار المقنن لوقت رفع الدعوى إلى استقرار الدعوى، وعدم تأثر قيمتها بالتغيرات والتقلبات التى تطرأ على الأسعار وقيم الأشياء، وبذلك فقد تجنب المقنن تأثير هذه المتغيرات على قواعد الاختصاص؛ نظراً لما يترتب على هذه المتغيرات من تأخير الفصل فى الدعاوى^(٦).

(١) الوسيط . د / أحمد السيد صاوى . بند ٢٠٨ . ص ٢٨٩ .

(٢) مبادئ القضاء المدنى . د / وجدى راغب . ص ٢٨٦ .

(٣) القانون القضائي الخاص. د/ إبراهيم نجيب سعد . ج ١ . بند ١٨٤ . ص ٤٥٢ ، قانون القضاء المدنى . د/ فتحى والى . بند ١٩٨ . ص ٤٥٦ .

(٤) قانون القضاء المدنى . د/ محمود هاشم. بند ٢١٨ . ص ٣٤١ ، الوسيط . د/ أحمد السيد صاوى. بند ٢٠٧ ص ٢٨٩ .

(٥) أصول المرافعات . د/ أحمد مسلم . بند ٣٠٠ . ص ٢٨٩ ، أصول وقواعد المرافعات . د/ أحمد ماهر زغلول . ص ٥٥٣ هامش " ٢ " .

(٦) الوسيط. د/ أحمد السيد صاوى. بند ٢٠٧ . ص ٢٨٩ ، قانون القضاء المدنى . د / فتحى والى ص ٢٦٨ ، الوسيط . د/ نبيل إسماعيل عمر . بند ٣٣ . ص ٩٣ .

وبناءً على هذا : إذا كانت قيمة الطلب وقت رفع الدعوى خمسون ألف جنيه اعتبر هذا القدر قيمة لها، ومن ثم تكون قيمتها مقدرة بهذا المبلغ، ويترتب على هذا التحديد إختصاص المحكمة الجزئية بنظرها، لدخولها في حدود اختصاصها القيمي، ويكون حكمها قابلاً للاستئناف؛ لدخوله في النصاب الابتدائي لهذه المحكمة.

ووفقاً لهذا تظل المحكمة الجزئية مختصة بنظر الدعوى ولو أن قيمة ما طلبه المدعى قد زادت بعد رفعها، عملاً بما قرره المقنن من أن العبرة في قيمة الدعوى بوقت رفعها إلى القضاء^(١)، وليس بما يطرأ على هذه القيمة من تغيير بالزيادة أو النقصان ويطبق هذا المبدأ أمام المحكمة الابتدائية، فلو فرض أن قيمة ما يطلبه المدعى وقت رفع الدعوى أكثر من مائة ألف جنيه، فإن المحكمة الابتدائية هي المختصة قانوناً بنظر هذه الدعوى : لدخولها في حد نصابها الابتدائي، ومن ثم إذا ما حدث هبوط في الأسعار وفي قيم الأشياء أدى إلى هبوط في قيمة الطلب المقدم من المدعى، بأن قلت قيمته لتصل مثلاً إلى تسعون ألف جنيه مثلاً، فلا يقال في هذه الحالة بسلب الاختصاص من القاضى الابتدائي إلى القاضى الجزئى، لخروج الدعوى من اختصاص الأول القيمي ودخولها في اختصاص الثانى، فهذا القول لا يقبل قانوناً، لأن المقرر أن العبرة في تحديد قيمة الدعوى بوقت رفعها ومن ثم فلا أثر لتغيير الأسعار وقيم الأشياء على قواعد الاختصاص المقررة.

وعليه تظل المحكمة الابتدائية صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى : لدخولها في حد اختصاصها القيمي وقت رفعها.

القاعدة الثالثة: العبرة بقيمة الطلب المتنازع فيه :

المعتبر قانوناً عند تحديد قيمة الدعوى هو قيمة الشئ المتنازع فيه، ومن ثم فلا يدخل في قيمتها ما يطلبه الخصم دون أن يكون محلاً للمنازعة^(٢)، ولقد نص المقنن على ذلك صراحة في المادة ٤٠ مرافعات "إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء وحده، إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه، ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه، فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله" وبالنظر إلى هذا النص يتضح جلياً أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى إنما هي بقيمة الشئ المتنازع فيه، فإن كان التنازع واقعاً في جزء من الحق كانت قيمة الدعوى محددة بحسب قيمة هذا الجزء فحسب ولو أن المدعى عليه أثار النزاع في الحق بأكمله^(٣).

(١) الوسيط. د/نبيل إسماعيل عمر. بند ٣٣. ص ٩٣

(٢) مبادئ القضاء المدنى. د/ وحدى راغب. ص ٢٨٦ .

(٣) المرافعات. د/ عبد الحميد أبو هيف. بند ٥٦٧. ص ٤٢٣، ص ٤٢٤.

أما إذا كانت المنازعة في الحق بأكمله حددت قيمة الدعوى بحسب قيمة الحق المتنازع فيه بأكمله، بيد أن التنازع إذا وقع في الحق بأكمله فيشترط لتقدير قيمة الدعوى بقيمة الحق بأكمله الشرطان التاليان:

الأول: أن يكون المدعى - صاحب الطلب - خصماً في الدعوى، أى ذا صفة في النزاع الذى يثيره المدعى عليه في كامل الحق فإن لم يكن المدعى كذلك إلا بالنسبة للجزء المطالب به في الدعوى قدرت القيمة في هذه الحالة بقيمة هذا الجزء فقط، حيث لا يتصور التمسك بحجية الحكم الذى يصدر في الحق بأكمله تجاه شخص لم يكن طرفاً في الدعوى. ومثال ذلك: أن يحيل الدائن جزءاً من دينه إلى آخر، فيرفع المحال إليه بالدين دعوى على المدين لمطالبته بالجزء المحال، فينازعه المدين في أصل الدين كله دون أن يدخل في الدعوى الدائن الأصلي، فالدعوى بين المحال إليه بالدين والمدين لا تقدر إلا بقيمة الجزء المحال من الدين، لأن الحكم في هذه الدعوى لا يكون له حجية الشيء المحكوم به إلا بالنسبة للجزء المطلوب فقط، ولا صفة للمدعى في الخصومة التى يثيرها المدعى عليه إلا في ذلك الجزء^(١).

الثاني: ألا يكون الجزء المطلوب . محل الدعوى . هو الجزء الأخير من الحق، فإن كان كذلك فالدعوى تقدر بقيمة هذا الجزء وحده، ولو أثار المدعى عليه المنازعة في الحق بأكمله^(٢)؛ حيث لا أهمية لتلك المنازعة بالنسبة لقيمة الدعوى^(٣).

القاعدة الرابعة: العبرة بالطلب الختامى للمدعى:

تقدر قيمة الدعوى على أساس الطلب الختامى للمدعى^(١)، وذلك إعمالاً لما قرره المقتن في المادة ٣٦ / ٣ مرافعات.

(١) المرافعات. د/ أحمد أبو الوفا. بند ٣١٣. ص ٣٥٦.

(٢) المرافعات. د/ عبد الحميد أبو هيف. بند ٥٦٧. ص ٤٢٤.

(٣) قانون القضاء المدنى. د/ محمود هاشم. بند ٢١٨. ص ٣٤٢.

والحكمة من ذلك تكمن في الرغبة في التفويت على المدعى فرصة التحايل على قواعد الاختصاص، فإذا كانت الدعوى بحسب قيمتها من اختصاص المحكمة الابتدائية، فإنه يحال دون المدعى بموجب القاعدة المتقدمة دون التحايل على الاختصاص، بأن يقسم دعواه إلى دعاو صغيرة يرفعها مستقلة عن بعضها أمام المحاكم الجزئية، وكذلك إذا كانت الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية وتدخل في نصاب الاستئناف، فإنه لا يجوز تقسيمها كما تقدم؛ حتى لا تكون الأحكام الصادرة فيها انتهائية، وهو ما يؤدي إلى تفويت درجات التقاضى على المدعى عليه. أصول وقواعد المرافعات. د/ أحمد ماهر زغلول. ص ٥٦٨. هامش "٣" المرافعات. أحمد أبو الوفا. بند ٣١٣. ص ٣٥٧.

حيث نصت على أنه: ".... ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم"، وما قرره أيضاً في المادة ٢٢٥ مرافعات، حيث نص فيها على أنه: "يكون التقدير بمراعاة القواعد العامة على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى".

وبناءً على هذا يتضح أن المعتبر قانوناً من الطلبات عند تقدير قيمة الدعوى هو الطلب الختامي المقدم من المدعى دون غيره .

فإذا رفعت دعوى أمام محكمة جزئية تدخل بحسب قيمتها في نصاب تلك المحكمة، ثم أعقب ذلك المدعى بطلب ختامي من شأنه تعديل الطلب الأصلي بزيادة قيمته عن القيمة التي رفع بها عند اتصال الدعوى بالمحكمة الجزئية، فالزيادة هنا تستوجب على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وتأمّر بإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، لدخولها في النصاب المالي المقدر لها^(٢).

أما إذا حدث بمقتضى الطلب الختامي العكس بأن تضمن تعديل الطلب الأصلي بنقص قيمته إلى نصاب المحكمة الجزئية، وكانت الدعوى قد رفعت بداية إلى المحكمة الابتدائية ؛ لدخولها وفقاً للطلب الأصلي - المعدل - في نصاب تلك المحكمة، فهل تظل المحكمة الابتدائية مختصة بنظر الدعوى أو تحيل الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة ؛ لدخولها في نصابها وفقاً للطلب الختامي ؟

ذهب معظم شراح القانون - وأرى تأييد هذا المذهب - إلى القول بأن على المحكمة الابتدائية أن تتوقف عن نظر الدعوى وتحكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية التي صارت وفقاً للطلب الختامي مختصة بنظرها، وذلك لصريح نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات، الذي يقضى بأن على المحكمة إذا بان لها عدم الاختصاص بنظر الدعوى، فإنها تقضى فيها بعدم الاختصاص والإحالة^(٣).

في حين ذهب بعض الفقه إلى القول بأن المحكمة الابتدائية تستمر في نظر الدعوى، ولا أثر لتعديل الطلب الأصلي بالطلب الختامي، وذلك لاعتبار هذا الطلب وجهاً من وجوه الطلبات

(١) أصول قانون المرافعات . د/ أحمد هندی بند ٧٦ ص ١٩٧ .

(٢) الوسيط . د/ أحمد السيد صاوى . بند ٢٠٩ . ص ٢٩٠ ، أصول وقواعد المرافعات . د/ أحمد ماهر زغلول . ٢٧٩ . ص ٥٧٣ ، الوسيط . د/ نبيل إسماعيل عمر . بند ٣٦ . ص ٩٥ .

(٣) المرافعات . د/ أحمد أبو الوفا . بند ٣٠٩ ص ٢٤٩ ، ص ٣٥٠ ، نظرية الاختصاص . د/ عبد الباسط جمعى ص ٥٠ . القانون القضائي الخاص . د/ إبراهيم نجيب سعد . بند ١٨٤ . ٤٥٦ قانون القضاء المدني . د/ محمود

هاشم . بند ٢١٩ ص ٣٤٣ ، مبادئ القضاء المدني . د/ وجدي راغب . ص ٢٨٦ ، ص ٢٨٧ .

العارضة التي أشارت إليها المادة ١٢٤ مرافعات، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الابتدائية أياً كانت قيمتها طبقاً للمادة ٣/٤٧ مرافعات، فضلاً عن كون المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص العام والشامل في مجال الاختصاص القضائي، وإعمالاً للمبدأ الذي يقرر أن من يملك الأقل يملك الأكثر^(١).

بيد أنه لا يجوز في هذه الحالة استئناف الحكم الصادر في تلك الدعوى ؛ لدخوله في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية^(٢).

ويشترط لاعتبار الطلب -المعدل . طلباً ختامياً الشروط التالية:

- ١- أن يكون طلباً معدلاً في الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان، فإن لم يكن كذلك بأن كان طلباً جديداً اعتبر طلباً عارضاً، ومن ثم يسرى عليه الأحكام المتعلقة بالطلبات العارضة^(٣).
 - ٢- ألا يكون الطلب – المعدل - قد قصد به التحايل على قواعد الاختصاص المقررة أو على نهائية الحكم^(٤).
 - ٣- ألا يكون الطلب مندمجاً في الطلب الأصلي . أي أن الطلب الأصلي يتضمنه . فإن كان كذلك فلا أثر له في تقدير قيمة الدعوى^(٥)، ولا يدخل هذا الطلب في التقدير؛ لأن الحكم في الطلب الأصلي يتضمنه؛ حيث لا يجوز أن يكون للطلب المندمج كياناً مستقلاً، كما هو الشأن في شطب الرهن في دعوى براءة الذمة^(٦).
- ويلاحظ أن الطلب المندمج الذي لا يؤثر في تقدير قيمة الدعوى يشترط فيه ألا يثار بشأنه النزاع فإن أثير فيه نزاعٌ وجب تقدير الطلب المندمج تقديراً مستقلاً عن الطلب الأصلي.

(١) المرافعات. د/ محمد حامد فهي. بند ١٥٧. ص ١٦٦ ، ص ١٦٧ . قواعد المرافعات . أ/ محمد العشماوي د/عبد

الوهاب العشماوي. بند ٢٤٢. ص ٤٤٠، الوسيط. د/ أحمد السيد صاوي. بند ٢٠٩. ص ٢٩٠ ، ٢٩١.

(٢) الوسيط . د/ أحمد السيد صاوي . بند ٢٠٩ . ص ٢٩١ .

(٣) القانون القضائي الخاص . د/ إبراهيم نجيب سعد . بند ١٨٤ . ص ٤٥٥ .

(٤) قانون القضاء المدني . د/محمود هاشم . بند ٢١٨ . ص ٣٤٣ .

(٥) أصول وقواعد المرافعات . د/ أحمد ماهر زغلول . بند ٢٧٧ . ص ٥٦٤

(٦) قانون القضاء المدني . د/ محمود هاشم . بند ٢١٨ . ص ٣٤٣

القاعدة الخامسة: العبرة بما يكون مستحقاً يوم رفع الدعوى "ملحقات الطلب الأصلي"^(١):

تقتضى هذه القاعدة بأن يراعى عند تحديد قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من فوائد وتعويضات ومصاريف وغير ذلك من ملحقات الطلب الأصلي.

وقد نص المقتن على تقرير هذه القاعدة في المادة ٣٦ مرافعات حيث نصت على أن: "تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى، ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها، وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.....".

وبناءً على ما تقدم فقد اعتبر المقتن قيمة ملحقات الطلب الأصلي وتوابعه عند تقدير قيمة الدعوى.

ويشترط لإدخال ملحقات الطلب الأصلي في تقدير قيمة الدعوى الشروط التالية:

- ١- أن يطلب ذلك المدعى، فلا يجوز للمحكمة إدخال هذه الملحقات في قيمة الدعوى من تلقاء نفسها، دون أن يطلبه الخصم^(٢).
 - ٢- أن تكون هذه الملحقات مقدرة القيمة. أي قابلة للتقدير. فإذا لم تكن كذلك فلا تدخل في تقدير قيمة الدعوى، وإنما تتحدد قيمتها في هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلي وحده، بيد أنه يستثنى من ذلك حالة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته^(٣).
 - ٣- أن تكون هذه الملحقات مستحقة الأداء وقت رفع الدعوى^(٤).
- ويستثنى من ذلك طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها؛ وذلك على اعتبار أن ما يستجد من الأجرة. ويكون في ذمة المستأجر. يعد جزءاً من الطلب الأصلي^(٥).

(١) يقصد بالطلب الملحق: هو الذى يتبع طلباً أصلياً فيصير في اعتبار القانون. أي كانت قيمته لو أنه نظر إليه مستقلاً عن الطلب الأصلي. كأنه جزء منه فلا يضيف شيئاً إلى قيمة الدعوى ولا يحسب في تقديرها. المرافعات د/ محمد حامد فهدى. بند ١٧١. ص ١٧٥.

(٢) قانون القضاء المدني. د/ محمود هاشم. بند ٢١٨. ص ٣٤٤.

(٣) أصول قانون المرافعات. د/ أحمد هندی بند ٧٧. ص ٢٠٣.

(٤) أصول المرافعات. د/ أحمد مسلم. بند ٢٠٠. ص ٢١١.

(٥) الوسيط. د/ نبيل إسماعيل عمر بند ٣٧ ص ٩٥، ٩٦.

الفرع الثاني

قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلبات المتعددة

التعدد في الدعوى قد يكون نتيجة لتعدد موضوع الدعوى أو نتيجة لتعدد أطرافها: أولاً: التعدد الموضوعي: وهو قد يكون تعددًا بسيطاً وقد يكون تعددًا موصوفاً، فالتعدد البسيط يقصد به: تعدد الطلبات الأصلية في الدعوى المقدمة من المدعى في مواجهة المدعى عليه^(١). وقد أطلق بعض الفقه الإجمالي على هذا النوع التعدد الاستقلالي^(٢)، وهو يعني استقلال كل طلب من الطلبات الأصلية المتعددة في الدعوى من حيث السبب الذي نشأ عنه.

والضابط القانوني لتقدير الدعوى متعددة الطلبات تعددًا موضوعيًا: هو السبب القانوني الذي تستند إليه هذه الطلبات، فإذا كان السبب واحدًا، فالدعوى تقدر بقيمتها بقيمة الطلبات كلها، أما إذا كان السبب متعددًا فالتقدير يكون باعتبار كل منها على حدة^(٣). عملاً بالمادة ١/٣٨ مرافعات والتي نصت على أنه: "إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار كل منها على حدة".

مثال الدعوى متعددة الطلبات المستندة إلى سبب قانوني واحد، دعوى المطالبة بعدة أقساط من الأجرة، فالدعوى تقدر في هذه الحالة بقيمة مجموع الأقساط -المطالب بها- كلها، نظرًا لوحدة السبب القانوني وهو عقد الإيجار^(٤).

مثال الدعوى متعددة الطلبات المستندة إلى عدة أسباب مختلفة دعوى الشخص بدفع أجرة الشئ المؤجور وبدفع ثمن ما باعه من منقولات، فالدعوى هنا تقدر بقيمة كل طلب على حدة، وذلك نظرًا لاختلاف السبب في كل من الطرفين^(٥).

بيد أنه يلاحظ أن وحدة السبب أو تعدده كأساس لتقدير قيمة الدعوى لا يكون إلا بالنسبة لطلبات المدعى وحده، فلا تجمع فيها طلبات المدعى عليه^(٦).

(١) مبادئ المرافعات. د/عبد الباسط جميعي ص ٦٢

(٢) أصول المرافعات. د/ أحمد مسلم. بند ٢٠٨. ص ٢١٥.

(٣) الوسيط. د/ نبيل إسماعيل عمر. بند ٣٨. ص ٩٦، ٩٧.

(٤) مبادئ المرافعات. د/ عبد الباسط جميعي. ص ٦٢.

(٥) تقنين المرافعات. أ/ محمد كمال عبد العزيز ص ١٥١. ١٥٣.

(٦) الوسيط. د/نبيل إسماعيل عمر. بند ٣٨. ص ٩٦، ٩٧.

وأما التعدد الموصوف، فقد يكون تعدداً احتياطياً وقد يكون تعدداً اختيارياً، فالتعدد الاحتياطي كما لو طالب المدعى المدعى عليه بطلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي فبأى الطلبين يكون تقدير الدعوى؟.

لقد ترك المقتن الإجابة عن هذا التساؤل لجهود الفقه والقضاء، وجعل هذه المسألة تقديرية للمحكمة، بيد أن الرأي الغالب يميل نحو تقدير قيمة الدعوى على أساس أكبر الطلبين قيمة، ويشترط كذلك أن يكون الطلبان في مواجهة شخص واحد^(١)؛ فإذا كانا في مواجهة شخصين أو أكثر اعتبرت الدعوى في هذه الحالة دعوى منطوية على تعدد في الخصوم، ومن ثم فيطبق بشأنها وحدة السبب أو تعدده^(٢). عملاً بالمادة ٢٩ مرافعات والتي نصت على أنه: "إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه". ويرى بعض الفقه أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي دون الطلب الاحتياطي^(٣).

وأما التعدد الاختياري فهو يتحقق عندما تتعلق الدعوى بحق تخييري. والخيار هنا إما أن يكون للمدعى أو للمدعي عليه فإن كان الخيار للمدعي كما لو كان موضوع الدعوى عدداً من الأموال تبرأ ذمة المدين بوفاء أحدها، وهنا تقدر الدعوى بحسب قيمة الشئ الذي يختاره المدعى محلاً للوفاء. وأما إذا كان الخيار للمدعي عليه فإن المدعى يطالب المدعى عليه بأى من الأشياء التي تبرأ بها ذمته، وهنا لا مناص من تقدير قيمة الدعوى بأكبر الأشياء قيمة^(٤)، ومن ثم تتحدد على أساسها المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

ثانياً: تعدد أطراف الخصومة: إذا تعدد أطراف الدعوى فإن القاعدة التي تحكم قيمة الدعوى هي ذات القاعدة التي تتبع في حالة تعدد الطلبات، ومن ثم يطبق بشأنها القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٩ مرافعات. ويستوى في هذا أن يكون التعدد في جانب المدعى أو في جانب المدعى عليه. وبهذا يتضح أن العبرة بوحدة السبب أو تعدده، فالدعوى تقدر بقيمة المطلوب فيها - ولو تعدد فيها الخصوم ما دام السبب واحداً - وبنصيب كل خصم إذا تعددت أسبابها. كما لو رفع دائن دعوى على مجموعة ورثة وطالب كلاً منهم بقدر نصيبه في الدين، فهنا تقدر الدعوى بقيمة الدين كله نظراً لوحدة السبب القانوني.

(١) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٣١٤ ص ٢٥٧ .

(٢) الوسيط . د / أحمد السيد صاوى . بند ٢١٤ . ص ٢٩٦ .

(٣) قواعد المرافعات / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى . بند ٣٤٣ ص ٤٤٢ .

(٤) قانون القضاء المدني . د / محمود هاشم بند ٢٢١ . ص ٣٥٠ .

المطلب الثاني

كيفية تقدير قيمة الدعوى

لا شك أن تقدير قيمة الدعوى له أهميته في تحديد المحكمة المختصة، ومعرفة قابلية الحكم الذي يصدر منها للاستئناف أو عدم قابليته لذلك كما تقدم^(١)، وحرصاً من المقتن على تحقيق هذه الأهمية في العمل القضائي فقد عمد بعد أن فرغ من بيان القواعد التي تحكم تحديد قيمة الدعوى إلى بيان كيفية تقدير هذه القيمة، وذلك في كافة الدعاوى المختلفة .

وهذه الدعاوى قد يكون محلها مبلغاً من النقود وهنا الأمر لا يحتاج إلى عناء أو مشقة في تقدير قيمة الدعوى، حيث تقدر قيمتها بقيمة مبلغ المال النقدي المطلوب فيها^(٢).

وقد يكون محلها طلباً آخر غير نقدي، وهنا وضع المقتن بعد جهد كبير وعناء شديد عشرة قواعد قانونية يتم بمقتضاها تقدير قيم الدعوى، وقد نص عليها في المادة ٣٧ مرافعات، وأوضح . بإيجاز. فيما يلي هذه القواعد، وذلك على النحو التالي :

القاعدة الأولى: الدعاوى العقارية:

"الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي غير المبنية أو الزراعية يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية^(٣)، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته " م ٣٧ / ١ مرافعات . وبهذا يتضح أن المقتن جعل للمحكمة سلطة تقدير قيمة الدعاوى العقارية التي لم تربط عليها ضريبة، وللمحكمة في سبيل ذلك أن تستعين بما يقدمه الخصوم من مستندات أو بتقارير الخبراء الذين تنديهم لذلك، أو بمثل المثل^(٤) . كما يلاحظ أن المعتبر في التقدير هو الضريبة الأصلية دون الضريبة الإضافية^(٥).

(١) الوسيط. د/ نبيل إسماعيل عمر. بند ٣٠. ص ٨٩ .

(٢) قانون القضاء المدني. د/ محمود هاشم. بند ٢٢٣ ص ٣٥٣

(٣) لقد سبق تعديل هذه المادة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ م، الجريدة الرسمية. العدد ٢٢ مكرر، في ١٩٩٢/٦/١ م ثم عدلت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ م، الجريدة الرسمية. العدد ١٩ مكرر في ١٧ مايو ١٩٩٩ م، وذلك باستبدال عبارة " خمسمائة مثل " بعبارة " ثلثمائة مثل " وعبارة " أربعمائة مثل " بعبارة " مائتي مثل " .

(٤) الوسيط. د/ فتحي والي. بند ص ٢٨٠ .

(٥) الاختصاص القبي ومواعيد الإعلانات والتنفيذ في ضوء القانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ م. د/ رمضان جمال كامل بند

٥. ص ١١. ط/ المركز القومي للإصدارات القانونية .

القاعدة الثانية : الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار:

"الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار، أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق، فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار" م ٢/٣٧ مرافعات.

وبناء على هذه القاعدة جعل المقتن قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقار هي قيمة العقار المتنازع على ملكيته، فتقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار ثبوتاً أو نفياً بقيمة العقار ذاته، ولو لم تكن الدعوى من الدعاوى العينية العقارية كدعوى الشفعة مثلاً، وغيرها من الدعاوى التي تتصل بالملكية^(١).

كذلك تقدر قيمة الدعوى على النحو المتقدم بالنسبة للمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار في حالة ما إذا ورد التنفيذ على حق الملكية، أما إذا ورد على حق آخر قدرت قيمة الدعوى على أساس هذا الحق^(٢)، بيد أن المقتن قد أسند الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقفية لقاضي التنفيذ م ٢٧٥^(٣) ومن ثم فلا أهمية لتقدير قيمة المنازعات بالنسبة لتحديد المحكمة المختصة، حيث تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ، ولكن تبقى أهمية التقدير في معرفة نصاب الاستئناف^(٤). وإذا تعلق الدعوى بتقرير حق انتفاع أو نفيه أو ملكية الرقبة أو نفيها قدرت قيمة الدعوى بنصف قيمة العقار، وبربع قيمة العقار. المقرر عليه الحق إذا تعلق الدعوى بحق ارتفاق أو نفيه^(٥).

القاعدة الثالثة: الدعاوى المتعلقة بالحكر:

"إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة الحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين".
تقرر هذه القاعدة أن دعوى الحكر إذا تعلق بطلب تقدير قيمة معينة له قدرت الدعوى بعشرين مثل القيمة السنوية، وإذا تعلق بزيادة قيمة له قدرت الدعوى بعشرين مثل الزيادة

(١) أصول وقواعد المرافعات. د/ أحمد ماهر زغلول. بند ٢٩٣. ص ٦٠٦، ٦٠٧.

(٢) القانون القضائي الخاص. د/ إبراهيم نجيب سعد بند ص ٤٦٦.

(٣) معدلة القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ م.

(٤) الوسيط د/ نيل إسماعيل عمر. بند ٤٠ ص ١٠٣.

(٥) نظرية الاختصاص. د/ عبد الباسط جمعي. ص ٤٧.

المطلوبة^(١)، ويلاحظ أن الضابط في اتباع هذا التقدير هو انصباب الدعوى على أصل الحكر أو زيادة قيمته، ومن ثم لا تتبع هذه القاعدة إذا كان النزاع مثلاً خاصاً بمبلغ الحكر، حيث يكون التقدير في هذه الحالة بحسب قيمة المبلغ المطلوب^(٢).

القاعدة الرابعة : الدعاوى المتعلقة بالحيازة :

"دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة" م ٤/٣٧ مرافعات. وذلك لأن النزاع في هذه الدعاوى وإن لم يتعلق بالحق الموضوعي الذي ترد عليه الحيازة إلا أنه يدور حول المكنات التي يخولها هذا الحق، فضلاً عن كونها دليلاً على الملكية، وسبباً من أسباب كسبها^(٣).

القاعدة الخامسة: الدعاوى المتعلقة بالإيراد المرتب :

"إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً، وعلى أساس مرتب عشرين إن كان لمدي الحياة" م ٥/٣٧ مرافعات.

ويكون الإيراد مؤبداً إذا كان لا ينتهي بوفاة أحد، ومن ثم فينتقل إلى ورثة المستحق بعد الوفاة، ويكون لمدي الحياة إذا كان مرتباً دورياً لشخص طول حياته، أو حياة شخص آخر^(٤).

القاعدة السادسة : الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل :

"الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة" م ٦/٣٧ مرافعات.

وتطبق هذه القاعدة على الغلال وغيرها من المحاصيل الزراعية دون سائر المنقولات، لسهولة الوقوف على أسعارها في أسواقها العامة، هذا والمعتبر في تقدير قيمة الدعوى هو سعر المحاصيل وقت رفع الدعوى دون غيره.

أما إذا تعلقت الدعوى بمنقولات من غير المحاصيل الزراعية فأرى تأييداً لما ذهب إليه بعض الفقه أن المحكمة تستقل بتقدير قيمة هذه الدعاوى قياساً على استقلالها بتقدير قيمة العقار الذي لم تربط عليه ضريبة^(١). وذلك لعدم النص على تقدير مثل هذه الدعاوى.

(١) الوسيط . د/ أحمد السيد صاوي . بند ٢٢٢ . ص ٣٠٤ ، الوجيز د/ محمد إبراهيم . ص ٤٧٢ .

(٢) قواعد المرافعات أ / محمد العشماوي ، د/ عبد الوهاب العشماوي . بند ٣٥٧ . ص ٤٦٥ .

(٣) تقنين المرافعات أ / محمد كمال عبد العزيز . ص ١٤٩ .

(٤) قانون القضاء المدني د/ محمود هاشم . بند ٢٢٧ . ص ٣٥٦ . مبادئ المرافعات . د/ عبد الباسط جمبجي ص ٥٤

القاعدة السابعة: الدعاوى المتعلقة بعقود غير مستمرة:

"إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البذل تقدر الدعوى بأكبر البديلين قيمة" م ٣٧/٧ مرافعات ويستوى في أعمال هذه القاعدة أن يكون محل التعاقد عقاراً أو منقولاً، بيد أنه يراعى عند تقدير قيمة الشيء محل العقد قواعد التقدير المتبعة في كل منهما^(٢).

القاعدة الثامنة: الدعاوى المتعلقة بعقود مستمرة:

"إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على إمتداد العقد إليها" م ٨/٣٧ مرافعات. وبهذا يتضح: أن المقابل النقدي في دعاوى العقود المستمرة معتبر قانوناً كأساس يتم بمقتضاه تقدير قيم الدعاوى^(٣)، ومن ثم تتحدد بمقتضاه المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى محل النزاع.

القاعدة التاسعة: الدعاوى المتعلقة بالحجز والتأمينات العينية:

"إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر بقيمة الدين المضمون، فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال" م ٩/٣٧ مرافعات.

وبناء على هذه القاعدة يتضح أنه لا شأن لقيمة المال ذاته المحجوز عليه أو محل التأمين العيني في تقدير قيمة الدعوى، إذا كانت بين الدائن الحاجز والمدين^(٤).

(١) الوسيط . د/ أحمد السيد صاوى . بند ٢١٧ . ٢٩٩ . ويرى بعض الفقه أن هذا النص وإن ورد بشأن المحاصيل إلا أنه يطبق أيضاً بالنسبة لجميع المنقولات . نظرية الاختصاص . د / عبد الباسط جمبى . ص ٤٧ .

(٢) الوسيط . د/ نبيل إسماعيل عمر . بند ٤٠ ص ١٠٤ .

(٣) قانون القضاء المدني . د/ محمود هاشم . بند ٢٢٨ ص ٣٥٧

(٤) قانون القضاء المدني د/محمود هاشم بند ٣٥٦ .

أما إذا كانت الدعوى مقامة من الغير بطلب استحقاقه للأموال المحجوزة أو التأمين، فإن التقدير في هذه الحالة يكون باعتبار قيمة هذا المال عقاراً كان أو منقولاً^(١)؛ لأن الدعوى هنا بمثابة دعوى ملكية^(٢).

القاعدة العاشرة : الدعاوى المتعلقة بصحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية

"دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها"^(٣) م ١٠/٣٧ مرافعات. وذلك تأسيساً على أن الدعوى وإن تعلقت بصحة التوقيع أو التزوير إلا أنها تتصل بالحق الثابت في الورقة المدعى بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها^(٤).

أما الدعاوى غير القابلة للتقدير: فقد نص عليها المقنن بقاعدة مستقلة عن القواعد المتقدمة، وهي القاعدة التي قررها في المادة ٤١ مرافعات؛ حيث نص فيها على أنه: "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتي ألف جنيه".

وبناء على هذه القاعدة يفترض في الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير أن قيمتها تزيد عن النصاب الابتدائي للمحكمة الجزئية، ومن ثم فينעד الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحكمة الابتدائية، ويكون حكمها الصادر في هذه الدعاوى قابلاً للاستئناف^(٥).

كما هو الحال في دعاوى الطرد والإخلاء وتسليم الصغير لمن يستحق حضائته^(٦)، هذا ويلاحظ أن الأحكام المتقدمة لا تطبق بالنسبة للدعاوى التي نص المقنن صراحة على عقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية أي كانت قيمتها، ولو أنها كانت غير مقدرة القيمة.

(١) تقنين المرافعات. أ/محمد كمال عبد العزيز ص ١٥٠

(٢) المرافعات ، د/أحمد أبو الوفا. بند ٣٢٤ . ص ٤٤٢ .

(٣) يلاحظ أن المقنن عقد الاختصاص بنظر دعوى صحة التوقيع للمحكمة الجزئية أيأ كانت قيمة هذه الدعوى م ٤٣ / ٥ مرافعات والتي أضافها بمقتضى القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ، وانظر المادة الثالثة من هذا القانون وبناء على هذا : فإن معرفة قيمة هذه الدعوى لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى لم تعد لها أهمية عملية بعد عقد المقنن الاختصاص بنظر تلك الدعوى للمحكمة الجزئية أيأ كانت قيمتها. بيد أن معرفة قيمة الدعوى تبدو أهميتها في معرفة قابلية الحكم الصادر فيها للاستئناف أو عدم قابليته لذلك .

(٤) قانون القضاء المدني قانون القضاء المدني د/فتحى والى. بند ٢٠١ ص ٤٨٠ .

(٥) قانون القضاء المدني د/محمود هاشم. بند ٢٣٠ ص ٣٥٩ ، الوسيط، د/أحمد السيد صاوى. بند ٢٢٤ ص ٣٠٢

(٦) الوسيط . د / نبيل إسماعيل عمر. بند ٣٥ ص ٩٥ .

الفصل الرابع

الاختصاص المحلي

المبحث الأول

مقصود الاختصاص المحلي وأهميته تحديده

الاختصاص المحلي هو: النطاق المكاني أو الجغرافي الذي تمارس فيه المحكمة جزء من الاختصاص النوعي للطبقة التي تتبعها، فكل محكمة تختص بما تختص به طبقته ولكن في حدود نطاقها الإقليمي أو المكاني. فقواعد الاختصاص المحلي هي تلك القواعد التي تحدد اختصاص المحاكم بالنظر إلى محل المحكمة أو بالنظر إلى مجالها المكاني الإقليمي^(١). ويسمى الاختصاص المحلي أيضاً بالاختصاص المكاني أو الإقليمي، وهو يقوم على توزيع المحاكم على الأقاليم لتقريب القضاء من المتقاضين. ويحدد القانون سلطة المحكمة بحيث تقتصر على الدعاوى التي تنتمي بأحد عناصرها - المدعى عليه أو المدعي أو محل الدعاوى أو سببها - إلى الإقليم التابع لها^(٢).

وقد عمد المقتن إلى تقسيم الولاية القضائية محلياً على مجموع المحاكم ذات الطبقة الواحدة في المناطق التي يشملها إقليم الدولة؛ وذلك بتخصيص محكمة أو أكثر - مشكلة من قاضي أو أكثر - في كل منطقة إقليمية تتولى نظر الخصومات التي تقع في هذه المنطقة، وتكون وحدها دون غيرها المختصة بالفصل فيها، ما لم ينص المقتن على غير ذلك^(٣). هذا ويعد الاختصاص المحلي نوعاً من الاختصاص القضائي، تنقسم عليه ولاية القضاء مع غيره من أنواع الاختصاص الأخرى، بيد أن الاعتبار فيه المكان، حيث تتوزع على أساسه الولاية القضائية على مختلف المحاكم من ذات الطبقة بقصد تيسير التقاضي على المتقاضين^(٤).

ويمكن تعريفه بأنه "قدر ما لمحكمة معينة من محاكم الطبقة الواحدة من اختصاص بنظر المنازعات في دائرة إقليم معين أو حدود مكانية معينة"^(١).

(١) قانون المرافعات د/ الأنصاري حسن النيداني ج ١/ ٢٣٩.

(٢) مبادئ النظام القضائي، د/ وجدي راغب فهد ص ٢٣٥.

(٣) نظرية الاختصاص د/ عبد الباسط جميعي ص ١٠٣.

(٤) نظرية الاختصاص د/ عبد الباسط جميعي ص ١٠٣، ١٠٤، القانون القضائي الخاص د/ إبراهيم نجيب سعد ج

١ بند: ١٨٨، ص ٤٧٢.

وعليه : فإن الاختصاص المحلي لمحكمة ما يتحدد بالدائرة الإقليمية التي تشملها بحسب حدودها الجغرافية. فالمحكمة الابتدائية لمدينة سوهاج - مثلاً - تختص محلياً بكافة الدعاوى التي تقع في جميع مراكز وقرى محافظة سوهاج، متى كانت هذه الدعاوى تدخل بحسب قواعد الاختصاص في حدود اختصاصها النوعي والقيمي^(٢). كذلك فإن محكمة جرجا الجزئية تختص محلياً بكل الدعاوى التي تقع في مركز جرجا بما يشملها هذا المركز من قرى وأحياء.

والملاحظ في هذه الحالة أن لقواعد الاختصاص المحلي أثرها القانوني في عقد الاختصاص المحلي لمحكمة معينة أو سلبه منها بعقده إلى محكمة أخرى.

الاختصاص المحلي في الفقه الإسلامي:

الفقه الإسلامي عرف فكرة تخصيص ولاية القاضي بالقضاء في نطاق مكاني محدد، حيث أدى اتساع رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب واختلاط العرب بغيرهم من سكان البلاد التي دخلت في الإسلام حديثاً، إلى زيادة أعباء الولاية، فاحتاج الأمر إلى فصل القضاء عن الولاية، فعين عمر رضي الله عنه للقضاء في بعض الولايات رجالاً يخصصون للقضاء^(٣). ثم تتابع التخصيص في العصور التالية إلا أنه كان يقع بين مد وجزر بحسب كل إمام وكل وال^(٤).

وقد قرر الفقهاء في تخصيص القضاء قاعدة ذكرها الإمام الكرابيسي في كتابه الفروق، فقال: "القضاء مما إذا خص اختصاص به"^(٥). والمعتمد في تخصيص القضاء هو العرف، يقول ابن فرحون "واعلم أن الذي ينبغي أن يعول عليه في ذلك العرف"^(٦). ثم نقل كلام ابن القيم عندما قال "واعلم أن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولى بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب، وقد تكون بعض الأمكنة والأزمنة قاصرة على الأحكام الشرعية فقط، فيستفاد من ولاية القضاء في كل قطر ما جرت به العادة واقتضاه العرف"^(٧).

(١) قواعد المرافعات. أ / محمد العشماوى، د / عبد الوهاب العشماوى ج ٢ بند ٣٧٢ ص ٤٨٢

(٢) المرافعات د / محمد حامد فهمي ص ٣٣٣.

(٣) التنظيم القضائي الإسلامي د / حامد أبو طالب، ص ٣٢.

(٤) المرجع السابق، ص ٣٥٠.

(٥) الفروق، للكرابيسي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ١٤٠٢هـ، كتاب الشهادات ج ٢ / ١٢٠.

(٦) تبصرة الحكام لابن فرحون، ج ١ / ٢٧.

(٧) الطرق الحكمية لابن القيم، ج ١ / ٣٤٨.

وقد أجاز الفقهاء تخصيص القضاء بالمكان^(١) فأجازوا تخصيص قاض أو عدة قضاة لنظر الدعاوى في منطقة جغرافية معينة تصح أن تشمل إقليم الدولة كله أو جزء من هذا الإقليم أو بلدة محددة من بلاده. فالاختصاص المكاني يعني: تقييد عمل القاضي في بلدة معينة أو ناحية منها، بحيث لا تكون للقاضي ولاية على البلد الآخر أو الناحية الأخرى^(٢)، وذلك بأن يخصص ولي الأمر من ولده القضاء بأن يحكم في دائرة مخصصة وأمكنة معينة، وذلك بقصر ولايته على قضاء بعض البلد، سواء اقتصر على أكثر البلد أو أقله أو محلة من محاله، فلا يجوز له أن يحكم في غيرها^(٣). فيكون الاختصاص المكاني بنصب القاضي في مكان معين من الإقليم بحيث يتولى الفصل في المنازعات التي ترفع إليه في حدود الدائرة التي يختص بالقضاء فيها، ولا يجوز له تجاوز هذه الدائرة المكانية المحددة له وإلا كان حكمه باطلا لخروجه عن الاختصاص المكاني المحدد له.

جاء في مجلة الأحكام العدلية "القضاء يتقيد بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات ... والقاضي المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له أن يحكم في محل آخر" (المادة ١٨٠١ من المجلة).

وقد ذهب أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله إلى جواز تخصيص القضاء بالمكان^(٤)، وأدلة مشروعية تخصيص القضاء بالمكان كثيرة، منها: ما روى البخاري في صحيحه عن أبي بردة قال: بعث النبي ﷺ أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال وبعث كل واحد منهما على مخالف، قال واليمن مخالفان، ثم قال "يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا" فانطلق كل واحد إلى عمله.

(١) البحر الرائق لابن نجيم ج٦/٢٥٨ - مغني المحتاج للشربيني ج٤/٣٧٩ .

(٢) د. محمد الزحيلي (التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي)، مرجع سابق، ص ١٣٨ .

(٣) أدب القاضي للماوردي، ج١/١٥٥-١٥٦ .

(٤) رد المحتار لابن عابدين، ج٥/٤١٩ - الفتاوى الهندية، ج٣/٣١٥ - الفروق للقرافي ج٤/٤٠ - أدب القضاء لابن

أبي الدم ص ٥٤-٥٥ - المغني لابن قدامة ج١٤/٨٩ .

المبحث الثاني

قواعد الاختصاص المحلي

إن التنظيم القضائي الرشيد يستلزم عدم جمع المحاكم في مكان واحد، وإنما يجب أن تبت في أرجاء الدولة كلها، فيجعل لكل محكمة نصيباً محدداً من ولاية القضاء، وفقاً لمكانها الإقليمي أو المحلي، وذلك بالنسبة للمحاكم ذات الطبقة الواحدة، بحيث تقسم ولاية القضاء محلياً على جملة المحاكم المتماثلة في طبقته أو نوعها، ويسمى الاختصاص القضائي المحلي لكل محكمة من المحاكم بدائرة اختصاص المحكمة.

وقد نص على ذلك في المادة ١/٤٩ مرافعات : "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وبالنظر إلى هذه المادة يتضح أن المقنن قد جعل القاعدة العامة في الاختصاص المحلي هي موطن المدعى عليه، ولا يجوز لأطراف الخصومة الخروج عن أحكام هذه القاعدة إلا بنص صريح.

وفيما يلي أوضح القاعدة العامة في الاختصاص المحلي والاستثناءات الواردة عليها، وذلك على النحو التالي :

أولاً : القاعدة العامة: اختصاص محكمة موطن المدعى عليه:

تختص محكمة موطن المدعى عليه بنظر الدعاوى التي ترفع عليه^(١)، متى كانت من الدعاوى الشخصية أو المنقولة ويستوى في هذا أن تكون الدعوى مدنية أو تجارية^(٢)، رفعت أمام القضاء العادي أو الاستثنائي^(٣)، أما الدعاوى العقارية فينقصد اختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها على النحو الذي يرد بيانه فيما بعد .

ويقصد بموطن المدعى عليه: المحل الذي يقيم فيه عادة، ويتخذ منه موطناً له على سبيل الاستقرار فيه فيكون موطنه في استيفاء ما له وإيفاء ما عليه، ولا يجهل ما يحدث فيه، ولو غاب عنه أحياناً كان في نيته الرجوع إليه . وهذا ما يعرف بالموطن الأصلي أو الحقيقي. وبناءً على هذا : لا ترفع الدعوى على المدعى عليه إلا في موطنه الأصلي فإن لم يكن له موطنٌ أصلي جاز رفع الدعوى عليه في محله المختار^(٤) .

(١) التعليق على قانون المرافعات أ / عز الدين الدناصوري ، أ / حامد عكاز ص ٢٧٨ .

(٢) قانون المرافعات أ / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى ، بند ٣٧٥ ص ٤٨٥.

(٣) قانون القضاء المدني د / فتحي والى بند ٢٨٣ ص ٥٠٠ .

(٤) المرافعات د / محمد حامد فهمي ، بند ٣٠٧ ص ٣٣٤.

والمحل المختار: هو المكان الذي يختاره الخصم المتقاضى محلاً لإقامته، لتسليم إعلان الأوراق القضائية إليه في هذا المحل دون غيره، وقد يكون المحل المختار محلاً يتفق الخصوم على تعيينه لتنفيذ عمل قانوني معين، غالباً ما يكون مكتباً للمحاماة. فإذا تعدد المحل المختار جاز رفع الدعوى في إحدى المحاكم التي يقع في دائرتها أى منها. فإذا لم يكن للمدعى عليه محلاً مختاراً، ولم يستدل على مكانه جاز للمدعى أن يرفع دعواه أمام المحكمة التي وجد بدائرتها وقت رفع الدعوى.

والعبرة في تحديد محل الإقامة بوقت رفع الدعوى لا بوقت قيام سببها؛ إذ لا أثر لتغير محل الإقامة على اختصاص المحكمة بعد رفع الدعوى. فإذا فرض وأن كان المدعى عليه ليس له موطن أصلي ولا محل مختار ولم يستدل على مكان وجوده، ففي هذه الحالة ترفع عليه الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته^(١)، فإذا لم يكن للمدعى موطناً ولا محلاً معيناً فينعتد الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية. ولما كانت القاهرة تشتمل على محكمتين إحداها محكمة جنوب، والأخرى محكمة شمال فإن للمدعى الخيار في رفع دعواه أمام أى من هاتين المحكمتين.

وإذا كانت الدعوى جزئية فالخيار للمدعى أيضاً فله الحرية في رفع دعواه أمام أى من المحاكم الجزئية شريطة أن تكون المحكمة المختارة داخل مدينة القاهرة^(٢)، بيد أنه إذا رفع إلى محكمة بعينها من محاكم مدينة القاهرة، لا يجوز له الرفع أمام محكمة أخرى بذات المدينة؛ لأن الرفع إلى إحدى المحاكم ينزع اختصاص من غيرها.

الموطن الحكمي:

يلاحظ أن موطن الشخص الأصلي قد لا يكون هو المكان الذي يقيم فيه عادة، كما هو شأن عديم الأهلية أو ناقصها، فموطنه الأصلي حكماً هو موطن وليه أو وصيه أو القيم عليه. كذلك يعد موطناً أصلياً الموطن الذي يقع فيه مركز الإدارة الرئيسى لشخص معنوى — شركة كان أو مؤسسة، ومن ثم ينعتد الاختصاص بنظر الدعاوى التي تقام عليه للمحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارته الرئيسى فإذا لم يكن له مركز إدارة فالدعوى تقام عليه في المحكمة التي يقع بدائرتها موطن النائب عنه^(٣).

(١) المرافعات د/أحمد أبو الوفا بند ٣٣٣ ص ٤٨٠.

(٢) أصول المرافعات/ أحمد مسلم بند: ٢٤٥ ص ٢٦٨.

(٣) المرافعات د / أحمد أبو الوفا. بند ٣٣٢ ص ٣٧٨.

تعدد المدعى عليهم في دعوى واحدة:

قرر المقتن أنه في حالة تعدد المدعى عليهم في دعوى واحدة ترفع الدعوى من المدعي علي المدعى عليهم جميعاً أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم^(١)، وهذا يعنى أن قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه لا تزال قائمة، فلا يعتبر هذا خروجاً عن قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه، فالمقتن وإن كان قد منح الخيار للمدعى في اختيار المحكمة التي يرفع أمامها دعواه، فقد قيده بوجوب رفعها أمام محكمة موطن أحد المدعى عليهم^(٢)؛ نظراً لاتحاد موضوع الدعوى^(٣).

ويشترط لاستفادة المدعى بالخيار الممنوح له قانوناً في حالة تعدد المدعى عليهم:

١- أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً:

ويكون التعدد حقيقياً إذا كانت طلبات المدعى في الدعوى موجهة إليهم جميعاً^(٤)، ومن ثم لا يكفى لقيام حالة التعدد بين المدعى عليهم مجرد اختصاصهم للمثول في الدعوى، أو مجرد اختصاصهم ليصدر الحكم في مواجبتهم.

وهذا يعنى أن حالة التعدد تكون قائمة إذا كان المدعى عليهم جميعاً خصوصاً أصليين في تلك الدعوى أو على الأقل ملتزمين فيها بالتزام لا يقبل التجزئة ويستوى في ذلك أن يكون المدعى عليهم متضامنين - كالدعوى التي ترفع على الشركاء في المسؤولية عن فعل واحد ضار - أم غير متضامنين، استوت مراكزهم القانونية أم تفاوتت.

أما إذا كان التعدد بين المدعى عليهم تعدداً صورياً^(٥) لا حقيقة له في واقع القانون، فلا يستفيد المدعى من هذا الخيار، كما لو اختصم في دعواه خصمين، واختار موطن أحدهما لرفع دعواه. ولما بدأت الخصومة في محكمة الخصم. المختار موطنه. تنازل عنه أو لم يتنازل ولم يأخذ منه شئ أو دفع المدعي عليهم أنه ليس معهم وأثبت ذلك، ففي هذه الحالة يقرر القانون للخصم الآخر الحق في الدفع بعدم الاختصاص، وطلب الإحالة إلى محكمة موطنه^(٦).

(١) المرافعات د / محمد حامد فهى بند ٣٠٨ ص ٣٣٤.

(٢) قواعد المرافعات أ/ محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى بند ٣٨٠ ص ٤٩٠.

(٣) أصول المرافعات د/ أحمد مسلم بند ٢٤٤ ، ص ٢٦٧.

(٤) المرافعات د / أحمد مسلم ، بند ٢٤٤ ص ٢٦٧ .

(٥) أصول المرافعات د / أحمد مسلم بند ٢٤٤ ص ٢٦٧ .

(٦) المرافعات د/ محمد حامد فهى بند ٢٣٩ ص ٣٣٤.

٢- أن يعلن المدعى عليهم جميعاً في مواطنهم بالمحكمة التي رفعت إليها الدعوى^(١)، حتى يتمكن الجميع من معرفة المحكمة التي رفعت إليها الدعوى، ومن ثم يواصلون السير فيها؛ فإذا لم يتم إعلان المدعى عليهم كان لهم حق التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي.

٣- أن تكون هناك مصلحة ظاهرة تتحقق من وراء الجمع وتبدو هذه المصلحة ظاهرة في حالة وحدة موضوع الدعوى كوحدة الدين ونحوه.

الأسباب القانونية التي تبرر اختصاص محكمة موطن المدعى عليه كقاعدة عامة:

يستند شراح القانون في تبرير قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه بنظر الدعوى دون غيرها من المحاكم إلى عدة أسباب أهمها:

١- أن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته مما يشغلها حتى يثبت العكس، فكان هو الأولي بالرعاية^(٢).

٢- أن المدعى هو الطالب للحق وعليه أن يسعى إلى طلبه، فيلاحق المدعى عليه في أقرب المحاكم إليه^(٣) سعياً منه وراء طلبه، وليس من المعقول حمل المدعى عليه إلى محكمة أخرى في دعوى شخصية أو منقولة لمجرد دعوى من المدعى غالباً ما يثبت عدم صحتها^(٤)، وفي معظم معظم الأحيان لا يراد منها إلا الكيد.

لذا: فإن المدعى يكلف بإثبات دعواه، فيلاحق المدعى عليه في موطنه، دون أن يكلفه مشقة الانتقال من موطنه إلى موطن آخر، مما يؤدي إلى تحمله نفقات عالية قد تفوق طاقته المالية. أن الديون مطلوبة وليست محمولة، فعلى المدعى مطالبة المدعى عليه في موطنه.

٣- المدعى هو الذي بدأ بالخصومة واختار الوقت المناسب لرفعها، وأعد من الأدلة ما يؤيد دعواه، فكان من العدل أن يطلب التقاضي في المحكمة التي بدائرتها موطن المدعى عليه، فيفاجئه بالدعوى في موطنه.

ثانياً : القواعد الخاصة في الاختصاص المحلي:

بعد أن نص المقتن على القاعدة العامة في الاختصاص المحلي في المادة ٤٩ من قانون المرافعات، أورد بعد ذلك عدة قواعد خاصة، يتحدد على أساسها الاختصاص المحلي، وذلك

(١) المرافعات د / عبد الحميد أبو هيف . بند ٦١١ ، ص ٤٤٦ .

(٢) المرافعات . د / محمد حامد فهدى . بند ٣٠٦ ص ٣٣٣ .

(٣) المرافعات د / محمد حامد فهدى بند ٣٠٦ ص ٣٣٣ .

(٤) أصول المرافعات د / أحمد مسلم ، بند ٢٤٣ ، ص ٢٦٦ .

لحماية مصلحة عامة، أو مصلحة خاصة يستلزمها حسن التقاضى، وتحقق بمقتضاها العدالة القضائية، فضلاً عن تفادى الدفع بعدم الاختصاص المحلى .
وبناءً على هذا فإن المقنن قد يعقد الاختصاص المحلى أحياناً لمحكمة غير محكمة موطن المدعى عليه، وأخرى يجعل الاختصاص مشتركاً بينها وبين محكمة أو محاكم أخرى، وذلك وفقاً لما يحقق مصالح الخصوم، ويقتضيه حسن سير الدعاوى داخل النظام القضائى .
ويمكن إجمال الحالات التى ينعقد فيها الاختصاص المحلى لمحكمة غير محكمة موطن المدعى عليه، أو يكون الاختصاص مشتركاً بينها وبين محكمة أو محاكم أخرى فى الحالات التالية:

١- المحكمة المختصة بالدعاوى العينية العقارية:

عقد المقنن الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى العينية العقارية للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار^(١). وقد نص على ذلك فى المادة ٥٠ / ١ من قانون المرافعات "فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً فى دوائر محاكم متعددة".

والدعاوى العينية العقارية : هى التى يكون محلها عقاراً، كدعاوى تثبيت الملكية ودعاوى الحيازة، ودعاوى الشفعة، فهذه الدعاوى وأمثالها ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التى يقع العقار المتنازع فيه بدائرتها^(٢)؛ وذلك لأنها هى المحكمة الأقرب للعقار، والأجدر على فصل النزاع المتعلق به، فهى التى تتمكن دون غيرها من معرفة حدوده ومعالمه، فضلاً عن إمكانها معاينته وقت الحاجة إليها^(٣)، فدعوى طلب الحراسة مثلاً على عقار معين الأولى أن تنظر فيه المحكمة التى بدائرتها العقار المطلوب حراسته، وهكذا جميع الدعاوى العينية العقارية.
وإذا تعددت أجزاء العقار بين دوائر محاكم مختلفة كان الخيار للمدعى فى رفع دعواه أمام أى من هذه المحاكم التى يقع فى دائرتها أحد أجزاء العقار، صغر هذا الجزء أم كبر، وذلك تحقيقاً للعدالة خلافاً لما كان سائداً من قبل.

حيث كان الاختصاص المحلى فى دعوى العقار الذى تعددت أجزاؤه فى دوائر محاكم مختلفة ينعقد قانوناً للمحكمة التى يقع فى دائرتها أكبر الأجزاء، وهذا يستلزم إطالة النظر فى الدعوى ؛ نظراً لما يترتب على ذلك من ندب خبير أو أكثر لمعرفة الجزء الأكبر أو الأعلى قيمة^(٤) .

(١) المرافعات د / عبد الحميد أبو هيف بند ٥٨٩ ص ٤٣٤ .

(٢) قانون المرافعات د / محمد عبد الخالق عمر . ص ١٧٦ .

(٣) مبادئ القضاء المدنى د / وجدى راغب ص ٣١٩ .

(٤) التعليق على قانون المرافعات أ / الدناصورى ، أ / عكاز ص ٢٨٢ .

لذا فقد حالف المقنن الصواب عندما عقد الاختصاص المحلى لأية محكمة يقع في دائرتها أحد أجزاء العقار المتنازع فيه .

ودعوى العقار على النحو المتقدم يشترط لنظرها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه أن تتعلق بذات العقار أو أى حق عيني يرد عليه، ومن ثم يستبعد من ذلك الدعاوى المتعلقة بحق شخصي على العقار، كدعوى المطالبة بأجرة العقار أو بطلان أو فسخ عقد الإيجار، أو بإلزام المؤجر بتسليم المستأجر العقار المؤجر لأن هذه الدعاوى من الدعاوى الشخصية العقارية وليست دعاوى عينية عقارية^(١).

٢- المحكمة المختصة بالدعاوى الشخصية العقارية:

الدعاوى الشخصية العقارية هي التي تتضمن التزاماً شخصياً وارداً على عقار، كما هو شأن الدعوى التي يطلب فيها مشتري عقار بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة ونفاذ عقد البيع، أو دعوى البائع بفسخ البيع ورد العقار إليه^(٢).

فهذه الدعاوى شخصية من حيث التزام شخص المدعى عليه، وعقارية من حيث كونها ترد على عقار^(٣). لذا فقد عقد المقنن الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه. أو المحكمة التي يقع بدائرتها العقار محل المنازعة، وقد نص على ذلك في المادة ٥٠ / ٢ مرافعات: "في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها العقار أو موطن المدعى عليه". وبذلك يكون للمدعى الخيار بين رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه، أو محكمة موقع العقار .

أما إذا تعلق النزاع بثمان هذا العقار الذي حررت به كميالة مثلاً، وحولها البائع إلى الغير وكان النزاع من هذا الوجه فلا تختص محكمة العقار في هذه الحالة، وإنما يجب تطبيق القواعد العامة في الاختصاص المحلى.

٣- المحكمة المختصة بدعاوى تسليم العقار :

ينعقد الاختصاص بنظر دعاوى تسليم العقار للمحكمة الجزئية التي يقع بدائرتها العقار، وقد نص على ذلك في المادة ٣/٥٠ من قانون المرافعات وجاء فيها: "واستثناءً من حكم المادة ١٠٨ من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات".

(١) قانون القضاء المدني المصري ، د/ عزمى عبد الفتاح . ص ٣٨٦.

(٢) قواعد المرافعات أ / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى . بند ٣٨٥ ص ٤٩٥.

(٣) قانون القضاء المدني د / فتحى والى . بند : ٢٢٠ ص ٥١٨ ، ولا يجوز مخالفة هذه القاعدة حماية للطرف

الضعيف . نقض مدنى طعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٦١ ق ، جلسة ٢٥/٣/٢٠٠٦ م .

وبناءً على هذا تختص المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها العقار بنظر الدعاوى المتعلقة بتسليمه اختصاصاً محلياً يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه القاعدة. وتعد هذه القاعدة قيدهم المقتن على حكم المادة ١٠٨ مرافعات، والذي يفيد سقوط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالتكلم في موضوع الدعوى لعدم تعلقه بالنظام العام.

٤- المحكمة المختصة بالدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة :

يقرر المقتن أن الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو المؤسسات العامة، ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية التي يكون بدائرتها مقر المحافظة م ٥١ مرافعات^(١). وذلك تيسيراً على إدارة قضايا الحكومة لمتابعة القضايا التي ترفع على الحكومة أو هيئاتها في محكمة واحدة^(٢)، ويشترط لذلك ما يلي :

- أن تكون الدعوى التي رفعت على الحكومة أو إحدى الهيئات العامة دعوى جزئية، ومن ثم لا تطبق هذه القاعدة إذا كانت الدعوى ابتدائية.
- أن تكون الحكومة أو الشخص العام مدعي عليه بصفة أصلية، فإذا كانت الحكومة خصماً تدخل في الدعوى بصفة تبعية، كما لو كانت الدعوى من دعاوى الضمان أو كانت دعوى فرعية، ففي هذه الحالة يجب اتباع القواعد العامة في الاختصاص المحلي.
- أن تكون الدعوى من الدعاوى الشخصية أو المنقولة، فإذا كانت من الدعاوى العينية العقارية، فيسري عليها قاعدة اختصاص محكمة موقع العقار.

٥- المحكمة المختصة بدعاوى الشركات والجمعيات أو المؤسسات الخاصة:

يعقد المقتن الاختصاص المحلي بنظر دعاوى الشركات، أو الجمعيات، أو المؤسسات الخاصة للمحكمة التي يقع بدائرتها مركز الإدارة الرئيسي للشركة أو الجمعية، أو المؤسسة^(٣) والسبب في ذلك:

أن محكمة مركز الإدارة الرئيس هي أقدر المحاكم على فحص أوراق الشركة ودفاترها، ومن ثم تكون هذه الأوراق والدفاتر أساساً لحسم النزاع الذي يطرح على هذه المحكمة^(٤) فقرب

(١) المادة ٥١ مرافعات .

(٢) القانون القضائي الخاص د/ إبراهيم نجيب سعد. بند ١٩٤ ص ٤٨٢ .

(٣) المادة ٥٢ / ١ من قانون المرافعات .

(٤) قواعد المرافعات . أ / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى . بند ٣٨٦ ص ٤٩٧ .

المحكمة من مركز الإدارة الرئيسى يعتبر قانونا في تحديد المحكمة المختصة محليا بنظر المنازعة المتعلقة بعمل من أعمال الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة .
وإذا كانت الشركة متعددة الفروع فيجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة متى كان النزاع المطروح يتعلق بهذا الفرع.

٦- المحكمة المختصة بدعاوى التركات:

ينص المقتن فى المادة ٥٣ مرافعات على أن "الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن، أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع بدائرتها آخر موطن للمتوفى"^(١).

ويتضح من هذا النص أن المقتن جعل الاختصاص المحلى بنظر دعاوى التركات التى ترفع قبل القسمة منعقدا للمحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن كان للمتوفى، فىكون هذا الموطن محلاً لافتتاح التركة، ويستوى فى ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة من الدائن على المورث. كما هو شأن المطالبة بدين أو نحوه أو من بعض الورثة على البعض الآخر. كما هو شأن المطالبة بالنصيب الموروث —، بيد أنه يشترط لإعمال هذه القاعدة أن تكون الدعوى من الدعاوى المتعلقة بأموال التركة، كما يشترط أيضا أن تكون الدعوى . أياً كان المدعى فيها . قد رفعت قبل القسمة لا بعدها، ويستوى فى ذلك أن تكون الدعوى شخصية أو عينية منقولة كانت أو عقارية.

٧- المحكمة المختصة بدعاوى الإفلاس:

إذا توقف تاجر عن دفع ديونه كلها أو بعضها وطلب الحكم بشهر إفلاسه فالمحكمة المختصة محليا بنظر دعوى شهر إفلاس التاجر هى المحكمة الاقتصادية المختصة محلياً التى يقع بدائرتها محل التاجر المفلس، وذلك طبقاً لما قرره المقتن فى القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ م^(٢).
وذلك باعتبارها أقدر المحاكم على الفصل فى الدعوى، وأكثر المحاكم إحاطة بظروف المدين المفلس^(٣).

(١) المرافعات . د / محمد حامد فهى . بند ٣١٢ ص ٣٣٧ ، أصول المرافعات . د / أحمد مسلم بند ٢٥٠ ص ٢٧٢ ، المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٤٠ ص ٣٨٥ ، فإذا لم يكن = للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة . م ١٥ من قانون الأحوال الشخصية رقم " ١ " لسنة ٢٠٠٠ م ، الجريدة الرسمية ، العدد ٤ مكرر الصادر فى ٢٩ يناير سنة ٢٠٠٠ م .

(٢) انظر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

(٣) المرافعات. د/عبد الحميد أبو هيف بند ٦٠٤ . ص ٤٤٣.

٨- المحكمة المختصة بالدعاوى التجارية:

تنص المادة ٥٥ من قانون المرافعات على أنه : " في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها " .

ويتضح من هذا النص أن المقنن قد جعل الخيار للمدعى . تيسيراً له . في رفع دعواه المتعلقة بعمل من الأعمال التجارية أمام إحدى المحاكم الثلاث التالية :

الأولى : محكمة موطن المدعى عليه ؛ وذلك باعتبارها القاعدة العامة في الاختصاص المحلي .
الثانية : المحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها، بمعنى : أن يكون الاتفاق والتنفيذ الكلي أو الجزئي قد تم في دائرة محكمة واحدة، فإن تم أحدهما في دائرة محكمة تختلف عن دائرة المحكمة التي تم فيها الآخر، فلا اختصاص لأى من المحكمتين^(١) .

الثالثة : المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق بحكم العقد أو بقوة القانون في دائرتها، مستوى في ذلك أن يكون الاتفاق قد نفذ أو لم ينفذ^(٢) .

وإذا اتفق على تنفيذ الاتفاق في أكثر من مكان، كما لو اتفق بشأن عقد بيع مثلاً على أن يتم التسليم في مكان ودفع الثمن في مكان آخر، فالاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها كل من المكانين ؛ لأن كلاً من المكانين محل للتنفيذ فيه^(٣) .

ويلاحظ أن تمام التنفيذ ليس شرطاً، وإنما يكفي أن يكون التنفيذ واجباً في دائرة المحكمة ولو لم يتم بالفعل، كما لا يشترط أن يكون المدعى عليه تاجراً بل يشترط أن يكون العمل محل الاتفاق عملاً تجارياً .

٩- المحكمة المختصة بدعاوى التوريدات، والمقاولات، وأجرة المساكن، وأجور

العمال، والصناع، والأجراء:

عقد المقنن اختصاص المحلي بنظر هذه الدعاوى لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها، بيد أنه يشترط في هذه الحالة الأخيرة أن تكون محكمة الاتفاق أو التنفيذ يقع بدائرتها موطن المدعى م٥٦ مرافعات.

والمقصود بهذه الدعاوى تلك التي تنشأ بين المستهلكين والموردين، كالدعوى التي يرفعها البقال أو الجزار للمطالبة بثمن ما ورده من بضاعة، وبهذا يكون الخيار للمدعى في رفع الدعوى

(١) قانون القضاء المدني . د / فتحي والى . بند ٢٢١ . ص ٥١٨ ، ص ٥١٩ .

(٢) المرافعات د / محمد حامد فهى . بند ٣١٥ . ص ٣٣٨ .

(٣) الوسيط . د / رمزي سيف . ص ٣٠٣ .

في أي من هاتين المحكمتين، فله أن يرفع دعواه في محكمة موطن المدعى عليه ؛ عملاً بالقاعدة العامة في الاختصاص المحلي، أو يرفعها في المحكمة التي تم الاتفاق في دائرتها أو نفذ في جزء منه وذلك تيسيراً على المدعى ؛ نظراً لضآلة المبلغ الذي ترفع به الدعوى^(١).

وهذا الاستثناء يرد عليه قيدان .

الأول : أن تكون التوريدات أو المقاولات فردية وليست عامة .

الثاني : إذا اختار المدعى رفع الدعوى أمام محكمة الاتفاق أو التنفيذ فلا بد أن يكون هو من دائرة هذه المحكمة^(٢).

١٠- المحكمة المختصة بدعاوى النفقات:

تنص المادة ٥٧ مرافعات على أنه : " في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى"، وبناء على هذا النص يكون الخيار للمدعى إذا تعلقت دعواه بطلب النفقة وما يتصل بها في رفع الدعوى أمام محكمة المدعى عليه طبقاً للقاعدة العامة، أو أمام محكمته هو التي يقع بدائرتها موطنه، وذلك رغبة من المقنن في التيسير على طالب النفقة، ودعاوى النفقة تشمل كافة الدعاوى المتعلقة بالنفقات، والتي ترفع من مستحق النفقة على من تجب عليه، سواء أكان طالب النفقة يطلب تقريرها أم يطلب زيادتها، بناء على أن طلب زيادة النفقة يعد صورة من صور المطالبة بالنفقات.

بيد أن هذه القاعدة لا تطبق إذا كانت دعوى النفقة تتضمن طلب إسقاطها أو نقصها؛ حيث يجب في هذه الحالة تطبيق القاعدة العامة في الاختصاص المحلي، ومن ثم لا يسرى عليها الحكم المتقدم.

ويلاحظ أن دعاوى النفقات تشمل النفقات المقررة قانوناً، كنفقة الآباء على الأبناء والزوج على زوجها، ونفقة الأقارب، كذلك تشمل النفقات المؤقتة، كالنفقة التي يطلبها الدائن من المدين الذي حجز على كل أمواله إلى أن يفصل في أصل الحق.

١١- المحكمة المختصة بدعاوى المطالبة بقيمة التأمين:

إذا كانت الدعوى تتضمن المطالبة بقيمة التأمين فقد عقد المقنن الاختصاص المحلي بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد - غالباً ما يكون هو المدعى - أو مكان المال المؤمن عليه م ٥٨ مرافعات.

(١) الوسيط . د / أحمد السيد صاوى . بند ٢٣٦ . ص ٣١٢ .

(٢) أصول المرافعات. د/ أحمد مسلم. بند ٢٥٣ . ص ٢٧٧.

وبناء على هذا يكون الخيار للمدعى في رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها إذا كان هو المستفيد، أو رفعها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها المال المؤمن عليه^(١)، عقارا كان أو منقولاً^(٢).

ويقصر تطبيق هذه القاعدة على الدعاوى التى تتضمن المطالبة بقيمة التأمين سواء رفعت من المستفيد أو من ورثته، أو من المؤمن نفسه، أما الدعاوى الأخرى التى تتعلق بطلب إبطال العقد أو فسخه، أو الدعاوى التى ترفع من الشركة للمطالبة بقيمة الأقساط، فيتبع بشأنها القواعد العامة فى الاختصاص المحلى^(٣).

١٢- المحكمة المختصة بالدعاوى المستعجلة.

إذا كانت الدعوى محل المنازعة تتضمن طلباً بإجراء وقتى فالمحكمة المختصة محلياً بنظرها هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ؛ عملاً بالقاعدة العامة، أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها، باعتبارها الأقرب والأجدر على معرفة الدعوى وظروفها م ١/٥٩ من قانون المرافعات .

أما إذا كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ فيقرر المقنن عقد الاختصاص المحلى بنظرها إلى المحكمة التى يجرى التنفيذ فى دائرتها م ٢/٥٩ من قانون المرافعات.

١٣- المحكمة المختصة بالطلبات العارضة أو المرتبطة:

ينعقد الاختصاص بنظر الطلبات العارضة أو المرتبطة وكذلك الدفوع للمحكمة التى رفعت إليها الدعوى بصفة أصلية، بغض النظر عن مكانها الإقليمي، وذلك تحقيقاً للعدالة القضائية وحسن سير الدعوى م ٦٠ مرافعات.

وبناء على هذا : فإن الشخص الذى يتدخل فى الدعوى الأصلية : ليتفادى الحكم الذى يصدر فيها، يمثل أمام تلك المحكمة التى رفعت إليها الدعوى الأصلية مرافعة أو مدافعة، ولو لم تكن فى الأصل محكمته التى يقع فى دائرتها موطنه^(٤).

(١) المرافعات. د/أحمد أبو الوفا. بند ٣٤٤ . ص ٣٨٩ .

(٢) مبادئ القضاء المدنى . د / وجدى راغب ص ٣٢٥ .

(٣) قانون القضاء المدنى . د / محمود هاشم . بند ٢٦٢ . ص ٤٠٧ ، ص ٤٠٨ .

(٤) المرافعات . د/عبد الحميد أبو هيف . بند ٦٠٣ . ص ٤٤٣ ، قانون القضاء المدنى . د / فتحي والى بند ٢٢٧ . ص

غير أن المقنن خرج - استثناء - عن تلك القاعدة وأجاز للمدعى عليه في دعوى الضمان الفرعية أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة، إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير مختصة^(١).

ودعوى الضمان هي : الدعوى الناشئة عن دعوى أصلية أخرى، ويقرر شراح القانون الإجرائي أن دعاوى الضمان على قسمين:

الأول : دعوى الضمان الأصلية هي التي ترفع ابتداء ويتبع في رفعها القواعد العامة المعتادة لرفع الدعوى، وفقا لقواعد الاختصاص المقررة قانونا.

الثاني : دعوى الضمان الفرعية وهي المقصودة في المادة ٦٠ / ٢ من قانون المرافعات، حيث إنها ناشئة عن دعوى أصلية أو متفرعة عنها، ومن ثم فإن المحكمة المختصة محليا بنظرها هي المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى الأصلية ولو لم تكن هذه المحكمة هي محكمة موطن المدعى عليه بحسب القواعد العامة^(٢).

ويستوى في دعوى الضمان الفرعية أن تكون الدعوى الأصلية شخصية أو عينية عقارية أو منقولة، كما يستوى أيضا أن يكون طالب الضمان - صاحب الطلب العارض - هو المدعى في الدعوى الأصلية أو المدعى عليه.

وعلى هذا فطالب الضمان يمكنه إحضار الضامن أمام محكمة الدعوى الأصلية، بما في ذلك الحكومة متى كانت ضامنة في الدعوى، ولو لم تكن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية من محاكمها المخصصة للنظر في قضاياها.

وحرصا من المقنن على حماية الضامن من تلاعب طالب الضمان بقاعدة الاختصاص المقررة في المادة ٦٠ / ١ من قانون المرافعات .

لذا فقد أوجب المقنن على المحكمة إجابة الضامن إلى طلبه بعد توافر شرطه ومن ثم يجب عليها أن تقضى في الدعوى بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة موطن الضامن^(٣).

مثال دعوى الضمان الفرعية :

أن يرفع المشتري دعوى بفسخ البيع على السمسار - الذي توسط لعقد الصفقة - أمام محكمة السمسار فيدخل السمسار البائع ضامنا في الدعوى.

(١) قواعد المرافعات . أ / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى . بند ٣٨٩ . ص ٤٩٠ ، مبادئ القضاء المدني . د / وجدى راغب . ص ٣٣٦ .

(٢) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٤٦ ، ص ٣٩١ ، دعوى الضمان الفرعية د / أحمد ماهر زغلول . بند ١٤٣ . ص ١٤٧ ط / المطبعة التجارية الحديثة . القاهرة . ط / بدون تاريخ .

(٣) أصول وقواعد المرافعات . د / أحمد ماهر زغلول . بند ٣٧٦ . ص ٧٩٢ .

فللبائع هنا - الذي أدخل بصفته ضامناً- أن ينازع في اختصاص محكمة السمسار، ويطلب التقاضى إلى محكمته هو، حيث إن علاقته بالمشتري هى الأصل وليست الفرع، وذلك متى أثبت - البائع - تحايل طالب الضمان على قواعد الاختصاص وجلبه البائع للتقاضى أمام محكمة غير مختصة^(١).

١٤- المحكمة المختصة طبقا لاتفاق الخصوم:

حرص المقتن على رعاية مصلحة الخصوم عند التقاضى، فأجاز بنص صريح الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى، وقد نص على ذلك فى المادة ٦٢ / ١ من قانون المرافعات وجاء فيها: " إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة، أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعي عليه".

١٥- المحكمة المختصة بدعاوى تفسير الأحكام القضائية :

تختص المحكمة التى أصدرت الحكم بتفسيره، حيث إنها الأولى دون غيرها فى بيان المقصود من حكمها، بمالها من ولاية تكميلية على القضية، ومن ثم فهى تختص دون غيرها بنظر الدعوى المتعلقة بتفسير حكمها، بغض النظر عن موقعها المحلى، أو مواطن أطراف الدعوى^(٢). ويسرى هذا الحكم أيضا على طلب المعارضة والتماس إعادة النظر؛ حيث يتعين رفع الطعن إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم.

(١) مبادئ القضاء المدنى د / وجدى راغب . ص ٣٣٦ .

(٢) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٦٠ . ص ٤٠٩ بند ٣٩٥ . ص ٤١٨ .

الفصل الخامس

مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام والآثار المترتبة عليه

المبحث الأول

مدى تعلق قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام والآثار

المرتبة علي ذلك

قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من القواعد التي تتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن الدفع الذي يثار بشأنه دفع يتصل بالنظام العام ويترتب علي ذلك جملة من الآثار أهمها :

١- يجب علي المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص ولو من تلقاء نفسها :

لقد أوجب المقتن علي المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من تلقاء نفسها، متى استندت في ذلك على أساس من القانون، بأن رأت أن الدعوى التي عرضت عليها لا تدخل في اختصاصها الولائي أو النوعي أو القيمي، ومن ثم فتقضى المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى أو نوعياً أو قيمياً، وتأمراً بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها طبقاً لقواعد الاختصاص، وذلك من تلقاء نفسها دون أن يتوقف قضاؤها على طلب الخصوم^(١)، وهذا لا يعد حكماً بما لم يطلبه الخصوم، وإنما هو إعمال لمبدأ احترام قواعد القانون الأمرة، والتي راعى المقتن عند تقريرها فكرة توزيع الولاية القضائية وسلطة القضاء بين جهاته ومحاكمه المختلفة^(٢).

٢- منح الخصوم حقاً إجرائياً في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص في أية مرحلة تكون عليها الدعوى :

ينشأ عن تجاوز حدود الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي الحق الإجرائي للخصوم في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي في أية مرحلة من مراحل الدعوى، ومن ثم فيجوز التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف ولو لأول مرة، كما يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فضلاً عن عدم سقوط الحق في إبداء الدفع بالتكلم في موضوع الدعوى أو إبداء دفاع فيها^(٣).

(١) أصول وقواعد المرافعات . د / أحمد ماهر زغلول بند ٣٨٦ . ص ٨١٩ .

(٢) قواعد المرافعات أ / محمد العشماوي ، د / عبد الوهاب العشماوي ٢٣٥/٢ .

(٣) أصول المرافعات . د / أحمد مسلم . بند ٢٦ . ص ٢٩٣ ، ٢٩٤ .

وترتيباً على هذا لا يسقط الحق في التمسك بهذا الدفع، إذا لم تقض به المحكمة من تلقاء نفسها.

وكما يتقرر الحق في التمسك بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي للخصوم أطراف الدعوى يتقرر أيضاً لكل ذي مصلحة في إبدائه، بما في ذلك النيابة العامة إذا كانت طرفاً منضماً في الدعوى. حيث ينصرف إليها أثر الحكم. محل الدفع، والحكم الذي يصدر في الدفع له حجته في مواجهة جميع الخصوم سواء أكانوا خصوماً أصليين أم متدخلين^(١).

٣- عدم الاعتداد باتفاق الخصوم على مخالفة قواعد الاختصاص.

لا أثر لاتفاق الخصوم على ما يخالف القواعد القانونية المنظمة للاختصاص الولائي والنوعي والقيمي، فمثل هذا الاتفاق يقع باطلاً لمخالفته صريح نص القانون، سواء تم هذا الاتفاق قبل رفع الدعوى أو أثناء النظر فيها من محكمة غير مختصة ولائياً أو نوعياً أو قيمياً بنظرها^(٢).

ومن ثم فلا تنقيد بذلك المحكمة بل يتعين عليها القضاء بعدم الاختصاص والإحالة طبقاً للمادة "١١٠ مرافعات"، كما لا يتقيد به أي من طرفي الدعوى؛ بل يجوز له التمسك به أمام المحكمة ولو سبق تنازله عنه أو تصالحه عليه.

٤- نسبية الحجية القانونية للحكم الصادر من جهة غير مختصة :

المقرر قانوناً لدى الفقه الإجرائي أن الحكم الصادر من جهة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لا يحوز الحجية القانونية أمام الجهة صاحبة الولاية وذلك : للاستقلال القائم بين جهات القضاء، ومن ثم فإن قضاء الجهة غير المختصة لا يقيد الجهة صاحبة الولاية من نظر الدعوى طبقاً لقواعد الاختصاص^(٣).

بيد أن انعدام حجية الحكم الصادر من جهة غير مختصة ليس مطلقاً، وإنما هو انعدام نسبي، حيث يحوز هذا الحكم الحجية القانونية أمام المحكمة التي أصدرته، وكذا أمام المحاكم الأخرى التابعة لذات الجهة، ومن ثم تنقيد محاكم هذه الجهة بحجية هذا الحكم، فلا يجوز لها

(١) نقض مدني. طعون أرقام ٣١٥، ٦٣٢، ٧٠٢ لسنة ٥٩ق. جلسة ١٩٩٢/٧/٣٠م، وجاء فيها: "... التدخل في أثره،

صيرورة المتدخل سواء للاختصاص أو الانضمام طرفاً في الدعوى، الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه..." مجموعة المكتب الفني. السنة الثالثة والأربعون ١٠١٧ / ٢، وسوف يأتي الحديث عن ذلك مفصلاً فيما بعد.

(٢) أصول المرافعات. د / أحمد مسلم. بند ٢٦٦. ص ٢٩٣، ٢٩٤.

(٣) مبادئ المرافعات. د/عبد الباسط جميعي ص ١٠٤.

معاودة الفصل في الدعوى مرة أخرى، وهذا تستنفذ ولايتها على الدعوى إذا رفعت إليها مجددة بنفس الموضوع بين ذات الخصوم^(١).

وبناء على هذا: لا حجية لحكم يصدر من جهة قضائية غير مختصة ولائياً. ولو أنها جهة القضاء العادى - أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية؛ بل إن حجية هذا الحكم قاصرة على المحاكم التابعة لجهة القضاء التى أصدرته، ولو كانت المحكمة التى صدر عنها الحكم محكمة عادية؛ وذلك لإستقلال جهات القضاء فيما بينها، وهذا هو السائد لدى الفقه الإجرائى.

المبحث الثاني

مدى تعلق قواعد الاختصاص المحلى بالنظام العام وآثاره

يفرق المقتن الإجرائى بين نوعين من قواعد الاختصاص المحلى، وذلك على النحو التالى:

الأول: قواعد الاختصاص المحلى التى لا تتعلق بالنظام العام:

وهذه القواعد تعد الأصل فى الاختصاص المحلى؛ حيث تنقرر لمصالح الخصوم للتيسير عليهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم فى ظروف طبيعية لا تحملهم على المشقة أو العناء الذى قد يفوق طاقتهم وقدراتهم^(٢) لو أنه فرض عليهم الانتقال بقضاياهم إلى أماكن بعيدة عن مواطن إقامتهم.

لذا فقد رخص المقتن لمن تقرررت لمصلحته القاعدة المحلية أن يتنازل عنها بالاتفاق مع خصمه على مخالفة تلك القاعدة، متى قدر أن ذلك يحقق مصلحته التى قصدها المقتن^(٣). وبناءً على هذا فإن قواعد الاختصاص المحلى المقررة لحماية مصالح خاصة يجوز لأصحاب هذه المصالح الاتفاق على مخالفتها، فهم أولى الناس بمعرفة ما يحقق مصالحهم ويحمى حقوقهم.

وهذا يمكن القول بأن قواعد الاختصاص المحلى المقررة لمصلحة الخصوم ليست من النظام العام، كما هو شأن قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه م ٤٩ مرافعات، أو القواعد التى تجعل الخيار للمدعى بين محكمة موطن المدعى عليه ومحكمة أخرى قد تكون محكمة موطنه أو غيرها. م ٥٧، ٥٨ مرافعات.

(١) قانون المرافعات. د/ نبيل إسماعيل عمر. بند ٦٢. ص ٢٠٠.

(٢) نظرية الاختصاص. د/ عبد الباسط جميعى. ص ٩١، ص ١٠٤، قانون القضاء المدنى. د/ محمود هاشم. بند ٢٦٥. ص ٤١٣.

(٣) نظرية الاختصاص. د/ جميعى. ص ٩١، الوسيط د/ أحمد السيد صاوى. بند ٢٢٦. ص ٣٠٦.

وتأسيساً على هذا يرتب القانون الإجرائي على عدم تعلق قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام الآثار القانونية التالية :

أولاً: يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي مقدماً على رفع الدعوى أو لاحقاً عليها^(١)، ويكون هذا الاتفاق ملزماً لأطرافه وللمحكمة^(٢)، ولا يجوز للمدعى عليه التمسك بعدم اختصاص المحكمة التي رفعت إليها الدعوى بناء على هذا الاتفاق^(٣). ويستوى في هذا الاتفاق أن يكون صريحاً بالنص عليه في العقد - أو الواقعة - محل الدعوى، أو ضمناً مستفاداً من سكوت المدعى عليه بعد إعلانه بالدعوى التي رفعت أمام محكمة أخرى، دون أن يدفع قبل التكلم في موضوعها بعدم اختصاصها^(٤). كذلك لا يجوز للمدعى الذي رفع دعواه أمام محكمة أخرى على خلاف ما تقرره قواعد الاختصاص المحلي أن يتمسك بعدم اختصاص تلك المحكمة، حيث إن رفعه الدعوى أمامها ابتداءً دليل على رضاه باختصاصها انتهاءً.

ثانياً: يسقط حق المدعى عليه في التمسك بعدم الاختصاص المحلي إذا لم يتقدم به في مبتدأ الخصومة، أي قبل التكلم في موضوع الدعوى، كما يسقط حقه إذا أبدى دفاعاً فيها أو دفاعاً بعدم القبول^(٥). م ١٠٨ مرافعات، ولا يعد حضور المحامي وكيلاً عن المدعى عليه ومثوله في الدعوى دون الدخول في موضوعها تكلماً في الدعوى.

ثالثاً: إذا سكت المدعى عليه عن التمسك بهذا الدفع فليس للنأيبة العامة إذا تدخلت في الدعوى باعتبارها طرفاً منضماً إلى جانب المدعى عليه حق التمسك به^(٦)؛ لأن الحق فيه مقرر لمصلحة الخصم، ولا معنى لحرمان الخصم رغماً عنه من قضاء محكمة قبل هو باختصاصها في حدود الحق المقرر له قانوناً.

بيد أنه يجوز للنأيبة العامة إذا تدخلت منضمة في دعوى - في تلك الحالات التي يوجب عليها القانون ذلك - معينة لحماية شخص معين، كما هو شأن عديم الأهلية، فليس هناك ما

(١) المرافعات . د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٥٩ . ص ٤٠٧.

(٢) أصول المرافعات د/أحمد مسلم . بند ٢٦٧ . ص ٢٩٥ ، قانون القضاء المدني د/ فتحي والي . بند ٢٣٤ ص ٥٥٩.

(٣) القانون القضائي الخاص . د/ إبراهيم نجيب سعد . بند ٢١٠ . ص ٥١٧.

(٤) مبادئ المرافعات د/عبد الباسط جميعي . ص ١٠٠ ، نقض مدني طعن رقم ٣٩٠٨ . لسنة ٧٠ ق جلسة ٢٠٠١/٥/٩ .

(٥) مبادئ المرافعات د/عبد الباسط جميعي . ص ١٠٠ ، نظرية الدفوع . د / أحمد أبو الوفا . بند ٨٥ . ص ١٨٠.

(٦) نظرية الاختصاص . د/عبد الباسط جميعي . ص ٩٦ ، قانون القضاء المدني . د/ محمود هاشم . بند ٢٦٦.

يمنع قانوناً من تمسكها بهذا الدفع، متى رأت في ذلك نفعاً يعود على الشخص الذي تدخلت هي لحمايته، ولو أنها ليست خصماً حقيقياً في الدعوى.

رابعاً: لا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها ما لم يتمسك بذلك أحد الخصوم، وإلا عد ذلك حكماً منها بما لم يطلبه الخصوم، حيث إنها ليست مجبرة على أن تغرق نفسها في شيء قد وضعه المقتن على عاتق غيرها^(١).

خامساً: في حالة التنازع بين الخصوم حول حصول الاتفاق على اختصاص محكمة معينة أو عدم حصوله، فإن عبء الإثبات يقع في هذه الحالة على عاتق المدعى عليه^(٢).

سادساً: إذا تمسك المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى محل المنازعة، وتحققت المحكمة من صحة ما استند إليه، وجب عليها أن تقضى بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة: عملاً بالمادة ١١٠ مرافعات، ومن ثم تنتهي الدعوى أمامها بغير حكم في موضوعها^(٣).

سابعاً: إذا كان الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه، وأقام المدعى دعواه أمام محكمة موطن المدعى عليه، جاز لهذا الأخير التمسك بالدفع بعدم اختصاص محكمته بشرط عدم تكلمه في موضوع الدعوى، ولا شأن لهذا بما تقرره المادة ٦٢ / ٢ مرافعات^(٤).

الثاني: قواعد الاختصاص المحلي التي تتعلق بالنظام العام.

من قواعد الاختصاص المحلي القواعد الخاصة التي قررها المقتن على خلاف حكم المادة ٤٩ مرافعات، وهذه القواعد حظر المقتن على الخصوم الاتفاق على مخالفة أحكامها، وذلك رعاية لمصلحة عامة رأى المقتن حمايتها واعتبر حماية المصلحة العامة أولى وأجدر بالرعاية من المصلحة الخاصة المتعلقة بالخصوم^(٥).

(١) المرافعات د / أبو هيف ٥٤٥، بند ٥٤٦، المرافعات أ / محمد العشماوى، د / عبد الوهاب العشماوى ص ٤٨٤.

(٢) قانون القضاء المدني. د / فتحى والى. بند ٢٣٤. ص ٥٦١، نظرية الدفع. د / أحمد أبو الوفا. بند ٨٥.

(٣) أصول المرافعات د / أحمد مسلم. بند ٢٦٣. ص ٢٩١، تقنين المرافعات أ / محمد كمال عبد العزيز. ص ١٨٠.

(٤) نقض مدنى. طعن رقم ٥٣٧. لسنة ٤٥ ق. جلسة ١٤ / ٥ / ١٩٨٠ م، وقد نصت المادة ٢/٦٢ من قانون

المرافعات الجالى وجاء فيها رد على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تحويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة " ٤٩ " لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص "

(٥) نظرية الاختصاص. د / عبد الباسط جمعى. ص ١٠٥ - ١٠٧، قواعد المرافعات أ / محمد العشماوى، د /

عبد الوهاب العشماوى. بند ٤٠٥. ص ٥١٩.

تأسيساً على أن رعاية المصالح العامة تتصل مباشرة بالعدالة في أدائها لدورها المقصود، وتعمل على احترام قواعد القانون من أن تمس، كما أن اعتبار المقنن للمصلحة العامة لا يعنى انعدام رعايته للمصالح الخاصة، حيث إن مردود الحماية عائد لا محالة على المصالح الخاصة بالخصوم^(١) فقيام العدالة بواجبها في احترام القانون لا شك أنه من صميم مصالح الخصوم. بيد أن المقنن قد رأى نفسه الأجدر أنه في تحقيق ذلك من الخصوم أنفسهم^(٢) لذا فقد رسم لهم طريقاً معيناً عند تقاضيتهم، ونص على ضرورة التزامهم بهذا الطريق دون غيره، لذا فقد قرر بطلان الاتفاق الذي يجرى بين الخصوم على نحو يخالف ما قرره من أحكام أمرة.

ومن أمثلة القواعد الخاصة التي نص المقنن على احترامها والتزام أحكامها قاعدة عقد الاختصاص المحلى لمحكمة موقع العقار دون النظر إلى مواطن الخصوم. كذلك قاعدة عقد الاختصاص المحلى بنظر دعاوى الإفلاس للمحكمة الاقتصادية، التي يقع في دائرتها محل المدين المفلس المطلوب شهر إفلاسه^(٣). وكذلك قاعدة عقد الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة للمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر المحافظة، وعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها العقار المطلوب تسليمه إلى غير ذلك من القواعد التي نص المقنن على اعتبارها في تحديد الاختصاص المحلى، وجعل فيها الاختصاص بنظر الدعوى محل المنازعة لمحكمة بعينها دون غيرها. كما هو شأن دعاوى الاستئناف التي أوجب المقنن رفعها إلى محكمة أعلى درجة، تقع المحكمة المستأنف عليها في دائرة اختصاصها الإقليمي^(٤). وكذا دعاوى التماس إعادة النظر التي أوجب المقنن رفعها إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم؛ متى توافرت لها الشروط المعتبرة قانوناً^(٥).

فهذه القواعد تعد من قبيل النظام العام في الاختصاص المحلى، ومن ثم لا يجوز للخصوم أو غيرهم أو المحكمة مخالفتها، حيث إنها مقررة بمقتضى قواعد القانون الأمرة، ويقع باطلاً كل أمر يخالف أحكامها^(٦).

(١) مبادئ المرافعات. د/عبد الباسط جميعي ص ٩٨ ، ص ٩٩ .

(٢) مبادئ المرافعات. د/ عبد الباسط جميعي . ص ٩٩ .

(٣) نظرية الدفع. د/أحمد أبو الوفا . بند ٨٥ . ص ١٨٣ ، ص ١٨٥ .

(٤) مبادئ المرافعات. د/عبد الباسط جميعي. ص ١٠٨ ، نظرية الدفع . د/أحمد أبو الوفا . بند ٨٥ ص ١٨٣ .

(٥) المرافعات د / أحمد أبو الوفا . بند ٣٦٠ . ص ٤٠٩ .

(٦) قواعد المرافعات أ / محمد العشماوى ، د / عبد الوهاب العشماوى . بند ٤٠٥ . ص ٥١٩ ، أصول المرافعات .

د / أحمد مسلم بند ٢٦٨ . ص ٢٩٦ .

وقد نص المقتن على ذلك في المادة ٢/٦٢ من قانون المرافعات وجاء فيها: "على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تحويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة " ٤٩ " لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص".

والذي يتضح لي من هذه الفقرة أن المحظور قانوناً على الخصوم هو إنما هو الاتفاق مقدماً على اختصاص محكمة معينة في الحالات التي ينص فيها على عقد الاختصاص لمحكمة ما على خلاف ما تقرره المادة ٤٩ مرافعات^(١).

أما الاتفاق اللاحق على رفع الدعوى فلا يحظره القانون على الخصوم، ومن ثم يعتد قانوناً بإرادتهم فيما يتفقون عليه بعد رفع الدعوى على النحو المقرر في المادة ٦٢ / ٢ مرافعات^(٢).
وتأسيساً على هذا : يترتب على تعلق قواعد الاختصاص المحلي - القواعد الخاصة - بالنظام العام ذات الآثار الإجرائية المترتبة علي تعلق قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي، ومن ثم فلا حاجة للتكرار.

(١) التعليق على قانون المرافعات . أ/الدناصوري ، أ/ عكاز. ص ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، تقنين المرافعات أ / محمد كمال عبد العزيز ص ١٨٠ .

(٢) نظرية الدفع . د / أحمد أبو الوفا . بند ٨٥ . ص ١٨٠ - ص ١٨٣ ، قانون القضاء المدني. د/فتحى والى . بند ٢٣٤ . ص ٥٦٣ ، وقد نصت المادة ٢/٦٢ من قانون المرافعات الحالى وجاء فيها : " على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تحويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة " ٤٩ " لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص " .

الفصل السادس

الإحالة

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : الإحالة وأحكامها

المبحث الثاني : الآثار الإجرائية المترتبة على الإحالة

المبحث الأول

الإحالة وأحكامها

أولاً: مفهوم الإحالة وأنواعها:

هي : نقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى وفقاً للقواعد المقررة قانوناً^(١)

ثانياً : أنواع الإحالة :

قد تكون الإحالة لعدم الاختصاص أو لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى أو أكثر، أو للارتباط بين موضوع الدعوى المنظورة ودعوى أخرى منظورة أمام محكمة أخرى- ولو لم تكن هناك مخالفة لقواعد الاختصاص المقررة - وقد تكون الإحالة لاتفاق الخصوم على نقل دعواهم من محكمة إلى أخرى على النحو الذي يرسمه القانون وتسمى حينئذ بالإحالة الاتفاقية. وبناءً على هذا فإن الإحالة تنوع إلى أربعة أنواع رئيسة هي :

١- الإحالة لعدم الاختصاص :

والإحالة هنا تعد الوسيلة الفنية الإجرائية التي يتم بمقتضاها تصحيح سير الدعوى في مرحلة^(٢) اتصالها بالقضاء ، وذلك عن طريق نقلها من محكمة غير مختصة إلى جهة مختصة . كما هو الشأن في إحالة الدعوى الإدارية من محكمة عادية إلى جهة القضاء الإداري ، أو نقلها من محكمة عادية غير مختصة إلى محكمة عادية أخرى مختصة بنظرها بعد ثبوت عدم الاختصاص بنظرها طبقاً للقانون .

(١) المرافعات د / عبد الحميد أبو هيف. ص ٨٩٩ ، قانون القضاء المدني د / فتحي والي . بند ٢٣٥ . ص ٥٦٤ ، أصول قانون المرافعات د/ أحمد هندي . بند ١٧٩ .

(٢) قانون القضاء المدني د/ فتحي والي. بند ٢٣٦. ص ٥٦٨، الجزء الإجرائي. د / أيمن رمضان . ص ٧٢٣

هذا وقد قرر المقنن وجوبية الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص، فنص في المادة " ١١٠ " مرافعات على أنه : "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية..." وهذا يتضح أن المقنن قد سوى في الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص بين عدم الاختصاص المتعلق بالولاية وعدم الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى أو قيمتها أو محلها، فالحكم بعدم الاختصاص أيّاً كان مبناه يستوجب الإحالة إلى المحكمة المختصة^(١). كما أنه سوى في وجوبية الإحالة بين قضاء المحكمة بعدم الاختصاص بناءً على دفع تمسك به أحد الخصوم وقضائها بذلك من تلقاء نفسها إذا كان الاختصاص من النظام العام، فالإحالة واجبة على كل حال بعد الحكم بعدم الاختصاص^(٢).

٢- الإحالة لقيام ذات النزاع :

وهذا الدفع في هذه الحالة يفترض أن هناك دعوى أقيمت لدى محكمة مختصة، ثم أعيد رفعها أمام محكمة أخرى مختصة أيضاً أو تعاصر رفعهما، كما لو أقيمت دعوى على جملة أشخاص تابعين لمحاكم مختلفة، أو كان هناك اتفاق بين المدعى والمدعى عليه على محل معين لتنفيذ العقد منشأ النزاع يختلف عن محل المحكمة التابع لها المدعى عليه. ففي هذه الحالة يقرر المقنن الإجرائي حق الدفع للمدعى عليه؛ تجنباً لزيادة المصروفات، وتوحيداً في نظر الخصومات، وحفظاً لأحكام القضاة من التناقض^(٣)، وهذا الدفع يستلزم بطبيعته أن تكون الدعويان متحدتان سبباً وموضوعاً وخصوصاً، فضلاً عن اختصاص كل من المحكمتين، وتبعيتهما لجهة قضائية واحدة^(٤).

٣- الإحالة للارتباط :

وهنا يفترض أن هناك دعوى أقيمت في محكمة بعينها وارتبطت بدعوى أخرى رفعت لدى محكمة أخرى، وكان الارتباط بينهما وثيقاً، الأمر الذي حدا بالمقنن الإجرائي أن يعمل على الجمع بينهما بدلاً من تفريقهما بين المحاكم، فنص على عقد الاختصاص بنظرهما معاً لدى محكمة

(١) الوسيط د / أحمد السيد صاوي بند ١٥٢ . ص ٢١٥ .

(٢) قوانين المرافعات. د/ أمينة النمر. بند ٢٨٧ . ص ٦٢٩ ، نقض مدني . طعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٦١ ق . جلسة

١٩٩٦/٥/١٥ م المستحدث . ص ٢٢٣ .

(٣) نظرية الدفع . د/ أحمد أبو الوفا . بند ١٠٨ ص ٢٢٨ .

(٤) الوجيز د/ عبد الفتاح السيد بك. بند ٥٥٣. ص ٥٠٢.

واحدة^(١)، كما لو رفعت دعوى مطالبة بتنفيذ عقد بعينه، في حين يرفع الطرف الآخر دعوى يطلب فيها بطلان العقد نفسه أو فسخه^(٢)، وهذا الدفع يشترط له اتحاد الموضوع والسبب دون اتحاد الخصوم^(٣)، وهذا ما يفارق بينه وبين الدفع في الحالة الأولى، كما أن الدفع بالإحالة للارتباط لا يتقيد قبوله بالمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً، بل العبرة بأسبقية الدفع أمام أي منهما^(٤)، وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام، منعاً لتناقض الأحكام.

٤- الإحالة لاتفاق الخصوم :

قد تتم الإحالة استجابة لاتفاق الخصوم، وبناء على طلبهم ومحض إراداتهم، وذلك في الأحوال التي تكون فيها قاعدة الاختصاص مقررة بحسب الأصل لمصلحتهم، فهنا يخول القانون للخصوم الحق في الاتفاق على نقل دعواهم من محكمة إلى أخرى م " ١١١ " مرافعات؛ وذلك على نحو يحقق مصالح الخصوم المشروعة في التقاضي، ولا يخالف بحال قواعد القانون الأمرة في هذا الشأن، ويؤدي إلى حسن سير العدالة القضائية، وتحسين الأداء في رسالة القضاء.

هذا ويشترط في الاتفاق على الإحالة أن يكون صريحاً وواضحاً ومجمعاً عليه من قبل الخصوم، وخالياً من كل عيب يشوب إرادة أحدهم، فضلاً عن ضرورة أن تكون المحكمة التي رفعت إليها الدعوى ابتداءً مختصة فإن لم تكن كذلك فقد وجب على المحكمة هذه أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة بناءً على نص المادة " ١١٠ " مرافعات وليس على أساس نص المادة " ١١١ " مرافعات المتعلقة بالاتفاق فيما بين الخصوم.

وتعد الإحالة بناءً على اتفاق الخصوم على فرض توافر شروطه وصحته أمراً جوازياً في حق المحكمة، حيث يحق لها قانوناً أن تستجيب لطلب الخصوم أو ترفضه متى قام للرفض عندها سبب يقتضيه كما لو كانت المحكمة قد قطعت في الدعوى شوطاً كبيراً، أو كانت قد أوشكت على الانتهاء منها أو أن انتقال الدعوى منها إلى غيرها مما يؤثر على حسن العدالة القضائية .

ثالثاً : أهمية الإحالة:

تعد الإحالة عنواناً لصحة الحكم بعدم الاختصاص . ما لم يطعن فيه . ومن ثم فهي الوسيلة القانونية لتصحيح سير الدعوى وقت اتصالها بالقضاء^(٥).

(١) نظرية الدفوع، د/ أحمد أبو الوفا . بند ١٢٧ ص ٢٤٩ ، ٢٥٠ .

(٢) الدفوع الشكلية، د/ زياد صبحي ذياب . ص ٤٤ .

(٣) الدفوع الشكلية، د/ زياد صبحي ذياب . ص ٤٤ .

(٤) الوجيز، د/ عبد الفتاح السيد بك بند ٥٥٤ . ص ٥٠٣ .

(٥) الجزء الإجرائي . د/ أيمن رمضان . ص ٧٢٣ .

كما أن الإحالة هي الأثر الإجرائي المترتب على الحكم بعدم الاختصاص، وقد استهدف المقنن من وجوبها بعد الحكم بعدم الاختصاص تبسيط الإجراءات، وتقليل النفقات، ورفع المشقات عن المتخاصمين^(١) عند التقاضي والخصومات .

وهذا يتضح من اتجاه المقنن في تقريره نظر الدعوى أمام المحكمة المحالة إليها بحالتها دون حاجة إلى رفعها من جديد م ١١٠ مرافعات، وفي هذا توفير لوقت القضاء والمتخاصمين، وتبسيط للإجراءات القضائية .

فالمحكمة المحالة إليها الدعوى تلتزم بنظرها وفقاً للحالة التي كانت عليها أمام المحكمة المحيلة، ومن ثم فيعتد بكل إجراء أو تحقيق اتخذ بشأنها أو حكم صدر فيها وكان سابقاً على الأمر بالإحالة، وهذا يستلزم القول بأن المحكمة المحالة إليها الدعوى تبدأ بالنظر فيها من حيث انتهت المحكمة المحيلة^(٢).

وهذا مما يدل على أهمية الإحالة، حيث يترتب عليها انعدام المشقة في رفع الدعوى من جديد أو إعادة إجراءاتها مرة أخرى كما يترتب عليها تقليل النفقات، وتقصير مدد التقاضي، فضلاً عن سرعة الفصل في الخصومات والدعاوى؛ حيث لا يقبل عقلاً أن تقضى محكمة بعدم اختصاصها لقيام سببه دون أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي تراها مختصة بنظرها، ثم يكلف الخصم بإعادة إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة التي يحددها القانون؛ لتنظر في دعواه من جديد^(٣).

رابعاً: نطاق الإحالة:

يتسع نطاق الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص ليشمل الإحالة من محكمة قضائية إلى مثيلها، كما يشمل أيضاً الإحالة من محكمة قضائية إلى غيرها من جهات القضاء الأخرى^(٤)، المنصوص على منحها الولاية القضائية للنظر في دعاوى معينة كالمحاكم الاستثنائية. محاكم أمن

(١) الوسيط د / أحمد السيد صاوى . بند ١٥٢ . ص ٢١٥ ، قوانين المرافعات د / أمنية النمر . بند ٢٨٧ . ص ٦٢٩ .

(٢) الوسيط د / نبيل إسماعيل عمر . ص ٣٥١ ، قانون القضاء المدني د/فتحى والى . بند ٢٣٦ . ص ٥٦٨ ، ص ٥٦٩ ، نقض مدنى طعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٦١ ق . جلسة ١٩٩٦/٥/١٥ م .

(٣) أصول قانون المرافعات د / أحمد هندى . بند ١٧٩ . ص ٤٩١ ، الاختصاص القضائى أ / عبد الهادى عباس . بند ١٦٤ . ص ٣٤٥ ، الجزاء الإجرائى د / أيمن رمضان . ص ٧٢٣ .

(٤) قانون القضاء المدني د / فتحى والى . بند ١٨٨ . ص ٢٨٤ ، ص ٢٨٥ ، الوسيط د / أحمد السيد صاوى . بند

١٥٣ . ص ٢١٤ ، أصول قانون المرافعات د/أحمد هندى . بند ١٧٩ . ص ٤٩٥ ، قوانين المرافعات د/أمنية النمر

. بند ٢٨٧ . ص ٦١٣ ، الدفوع والطلبات المعارضة أ / مجدى هرجة . ص ٤٥ ، بحوث في قواعد المرافعات د /

عبد العزيز بدوي . ص ٨٩ . وقضاء انظر: نقض مدنى طعن رقم ٦٤٣ لسنة ٤٥ ق . جلسة ١٩٧٩/٣/٢٤ م .

الدولة، والمحاكم العسكرية ومحكمة القيم. واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي المحدد قانوناً. كهيئات التحكيم، ولجان فض المنازعات .
وبناءً على هذا تصح الإحالة من محكمة قضائية إلى محكمة استثنائية أو إلى لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، وذلك بضوابط مخصوصة تضمن سلامة رفع الدعوى وصحة اتصالها بالقضاء.

خامساً : تقييد الإحالة في مجال القضاء المستعجل:

يسرى حكم المادة ١١٠ مرافعات على القضاء المستعجل بشرط أن تكون الدعوى التي رفعت إلى قاضي الأمور المستعجلة دعوى موضوعية، أخطأ المدعى في رفعها^(١)، كدعوى تثبيت الملكية، ففي هذه الحالة يجب على القاضي المستعجل أن يقضى في هذه الدعوى بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة الموضوع المختصة^(٢).

أما إذا كانت الدعوى المرفوعة إلى القاضي المستعجل دعوى مستعجلة لم يتوافر بشأنها شرط الاستعجال أو عدم المساس بأصل الحق، كدعوى طرد المستأجر الذي قام بسداد الأجرة، فهنا يجب على القاضي المستعجل أن يقضى بعدم الاختصاص فقط ولا يأمر بالإحالة لأن قضاءه بعدم الاختصاص يعنى ضمناً الحكم برفض الدعوى وعدم قبولها^(٣)؛ لانتفاء شرطها ولا صحة للأمر بالإحالة، حيث إنها لا تكون إلا تبعاً للحكم بعدم الاختصاص^(٤).

والقاضي المستعجل يتحدد اختصاصه بالطلب الوقتي، فإذا توافر شرطه كان مختصاً بنظره وإلا قضى فيه بعدم القبول حيث لم يقدّم له اختصاص بنظر دعوى تخلف عنها شرطها، ومن ثم فيقضى بعدم القبول، وإذا قضى بعدم الاختصاص فهذا يعنى رفضه للدعوى وعدم قبولها ولا يجوز له والدعوى على تلك الحالة أن يأمر بالإحالة لأن الإحالة مقيدة بعدم الاختصاص .

وبهذا يكون حكم عدم الاختصاص من القاضي المستعجل سببه ذات الدعوى دون شخص القاضي .

(١) قوانين المرافعات د / أمينة النمر. بند ٢٨٩ . ص ٦٣٩ .

(٢) الدفوع والطلبات العارضة . أ/ مجدى هرجة . ص ٤٨ ، الوسيط . د / فتحي والي . بند ١٨٨ . ص ٢٨٤ .

(٣) الوسيط . د / فتحي والي . بند ١٨٨ . ص ٢٨٣ ، ص ٢٨٤ ، قوانين المرافعات . د/ أمينة النمر . بند ٢٨٩ . ص ٦٤١ .

(٤) وقد قضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بعدم الاختصاص لعدم توافر ركن

الإستعجال حكم منه للنزاع أثره عدم جواز إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع . نقض مدني . طعن رقم ١٠٦٧

لسنة ٥١ ق . جلسة ١٩٨٦/١/٢ م .

المبحث الثاني

الآثار الإجرائية المترتبة على الإحالة

إذا ما انتهت المحكمة من بحثها في الدفع بعدم الاختصاص، وتبين لها أنها هي المختصة بنظر الدعوى حكمت برفض الدفع واستمرت في نظر الدعوى، وأما إذا قضت بقبول الدفع فالدعوى تزول من أمامها، وقد أوجب عليها المقنن في هذه الحالة أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة^(١) عقب حكمها بعدم الاختصاص، أيّاً كان نوع الاختصاص، الذي استندت إليه في حكمها. وبناءً على هذا يترتب على الأمر بالإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص الآثار الإجرائية التالية:

أولاً: استنفاد المحكمة المحيلة سلطتها على الدعوى:

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائياً، أو قيمياً، أو نوعياً، أو محلياً وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بناءً على دفع الخصم، أو من تلقاء نفسها تستنفد بذلك سلطتها القضائية على الدعوى محل الإحالة^(٢).

وبذلك فإن الحكم الصادر بعدم اختصاص والإحالة ينهى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته، وإن لم تتعرض فيه للحق الموضوعي محل الدعوى، ومن ثم لا يكون لهذه المحكمة سلطة التصدي لهذه الدعوى مرة أخرى، كما أنه لا يجوز للخصوم إعادة رفع الدعوى من جديد أمام تلك المحكمة، حيث انتهت الخصومة أمامها بمجرد الحكم بعدم اختصاص والإحالة، ومن ثم فإن الدعوى تعتبر في حق المحكمة المحيلة كأن لم تكن، وذلك في حدود المسألة التي قضت فيها^(٣). ولا سبيل لإعادة سلطة المحكمة المحيلة على الدعوى مرة أخرى سوى الطعن في الحكم الصادر بعدم اختصاص والإحالة، وإلغاء الحكم المطعون فيه من قبل المحكمة الاستئنافية^(٤)، والحق في الطعن لا تملكه المحكمة المحيلة، إذ يتقرر قانوناً للخصوم أطراف الدعوى، ومن ثم فلهم الحق في التمسك به أو الزول عنه.

(١) الوسيط . د/أحمد السيد صاوي. بند ١٥٢ ص ٢١٤ ، قوانين المرافعات د/أمنية النمر. بند ٢٨٧. ص ٦٢٩

(٢) أصول قانون المرافعات د/ أحمد هندی . بند ١٧٩ . ص ٤٩٠ ، ص ٤٩١ ، الدفوع والطلبات العارضة . أ / مجدى هرجة . ص ٤٠ ، ص ٤١ .

(٣) المرافعات د/محمد حامد فهى . بند ٤٤٢ ، بحوث في قواعد المرافعات . د/ عبد العزيز بديوى . ص ٨٥ .

(٤) أصول قانون المرافعات د / أحمد هندی . بند ١٧٩ . ص ٤٩١ ، اختصاص القضاء . أ / عبد الهادي عباس . بند ٢٨٣ . ص ٥٤٣ .

فإذا لم يتم الطعن في حكم المحكمة المحيلة، أو رفع الطعن بعد فوات وقته المحدد له قانوناً أو تنازل الخصم عنه أو سبق اتفاقه على نهائية الحكم الذي يصدر في الدعوى أياً كان نوعه، ففي هذه الحالة لا يجوز للخصوم بأي حال إعادة دعواهم أمام المحكمة التي قضت بعدم الاختصاص والإحالة، وإذا رفعت تلك الدعوى أمام المحكمة المحيلة مرة أخرى فإنها تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها^(١).

هذا ويلاحظ أن للمحكمة المحيلة سلطة جوازية في توقيع الغرامة المالية على المدعى الذي أخطأ في رفع دعواه إلى محكمة غير مختصة^(٢). وهذه الغرامة تعد جزاءً إجرائياً يوقعه القانون على الخصم عند مخالفته قواعد الاختصاص المقررة، وهذه الغرامة لا تتجاوز قيمتها أربع مائة جنيه، ويلزم المدعى بأدائها طبقاً للمادة ١١٠ مرافعات.

كما يلاحظ أن مجال توقيع هذه الغرامة هو حالة قبول الدفع بعدم الاختصاص، أما إذا قضت المحكمة برفض الدفع فلا يجوز لها قانوناً توقيع الغرامة، لأن نص المادة ١١٠ مرافعات يعد استثناءً فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه^(٣).

ويجوز للمحكمة إعفاء المدعى من تلك الغرامة إذا ثبت لديها أن المدعى كان معذوراً في خطئه، لعدم وضوح الاختصاص.

ثانياً: انتقال الدعوى من المحكمة المحيلة إلى المحكمة المحال إليها أياً كان نوعها أو طبقته:

يترتب على الحكم بعدم الاختصاص والأمر بالإحالة انتقال الدعوى من المحكمة المحيلة إلى محكمة أخرى ترى المحكمة المحيلة أنها مختصة قيمياً أو نوعياً أو محلياً بنظر الدعوى، طبقاً لقواعد الاختصاص^(٤).

أما إذا كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة سببه انتفاء الولاية فيكفي لصحة الإحالة أن تحدد المحكمة المحيلة الجهة ذات الاختصاص دون تعيين للمحكمة المختصة داخل تلك الجهة^(٥)، كما هو الشأن في قضاء محكمة عادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الإدارية والأمر

(١) قوانين المرافعات د / أمينة النمر. بند ٢٨٧. ص ٦٣٣.

(٢) قانون القضاء المدني د/ فتحي والي . بند ٢٣٦ . ص ٥٦٨ .

(٣) قانون القضاء المدني. د/ فتحي والي بند ٢٣٦. ص ٥٦٨.

(٤) الوسيط. د/ أحمد السيد صاوي. بند ١٥٢. ص ٢١٥، الدفع والطلبات العارضة. أ/ مجدى هرجة ص ٤٦.

(٥) قانون القضاء المدني د / فتحي والي . بند ٢٣٦ . ص ٥٦٧ ، أصول قانون المرافعات . د/ أحمد هندی . بند ١٧٩ .

بإحالتها إلى جهة القضاء الإداري المختصة قانوناً بنظرها، وكذلك الحال بالنسبة للإحالة من جهة القضاء الإداري إلى جهة القضاء العادي^(١)، حيث يكفي لصحة أمر الإحالة أن يكون متضمناً تحديد اختصاص الجهة القضائية دون تعيين المحكمة المختصة التابعة لتلك الجهة وذلك دفعاً لتسلط قضاء محكمة تتبع جهة معينة على تحديد اختصاص محكمة أخرى تابعة لجهة أخرى^(٢). وقد هدف المقتن من تحديد الاختصاص بنظر الدعوى إلى احترام حكم المحكمة المحيلة الذي قضى باختصاص جهة أخرى؛ دفعاً لحالات تنازع الاختصاص السلبي بين جهتي القضاء^(٣).

أما إذا كانت المحكمة المحيلة والمحكمة المحال إليها تتبعان جهة قضائية واحدة فقد أوجب المقتن على المحكمة المحيلة أن تحدد عند الحكم بعدم الاختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى^(٤) ولا يعد هذا تسلط قضاء محكمة على تحديد اختصاص محكمة أخرى؛ لأن مصدر التحديد هو القانون. م ١١٠ مرافعات. وليس أمر الإحالة، ومن ثم فيجب احترامه وإعمال أحكامه والعمل بموجبه ومقتضاه.

وبناءً على هذا تنتقل الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة إلى المحكمة المحال إليها، ويستوى في ذلك أن تكون المحكمة المحال إليها من نفس طبقة المحكمة المحيلة أو من طبقة أعلى أو أدنى منها^(٥)، وذلك لعموم نص المادة ١١٠ مرافعات حيث قضى بوجوب الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص دون تمييز بين طبقات المحاكم أو درجاتها. فتصح الإحالة من محكمة جزئية إلى محكمة جزئية أخرى ومن محكمة جزئية إلى محكمة ابتدائية والعكس، كذلك تصح الإحالة من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف وهكذا. هذا وتلتزم المحكمة المحيلة بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها وإخطار الخصوم بموعدها، حتى يتسنى لهم متابعة سير دعواهم طبقاً للقانون^(٦).

(١) الوسيط. د/أحمد السيد صاوي. بند ١٥٢. ص ٢١٥، الوسيط. د/نبيل إسماعيل عمر. ص ٣٥١.

(٢) قانون القضاء المدني. د/ فتحي والي. بند ٢٣٦. ص ٥٦٧، ص ٥٧٠.

(٣) الوسيط. د / أحمد السيد صاوي. بند ١٥٢. ص ٢١٥، ص ٢١٦.

(٤) قانون القضاء المدني د/فتحي والي. بند ٢٣٦. ص ٥٦٧.

(٥) لأن المقرر من قضاء محكمة النقض: أن مفاد المادة ١١٠ أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التي تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها "، نقض مدني. طعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٦١ ق جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٦ م. ص ٧٩٤.

(٦) الوسيط. د/فتحي والي. بند ١٨٨. ص ٢٨٣، ص ٢٨٤، أصول علم القضاء. د/ عبد الرحمن عياد ص ٢٧٨،

بحوث في قواعد المرافعات د / عبد العزيز بديوي. ص ٨٩.

ثالثاً : التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها على حالتها :

تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها تنفيذاً لحكم الإحالة، بيد أن هذه المحكمة تتقيد وهي بصدد نظر الدعوى بالحالة التي تكون عليها وقت الحكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة من قبل المحكمة المحيلة، ويستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت إلى المحكمة المحيلة في صورة دعوى أصلية، أو في صورة دعوى تبعية، أو في صورة طلب عارض أو مرتبط^(١). وهذا يعني أن المحكمة التي تحال إليها الدعوى تعند بكافة الإجراءات، وأدلة الإثبات والأحكام الفرعية التي اتخذت أو صدرت في الدعوى محل الإحالة، وذلك عملاً بما تقرره المادة ١١٠ من أن الدعوى تحال إلى المحكمة بحالتها التي تكون عليها وقت الحكم بعدم الاختصاص^(٢).

هذا ويحق للخصوم عند متابعة دعواهم أمام المحكمة المحال إليها التمسك بجميع أوجه الدفع والدفاع التي كانت مقررة لهم أمام المحكمة المحيلة^(٣)، وهذا يعد تأكيداً على مبدأ أن الدعوى عند الإحالة تحال بحالتها.

رابعاً: حق المحكمة المحال إليها في القضاء بعدم الاختصاص والإحالة:

إذا رأت المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها لسبب آخر قام لديها كان لها الحق في القضاء بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، كما لو أحيلت إليها دعوى من محكمة جزئية مثلاً لعدم إختصاصها بنظرها محلياً، ورأت المحكمة المحال إليها أنها لا تختص بها نوعياً، فإنها تحكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية المختصة^(١)، كما يحق أيضاً للمحكمة الأخيرة القضاء بعدم الاختصاص المحلي والإحالة إلى المحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر الدعوى وهكذا . والسبب في هذا يرجع إلى أن التزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى محدد بالأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة^(٢).

(١) وإذا كان الاختصاص القضائي يباشر بغير طريق الدعوى فلا تتم الإحالة ، كما لو قدمت عريضة أمر الأداء إلى قاضي غير مختص ، رفض الأمر لعدم الاختصاص ، فإنه لا يحيله إلى القاضي المختص . قوانين المرافعات . د / أمينة النمر . بند ٢٨٨ . ص ٦٣٤ ، ص ٦٣٥ .

(٢) الوسيط . د/أحمد السيد صاوي . بند ١٥٣ . ص ٢١٥ ، ص ٢١٦ .

(٣) الوسيط . د / فتحي والي . بند ١٨٨ . ص ٢٨٣ .

(١) قوانين المرافعات د / أمينة النمر . بند ٢٨٧ . ص ٦٣٠ ، نقض مدني . طعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٦١ ق . جلسة ١٩٩٦/٥/١٥ .

(٢) نقض مدني ، طعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٦١ ق . جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م . المستحدث . ص ٢٢٣

ومن ثم يحق للمحكمة المحال إليها أن تقضى بعدم الاختصاص لسبب آخر تراهي لها، ويعد هذا تطبيقاً عملياً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً. كذلك يحق للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تقضى بعدم القبول لسبب يقتضيه كإنتفاء المصلحة في رفع الدعوى وشيها^(١). ومما تجدر ملاحظته في هذا الشأن؛ أن المحكمة المحال إليها الدعوى إنما تكون قد أدت التزامها المفروض عليها بمقتضى المادة ١١٠ مرافعات إذا قامت بمجرد النظر في الدعوى، ولولم تفصل هي في موضوعها^(٢). كما لو تبين لها عدم الاختصاص بنظر الدعوى لسبب آخر على النحو السابق بيانه..

وأرى أن المقنن كان موفقاً عندما استخدم في المادة ١١٠ مرافعات عبارة " بنظرها " دون عبارة "الفصل في موضوعها" مما يؤكد على أن المحكمة المحال إليها ليست ملزمة قانوناً بالفصل في موضوع الدعوى تنفيذاً لأمر الإحالة، وإنما قيامها بالنظر في الدعوى . ولو قضت بعدم الاختصاص لسبب آخر أو قضت فيها بعدم القبول . يعد تنفيذاً منها لأمر الإحالة وأداءً لواجبها المفروض عليها بمقتضى القانون-، وهذا لا يناقض حق الخصوم في الطعن على الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة أيأ كانت المحكمة التي أصدرته^(٣).

خامساً : الإبقاء على الإجراءات السابقة على أمر الإحالة:

تحال الدعوى عند الحكم بعدم الاختصاص إلى المحكمة المختصة بكل ما اتخذ فيها من إجراءات، وما تم فيها من تحقيقات، وأعمال للخبراء، وما قدم فيها من أدلة للنفي أو الإثبات، ومن ثم فهي تنتقل بكافة آثارها المترتبة عليها اعتباراً من يوم رفعها^(١)، فضلاً عن الإجراءات التي رفعت بمقتضاها أمام القضاء، بحيث لا يحتاج المدعى إلى تجديد لرفع دعواه أمام المحكمة المحال إليها، وإنما تبدأ هذه المحكمة بالنظر في الدعوى من حيث انتهت المحكمة المحيلة^(٢).

(١) الدفوع والدفاعات د/عبد الحكم فودة. ص ٣٠، قانون القضاء المدني د/ فتحي والي . بند ٢٣٦. ص ٥٦٨، ص ٥٧٠.

(٢) أصول قانون المرافعات د / أحمد هندی . بند ١٧٩ . ص ٤٩٤ .

(٣) الوسيط . د/رمزي سيف. ص ٣٩١ ، الوسيط . د/ أحمد السيد صاوى . بند ١٥٢ . ص ٢١٥ ، ص ٢١٦ ، الدفوع والدفاعات د / عبد الحكم فودة . ص ٣٢ .

(١) الوسيط. د/نبيل إسماعيل عمر. ص ٣٥٠ ، الدفوع والدفاعات . د/ عبد الحكم فودة . ص ٣١ . هذا وتعد الدعوى مرفوعة من تاريخ إيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة المحيلة ، بحوث في قواعد المرافعات . د / عبد العزيز بدوي . ص ٨٩ هامش رقم " ١ " .

(٢) الوسيط . د / رمزي سيف . ص ٣٩١ ، الوسيط . د / فتحي والي . بند ١٨٨ . ص ٢٨٢ .

وهذا يدل على مدى مرونة القضاء ووحدة عناصره ومحاكمه المختلفة ؛ ليعبر عن قضاء موحد لا تناقض ولا انفصال فيه، بل هو كل لا يتجزأ .
هذا ويمكن القول بأن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة يعبر في ذاته بطريق ضمني عن حكم آخر هو اختصاص المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى، مما يستلزم القول بحجية هذا الحكم أمام جميع المحاكم^(١).

والفقه الإسلامي يرتب عند إحالة الدعوى من قاض إلى آخر وجوب نظر القاضى الآخر المحال عليه في الدعوى المحالة إليه، ومصدر هذا الوجوب هو أصل الولاية وليس أمر الإحالة^(٢) فالقاضى المحيل انتفت عنه ولاية الفصل في الدعوى، في حين أنها ثبتت عليها ولاية نظر القاضى المحالة إليه، طبقاً لقواعد الاختصاص التي تحدد اختصاص كل قاض وترسم حدود ولايته.

وهذا هو معنى وجوب نظر القاضى في الدعوى المحالة عليه فالوجوب مصدره ثبوت الولاية له دون أمر الإحالة إليه. وبناءً على هذا يستنفذ القاضى الأول سلطته على الدعوى ؛ لعدم اختصاصه بها دون القاضى الثانى الذى تدخل الدعوى في اختصاصه بمقتضى ولايته .
كذلك يرتب الفقه الإسلامى على إحالة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص اعتبار الإجراءات التى رفعت بها الدعوى والاعتداد بما تم فيها من إثبات للحجج الشرعية وشهادة للشهود المعنية، وأيمان جبرية اعتبرها القاضى الأول^(٣) على وجهها الشرعى مخاطباً بها القاضى الثانى المكتوب إليه^(٤).

وفى هذا تقصير لمدد التقاضى، ورفع للمشقة عن عاتق القاضى من أن يعيد الثبوت أو إجراءات التقاضى، هذا فضلاً عن سرعة الفصل فى الدعاوى والخصومات، وتيسير الأمر على المتقاضين فى حسم المنازعات.

وقد أورد الفقه الإسلامى عدة أمثلة على الإحالة الوجوبية بعد الحكم بعدم الاختصاص أهمها :

(١) أصول قانون المرافعات . د / أحمد هندى . بند ١٧٩ . ص ٤٩٤ ، الوسيط . د / أحمد السيد صاوى . بند ١٥٢ . ص ٢١٥ ، ص ٢١٦ ، نقض مدني ، طعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٦٥ ق ، جلسة ٥ / ٧ / ١٩٩٦ م . ص ٧٣٦ ، طعن رقم ٣٩٢٩ لسنة ٦١ ق جلسة ٥ / ٤ / ١٩٩٧ م . ص ٦١٣ ، طعن رقم ٢١١٦ لسنة ٦٦ ق جلسة ٢٩ / ٦ / ١٩٩٧ م . ص ١٠٣٤ .

(٢) نظام القضاء فى الإسلام . د / محمد جمال الدين عواد . ص ١٤٣ .

(٣) مواهب الجليل للحطاب ٦ / ١١٠ ، تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٤٠ ، ٤١ .

(٤) المغنى ومعه الشرح الكبير لابن قدامة ١١ / ٤٥٨ وما بعدها .

١- إذا رفعت دعوى تتعلق بعقار ليس في بلد القاضى فعلى القاضى الذى رفعت إليه أن يحيلها إلى القاضى الذى يقع العقار في دائرة اختصاصه^(١).

يقول ابن فرحون " وفي مختصر الواضحة في الرجل من أهل المدينة يكون له دار بمكة فيدعيها رجل من أهل مكة قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : إنما تكون خصومتها حيث الدار والشئ المدعى فيه "

بيد أنه يلاحظ أن المدعى في هذه الدعوى بالخيار بين رفع دعواه مباشرة إلى قاضى بلد الدار، أو رفع دعواه أمام قاضيه لإثبات حجته ثم إحالة دعواه إلى قاضى موقع الدار، ويكتب القاضى المحيل إلى القاضى المحال إليه ما ثبت عنده من المدعى وما استند إليه من حجج شرعية^(٢).

٢- إذا رفعت دعوى على المدعى عليه في غير موطنه في الوقت الذى تقرر فيه قواعد الاختصاص الشرعية عقد الاختصاص بنظر الدعوى لقاضى موطنه، فهنا يكون للمدعى عليه الحق في الدفع بعدم اختصاص القاضى الذى رفعت إليه دعوى المدعى يطلب فيها إحالة الدعوى إلى قاضى موطنه المختص بنظرها شرعاً، وعلى القاضى الناظر في الخصومة إجابته إلى طلبه^(٣).

٣- إذا رفعت دعوى تنفيذية أو مستعجلة إلى قاض قصرت ولايته القضائية على الأنكحة فقط أو النفقات فقط أو المداينات فقط، فعلى القاضى إحالة الدعوى إلى القاضى المختص بالتنفيذ على المحكوم عليه دون غيره^(١).

(١) فكل دعوى تتعلق بعقار للأراضى والدور والتركات العقارية وأشباهاها ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضى موقع العقار انظر: جامع الفصولين . لابن قاضى سماونه ١ / ١٦ ، تبصرة الحكام . لابن فرحون ١ / ٦٧ .

(٢) تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٦٧ ، وجاء فيه : " قال ابن حبيب وخالف مطرف وأصيب قول ابن الماجشون في ذلك وقالوا إنما تكون الخصومة حيث يكون المدعى عليه ولا يلتفت إلى موضع المدعى ولا موضع المدعى فيه غير أن من حق المدعى إن شاء بدأ بقاضيه يعنى قاضى مكة فرفع إليه أمره وأثبت عنده بينته ثم كتب قاضى مكة بذلك إلى قاضى المدينة " .

(٣) نظرية الدعوى . د / محمد نعيم ياسين . ص ٦٠١ .

(١) المغنى ومعه الشرح الكبير . لابن قدامة ١١ / ٤٥٨ .

القسم الثاني

نظرية الدعوى القضائية وأجراءات التقاضي

مقدمة

جاء قانون المرافعات باعتباره الشريعة العامة للقوانين الإجرائية وبحكم أسبقيته التاريخية، لينظم إجراءات التقاضي أمام القضاء المدني، ولتوفير ضمانات لسيادة القوانين الموضوعية، بما تقرر من قواعد تنظم الحقوق وتبين طبيعتها وأصحابها وحدودها وكيفية استعمالها، وهذه الضمانة هي الحماية الإجرائية، التي يقوم عليها قانون المرافعات، من خلال تنظيمه للإجراءات التي تتبع في حماية المصالح أمام القضاء المدني.

وفي سبيل تنظيمه لهذه الإجراءات، نص المشرع على وسيلتين مهمتين للتقاضي، تتحقق من خلالهما وظيفة القضاء المدني في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، هما: التقاضي بوسيلة الدعوى، والتقاضي بوسيلة العريضة. ونتناول في هذا القسم بيان إجراءات التقاضي بهاتين الوسيلتين، وقد قسمنا الدراسة إلى أربعة أبواب:

الباب الأول: الدعوى القضائية: وتناولنا خلاله، بيان تعريف الدعوى القضائية في ضوء طبيعتها القانونية، ثم خصائصها، وعناصرها، وشروط قبولها، وتقسيماتها.

الباب الثاني: إجراءات التقاضي بوسيلة الدعوى: وتناولنا خلاله، بيان ماهية الإجراء القضائي ومقتضياته الموضوعية والشكلية، ثم بيان الجزاء الإجرائي، وما يجب اتباعه في الخصومة من إجراءات، بدء من رفع الدعوى وقيدها وانعقادها، ومرورا ببيان نطاق الخصومة، وإجراءات نظرها، وانتهاء بالحديث عن عوارض الخصومة، والتي قد تؤدي إلى ركودها أو انقضاؤها وانتهاءها.

الباب الثالث: التقاضي بوسيلة العريضة: وتناولنا خلاله، الأوامر على العرائض، ومجالاتها ونظامها القانوني، ثم تناولنا أمر الأداء ومجالاته ونظامه القانوني.

الباب الرابع: الحكم القضائي وطرق الطعن فيه، وذلك باعتبار الحكم خاتمة إجراءات التقاضي، كونه الإجراء الحاسم للتزاع والفاصل في الخصومة.

وقد راعينا في شرح هذه الإجراءات بساطة التعبير والابتعاد عن التعقيدات اللفظية واللغوية، والاستغراق في التفاصيل التي قد يكون محلها مؤلفات أخرى،

الباب الأول

الدعوى القضائية

نتناول خلال هذا الباب بيان ماهية الدعوى وخصائصها (فصل أول)، ثم بيان عناصر الدعوى وشروط قبولها وتقسيمات الدعاوى (فصل ثان).

الفصل الأول

ماهية الدعوى وخصائصها

الدعوى أداة للحق في التقاضي ومقيدة بحسن النية في استعماله:

الدعوى وسيلة للالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به^(١)، وقد هيئت الدولة بواسطتها للفرد كيفية الحصول على حقه، بعد أن حرمت عليه اقتضاءه بنفسه^(٢)، وبذلك أصبحت الدعوى وسيلة قانونية بمقتضاها يلجأ صاحب الحق إلى المحاكم لحماية حقه، وهي رخصة لصاحب الحق، واستعماله لها أمر اختياري، فله مطلق الحرية في الالتجاء إلى القضاء، وله أيضا مطلق الحرية في اختيار الوقت المناسب للالتجاء إليه، كما أن له مطلق الحرية في أن يتنازل عن خصومته التي أقامها إذا لم يتعلق بها حق للمدعى عليه^(٣).

ذلك أن حق الالتجاء إلى القضاء -باعتباره حق دستوري بنص المشرع الدستوري عليه- هو حق عام للناس جميعا، بحيث يتمتع به جميع الأشخاص دون تفرقة أو تمييز بينهم لأي سبب كان^(٤)، وبمقتضى هذا الحق، فإن لكل شخص الحرية في أن يطلب الحماية القضائية في الوقت الذي يرى فيه حاجته للحصول على هذه الحماية، ومعنى هذه الحرية أن الشخص حر في المطالبة القضائية، دون قيود معينة، أو أشكال محددة، فتكون له المطالبة بهذه الحماية بما يشاء من إجراءات، ويكون له أن يتخذ الإجراء المطلوب بأي شكل أو صورة. وحرية الادعاء بهذا المعنى لا تتعارض مع ما يقرره المشرع من وجوب اتباع طريق خاص عند المطالبة بالحماية القانونية^(٥).

(١) م. سيد حسن البغال: المطول، مكتبة عالم الكتب، ٢٠٠١، المجلد الأول، ص ١٢.

(٢) د. عيد محمد القصاص: الوسيط، دار النهضة العربية، ٢٠٠٥ م، ص ٥٣ و ٣٩٥- د. فتحي والي، الوسيط، طبعة مخصصة لنقابة المحامين، ١٩٨١ م، ص ٥٧.

(٣) د. أحمد مليجي: محاضرات في قانون المرافعات، (د.ن)، ٢٠٠١ م، ص ٢٢.

(٤) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات، مطبعة حمادة، ج ١/١٥.

(٥) د. أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الأول، ص ٤٧.

المبحث الأول

ماهية الدعوى وتميزها عن غيرها

أثارت فكرة الدعوى خلافا في الفقه القانوني، حول ما إذا كانت الدعوى هي الحق الموضوعي ذاته، أم حقا مندمجا به، أم مستقلا عنه، وتعددت الاتجاهات الفقهية في ذلك، ونتج عن ذلك اختلافا في تعريف الدعوى. ويقتضي بيان ماهية الدعوى، أن نبين أولا طبيعتها القانونية. واتجاهات الفقه القانوني حول طبيعة حق الدعوى، ثم نتحدث بعد ذلك عن تعريفها وتميزها عن غيرها.

المطلب الأول

فكرة الدعوى في ضوء طبيعتها القانونية

غموض فكرة الدعوى:

الحق فائدة يقررها القانون لصالح الأفراد، وهذا الحق لا يستكمل مقومات وجوده إذا لم يكن في وسع صاحبه أن يحميه ويرعاه وينتفع به، إلا أن ذلك لا يعني أن يقتضي الفرد حقه بذاته، أو يقضي لنفسه بنفسه، فيكون خصما وحكما في الوقت ذاته، إذ منعت الدولة الحديثة ذلك، وإنما على الفرد إذا أراد اقتضاء حقه ممن منعه إياه أو اعتدى عليه أن يلجأ إلى الوسيلة التي هيأتها الدولة لاقتضاء هذا الحق، وهذه الوسيلة هي الدعوى، إذ الدعوى هي الوسيلة القانونية للحصول على الحماية القضائية للحق أو المركز القانوني الذي وقع عليه الاعتداء، وهي أداة الأفراد لتأكيد تلك الحماية، كما أنها أداة القضاء في القيام بأدائها^(١).

فالدعوى إذا؛ وسيلة أو طريق للالتجاء إلى القضاء، وهي وسيلة ضرورية ولازمة بعد أن حرمت الدولة على الفرد اقتضاء حقه بنفسه، وهي المحل المباشر للعمل القضائي^(٢)؛ فبدونها لا يتصدى القاضي لحماية الحق، ولا يمكنه ذلك؛ إذ هي مناط عمله ومحل سلطانه، وبدونها يجد المرء نفسه في أحد مركزين^(٣)؛ إما رؤية حقه والغير يعتدي عليه دون عقاب ولا جزاء، وإما

(١) د. عبد المنعم الشرقاوي: شرح المرافعات المدنية والتجارية، دار النشر للجامعات المصرية، ١٩٥٠م ص ٢٨- د. عبد الحميد أبو هيف: المرافعات المدنية والتجارية، مكتبة الوفاء القانونية، ٢٠١٦م ص ٤١١- د. محمود مصطفى يونس: المرجع في قانون إجراءات التقاضي المدنية، دار النهضة العربية، ٢٠١٥م، ص ٣٢٧- د. وجدي راغب فهي: مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي، ١٩٨١م، ص ٧٥.

(٢) د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٧٥.

(٣) د. عبد الحميد أبو هيف، مرجع سابق، ص ٤١١.

اضطراره للانتقام لنفسه واستعادة حقه إليه إن أمكنه ذلك، وكلا المركزين غير جائز في الدول الحديثة ذات الأنظمة القانونية، ولذلك وجدت الدعوى.

ورغم هذه الأهمية للدعوى، فإنها إلى الآن كلمة قلقة غير معينة المراد، شاع الاضطراب في استعمالها، والتعبير عنها، ولم يعرفها المشرع المصري في قانون المرافعات ولا في القانون المدني^(١)، ولم يستقر الفقه القانوني على رأي بشأنها، كما لم تتحدد في أحكام القضاء تحديدا ينفي الغموض عنها؛ إذ لا تزال محل بحث واختلاف في وجهات النظر، ينظر إليها كل فقيه حسب زاوية معينة من وجهة نظره، فيعرفها ويكيفها ويحدد طبيعتها وفقا لهذه الزاوية، وفي ذلك اختلفت وجهات النظر.

وترجع صعوبة دراسة فكرة الدعوى إلى عدة أسباب^(٢)، أولها: الاختلاف حول علاقة الدعوى بالحق الموضوعي، وهل هما شيء واحد أم مختلفان؟ وثانيها: الاختلاف حول طبيعتها، هل هي سلطة أم حق؟ وثالثها: تعدد المصطلحات الإجرائية التي تستخدم في بعض الأحيان كمرادف لها، مثل القضية، والخصومة، والطلب، والادعاء، والمنازعة. ورابعها: ندرة النصوص التشريعية التي تنظمها وتزيل الغموض حول هذا الخلاف، بل إن بعض النصوص ساهمت في هذا الخلاف باستعمالها المصطلحات الإجرائية المرادفة لها، دون تمييز قاطع بينها.

وعلى الرغم من أن نظرية الدعوى لم تحظى قديما بقسط كبير من عناية شراح القانون؛ إذ لم تظفر من شراح القانون المدني، إلا بالفتاة عابرة في مقدمة القانون بمناسبة التعريف بالحق، ولم تنل من شراح قانون المرافعات غير مثل تلك الالتفاتة بمناسبة تقسيمات الدعوى في باب الاختصاص^(٣)؛ فإن شراح المرافعات أفردوا لها الآن من الدراسات ما يدل على عنايتهم واهتمامهم بإيضاح حقيقتها وبيان ماهيتها، ورغم ذلك، لم تستقر فكرة الدعوى حتى الآن، فلا تزال محور لخلاف محتدم لم ينته لنتيجة مؤكدة؛ إذ يقدم كل فقيه تعريف للدعوى يعد في ذاته صحيحا بالنسبة لما يقصده، ولكنه لا ينطبق على كل الاستعمالات التي يستعمل فيها لفظ الدعوى، ولا ينفي بالضرورة صحة التعريف الآخر الذي يستنكره^(٤)، واختلاف فقهاء القانون في تعريف الدعوى، يرجع إلى اختلافهم حول طبيعتها، ولذلك نبين اتجاهات الفقه القانوني في طبيعة الدعوى أولا، ثم نبين تعريفها ثانيا.

(١) د. عبد المنعم الشرقاوي: نظرية المصلحة في الدعوى، مكتبة عبد الله وهبه، ١٩٤٧، ص ١١.

(٢) د. عزمي عبدالفتاح: نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى، منشأة المعارف، ٢٠١٨، ص ٦.

(٣) د. عبد المنعم الشرقاوي، شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٢٧.

(٤) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٨.

اتجاهات الفقه القانوني حول طبيعة حق الدعوى

قلنا إن الدعوى مركز قانوني، وقد اختلف الفقه القانوني في تحديد ماهية هذا المركز القانوني، كاختلافهم في تعريف الدعوى، وأساس هذا الخلاف؛ تحديد العلاقة بين حق الدعوى، وبين الحق الموضوعي محل الدعوى، وللفقه في ذلك اتجاهات ثلاثة، يرى الأول منها: أن الدعوى هي ذات الحق الموضوعي، ويرى الثاني: أنها حق مستقل عن الحق الموضوعي، إلا أنهما مرتبطان ببعضهما البعض، في حين يرى الثالث: أنهما حقان مستقلان تماما. ونشير إلى هذه الاتجاهات فيما يلي:

الاتجاه الأول: الاتجاه التقليدي (الدمج بين الدعوى والحق الموضوعي):

يذهب الفقه التقليدي، إلى الربط بين الدعوى وبين الحق؛ إذ الدعوى في نظرهم ليست حقا مستقلا عن الحق الذي تحميه، بل هما شيء واحد، فالحق يبقى ساكنا هادئا ما لم يعتدى عليه، فإذا وقع هذا الاعتداء، فقد الحق سكونه وهدوءه وتحرك في صورة دعوى، فالدعوى إذا هي الحق الموضوعي ذاته ولكن في حالة حركة^(١).

ويتربط على هذا الرأي عدة نتائج، وهذه النتائج هي بذاتها حجة هذا الرأي فيما ذهب إليه، وأهمها: التلازم بين الحق والدعوى، فلا يوجد حق بلا دعوى، ولا توجد دعوى بلا حق، وأن لكل حق دعوى تحميه، وتكتسب الدعوى ذات الوصف الذي يكون للحق فتكون شخصية أو عينية بحسب الحق، وهكذا، ويعد وجود الحق شرط لقبولها^(٢).

وهذا الاتجاه منتقد من عدة وجوه:

أولها: أن الدعوى والحق الموضوعي يختلفان من حيث السبب، والمضمون، والأشخاص، والانقضاء، فسبب الحق الموضوعي، وقائع حددها القانون كمصادر للحق (كالعقد، أو الإرث مثلا)، أما حق الدعوى، فينشأ عن الاعتداء على الحق أو من واقعة تجهيله بصفة عامة، كما أن مضمون الحق يختلف بحسب نوعه، وما إذا كان حقا شخصيا، أو عينيا، أو غير ذلك، في حين أن مضمون الدعوى واحد دائما، وهو الحصول على حكم المحكمة، كما يختلفان من حيث الأشخاص، فقد لا يتفق دائما أصحاب الحق مع أشخاص الدعوى، فدعوى المطالبة بالدين

(١) د. أحمد السيد صاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، (د.ن)، ٢٠٠٥ ص ١٩٠- د. الكوني على أعبوده: قانون علم القضاء، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، ليبيا، ١٩٩٨م ص ١٢- د. وجدي راغب، مرجع سابق، ص ٨٣.

(٢) د. الكوني علي أعبوده، مرجع سابق، ص ١٢.

مثلا، قد ترفع من غير الدائن، كما لو رفعت من دائن الدائن في الدعوى غير المباشرة. كما أن أسباب الانقضاء تختلف في كليهما، فالدعوى قد تنقضي صلحا أو بالحكم في موضوعها دون أن ينقضي الحق الموضوعي^(١).

وثانياً: أن التلازم بين الدعوى والحق الموضوعي ليس دائماً، فقد يوجد الحق الموضوعي بغير دعوى، كحق الملكية الذي لم يعتدي عليه أحد، وحق الدائنية الذي لم يحل أجل الدين فيه، وقد توجد الدعوى بغير حق موضوعي، كدعوى الحيازة، حيث يتمسك المدعي بمركز واقعي، والدعاوى التقريرية السلبية، كدعوى براءة الذمة^(٢).

وثالثاً: أن الدعاوى قد تتعدد بشأن موضوعي واحد، فالاعتداء على حق الملكية مثلاً، يعطي الحق في دعوى الاستحقاق، ودعوى التعويض عن ضرر هذا الاعتداء^(٣).

ورابعاً: أن الدعوى تضيف جديداً إلى الحق، فاستعمال الدعوى يؤدي إلى إضفاء تأكيد قضائي له حجيته، لم يكن يتمتع به الحق من قبل^(٤).

الاتجاه الثاني: الاتجاه الحديث (استقلال الدعوى عن الحق الموضوعي):

ينذهب هذا الاتجاه إلى التمييز بين الدعوى والحق الموضوعي؛ إذ الدعوى في نظر القائلين به، ذات كيان مستقل عن الحق الذي تحميه، فهي وسيلة لحماية الحق وليست الحق ذاته^(٥). فالدعوى سلطة إجرائية ينظمها قانون المرافعات، وتتميز عن الحق الموضوعي (الملكية والدائنية مثلاً)، وهو سلطة موضوعية ينظمها القانون الموضوعي، كالقانون المدني^(٦).

ورغم ذلك، فإن هذا الاتجاه يربط بين حق الدعوى والحق الموضوعي، ويعتبر أن الدعوى تؤم الحق، ومجرد وسيلة لحمايته، فيعرفونها بأنها سلطة أو مكنة يعترف بها قانون المرافعات لصاحب الحق الموضوعي تخوله الحصول على الحماية القضائية، وهم بذلك يعدون الحق الموضوعي شرطاً من شروط الدعوى، وأن القانون لا يعترف بحق الدعوى للمدعي إلا إذا كان محققاً في دعواه^(٧).

(١) د. الكوني على أعبوده، ص ١٣ - د فتحي والي، الوسيط، ص ٦٣ - د. وجدي راغب فهي، ص ٨٤-٨٥، د. عزمي عبدالفتاح، ص ٢٧.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٣ - د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٨٥.

(٣) د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٨٥.

(٤) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٢٤٢.

(٥) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ١٩١.

(٦) د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٨٦.

(٧) المرجع السابق، ص ٨٦.

- وقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى ما وجه من انتقادات إلى الاتجاه السابق، لتبرير وجهتهم، إلا أن هذا الاتجاه تعرض أيضا لكثير من أوجه النقد، أهمها:
- ١- أن هذا الاتجاه أغفل التفرقة بين الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء؛ وهو حق عام يعترف به للكافة^(١)، أما الدعوى فهي حق لمن وقع عليه الاعتداء.
 - ٢- أن اعتبار الدعوى مجرد سلطة لا صلة لها بمحلها (الحق أو المركز القانوني المراد حمايته) لا يتفق مع المنطق، لأن المحل ركن في الدعوى^(٢).
 - ٣- أن هذا الاتجاه يؤدي إلى تبعية حق الدعوى للحق الموضوعي، رغم استقلال قانون المرافعات عن القانون المدني، فالأول ينظم حق الدعوى تنظيما مستقلا عن تنظيم القانون المدني للحقوق، فلا يجعل الحق الموضوعي شرطا لقبول الدعوى، بل يضع شروطا أخرى أهمها المصلحة^(٣).
 - ٤- أنه يؤدي إلى نتيجة غير منطقية؛ وهي عدم إمكانية التحقق من شروط الدعوى إلا بعد انقضاء حق الدعوى، وذلك لأن الحق الموضوعي لا يتأكد للمدعي إلا بالحكم في موضوع الدعوى^(٤).

الاتجاه الثالث: الاتجاه التوفيقى:

وقد حاول هذا الاتجاه التوفيق بين الاتجاهين السابقين، فذهب إلى أن الدعوى ليست الحق ذاته، كما في الاتجاه التقليدي، ولا حقا مستقلا عن الحق الذي تحميه، كما في الاتجاه الحديث، وإنما تعد جزء لا يتجزأ من الحق في إحدى عناصره، لا يكتمل الحق بدونها^(٥)، إذ الحق مصلحة مادية أو أدبية يحمها القانون، فعنصرها الحق هما المصلحة والحماية القانونية، وصورة الحماية القانونية هي الدعوى^(٦).

(١) د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٣٤١.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٢٤٢.

(٣) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٨٦.

(٤) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٨٧.

(٥) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ١٩٢.

(٦) د. عبد المنعم الشرقاوي، شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٣٣.

المطلب الثاني

تعريف الدعوى وتمييزها عن غيرها

إزاء عدم اهتمام المشرع بوضع تعريف للدعوى؛ فإن تعريفات الفقه القانوني لها تعددت واختلفت، ولسنا هنا في مجال سرد هذه التعريفات والتعليق عليها، وإنما نكتفي باختيار أنسبها في نظرنا للتعبير عن حقيقة الدعوى؛ إذ هي "الوسيلة التي خولها القانون صاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لتقرير حقه أو حمايته"^(١)، أو هي "وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو حمايته"^(٢).

وينبغي على القول بأن الدعوى، أداة الحصول على حماية القضاء عدة نتائج، أهمها: أنه ليس للقضاء أن يتدخل من تلقاء نفسه للفصل في منازعة لم تعرض عليه، كما أن هذه الوسيلة حق لصاحب الحق، وليس واجبا عليه، وما دامت كذلك؛ فلا يجبر على استعمالها، بل له أن يستعملها، أو لا يستعملها، كما أن له التنازل عنها إذا باشرها، كما أنها في نظرنا لا تتداخل مع الحق الموضوعي ذاته، بل هي وسيلة لاقتضاءه، وما دامت حقا فإنها كسائر الحقوق، يشترط في استعمالها حسن النية.

وينبغي على اعتبار الدعوى أداة لاقتضاء الحق، أنها تعد فرع عنه ونتيجة لازمة له، فلا حق يعتدى عليه أو يجهل به أو ينكر إلا وتكون له دعوى، يصل بها صاحب الحق إلى حقه^(١)، وإذا كانت الحقوق لا يحصى عددها؛ فكذلك الدعاوى، كما أن الحق والدعوى يولدان سويا ويعيشان سويا، فيبقى أحدهما ما بقي الآخر، كما أن لها من الأوصاف والمميزات ما للحق، فتارة تكون شخصية، وأخرى تكون عينية، وتارة تكون منقولة، وأخرى تكون عقارية، وهكذا، بحسب الحق الذي تحميه، كما أن موضوعها هو نفس موضوع الحق، فيحكم القاضي فيها بنفس الشيء المدعى به^(٢).

(١) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ١٨٨.

(٢) د. عبد المنعم الشرقاوي، شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٢٩. ونفضل استعمال كلمة "وسيلة" بدلا من "الوسيلة" لأن الأخيرة قد تفيد اعتبار الدعوى الوسيلة الوحيدة للجوء إلى القضاء لحماية الحق أو تقريره، وهذا ليس صحيح، فإلى جوارها توجد وسيلة التقاضي بالعريضة لحماية بعض الحقوق واقتضاؤها، كما في اقتضاء الديون الثابتة بالكتابة، باتباع طريق أمر الأداء.

(١) ويستثنى من ذلك الالتزامات الطبيعية التي يقر القانون وجودها، دون أن يعط صاحبها الحق في رفع دعوى للمطالبة بها، ومنها الالتزامات المدنية التي سقطت بمضي المدة، فلا يجوز المطالبة بها، وإن أدت فلا تسترد. (د. عبد الحميد أبو هيف، ص ٤١٤).

(٢) د. عبد الحميد أبو هيف، ص ٤١٤. واستثناء: توجد حالات لا يكون موضوع الدعوى فيها هو نفس الحق، كما في التعهدات التخيرية، وفي حالة تعذر الوفاء عينا، وفي التعهدات بعمل شيء مخصوص.

مفترضات الدعوى^(١):

الدعوى باعتبارها كائن قانوني، لها مفترضات تسبق وجودها، وهذه المفترضات، ثلاثة، الأول: حق أو مركز قانوني، وهذا الحق قد يكون عينيا، أو شخصا، أو معنويا، والثاني: أن يحدث اعتداء على هذا الحق أو المركز القانوني، وهذا الاعتداء يحرك عنصر الحماية القانونية في الحق، فتوجد الدعوى كوسيلة إلى هذا الحق، والثالث: طرفا الاعتداء، وهما صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه، والمعتدي.

تمييز الدعوى عن الأفكار المشابهة لها:

قلنا إن من أسباب غموض فكرة الدعوى، تشابهها مع عدد من الأفكار الأخرى، كحق الالتجاء إلى القضاء، والمطالبة القضائية، والخصومة، والقضية، والادعاء؛ ولذا لزم التمييز بين الدعوى وبين هذه المصطلحات القانونية المشابهة لها، على النحو الآتي:

١- الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء:

حق الالتجاء إلى القضاء -كما ذكرنا- من الحقوق العامة، المكفولة للناس جميعا بنص الدستور والقانون، ويرى البعض أن الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء شيء واحد^(١)، في حين يرى البعض الآخر أن هذا الرأي في غير محله، وأنه من المفيد التفرقة بينهما، فحق الالتجاء إلى القضاء باعتباره حق عام، مقرر لكل إنسان للدفاع عن حقوقه مصالحه، وهو بذلك لا يقبل التنازل عنه، ولا الانقضاء بأي سبب من الأسباب، أما حق الدعوى فهو حق مقرر بموجب قانون المرافعات، وهو حق شخصي إجرائي يثبت لشخص محدد، يستأثر به من يدعي حقا أو مركزا قانونيا معيناً، ولذا فهو يقبل الزول عنه، وينقضي بالتقدم، أو بأي سبب آخر يراه المشرع، وبناء على ذلك، فإن حق الالتجاء إلى القضاء يثبت للإنسان دائما ما دام على قيد الحياة، في حين أن حق الدعوى قد يثبت له، أو لا، بحسب ما إذا كان قد وقع اعتداء على حق من حقوقه أم لا^(٢).

٢- تمييز الدعوى عن المطالبة القضائية:

تختلف الدعوى عن المطالبة القضائية، فالدعوى وسيلة قانونية أقرها المشرع لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء، وهي وسيلة اختيارية، له استعمالها، أو عدم استعمالها، أما

(١) د. عبدالنواب مبارك: الوجيز في أصول القضاء المدني، دار النهضة العربية، ٢٠٠٨م، ص ٢٤٢.

(١) د. عزمي عبدالفتاح، مرجع سابق، ص ٧٠.

(٢) د. الكوني علي أبودود، مرجع سابق، ص ٢١- د. فتحي والي، ص ٦٠.

المطالبة القضائية؛ فهي الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى إلى القضاء، ويتم بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة؛ فهي إذا مجرد وسيلة لرفع الدعوى^(١).

فالمطالبة إذا ليست استعمالاً لحق الدعوى؛ إذ حق الدعوى أسبق في الوجود منها، كما أنها قد تكون صحيحة قانوناً دون أن تكون الدعوى مقبولة^(٢)، كما أن التنازل عن المطالبة القضائية لا يؤدي إلى انقضاء الحق في الدعوى، فله أن يعيد رفعها بمطالبة جديدة، إذا لم ينقض الحق فيها^(٣). فالمطالبة القضائية -في الرأي الذي نؤيده- وسيلة لتحريك القضاء ورفع الادعاء أمامه، وتعبير آخر، هي العمل الإجرائي الذي يعلن به الطالب رغبته في الحصول على حماية القضاء، وهي بذلك وثيقة الصلة بالدعوى؛ إذ الدعوى حق في الحماية القضائية بواسطة القضاء، ووسيلة الحصول على الحماية القضائية: الطلب القضائي^(٤).

٣- تمييز الدعوى عن الخصومة:

تتميز الدعوى عن الخصومة، إذ الخصومة هي مجموعة الأعمال الإجرائية التي يقوم بها القاضي وأعدائه والخصوم وممثلوم وأحياناً الغير؛ بقصد تحقيق الحماية القضائية؛ التي هي الحق في الدعوى^(٥). فالخصومة إذا هي مجموع الإجراءات التي يتم من خلالها عرض موضوع الدعوى على القضاء للفصل فيه، والجزاءات الإجرائية توجه إليها وتتعلق بها (كالشطب والوقف الجزائي والسقوط والانقضاء)، أما الجزء الذي يترتب على التعسف في استعمال حق الدعوى فهو جزء مدني، يتمثل في طلب التعويض^(٦)، وزوال الخصومة يترتب عليه زوال الإجراءات دون أن يؤثر ذلك على الحق في الدعوى، إذ للمدعي أن يجدد دعواه أمام القضاء بإجراءات جديدة^(٧).

(١) د. وجدي راغب فهبي، مرجع سابق، ص ٨١.

(٢) وذلك كما لو توافرت الشروط الشكلية لصحة المطالبة (بيانات صحيفة الدعوى أو الطعن أو الإعلان)، وكذلك شروطا الموضوعية، كأن تقدم ممن يتمتع بالأهلية الإجرائية، وفي الوقت نفسه تخلفت شروط الدعوى، وهي المصلحة والصفة. والجزاء المترتب على تخلف شروط المطالبة يختلف عن الجزء المقرر على تخلف شروط الدعوى، ففي الولي يكون الجزء هو البطلان، ووسيلة التمسك به الدفع بالبطلان، وهو دفع شكلي، وفي الثانية يكون الجزء عدم القبول، ووسيلة التمسك به، الدفع بعدم القبول، ولكل منهما أحكام مختلفة.

(٣) د. الكوني علي أعبوده، مرجع سابق، ص ٢٣.

(٤) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٥-٦٦.

(٥) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٥-٦٦.

(٦) د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٣٥١.

(٧) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ١٩٣.

٤ - تمييز الدعوى عن القضية:

القضية تعبير شائع في الحياة القضائية، يستخدم أحيانا بمعنى مرادف للخصومة، وأحيانا بمعنى مرادف للدعوى^(١)، وهي عبارة عن مجموعة من المسائل الموضوعية والإجرائية المعروضة على القضاء لفحصها وتحقيقها تمهيدا للفصل فيها^(٢).

وتمثل الدعوى محور القضية، أي الأداة الفنية التي تعرض موضوع القضية على القضاء، فهي إذن جزء من القضية لأنها تمثل الجانب الموضوعي فيها، غير أنهما يختلفان من حيث عناصرهما، فمن حيث الأطراف: فإن طرفي الدعوى هما المدعي والمدعى عليه فقط، في حين تتسع القضية لتشمل المدعي والمدعى عليه والمتدخل والمدخل، ومن حيث الموضوع: فإن موضوع الدعوى يتضمن مسائل موضوعية فقط، في حين يتسع موضوع القضية ليشمل المسائل الموضوعية والإجرائية، ومن حيث السبب: فإن سبب الدعوى يتجسد في وجود اعتداء على الحق أو المركز المدعى به، أو وجود تهديد بالاعتداء على هذا الحق أو المركز، في حين أن سبب القضية هو عدم جواز القضاء الخاص^(٣).

٥ - تمييز الدعوى عن الادعاء:

إذا كان لفظ الادعاء يتشابه مع لفظ الدعوى، ويستعمل الأخير في بعض الأحيان ويقصد به الأول، فإنه يجب عدم الخلط بينهما، إذ لا يمكن القول بأن الدعوى وهي وسيلة لحماية الحقوق والمراكز القانونية، هي الادعاء، فالذي يحقق الحماية ليس مجرد الادعاء أو الحق فيه، وإنما الحق في الحصول على حكم يحقق هذه الحماية بواسطة القضاء، والادعاء لا يعني أن لمن تقدم به الحق فيه، فقد يقبل إذا كان رافعه هو صاحب الحق في الدعوى أو يرفض إذ لم يكن كذلك.

ولاختلاف فكرة الدعوى عن الادعاء، فإن من المقرر أن الدعوى توجد بمجرد الاعتداء على الحق ولو قبل بدء الخصومة، أما الادعاء فإن لا يوجد إلا برفعه أمام القضاء^(٤).

(١) د. وجدي راغب فهري، مرجع سابق، ص ٨٢.

(٢) د. سيد أحمد محمود: التقاضي بقضية وبدون قضية، دار النهضة العربية، ٢٠٠٩ م، ص ٤٤.

(٣) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٤٦.

(٤) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦١.

المبحث الثاني

خصائص الدعوى

من خلال ما سبق، نتبين خصائص الدعوى وهي: أن الدعوى حق وليست واجبا، وهي من الحقوق التي تقبل التنازل، وحق قابل للحالة والانتقال، وقابل للانقضاء أيضا.

١- الدعوى حق وليست واجبا:

فحين يقع الاعتداء على الحق أو المركز القانوني، ينشأ لصاحبه حق الدعوى، وهو حق شخصي إجرائي، له أن يستعمله، وله ألا يفعل، إذ لو كانت الدعوى واجبا، لأجبر الشخص على استعمالها، وهو أمر لا يستقيم مع طبيعتها، ومن ثم لا تتفق مع من يرى أنها واجب وليست حق^(١)، والدعوى باعتبارها حق لها طابعان، أحدهما: طابع اختياري: بمقتضاه يكون صاحب الحق بالخيار بين استعمالها أولا، وثانها: طابع حر ومقتضاه أن مجرد خسارتها، لا يوجب المساواة^(٢).

إلا أنه في نظرنا، يجب أن يكون استعمال حق الدعوى مبنيا على حسن النية، فالدعوى باعتبارها حق، يجب أن تتقيد بما تتقيد به سائر الحقوق من عدم التعسف في استعمالها، مع وجوب عدم التوسع في فكرة التعسف في استعمال حق الدعوى، حتى لا تؤدي إلى تعطيل حق الالتجاء إلى القضاء خشية المسؤولية حال الإخفاق في الدعوى، وهو أمر يستلزم حسن إعمال السلطة التقديرية للقاضي في هذا الشأن، وخضوعها لرقابة محكمة النقض.

٢- الدعوى حق يقبل التنازل عنه:

فمقتضى كونها حق، أن يكون لصاحبه الحق في التنازل عنه، وتجب التفرقة هنا بين التنازل عن الحق الموضوعي، والتنازل عن الحق في الدعوى، فالأول، يؤدي إلى زوال الحق الموضوعي نفسه، ومن ثم وبالتالي؛ زوال الدعوى التي تحميه، فيشمل كلاهما (الحق الموضوعي وحق الدعوى)، أما الثاني، فهو تنازل عن الحق في الدعوى وحده، وهو لا يمتد إلى الحق الموضوعي، فيبقى الأخير قائما رغم التنازل عن الدعوى التي تحميه، والتنازل عن الدعوى تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة للمتنازل وحده، لا يلزم لصحته أو لإتمامه؛ أن يصادفه قبول من جانب المدعى عليه^(٣).

(١) وهو رأي الفقيه إهرنج، وأشار إليه د. فتحي والي، الوسيط، ص ٦٧.

(٢) د. الكوني علي أعبوده، مرجع سابق، ص ١٩.

(٣) أستاذي د. الأنصاري النيداني: التنازل عن الحق في الدعوى، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٩ م، ص ٥.

٣- الدعوى حق قابل للحوالة والانتقال:

فهي تابعة للحق الموضوعي الذي تحميه، وتقبل - إذا كان يقبل- الحوالة والانتقال، فتجوز حوالتها، بحوالة الحق الموضوعي إلى الغير، ويجوز انتقالها بسبب الخلافة العامة أو الخاصة؛ إلا إذا كان الحق لصيقاً بصاحبه؛ فلا تقبل دعواه حوالة أو انتقالاً.

٤- الدعوى حق ينقضي بالتقادم:

فهي تخضع لمدة محددة يجب رفعها خلالها، فإذا انقضت هذه المدة، تقادمت ولم يعد لها وجود، ومقصود المشرع من تقادم الحق أو الالتزام، ينصرف في الحقيقة إلى الحق في الدعوى، ودليل ذلك أن مدة التقادم تبدأ بنشأة الحق في الدعوى^(١).

(١) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦١.

الفصل الثاني

عناصر الدعوى وشروط قبولها وتقسيمات الدعوى

المبحث الأول

عناصر الدعوى

تتطلب الدعوى وجود ثلاثة عناصر، هي: الأشخاص، والمحل، والسبب، وهذه العناصر قد لا تظل ثابتة بالضرورة خلال نظر الدعوى؛ إذ قد يرد عليها تعديل، فقد يتحدد أشخاص الخصومة مثلا بعد تقديم المطالبة القضائية وذلك بالتدخل أو الإدخال - على نحو ما سيأتي بعد- وقد يتغير المحل بالإضافة أو النقصان (الطلبات العارضة)، وكذلك فإن سبب الدعوى قد يتغير أو يضاف إليه؛ ولذلك فإن الأقرب إلى الصواب، عدم الخلط بين عناصر الدعوى في حالة السكون، وعناصرها في حالة الحركة (الخصومة القضائية)^(١). وقبل الحديث عن عناصر الدعوى، نبين أهمية هذه العناصر، فيما يلي:

أولاً: أهمية تحديد عناصر الدعوى:

تتمثل أهمية تحديد عناصر الدعوى في أربعة أمور أساسية، هي:

١ - تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بدعوى واحدة أم بدعويين:

ذلك أنه لا يجوز أن تقوم خصومتان متعاصرتان في دعوى واحدة، منعا لتضارب الأحكام وتفاديا لضیاع الوقت والجهد والمصروفات، وتحديد عناصر الدعوى يبين ما إذا كنا بصدد دعوى واحدة أم دعويين، بحيث إذا كانت عناصر الدعويين واحدة من حيث الأشخاص والمحل والسبب، فإننا نكون أمام دعوى واحدة، ولا يجوز أن تقوم بشأنها خصومتان أمام القضاء؛ فإذا حدث ذلك؛ كان للخصم أن يدفع بسبق رفع الدعوى، فتضم الدعوى الثانية إن كانت نفس محكمة الدعوى الأولى، أو تأمر المحكمة بإحالتها إذا رفعت أمام محكمة أخرى.

٢ - تقييد القاضي بعناصر الدعوى:

إذ المحكمة لا تملك الفصل في مسألة لم ترفع إليها، ولا يملك القاضي أن يخرج على عناصر الدعوى المطروحة عليه؛ فليس له أن يقضي لغير الخصوم، ولا أن يفصل في غير موضوع الدعوى، ولا بسبب غير ما رفع به الخصم دعواه؛ فإن فعل كان حكمه معيبا.

(١) د. الكوني علي أعبيده، مرجع سابق، ص ٣٠.

٣- عدم جواز صدور حكمان قضائيان في دعوى واحدة:

ذلك أن تعدد الأحكام في المسألة الواحدة قد يؤدي إلى تعارض الأحكام، وهذا التعارض يؤدي إلى استحالة تنفيذ الأحكام المتعارضة، ويتساوى ذلك مع فكرة إنكار العدالة، ولا يمكن أن يقر المشرع أمراً فيه إنكار للعدالة؛ لذلك حرص على تأكيد مبدأ عدم تعدد الخصومات في الدعوى الواحدة، فجعل للحكم الصادر في الدعوى حجية تحول دون إعادة نظر النزاع من جديد أمام ذات المحكمة أو أية محكمة أخرى؛ فإذا رفعت دعوى سبق الفصل فيها؛ فإن على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، وللخصوم أن يدفعوا بذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

٤- تتحدد خصومة الاستئناف بعناصر الدعوى:

إذ الطعن بالاستئناف يرتب أثران مهمان، أولهما: خروج الدعوى من سلطة محكمة أول درجة، فلا يجوز لها إعادة نظرها بعد أن فصلت فيها، وثانيهما: نقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف بكل ما أبداه الخصوم في شأنه من طلبات أو أسباب أو دفعات أو أوجه دفاع، وهو ما يعرف بالأثر الناقل للاستئناف، وهذا يقتضي تحديد عناصر الدعوى التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى، أشخاصا ومحلا وسببا، حتى لا تتغير هذه العناصر أو أحدها أمام محكمة الاستئناف^(١).

ثانيا: عناصر الدعوى:

عناصر الدعوى -كما قلنا- ثلاثة، هي: الأشخاص والمحل والسبب، وهذه العناصر قد تظل كما هي منذ المطالبة القضائية، وقد تتغير أثناء سير الدعوى، سواء بالإدخال أو التدخل، أو بالطلبات العارضة، أو بتعديل سبب الدعوى أو تغييره. ونشير إليها فيما يلي:

١- أشخاص الخصومة:

وهم الخصوم، والخصم من يقدم طلبا إلى القضاء أو من يقدم في مواجهته هذا الطلب، وقد يأخذ صفة المدعي أو صفة المدعى عليه، والمدعي هو من يقدم بنفسه أو بواسطة غيره الطلب، والمدعى عليه هو من يقدم في مواجهته هذا الطلب^(٢).

والعبرة في تحديد أشخاص الدعوى، هي بصفاتهم فيها لا بمباشرتهم لها، فقد يباشر الدعوى شخص لا صفة له بالنسبة للحق أو المركز المدعى به، مثل المحامي أو النائب أو الولي أو الوصي،

(١) د. محمد عبد النبي غانم، مرجع سابق، ص ٤٥.

(٢) د. عبيد محمد القصاص: قانون المرافعات، دراسة موجزة خاصة بطلبة حقوق، ٢٠٠٨م، ص ٣٤٣.

ومع ذلك لا يعد طرفا في الدعوى؛ لأن الطرف الأصلي هو الموكل أو المشمول بالولاية أو الوصاية، حيث يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، على الرغم من عدم حضوره أو مباشرته لإجرائها.

ولكي تعتبر دعوى معينة مطابقة لدعوى أخرى، بحيث يتعلق الأمر بدعوى واحدة، بما يترتب على ذلك من آثار إجرائية؛ فإنه يشترط أن يكون العنصر الشخصي واحدا في الدعويين، متى اتفقت الدعويين في عنصري الموضوع والسبب.

٢- موضوع الدعوى:

وهي النتيجة التي يسعى المدعي إلى الحصول عليها من وراء دعواه، كإثبات ملكيته لعقار معين أو منقول أو حقه في تعويض مالي أو غير ذلك، بأن يطلب تقرير وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني، أو يطلب إلزام المدعى عليه بأداء معين، أو القيام بعمل معين، أو الامتناع عن عمل معين، أو طلب تغيير المركز القانوني، كالتطليق، أو حل الشركة، أو يطلب إجراء وقفي أو تحفظي، كفرض نفقة مؤقتة أو تعيين حارس على العقار.

ويتكون محل الدعوى من ثلاثة عناصر، هي: نوع الحماية التي يطلبها المدعي، ونوع الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته، ومحل الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته^(١).

٣- سبب الدعوى:

ويقصد به الوقائع القانونية المنتجة، التي يتمسك بها المدعي كسبب لدعواه، بصرف النظر عن التكييف القانوني لهذه الوقائع^(٢)، وهذا السبب لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.

وتجب التفرقة بين سبب الدعوى وبين النص القانوني أو القاعدة القانونية التي يستند إليها المدعي في دعواه، وكذلك تجب التفرقة بين سبب الدعوى وأدلتها.

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب: قانون المرافعات، الكتاب الثاني، ص ٣٩٢.

(٢) المرجع السابق، ص ٣٩٤.

المبحث الثاني

شروط قبول الدعوى

قبول الدعوى مرحلة سابقة على الفصل فيها؛ إذ المحكمة لا تنتقل إلى مرحلة الفصل في الدعوى إلا إذا تحققت من شروط قبولها أمامها؛ ولذلك يجب على المحكمة أن تبحث مدى توافر هذه الشروط أولاً؛ فإذا ما تحققت من توافرها واختصاصها بنظرها؛ انتقلت إلى مرحلة الفصل فيها.

ويذهب الفقه القانوني إلى أن هناك شروط عامة للدعوى، وهي عبارة عن الخصائص الإيجابية التي يتطلب القانون توافرها في الدعوى لقبولها والفصل في موضوعها، وجميعها تبر عن المصلحة في الدعوى، وأحياناً يتطلب القانون شروطاً أخرى تعرف بالشروط الخاصة، وهي التي يتطلب القانون توافرها في دعوى معينة دون غيرها من الدعاوى، كالمواعيد الخاصة ببعض الدعاوى؛ أي التي يجب رفع الدعوى خلالها. فضلاً عن أن هناك شروطاً أخرى يعبر البعض عنها بالشروط السلبية أو موانع الدعوى، وهي ما يرتب القانون على تحققها عدم قبول الدعوى؛ كالتقادم مثلاً.

ولسنا هنا بصدد بحث الشروط الخاصة لكل دعوى أو بحث الشروط السلبية في الدعوى؛ وإنما نعى هنا بالشروط العامة لقبول الدعوى، وفي هذا الصدد نجد أكثر من اتجاه للفقه القانوني في تحديد هذه الشروط، إلا أننا نميل إلى ما ذهب إليه جمهور الفقه من أن شرط الدعوى الوحيد، هو المصلحة، كما نص على ذلك المشرع في المادة الثالثة مرافعات. إذ لم يشترط المشرع لقبول الدعوى سوى شرطاً واحداً فقط، وهو شرط المصلحة، باعتبار أن مفهوم المصلحة باوصافها التي حددها المشرع يتسع ليشمل كافة الشروط الأخرى التي تحدث عنا بعض الفقه. وتتناول شرط المصلحة فيما يلي:

المطلب الأول

المصلحة

قلنا إن الحق في التقاضي، حق عام مكفول للناس كافة، وأن الدعوى وسيلة قانونية لاستعمال هذا الحق، والقضاء هو السلطة المختصة بالفصل في الدعوى، وشروط قبول الدعوى لم توضع لتقييد استعمال هذا الحق، وإنما وضعت من أجل الحفاظ على وقت القضاء وجهده، من الضياع في دعاوى وادعاءات عديمة الفائدة، وليس في نظرها وبحثها أية منفعة، ولذلك اشترط المشرع توافر المصلحة كشرط لقبول الدعوى، تنزيهاً لساحات المحاكم

عن الانشغال بدعاوى لا فائدة منها، فقد يسيء الفرد استعمال حق اللجوء إلى القضاء، ويرفع دعاوى لا فائدة منها^(١)، وهذا أمر غير مقبول؛ إذ لا يحق للمرء أن يرفع دعوى لا تهمه نتائجها ولا تفيده، ولا أن يشغل أوقات المحاكم الثمينة بمسائل لا تعود عليه بالنفع ولا تدفع عنه الضرر^(٢).

ولذلك نص المشرع في المادة الثالثة مرافعات على أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

ويجوز للمحكمة عند عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبين أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي".

فالمصلحة وفقا لذلك، شرطا لقبول الدعوى، وبدونها تعد الدعوى عبثا لا فائدة منه، وحينئذ لا يجوز للقضاء نظرها، ولا الانشغال بها، فما المصلحة؟ وما أوصافها؟ وما منزلتها من شروط الدعوى؟

فكرة المصلحة:

المصلحة هي الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء، وما لم تتوافر هذه المصلحة فلا تقبل الدعوى، ولذلك يقال بأن المصلحة هي مناط الدعوى، ولا دعوى حيث لا توجد مصلحة^(٣).

فينبغي أن تكون هناك فائدة أو منفعة تعود على المدعي من دعواه على فرض الحكم لصالحه، وهذه الفائدة قد تتمثل في حماية الحق، أو اقتضاؤه، أو الاستيثاق له، أو الحصول على ترضية مادية، أو أدبية؛ فالمصلحة إذا هي الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء^(٣).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في قانون المرافعات، ج ١/١٣١- د. عبدالتواب مبارك، مرجع سابق، ص ٢٤٦.

(١) د. عبد الحميد أبو هيف، مرجع سابق، ص ٤٢٣.

(٢) المستشار. سيد حسن البغال، المطول، مرجع سابق، ص ٢٩٠.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١/١٣٠.

ورغم إجماع فقهاء المرافعات على أهمية المصلحة وضرورتها كشرط لقبول الدعوى، فإن غالبيتهم لم يتعرض لتعريفها، في حين تعددت تعريفات البعض الآخر لها، فعرفها البعض^(١) بأنها "الفائدة أو المنفعة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها"، وعرفها البعض^(٢) بأنها "الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدى عليه، والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق هذه الحماية"، في حين عرفها البعض^(٣) الآخر بأن "المصلحة في الدعوى تعني الحاجة إلى الحماية القضائية"^(٤).

والمصلحة ليست شرطاً لقبول الدعوى فقط، وإنما هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في حكم^(٥)، وهي ليست لازمة لقبول ما يتمسك به المدعي فحسب؛ وإنما شرط لقبول ما يتمسك به المدعي عليه من دفع أو أيا كان نوعها، ومصلحة المدعي عليه فيما يبديه من دفع هي تفادي الحكم عليه بطلبات المدعي كلها أو بعضها^(٦)، وشرط لكل ما يقدمه الغير الذي يتدخل في الدعوى، سواء كان تدخله انضمامياً أو اختصاصياً.

وقد ثار خلاف واسع في فقه المرافعات حول شرط المصلحة ومنزلته من شروط الدعوى، وما إذا كان هو الشرط الوحيد لقبول الدعوى أم أن هناك شروط أخرى، إلى جانبه، كأن تكون الدعوى قانونية، وأن يكون للمدعي والمدعى عليه صفة في الدعوى، وأن تتوافر الأهلية فيهما، وأن يتوافر الحق الذي تقام الدعوى لحمايته، وغير ذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقه.

ونرى أن المشرع وبمقتضى تعديل المادة الثالثة مرافعات^(٧) على النحو الذي أسلفناه، حسم بهذا النص المعدل الخلاف الفقهي حول شروط قبول الدعوى، فجعل المصلحة بأوصافها المذكورة في النص، الشرط الوحيد لقبول الدعوى^(٨).

والمصلحة المقصودة من الدعوى، والتي نعني بها هنا، تختلف عن الحق ذاته؛ إذ المصلحة، وهي الفائدة التي تعود من الدعوى، تتمخض عن حماية الحق أو اقتضائه، وهذا أمر مختلف عن الحق ذاته، فالحق رغم الاعتداء عليه أو رغم التراخي في وفائه قائم قانوناً، ولكن الدعوى

(١) د. محمد حامد فهبي: المرافعات المدنية والتجارية، طبعة ١٩٣٥-١٩٣٦، ص ٢٨٧.

(٢) د. عبد المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى، مرجع سابق، ص ٥٦.

(٣) د. محمد حامد فهبي: المرافعات المدنية والتجارية، طبعة ١٩٣٥-١٩٣٦، ص ٢٨٧.

(٤) د. وجدي راغب فهبي، مرجع سابق، ص ٩٢.

(٥) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ١٣٣/١.

(٦) د. رمزي سيف: الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار النهضة العربية، ١٩٦٧م، ص ١٣٣.

(٧) عدلت هذه المادة بالقانون رقم (٨١) لسنة ١٩٩٦م.

(٨) أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٤٠٠- د. عبد التواب مبارك، سابق، ص ٢٤٧. ويراعى في هذا الصدد،

ما يوجبه المشرع من نصوص خاصة برفع بعض الدعاوى.

ترفع لدفع العدوان عليه أو لتعجل الوفاء به، فالهدف منها هدف عملي وهو ابتغاء ثمرة الحق والحصول فعلا على المنفعة المرجوة منه^(١).

والدفع بانعدام المصلحة لم يعد متعلقا بمصلحة الخصوم، بل أصبح -بمقتضى التعديل المشار إليه- دفعا متعلقا بالنظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وتجاوز إثارته في أية حالة كانت عليها الإجراءات، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، أو أمام محكمة النقض^(٢).

النتائج المترتبة على اعتبار المصلحة شرط قبول الدعوى:

إذا كنا قد انتهينا إلى أن المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى وفقا لما قرره المشرع، ولما استقر عليه جمهور الفقه القانوني، فإن ذلك يرتب عدة نتائج، أهمها^(٣):

- ١- أن وجود الحق، لا يكفي وحده لإمكانية رفع الدعوى ما لم تكن ثمة مصلحة من الحكم للمدعي بطلباته.
 - ٢- أن توافر المصلحة يكفي بذاته لقبول الدعوى، ولو كان المدعي مهملًا فيما رفعت الدعوى بشأنه.
 - ٣- تنتفي المصلحة إذا كان الأثر القانوني للدعوى يترتب على إجراء أو واقعة أخرى دون حاجة لرفع الدعوى.
 - ٤- المصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فقط؛ وإنما لقبول أي طلب أو دفع أو طعن.
- الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه المصلحة:
- المصلحة باعتبارها شرط قبول الدعوى، يجب توافرها وقت رفع الدعوى، ولكن ما الحكم إذا توافرت في هذا الوقت، وزالت أثناء نظر الدعوى؟
- للفقه في هذه المسألة أكثر من رأي، فالبعض يرى: أنه يكفي توافرها وقت رفع الدعوى ولو زالت بعد ذلك^(٤)، في حين يرى البعض الآخر: ضرورة توافر المصلحة من بداية الدعوى، وحتى الحكم فيها، بحيث يجب أن تستمر في كافة مراحل نظر الدعوى، فإن زالت أثناء نظرها وجب الحكم بعدم قبول الدعوى^(٥). وإذا لم تتوفر المصلحة وقت رفع الدعوى، ولكنها توافرت عند نظرها؛ حكم بقبولها، حتى لا يعاد رفع الدعوى من جديد وبإجراءات جديدة^(٦).

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٢٠٤.

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٢٠٢.

(٣) د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٣٦١.

(٤) د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٩٨.

(٥) د. عبد المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة، مرجع سابق، ص ٨٥.

(٦) د. أمينة النمر، الدعوى وإجراءاتها، ص ٦٦- د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٣٦٤.

المطلب الثاني

أوصاف المصلحة

لا تكفي المصلحة لقبول الدعوى إلا إذا توافرت أوصافها التي نص عليها المشرع في المادة الثالثة مرافعات، وهي أوصاف ثلاثة، الأول: أن تكون قانونية، والثاني: أن تكون شخصية ومباشرة، والثالث: أن تكون قائمة. وفيما يلي نتناول هذه الأوصاف الثلاثة:

أولاً: المصلحة القانونية

يشترط في المصلحة أن تكون قانونية، بأن تكون منفعة يقرها القانون، ويتحقق ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز قانوني، فيكون غرضها المطالبة بهذا الحق أو المركز القانوني، أو رد الاعتداء عليه، أو المطالبة بتعويض عن الضرر الذي أصاب الحق، إذ يجب في كافة الحالات أن تكون المصلحة مشروعة يقرها القانون^(١).

فالمصلحة القانونية وحدها هي التي تصلح عماداً أو أساساً للدعوى، وهي تتميز عن المصلحة الاقتصادية؛ بأنها تكون متصلة بحق فردي معين، فإذا كانت المصلحة مرسلة، غير مرتبطة بحق معلوم؛ فإنها لا تكون قانونية، ولا يمكن إقامة الدعوى على أساسها^(٢)، وإذا أقيمت الدعوى وفقاً لذلك، فإنها تكون غير مقبولة.

ولا يعني ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى وجود الحق الموضوعي المدعى به؛ وإنما يشترط فقط؛ أن تكون الدعوى إدعاء بحق أو مركز قانوني، وهي مسألة يتحقق القاضي منها، فإذا وجد أن قواعد القانون المجردة تحمي نوع المصلحة المطلوبة؛ فإن الدعوى تكون قانونية، وإلا حكم بعدم قبولها^(٣)، والقاضي بذلك يستبق الزمن الحاضر ويبحث فيما إذا كان القانون يحمي المصلحة المطلوبة أم لا؛ حتى يتمكن من إصدار حكمه لقبول الدعوى^(٤).

وحكمة النص على وصف قانونية المصلحة، تكمن في وظيفة القضاء؛ وهي حماية النظام القانوني، وبالتالي حماية الحقوق والمراكز القانونية، ومن ثم لا تقبل الدعوى إلا إذا كانت ترمي إلى حماية حق أو مركز قانوني، فإذا رفعت للمطالبة بمصلحة اقتصادية أو أدبية لا يحميها القانون؛ فإنها لا تكون مقبولة لأنها تتجاوز وظيفة القضاء^(٥).

(١) د. أحمد السيد صاوي، ص ٢٠٩ - د. أحمد مليجي، ج ١٣٤/١ - د. عبد التواب مبارك، ص ٢٤٩.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٣٥/١.

(٣) د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٩٤.

(٤) د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٠ م، ص ٢٩٩.

(٥) د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٩٥.

وقانونية المصلحة لا تعني أنها تكون مادية في كل الأحوال، وإنما قد تكون كذلك، وقد تكون مصلحة أدبية، فتتخذ إذا إحدى صورتين: الأولى: المصلحة المادية: وهي الصورة الأكثر شيوعاً، وتكون كذلك إذا كان الغرض من الدعوى حماية حق عيني أو اقتضاء حق شخصي، كدعوى استرداد الحيازة، أو دعوى النفقة، أو دعوى الإثراء بلا سبب، أو دعوى الشفعة، فالمدعي قد يطالب المدعى عليه بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، أو يطلب مبلغاً من النقود نتيجة لتعهد ارتبط به المدعى عليه، أو يطلب تعويض عن إخلال المدعى عليه بالتزامه، أو عن فعل خاطئ ارتكبه، فمثل هذه المصلحة إما أن تكون لها قيمة مالية، أو تؤدي إلى قيمة مالية^(١).

والثانية: المصلحة الأدبية: وهي التي تحمي حقاً أدبياً لرافع الدعوى^(٢)، فهي تستند إلى حق أدبي أو معنوي، يتمثل في حماية عواطف المحبة بين الناس، أو حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، أو حماية الشرف والاعتبار^(٣)، كدعوى التعويض عن السب أو القذف، ودعوى التعويض من الوارث عن الألم النفسي من جراء قتل المورث، ودعوى الوالد بتعويض الضرر الأدبي الذي لحقه جراء حادثة وقعت لطفله^(٤).

وقد تستند الدعوى إلى الحقين (المادي والادبي) معاً، كدعوى التعويض التي ترفعها الزوجة عن وفاة الزوج أثناء عمله لعدم اتخاذ إجراءات السلامة من قبل المصنع الذي يعمل به، فتطلب التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها بوفاة العائل الوحيد لها، والأخرى تتمثل في الآثار النفسية المترتبة على وفاة زوجها^(٥).

وقد تستند المصلحة إلى حق أو مركز قانوني ورغم ذلك تكون غير مشروعة ومخالفة للنظام العام، ولا تكون الدعوى معها مقبولة، ومثالها: دعوى المطالبة بفوائد تزيد عن الحد المسموح به قانوناً^(٦). وهناك حالات تتوفر فيها المصلحة، ورغم ذلك لا تكون الدعوى مقبولة، كالمصلحة الاقتصادية (المادية البحتة)، ومثالها: مطالبة أحد التجار بتعويض عن حادثة أدت إلى وفاة أحد عملائه، أو مطالبة تاجر بإبطال عقد شركة لا يكون عضواً فيها، حتى وإن كان عقد تأسيسها باطلاً وكانت له مصلحة من الحكم بإبطاله، تتمثل في إنهاء منافستها له، إذ أنها مصلحة اقتصادية بحتة، لا يتوافر معها شرط قبول الدعوى.

(١) د. أحمد مليجي، ج ١/١٣٥ - د. محمد عبد النبي، ص ٧٤ - د. محمود مصطفى يونس، ص ٣٧٠.

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٢١٠.

(٣) د. محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٣٧١.

(٤) د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، ص ١٤٧ - د. أحمد أبو الوفا، المرافعات، ص ١٢٣.

(٥) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٤٦.

(٦) د. عبد التواب مبارك، مرجع سابق، ص ٢٥٠.

كذلك فإن المصلحة التافهة لا تكفي لقبول الدعوى، وتتمثل تفاهة المصلحة في أن يعود على صاحبها نفع لا شأن له، أو زهيد القيمة، فمثل هذه المصلحة لا يصح لأجلها شغل وقت القضاء؛ إذ القانون لا يأبه بالتوافه، وساحات القضاء ينبغي ألا تنشغل إلا بما يعود بنفع ذي بال على الأشخاص، ولذلك لا تقبل دعوى يطالب فيها المدعي بهدم عقار جاره لأنه امتد عدة سنتيمترات في أرضه^(١).

كما لا تكفي المصلحة النظرية البحتة لقبول الدعوى، إذ الدعوى تكون غير منتجة وبالتالي غير مقبولة، فليس لشخص أن يطالب بإبطال زواج شخص آخر وإن عاد عليه نفع نظري يتمثل في الثأر لكرامته لأنه كان زوجا سابقا لهذا الشخص، فالدعوى هنا غير مقبولة لأن المصلحة نظرية، ولأن المدعي لا صفة له فيها^(٢).

ثانيا: المصلحة الشخصية والمباشرة

فضلا عن اشتراط المصلحة القانونية؛ فإنه لا تقبل الدعوى إلا إذا كان لصاحبها مصلحة شخصية ومباشرة، والمقصود بذلك: أن يكون المدعي هو صاحب الحق الذي حصل الاعتداء عليه والذي يرمي بدعواه إلى حمايته وتقديره^(٣)؛ إذ لا يجوز لشخص آخر أن يرفع الدعوى للدفاع عن صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه، إلا إذا كان هذا الشخص نائبا عنه، كالوكيل والوصي والقيم، أي ممثله القانوني، فليس لأحد أن يفتئت على صاحب الحق، فينصب من نفسه قيما عليه؛ ذلك أن صاحب الحق الذي وقع الاعتداء عليه هو الأقدر على ترجيح مصلحته، وتقدير ما إذا كان الأنفع له رفع الدعوى أم لا، كما أنه ليس لأحد أن يجبره على رفع الدعوى، وإلا عد ذلك فضولا منه^(٤).

ويعبر عن هذا الشرط بشرط "الصفة"، والمراد بها في لغة القانون، السلطة أو الصلاحية التي بموجبها يستطيع الشخص القيام بعمل نظرا لوجود علاقة بينه وبين هذا العمل^(٥)، وهي ليست شرطا في المدعي فقط، وإنما شرط في المدعى عليه كذلك، بأن يكون رافع الدعوى هو نفسه من اعتدى على حقه أو مركزه القانوني، وأن يرفعها في مواجهة الشخص الذي اعتدى على هذا الحق^(٦). فالدعوى يجب أن توجه من ذي صفة على ذي صفة.

(١) د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٣٧١.

(٢) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٤٦.

(٣) د. حامد فهد، مرجع سابق، ص ٣٦٠.

(٤) د. أحمد سيد صاوي، مرجع سابق، ص ٢١٣- د. محمود مصطفى يونس، سابق، ص ٢٨٨.

(٥) د. الكوني علي أعبوده، مرجع سابق، ص ٣٨.

(٦) د. عبدالتواب مبارك، مرجع سابق، ص ٢٥١- د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ١٢٤.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بعدم قبول دعوى رفعها زوجة لإبطال تصرفات صادرة من زوجها لبعض أولاده، بدعوى أنه قصد منه التحايل على الميراث، إذ لا صفة لها في رفعها، طالما كان زوجها على قيد الحياة، لأن حقها في الميراث لا يتقرر إلا بعد وفاته^(١).

ورغم اتفاق الفقه القانوني على ضرورة كون المصلحة شخصية ومباشرة، إلا أن هناك من يميز بين هذا الشرط وبين شرط الصفة، فيعتبرون أن المصلحة الشخصية والمباشرة هي الفائدة التي تعود على الشخص من مباشرة الدعوى، أما الصفة فهي سلطة مباشرة الدعوى، فقد يكون للشخص مصلحة شخصية ومباشرة ولكن المشرع لا يعترف له بالصفة في رفع الدعوى، فلا يجوز لغير من تقرر البطلان لمصلحته أن يرفع دعوى إبطال العقد، على الرغم من مصلحة الطرف الآخر أو مصلحة أشخاص ليسوا أطراف في طلب البطلان.

في حين يرى الرأي الغالب في الفقه القانوني -ونؤيدهم في ذلك- أن شرط المصلحة الشخصية والمباشرة هو بذاته شرط الصفة، بمعنى أن الصفة المطلوبة في التقاضي ليست إلا المصلحة الشخصية المباشرة.

وهنا تجب التفرقة بين حالتين، الأولى: أن يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المعتدى عليه، فهنا تختلط الصفة بالمصلحة الشخصية المباشرة. والثانية: أن يكون رافع الدعوى شخصا آخر غير صاحب الحق، ولكنه يرفعها باعتباره نائبا عن صاحب الحق، وهنا تتميز الصفة عن المصلحة الشخصية المباشرة، إذ يجب على المدعي في هذه الحالة أن يثبت صفته في تمثيل ذلك الغير الذي ترفع الدعوى باسمه، كما لو كان وصيا أو قيما عليه، أو كان نائبا عن الشخص المعنوي^(٢).

التمييز بين الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي:

ينبغي التمييز بين الصفة في الدعوى، سواء كانت صفة عادية أو غير عادية، وبين الصفة في التقاضي، وهي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية في الدعوى باسم غيره، فهناك حالات لا يستطيع فيها صاحب الحق أن يباشر الدعوى بنفسه، فينوب عنه في ذلك شخص آخر وهو ممثله القانوني، كالولي، والوصي، والقيم، والوكيل، والحارس، ورئيس مجلس الإدارة، فهؤلاء ينوبون عن صاحب الحق في الدعوى ولا يطالبون لأنفسهم بشيء فيها، ومن ثم فإن صفتهم في الدعوى قاصرة على مباشرة إجراءاتها، دون أن تكون لهم صفة الحق المدعى به.

(١) الطعن رقم ٥٣ لسنة ٦ قضائية جلسة ١٩٣٧/١/٢٨.

(٢) د. أحمد مليجي، مرجع سابق، ج ١/١٣٧- أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٤٢٥.

ويترتب على هذا التمييز أن توافر الصفة في الدعوى شرط لقبولها، ولذا يترتب على تخلفه عدم قبول الدعوى، أما توافر الصفة الإجرائية فهو شرط لصحة الإجراءات، ولذا يترتب على تخلفه انقطاع الخصومة^(١).

وتجدر الإشارة إلى أن الصفة الإجرائية لا تثبت إلا للشخص الطبيعي كامل الأهلية الإجرائية، بخلاف الصفة في الدعوى، فهي تثبت للشخص الطبيعي سواء كان كامل الأهلية أو ناقصها، وكذلك للشخص الاعتباري. وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص توافر الصفة في الدعوى، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله^(٢).

الاستثناءات على شرط المصلحة الشخصية والمباشرة:

الأصل أن الدعوى لا تقبل إلا ممن كانت له مصلحة شخصية ومباشرة، واستثناء من ذلك، أورد المشرع عدة استثناءات على هذا الأصل، منها ما يعد رعاية لمصلحة خاصة جديرة بالرعاية، ومنها ما يعد رعاية لمصلحة عامة، أو رعاية لمصلحة جماعية، وقد أشارت إلى هذه الاستثناءات المادة (٣) مكرر من قانون المرافعات^(٣). وهي:

١ - الدعوى غير المباشرة:

نص المشرع على هذه الدعوى في المادتين (٢٣٥ و ٢٣٦) من القانون المدني، وأجاز بمقتضاها لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلا بشخصه أو غير قابل للحجز، وله في هذا الصدد رفع الدعاوى للمطالبة بحقوق مدينه لدى الغير، وذلك للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائنين على جميع أموال المدين، إذ قد يقعد هذا المدين عن المطالبة بحقوقه، قصدا أو إهمالا فيتأثر بذلك الضمان العام للدائنين.

وقد نصت المادة (٢٣٥) مدني، على وجوب توافر شروط معينة لرفع هذه الدعوى، أهمها من الناحية الإجرائية، إدخال المدين خصما في الدعوى، فضلا عن شروط أخرى مجال بحثها في القانون المدني^(٤).

(١) د. محمود مصطفى يونس، ص ٣٩٤ - د. وجدي راغب فهبي، ١٢٥-١٢٦.

(٢) د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٣٨٩.

(٣) هذه المادة مستحدثة بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٦ م.

(٤) د. أحمد مليجي، مرجع سابق، ج ١/١٣٩.

٢- دعاوى النيابة العامة (ومنها دعوى الحسبة):

الأصل في الدعوى المدنية أن يرفعها الأفراد أو غيرهم من الأشخاص الخاصة دفاعاً عن مصالح خاصة، إلا أن هناك بعضاً من هذه المصالح الخاصة تمس مصلحة عامة للمجتمع، ولذلك أعطى المشرع للنيابة العامة في هذه الحالات الحق في رفع الدعوى أو التدخل فيها حماية للمصلحة العامة وحفاظاً على النظام العام والآداب^(١).

ومثال ذلك: حق النيابة العامة في رفع دعوى شهر إفلاس تاجر، وحققها في التدخل في الدعاوى الخاصة بعديمي الهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، والدعاوى المتعلقة بالنظام العام طبقاً للمادة (٨٩) مرافعات، وحققها في الطعن في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، طبقاً للمادة (٩٦) مرافعات^(٢). وكذلك حيث يجيز لها المشرع بالنقض لمصلحة القانون حيث لا يجوز للخصوم ذلك (مادة ٢٥٠ مرافعات).

دعوى الحسبة:

وهي تلك الدعوى التي لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية ومباشرة، وإنما يرفعها احتساباً لوجه الله تعالى وابتغاء الثواب منه، وأساسها النهي عن المنكر، كدعوى التفريق بين زوجين يكون زواجهما باطل، لعدم رضا الزوجة، أو لردة الزوج، أو للجمع بين أختين، أو أكثر من أربع زوجات، أو لزواج مسلمة بغير مسلم، والدعوى بإثبات طلاق زوجة من زوجها طلاقاً بائناً، ودعوى طلب الحجر على شخص أو تعيين قيم عليه، والدعوى بتعيين قيم، أو عزل ناظر على وقف الفقراء. ولم يأخذ المشرع بدعوى الحسبة سوى في مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية، وجعل حق تحريكها للنيابة العامة وحدها، وقصر دور الأفراد فيها على مجرد تقديم شكوى للنيابة، والتي يكون لها بعد إجراء ما تراه من تحقيقات، حفظ الشكوى، أو رفع الدعوى بها إلى المحكمة المختصة، وفي الحالة الأخيرة تأخذ موقف المدعي في الدعوى، ويكون لها حق رفعها ومباشرتها، استثناء من شرط المصلحة الشخصية والمباشرة (أو ما يعبر عنه بالصفة في الدعوى).

٣- دعاوى النقابات والجمعيات:

هل يجوز للنقابة، وللجمعية، رفع الدعاوى سواء للمطالبة بحقوقها الخاصة، أو المطالبة بحقوق أعضائها، أو أحدهم؟ وهل تتوافر لها الصفة في ذلك؟

(١) د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ١٦٣.

(٢) د. عبدالنواب مبارك، مرجع سابق، ص ٢٥٤.

نفرد في دعاوى النقابات والجمعيات بين ثلاثة حالات أو ثلاثة أنواع من الدعاوى:

النوع الأول: الدعاوى التي ترفعها النقابة أو الجمعية باعتبارها شخصا معنويا له ذمة مالية مستقلة: ولها في هذه الحالة رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقها الخاصة، طبقا للقواعد العامة، فاللنقابة أو الجمعية صفة المطالبة مثلا بثمن أشياء قامت ببيعها، أو بإلزام مقول بتنفيذ ما اتفق عليه من أعمال، كما أن لها صفة في المطالبة بحماية اسمها إذا اعتدى عليه غيرها^(١).

النوع الثاني: الدعاوى التي ترفعها النقابة أو الجمعية للدفاع عن مصلحة خاصة بأحد أعضائها: والأصل أن لا صفة لها في رفع هذه الدعاوى، غير أن المشرع منح النقابة صفة غير عادية أو استثنائية في هذه الدعاوى، بنص المادة (١٦٥) من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣م الخاص بقانون العمل، وهذا النص خاص بالنقابة فقط متى كانت طرفا في اتفاقية عمل جماعية، ولا شأن له بالجمعيات^(٢)، إذ ليس لهذه الأخيرة رفع الدعوى دفاعا عن المصلحة الخاصة لأحد أعضائها.

النوع الثالث: الدعاوى التي ترفعها النقابة دفاعا عن المصلحة الجماعية: وهي تلك الدعاوى التي تتعلق بالمصلحة المشتركة المستقلة التي أنشئت النقابة أصلا لحمايتها، وليس مجموع المصالح الفردية لأعضائها.

وقد استقر الرأي فقها وقضاء في مصر، على حق النقابة في رفع الدعوى دفاعا عن المصلحة المشتركة للمهنة التي تمثلها، ومن ثم تقبل الدعوى التي ترفعها نقابة المحامين مثلا على من ينشر مقالا أو يقوم بعمل يتضمن إهانة لمهنة المحاماة، وكذلك تقبل دعوى نقابة الأطباء ضد شخص يمارس مهنة الطب خلافا لقوانين المهنة^(٣). أما بالنسبة للجمعيات فالرأي أنها لا صفة لها في الدفاع عن هذه المصالح، لأنها ليست على غرار النقابة لا تمثل المهنة التي ينتمي إليها أعضاؤها^(٤).

(١) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ١٢٨-١٢٩.

(٢) د. عبدالتواب مبارك، مرجع سابق، ص ٢٥٧.

(٣) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ١٢٨.

(٤) د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٤٠١. وذكر سيادته أن هذا الاتجاه منتقد، لأنه يفرق بين دعوى رفعت من نقابة للدفاع عن مصالح مشتركة لأصحاب مهنة واحدة فيقبلها القضاء، ولا يقبلها إذا رفعت من جمعية، مع أن الغرض من إنشاء هذه التنظيمات واحد في الحالتين، وهو تحقيق المصلحة العامة لأعضائها.

ثالثاً: المصلحة القائمة

أوجبت المادة الثالثة مرافعات، أن تكون المصلحة اللازمة كشرط لقبول الدعوى؛ حالة وقائفة، ويتضح من نص هذه المادة أن المشرع أورد قاعدة عامة بشأن شرط المصلحة القائمة، كما أورد استثناءات على هذه القاعدة العامة، وذلك على النحو الآتي:

القاعدة العامة: أن تكون المصلحة قائمة وحالة:

إذ يجب أن تكون المصلحة قائمة بالفعل، بمعنى أن يكون الاعتداء قد وقع على الحق المرفوعة به الدعوى، أو أن يكون قد حصل فيه نزاع يتطلب فضه بواسطة القضاء، لأن القضاء إنما يفصل في النزاع الذي وقع فعلاً^(١). كأن يمتنع المدين عن الوفاء بالتزامه للدائن بالرغم من حلول الدين، فيحرم الدائن من الانتفاع بمزايا حقه؛ ولذلك تقبل دعوى الدائن للمطالبة بدين حل أجله، أما قبل حلول الالتزام فلا تقبل الدعوى لأن المصلحة فيها ليست قائمة؛ ولو كان الدائن يتوقع عدم وفاء المدين بالتزامه عند حلول الأجل^(٢).

والاعتداء على الحق أو المركز القانوني يتخذ صوراً متعددة، فقد يقع بمجرد الامتناع عن القيام بعمل، كما في المثال السابق، وقد يتحقق بمجرد التشكيك حول هذا الحق أو المركز القانوني والتجهيل به باتخاذ مظاهر خارجية ملموسة، فيطلب المدعي إزالة هذا الشك، كما في دعوى إثبات النسب، وقد تنشأ الحاجة لتدخل القضاء لتغيير مركز قانوني قائم أو تعديله، كما لو أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبة على العقد فيطلب الطرف الآخر فسخ العقد^(٣).

أما إذا كانت المصلحة غير قائمة أو غير حالة، بأن كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ولم يكن قد تحقق بعد، وقام المدعي برفع دعواه إلى القضاء، فإنها تكون غير مقبولة، لرفعها قبل الأوان، وللمدعي أن يدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب. وعلة ذلك أنه لا حاجة لصاحب الحق في أن يلجأ إلى القضاء إذا لم ينازع في حقه أو مركزه القانوني، ولأن ذلك يتنافى مع مهمة القضاء بالفصل في المنازعات، وحيث لا منازعة حول الحق أو المركز القانوني، فلا يصح شغل القضاء بمنازعات لم تحل بعد^(٤).

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٤٠٧.

(٢) د. أحمد مليجي، مرجع سابق، ج ١٥٠/١.

(٣) د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٣٧٤.

(٤) د. أحمد سيد صاوي، مرجع سابق، ص ٢٢١-٢٢٢.

الاستثناء على القاعدة العامة:

توجب القاعدة العامة - كما سبق أن أشرنا- أن تكون المصلحة قائمة وحالة. ومع ذلك أوردت المادة (٣) مرافعات استثناء هاما على هذه القاعدة، حيث نصت على قبول الدعوى إذا كانت هناك مصلحة محتملة، وكان الغرض من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ومن ثم نشير إلى فكرة المصلحة المحتملة، ثم إلى حالات قبولها، وذلك فيما يلي:

فكرة المصلحة المحتملة:

واجه المشرع حالات لا يكون الاعتداء فيها حالا- كما أوجبت القاعدة العامة- وإنما يكون على وشك الوقوع، فتنشأ للمدعي مصلحة في عدم وقوعه، وهو ما يعرف "بالمصلحة المحتملة"، فاستثنى هذه المصلحة من شرط المصلحة القائمة، وهو استثناء لا يرد على شرط المصلحة ذاته، وإنما على شرط وقوع الضرر- فالمشرع يشترط المصلحة دائما لقبول الدعوى، ولا يستثني من ذلك شيء إذ لا دعوى بلا مصلحة- وإنما يتخفف في بعض الحالات، فلا يشترط أن تكون المصلحة قائمة، فيجيز قبول الدعوى رغم أن الضرر لم يقع بالفعل ولكن يحتمل وقوعه^(١). ويمكن حصر الحالات التي يجيز فيها المشرع قبول الدعوى بناء على هذه المصلحة المحتملة في طائفتين من الدعاوى، هما:

- ١- دعاوى القصد منها الاحتياط لدفع ضرر محقق، وتسمى "الدعاوى الوقائية".
- ٢- دعاوى القصد منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتسمى "دعاوى الأدلة". وتتناول هذين النوعين فيما يلي:

الطائفة الأولى: الدعاوى الوقائية:

وهي تلك الدعاوى التي يقصد منها الاحتياط لدفع ضرر محقق، أي وشيك الوقوع، وهنا يكون للشخص الحق في توقي حدوث هذا الضرر والاطمئنان على حقه من عدم الاعتداء الفعلي عليه والذي قد يجرمه من المزايا والمنافع التي تتولد عن هذا الحق. وهذه الطائفة يندرج تحتها عددا من الدعاوى، منها:

١- دعوى وقف الأعمال الجديدة:

وهي إحدى دعاوى الحيابة التي نظمها المشرع، وصورتها أن يبدأ شخص في القيام بعمل يعد لو تم تعرضا لشخص آخر في حيازته لعقار، فيرفع حائز العقار دعوى لحماية حيازته من هذا الاعتداء المحتمل، لمنع من شرع في العمل من الاستمرار فيه.

(١) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٢٢٢- د. محمود مصطفى يونس، ص ٣٧٥.

فهي إذن دعوى وقائية، الهدف منها توقي ضرر لم يقع بعد، كما لو كان لشخص حق ارتفاق بالمطل على عقار الجار، وبدأ الجار في بناء حائط إذا تم كان من شأنه أن يحرم هذا الشخص من حق المطل^(١).

٢- دعوى منع التعرض:

وهي دعوى يرفعها الحائز على من تعرض له في حيازته، وتختلف عن الدعوى السابقة في أن الحيازة هنا لم تسلب؛ بل هي باقية؛ إذ لو كانت الحيازة قد سلبت، لكان على المدعي أن يرفع دعوى استرداد الحيازة. فهي إذن في مرحلة وسط بين دعوى وقف الأعمال الجديدة وبين دعوى استرداد الحيازة^(٢).

٣- دعوى قطع النزاع (الدعوى التحريضية):

وصورة هذه الدعوى أن يشيع شخص ضد آخر مزاعم تتضمن الادعاء بحق للزاعم قبل المزعوم ضده، فيرفع هذا الأخير دعوى مطالبا خصمه بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه، وإلا حكم بعدم أحقيته فيه، وامتنع عليه مستقبلا أن يرفع دعوى للمطالبة به^(٣)، وتحقق هذه الدعوى نفس غاية الدعوى التقديرية، بإزالة الشك حول الحق أو المركز القانوني ولكن بصورة غير مباشرة. وقد اتجه القضاء المصري إلى قبولها متى كانت المزاعم جدية ولها أثر يعتد به، ولا تكون مجرد تحريضات فارغة لا نتيجة لها^(٤).

٤- الدعاوى الوقائية:

وهي الدعوى التي تهدف إلى اتخاذ تدابير وقائية أو إجراءات تحفظية، وذلك للوقاية من خطر التأخير في منح الحماية الموضوعية للحق أو المركز القانوني، وهذا ما يتوافر إذا كان الحق المطلوب حمايته مهددا بضرر محقق، ومثاله طلب الحراسة القضائية التي تهدف إلى وقاية المال المطلوب وضعه تحت الحراسة من خطر الهلاك أو الضياع في يد حائزه^(٥).

٥- الدعاوى التقديرية:

وهي الدعاوى التي يكون الغرض منها الحصول على حكم يقرر وجود حق أو واقعة قانونية أو مركز قانوني لصاحبه، دون إلزام الخصم بأداء معين، ودون أن تكون هناك منازعة بشأنه.

(١) د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٣٧٥.

(٢) أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٤١٠.

(٣) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ١٢٨.

(٤) د. أحمد مليحي، ج ١/ ١٥٠ - د. حامد أبو طالب، ص ٤١١ - د. محمود مصطفى يونس، ص ٣٧٩.

(٥) د. عبدالتواب مبارك، مرجع سابق، ص ٢٦٠.

ولكن توجد معارضة أو مجرد تشكيك حوله، وغاية ما تستهدفه الدعوى هو إزالة الشك حول الحق المدعى أو المركز القانوني.

ومن صور الدعاوى التقريرية دعوى براءة الذمة التي يرفعها المدين الذي يختلف مع دائئه حول انقضاء الدين بالوفاء أو التقادم أو غير ذلك من أسباب الانقضاء، ودعوى نفي ارتفاق، ويقصد بها الحصول على حكم في مواجهة شخص معين بأن العقار الذي يملكه المدعى ليس محملاً بحق ارتفاق آخر يملكه المدعى عليه، ودعوى صحة عقد أو بطلانه لم ينزع أحد فيه^(١).

والرأي الراجح في الفقه القانوني، هو قبول هذا النوع من الدعاوى، لأن المدعي فيها ينشد حماية قضائية لضمان استقرار مركزه القانوني وعدم تهديده، وبالتالي تتوافر له مصلحة مما يجعل حقه عرضة للنزاع^(٢).

٦- دعوى المطالبة بحق مؤجل:

استثنى القانون من شرط حلول الأجل للمطالبة بالدين، جواز المطالبة بحق لم يحل أجله في العقود المستمرة، وذلك إذا أخل المدين بتنفيذ ما حل أجله من التزامات، على أن ينفذ الحكم بالنسبة لما لم يحل أجله من التزامات عند حلول أجلها، إذ يعتبر تقصير المدين قرينة على أنه سوف يقصر فيما لم يحل أجله من التزامات. ومثال هذه الدعوى، الدعوى التي يرفعها المؤجر على المستاجر طالبا إلزامه بدفع ما حل من أجرة وما يحل منها مستقبلاً^(٣).

الطائفة الثانية: دعاوى الأدلة :

وهي دعاوى يقصد بها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، فهي لا تتعلق بحق موضوعي للمدعي، وإنما مجرد دليل، فيقصد ببعضها إقامة دليل أو المحافظة عليه، ويقصد بالبعض الآخر هدم دليل يتنافى مع الحق، وأهم هذه الدعاوى:

١- دعوى إثبات الحالة:

وهي صورة خاصة من صور الدعاوى الوقتية، والوقائية، وترمي إلى المعاينة كإجراء وقتي قبل رفع الدعوى الموضوعية التي تستخدم فيها المعاينة كدليل إثبات^(٤)، فهي تهدف إلى إثبات حالة معينة قبل أن تتغير معالمها بمضي الوقت، وذلك بطلب إجراء تحفظي عاجل الهدف منه تصوير

(١) د. عبد المنعم الشرقاوي، مرجع سابق، ص ٤٢- أستاذي د. حامد أبو طالب، ص ٤١٤.

(٢) د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٣٧٩.

(٣) م. يحيى اسماعيل، المرشد في قانون الإثبات، طبعة نادي القضاة، ص ٨٤٤.

(٤) د. أحمد هندي: أصول قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٦ م، ص ١٥٤.

حالة مادية يتعذر إثبات معالمها أو أدلتها أو معرفة أسبابها لو تركت لحين نظر الموضوع أمام القضاء العادي، وقد يضيع كل أو بعض آثارها إذا لم تثبت في حينها^(١).

ومثالها: قيام شخص بإغراق أرض جاره أو مزروعاته بالماء، فيرفع هذا الجار دعوى إثبات حالة، تمهيدا لإقامة دعوى تعويض؛ إذ قد يؤدي انتظاره حتى رفع دعوى التعويض إلى جفاف الأرض وتغير معالمها، وكذلك مالو ترك المستأجر العين المؤجرة بعد إتلافها، فيقوم المؤجر برفع دعوى إثبات حالة للعين المؤجرة، تمهيدا لرفع دعوى التعويض أمام القضاء^(٢)، وقد نصت على هذه الدعوى المادتان (١٣٣ و ١٣٤) إثبات.

٢- دعوى سماع شاهد:

وصورتها أن يخشى شخص فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض على القضاء ويحتمل عرضه عليه، كأن يكون الشاهد مريضا مرض الموت، أو مزمعا على السفر^(٣)، فأجاز له المشرع رفع الدعوى الأصلية بطلب سماع هذا الشاهد أمام القضاء المستعجل، وذلك بهدف إثبات أقواله لاتصالها الواقعة لم يثر نزاع حولها، ولكن من المحتمل إثارته مستقبلا لكي يستند إليها في دعواه الموضوعية بعد ذلك^(٤). ويجب لسماع هذه الدعوى؛ أن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود، وأن يستشعر القاضي وجه الضرورة فيها. وقد نصت على هذه الدعوى المادة (٩٦) إثبات.

٣- دعوى تحقيق الخطوط الأصلية:

وفي هذه الدعوى يجوز لمن بيده محرر عرفي مثبت لحق لم يحل أجل الوفاء به، أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر، ليقر بأنه كتبه بخطه أو موقعا عليه بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة (مادة ٤٥ إثبات)^(٥).

والأصل أن يقدم هذا المحرر العرفي كدليل إثبات عند نظر دعوى المطالبة بالحق، ولكن قوته في الإثبات تتوقف على موقف الخصم، إذ يعتبر المحرر صادرا ممن وقع ما لم ينكر ذلك صراحة (مادة ١٤ إثبات)، وهكذا يعد المحرر دليلا واهيا على الحق، ويظل حائزه مهددا بإنكار خصمه، ولهذا أجاز له القانون رفع دعوى أصلية لتقرير صحته، وتقبل هذه الدعوى ولو كان

(١) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٢٢٨.

(٢) أستاذي د. حامد ابو طالب، مرجع سابق، ص ٤١٨.

(٣) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٢٣٠.

(٤) د. محمد عبد النبي غانم، مرجع سابق، ص ١٤٢.

(٥) د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ١٥٥.

الحق الثابت بالمحرر غير مستحق الأداء، وذلك تفاديا لإنكار الخصم عند المطالبة بالحق، وتحقيقا للاستقرار بشأنه^(١).

وتحكم المحكمة في هذه الدعوى بصحة المحرر إذا حضر المدعى عليه وأقر بصحة الورقة، أو سكت، أو لم ينكر المحرر، أو ينسبه لغيره، وكذلك إذا غاب ولم يحضر (مادة ٤٦ و ٤٧ إثبات)، ذلك أن شرط صحة المحرر عدم الإنكار.

والحكم الصادر في هذه الدعوى، أيا كان مضمونه، يحوز حجية الأمر المقضي، وبالتالي تعتبر الورقة صحيحة أو غير صحيحة أيضا بالنسبة لأية خصومة مستقبلية يتمسك فيها بالورقة، وهذا الحكم قابل للاستئناف في جميع الأحوال^(٢).

٤- دعوى التزوير الأصلية:

وقد نصت على هذه الدعوى المادة (٥٩) إثبات، بقولها "يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة...".

والغرض من هذه الدعوى، هدم دليل قائم في الواقع ومدعى ببطلانه نظرا لتزويره، وهي تقوم على أساس احتمالي، فقد لا يكون الدليل موجودا، وحتى إذا كان موجودا فقد لا يقوم نزاع أصلا، وإذا نشب نزاع فقد لا يحتج به من بيده المحرر، إلا أن هناك مصلحة للمدعي تتمثل في اطمئنانه على أن هذا الدليل لن يستعمل ضده في أي وقت، ولذلك رخص له المشرع بالحق في رفع هذه الدعوى، إعمالا لنص المادة (٣) مرافعات، باعتبارها من دعاوى الاستيثاق التي أشارت إليها هذه المادة^(٣).

وتقتصر سلطة المحكمة في نظرها لهذه الدعوى على الحكم بصحة المحرر أو بتزويره دون التطرق لأصل الحق^(٤).

(١) د. وجدي راغب فهبي، مرجع سابق، ص ١٢١.

(٢) د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ١٥٦.

(٣) أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٤٢١.

(٤) نقض: الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٣٥ قضائية - جلسة ١٧/٦/١٩٦٩م.

المبحث الثالث

تقسيمات الدعاوى

تأخذ الدعاوى المدنية صفة الحماية القانونية المراد تحقيقها، أو الحقوق أو الأموال المراد حمايتها، ولما كانت الحقوق متنوع ومختلفة، منها ما هو شخصي ومنها ما هو عقاري، وقد ترد على منقول أو على عقار؛ فإن الدعاوى تنوع تبعاً لذلك، إلى: دعاوى شخصية، ودعاوى عينية، ودعاوى منقولة، ودعاوى عقارية، وهذه الأخيرة تنقسم إلى: دعاوى تحمي الحق، ودعاوى تحمي الحياة، كما قد تنقسم الدعاوى بحسب صور الحماية المطلوبة منها، إلى: دعاوى تقريرية، ودعاوى إلزام، ودعاوى منسئة. ومن ثم فالدعاوى تنقسم إلى عدة أقسام وفقاً لعدة اعتبارات:

أولاً: تقسيم الدعاوى باعتبار صور الحماية القضائية:

تنقسم الدعاوى وفقاً لهذا التقسيم إلى:

١- الدعاوى التقريرية:

وهي الدعاوى التي ينحصر أثرها المباشر في الحصول على حكم يؤكد أو ينفي وجود حق أو مركز قانوني للمدعي، أو في ثبوت أو عدم ثبوت واقعة قانونية معينة^(١)، فلا يطلب المدعي فيها إلزام المدعى عليه بأداء معين، أو إحداث تغيير في الحق أو المركز الموضوعي.

والدعاوى التقريرية تنقسم بدورها إلى قسمين، دعاوى تقريرية إيجابية، ودعاوى تقريرية سلبية. ويكون الغرض من الأولى تقرير وجود حق أو مركز قانوني معين أو واقعة قانونية معينة، كدعوى إثبات الجنسية، أو البنوة الشرعية، أو قيام علاقة الزوجية، أو دعوى صحة عقد. أما الثانية فيهدف الخصم من ورائها إنكار حق أو مركز قانوني لخصمه، كدعوى براءة الذمة التي يرفعها المدين في مواجهة دائنه، ودعوى نفي حق ارتفاق، أو دعوى التزوير الأصلية. وهذه الدعاوى وقائية موضوعية بحتة، ترمي إلى الحصول على حكم موضوعي، يحوز حجية الأمر المقضي^(٢).

٢- دعاوى الإلزام:

وهي التي يكون غرضها إلزام المدعى عليه بأداء معين امتنع عن أدائه، وهي هي أكثر الدعاوى شيوعاً في الحياة العملية، ولا يشترط لقبولها أكثر مما قيل بالنسبة لشروط الدعوى بصفة عامة^(٣). والحكم الصادر في هذه الدعاوى يكون قابلاً للتنفيذ الجبري.

(١) د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٤٠٦.

(٢) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ١٣٢.

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ١٤٥ وما بعدها.

وهي دعوى موضوعية ترمي إلى الحصول على حكم موضوعي يحوز حجية الأمر المقضي، وترمي أيضا إلى تحقيق وظيفة تنفيذية: إذ تستهدف الحصول على سند تنفيذي في صورة حكم إلزام^(١). ومثالها: الإلزام بأداء معين، كدفع دين، أو تسليم عقار، أو إخلاء عين مؤجرة، أو بناء حائط أو هدمه.

٣- الدعوى المنشئة:

وهي الدعوى التي يكون الغرض منها الحصول على حكم يحدث تغييرا في حق أو مركز قانوني معين، سواء بإنشاءه، أو تعديله، أو إنهائه^(٢). وتقوم هذه الدعوى كالدعوى التقريرية بمهمة تقريرية. ولكن الفرق بينهما، هو في الحق محل التقرير.

إذ يتميز الحق في الدعوى المنشئة بأنه حق إرادي، وهو الحق في إحداث تغيير قانوني، ويترتب على ذلك حدوث تغيير في مركز قانوني سابق، وذلك على عكس الدعوى التقريرية، والتي يكون غرضها مجرد التقرير دون أي تغيير في مركز سابق^(٣).

وهذه الدعوى أيضا دعوى موضوعية، ترمي إلى الحصول على حكم موضوعي يحوز حجية الأمر المقضي.

ثانيا: تقسيم الدعوى باعتبار طبيعة الحقوق التي تحميها:

تنقسم الدعوى بحسب طبيعة الحق الذي تحميه إلى دعاوى شخصية ودعاوى عينية، ودعاوى مختلطة، وذلك على النحو الآتي:

١- الدعوى الشخصية:

وهي الدعوى التي تستند إلى حق شخصي، ناشئ عن دين أو التزام شخصي أيا ما كان مصدره، أي سواء نشأ عن عقد أو فعل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص في القانون^(٤).

ومثالها: الدعوى التي يرفعها الدائن على مدينه للمطالبة بالدين، والدعوى التي يرفعها المؤجر على المستاجر للمطالبة بالأجرة، والدعوى التي يرفعها البائع على المشتري للمطالبة بالثمن. إلى غير ذلك من الدعوى التي لا تقع تحت حصر.

والغرض من الدعوى الشخصية، حماية الحق الشخصي لرافعها بتقريره في مواجهة الملتزم به، أو إلزامه بالوفاء به^(٥).

(١) د. وجدي راغب فهي، المرجع السابق، ص ١٣٢.

(٢) د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٤١٠.

(٣) د. فتحي والي، المرجع السابق، ص ١٤١.

(٤) أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٤٢٣.

(٥) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٢٣٦.

٢- الدعاوى العينية:

فهي التي تستند إلى حق عيني، كدعوى الملكية ودعوى تقرير حق ارتفاق أو انتفاع أو دعوى الرهن. وتهدف هذه الدعاوى إلى حماية الحق العيني سواء بتقريره أو بنفيه، وهذه الدعاوى محددة على سبيل الحصر، شأنها شأن الحقوق العينية التي تحميها^(١).

٣- الدعاوى المختلطة:

وهي التي تستند إلى الحقين معا (الشخصي والعيني)، ومثالها الدعوى التي يرفعها مشتر العقار بعقد مسجل يطلب فيها تسليم العقار المبيع، فهي شخصية لأنها تستند إلى حق شخصي للمشتري في مواجهة البائع يلزمه بتسليم العقار المبيع، وعينية لأنها تستند إلى حق الملكية، وهو حق عيني.

أهمية تقسيم الدعاوى إلى شخصية وعينية:

ترجع أهمية تقسيم الدعاوى إلى دعاوى شخصية ودعاوى عينية، إلى تحديد من توجه إليه الدعوى؛ إذ الدعوى الشخصية لا ترفع إلا على الملتزم بالحق الشخصي، لكون الحق الشخصي رابطة بين طرفين، أما الدعوى العينية، فترفع على أي شخص تؤول إليه العين، لأن الحق العيني ينصب على عين بذاتها، ومن ثم يتبعها أينما كانت^(٢).

ثالثا: تقسيم الدعاوى باعتبار طبيعة الشيء المطلوب بها:

تنقسم الدعاوى باعتبار طبيعة المال الذي تحميه، إلى دعاوى منقولة ودعاوى عقارية:

١- الدعاوى المنقولة:

وهي التي يكون الغرض منها حماية مال منقول أو حق عيني وارد عليه، كالدعوى التي يرفعها مالك المنقول باسترداده.

٢- الدعاوى العقارية:

وهي التي يكون محلها حق عيني عقاري، أو يكون محل الحق فيها عقارا، كالدعوى التي يرفعها مالك العقار على من اغتصبه.

تداخل التقسيمين السابقين:

يتداخل التقسيمان السابقان (ثانيا وثالثا)، فتكون الدعوى الشخصية منقولة أو عقارية، وتكون الدعوى العينية منقولة أو عقارية، وذلك على النحو الآتي:

(١) د. عبدالتواب مبارك، مرجع سابق، ص ٢٦٦.

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٢٣٧.

- ١- الدعوى الشخصية المنقولة: وهي الدعوى التي تستند إلى حق شخصي ويكون الغرض منها الحصول على مال منقول، كدعوى الدائن ضد المدين بمبلغ من النقود، وكالدعوى التي ترفع بتسليم سيارة^(١).
- ٢- الدعوى الشخصية العقارية: وهي التي تستند إلى حق شخصي يرد على عقار، كدعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار.
- ٣- الدعوى العينية المنقولة: وهي التي تستند إلى حق عيني على منقول، كدعوى المطالبة بملكية منقول.
- ٤- الدعوى العينية العقارية: وهي التي تستند إلى حق عيني على عقار، كدعوى استحقاق العقار، أو دعوى الارتفاق، أو دعاوى الحيازة.

أهمية التقسيم السابق:

تبدو أهمية تقسيم الدعاوى إلى شخصية وعينية، ومنقولة وعقارية، في تحديد الاختصاص المحلي بنظر الدعوى، فالدعوى المنقولة -شخصية كانت أو عقارية- تختص بها محكمة موطن المدعى عليه، أما الدعوى العينية العقارية، فتختص بها محليا، محكمة موقع العقار، في حين تختص بالدعاوى الشخصية العقارية، محكمة موطن المدعى عليه، أو محكمة موقع العقار.

دعاوى تخرج عن تقسيم الدعاوى إلى شخصية وعينية، أو منقولة وعقارية:

يخرج عن التقسيم السابق الدعاوى التي لا تمس حقوقا مالية، كالدعاوى المتعلقة بحالة الإنسان، ومثالها: دعوى النسب ودعوى الحجر ودعوى الجنسية، وغيرها مما يتعلق بشخصية الإنسان، وتختص بها محليا محكمة موطن المدعى عليه.

دعاوى الحق ودعاوى الحيازة:

تنقسم الدعاوى العينية العقارية إلى دعاوى تحمي الحق، ودعاوى تحمي الحيازة، والأولى تتعلق بحق عيني على عقار، كحق الملكية أو الانتفاع أو الارتفاق، أما الثانية، فهي التي يقصد بها حماية حيازة الحق العيني الواقعي، وهو وضع اليد، وهذه الدعاوى هي: دعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة.

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٤٣٧.

الباب الثاني

إجراءات التقاضي بوسيلة الدعوى

إذا كان حق الالتجاء إلى القضاء هو حق دستوري - كما سبق القول - فإنه أيضاً مبدأ أساسياً من المبادئ التي يقوم عليها ويتناولها بالتنظيم قانون المرافعات، ذلك أن هذا القانون هو الذي يبين كيفية اللجوء إلى القضاء وما يجب على الخصوم والمحكمة اتباعه منذ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، وكيفية إصدار الحكم وطرق الطعن فيه، باعتباره مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القضاء المدني، وتحدد اختصاصه وإجراءات التقاضي أمامه، فهو أداة تنظيم القضاء والطريق إلى إعمال القوانين الموضوعية التي تنظم الحقوق والواجبات من خلال وضعه لقواعد دقيقة ومحكمة تنظم الإجراءات وبما يحقق السلام الاجتماعي^(١).

وباعتبار قانون المرافعات (قانون القضاء المدني) هو الذي يتولى بالتنظيم القانوني الدقيق، الإجراءات التي يجب اتباعها في الخصومة منذ رفع الدعوى إلى القضاء وحتى صدور الحكم فيها، فإنه يتناول بالتنظيم ليس فقط كيفية هذه الإجراءات ومواعيدها وانقضاء الحق فيها وبطلانها، وأثارها، وغير ذلك، وإنما ينظم أيضاً الوسائل المثبتة لاتخاذ هذه الإجراءات والبيانات التي يجب أن تتضمنها أوراق المرافعات.

والمشروع في تنظيمه لإجراءات الخصومة ولكافة المراحل التي تمر بها حرص في المقام الأول أن تتم جميع هذه الإجراءات في إطار من الشكلية التي تبدو أمراً ضرورياً لاستتباب الأمن والنظام في المجتمع، ولتحقيق قضاء عادل للأشخاص، بتمكينهم من الحصول على الحماية القضائية بإجراءات موحدة وأمام هيئات قضائية موحدة كذلك، وذلك ليس فقط لضمان تحقق هذه الإجراءات من خلال اتباع الشكل المقرر قانوناً، وإنما لأن الإجراءات المنضبطة والثابتة تحول دون فوضى القضاء وسوء نية الخصوم، وهذا يفسر قول البعض أن الشكل توأم الحرية باعتباره عدو التحكم^(٢).

فإذا كان القضاء هو السلطة المختصة بتطبيق أحكام القانون على النزاع المعروض عليه، وكانت الدعوى هي وسيلة الأفراد في الالتجاء إلى القضاء، وكان قانون المرافعات هو الذي ينظم كيفية مباشرة الخصومة والإجراءات فيها، فإن رفع الدعوى إلى القضاء بالطرق المحددة قانوناً

(١) د. أمينة مصطفى النمر، مرجع سابق، ص ٤٨ - د. فتحي والي، مرجع سابق، ص ٥ - د. عيد محمد القصاص: قانون المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الأول ١٩٩٨ م، ص ٦.

(٢) د. عاشور مبارك: الوسيط في قانون القضاء المصري، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، الكتاب الأول، مكتبة الجلاء الجديدة، الطبعة الأولى ١٩٩٦ م، ص ٢٥.

ينشئ خصومة قضائية يجب الفصل فيها وإنزال حكم القانون على الوقائع محل مجادلة الخصوم فيها، ولذا كان لا بد من وجود تنظيم قانوني دقيق لهذه الخصومة يبين سيرها، وإجراءاتها، وانتهائها، وقد تولى قانون المرافعات -كما سبق القول- تنظيم هذه الإجراءات بشكل دقيق يحقق الهدف من إنشاء مرفق القضاء ويحول دون تلاعب الخصوم بالإجراءات، ومما ظلتهم في الحق بوسائل إجرائية قد تحول دون تطبيق أحكام القانون.

والخصومة ظاهرة مركبة من حيث تكوينها، فهي عبارة عن مجموعة من الأعمال القانونية التي تتخذ أمام القضاء، الإجراء الأول فيها هو المطالبة القضائية، ثم تتابع إجراءاتها حتى تصل إلى نهايتها الطبيعية بصدور حكم في موضوعها، وقد تنقضي أحياناً دون صدور هذا الحكم لأسباب مختلفة كالصلح أو سقوط الخصومة^(١)، وتعتبر الخصومة وحدة فنية ترتبط بجميع إجراءاتها، وتتميز بالحركة والسير نحو تحقيق الغاية المرغوبة، وهي حصول صاحب الحق على الحماية المطلوبة بإيجاد حل للنزاع الذي يعرقل تنفيذ القانون^(٢).

وعلى الرغم من الأهمية العملية والقانونية للشكلية في إجراءات الخصومة، حيث يستطيع المشرع بموجها وضع تنظيم دقيق ومنضبط للإجراءات يحول دون فوضى القضاء وسوء نية الخصوم، إلا أنه يتعين عدم المغالاة فيها، حتى لا تؤدي إلى تعقيد طريق الحصول على الحماية القضائية بما قد يدفع الأشخاص إلى العزوف عن الالتجاء إلى القضاء، وقد راعى المشرع ذلك في قانون المرافعات فعمل على التخفيف من الشكلية، والحد من الحكم بالبطان جزاء مخالفتها، وذلك بالنص على عدة وسائل تحول دون بطلان الإجراءات^(٣) وتؤدي إلى تذليل العقبات الإجرائية في الخصومة.

ويقتضي الحديث عن إجراءات التقاضي، أن نبين أولاً إجراءات رفع الدعوى وقيدها وانعقادها، ثم نبين إجراءات نظر الدعوى، وعوارض الخصومة، وذلك في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: رفع الدعوى وقيدها وانعقاد الخصومة.

الفصل الثاني: إجراءات نظر الدعوى.

الفصل الثالث: عوارض الخصومة.

(١) د. أحمد هندي: قانون المرافعات المدنية والتجارية، الخصومة والحكم والطعن، دار الجامعة الجديدة للنشر، ١٩٩٥م، ج ٢/٥.

(٢) د. إبراهيم نجيب سعد: القانون القضائي الخاص، ج ٢، منشأة المعارف، (د.ت) ص ٧.

(٣) من هذه الوسائل: فكرة الغاية من الإجراء، وعدم التمسك بالبطان إلا ممن شرع لمصلحته، والتنازل عن البطان المقرر للمصلحة الخاصة، وتصحيح البطان، وتحول الإجراء الباطل، أو انتقاصه، والإحالة إلى المحكمة المختصة.

الفصل الأول

رفع الدعوى وقيدتها وانعقاد الخصومة

يقتضي الحديث عن رفع الدعوى وقيدتها وانعقادها أن نقف أولاً على فكرة الإجراء القضائي - باعتباره الوحدة التي تتكون من مجموعها الخصومة القضائية- وأهمية الشكلية الإجرائية، ثم نبين بعد ذلك إجراءات رفع الدعوى وإجراءات قيدتها، وكيفية انعقاد الخصومة بين طرفيها.

المبحث الأول

فكرة الإجراء القضائي وأهمية الشكلية الإجرائية

المطلب الأول

الإجراء القضائي

استعمل المشرع المصري تعبير الإجراء بالمفرد في أكثر من موضع في قانون المرافعات (كالمواد: ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٥، ٧، ٢٠٥، وغيرها)، واستعمل تعبير الإجراءات بالجمع في العديد من المواد الأخرى (كالمواد: ١٩، ١٠، ٧٥ وغيرها). ومن ثم يلزم الوقوف على تحديد المقصود بالإجراء القضائي. ويعبر بعض الفقه عن الإجراء القضائي بالعمل الإجرائي^(١) والبعض الآخر يعبر بتعبير الإجراء القضائي. ونتفق مع رأي بعض الفقه^(٢) في أن الاختلاف بين الاصطلاحين مجرد اختلاف شكلي. فالعمل الإجرائي عبارة عن العمل الذي يرتب عليه القانون مباشرة أثراً إجرائياً ويكون جزءاً من خصومة^(٣). والإجراء القضائي هو كل مسلك إيجابي من جانب الخصوم أو من جانب المحكمة، في رفع الدعوى إلى القضاء أو المرافعة فيها أو تحقيقها أو الحكم فيها^(٤)، أو هو المسلك الإيجابي الذي يكون جزءاً من مجموعة الإجراءات ويترتب أثراً إجرائياً مباشراً فيها^(٥).

وباعتبار الخصومة مجموعة من الإجراءات، فإن الإجراء القضائي هو الوحدة التي تتكون منها هذه الخصومة، وإجراءات الخصومة مختلفة ومتنوعة، منها ما يقوم به الخصوم كتقديم طلب أو دفع أو مذكرة، ومنها ما يقوم به غيرهم كشهادة الشهود أو تقرير الخبير، ومنها ما يقوم به

(١) يرجع أول استعمال لتعبير (العمل الإجرائي) في الفقه القانوني العربي إلى أ.د/ فتحي والي في رسالته عن (نظرية البطلان) عام ١٩٥٨، وتبعه في ذلك بعض الفقه القانوني، في حين يؤثر البعض استعمال اصطلاح الإجراء القضائي.

(٢) د. الكوني على أعبوده، مرجع سابق، ص ١٣١.

(٣) د. فتحي والي، نظرية البطلان، مرجع سابق، ص ٨١، وله أيضاً: الوسيط، ص ٤١٢.

(٤) د. أحمد مسلم: أصول المرافعات، مطابع دار الكتاب العربي، ١٩٦١م، ص ٣٩٣.

(٥) د. وجدي راغب فههي، مرجع سابق، ص ٣٠٥.

أعوان القاضي كالإعلان القضائي، ومنها ما يقوم به القاضي كالحكم القضائي. وهذه الإجراءات على تنوعها واختلافها تختلف أحكامها من حيث الشروط والآثار والجزاء المترتب على مخالفتها.

ويجب لاعتبار عمل ما عملاً إجرائياً^(١): توافر ثلاثة أمور، "الأول أن يكون عملاً قانونياً، فلا تعتبر أعمال الذكاء المحضه مثل قيام القاضي بدراسة القضية أعمالاً إجرائية، وكذلك لا تعتبر الأعمال الممهدة للقيام بأعمال قانونية في الخصومة أعمالاً إجرائية، ومثالها الحضور أمام القضاء. والثاني أن يترتب عليه مباشرة آثار إجرائية، والآخر الإجرائي هو الأثر المتعلق بالخصومة، سواء ببديها أو بالمشاركة في سيرها أو تعديلها أو إنهاؤها، ويجب أن يكون هذا الأثر مباشراً، ولذلك فإنه لا يعتبر عملاً إجرائياً الزول عن الحق الموضوعي أو الزول عن الدعوى، ذلك أن الأثر الإجرائي المترتب على أي منهما - وهو انتهاء الخصومة، ليس أثراً مباشراً للعمل، وإنما يترتب كنتيجة لأثر موضوعي هو زوال الحق أو زوال الدعوى. والثالث أن يكون جزءاً من خصومة، ولهذا لا تعتبر أعمالاً إجرائية تلك التي تكون خارج الخصومة سواء تمت قبل بدأ الخصومة أو أثنائها، ولو ترتب عليها آثار إجرائية، ولهذا لا يعتبر عملاً إجرائياً: طلب إحدى الوثائق من إحدى الهيئات الإدارية لتقديمها في الخصومة".

وللعمل الإجرائي - شأنه شأن أي عمل قانوني - مقتضيات موضوعية وهي: صلاحية القيام بالعمل الإجرائي، وإرادة القيام بالعمل الإجرائي، ومحل العمل الإجرائي.

المطلب الثاني

الشكلية الإجرائية في قانون المرافعات

الفرع الأول

ماهية الشكلية في قانون المرافعات

أولاً: مفهوم الشكل في قانون المرافعات:

يختلف قانون المرافعات عن القانون المدني في أن الشكل في الأخير لا يعد عنصراً من عناصر العمل أو التصرف القانوني، بحيث يكون للأشخاص الحرية في التعبير عن إرادتهم بالكيفية وعلى النحو الذي يروق لهم، لأن القاعدة في هذا القانون هي مبدأ الرضائية، بمعنى أن المشرع لا يتدخل في طريقة تكوين إرادة الأفراد. والأمر على خلاف ذلك في قانون المرافعات، ذلك أن من أهم السمات المميزة لهذا القانون أنه قانون شكلي ينظم ويحدد الإجراءات والأشكال التي يتعين

(١) د. فتحي والي: نظرية البطلان، دار الطباعة الحديثة، ١٩٩٧م، ص ٨١.

اتخاذها ومراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية وعند الفصل في المنازعات وعند إصدار الأحكام وغيرها من السندات التنفيذية، فالمشرع في قانون المرافعات لم يترك للخصوم أو للقاضي الحرية في اختيار الوسيلة التي يتم بها العمل الإجرائي أو الزمن أو الميعاد أو المكان الذي يجب اتخاذه فيه، بل يقوم بنفسه وفي أغلب الحالات بتحديد الشكل الذي يتم فيه العمل والبيانات التي يتضمنها والوقت والميعاد والمكان الذي يجب القيام به خلاله، وهذه الشكلية التي يتصف بها قانون المرافعات تحقق ضمانات كثيرة للمتقاضين كما أنها تعمل على حسن سير القضاء^(١).

والقاعدة العامة بالنسبة للأعمال الإجرائية هي أن الإجراء القضائي عمل شكلي، بحيث لا يترك القانون للقائم به حرية اختيار وسيلة القيام به، بل يحدد له القانون هذه الوسيلة ويفرضها عليه ولذا يعتبر الشكل عنصراً من أهم عناصر الإجراء القضائي^(٢)؛ فالعمل القانوني أياً كان ليس إلا حركة أو تغييراً في العالم الخارجي، بحيث لا يمكن الكلام عنه إذا لم يظهر للعالم الخارجي^(٣)، وعلى ذلك فالشكل هو وسيلة العمل لإحداث آثاره، ويتركب من عنصرين: الأول نشاط يقوم به الشخص، والثاني حدث أو نتيجة لهذا النشاط، وكل نشاط يؤدي إلى حدث وكل حدث يفترض نشاط أو حركة أدت إليه^(٤).

ويمكن تعريف الشكلية بأنها الحركة أو التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي. ويرى البعض أن الشكل بمعناه الضيق هو الوسيلة التي يتحقق بها الحدث أو المضمون^(٥). والمشرع في تحديده للوقائع القانونية، قد يحددها في مضمونها فقط وهذا هو الشائع، وقد لا يقتصر على تحديد مضمون العمل بل يمتد إلى أبعد من ذلك فيحدد وسيلة تحقيق مضمون العمل، وإذا حدد المشرع وسيلة العمل تحديداً جامداً بحيث لا يترك حرية للقائم بالعمل إزائها فإن الشكل يكون جامداً، أما إذا اقتصر القانون على تحديد مضمون العمل أو الحدث الذي يتولد من هذا العمل، دون أن يتعرض للوسيلة، فإن الشخص يكون حراً في اختيار الوسيلة

(١) د. إبراهيم أبو النجا: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للبيبي: النظرية العامة للمرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة الأولى ١٩٩٨م، ص ١١ - الأستاذ د. الأنصاري حسن النيداني: قانون المرافعات، ج ١/١ - د. أمينة النمر، مرجع سابق، ص ١٩ - د. عاشور مبروك، مرجع سابق، ص ٢٥ - د. نبيل إسماعيل عمر: إعلان الأوراق القضائية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى ١٩٨١م، ص ٢١.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٤٢١ - د. وجدي راغب فهي، سابق، ص ٣١٥.

(٣) د. فتحي والي: نظرية البطلان، دار الطباعة الحديثة، ط ٢ ١٩٩٧، ص ١٥٨.

(٤) د. فتحي والي، نظرية البطلان، ص ١٥٨ - د. نبيل عمر، إعلان الأوراق القضائية، ص ٢٢.

(٥) د. نبيل إسماعيل عمر، إعلان الأوراق القضائية، ص ٢٢.

التي تؤدي إليه، وهنا يقال بأن الشكل حر^(١)، فالشكلية تختلف جمودا ومرونة من عمل إلى آخر، وأحيانا يبالغ المشرع في الشكلية كما هو الحال بالنسبة للإعلانات القضائية، وأحيانا يترك تحديد شكل العمل لقواعد الخبرة ولما يقتضيه مضمون العمل^(٢). وفي الحالات التي لم يحدد القانون فيها شكلا معيناً للإجراء؛ ينبغي أن يتخذ في الشكل الأكثر ملاءمة لتحقيق وظيفته^(٣).

والشكل قد يكون عنصرا من عناصر العمل الإجرائي، كما قد يكون ظرفا يجب وجوده خارج العمل لكي ينتج العمل آثاره القانونية، ويتضمن الشكل كعنصر للعمل وجوب تمام العمل كتابة ووجوب أن تتضمن الورقة بيانات معينة، أما باعتباره ظرفا للعمل فإن الشكل هنا يقف خارج العمل الإجرائي ولكن يجب وجوده لكي ينتج العمل آثاره القانونية، وفي هذه الحالة قد يتصل الشكل بمكان العمل، كوجوب تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه، أو وجوب أن يتم الحجز في مكان المنقولات المحجوزة، كما قد يتصل بزمان العمل، والزمن كشكل للعمل قد يكون زمنا مجردا بغير نظر إلى واقعة سابقة أو لاحقة كوجوب أن يتم الإعلان بين الساعة السابعة صباحا والثامنة مساء، وقد يكون الزمن هو يوما معيناً كوجوب إجراء المرافعة في أول جلسة، وقد يتحدد الزمن بميعاد أي بفترة بين لحظتين، لحظة البدء ولحظة الانتهاء وقد يكون ميعادا يجب أن ينقضي قبل إمكان القيام بالعمل، وقد يكون ميعادا يجب أن يتم العمل قبل بدئه، وقد يكون ميعادا يجب أن يتم العمل خلاله في عنصر الزمن، وأيضا ما ينص عليه القانون من ترتيب زمن معين بين الأعمال الإجرائية^(٤).

ثانيا: وظيفة الشكل في قانون المرافعات^(٥):

الشكلية في العمل الإجرائي مقررة لصحة العمل لا لإثباته، ولهذا فإنه إذا كان العمل معيبا بعيب شكلي فلا يجوز تكملة هذا النقص عن طريق الإثبات، فإذا كانت صحيفة الدعوى - مثلا - معيبة بعيب شكلي فإنه لا يجوز تكملة هذا النقص عن طريق الإثبات، ولا يجوز إثبات أن صحيفة الدعوى التي ينقصها التاريخ قد أعلنت في الواقع في يوم معين^(٦)، لأنه لا يحل محل الشكل الذي يوجب القانون اتباعه أي طريق من طرق الإثبات كالبينة أو القرائن أو حتى وجوه

(١) د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ١٦٠.

(٢) د. فتحي والي (الوسيط في قانون القضاء المدني)، مرجع سابق، ص ٤٢١.

(٣) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٣١٥.

(٤) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بشأن المواعيد.

(٥) د. نبيل إسماعيل عمر، إعلان الأوراق القضائية، مرجع سابق، ص ٢٥.

(٦) د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ١٦٦.

الإثبات الأخرى بما فيها توجيه اليمين الحاسمة أو الإقرار، لأن الشكلية تقتضي أن يكون المحرر جامعا لكل ما هو مطلوب قانونا فيه من بيانات وخطوات يستوجبها القانون كإجراء جوهري^(١).

فالشكلية في قانون المرافعات تؤدي دورها على أكمل وجه من خلال التنظيم القانوني للخصومة، لأن الخصومة باعتبارها وسيلة قانونية لتحقيق غاية معينة هي تطبيق القانون وباعتبارها تتكون من أعمال قانونية مختلفة، لا يمكن البحث في كل عمل منها عن عنصر الإرادة لمعرفة طبيعة العمل المراد القيام به، لأن ذلك سيؤدي إلى عرقلة السير في الخصومة وعدم تحقيق الغاية منها بالسرعة اللازمة، ولذلك كان من الضروري تحديد شكل خاص لكل عمل إجرائي يعتبر احترامه عنوانا للعمل المراد وهاديا إلى تحديده من جانب القاضي والخصوم^(٢) "وداخل التنظيم القانوني للخصومة وإعمالا للمبادئ العامة التي تسيطر عليها وأهمها مبدأ المساواة بين الخصوم ومنع القاضي من التعسف، فإن القانون لا يكتفى بفرض تنظيم معين للخصومة بل يوجب أيضا أن يتم كل عمل إجرائي وفقا لشكل معين، بمعنى أن القانون يشيد للخصومة تنظيما شكليا"^(٣).

ثالثا: أهمية الشكل في قانون المرافعات ووجوب احترامه^(٤):

يتمتع الشكل في قانون المرافعات بأهمية بالغة باعتباره وسيلة تنظيمية وضرورية لحسن سير الإدارة القضائية كما أنه ضمانات مهمة ضد أهواء الخصوم وضد القرارات التحكيمية، ذلك أن الشكلية تحقق ضمانات كثيرة للمتقاضين لأن بيان الإجراءات التي يلزم اتباعها والمواعيد الثابتة التي يلزم مراعاتها عند مباشرة الإجراءات، يجعل الخصم على علم مسبق بما يوجهه إليه خصمه فيكون في مأمن من المفاجآت، ويعطي للخصوم فرصة للاستعداد والتروي والتدبر، كما تعمل الشكلية على حسن سير القضاء وتجعل المتقاضين في مأمن من تحكم القضاة، فلا تترك لهم أمر التقاضي يمارسونه وفقا لمطلق تقديرهم^(٥).

ونظرا لهذه الأهمية فإن القانون يفرض على الخصوم الشكل الذي يتعين عليهم اتباعه عند اتخاذ الإجراءات القضائية ولا يترك لهم حرية كبيرة في هذا الصدد، فلا يعتد بالإجراء إذا لم يتم في الشكل المحدد قانونا، وتبدو مظاهر الشكلية في اشتراط الكتابة في الإجراءات، وقد لا يكتفى

(١) المستشار. محمد نصر الدين: أوراق المحضرين، ١٩٨٩م، ص ٦.

(٢) د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ١٨٢.

(٣) د. نبيل إسماعيل عمر، إعلان الأوراق القضائية، مرجع سابق، ص ٢٦.

(٤) د. إبراهيم أمين النفاوي: الإخلال بالواجب الإجرائي، ص ٥٦.

(٥) د. إبراهيم أبو النجا، مرجع سابق، ص ١١-١٢.

القانون بذلك وإنما يحدد بيانات معينة يجب أن يحتوي عليها الإجراء، كما يشترط أن تتم الإجراءات بترتيب معين، كما قد يعين المكان والزمان اللازمين لاتخاذ الإجراء، ومن أجل ضمان الاحترام الواجب لهذا الشكل فإن المشرع لا يعتد بالإجراء إذا جاء مخالفاً له^(١)، بحيث يترتب البطلان في العديد من الحالات التي يتم فيها مخالفة الشكل، كما يؤدي عدم مراعاة الشكل إلى سقوط الحق في اتخاذ الإجراء كسقوط الحق في تقديم الدفوع الشكلية (مادة ١٠٨ مرافعات)، وسقوط الحق في تقديم طلب الرد (مادة ١٥١ مرافعات)، وسقوط الحق في الطعن (مادة ٢١٥ مرافعات)، كما قد يؤدي إلى اعتبار الإجراء كأن لم يكن (مادة ٢٣٠ مرافعات)^(٢).

رابعاً: مرونة الشكل في قانون المرافعات^(٣):

على الرغم من اهتمام المشرع بالشكل في قانون المرافعات؛ إلا أنه لم يتبنى شكلاً جامداً، وإنما الملاحظ في هذا الشأن هو مرونة الشكل في قانون المرافعات، وتبدو مرونة الشكل في أن المشرع لم يشترط ألفاظاً معينة في البيانات أو الأشكال الإجرائية، كما أنه لا يشترط أن تأتي البيانات بترتيب معين، ومنها أن للمحكمة أن تحيل في بيانها لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم فيها ودفوعهم وأوجه دفاعهم إلى محاضر الجلسات.

كما يبدو حرص المشرع في عدم المغالاة في الشكلية والحد منها ومن حالات البطلان المترتبة عليها، فيما قرره في قانون المرافعات من فكرة الغاية من الإجراء أو الشكل، وفكرة تفادي البطلان، وفكرة انتقاص الإجراء الباطل وتحوله، وفكرة التنازل عن البطلان المقرر لمصلحة الخصوم، وفكرة الإحالة في الحكم بعدم الاختصاص، ثم إلى فكرة القرائن كوسيلة يستنبط منها القيام بالإجراء أو للتخفيف من الشكلية، أو لاعتبار أن هناك قرينة على صحة الإجراءات^(٤).

(١) د. إبراهيم أمين النفيماوي، الإخلال بالواجب الإجرائي، مرجع سابق، ص ٥٦-٥٧.

(٢) المرجع السابق، ص ٩٢.

(٣) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: قانون المرافعات، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ١١.

(٤) أنظر للمؤلف: نظرية القرائن في قانون المرافعات، مرجع سابق، ج ١/٢٤٢.

الفرع الثاني

مظاهر الشكلية في قانون المرافعات

تبدو مظاهر الشكلية في قانون المرافعات في مظهرين أساسيين، الأول، ضرورة كتابة الإجراء، حيث يتقيد القائم بالإجراء بضرورة كتابته، وهذا يعنى أن صحة الإجراء تقتضي أن تحتوية ورقة مكتوبة (وتسمى هذه الأوراق أوراق المرافعات)، والثاني ضرورة أن تتم هذه الإجراءات خلال المواعيد التي حددها القانون تجنباً لإطالة أمد النزاع^(١).

الفصل الأول

أوراق المرافعات

أوراق المرافعات أوراق شكلية، بمعنى أنها يجب أن تثبت بالكتابة وأن تراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون لها، وأن تشتمل على البيانات التي أوجب ذكرها فيها، فلا يحل محل الشكل الذي أوجبه القانون اتباع أي طريق آخر من طرق الإثبات، بحيث تقتضي الشكلية أن تكون الورقة جامعة لكل ما هو مطلوب فيها قانوناً من بيانات وخطوات يستوجبها القانون كإجراء جوهري.

فصحيفة الدعوى -مثلاً- هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم بطلانها فإنه ينبغي على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة عليها وزوال جميع الآثار التي تترتب على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد، ولذلك يوجب المشرع أن تشتمل هذه الصحيفة على بيانات محددة ورد النص عليها في قانون المرافعات، وهذه البيانات هي التي تشكل بنیان الصحيفة وجوهرها، فلا يجوز خلوها منها. كما أن ورقة الإعلان، ونظراً للدور المهم الذي تؤديه في انعقاد الخصومة والعلم بما يدور في جلسات نظرها، يوجب المشرع أن تشتمل على مجموعة من البيانات التي يؤدي كل منها إلى تحقيق غاية معينة استهدفها المشرع مراعاة لمصلحة الخصوم ولضمان حسن سير العدالة. كما أن الحكم باعتباره الغاية الطبيعية التي يهدف إلى تحقيقها كل خصم، فإن المشرع أحاط إصداره بضمانات عديدة من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، قاصداً بذلك حماية حقوق الخصوم ورعاية مركز القاضي بما يبرئ له الظروف المناسبة لإصدار حكمه طبقاً للقانون ولضميره، فأوجب على القاضي أن يضمن حكمه بيانات محددة تكفل تحقيق الحماية القضائية التي يسعى إليها الخصوم، وتزيل كل لبس أو غموض حول المحكوم له أو عليه والمحكمة التي أصدرت الحكم ومنطوقه وأسبابه.

(١) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٤٧٨- د. عبدالتواب مبارك، مرجع سابق، ص ٣١٣.

وتعد الكتابة شرطاً لازماً لصحة معظم الإجراءات القضائية وليس لإثباتها، بحيث إذا لم يكتب الإجراء في الشكل الذي يتطلبه المشرع فإنه يكون باطلاً، ولا يغني عن ذلك إثباته بأي طريق آخر، فالمشرع يشترط كشكل للعمل أن يتم كتابة، بحيث لا يعتبر صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً. فالمطالبة القضائية تتم عن طريق ورقة مكتوبة تتضمن بيانات معينة تسمى صحيفة الدعوى، وإعلام الخصوم بالإجراءات ومواعيدها يتم عن طريق ورقة مكتوبة تتضمن بيانات معينة تسمى ورقة الإعلان، والحكم الصادر من القاضي في النزاع المعروض عليه يتم من خلال ورقة مكتوبة تتضمن بيانات معينة تسمى ورقة الحكم، والطعن في هذا الحكم يتم عن طريق ورقة مكتوبة تتضمن بيانات معينة تسمى صحيفة الطعن، وهذه الأوراق وغيرها تسمى أوراق المرافعات وجميعها يجب أن تتم كتابة في الشكل الذي أوجبه المشرع متضمنة بيانات محددة.

وتتنوع أوراق المرافعات بتنوع الإجراءات، فبعض هذه الأوراق يحررها القاضي، كالأحكام والأوامر، وبعضها يحررها الخصوم أو ممثلوهم كصحف الدعاوى والطعون، وبعضها يحررها الكتبة كمحاضر الجلسات، وبعضها يحررها المحضرون أو يشتركون في تحريرها ويطلق عليها أوراق المحضرين مثل أوراق الإعلان^(١). فأوراق المرافعات إذا هي الأوراق المثبتة للإجراءات التي يتطلب قانون المرافعات إثباتها كتابة^(٢) وهذه الأوراق تتنوع كما قلنا بحسب الهدف المطلوب من كل ورقة، فصحيفة افتتاح الدعوى تهدف إلى استعمال الحق في الدعوى والالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القضائية، وأوراق التكليف بالحضور تهدف إلى إخبار المكلف بالحضور ليأتي إلى محكمة معينة في يوم معين ليسمع الحكم عليه بادعاء معين.

خصائص أوراق المرافعات:

جميع أوراق المرافعات تشترك في خاصيتين، هما:

الأولى: أوراق المرافعات أوراق شكلية: فجميع أوراق المرافعات أوراق شكلية، بمعنى أنها يجب أن تثبت بالكتابة وأن تراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون لها، وأن تشمل على البيانات التي أوجب ذكرها فيها. ولذلك فإنه لا يحل محل الشكل الذي أوجبه القانون اتباع أي طريق آخر من طرق الإثبات، فالشكلية تقتضي أن تكون الورقة جامعة لكل ما هو مطلوب فيها قانوناً من بيانات وخطوات يستوجبها القانون كإجراء جوهري^(٣).

(١) د. عبدالنواب مبارك، مرجع سابق، ص ٣١٥.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية مرجع سابق، ص ٤٤١.

(٣) د. أحمد هندي، قانون المرافعات، ج ٢/٤٧- د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٤٩٠- المستشار محمد

نصر الدين كامل، مرجع سابق، ص ٦.

الثانية: أوراق المرافعات أوراق رسمية: وذلك لأن الذي يقوم بتحريرها موظف مختص، ومن ثم فإنها تكون حجة بما أثبتته فيها من بيانات عن أمور باشرها بنفسه أو وقعت أمامه من ذوي الشأن، ولذلك لا يجوز إثبات ما يناقها إلا عن طريق الطعن بالتزوير^(١). فمثلا ما يثبتته المحضر في الورقة من أنه انتقل إلى المحل المراد الإعلان فيه وخاطب فيه شخصا له صفة في تسلم الإعلان وامتنع ذلك الشخص عن تسلمه فسلمه إلى جهة الإدارة، وأنه أخطر الشخص المراد إعلانه بذلك بخطاب موصى عليه، لا يمكن تكذيبه إلا بالادعاء بالتزوير. وما يثبتته المحضر من أنه مكن المعلن إليه من الاطلاع على الأصل ومن أنه اطلع عليه بالفعل ثم سلمه صورة منه أو سلم خادمه هذه الصورة لا يمكن كذلك تكذيبه فيه إلا بالادعاء بالتزوير.

الفصل الثاني

مواعيد المرافعات

يقترن الإجراء القضائي غالبا وأيا كان نوعه بميعاد محدد لمباشرة، وما لم يتخذ الإجراء في موعده، فلا يعد بحسب الأصل صحيحا ولا منتجا لأثاره القانونية، وبذا تضحي المواعيد المقرنة بالإجراءات متممة لشكليتها. وقد قيد القانون كثيرا من إجراءات المرافعات بمواعيد أوجب مراعاتها فيها، قاصدا بذلك الاطمئنان إلى حسن سير القضاء وتعجيل القضايا ووضع حد للمنازعات ومنع المفاجآت، وتمكين الخصوم من إعداد وسائل دفاعهم للرد على الطلبات التي توجه إليهم أو المستندات التي تقدم ضدهم.

أولا: التعريف بالمواعيد وأهميتها ووظائفها:

الميعاد الإجرائي عبارة عن فترة زمنية يحددها القانون يقيد بها الإجراء القضائي فيشترط القيام به إما قبل بدئها أو خلالها أو بعد انقضائها. ذلك أن قانون المرافعات يحدد آجالا معينة يتخذ فيها الإجراء حتى ينتج أثره، وحتى يكون أطراف النزاع على علم مسبق بهذه المواعيد، ومن ثم يراعونها عند اتخاذ الإجراءات محافظةلة على حقوقهم^(٢).

وتمثل أهمية المواعيد في أنها تعد ضمانا لحسن سير القضاء، إذ تؤدي إلى تقييد الخصوم بزمان معين لاتخاذ الإجراء، حتى لا تتراخي إجراءات الخصومة وتتأخر على نحو غير مبرر، فيأتي الميعاد ليحول دون تأبيد المنازعات وبما يحقق مصالح الخصوم باستقرار مراكزهم القانونية في وقت مناسب، كما أن المواعيد تؤدي إلى احترام حقوق الدفاع بمنح الخصوم فسحة من الوقت

(١) د. أحمد السيد صاوي ، مرجع سابق ، ص ٤٩٢.

(٢) د. حامد أبو طالب ، مرجع سابق، ص ٥٠٦.

تكفي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإعداد وسائل الدفاع، وبذلك تستجيب مواعيد الإجراءات لمبدأ حرية الدفاع^(١).

فالمواعيد تؤدي وظيفتان في الخصومة: فبعضها يرمي إلى دفع الخصم إلى القيام بعمل إجرائي معين حتى لا تبقى الخصومة مؤبدة بغير نهاية، كميعاد سقوط الخصومة، وبعضها يرمي إلى منح الخصم فترة زمنية كافية للقيام بعمل، كميعاد التكليف بالحضور^(٢).

ثانيا: أنواع المواعيد :

تنوع المواعيد من ناحية الوقت الذي يجب القيام بالإجراء فيه، إلى ثلاثة أنواع:
الأول: الميعاد الكامل: وهو الميعاد الذي يجب أن ينقضي كله قبل اتخاذ الإجراء، إذ لا يجوز مباشرة الإجراء قبل انتهاء هذا الميعاد. فهو عبارة عن فترة زمنية يجب أن تنقضي قبل مباشرة الإجراء، ولا يصح الإجراء إلا بعد انقضائها.

ومثال هذا الميعاد: ميعاد التكليف بالحضور: وهو عبارة عن مهلة زمنية يمنحها القانون للمدعى عليه للاستعداد للحضور أمام المحكمة المطلوب الحضور أمامها، وهي أربع وعشرين ساعة للحضور أمام المحاكم المستعجلة، وثمانية أيام للحضور أمام المحكمة الجزئية، وخمسة عشر يوما للحضور أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. وميعاد التنفيذ: إذ لا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي (مادة ٢٨١ مرافعات).

الثاني: الميعاد الناقص: وهو الميعاد الذي يجب القيام بالإجراء خلاله، وهذا الميعاد يعتبر ظرفا زمنيا يجب أن يتم الإجراء خلاله، فيكون اليوم الأخير من الميعاد هو آخر فرصة لاتخاذ الإجراء، فإذا انقضى الميعاد سقط الحق في اتخاذ الإجراء.

ومثاله: ميعاد الطعن في الأحكام: فإذا كان ميعاد الاستئناف أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه، فيجب رفع الاستئناف قبل مضي اليوم الأخير، وهذا معنى كون الميعاد ناقصا، لأنه لو تم الميعاد ولم يرفع الاستئناف أصبح الحكم نهائيا ولا يجوز استئنافه ولو في اليوم التالي لانقضاء الميعاد^(٣).

الثالث: الميعاد المرتد: وهو الميعاد الذي يجب أن يتخذ العمل الإجرائي قبل بدئه، وببدء هذا الميعاد يمتنع اتخاذ الإجراء أو حتى بعد انقضائه، فهذا الميعاد عبارة عن فترة زمنية يتعين اتخاذ الإجراء قبل أن تبدأ، فإذا بدأت لا يجوز القيام بالإجراء.

(١) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٥٥٣ - د. محمد عبد النبي غانم، ص ٤٥٢.

(٢) د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة، الجزء الأول، ص ٥٧٧.

(٣) أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٥٠٦.

ومثاله: الاعتراض على قائمة شروط البيع: حيث يجب أن يتم قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في التمسك به (١/٤٢٢ مرافعات).

ثالثاً: كيفية حساب المواعيد:

عنى قانون المرافعات بتحديد طريقة حساب المواعيد في المادة (١٥) منه، فنص على قواعد يتعين العمل بها عند احتساب المواعيد الإجرائية، ومخالفة هذه القواعد تؤدي إلى سقوط الحق في اتخاذ الإجراء، وبالتالي عدم قبوله، وقد تؤدي إلى بطلان الإجراء، وقد تعطي الحق للخصم في طلب التأجيل لاستكمال الميعاد^(١).

وتقدر مواعيد المرافعات إما بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالأعوام، ووفقاً لقواعد احتساب المواعيد والتي قررتها المادة (١٥) مرافعات، فإن حساب المواعيد الإجرائية يتم على النحو الآتي:

١- إذا كان الميعاد محددًا بالساعات: مثل ميعاد الحضور أمام القاضي المستعجل وهو ٢٤ ساعة (مادة ٦٦ مرافعات)، فلا تحسب الساعة التي تمت فيها الواقعة التي يبدأ منها الميعاد، بل يتم حساب الميعاد من الساعة التالية، وينتهي بتمام الساعة الأخيرة. فإذا كان الإعلان هو الواقعة المعتبرة قانوناً في بدء ميعاد الحضور، وكان قد تم في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، فإن الميعاد يبدأ من الساعة الثانية، وينتهي بنهاية الساعة الواحدة من ظهر اليوم التالي. ومن ثم يكون تحديد الجلسة بعد انتهاء هذه الساعة.

٢- إذا كان الميعاد محددًا بالأيام: فلا يحسب منه اليوم الذي تم فيه الإجراء أو حدث فيه الأمر الذي نص القانون على أن اليوم يبدأ منه، حتى لا يعتد بالساعة التي تم فيها الإجراء أو حدث فيها الأمر المعتبر بداية للميعاد، فيستحيل الميعاد الذي قدره المشرع بالأيام إلى ميعاد يحسب بالساعات، بل يبدأ الحساب من اليوم التالي، وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه، بحيث يدخل اليوم الأخير في حساب الميعاد. وذلك كما يلي:

■ إذا كان الميعاد كاملاً: مثل ميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية (وهو ثمانية أيام) وتم الإعلان يوم ٢٣ يناير، فيبدأ حساب ميعاد الثماني أيام من اليوم التالي، أي يوم ٢٤ يناير، ينتهي في يوم ٣١ يناير، ومن ثم يجوز تحديد الجلسة يوم ١ فبراير، ولا يجوز تحديدها قبل هذا اليوم مراعاة لميعاد الحضور ولقواعد تحديده.

■ وإذا كان الميعاد ناقصاً: مثل ميعاد الطعن بالاستئناف (وهو ٤٠ يوماً)، وصدر الحكم يوم ١١ أغسطس، فيبدأ الميعاد من يوم ١٢ أغسطس وينتهي بنهاية يوم ٢٠ سبتمبر، وبانتهاء

(١) المستشار. سيد حسن البغال: المطول، المجلد الأول، ص ٣٨٣.

اليوم الأخير من الميعاد الناقص يسقط الحق في اتخاذ الإجراء، فلا يجوز في الحالة الماثلة استئناف الحكم بعد يوم ٢٠ سبتمبر.

■ أما إذا كان الميعاد مرتدا: مثل ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع، فيبدأ الحساب بالرجوع إلى الخلف، دون احتساب اليوم المعتبر مجريا للميعاد، وعلى سبيل المثال فإن ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع هو ثلاثة أيام قبل جلسة الاعتراضات، يتم حسابه كما يتم حساب الميعاد الكامل ولكن بالرجوع إلى الخلف أو بطريقة عكسية، فإذا كان ميعاد الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات يوم ٥/١٥ فإن هذا اليوم لا يحسب لأنه نهاية الميعاد، وتحسب ثلاثة أيام قبله وهي أيام ١٢، ١٣، ١٤، فيجب تقديم الاعتراض قبل يوم ١٢، لأن مدة الثلاثة أيام يجب أن تنقضي كاملة.

٣- إذا كان الميعاد محددا بالأشهر أو السنين: فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجريا للأجل، ويبدأ الحساب من اليوم التالي له، ثم نحسب الشهور أو السنين دون اعتداد بعدد أيام الشهر أو عدد أيام السنة، فإذا كان الميعاد مثلا هو ما ورد النص عليه في المادة (٧٠) مرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان قيد الدعوى قد تم في يوم ١٠/٤، فإن الميعاد يبدأ من يوم ١١/٤، وينتهي بانتهاء يوم ١٠/٧، بغض النظر عن عدد أيام الشهور التي تخللت الميعاد، حتى ولو كان بعضها أكثر أو أقل من ثلاثين يوما. وتحسب المواعيد بالشهور أو السنين بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

رابعاً: امتداد مواعيد المرافعات:

يقصد بامتداد المواعيد هنا، امتدادها بحكم القانون لتوافر السبب القانوني الذي نص عليه المشرع، وهي تمتد بقوة القانون إذا توافر أحد سببين:

أ- امتداد المواعيد بسبب العطلة الرسمية:

وفقا لنص المادة (١٨) مرافعات، فإنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.

والمقصود بالعطلة الرسمية، الأجازات الرسمية سواء تلك المحددة سلفا بموجب قرار أو تلك الأجازات الرسمية المفاجئة التي تعطل فيها المصالح الحكومية، ويدخل فيها أيضا العطلات الإجبارية، التي تنشأ عن قيام اضطرابات، ويفرض فيها حظر التجول في مواعيد العمل الرسمية. فإذا تصادف أن آخر الميعاد عطلة رسمية فإن هذا الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، لأنه لا يمكن قانونا القيام بعمل إجرائي أثناء العطلة الرسمية. "وعلة هذا الامتداد هي أن تتاح

الفرصة لمن تقرر الميعاد لمصلحته للتروي في القيام بالعمل حتى آخر يوم فيه، فإذا قرر القيام بالعمل في هذا اليوم ووجده عطلة رسمية، فيجب أن يمنح يوماً كاملاً بعدها^(١).

فامتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية مرهون بأن يقع اليوم الأخير منه يوم عطلة، أما إذا كان اليوم الأخير منه يوم عمل، فإنه لا يمتد حتى ولو وقع الجزء الأكبر منه في يوم العطلة^(٢). ومن ثم تجب التفرقة بصدد امتداد الميعاد للعطلة الرسمية بين حالتين: الأولى: إذا جاء يوم العطلة في بداية الميعاد أو في أثنائه، فلا يكون له تأثير في هذه الحالة في امتداد الميعاد، بل ينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه دون اعتداد بيوم العطلة. والثانية: إذا كان آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية، فيمتد لأول يوم عمل بعد العطلة.

وإذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا يوماً واحداً بعد انتهاء العطلة. ويمتد الميعاد إلى أول يوم فقط من أيام العمل مهما كان عدد أيام العطلة التي وقعت آخر الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات ووقعت الساعة الأخيرة منه في يوم عطلة امتد الميعاد إلى أول ساعة عمل بعد العطلة^(٣).

ويسري الامتداد سواء كان الميعاد كاملاً أو ناقصاً، وسواء كان يحسب بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنين^(٤). كما يسري الامتداد على الميعاد سواء كان كاملاً، أو ناقصاً، أما بالنسبة للمواعيد المرتدة، وهي المواعيد التي يتعين اتخاذ الإجراء قبلها فلا يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية لأن ذلك يؤدي إلى نقصه، لا إلى زيادة الميعاد.

وإذا قلنا بامتداد الميعاد فهو يمتد من بدايته، لأن نهايته محددة سلفاً، فلو كانت الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات محددة يوم ٢٦/٣ وتقدم الاعتراضات إلى ما قبل الجلسة بثلاثة أيام، فنعود إلى الوراء ٢٣، ٢٤، ٢٥، فلو صادف يوم ٢٢ (وهو آخر يوم لتقديم الاعتراضات) عطلة فلا يمتد الميعاد ويقدم الاعتراض يوم ٢٣ لأنه يؤدي إلى اقتطاع يوم من الأيام الثلاثة، التي يجب أن تسبق جلسة نظر الاعتراضات، ويتبقى يومان فقط ويؤدي ذلك إلى الاصطدام بما قرره المادة (١/٤٢٢) مرافعات، من أنه يجب إبداء الاعتراض على قائمة شروط البيع قبل جلسة نظر الاعتراضات بثلاثة أيام^(١).

(١) د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة، الجزء الأول، ص ٦٢٠.

(٢) د. أحمد سيد صاوي، مرجع سابق، ص ٥٥٧.

(٣) د. رمزي سيف، مرجع سابق، ص ٤٨٣ - محمد عبد النبي غانم، مرجع سابق، ص ٤٦١.

(٤) د. عبد التواب مبارك، مرجع سابق، ص ٣٢٣.

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٥١١.

ب- امتداد الميعاد بسبب المسافة:

نظمت المادتان (١٦،١٧) مرافعات، امتداد مواعيد المرافعات بسبب المسافة، فإذا اقتضى اتخاذ الإجراء انتقال الخصم أو المحضر القائم به من بلدة إلى أخرى، فإن الميعاد الأصلي يمتد مدة معينة يحددها القانون^(١)، "إذ قد يكون المعلن إليه مضطرا لكي يرد على الإعلان بإعلان مثله أو ليحضر أمام المحكمة أو ليقوم بالعمل المطلوب منه أو ليطعن في الحكم المعلن إليه، أن ينتقل من موطنه إلى الموطن الذي يجب أن يقوم فيه بالعمل. ولذلك كان من الطبيعي أن يقدر المشرع هذا الظرف وأن يزيد في المواعيد التي حددها أصلا، بما يسمح لهذا الشخص بالانتقال من موطنه إلى الموطن الآخر، وذلك تحقيقا للمساواة بين الخصوم، وحتى لا يضار خصم من بعد موطنه أو يفيد آخر من بعد خصمه عن مقر المحكمة، وهذه الزيادة في الميعاد هي التي تسمى بميعاد المسافة"^(٢).

فميعاد المسافة هو مهلة زمنية تضاف إلى الميعاد الأصلي بقوة القانون، لما ارتأه المشرع من أن اتخاذ إجراء ما في الخصومة يقتضي انتقال الخصم أو ممثله القانوني أو وكيله في الخصومة أو المحضر، من المكان الذي يعتبره القانون مقرا له إلى المحكمة التي يتعين اتخاذ الإجراء أمامها^(٣).

ويجب لإضافة ميعاد المسافة أن تكون المسافة المتقدم ذكرها خمسين كيلو مترا على الأقل، فإن قلت عن هذا، فلا يضاف أي ميعاد للمسافة^(٤). والمقصود بالمكان في ميعاد المسافة هو البلدة بصفة عامة لا أية بقعة داخلية بها، وبذلك تحتسب المسافة من محطة السفر بها إلى محطة الوصول بالبلدة دون احتساب المسافات الداخلية^(٥). كما أن العبارة في احتساب ميعاد المسافة أن يكون وفقا لما هي عليه عن طريق السكك الحديدية، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بالطريق البري^(٦)، فإذا كانت البلدة المطلوب اتخاذ الإجراء فيها لا تقع على خطوط سكك حديدية، فهنا لا مناص من الاعتداد بمسافة الطريق البري^(٧). وبالرجوع إلى نص المادتين (١٦،١٧) مرافعات نجد أن المشرع فرق بشأن ميعاد المسافة بين ثلاث حالات على النحو الآتي:

(١) د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٣٢٥.

(٢) د. أحمد هندي: قانون المرافعات، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ١٦٥.

(٣) المستشار. سيد حسن البغال: المطول، مرجع سابق، ص ٣٨٦.

(٤) د. فتحي والي، مرجع سابق، ص ٤٢٩.

(٥) نقص: الطعن رقم ٨٤ لسنة ٢٥ قضائية – جلسة ١٩٥٩/٤/٢٣.

(٦) نقص: الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٥٦ قضائية – جلسة ١٩٦١/٦/١٣.

(٧) المستشار. سيد حسن البغال: المطول، مرجع سابق، ص ٣٨٧.

الحالة الأولى: إذا كان الشخص مقيماً داخل مصر (في غير مناطق الحدود):

يضاف إلى الميعاد الأصلي يوماً لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترين المكان الذي يجب الانتقال منه (وهو عادة موطن الشخص) والمكان الذي يجب الانتقال إليه (وهو عادة مقر المحكمة)، وقد يكون الانتقال عكسياً من مقر المحكمة إلى موطن شخص معين. ويوماً لما يزيد من الكسور عن ثلاثين كيلو متراً، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام، (م ١٦ مرافعات).

الحالة الثانية: إذا كان الشخص يقيم في مناطق الحدود في مصر:

فإن ميعاد المسافة بالنسبة له خمسة عشر يوماً، بصرف النظر عن عدد الكيلو مترات.

الحالة الثالثة: إذا كان الشخص يقيم خارج مصر:

فإن ميعاد المسافة له، ستون يوماً، أي كان موطنه، فهو ميعاد موحد لجميع البلاد. غير أن المادة (١٧) مرافعات أوردت حكماً خاصاً بمن يقيم خارج مصر، هما:

الأول: أن لقاضي الأمور الوقفية - بناء على طلب المعلن - الأمر بإنقاص ميعاد المسافة لمن يقيم بالخارج، بالنظر إلى سهولة المواصلات أو ظروف الاستعجال في الدعوى، ولو كانت الدعوى موضوعية، وعندئذ يجب إعلان صورة أمر القاضي مع الأوراق المعلنة.

والثاني: أنه إذا كان المقيم بالخارج قد أعلن لشخصه أثناء تواجده داخل الجمهورية، فإنه لا يستفيد من ميعاد المسافة المقرر له إذا أعلن في موطنه بالخارج، وإنما يستفيد فقط من مواعيد المسافة العادية المقررة لمن موطنه في مصر، محسوبة بالنظر إلى مكان إعلانه.

على أنه يجوز لقاضي الأمور الوقفية أن يأمر بمد هذه المواعيد (بالنظر لظروف تواجد هذا الشخص في غير موطنه)، كما أن للمحكمة عند نظر الدعوى اعتبارها ممتدة، وفي الحالتين لا يمنح الشخص ميعاد مسافة أطول من ستين يوماً (مادة ١٧)^(١).

قواعد خاصة بشأن ميعاد المسافة^(٢):

١- يضاف ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي أي كان نوع الخصومة، وأياً كانت طريقة حساب الميعاد الأصلي، سواء كان يتم حسابه بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، ويلتحم ميعاد المسافة بالميعاد الأصلي بحيث يعتبر آخر يوم في ميعاد المسافة، هو اليوم الأخير في الميعاد، ولهذا يمتد إذا وقع آخر يوم فيه عطلة رسمية.

(١) د. فتحي والي، مرجع سابق، ص ٤٢٩.

(٢) د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة، ج ١/ ٥٩٣ - د. أحمد هندي: قانون المرافعات، ج ١/ ١٧٠ - د. أحمد السيد

صاوي، ص ٥٦٢ - د. فتحي والي، ص ٤٣٠ - د. عبد التواب مبارك، ص ٣٢٦.

٢- لا عبء بالموطن الأصلي للشخص في تقدير المسافة إذا أعلن في موطنه المختار أو الخاص أو أعلن في موطن من يمثله قانونا أو اتفاقا متى كان من الجائز إعلانه فيه فالعبء في هذه الحالة بالمسافة بين هذا الموطن والمكان الواجب الانتقال إليه للحضور أو لمباشرة الإجراء فيه. كما أن العبء بالنظر إلى موطن الشخص المنوط به القيام بالإجراء، كما لو كان القائم بالإجراء هو ممثل القاصر، وبدأ الميعاد من إعلان هذا الممثل، فالعبء بموطنه هو دون موطن القاصر.

٣- ميعاد المسافة من المواعيد التي تتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجب على المحكمة مراعاته من تلقاء نفسها، وإلا كان هناك خطأ في تطبيق القانون.

٤- لا يجوز التمسك لأول مرة في النقص بإضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي لما يخالطه من واقع.

خامسا: سلطة القضاء في تعديل المواعيد:

من المبادئ المقررة أن المحكمة ليست لها سلطة في مد مواعيد المرافعات أو تقصيرها وفق رغبتها وذلك لأن هذه المواعيد مقررة لحماية حقوق المتقاضين ومصالحهم، إلا أن القانون خول القضاء في نصوص صريحة وظروف استثنائية سلطة تعديل مواعيد المرافعات^(١). ومثال ذلك:

١- مد المواعيد: حيث نصت المادة (١٧) مرافعات، على السلطة الجوازية لقاضي الأمور الوقفية، أو للمحكمة عند نظر الدعوى على الشخص الذي أعلن لشخصه في الجمهورية إذا كان يقيم في الخارج، ولم يسر في حقه ميعاد المسافة المقرر لمن يقيم خارج البلاد، أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج.

٢- إنقاص المواعيد: حيث أجاز القانون للقاضي أن ينقص المواعيد في بعض الحالات، من ذلك :

- إنقاص ميعاد المسافة الوارد بالمادة (١٧) مرافعات، وهو ستون يوما لمن موطنه بالخارج، حيث يجوز بأمر من قاضي الأمور الوقفية وبناء على طلب المعلن، إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال، على أن يعلن أمر إنقاص الميعاد مع الورقة المعلنة.
- إنقاص ميعاد الحضور (مادة ٦٦ مرافعات)، وهو خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وثمانية أيام أمام المحكمة الجزئية.

(١) د. عبد المنعم الشرقاوي، مرجع سابق، ص ٣٤٠-٣٤١.

حيث يجوز في حالة الضرورة وبإذن من قاضي الأمور الوقتية نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام، وإلى أربع وعشرين ساعة على التوالي.

كما يجوز نقص ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة (وهو أربع وعشرين ساعة) بإذن من قاضي الأمور الوقتية، وجعله من ساعة إلى ساعة، إذا توافرت ثلاثة شروط:

الأول: توافر حالة الضرورة التي تدعو إلى ذلك، والثاني: أن يتم إنقاص الميعاد بإذن من قاضي الأمور الوقتية، والثالث: ألا تكون الدعوى من الدعاوى البحرية.

على أنه يشترط في جميع الحالات التي يتم فيها إنقاص ميعاد الحضور بإذن من قاض الأمور الوقتية، أن تعلن صورة الإذن مع صحيفة الدعوى.

سادسا: أثر القوة القاهرة على مواعيد المرافعات^(١):

تؤدي القوة القاهرة إلى وقف المواعيد أو منع سريانها أو تأجيلها، وهذا هو أحد الآثار المهمة التي تترتب على القوة القاهرة في قانون المرافعات، ومثال ذلك: نص المادة (٢١٦) مرافعات، والتي جرى نصها على أنه "يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث إن كان".

وبدل هذا النص على أثر القوة القاهرة على المواعيد، فعلى الرغم من أن مواعيد الطعن تعتبر من مواعيد السقوط التي لا يسري عليها أسباب الوقف أو الانقطاع، إلا أن المشرع واجه حالة قيام قوة القاهرة في مواجهة الطاعن، فقرر وقف ميعاد الطعن بناء على هذه القوة القاهرة^(٢).

سابعا: الجزاء المترتب على مخالفة مواعيد المرافعات:

تبدو أهمية التفرقة بين الأنواع الثلاثة للمواعيد، في أن جزاء البطلان أو سقوط الحق في اتخاذ الإجراء لا يرد إلا على عدم احترام المواعيد الناقصة والمواعيد المرتدة. أما المواعيد الكاملة فإنه لا يترتب على عدم مراعاتها جزاء البطلان، لأن عدم احترامها يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الإجراء، لأنه اتخذ قبل أوانه، أو أن يكتفي المشرع بالتأجيل كما إذا لم تحترم مواعيد الحضور، إذ نصت المادة (٦٩) على أنه لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد^(٣).

(١) د. محمد سعيد عبدالرحمن: القوة القاهرة في قانون المرافعات، دار النهضة، ٢٠٠١م، ص ٢٣١.

(٢) أنظر للمؤلف: نظرية القرائن، مرجع سابق، ج ١/٤٥٤.

(٣) د. محمد مصطفى يونس: المرجع في قانون إجراءات التقاضي، دار النهضة، ٢٠١٥م، ص ٦١٧.

المبحث الثاني

إجراءات رفع الدعوى وإجراءات قيدها وكيفية انعقاد الخصومة بين طرفيها

يفرق المشرع بين رفع الدعوى وقيدها وبين انعقاد الخصومة فيها، فنص على أن الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة. غير أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب على هذا النحو، وإنما يشترط لانعقادها أن تعلن صحيفة الدعوى إلى الخصم إعلاناً صحيحاً، وهذا الإعلان تنعقد الخصومة، ونبين ذلك في مطلبين نتناول في الأول منهما رفع الدعوى وقيدها، وفي الثاني انعقاد الخصومة.

المطلب الأول

رفع الدعوى وقيدها

تضمنت المادة (٦٣) مرافعات طريقة رفع الدعوى، بنصها على أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومن ثم فالدعوى ترفع إلى القضاء بورقة تسمى "صحيفة افتتاح الدعوى" أو صحيفة الدعوى أو عريضة الدعوى وهذه الورقة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

أولاً: ماهية صحيفة الدعوى:

صحيفة افتتاح الدعوى هي أساس الخصومة، والخصومة تدور وجوداً وعدماً معها^(١)، فصحيفة الدعوى هي الإجراء الذي تفتتح به الخصومة، ويعتبر أحد إجراءاتها، فبه تنشأ الخصومة وتصبح المحكمة ملزمة بإصدار حكم فيها^(٢). إذ القاعدة أن القاضي لا يعمل من تلقاء نفسه وإنما بناء على طلب من صاحب المصلحة، وهو ما يعبر عنه بمبدأ المطالبة القضائية. والمطالبة القضائية هي عمل إجرائي موجه من المدعي أو ممثله إلى المحكمة، يعلن فيه رغبته في الحصول على حماية القضاء لحق أو مركز قانوني معين في مواجهة المدعى عليه؛ فالخصومة لا تنشأ إلا بناء على طلب، ويتحدد محل الخصومة والحكم الصادر فيها بحدود الطلب، بحيث يلتزم القاضي بالدعوى موضوع الطلب أشخاصاً ومحللاً وسبباً^(٣).

(١) د. محمد محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص ١٧.

(٢) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: قانون المرافعات، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ٣٣.

(٣) د. أحمد هندي: أصول قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٢٦٩ - د. عبدالنواب مبارك، مرجع سابق، ص ٤٣٧ - د.

وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٥٠٣.

تحرير صحيفة الدعوى وأهميتها:

يحرر المدعي صحيفة دعواه - بنفسه أو مستعينا بغيره - إلا أنه يجب أن تضمن الصحيفة البيانات التي استلزمها القانون، وأن يكون موقعا عليها عند تقديمها إلى المحكمة من أحد المحامين المعتمدين للمرافعة أمام تلك المحكمة^(١)، ما لم تكن قيمة الدعوى خمسين جنبا أو أقل، ففي هذه الحالة لا يلزم توقيع محام .

والصحيفة هي الأساس الذي تقوم وتبنى عليه الخصومة، ولذلك فإن الخصومة تدور وجودا وعندما مع فكرة صحيفة الدعوى، بحيث إذا ما انتهت الصحيفة وزالت، زالت الخصومة واعتبرت كأن لم تنعقد أصلا وإن كان هذا لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة ولكن بصحيفة جديدة^(٢). وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم بطلانها فإنه ينبغي على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأه متى انتفى المانع القانوني من ذلك"^(٣).

ثانيا: بيانات صحيفة الدعوى:

يتطلب القانون بيانات عديدة في صحيفة الدعوى، وذلك لأن هذه الصحيفة تؤدي ثلاث وظائف: فهي أولا صحيفة دعوى، وهي ثانيا ورقة تكليف بالحضور، وهي أخيرا: ورقة إعلان من أوراق المحضرين، حيث يتم إعلانها بعد ذلك على يد محضر^(٤). وقد ورد النص على بيانات صحيفة الدعوى في المادة (٦٣) مرافعات، ووفقا لهذه المادة فإنه يجب أن تتوافر في صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

(١) د. عبدالباسط جميعي، مرجع سابق، ص ٤٠٨.

- يشترط لصحة رفع الدعوى أن يوقع صحيفة دعواها أحد المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويكفي في هذا الصدد توقيعه على أصل الصحيفة أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب. والحكمة من توقيع المحامي على صحيفة الدعوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، ذلك أن من شأن توقيع المحامي على صحيفة الدعوى مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق. ويترتب على عدم توقيع المحامي بطلان الصحيفة، لأن التوقيع على الصحيفة أمر متعلق بالنظام العام.

(٢) د. محمد محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص ١٧.

(٣) نقض ١٩٧٣/٥/١٥ مج س ٢٤ ص ٥٨٨.

(٤) د. وجدي راغب، مرجع سابق، ص ٥٠٦.

١- بيانات المدعي والمدعى عليه: فإذا كان المدعي ناقص الأهلية فيجب بيان اسم ممثله القانوني ولقبه ومهنته وصفته التي تخوله هذا التمثيل، كما يجب بيان موطنه (هذا بالإضافة إلى البيان الخاص بناقص الأهلية نفسه). وإذا كانت الدعوى مرفوعة من شخص اعتباري فيجب ذكر اسم الشخص الاعتباري وذكر صفة من يمثله، دون حاجة لذكر اسمه لعدم أهمية الاسم في هذه الحالة، وإنما المهم الصفة التي تخوله العمل باسم الشخص الاعتباري.

٢- تاريخ تقديم الصحيفة: ولهذا البيان أهمية بالغة؛ ذلك أن المشرع رتب أثراً معينة على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب، ومن ثم تعين تحديد التاريخ الذي يبدأ منه سريان هذه الآثار. فيجب ذكر اليوم الذي تم فيه إيداع الصحيفة بقلم الكتاب، ويقوم بهذه المهمة قلم الكتاب الذي يتعين عليه أن يبين تاريخ تقديم الصحيفة إليه^(١).

٣- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى: والغرض من ذلك أن يلتقي الخصمان أمام محكمة واحدة^(٢)، ولا يكفي في هذا الصدد عبارة المحكمة المختصة، فقد تكون هناك أكثر من محكمة مختصة، فيجب ذكرها على وجه التحديد بشكل لا يدع مجالاً للشك فيها.

٤- موطن مختار للمدعي: إذ يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له فيها موطن، وذلك حتى تعلن له في هذا الموطن الأوراق المتعلقة بالدعوى.

٥- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها: وهذا البيان هو جوهر صحيفة الدعوى، إذ بها تفتتح خصومة قضائية بادعاء ما قبل شخص معين، لذلك يجب أن تشتمل الصحيفة على سبب الخصومة ببيان موضوع الادعاء وأدلتها، كما يجب أن يحدد بها المدعي طلباته من المحكمة. والغرض من هذا البيان تمكين المدعي عليه من الوقوف على المطلوب منه، وأساس ذلك، فيتهيأ للدفاع قبل حضوره إلى المحكمة، كما أن هذا البيان يعين المحكمة على تكوين فكرة واضحة عن الدعوى^(٣).

٦- توقيع محام على صحيفة الدعوى: بالإضافة إلى البيانات السابق ذكرها والتي ورد النص عليها في المادة (٦٣) مرافعات فإنه يشترط لصحة صحيفة الدعوى أن يتم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

(١) المستشار. سيد حسن البغال: المطول، المجلد الأول، مرجع سابق، ص ١٨٣.

(٢) د. أحمد السيد صاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٦١٥.

(٣) د. أحمد السيد صاوي: مرجع سابق، ص ٦١٦.

القاعدة أن صحيفة افتتاح الدعوى لا يجوز استكمالها بأوراق أخرى:

"من المبادئ المقررة في قضاء محكمة النقض أن صحيفة الدعوى وإن كانت ذات كيان ذاتي متميز فلا يجوز تكملة النقص الذي يرد فيها كصحيفة بأوراق أخرى، لأنه يترتب على ذاتية الصحيفة أن تدل وتنتي بنفسها عن مضمونها دونما الاعتماد على أوراق أخرى وإلا كان مآلها البطلان، ولكن هذه القاعدة لا تعمل ويرد عليها استثناء في حالة استبدال الصحيفة أو سرقة بعضها وإحلال أجزاء محلها لم تكن معلنة في الأصل وهذا يتفق مع القاعدة"^(١).

الجزاء المترتب على النقص أو الخطأ في بيانات الصحيفة:

لم ينص المشرع صراحة على البطلان كجزاء على إغفال بيان أو أكثر من بيانات الصحيفة أو النقص أو الخطأ فيها، ومن ثم ينبغي تطبيق القواعد العامة بشأن البطلان وتوجب القاعدة العامة في هذا الصدد أن إغفال بيان من البيانات سالف الذكر - فيما عدا بيان الموطن المختار - يترتب عليه بطلان الصحيفة لأنه يفوت الغاية التي قصد المشرع تحقيقها منه. أما النقص أو الخطأ فلا يترتب عليه البطلان إلا إذا كان من شأنه التجهيل بالبيان إذ يعتبر في حكم الإغفال^(٢).

ثالثاً: قيد صحيفة الدعوى:

وفقاً لنص المادة (٦٣) مرافعات: فإن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، وعلى قلم الكتاب أن يقيد صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:

- ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعي منها .
- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صوراً منها تحت مسؤولية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
- مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتغال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم (مادة ١/٦٥ مرافعات).
- وإذا رأى الكاتب أن الأوراق أو المستندات التي نصت عليها (مادة ١/٦٥ مرافعات) غير مستوفاة، فإنه لا يستطيع قيد الدعوى، كما لا يستطيع أن يرفض قيدها نهائياً وإنما يقوم بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقفية ليفصل فيها فوراً (مادة ٢/٦٥ مرافعات)، ويكون ذلك في محضر

(١) د. محمد محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص ٢٢.

(٢) د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ٣٢٣.

يحرره الكاتب ويرفق بملف الدعوى^(١). وقيد الدعوى هو الإجراء الذي ترفع به الدعوى إلى المحكمة وليس إعلانها، لذا فإنه يترتب عليه عرضها على المحكمة لنظرها، فالدعوى قد تعرض على المحكمة ولو لم تعلن صحيفتها ما دامت قد قيدت عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب^(٢).

وقد اعتبر قانون المرافعات الدعوى مرفوعة من وقت إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهذا الحكم استحدثه القانون الحالي بقصد التيسير على رافع الدعوى، والقانون وإن كان قد اعتبر الدعوى مرفوعة إلى المحكمة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب إلا أنه قرن ذلك بإعلان الصحيفة إلى المدعى عليه في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب ورتب على عدم الإعلان خلال هذه المدة اعتبار الصحيفة كأن لم تكن (مادة ٧٠ مرافعات).

جزء عدم اتباع الشكل المحدد لرفع الدعوى:

إذا لم يتم اتباع الشكل المحدد لرفع الدعوى والذي أوجبه القانون، فإن ذلك يؤدي إلى البطلان، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام^(٣).

رابعاً: إعلان صحيفة الدعوى^(٤):

يوجب القانون بعد قيد الدعوى إعلان المدعى عليه بها وتكليفه بالحضور للجلسة المحددة لها، وهذا الإعلان يتم فعلاً انعقاد الدعوى، إذ يجب على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد، فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة (مادة ٦٨ مرافعات). على أنه يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب إذا كان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي (مادة ٧٠).

وإعلان الصحيفة شأنه شأن إعلان كافة أوراق المحضرين، قد يتم لشخص المعلن إليه، أو في موطنه، وهذا الإعلان إجراء منفصل عن قيد الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى، كان ذلك كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم، وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها أو لم يمثل أصلاً.

(١) د. عيد محمد القصاص: الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص ٤٧٧ وما بعدها.

(٢) د. رمزي سيف، مرجع سابق، ص ٤٦٤.

(٣) د. إبراهيم أمين النفاوي، مرجع سابق، ص ٨٨.

(٤) د. أحمد هندي: أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص ٢٧٨.

خامسا: مراعاة مواعيد الحضور:

أوجبت المادة (٦٨) مرافعات على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد، فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور، وميعاد الحضور هو مهلة مفروضة قانونا للمدعى عليه بين تاريخ إعلانه وتكليفه بالحضور، وبين الجلسة المحددة لنظر الدعوى، بحيث إذا كانت الفترة بين هذا التاريخ وذاك تقل عن المهلة المقررة كان ذلك إخلالا بميعاد الحضور المقرر قانونا، غير أنه لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، ولكن يحق للمدعى عليه التأجيل لاستكمال الميعاد.

ويختلف ميعاد الحضور باختلاف ما إذا كانت الدعوى مستعجلة أو عادية، وفي الدعاوى العادية باختلاف ما إذا كانت مرفوعة إلى محكمة جزئية، أو محكمة ابتدائية، أو استئنافية. فميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة (مادة ٢/٦٦)، وفي الدعاوى العادية أمام المحكمة الجزئية ثمانية أيام، أما في الدعاوى الكلية والاستئنافية فالميعاد خمسة عشر يوما على الأقل (مادة ١/٦٦).

ويجوز في حالة الضرورة نقص ميعاد الحضور بإذن من قاضي الأمور الوقتية وفي حدود معينة، بحيث لا يقل الميعاد عن ثلاثة أيام في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وأربع وعشرين ساعة في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية، أما في الدعاوى المستعجلة فيجوز نقص الميعاد إلى ساعة واحدة، بشرط حصوله للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.

سادسا: إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه:

أوجب المشرع على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته أو صوراً منها تحت مسؤوليته، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.

وذلك حرصاً من جانب المشرع على سرعة تجهيز الدعوى واكتمالها، تحقيقاً لسرعة الفصل في القضايا فلم ينتظر إعلان الدعوى إلى المدعى عليه عن طريق قلم المحضرين، وإنما استحدث حكماً بمقتضاه أوجب على قلم الكتاب بعد قيد الدعوى أن يرسل إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطر فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.

المطلب الثاني

إنعقاد الخصومة

من أهم المبادئ التي تسود الخصومة القضائية مبدأ المواجهة بين الخصوم، ويقصد به إلزام القاضي بواجب مواجهة الخصوم بعضهم بعضاً بادعاءاتهم ودفاعهم، أو على الأقل تمكينهم من ذلك، فالحكم القضائي هو ثمرة المناقشة الحرة بين الخصوم للعناصر المطروحة في القضية، بحيث يكون في مقدور كل خصم عرض أوجه دفاعه ودحض حجج خصمه. والمواجهة بين الخصوم من مقتضيات حرية الدفاع وهي تضيق إلى تلك الحرية حق كل خصم في العلم بطلبات خصمه ودفاعه ومناقشته، ويفرض مبدأ المواجهة على الخصوم التزامات تتعلق ببداية الخصومة وبسيرها، فعلى المدعي أن يعلن خصمه -المدعى عليه- بالدعوى المرفوعة عليه^(١)، إذ لا يجوز الحكم على شخص دون تمكنه من تقديم ما لديه من أدلة ووسائل دفاع مختلفة، ولهذا فإنه يجب إعلان الخصم بصحيفة الدعوى^(٢).

فلا يكفي لانعقاد الخصومة إيداع صحيفة قلم الكتاب؛ وإنما يجب إعلان هذه الصحيفة إلى المدعى عليه (مادة ٦٧ مرافعات). ذلك أن إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وإن كان يترتب عليه آثار قانونية هامة، وبه تبدأ الخصومة، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لا نكون إلا إزاء علاقة ثنائية فيما بين المدعي والمحكمة، وليس من شأن هذه العلاقة أن تفرض نفسها على المدعى عليه إلا بإعلانه بمضمونها بحيث إذا لم يتم الإعلان أو تم على وجه غير صحيح لم تنعقد الخصومة ويكون وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كآثر للمطالبة القضائية^(٣).

ولم يوجب المشرع حضور المدعى عليه بالجلسة حتى تنعقد الخصومة في مواجهته، وإنما أوجب إعلان صحيفة إليه بالشكل المقرر قانوناً، واعتبر إعلان الصحيفة على هذا النحو كافياً لعلم المدعى عليه بالجلسة وبموضوع الخصومة، وبالتالي تكون الخصومة حضورية إذا حضر الجلسة وفقاً لهذا الإعلان، وتعتبر حضورية أيضاً إذا لم يحضر الجلسة وتحقق القاضي من صحة إعلانه بها. وإذا كانت الخصومة تنعقد بإعلان صحيفة إلى المدعى عليه؛ فإنها تنعقد أيضاً بحضوره الجلسة، ونبين ذلك في فرعين على النحو الآتي:

(١) د. الكوني علي أعبوده، مرجع سابق، ص ٦٧-٦٨.

(٢) د. إبراهيم أمين النفيائي، الإخلال بالواجب الإجرائي، ص ٥٨ - د. رمزي سيف، ص ٤٦٦.

(٣) المستشار سيد حسن البيغال: المطول، المجلد الأول في الدعوى، مرجع سابق، ص ٢٣٤.

الفرع الأول الإعلان القضائي

يقتضي الحديث عن الإعلان القضائي باعتباره إجراء أساسيا من إجراءات الخصومة أن نوضح ماهية الإعلان وأحكامه العامة وكيفية إعلان الأوراق القضائية، وذلك على النحو الآتي:

الفصل الأول

ماهية الإعلان القضائي وأحكامه العامة

أولاً: ماهية الإعلان القضائي:

الإعلان القضائي: هو وسيلة قانونية هدفها تمكين الخصم من الإجراءات القضائية، ويقصد به إيصال أمر أو واقعة ثابتة بهذا الإعلان إلى علم شخص معين على يد موظف رسمي أو بأي طريق آخر يحدده القانون^(١). فهو الوسيلة الرسمية التي يبلغ بها خصم واقعة معينة إلى علم خصمه وذلك بتسليمه صورة من الورقة المعلنة^(٢).

وتعد ورقة الإعلان ورقة رسمية باعتبارها من أوراق المرافعات، ذلك أن الذي يقوم بالتوقيع عليها هو المحضر، وهذا التوقيع يسبغ عليها صفة الرسمية. ويتربط على ذلك النتائج الآتية:

١- يعتبر المحضر مرتكباً لجريمة التزوير في ورقة رسمية إن هو قام بتغيير الحقيقة في ورقة المحضرين بإثباته ما لم يحصل أو عدم إثباته ما حصل أمامه مما يجب تدوينه، كما يعتبر مرتكباً هذه الجريمة كل من يقوم بتزوير الورقة أو التغيير فيها أو تقليد إمضاء المحضر. وذلك كأن يقرر المحضر في محضره أنه خاطب المراد إعلانه شخصاً خارج موطنه لأنه يعرفه معرفة ذاتية، أو يقرر أنه انتقل إلى موطن المعلن إليه، أو يقرر أنه وجده مغلقاً، أو يقرر أنه لم يجد بموطن المعلن إليه أحد يصح تسليم الإعلان إليه، ويكون ذلك مخالفاً للحقيقة، فيكون ما يقره المحضر في الإعلان مخالفاً للحقيقة تزويراً.

٢- أن ورقة المحضرين تعتبر حجة بما فيها، فلا يقبل إثبات عكس ما حرره المحضر على أن رآه أو سمعه أو اتخذته بنفسه مما يدخل في اختصاصه بطريق دعوى التزوير.

شكليات الإعلان القضائي وأشخاصه:

الإعلان إجراء مهم جداً في الدعوى القضائية، يستهدف تمكين المدعى عليه أو نائبه من العلم بمحتويات صحيفة الدعوى، أو الورقة القضائية بوجه عام، عن طريق انتقال المحضر وتسليم

(١) د. إبراهيم النفيوي: الإخلال بالواجب الإجرائي، مرجع سابق، ص ١٢.

(٢) د. أحمد السيد صاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ٢٠٠٥م، ص ٥٠٥.

صورة من هذه الورقة إلى الأشخاص أو الجهات التي يحددها القانون، ويحدد القانون تفصيليا الأشخاص الذين يمكن أن تسلم لهم الصورة، ومكان تسليمها، والوقت الذي يجوز فيه الإعلان. وشكلية الإعلان القضائي تعتبر عنصرا من عناصره باعتباره عملا إجرائيا، ويدخل في هذا الشكل وسيلة القيام به، والمظهر الخارجي له، والبيانات الواجب توافرها فيه. ولما كان الشكل عنصرا من عناصر الإعلان القضائي، فإنه يترتب على تخلف أو تعيب هذا الشكل بطلان الإعلان، إلا أن ذلك لا يعني أن توفر الشكل حتما يؤدي إلى صحة وقبول الإعلان، لأن الإعلان قد يكون باطلا رغم صحة الشكل وذلك حينما يتخلف عنه أحد مقتضياته الموضوعية، أو يكون هناك غش قد ارتكب في الإعلان.

وأشخاص الإعلان القضائي ثلاثة، هم^(١):

المحضر: وهو موظف عام له صلاحية في أداء الأعمال الموكولة إليه ولا يجوز لغيره القيام بالأعمال التي أناط القانون به القيام بها، وهو المختص دون غيره بالقيام بإعلان الأوراق القضائية، فلا يجوز أن يتم الإعلان بواسطة شخص آخر، بل لابد أن يتم بواسطة المحضر في الشكل المحدد قانونا. والمعلن (طالب الإعلان): وهو صاحب المصلحة في أن يصل إعلانه إلى خصمه وقد يكون المعلن هو المدعي، أو الطاعن، أو المرسل لإخطار أو تنبيه، أو طالب التنفيذ الذي يوجه إجراءات التنفيذ إلى المنفذ ضده، كما قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا. والمعلن إليه (المراد إعلانه): هو الشخص الذي يقوم المحضر بإعلانه، وقد يكون هو المدعي عليه نفسه، أو وكيله، أو نائبه، أو الممثل القانوني له.

بيانات ورقة الإعلان القضائي:

هناك ثلاثة مبادئ رئيسة تسيطر على بيانات ورقة الإعلان القضائي، وهذه المبادئ هي:

- مبدأ تكافؤ بيانات ورقة الإعلان القضائي: ومضمون هذا المبدأ أنه إذا خلت الورقة من بيان معين أو حدث نقص أو خطأ فيه، فإنه يجوز تصحيح هذا البيان أو تكملته ببيان آخر مرادف له وثابت في الورقة نفسها. ويشترط لإعمال هذا المبدأ توافر شرطين: الأول: أن يوجد بيان مرادف للبيان الناقص. الثاني: أن يكون البيان المرادف موجودا في نفس الورقة أو ورقة أخرى معلنة مع الورقة المعيبة.
- مبدأ شكلية الأوراق القضائية.
- مبدأ رسمية الأوراق القضائية (وقد سبق الحديث عن ذلك).

(١) د. نبيل إسماعيل عمر: قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص ٤٣٤.

ويوجب المشرع على المحضر أن يضمن ورقة الإعلان جميع البيانات التي ورد النص عليها في المادة التاسعة من قانون المرافعات، وهذه البيانات هي :

١- تاريخ الإعلان ووقته: ويقصد به بيان اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. ويعتبر هذا البيان جوهرياً، لأنه يتوقف عليه معرفة ما إذا كان الإعلان قد تم في الوقت المناسب لإجرائه أم لا. كما أنه من البيانات المهمة لأن من تاريخ الإعلان يبدأ سريان بعض المواعيد التي نص عليها قانون المرافعات كميعاد الحضور، و ميعاد الطعن في الأحكام، فإذا لم يذكر تاريخ الإعلان أو شاب البيان عيب، تبطل الورقة للنص على البطلان صراحة.

٢- طالب الإعلان: حيث يجب بيان اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته كذلك إن كان يعمل لغيره. وهذا البيان تتحدد شخصية المعلن لدى المعلن إليه فيتمكن من معرفة موطنه وما إذا كان يعمل باسمه أو باسم غيره للرد على إعلانه إذا رأى لذلك محلاً^(١) وتعتبر هذه البيانات كلا واحداً يكمل بعضها البعض الآخر، فلا يؤدي النقص أو الخطأ في بعضها إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخصية المعلن، لأن كل بيان من هذه البيانات ليس مقصوداً لذاته^(٢).

٣- المعلن إليه: وذلك ببيان اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم وقت الإعلان فأخر موطن كان له. والمعول عليه في هذا الصدد هو تحديد شخصية المعلن إليه تحديداً نافياً للجهالة أو الشك^(٣).

٤- بيانات خاصة بالمحضر: حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة مرافعات على "اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها" ونصت الفقرة السادسة من نفس المادة على "توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة". وبهذا يكون المشرع قد أوجب أن تشتمل ورقة الإعلان على اسم المحضر واسم المحكمة التابع لها وتوقيعه على كل من أصل الإعلان وصورته. وذلك لأن ذكر اسم المحضر يؤدي إلى التحقق من أن من قام بالإعلان له صفة القيام به، ويؤدي ذكر اسم المحكمة إلى التأكد من أن المحضر قام بعمله في حدود اختصاصه المكاني. وتوقيع المحضر على ورقة الإعلان هو الذي يضفي عليها صفة الرسمية، وعدم توقيعه على الإعلان يؤدي إلى بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

٥- بيانات مستلم صورة الإعلان: حيث أوجبت المادة (٥/٩) مرافعات أن تشتمل ورقة الإعلان على اسم وصفة من سلمت إليه الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

(١) د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص ٤٤٤.

(٢) د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ٣٦٢.

(٣) د. نبيل إسماعيل عمر: إعلان الأوراق القضائية، مرجع سابق، ص ٥٠.

والحكمة من اشتراط بيان اسم وصفة من سلمت إليه الصورة، هي التحقق من أن الصورة قد سلمت إلى أحد المذكورين في المادة العاشرة من قانون المرافعات ممن يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم، ويقصد بتوقيع من تسلم صورة الإعلان على الأصل أن يكون ذلك شاهداً (بل هو الشاهد الوحيد) على تسلمه الصورة وبالتالي تمام الإعلان^(١).
وعدم توقيع مستلم الإعلان على الأصل باستلام صورة الإعلان يرتب البطلان، ولا يكفي ولا يغني عن التوقيع أن يثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه خاطب الشخص وسلمه الصورة، بل لا بد من قيام المستلم بالتوقيع على أصل الإعلان بالاستلام^(٢).

٦- البيانات الأخرى التي لم يشتمل عليها نص المادة التاسعة مرافعات:

يرى فقهاء قانون المرافعات أن نص المادة التاسعة من قانون المرافعات لم يشتمل على كافة البيانات التي يجب أن تذكر في ورقة الإعلان، ذلك أن هناك بيانات أخرى لها من الأهمية ما يجعل ذكرها في ورقة الإعلان واجباً^(٣)، وهذه البيانات هي:

- موضوع الدعوى: حيث يرى بعض الفقه -وهو ما نؤيده- أن موضوع الدعوى أو موضوع الإعلان هو بيان جوهرى لا يتصور خلو الورقة منه وإلا انتفت المصلحة من الإعلان والحكمة منه. فالورقة يجب أن تتضمن موضوع الإعلان، كموضوع الطلب القضائي، سواء تعلق بطرح الادعاء لأول مرة أمام القضاء أم كان الموضوع يتعلق بطعن في حكم قضائي أو التظلم من أمر ولائي، ولا يكفي في إعلان الحكم القضائي أن تتضمن الورقة الإشارة إلى هذا الحكم، بل يجب أن ترفق صورة الحكم بها^(٤).

- الخطوات التي اتبعها المحضر في سبيل إتمام الإعلان: حيث يجب على المحضر أن يثبت في أصل الورقة وصورتها نشاطه وهو بسبيل إعلان الأوراق القضائية، وهذا بيان جوهرى نصت عليه المادة (١١) مرافعات^(٥).

وفي هذا الصدد فإنه يجب على المحضر أن يثبت انتقاله إلى موطن المعلن إليه والوقت الذي انتقل فيه، فإذا كان المحل مغلقاً أثبت ذلك، فإذا لم يجده مغلقاً وجب عليه أن يذكر أنه سأل عن الشخص المراد إعلانه فوجده غائبا، وأنه تخاطب مع شخص له صفة في تسلم الإعلان، وعليه أن يثبت اسم ذلك الشخص، كما يجب عليه أن يحصل على توقيعه على الأصل، فإذا

(١) المستشار محمد نصر الدين كامل، مرجع سابق، ص ٤٠.

(٢) د. نبيل إسماعيل عمر: إعلان الأوراق القضائية، مرجع سابق، ص ٥٥.

(٣) د. نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، ص ٥٦.

(٤) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٥٠٢.

(٥) د. نبيل إسماعيل عمر: إعلان الأوراق القضائية، مرجع سابق، ص ٥٦.

امتنع عن التوقيع على الأصل أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يبين ذلك، ثم يثبت انتقاله إلى جهة الإدارة لتسليم صورة الإعلان ووقت هذا الانتقال وإخطار المعلن إليه بذلك في خطاب مسجل، إلى غير ذلك من الخطوات.

ثانيا: أحكام عامة في إعلان الأوراق القضائية:

أ- الإعلان بواسطة المحضرين:

القاعدة العامة في إعلان الأوراق القضائية أن يتم بواسطة المحضرين أو عن طريقهم، ووفقا لنص المادة السادسة مرافعات فإنه يجب أن يقوم المحضرون بإعلان الأوراق القضائية، حيث يبطل إعلان صحيفة الدعوى إذا تم بواسطة غيرهم، ولو كان من قام بالإعلان هو أحد الموظفين العموميين كرجال الشرطة^(١).

ويتم الإعلان عن طريق المحضر أيا كان طالب الإعلان، أي سواء كان الإعلان بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو المحكمة، ويعد الإعلان بواسطة المحضرين شرطا شكليا في شخص القائم بالعمل، بحيث إذا تم الإعلان بمعرفة غيره وقع باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام. ولا يكفي لصحة الإعلان أن يكون القائم به أحد المحضرين، وإنما يجب فضلا عن ذلك أن يكون هذا المحضر مختصا بإجرائه وفقا لاختصاصه المكاني في المحكمة التي يعمل بها.

ووفقا للمادة الثامنة مرافعات، يجوز للمحضر أن يمتنع عن القيام بالإعلان إذا تراءى له ما يبرر ذلك، كما إذا كانت الأوراق المطلوب إعلانها خالية تماما من البيانات اللازمة، أو كانت ناقصة على نحو يخل بمهمة المحضر، أو شاب البيانات غموض أو إبهام أو تجهيل، وكذلك إذا اشتملت الأوراق المطلوب إعلانها على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

وفي مثل هذه الحالات يجب على المحضر عرض الأمر فوراً على قاض الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. ولطالب الإعلان أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب.

ب - إجراء الإعلان في الأوقات الرسمية:

نصت المادة السابعة من قانون المرافعات على أنه: "لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية".

(١) د. عبد الباسط جمعي، مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي، ١٩٨٠م، ص ٤١٢.

والحكمة من حظر تسليم صورة الإعلان في هذه الساعات أو تلك الأيام: هي الرغبة في عدم الازعاج في تلك الساعات التي يفترض ألا تكون ساعات عمل، بل ساعات راحة، وكذلك في أيام العطلات الرسمية التي لا تكون أيام عمل بل أيام راحة أيضاً.

ولذلك فإنه إذا حاول المحضر مباشرة الإعلان في وقت من الأوقات المحظور الإعلان فيها فرفض المعلن إليه تسليم الإعلان، فلا يعد ذلك امتناعاً عن تسليم الإعلان، ولا يحق للمحضر في هذه الحالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة، فإن فعل ذلك كان الإعلان باطلاً، كما أن الإعلان الذي تسلم صورته في هذه الساعات أو تلك الأيام المحظور الإعلان فيها يكون باطلاً، سواء في ذلك أن يتم الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه في غيبته^(١).

ويستثنى من الحظر السابق: إجراء الإعلان في حالات الضرورة بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقفية، فإذا توافر هذين الشرطين فإن المشرع يجيز إجراء الإعلان في الساعات أو الأيام التي نص على حظر الإعلان فيها في المادة السابعة.

الفصل الثاني

كيفية الإعلان القضائي

أولاً: إعلان الشخص الطبيعي:

نصت المادة (١٠/١) مرافعات على أنه "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون". ووفقاً لهذا النص فإن إعلان الشخص الطبيعي يتم على النحو الآتي:

أ- الإعلان لشخص المعلن إليه:

لا شك أن أفضل وسيلة لعلم المعلن إلية بمضمون الإعلان أن يسلم الإعلان له شخصياً، لذلك فإن على المحضر أن يسعى إلى تسليم الإعلان للمعلن إليه شخصياً - سواء في موطنه أو في أي مكان آخر يجده فيه - فإذا تعذر عليه الإعلان لشخص المعلن إليه فيجوز إعلانه في موطنه. ومن ثم فإن الأصل للعلم الفعلي هو إعلان الأوراق القضائية إلى شخص المعلن إليه، لأن هذا الإعلان هو الذي يضمن وصول الورقة إلى علم المعلن إليه فعلاً.

ولا يوجد التزام على المحضر بأن يبدأ بالإعلان الشخصي أولاً، ثم يلجأ بعد ذلك إلى موطن المعلن إليه إن لم يتمكن من إعلانه لشخصه، وإنما يكون للمحضر أن يلجأ مباشرة إلى موطن المعلن إليه.

(١) المستشار. محمد نصر الدين كامل، مرجع سابق، ص ١١٦.

ب-الإعلان في الموطن:

إذا تعذر على المحضر تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه، جاز إعلانه في موطنه لأحد الأشخاص الذين منحهم القانون صفة في تسلم الإعلان^(١). ووفقا لنص المادة (٢/١٠) مرافعات فإنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار".

وإذا تم الإعلان في موطن المعلن إليه متفقا مع الإجراءات والشروط التي أوجبها المشرع في هذا الإعلان، فإن الإعلان في الموطن يعد قرينة قانونية قاطعة على علم المعلن إليه بمضمون الإعلان، إلا أن المشرع وحرصا على سلامة الإجراءات وصحتها وعلى مصلحة المعلن إليه، أوجب في هذا الإعلان توافر مجموعة من الضمانات والشروط، وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: أن يتم الإعلان في موطن المعلن إليه:

الإعلان في الموطن جائز -كقاعدة عامة- ما لم ينص المشرع على ضرورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وغالبا ما يتم الإعلان في موطن المعلن إليه، لأنه لا يقتضي من المحضر التحقق من شخصية من تسلم له الورقة، إذ يكفي لصحة الإعلان أن يقرر من يتسلم الورقة صفة تخول له تسلمها، ولو لم تكن هذه الصفة حقيقية^(١).

والمشرع يجيز دائما الإعلان في الموطن، بل يجعله قاعدة عامة، فلا يوجد التزام على المحضر أن يبدأ أولا بالإعلان الشخصي؛ وإنما له أن يعتمد مباشرة إلى موطنه ويسلمه الإعلان إن كان موجودا، أو يسلمه لأحد ممن لهم صفة في استلام الإعلان إن لم يكن المعلن إليه موجودا، وبذلك يساوى المشرع المصري بين الإعلان في الموطن والإعلان لشخص المعلن إليه.

الشرط الثاني: أن يتم تسليم الإعلان لأحد المذكورين في المادة العاشرة مرافعات:

حيث أوجب القانون توفر صفة خاصة فيمن يتسلم الإعلان تخوله تسلمه، وقد ذكر المشرع -على سبيل الحصر- الأشخاص الذين يمكن تسليم الإعلان لأحدهم في موطن المعلن إليه، وهم: الزوج والأقارب والأصهار والخدم والوكيل؛ فيجوز تسليم الإعلان للزوج أو لأحد أقاربه سواء من الأصول كالأب والجد أو من الفروع كالابن وابن الإبن، أو من الحواشي كالأخ والعم، وذلك دون اشتراط درجة قرابة معينة، حيث يجوز تسليم الإعلان لأي قريب منهم مهما بعدت القرابة بينه وبين المعلن إليه، كما يجوز تسليم الإعلان لأحد الأصهار كأب الزوجة أو أخيها أو عمها.

(١) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: قانون المرافعات، الجزء الثاني، ٢٠١٠ م، ص ٤٧-٤٨.

(١) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٣٤٠.

كما يجوز تسليم الورقة إلى من يقرر أمام المحضر أنه وكيل المراد إعلانه أو أنه يعمل في خدمته، ولا يلزم أن يتحقق المحضر من الصفة التي تذكر أمامه، لأن المعلن إليه هو المسئول عما يتواجد في موطنه^(١)، فإذا كان ما تقرر أمام المحضر غير صحيح؛ فلا مسئولية على المحضر لأنه غير مكلف بالتحقق من ذلك، ويشترط لصحة الإعلان لشخص آخر غير المعلن إليه أن يبين المحضر صفة من تسلم الإعلان، وعلاقته بالمعلن إليه والتي تجيز له تسلم الإعلان نيابة عنه، فإذا لم يثبت المحضر ذلك كان الإعلان باطلاً.

الشرط الثالث : أن يكون الزوج أو القريب أو الصهر ساكناً مع المعلن إليه:

اشتراط القانون فيمن يتسلم الورقة من هؤلاء أن يكون ساكناً مع المعلن إليه، أي مقيماً معه. وشرط السكن أو الإقامة شرط جوهري يترتب البطلان على تخلفه، لذلك يلتزم المحضر في هذه الحالة بأن يذكر في الورقة صفة من تسلمها وإقامته مع المعلن إليه^(٢). وتبدوا أهمية هذا الشرط في أن الإقامة هنا هي الضمان لوصول الإعلان لصاحبه، على أساس أن المساكنة تضمن اللقاء المستمر بين المعلن إليه وقريبه المقيم معه ليسلمه الإعلان، فإذا كان القريب غير مقيم، فلا يجوز تسليم الإعلان إليه ما لم يكن خادماً أو وكيلاً^(٣).

الشرط الرابع: ألا يكون المعلن إليه موجوداً في موطنه وقت تسليم الإعلان:

يشترط لصحة الإعلان في الموطن، ألا يكون المعلن إليه موجود شخصياً في موطنه وقت تسليم الإعلان لشخص غيره ممن ورد النص عليهم في المادة العاشرة. وعلى المحضر أن يدون في أصل الإعلان أنه لم يجد المعلن إليه في موطنه فقام بتسليم الإعلان إلى الشخص الذي تسلمه. أما إذا انتقل المحضر إلى موطن المراد إعلانه ووجده حاضراً، فإنه يجب تسليم صورة الإعلان إليه نفسه، أو إثبات امتناعه عن ذلك، واتباع الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ج- الإعلان في جهة الإدارة^(٤):

توقع القانون حالات يصادفها المحضر عند الإعلان القضائي تحول دون إتمامه لشخص المعلن إليه أو في موطنه، فأوجب عليه فيها إعلانه في جهة الإدارة، وفي هذه الحالة فإن المشرع

(١) د. خيري عبدالفتاح: الإعلان القضائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الزقازيق، ص ٢٢١.

(٢) د. أمينة مصطفى النمر: الدعوى وإجراءاتها، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص ٢٨٢-٢٨٣.

(٣) د. عبدالباسط جميعي، مرجع سابق، ص ٤١٣.

(٤) المقصود بجهة الإدارة وفقاً للمادة (١/١١) من قانون المرافعات: مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال، ذلك أن الغرض من تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة هو أن تتولى هذه الجهة تسليمها للمطلوب إعلانه.

يعتد بالإعلان من وقت تسليم الصورة لجهة الإدارة. حيث تقرر المادة (١١) مرافعات أن الإعلان يعتبر منتجا لآثاره القانونية من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا. ولكن المشرع أوجب توافر مجموع من الضمانات في هذا الإعلان- الإعلان في جهة الإدارة- فإذا توافرت هذه الضمانات كان ذلك قرينة على العلم بالإعلان. وإذا تخلفت هذه الضمانات أو إحداها فلا مجال للعمل بهذه القرينة، بل يكون الإعلان باطلا ولا يرتب أثرا وتبطل جميع الإجراءات التالية له والمبنية عليه.

ويشترط لصحة الإعلان في جهة الإدارة توافر عدة شروط ، هي^(١):

- ١- أن تتوافر حالة من الحالات التي يجب على المحضر فيها الإعلان في جهة الإدارة وهي: عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه سواء في الموطن الأصلي أو الموطن المختار، أو امتناع المراد إعلانه عن تسلم الإعلان. أو امتناعه عن التوقيع على أصل الإعلان باستلام صورته، أو غلق المسكن أو المحل المختار، أو الامتناع عن ذكر الاسم والصفة.
- ٢- أن يسلم المحضر ورقة الإعلان لجهة الإدارة في ذات اليوم الذي حاول فيه تسليم الصورة. وذلك حتى لا تتراخى إجراءات الإعلان وآثاره لسبب لا دخل لطالب الإعلان فيه.
- ٣- أن يقوم المحضر بتوجيه خطاب موصى عليه إلى المعلن إليه يخبره فيه بتسليم الإعلان لجهة الإدارة، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الإعلان. ولو كان المعلن إليه قد رفض تسلم الإعلان، وذلك لإحاطته بوجود الإعلان في جهة الإدارة فيسعى إلى استلامه. فإذا لم يتم إرسال الخطاب كان الإعلان باطلا.
- ٤- أن يذكر المحضر جميع الخطوات التي قام بها لتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة.

د- الإعلان إلى النيابة العامة:

يجب تسليم الإعلان إلى النيابة العامة في حالتين، هما:

الحالة الأولى: إعلان من له موطن معلوم في الخارج :

إذا لم يكن للمعلن إليه موطن في مصر، ولكن له موطن معلوم في الخارج، سلمت صورة الإعلان للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضا في هذه الحالة، وبشرط المعاملة بالمثل، تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه. (مادة ٩/١٣) مرافعات.

(١) د. أحمد هندي: أصول قانون المرافعات، ص ٣٠٨- د. أمينة مصطفى النمر: الدعوى وإجراءاتها، منشأة المعارف،

ص ٢٥٨ - د. نبيل إسماعيل عمر: قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص ٤٤٦.

ويجب لصحة الإعلان في هذه الحالة أن يتضمن بياناً لموطن المراد إعلانه بالخارج، بحيث تستطيع وزارة الخارجية أن تسلمه للمعلن إليه.

على أنه إذا تواجد المعلن إليه في مصر وقت الإعلان وكان موطنه في الخارج، فإنه يجوز إعلانه لشخصه طبقاً للقاعدة العامة في الإعلان القضائي، كما أنه إذا كان للشخص موطن أصلي في مصر فإنه يجب إعلانه فيه ولو كان يقيم بالخارج وقت توجيه هذا الإعلان ما دام لم تشمل الأوراق على ما يفيد أنه غير موطنه بصفة نهائية ونقله إلى الخارج، وإذا كان للشخص موطن مختار في مصر بالنسبة للعمل المعلن، فإنه يتم إعلانه به في موطنه المختار.

وضمامنا للوصول خبر الإعلان إلى المعلن إليه^(١)، أوجب القانون على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى من الإعلان، ويخبره فيه أن الصورة المعلنه سلمت للنيابة العامة.

ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة، ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج، أو توقيعه على علم الوصول الخاص بالخطاب الموصى عليه أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

الحالة الثانية: إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم:

إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم، وجب أن تشمل الورقة المعلنه على آخر موطن معلوم له في الجمهورية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة العامة (مادة ١٣/١٠) مرافعات. ويشترط لصحة الإعلان للنيابة في هذه الحالة شرطين:

الأول: أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم لطالب الإعلان رغم القيام بكافة التحريات اللازمة للتقصي عنه، فيجب أن يكون طالب الإعلان غير عالم لموطن المطلوب إعلانه سواء في مصر أو في الخارج، فإن كان يعلم له موطن فلا يصح الإعلان للنيابة العامة، كما لا يصح الإعلان للنيابة إذا كان للمعلن إليه موطن مختار، إذ يصح إعلانه في هذا الموطن ولو كان المطلوب إعلانه قد غيره دون إخطار طالب الإعلان. ويعتبر في حكم صاحب الموطن غير المعلوم من لا موطن له أصلاً كما هو الحال بالنسبة للبدو الرحل^(٢).

والثاني: أن تشمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم للمعلن إليه، سواء كان هذا الموطن في مصر أو في الخارج.

(١) أستاذي د. حامد أبو طالب: محاضرات في قانون المرافعات، الكتاب الثاني، ص ٤٩٥.

(٢) د. أحمد هندي: قانون المرافعات، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ١١٠.

هـ - أفراد القوات المسلحة، وبحارة السفن التجارية والعاملين فيها، والمسجونين: أخرج المشرع إعلان هؤلاء الأشخاص من نص المادة العاشرة مرافعات بحيث لا يصح الإعلان لكل منهم إلا إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة إليه، ومرجع ذلك ظروفهم الخاصة^(١)، وذلك على النحو الآتي:

١- إعلان أفراد القوات المسلحة:

ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم الإعلان بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة (مادة ٦/١٣) مرافعات.

"ويشمل تعبير أفراد القوات المسلحة كل من ينخرط في صفوفها، رجلاً أو امرأة، سواء كان محترفاً أو متطوعاً أو مجنداً بصفة مؤقتة كمن يقضي فترة التجنيد الإلزامية والمستدعى من الاحتياط للتدريب الدوري أو لإعلان حالة الطوارئ، ويأخذ حكم هؤلاء موظفو المصالح العسكرية التابعة لوزارة الحربية من العسكريين والمدنيين"^(٢).

ويرتب الإعلان القضائي أثره في هذه الحالة من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى الإدارة القضائية المختصة، ويبطل الإعلان إذا لم يبين في أصله وصورته أن الصورة سلمت إلى الإدارة القضائية المختصة.

٢- إعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها:

وفقاً لنص المادة (٨/١٣) مرافعات، فإنه إذا تعلق الإعلان ببخارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها، فإنه يسلم للربان. فيسري النص على العاملين في السفينة سواء كان من البحارة أم لا، وينطبق على السفن الراسية بالموانئ المصرية، سواء كانت هذه السفن مصرية أم أجنبية، وعلة هذا النص هو عدم جدوى الإعلان في الموطن في غالب الأحيان، والرغبة في عدم الإخلال بنوبات العمل في السفينة التي تتأثر بتسليم الصورة مباشرة من المحضر للمطلوب إعلانه أثناء عمله بالسفينة، فضلاً عن ضمان وصول الإعلان للمطلوب إعلانه ولو كان قد غادر السفينة إلى الميناء^(٣).

ويصح إعلان أحد هؤلاء إذا تسلم الإعلان شخصياً، كما يسقط حقه في التمسك ببطلان الإعلان إذا حضر الجلسة.

(١) د. أحمد السيد صاوي: شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٥٤٢.

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٥٤٤.

(٣) د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة، ج ١/٥٢٤.

٣- إعلان المسجونين:

إذا كان المطلوب إعلانه مسجوناً، فإن صورة الإعلان تسلم إلى مأمور السجن أو مديره، أو من يقوم مقامه، إذ لا جدوى من إعلان المسجون في موطن مع عدم وصول الإعلان إليه، كما أنه يتعذر إعلان المسجون لشخصه وهو في السجن.

وإذا سلمت صورة الإعلان لمأمور السجن على هذا النحو، فإن الإعلان ينتج أثره من وقت تسليم الإعلان إليه، ولا عبرة بوقت تسليم صورة الإعلان من المأمور إلى المسجون، ولا بما إذا كان لم يسلمها إليه.

و- عدم تمكن المحضر من تسليم الإعلان:

في جميع الحالات، إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصل الإعلان باستلام الصورة، أو امتنع عن استلام صورة الإعلان، أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة، وتسلم الصورة للنياية العامة (الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ مرافعات).

ثانياً: إعلان الشخص الاعتباري:

يبين من نص المادة (١٣) مرافعات أن المشرع فرق في شأن إعلان الأشخاص الاعتبارية بين الأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك على النحو الآتي:

أ- إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة:

١- إعلان الدولة: فيما يتعلق بالدولة تسلم صورة الإعلان للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين، أو لمن يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها (مادة ١/١٣ مرافعات). فالمشرع فيما يتعلق بالأوراق المعلنة للدولة بين فرضين: الأول: إذا كانت هذه الأوراق هي صحف الدعاوى والطعون والأحكام، فهذه تسلم إلى إدارة قضايا الدولة سواء في المأمورية التي يدخل الإعلان في اختصاصها المحلي أو في الإدارة بالقاهرة^(١). وذلك حتى تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات في الوقت المناسب حفظاً لمصالح الشخص الاعتباري العام وصوناً لحقوقه من الضياع^(٢). وإذا ما تعدد المعلن إليهم من الوزراء والمحافظين وتعددت بالتالي فروع هيئة قضايا الدولة جاز الإعلان لأي فرع من فروع الإدارة.

(١) نقض ١٩٦٣/١/٣١ سنة ١٤ ص ٢٠٢.

(٢) د. رمزي سيف، مرجع سابق، بند ٣٨٢.

والثاني: إذا كانت الأوراق المعلنة غير ذلك، كالإنذارات ومحاضر الحجز، فإنها تسلم إلى ممثل الشخص الاعتباري في مقره، ويعد الوزير صاحب الصفة في تمثيل المصالح التابعة لوزارته^(١).

٢- إعلان الأشخاص العامة: إذا كان الإعلان متعلقاً بالأشخاص العامة، فإنه يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه، فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها (مادة ٢/١٣ مرافعات).

وهنا أيضاً نجد أن المشرع فرق بين فرضين أو نوعين من الأوراق المعلنة كما هو الشأن في إعلان الدولة، فجعل الاختصاص باستلام صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، لهيئة قضايا الدولة، أما غير ذلك من الأوراق المعلنة فتسلم للنائب قانوناً عن الشخص العام. "والأشخاص العامة هي التي تباشر مرفقاً من مرافق الدولة، ولها كيان مستقل، فهي معتبرة من الأشخاص المعنوية في القانون العام، والمقصود بالأشخاص الاعتبارية العامة التي تسلم صور صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بها إلى إدارة قضايا الدولة هم الأشخاص التي تنوب عنها هذه الإدارة طبقاً لقانونها، فلا يسري حكم هذا البند بالنسبة إلى غير هذه الأشخاص كالمؤسسات العامة"^(٢). ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره القانونية بتسليم صورته لهيئة قضايا الدولة، ولا حاجة بعد ذلك لقيام المحضر بإخطار الجهة المعلن إليها بأن صورة الإعلان قد سلمت في هيئة قضايا الدولة^(٣).

ب- إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة:

والمقصود بها الشركات والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة:

١- إعلان الشركات التجارية:

تسلم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، فإذا لم يكن للشركة مجلس إدارة سلمت الصورة لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

٢- إعلان الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية:

تسلم صورة الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها أو نظامها، أو لمن يقوم مقامه، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

(١) نقض: الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٤٥ قضائية - جلسة ١٩٧٦/٣/٢٢.

(٢) د. أحمد مليحي: الموسوعة الشاملة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ٥١٢.

(٣) د. فتحي والي: الوسيط في قانون القضاء المدني، ص ٤٥١.

٣- إعلان الشركات الأجنبية: نفرق بين حالتين:

الأولى: إذا كان للشركة فرع أو وكيل في مصر، وكان الإعلان يتعلق بهذا الفرع أو الوكيل، فتسلم صورته إلى هذا الفرع أو الوكيل.

ولا يقصد من جواز إعلان الشركة الأجنبية لدى فرعها أو وكيلها في مصر حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي في الخارج، وإنما قصد به التيسير عليه، ومن ثم يكون له إعلان الشركة الأجنبية في مركزها الرئيسي في الخارج رغم أن لها فرعاً في مصر^(١). ويشترط لصحة الإعلان في فرع الشركة أو الوكيل في مصر، أن يتعلق بنشاط الفرع أو الوكيل بها^(٢).

الثانية: إذا لم يكن للشركة الأجنبية فرع أو وكيل في مصر، فيتم إعلانها عن طريق النيابة العامة، وفقاً للقواعد المعمول بها في شأن من له موطن معلوم في الخارج^(٣).

إنعقاد الخصومة بإعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى:

إعلان صحيفة الدعوى شأنه شأن إعلان كافة أوراق المحضرين، قد يتم لشخص المعلن إليه، أو في موطنه^(٤)، وهذا الإعلان إجراء منفصل عن الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته. فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى، كان ذلك كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم، وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو لم يمثل أصلاً.

وقد نص المشرع في المادة (٨٤) مرافعات على أنه إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى. إذ جعل المشرع من إعلان الصحيفة لشخص المدعى عليه قرينة على علمه بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها، وأوجب على المحكمة في هذه الحالة نظر الدعوى دون الالتفات إلى غياب المدعى عليه ما دامت قد تحققت من صحة إعلانه لشخصه.

(١) د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ١٥١.

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٥٥١.

(٣) ذلك أنه في جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة (الفقرة الأخيرة للمادة ١٣ مرافعات).

(٤) ويراعى الحالات التي يتم الإعلان فيها لجهة الإدارة، أو في النيابة العامة، وإعلان أفراد القوات المسلحة، والبحارة، وغيرهم.

وبالتالي فإذا غاب المدعى عليه وكان إعلان الصحيفة قد سلم لشخصه، وكان صحيحا، فعلى المحكمة أن تحكم في الدعوى دون حاجة إلى إعادة إعلانه^(١)، لأن تسليم الإعلان لشخص المدعى عليه قرينة على العلم الفعلي بالدعوى المرفوعة ضده، فلا يكون لغيابه في هذه الحالة مبرر.

تأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلان المدعى عليه:

إذا تحقق العلم الفعلي للمدعى عليه برفع الدعوى؛ فإن المحكمة لا تلتزم بالتأجيل لجلسة تالية، ويتحقق العلم الفعلي إذا كان المدعى عليه قد حضر أية جلسة من الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه، أو كان قد أعلن لشخصه، فإذا لم يكن أعلن لشخصه، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وتختلف عن حضور الجلسة الأولى، فإنه يجب على المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه (مادة ٨٤ مرافعات)^(٢).

والحكمة من تأجيل نظر القضية وإعادة الإعلان في حالة غياب المدعى عليه وحده، هو تحقق ضمانات إضافية لحضوره لتمكينه من حقوق الدفاع، وقد يكون معذورا في غيابه لعدم علمه الفعلي بالدعوى^(٣). لأن الراجح في هذه الحالة أن الدعوى لم تصل إلى علمه^(٤). وفي هذه الحالة لا يلزم إعادة إعلان صحيفة الدعوى كاملة -لأنها قد أعلنت صحيحة من قبل- وإنما يكفي إعادة الإعلان بورقة تكليف بالحضور إلى الجلسة الجديدة، وفي الجلسة الجديدة بعد أن تتحقق المحكمة من إعادة الإعلان، تنظر الدعوى وتحكم فيها، ولو لم يحضر المدعى عليه إذ تعتبر الخصومة حضورية في حقه^(٥).

فالخصومة إذا تنعقد بالإعلان في حالتين: الأولى، أن يكون الإعلان قد تم صحيحا لشخص المعلن إليه، والثانية، أن يكون قد أعلن لغير شخصه إعلانين متتاليين، أي لا تنعقد الخصومة إلا بتمام إعادة الإعلان للمدعى عليه

(١) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات، ج٢/٧ - أستاذي د. حامد أبو طالب، محاضرات في قانون المرافعات، الكتاب الثاني، ص ٥٢٣.

(٢) نقض: الطعن رقم ٢٨٢٠٧٢٧ لسنة ٧٣ قضائية جلسة ٢٠٠٥/٢/٨ م.

(٣) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٥٣٠.

(٤) نقض: الطعن رقم ١٠٣٨٩ لسنة ٨١ قضائية - جلسة ٢٠١٢/٥/٢.

(٥) د. عبدالنواب مبارك، مرجع سابق، ص ٤٧٧.

فإذا لم يعلن المدعى عليه لشخصه وحكمت المحكمة في الدعوى بدون إعادة إعلانه فإن حكمها يكون باطلا ويجوز استئنافه ولو كان في حدود النصاب الانتهازي. (المستشار عز الدين الدناصوري و أ. حامد عكاز: التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٣٦٢).

الفرع الثاني

انعقاد الخصومة بحضور المدعى عليه الجلسة

إذا كانت الخصومة تنعقد بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه، على النحو السابق بيانه، فإنها تنعقد أيضاً بحضوره الجلسة. إذ نصت المادة (٣/٦٨) مرافعات على أنه "لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة"، كما نصت المادة (١١٤) على أنه "بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه". ووفقاً لهذه النصين فإننا نكون أمام فرضين :

الفرض الأول: حضور المدعى عليه بالجلسة إذا لم يكن أعلن بصحيفة الدعوى:

في هذا الفرض يكون حضور المدعى عليه بغير سبق إعلان، كما لو تحقق علمه بالجلسة والمحكمة التي تنظر الدعوى فيها بغير طريق الإعلان، بدليل حضوره. فهل يغني الحضور عن الإعلان الذي لم يتم أصلاً^(١)؟

نرى أن الحضور المطلق تنعقد به الخصومة دون قيد أو شرط أو ضابط، وذلك لصراحة نص الفقرة الثالثة من المادة (٦٨) مرافعات والتي لم تتطلب سوى الحضور المطلق دون تعليق ذلك على تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان.

الفرض الثاني: حضور المدعى عليه بالجلسة بناء على إعلان باطل :

إذا كانت القاعدة أن بطلان صحيفة الدعوى يخضع للقواعد العامة في البطلان، فإن المشرع أورد حكمين خاصين من شأنهما تعديل نطاق البطلان في صحف الدعاوى كأثر لحضور المدعى عليه أو لغيابه^(٢)، يتعلق الأول منهما بالحضور المزيل للبطلان، والثاني بغياب المدعى عليه الموجب لإعادة إعلان صحيفة الدعوى.

الحضور المصحح للبطلان :

إذا أعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى وكانت الصحيفة باطلة أو كان إعلانها باطلاً، أو كانت ورقة التكليف بالحضور باطلة لعيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة، فإن حضور المعلن إليه يصحح هذا البطلان، وهذا تحديد لنطاق قاعدة تصحيح البطلان بالحضور.

(١) د. طلعت محمد دويدار: (الإعلان القضائي بين قيمة الوقت في الدعوى ومبدأ سلطان الإرادة في الخصومة، منشأة المعارف بالإسكندرية، ٢٠٠٣ م، ص ٤٥.

(٢) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ٣٩.

ونطاق تطبيق نص المادة (١١٤) مرافعات ينحصر في الإعلان الذي يتضمن تكليفا بالحضور، وهو لا يتناول كافة العيوب التي يمكن أن تشوب هذا الإعلان وإنما العيوب التي ذكرت فيه^(١).

وحكمة نص المادة (١١٤) مرافعات أن الغرض من إعلان صحف الدعاوى وورقة التكليف بالحضور واشتمالها على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون واستيفائها للأوضاع القانونية هو دعوة المعلن إليه إلى الحضور أمام محكمة معينة في تاريخ معين، فإذا ما حضر بالفعل في الزمان والمكان المعينين لحضوره فقد تحقق بالفعل الغرض المقصود من الورقة. ويكون الحكم ببطلانها من قبيل المغالاة في التمسك بالشكلية^(٢). وزوال العيب في هذه الحالة قائم على أن هناك وقائع حددها المشرع ويعتبر حدوثها قرينة على تنازل الخصم عن البطلان. ومن هذه الوقائع واقعة الحضور بناء على إعلان باطل^(٣).

حضور المدعى عليه بالجلسة قرينة على تحقق الغاية من الإعلان :

إذا حضر المدعى عليه بالجلسة رغم بطلان صحيفتها أو بطلان إعلانه بها، فإن هذا الحضور يصحح البطلان باعتباره قرينة على العلم الفعلي يتحقق به الغاية التي استهدفها المشرع من إعلان صحيفة الدعوى ومن تكليف المدعى عليه بالحضور، كما أنه قرينة على تنازل المدعى عليه عن التمسك بالبطلان، لأن المدعى عليه لو شاء أن يتمسك بالبطلان لما حضر الجلسة. وإنما كان باستطاعته أن يتغيب عن الجلسة ثم يدفع بعد ذلك ببطلان الصحيفة أو بطلان إعلانه أو تكليفه بالحضور.

إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه:

إذا أودع المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا لما أوجبه المشرع في المادة (٤/٦٥) مرافعات ، فإن هذا الإيداع يعد قرينة قاطعة على علمه - الفعلي - بالدعوى، وتمكنه من الدفاع^(٤). وبالتالي لا يقبل منه بعد ذلك الادعاء بعدم العلم بالدعوى أو بالجلسة المحددة لنظرها، سواء حضر بالجلسة الأولى أو لم يحضرها، وسواء أعلن بالدعوى أو لم يعلن بها، لأن إيداع المذكرة في هذه الحالة يقوم مقام الحضور^(٥).

(١) د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٦٤٨ .

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ١٠٧٣/٢ .

(٣) د. أيمن أحمد رمضان، الجزء الإجرائي في قانون المرافعات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ، ٢٠٠٣ م، ص ٣٩٥ .

(٤) د. إبراهيم نجيب سعد، ص ٧٠ - د. وجدي راغب فهي، ص ٥٣١ .

(٥) د. فتحي والي، الوسيط، ص ٥١٩ .

ويترتب على ذلك أثر هام ورد النص عليه في المادة (١/٨٣) مرافعات، بنصها على أنه "إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك". فالمرشح أوجب على المحكمة بناء على هذه القرينة أن تنظر الدعوى ولو لم يحضر المدعى عليه في الجلسة وتعتبر الدعوى حضورية في حقه. كما يترتب على تقديم المذكرة أثر آخر يتعلق بتصحيح بطلان صحف الدعوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة ، إذ يزول هذا البطلان بإيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه (مادة ١١٤ مرافعات) .

حضور المدعى عليه أمام الخبير أو تقديم مذكرة بدفاعه :
تعتبر الدعوى حضورية في حق المدعى عليه إذا حضر أمام الخبير أو قدم له مذكرة بدفاعه، ويعد ذلك قرينة على علمه الفعلي بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها.

الفصل الثاني

إجراءات نظر الدعوى

قلنا إن الدعوى ترفع ابتداء بصحيفة تسمى صحيفة الدعوى، ويجب أن تشتمل على بيانات محددة، ويتم إيداعها قلم الكتاب وفقا لإجراءات محددة، ولا بد لانعقاد الخصومة من إعلان صحيفتها إلى المدعى عليه خلال مدة محددة؛ فإذا ما أودعت الصحيفة وأعلنت وفقا لهذه الإجراءات؛ انعقدت الخصومة أمام المحكمة، وأصبح من الواجب عليها أن تنظرها وتفصل فيها. وتنظر الدعوى في جلسة أو جلسات، حسب طبيعتها وما يستلزمه الفصل فيها، والجلسة هي فترة زمنية يجلس فيها القاضي في قاعة بمني المحكمة التي أقيمت ورفعت الدعوى أمامها، ويساعد القاضي كاتب (أمين سر) يحرر محضرها ويوقعه مع القاضي، ويتحدد زمانها بالفترة الزمنية التي يستغرقها نظر الدعوى، ومكانها بالمقر الذي يتم فيه مرور هذه الفترة الزمنية، وتبدأ إجراءاتها بإثبات كل ما يدور فيها، في محضر يسمى محضر الجلسة، أول ما يثبت فيه حضور الخصوم أو غيابهم، وتمثيلهم القانوني، أو الوكالة بالخصومة، إن وجد هذا أو ذاك، ثم يبدأ القاضي بعد ذلك في إثبات ما يبديه الخصوم من طلبات ودفع وأوجه دفاع، وما يقدمونه من مذكرات أو مستندات، وقد يطلب الخصوم تأجيل نظر الدعوى، فيستجيب القاضي أو لا يستجيب لذلك حسبما يراه محققا للعدالة، وحين يرى القاضي أن الدعوى أصبحت صالحة للفصل فيها، فإنه يحجزها للحكم، بإقفال باب المرافعة فيها، وقد يعيدها للمرافعة بعد ذلك بفتح باب المرافعة متى رأى مبررا لذلك، وقد يتفق الخصوم قبل حكم القاضي في الدعوى على إنهاؤها صلحا، فيتبع ما قرره القانون في ذلك^(١).

المبحث الأول

إجراءات الجلسات وحضور الخصوم وغيابهم

المطلب الأول

إجراءات الجلسة

نظرا لأهمية الجلسة باعتبارها الزمان والمكان الذي يتجادل فيه الخصوم ويتناضلون فيها لإثبات حقوقهم والدفاع عنها، فيقرعون الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان حتى تنجلي الحقيقة أمام القاضي، ليفصل في الخصومة بقرار قضائي يحقق استقرار المراكز القانونية، فإن المشرع

(١) في هذا المعنى: المستشار. سيد حسن البغال، المطول، مرجع سابق، ص ٦٩٧-٦٩٨.

أوجب في شأنها قواعد تكفل احترامها واحترام ما يدور فيها، وأناط برئيسها سلطات ضبطها وإدارتها، وأوجب تدوين ما يدور فيها في محضرها، كما أوجب أن تجرى -كقاعدة عامة- في علانية، وأن يسبقها تحضير الدعوى وتجهيزها لتتم المرافعة في أول جلسة. ونبين ذلك فيما يأتي:

أولاً: سلطات رئيس الجلسة في ضبطها وإدارتها:

خول المشرع - في المواد ١٠٤-١٠٧ مرافعات- لرئيس الجلسة سلطات واسعة في ضبطها وإدارتها، منها: أن يخرج كل شخص يخل بنظامها، فإن لم يمثل هذا الشخص وتمادى في إخلاله بالجلسة، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بإحدى عقوبتين: حبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو تغريمه مائة جنيه، والحكم الصادر بإحدى هاتين العقوبتين حكماً نهائياً.

ووفقاً لنص المواد المشار إليها، فإن سلطات رئيس الجلسة في إدارتها وضبطها، تتمثل في الآتي:

- ١- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة، أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مائة جنيه، ويكون حكمها بذلك نهائياً.

- ٢- فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، بشرط أن يتم توقيع الجزاء أثناء الجلسة وأن يثبت في محضرها.

- ٣- للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة الرجوع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين^(١).

- ٤- إذا وقعت جريمة أثناء انعقاد الجلسة فلرئيسها أن يأمر بتحرير محضر بشأنها، وبما يرى اتخاذ من إجراءات التحقيق، ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها

(١) تجب الإشارة إلى أن نص المادة ١٠٤ مرافعات لا ينطبق على المحامي إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستدعي مؤاخذه تأديبياً أو جنائياً، ذلك أن المحامي يخضع للقواعد الخاصة التي ورد النص عليها في المادة ١/٤٩ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، والتي جاء نصها على أن "للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات، والإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة، ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".

كما تنص المادة (٥٠) من ذات القانون على أنه "في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين الأول. ولا يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها".

- ٥- إذا كانت الجريمة التي ارتكبت أثناء انعقاد الجلسة جنائية أو جنحة كان لرئيس الجلسة أن يأمر بالقبض على من ارتكبتها وإحالته إلى النيابة العامة.
- ٦- إذا كانت الجريمة المرتكبة أثناء انعقاد الجلسة تمثل جنحة تعد على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد العاملين بها، فإن لها أن تحاكم المتعدي وتحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً، بشرط أن يتم ذلك في ذات الجلسة التي وقع فيها التعدي.
- ٧- للمحكمة أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور، ويتم تنفيذ الحكم الصادر في هذه الأحوال ولو تم استئنافه.
- ومناطق العقاب على شهادة الزور كون الشهادة قد أديت أمام القضاء بعد حلف اليمين وبقصد تضليله^(١)، وإذا كان الشاهد قد عدل بالجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره في شهادته الأولى وجاء عدوله بعد توجيه شهادة الزور وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى، فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة في القانون^(٢).

حجية الحكم الصادر وفقاً للمادة (١٠٤) مرافعات:

ووفقاً للمادة (١٠٤)، يكون للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته على من أخل بنظامها، فحجية الحكم هنا موقوفة أو معلقة على انتهاء الجلسة التي حدث الإخلال بنظامها، فإذا رجعت المحكمة أثناء انعقاد الجلسة عن الحكم الذي أصدرته بالحبس أو الغرامة زال الحكم ولم تكن له أية حجية. أما إذا انتهت الجلسة دون أن ترجع المحكمة عن حكمها الذي أصدرته، فإنه يحوز الحجية ولا يجوز لها بعد ذلك المساس بحجيتها والرجوع إليه أو تناوله بالتعديل أو الإلغاء، وإلا عد ذلك مساساً بحجية الحكم، وهو ما لا يجوز.

ثانياً: علانية الجلسات:

بينما عند حديثنا عن المبادئ التي يقوم عليها القضاء؛ أنه يجب بحسب الأصل أن تجرى الجلسة في علانية، ولا يجوز نظرها في سرية إلا في أحوال محددة، ومن ثم نحيل إلى ما سبق.

ثالثاً: محضر الجلسة:

نصت المادة (٢٥) مرافعات على أنه "يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان باطلاً". ووفقاً لنص هذه المادة فإن حضور الكاتب جلسة المحاكمة أمر لازم وضروري لا تصح الجلسة بغيره، ذلك أن استناد

(١) نقض جنائي ١٩٧١/٥/٢، سنة ٢٢ ص ٢٨٤.

(٢) نقض ١٩٥٥/٣/٣١، مجموعة النقض في ٢٥ سنة ج ٧٨٥/٢، قاعدة رقم ١٦.

الحكم إلى محضر جلسة لم يكتب بمعرفة الكاتب يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام. كما أنه يجب أن يحضر الكاتب مع القاضي في جميع إجراءات الإثبات ويحرر المحضر الذي يثبت هذا الإجراء ويوقع عليه مع القاضي: وإلا كان الإجراء باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام.

غير أنه تجب التفرقة في هذا الصدد بين محضر الجلسة الذي لم يكتبه الكاتب، وبين محضر الجلسة الذي لم يوقع عليه من القاضي أو الكاتب، فالأول يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام، أما الثاني فإنه يكون باطلا بطلانا غير متعلق بالنظام العام، ويجب على صاحب المصلحة التمسك به قبل مناقشة ما تضمنه هذا المحضر وإلا سقط حقه في طلب البطلان^(١).

محضر الجلسة محضر رسمي:

المقرر قانونا أن لكل جلسة محضر يدون فيه الكاتب ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها، واسم القضاة، واسمه، ورقم الدعوى والسنة التي قيدت فيها، ونوعها، وأسماء الخصوم وصفاتهم، وأسماء وكلائهم إن مثلوا بوكلاء عنهم، ثم كل ما أبداه الخصوم أو تقدموا به من مستندات أو مذكرات، إضافة إلى ما حدث من وقائع الجلسة، وأخيرا قرار المحكمة بشأن الدعوى، ثم يلي ذلك توقيع القاضي والكاتب على محضر الجلسة^(٢).

ووفقا لنص المادة (١٠) من قانون الإثبات فإن محضر الجلسة الذي يتم تحريره والتوقيع عليه من الكاتب يعتبر محررا رسميا ويكون ما أثبت فيه حجة على الخصوم^(٣) لا يجوز لهم إنكار ما أثبت فيه إلا بالطعن عليه بالتزوير^(٤).

رابعا: تحضير الدعوى:

أوجب المشرع في المادة (٣/٦٥) مرافعات، أن يودع المدعي قلم الكتاب مع صحيفة دعواه، أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسؤوليته، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه، كما أوجب على المدعى عليه في المادة ذاتها، أن يودع قلم الكتاب في جميع الدعاوى عدا المستعجلة، والتي أنقص ميعاد الحضور فيها، مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، أو صوراً منها، تحت مسؤوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق ج ١/٧٤٦- أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ١٦٩.

(٢) المستشار. سيد حسن البغال مرجع سابق، ص ٧٠١.

(٣) نصت المادة (١٠) إثبات على أن "المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه".

(٤) نصت المادة (١١) إثبات على أنه "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً".

وقصد المشرع من ذلك تهيئة الدعوى للفصل فيها فور عرضها على المحكمة، فلا يتأخر الفصل فيها بسبب تراخي الخصوم عن تقديم مستنداتهم وأدلتهم، بما يرتبه ذلك من إطالة أمد النزاع بلا مبرر وتعطيل الفصل في الدعوى.

غير أن مخالفة ما أوجبه المشرع في هذه المادة من تقديم المستندات لا يترتب عليه ثمة بطلان، سواء في ذلك تراخي المدعي عن تقديم مستنداته وأدلتها، أو تراخي المدعى عليه. وكل ما في الأمر أن المشرع أوجب في المادة (١/٩٧) مرافعات، أن تجرى المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (٦٥)، فإن المحكمة في هذه الحالة تفرق بين أمرين، أولهما: إذا كان قبول المستند لا يترتب عليه تأجيل نظر الدعوى، فإن على المحكمة أن تقبله، وثانيهما: إذا ترتب على تقديمه تأجيل النظر في الدعوى، ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة، قبلته المحكمة وعليها أن تحكم على مقدم المستند في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه. وفي هذه الحالة يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين.

فيجب على المحكمة في جميع الأحوال قبول المستندات المقدمة من الخصوم، حتى ولو كانت مقدمة من المدعي مع انتفاء العذر الذي منعه من تقديمها في الميعاد المقرر في المادة (٦٥)، إذ كل ما لها في هذه الحالة هو توقيع الغرامة التي قررها المشرع^(١).

جواز تقديم المستندات في بعض الحالات بدون غرامة:

إذا كان تأجيل القضية أمر تحتتمه الظروف لأي سبب من الأسباب فليس ثمة ما يمنع من قبول أي مستند، دون الحكم بالغرامة المشار إليها، كما أن المحكمة لا تحكم بأية غرامة إذا كان للخصم عذر في عدم تقديم المستند في الميعاد، كما يجوز للخصم أن يقدم مستندات جديدة ردا على الطلبات العارضة التي لم تكن مطروحة من قبل^(٢).

رفض المحكمة قبول المستند:

يجب على المحكمة حال قبول المستند، أن تتبين أن قبولها له يمثل تحقيقا للعدالة، بكونه منتجا في النزاع، وفي حالة ما إذا رفضت المحكمة المستند لتخلف هذا الشرط، فإن عليها أن تبين في محضر الجلسة ملخصا له وسبب رفضه، ويكفيها في هذا الصدد أن تذكر أن المستند غير

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج٢/٧٦٤.

والمقصود بالجلسة الأولى وفقا للمادة (٩٧)، الجلسة التي يتم فيها انعقاد الخصومة بتمام المواجهة سواء لإعلان المدعى عليه بشخصه أو لغير شخصه مع لزوم إعادة إعلانه، أو إعادة إعلانه في الحالات التي يلزم فيها ذلك.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج٢/٧٦٦-٧٦٧.

منتج في النزاع، ويجب عليها أن تؤثر على هذا المستند بأنه قدم لها ورفضته، ويجوز للمحكمة الابتدائية أن تقبل المستند إذا رأت أن رفض محكمة أول درجة له غير سديد^(١).

طلب تأجيل الدعوى:

المحكمة غير ملزمة بأن تستجيب لطلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة^(٢) ومع ذلك يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه للحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وفيما عدا هذه الحالات يكون التأجيل لإدخال الضامن جواريا للمحكمة، ويراعى في تقدير الأجل مواعيد الحضور، ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وإذا كان التأجيل لضم قضية أخرى، فإن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية أخرى أو وقف إحداها ريثما يفصل في الأخرى^(٣).

التأجيل الوجوبي^(٤): القاعدة أن تأجيل الدعوى مسألة تقديرية للمحكمة، ولكن يرد على السلطة التقديرية للمحكمة في هذا الصدد قيودان:

الأول: أن هناك حالات يكون التأجيل فيها واجبا بنص القانون، ومثالها:

- التأجيل لغياب المدعى عليه في الجلسة الأولى، متى كان لم يعلن لشخصه (م ٨٤).
 - التأجيل لإعادة الإعلان الباطل عند غياب المدعى عليه (مادة ٨٥ مرافعات).
 - التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور (مادة ٦٩ مرافعات).
 - التأجيل بناء على طلب الخصم لإدخال ضامن في الدعوى (مادة ١١٩).
 - التأجيل بناء على طلب الخصم للرد على الطلب المعارض المقدم ضده.
 - التأجيل عند تنازل المحامي عن التوكيل، لتوكيل محام آخر (م ٢/٩٢ محاماة).
- الثاني: يجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى بناء على طلب الخصم، حيث يكون التأجيل لازما لتمكينه من مباشرة حقوقه في الدفاع.

(١) المستشار عز الدين الدناصورى، والاستاذ حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، ١٩٩٢ م.

(٢) نقض: الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٤٠ قضائية - جلسة ١٩٧٥/١١/١..

(٣) نقض: الطعن رقم ٦٧٣ لسنة ٤٩ قضائية - جلسة ١٩٨٤/١/٢٦.

(٤) د. فتحي والي، الوسيط، ص ٥٣٢- د. وجدي راغب، ص ٥٣٥- د. عبدالتواب مبارك، ص ٤٨٥.

المطلب الثاني

حضور الخصوم وغيابهم وتمثيلهم القانوني

الفرع الأول

حضور الخصوم

يجب على القاضي ألا يحكم لخصم في الدعوى قبل سماع خصمه وهذا مبدأ مستقر عليه في النظام القضائي، وإعمال هذا المبدأ يقتضي حضور الخصوم أمام المحكمة، والأصل أنه متى أعلنت الدعوى فإنه يتعين على الخصم أن يحضر أمام المحكمة في اليوم والساعة المحددين بصحيفة الدعوى لإبداء ما يشاء من طلبات ودفع، فإن لم يحضر؛ فليس على المحكمة إجباره على الحضور إلا إذ أمرت بحضوره لاستجوابه^(١).

المناداة على الخصوم:

تبدأ إجراءات الجلسة، في الدعوى المطروحة، بالمناداة على الخصوم متى جاء دورها في رول المحكمة، وذلك للمثول أمامها وإثبات حضورهم؛ إذ يجب على المحكمة أن تتأكد في بداية الجلسة من حضور الخصوم أمامها، وذلك بالمناداة على كل خصم باسمه ولقبه، وتتأكد من رد كل منهم، وتثبت ذلك في محضر الجلسة^(٢). ذلك أن الحضور واقعة إجرائية إيجابية تؤثر في سير الخصومة وتجعلها تسير سيراً طبيعياً، بعكس الغياب باعتباره واقعة إجرائية سلبية تؤثر في سير الخصومة ولا تجعلها تسير سيراً طبيعياً^(٣).

الحضور الشخصي والوكالة بالحضور:

لا يشترط لصحة الحضور في الخصومة أن يحضر الخصوم بأنفسهم، وإنما يجوز لهم أن يوكلوا غيرهم في الحضور نيابة عنهم، وقد أوجب القانون أن يكون الوكيل عن الخصم محامياً، واستثناء من ذلك وبإذن من المحكمة: يجوز وكالة الزوج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة، ولو لم يكونوا من المحامين. وسنعرض لذلك لاحقاً.

الحضور الفعلي والحضور القانوني:

اعتد المشرع بالحضور القانوني وسأوى بينه وبين الحضور الفعلي؛ للتوفيق بين اعتبارين، أولهما: احترام مبدأ حق الدفاع، والذي يوجب ألا يحكم على شخص قبل سماع دفاعه،

(١) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ٤٩-د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٦٣٢.

(٢) المستشار. سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص ٧٢٩-د. عبدالنواب مبارك، ص ٤٦٧.

(٣) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٤٣٣.

وثانيهما: مراعاة مصلحة الخصم الحاضر، بعدم تعطيل الفصل في دعواه لغياب خصمه في الدعوى^(١).

ويقصد بالحضور الفعلي حضور الخصم بنفسه في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أما الحضور القانوني فهو اعتبار الخصم حاضرا رغم غيابه، في الحالات التي قررها المشرع وأوجب بمقتضاها اعتباره حاضرا ولو غاب فعليا عن حضور الجلسة. وهذه الحالات منها ما يتعلق بالمدعي ومنها ما يتعلق بالمدعى عليه:

أ- الحضور القانوني (الاعتباري) للمدعي:

يعتبر المدعى عليه حاضرا في الدعوى حضورا قانونيا (اعتباريا)، ولو لم يحضر أية جلسة، باعتباره رافع الدعوى ويعلم دائما بقيامها وبالجلسة المحددة لنظرها، إذ يعد ذلك قرينة قاطعة على علمه بالدعوى وبالجلسة المحددة لها^(٢). فالخصومة تعتبر دائما حضورية في حقه.

ب- الحضور القانوني (الاعتباري) للمدعى عليه:

يعتبر المدعى عليه حاضرا في الدعوى، وتكون حضورية في حقه، ولو لم يحضر بالفعل، في الحالات الآتية^(٣):

- ١- إذا كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه (مادة ١/٨٤ مرافعات).
- ٢- إذا لم يكن قد أعلن لشخصه وأعيد إعلانه مرة ثانية (مادة ١/٨٤ مرافعات).
- ٣- إذا حضر بنفسه أو بواسطة وكيله أية جلسة، ولو تخلف عن حضور باقي الجلسات (مادة ١/٨٣ مرافعات).
- ٤- إذا أودع مذكرة بدفاعه (مادة ١/٨٣ مرافعات).

الفرع الثاني

غياب الخصوم

يقصد بالغياب عدم حضور الخصم أو ممثله الجلسة، بألا يكون حاضرا حضورا فعليا أو اعتباريا، على النحو الذي سبق بيانه، وتختلف أحكام الغياب باختلاف فروضه، فقد يغيب الخصمان (المدعي والمدعى عليه)، وقد يغيب المدعى وحده، وقد يحضر المدعي ويغيب المدعى عليه.

(١) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٤٣.

(٢) للمؤلف: نظرية القرائن في قانون المرافعات، مرجع سابق، ج ١/٣٤٨.

(٣) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ٥٢-٥٣- د. أحمد سيد محمود، مرجع سابق، ص ٤٣٤.

أولاً: غياب المدعي والمدعى عليه:

نظمت المادة (١/٨٢) مرافعات الأحكام المتعلقة بغياب المدعي والمدعى عليه عن حضور الجلسة، بنصها على أنه "إذا لم يحضر المدعي والمدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن". وبمقتضى هذا النص تجب التفرقة في حالة غياب المدعي والمدعى عليه عن الجلسة، بين فرضين:

الفرض الأول: صلاحية الدعوى للفصل فيها:

ويقصد بصلاحية الدعوى للحكم فيها، أن يكون كلا من الخصمين قد أبدى أقواله أو قدم مذكرة بدفاعه، أو أن يكون المدعى عليه -على الأقل- قد أودع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى (مادة ٣/٦٥ مرافعات)، أو أعلن بها لشخصه، أو أعيد إعلانه بها، على تقدير أن صحيفة الدعوى تضمنت طلبات المدعي وما يستند إليه في دعواه^(١).

وفي هذه الحالة تحكم المحكمة في الدعوى، بمعنى أن تنظرها لتفصل فيها، يستوي في ذلك أن تحكم فيها نفس الجلسة التي تغيب فيها الخصوم، أو في جلسة لاحقة إذا رأت التاجيل إليها، والخيار في ذلك للمحكمة^(٢).

الفرض الثاني: عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها:

وفي هذا الفرض إذا رأت المحكمة أن الدعوى غير صالحة للفصل فيها، فإن عليها أن تأمر بشطبها^(٣)، وتظل الدعوى مشطوبة أمام المحكمة حتى يتحقق أحد أمرين:

الأول: تعجيلها من أحد الخصوم: وذلك بأن يطلب أحد الخصوم -سواء كان المدعي أو المدعى عليه- السير في الدعوى بتحديد جلسة لنظرها، بشرط أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، وأن يتم إعلان الخصم الآخر بالجلسة خلال الميعاد ذاته. ولا يشترط أن تقع جلسة نظر الدعوى بعد تعجيلها خلال هذا الميعاد، وإنما يشترط ذلك بالنسبة لطلب التعجيل والإعلان فقط، فإذا تم ذلك عادت الخصومة إلى سيرها أمام المحكمة من جديد.

(١) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ٦١.

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٦٤٠- د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٥٢٧.

(٣) ومعنى الشطب استبعادها من جدول القضايا (رول الجلسات) المتداولة أمام المحكمة، بحيث تبقى قائمة ومنتجة لآثارها خلال مدة الشطب، حتى يتم تعجيلها من أحد الخصوم أو انقضاءها باعتبارها كأن لم تكن. والشطب في ذلك يشبه وقف الخصومة، لأن كلاهما يؤدي إلى ركودها.

وتجب الإشارة إلى أن الشطب لا يقع بقوة القانون حتى مع توافر سببه - غياب الخصمين - وإنما لابد أن تحكم المحكمة به، والمحكمة غير ملزمة وجوباً بالحكم به، وإنما لها رغم ذلك، أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى^(١).

والثاني: عدم تعجيلها من أحد الخصوم: فإذا لم يتم تعجيل الخصومة من الشطب، وانقضى ستون يوماً على تاريخ شطبها، فإن الخصومة وبقوة القانون تعتبر كأن لم تكن، وهو ما يعني زوالها بجميع ما تم فيها من أعمال، وما ترتب عليها من آثار^(٢).

غياب الطرفين بعد تعجيل الدعوى:

أوردت المادة (١/٨٢) حكماً مهماً، مقتضاه، أنه إذا تم تعجيل الدعوى بعد شطبها، وغاب الخصمين عن الحضور في الجلسات التالية للتعجيل، فإن المحكمة لا تحكم بالشطب، وإنما تحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن؛ إذ الشطب لا يكون إلا مرة واحدة^(٣).

ثانياً: غياب المدعي وحضور المدعى عليه:

وفقاً لنص المادة (٢/٨٢) مرافعات، فإنه إذا حصلت المنادة على الخصوم في الجلسة الأولى، وتبين حضور المدعى عليه، وغياب المدعي، وتمسك المدعي عليه بالحكم في الدعوى، وجب على المحكمة إجابته إلى طلبه^(٤). وإذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن الحضور دون البعض الآخر، وتخلف المدعي عليه كذلك عن الحضور، جاز شطب القضية بالنسبة لمن تخلف من المدعين ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة^(٥).

وجدير بالإشارة ما جرت عليه العادة أمام المحاكم من أن المدعي عليه إذا تبين عند النداء على خصمه أنه غائب، فإنه يقرر انسحابه تاركاً للمحكمة سلطة الحكم بشطب الدعوى، أو الفصل فيها حسب صلاحيتها للحكم فيها^(٦).

ثالثاً: غياب المدعى عليه وحضور المدعي:

الأصل أن غياب المدعى عليه لا يمنع المحكمة من نظر القضية طالما أنه قد تم إعلانه بشكل صحيح؛ إذ القول بغير ذلك معناه التضحية بالاعتبارات العملية التي تتطلب سرعة الفصل في

(١) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٤٦.

(٣) د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٦ م، ص ٦٤٦.

(٤) د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط، مرجع سابق، ص ٤٩٨.

(٥) المرجع السابق، ص ٤٩٩.

(٦) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ٦٧.

الدعاوى حتى تستقر مراكز الخصوم، أما حق المدعى عليه في الدفاع، فهو الذي ضيعه بتخلفه عن الحضور؛ ومن ثم فلا يلومن إلا نفسه^(١).

ورغم ذلك فرق المشرع في أثر غياب المدعى عليه بين ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو تعدد المدعى عليهم (المادتان ٨٤-٨٥ مرافعات)، على النحو الآتي:

الحالة الأولى: إذا كان المدعى عليه واحدا:

إذا كان المدعى عليه واحدا وحضر الجلسة الأولى، وتغيب في غيرها، فلا أثر لغيابه، لأنه في هذه الحالة قد علم بالدعوى وحضر فيها، فلا أثر لغيابه بعد ذلك، أما إذا غاب عن الجلسة الأولى لنظر الدعوى، فتجب التفرقة بين ثلاثة فروض:

الفرض الأول: أن تكون صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، أو قدم مذكرة بدفاعه فيها، فإن المحكمة تحكم في الدعوى، ولا تلتفت لغيابه، لتحقق علمه بالدعوى بناء على الإعلان الشخصي.

الفرض الثاني: ألا تكون صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، كما لو أعلنت في موطنه لمن يجوز له تسلمها فيه، في هذه الحالة يجب على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية يعاد إعلانه به، بورقة تكليف بالحضور، وسواء أعيد إعلانه لشخصه أو في موطنه، وفي هذه الحالة تنظر المحكمة الدعوى ولو تغيب عن الحضور بعد إعادة الإعلان، لأن إعادة الإعلان قرينة على علمه بالدعوى.

الفرض الثالث: إذا كان إعلان صحيفة الدعوى باطلا، ولم يحضر المدعى عليه ولم يودع مذكرة بدفاعه، وجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية يعاد إعلانه بها، ويتم إعلانه في هذه الحالة بصحيفة الدعوى كاملة^(٢).

وإذا تم إعلانه بها على هذا النحو ولم يحضر فتجب التفرقة في هذه الحالة بين ما إذا كان إعادة الإعلان قد تم لشخصه، فإن على المحكمة أن تنظر الدعوى ولا أثر لغيابه، وبين ما إذا كان قد أعيد إعلانه لغير شخصه، فيجب إعادة الإعلان باعتبار أن الإعلان السابق هو أول إعلان صحيح ولم يكن لشخصه، قياسا على الحالة السابق ذكرها في الفرض الثاني.

(١) د. الكوني على أعبودة، مرجع سابق، ص ٢٧٨.

(٢) وإذا كان بطلان إعلان الصحيفة راجعا إلى فعل المدعي، وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة جنيه (مادة ٢/٨٥ مرافعات).

الحالة الثانية: إذا تعدد المدعى عليهم:

أوردت المادة (٢/٨٤) مرافعات، هذه الحالة بنصها على أنه "إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن بشخصه من الغائبين ويعتبر الحكم حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً". وبهذا النص وضع المشرع قاعدة خاصة، مقتضاها: التفرقة بين فرضين:

الفرض الأول: إذا تعدد المدعى عليهم وأعلنوا جميعاً لأشخاصهم - أو أودعوا مذكرة بدفاعهم- وتغيبوا جميعاً أو تغيب البعض منهم، فإن علمهم بقيام الخصومة قد تأكد، وعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى ولا تلتفت لغيابهم.

الفرض الثاني: إذا تعدد المدعى عليهم وأعلن البعض لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه، أو لم يودع مذكرة بدفاعه، فإنه يفرق بين أمرين، أولهما: غيابهم جميعاً أو غياب من لم يعلن لشخصه منهم، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية يعلن بها المدعي من لم يعلن لشخصه من المدعى عليهم. وثانئها: غياب من أعلن لشخصه وحضور من لم يعلن لشخصه، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة في الدعوى ولا تلتفت إلى غياب من أعلن لشخصه، على أساس ثبوت علمهم جميعاً بالخصومة وتساوي مراكزهم، فيعتبر الحكم حضورياً في حقهم جميعاً^(١).

حماية الخصم الغائب:

قدر المشرع أن الحضور والغياب رخصة للخصم له استعمالها أو عدم استعمالها، فلا يعتبر الغياب خطأ أو جريمة تستوجب عقابه، ومن ثم قرر قواعد لحمايته، أهمها^(٢):

- ١- أن غيابه ليس قرينة على التسليم بطلبات خصمه، فيبقى الفصل في القضية خاضعاً لأحكام القانون، من حيث عبء الإثبات، ومن حيث تسبب الحكم... الخ.
- ٢- لا يجوز للخصم الحاضر أن يبدي طلبات أو دفاع جديد في غيبة خصمه (م٨٣).
- ٣- حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة يؤدي إلى اعتبار كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن، ويجب نظر القضية من جديد في حضوره (مادة ٨٦ مرافعات).
- ٤- ميعاد الطعن في الحكم الصادر ضد الخصم الغائب يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم.

(١) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ٧٣.

(٢) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٤٤٠- د. عبدالنواب مبارك، مرجع سابق، ص ٤٨١.

الفرع الثالث

التمثيل القانوني

قلنا إنه لا يشترط حضور الخصم بشخصه أمام القضاء المدني - وإن كان الأصل حضوره - وإنما يجوز للخصوم أن يوكّلوا غيرهم في الحضور نيابة عنهم، فكل ما قرره المشرع في المادة (٧٢) مرافعات؛ أنه في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكّلونه من المحامين، وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكّلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة^(١).

وبمقتضى هذا النص أعطى المشرع للخصوم الحق في أن يوكّلوا غيرهم في الحضور نيابة عنهم أمام المحاكم المدنية، والأصل في الوكيل أن يكون من المحامين، واستثناء من هذا الأصل وبشرط قبول المحكمة، يجوز للخصم أن يوكّل شخصا آخر ولو لم يكن محاميا، شريطة أن يكون من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة.

إثبات الحضور عن الخصم:

أوجب المشرع على الوكيل أن يثبت حضوره عن موكله في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل الذي يمثله بها، وأن يكون بيده توكيل موثق بالشهر العقاري، سواء أكان توكيلا عاما أو خاصا أو مصدقا على توكيل الموكل عليه، فإذا حضر الخصم مع محاميه وأقر بوكالته وأثبت ذلك في محضر الجلسة فإنه يقوم مقام التصديق على التوقيع^(٢) وإذا كان التوكيل عاما فإنه يكتفى بإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، أما إذا كان توكيلا خاصا؛ فإنه يودعه ملف الدعوى^(٣).

(١) وينبغي ملاحظة التفرقة بين قاعدة المخاصمة بوكيل، وبين الوكالة في الحضور، فالمخاصمة بوكيل هي أن ترفع الدعوى من نائب عن الحق المطلوب حمايته، وهي صورة جائزة طالما أفصح الوكيل عن صفته واسم موكله، فإذا ثارت منازعة في النيابة في هذه الحالة كانت منازعة في الصفة في رفع الدعوى بما ينطوي على الدفع بعدم قبولها. أما الوكالة في الحضور فتكون حين ترفع الدعوى من صاحب الحق المراد حمايته أو ممن لا نزاع في نيابته عنه، ولكنه لا يحضر في الجلسة، وإنما يحضر عنه وكيل يخوله حق الحضور عنه أمام القضاء، فإذا ثار نزاع حول صحة هذا التوكيل أو جواز الحضور به كان الأمر متعلق بصحة حضور المدعي، وكان الجزاء هو إعمال أحكام غياب المدعي (د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٥٣٣/٢).

(٢) نقض مدني ٢ إبريل ١٩٥٩ لسنة ١٠ ص ٣١٢.

(٣) نقض: الطعن رقم ١١٦٦ لسنة ٤٧ قضائية - جلسة ١٩٨٠/٢/٩.

وقد قضت محكمة النقض بأنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة فإن هذا يكفي دليلا في الإثبات، وإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه بهذا العمل، فلا محل للاعتراض بان التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. (نقض ١٩٥٩/٤/٢ سنة ١٠ ص ٣١٢).

ومن ثم يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات هذه الوكالة حتى لا يجبر على مwalاة إجراءات مهددة بالإلغاء، إذا ما تنصل عنها خصمه، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل عليها فهذه مسألة متعلقة بالنظام العام^(١).

وسواء كان التوكيل عاما أو خاصا، فإنه يجب أن يتضمن صراحة الحق في المرافعة أمام القضاء، فإذا لم ينص صراحة على الحق في الترافع اقتصر التوكيل على أعمال الإدارة فقط^(٢).

الوكالة العامة بالخصومة والوكالة الخاصة بها:

الوكالة بالخصومة قد تكون وكالة عامة، وقد تكون وكالة خاصة، والوكالة تكون عامة؛ إذا تناولت مختلف الخصومات ولم تكن قاصرة على خصومة معينة أو مرحلة فيها، فيكون للوكيل سلطة القيام بجميع الأعمال الإجرائية باسم موكله ولصالحه، ولا يستثنى من ذلك إلا الأعمال التي يشترط فيها توكيلا خاصا، كالإقرار بالحق والصلح، وغير ذلك مما سنبينه لاحقا، أما الوكالة الخاصة؛ فإنها تكون بخصوص خصومة معينة فقط، أو بمرحلة فيها، مثل الطعن بالاستئناف، أو بعمل إجرائي معين داخل الخصومة كالادعاء بالتزوير، وفيه تنحصر سلطة الوكيل في اتخاذ هذا العمل فقط^(٣).

حتمية الوكالة الخاصة في بعض التصرفات القانونية:

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، إلا أن هناك من التصرفات القانونية ما أوجب المشرع بشأنه وكالة خاصة، لأهمية التصرف وخطورته بالنسبة للموكل، وهذه التصرفات هي: الإقرار بالحق المدعى به، والتنازل عنه، والصلح، والتحكيم، وقبول اليمين، وتوجيهها، وردها، وترك الخصومة، والتنازل عن الحكم، أو عن طريق من طرق الطعن فيه، ورفع الحجز، وترك التأمينات مع بقاء الدين، والادعاء بالتزوير، ورد القاضي، ومخاصمته، ورد الخبير، والعرض الفعلي، وقبوله، وأي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا. فجميع هذه التصرفات لا تصح مباشرتها من الوكيل إلا بمقتضى تفويض خاص يخوله القيام بها (مادة ٧٦ مرافعات).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ص ٥٥٣.

وأثبات الوكالة يكون إما بتقديم توكيل رسمي أو بتقديم توكيل ثابت في ورقة عرفية بشرط أن يكون توقيع الموكل عليه مصدقا عليه رسميا. (د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٥٣٥/٢).

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٦٣٣- د. محمد مصطفى يونس، سابق، ص ٥٣٠.

(٣) المستشار. سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص ٧٣٦-٧٣٧.

حالات الوكالة الإجبارية:

الأصل في الوكالة بالخصومة أنها جوازية للخصم، فيكون له الحق في أن يوكل عنه محامياً أو لا، ولا يفرض عليه أن يكون له وكيل في الخصومة. واستثناء من هذا الأصل، أوجب المشرع على الخصم أن يكون له وكيل في عدة حالات، هي^(١):

- ١- أمام محكمة النقض: فصحيفة الطعن بالنقض لابد من التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، لما تثيره الدعوى أمام هذه المحكمة من مشاكل قانونية دقيقة تقتضي خبرة قانونية معينة فيمن يتصدى لها.
- ٢- صحف الطعن بالاستئناف: سواء أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية هيئة استئنافية، يجب أن تكون موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها، وإلا كانت باطلة.
- ٣- صحف الدعاوى وأوامر الأداء أمام المحاكم الابتدائية، يجب التوقيع عليها من محام، وكذلك صحيفة الدعوى أمام المحكمة الجزئية إذا زادت قيمة الدعوى عن خمسون جنهما.

آثار الوكالة:

- يترتب على التوكيل بالخصومة عدة آثار، ورد النص عليها في المواد (٧٤-٨٠) مرافعات، وهي:
- ١- بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها (مادة ١/٧٤)^(٢).
 - ٢- التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية، إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وكذلك إعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف، إلا إذا نص القانون على غير ذلك (مادة ١/٧٥).
 - ٣- أي قيد يرد في التوكيل على خلاف ما ورد في البند السابق لا يحتج به على الخصم الآخر (مادة ٢/٧٥).
 - ٤- نص المشرع على بعض التصرفات القانونية التي يشترط لمباشرتها من الوكيل توكيلاً خاصاً، ولا تصح إلا به (مادة ٧٦)، وقد سبق الإشارة إليها، فنحيل إلى ما سبق ذكره.
 - ٥- يجوز تعدد الوكلاء في الخصومة، وإذا تعددوا؛ جاز لأحدهم الإنفراد بالعمل في القضية، ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل (مادة ٧٧).

(١) المستشار. سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص ٧٣٦.

(٢) فإذا لم يكن للخصم وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة، وجب عليه أن يتخذ له موطناً فيه (مادة ٢/٧٤)، فإن لم يفعل جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانها في الموطن المختار (مادة ١٢ مرافعات).

- ٦- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين؛ إلا إذا كان ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل (مادة ٧٩).
- ٧- كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة (مادة ٧٩).
- ٨- لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته؛ إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه (مادة ٨٠/١).
- وقد قصد المشرع من ذلك؛ إقرار الإجراءات التي اتخذها الخصم في مواجهة الوكيل الأول في فترة عزله، الذي كان يجهله بسبب عدم إخباره به من خصمه^(١).
- ٩- لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق (مادة ٨٠/٢). فإذا اعتزل الوكيل في وقت غير لائق مما سبب الإضرار بمصلحة موكله؛ جاز الحكم عليه بالتعويض، عملاً بالقواعد العامة في المسؤولية^(٢).

حظر الوكالة بالخصومة على بعض الأشخاص:

فضلاً عما قرره المشرع من وجوب أن يكون الوكيل محامياً، أو ممن تقبل المحكمة وكالته من الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثالثة؛ فإنه لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم؛ أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها؛ وإلا كان العمل باطلاً (مادة ٨١/١ مرافعات). بطلاناً متعلقاً بالنظام العام^(٣).

واستثناء من هذا الحظر يجوز لهؤلاء أن ينبوا أمام القضاء عمن يمثلونهم قانوناً، وعن زوجاتهم، وأصولهم، وفروعهم، إلى الدرجة الثانية (مادة ٨١/٢ مرافعات). هذا ولم يتعرض النص للوكالة عن الأصدقاء، ومن ثم فلا يجوز لهؤلاء الحضور عنهم^(٤).

(١) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات عن المادة (٨٠) منه.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٢/٥٩٤.

وفي هذا الصدد نصت المادة (٩٢) من قانون المحاماة، على أنه لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان لازماً للدفاع عن مصالح الموكل، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر. فإذا خالف المحامي ذلك بأن تنازل عن التوكيل في وقت غير لائق، أو لم يخطر موكله بهذا التنازل؛ فإنه يكون مسئولاً قبل موكله عما يصيبه من ضرر.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٢/٦٠٠.

(٤) د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٤٤٩.

المبحث الثاني

نطاق الخصومة

نعني بنطاق الخصومة المدنية، النطاق الشخصي والموضوعي للخصومة، ويتحدد النطاق الشخصي بأشخاص الخصومة، في حين يتحدد النطاق الموضوعي بالطلبات والدفع المقدمة فيها، ونتناول نطاق الخصومة في خمسة مطالب نتحدث في الأول منها عن الخصوم في الدعوى وتعدددهم، في حين نتناول في الثاني تعديل نطاق الخصوم في الدعوى، ونتحدث في المطلب الثالث عن النطاق الموضوعي للخصومة (الطلبات والدفع)، ونتناول في الرابع التقيد بنطاق الخصومة، وفي الخامس تنظيم المرافعة.

المطلب الأول

الخصوم في الدعوى وتعدددهم

أولاً: تحديد ماهية الخصم^(١):

الخصم بالمعنى الإجرائي هو من يقدم باسمه طلباً إلى القاضي ومن يقدم هذا الطلب في مواجهته، سواء أكان طلباً أصلياً أو عارضاً، على أن يتضمن هذا الطلب ادعاء بحق أو مركز قانوني معين. من ثم ترتبط فكرة الخصم وفقاً للمعنى الإجرائي بتقديم المطالبة القضائية، والتي يترتب عليها اكتساب مقدمها لوصف الخصم وكذا المقدمة في مواجهته، سواء أكانوا أطراف الرابطة الموضوعية أو أطراف الدعوى أم لا. وذلك لأن وجود الحق المدعى ليس شرطاً لقبول الطلب، ولكنه شرط لنجاحه موضوعياً، وكذلك لا يشترط وجود تطابق بين مركز الخصم ومركز صاحب الدعوى.

ويتنوع الخصوم إلى خصوم أصليين وهم الذين يكتسبون وصف الخصم منذ بداية الإجراءات، وخصوم متدخلين وهم الذين يكتسبون هذا الوصف في أثناء سير الإجراءات وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً.

ضرورة وجود خصمين لبدء الخصومة (المدعي والمدعى عليه)^(٢):

تفترض الدعوى بالضرورة وجود خصمين يقوم بينهما نزاع، هما: المدعي، والمدعى عليه، وقد يتعدد المدعون أو المدعى عليهم. والمدعي هو من يقدم بنفسه أو بواسطة غيره طلباً إلى القضاء

(١) د. إبراهيم أمين النفاوي، مسئولية الخصم عن الإجراءات، ط ١، ١٩٩١ م، ص ١٤ وما بعدها.

(٢) د أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٦٠٩- د. فتحي والي، الوسيط، ص ٣٥٣- د. عبد المنعم أحمد الشرقاوي،

مرجع سابق، ص ٣٤٧.

ليفصل فيه، فهو الذي يأخذ زمام المبادأة في الدعوى بأن يتوجه إلى القضاء طالبا الحكم له على خصمه بما يدعيه، أما المدعى عليه فهو من يقدم في مواجهته هذا الطلب، وبغير مدع ومدعى عليه لا توجد خصومة مدنية، إذ أن طبيعة الخصومة أن تكون بين شخصين يتنازعان حقا ما، ولهذا يسميان بالطرفين الأصليين في الخصومة.

ووصف الخصم بأنه المدعي أو المدعى عليه بداية يتحدد بحسب من يقدم الطلب الافتتاحي للخصومة ومن يقدم ضده هذا الطلب، غير أن مركز الشخص في الدعوى واعتباره مدعيا أو مدعيا عليه لا يتحدد فقط بصحيفة افتتاح الدعوى، إذ قد يوجه المدعى عليه طلبا عارضا إلى المدعي ردا على دعواه، وهو ما يسمى بدعوى المدعى عليه وفي هذه الحالة يصبح المدعى عليه مدعيا بينما يصبح المدعي مدعيا عليه.

وإذا كنا نقول بضرورة وجود خصمين لبدء الخصومة فإن ذلك لا يعني أن الخصوم قد لا يكونوا أكثر من ذلك، ذلك أن خصوم الدعوى قد يكونوا اثنين أو أكثر، فقد يتعدد المدعون كما قد يتعدد المدعى عليهم، وقد تتسع دائرة الخصوم لتشمل آخرين لم تشملهم صحيفة الدعوى، وهم من يتدخلون في الدعوى بإرادتهم أو يختصمون فيها. وسواء قل عدد الخصوم أو أكثر فمن الضروري تحديد مركز كل خصم هل هو مدعي أو مدعى عليه،

ثانيا: تعدد الخصوم عند بدء الخصومة:

قلنا إن الدعوى تفترض وجود خصمين هما المدعي والمدعى عليه، وأن المدعي قد يكون واحدا أو أكثر، كما قد يكون المدعى عليه واحدا أو أكثر، بمعنى أنه قد يتعدد الخصوم كمدعين أو مدعى عليهم عند بدء الخصومة، وذلك بأن توجه صحيفة الدعوى ابتداء من أكثر من مدع إلى مدعى عليه واحد، أو أن توجه ابتداء من مدع واحد إلى عدد من المدعى عليهم، أو أن يتعدد الطرفان معا -المدعون والمدعى عليهم- وهذا التعدد قد يكون اختياريا وقد يكون إجباريا.

أ- التعدد الاختياري:

هو التعدد الذي يتم بإرادة الخصوم دون أن يفرضه عليهم نص القانون، بحيث يكون للمدعي سلطة بدء خصومة واحدة ضد أكثر من شخص، أو يكون للمدعين سلطة بدء خصومة واحدة ضد شخص واحد أو أكثر، فيجوز أن ترفع الدعوى من أكثر من مدع أو على أكثر من مدعى عليه، إذا كان الحق موضوع الدعوى متعدد الأطراف، كدعوى يرفعها ورثة الدائن للمطالبة بحق لمورثهم أو دعوى يرفعها الدائن على ورثة مدينه^(١).

(١) د. فتحي والي، الوسيط، ص ٣٧٥- د. وجدي راغب فهد، ص ٤٧٦.

وكذلك إذا تعددت الدعاوى وكانت بينها صلة تبرر في نظر محكمة الموضوع نظرها معا، وتتحقق هذه الصلة إذا وجد ارتباط بينها، وقد يتحقق الارتباط في محل الدعوى مثل وجود تضامن بين المدعين والمدعى عليهم في الحق موضوع الدعوى، أو في سبب الدعوى مثل طلب عدة مستأجرين في عمارة تخفيض الأجرة لعدم تشغيل مصعد مثلا، وتقدير هذا الارتباط منوط بمحكمة الموضوع دون تعقيب من محكمة النقض^(١).

وتبدأ الخصومة بصحيفة واحدة في حالة التعدد الاختياري، وتتعدد صورة الصحيفة بتعدد الخصوم فيها، ويكتسب كل خصم مركزا قانونيا مستقلا عن الخصوم الآخرين، ويمكن للمحكمة أن تفصل في الخصومة تباعا، وعلى نحو يختلف باختلاف مراكز الخصوم ودفاع كل منهم في الخصومة^(٢).

ويشترط للجمع بين عدة دعاوى واحدة أن تكون المحكمة مختصة بنظر جميع الدعاوى، فإذا ترتب على جمع الدعاوى مخالفة قواعد الاختصاص فلا يجوز بدء خصومة واحدة. كما أنه إذا لم يتوافر الارتباط أو وحدة المسألة المثارة، فلا يقبل الجمع بين دعويين في خصومة واحدة، وحينئذ يجب على المحكمة أن تقضي بالفصل بين الدعويين لتتظر كل منهما في خصومة مستقلة، ولها أن تحكم بعدم قبول الدعويين من الناحية الإجرائية لعدم رفع كل منهما على استقلال^(٣).

ثانيا: التعدد الإجباري:

هذه الصورة على خلاف الصورة السابقة إذ لا يترك فيها التعدد لاختيار الخصوم، وإنما يجب أن يصدر الحكم في مواجهة أطراف متعددين، حيث يوجب القانون في بعض الدعاوى تعدد الخصوم، كما في الدعوى غير المباشرة والتي يجب أن ترفع على المدين ومدين المدين (مادة ٢٣٥/٢ مدني)، وكما في دعوى الشفعة التي يجب أن ترفع على البائع والمشتري (مادة ٩٤٣ مدني)، وكما في دعوى القسمة والتي يجب أن ترفع على باقي الشركاء (مادة ٨٣٦ مدني)^(٤).

وإذا كان الفرض الغالب في التعدد الإجباري هو تعدد المدعى عليهم، فإنه قد يوجد أيضا في جانب المدعي، كما لو رفعت دعوى من جانب مجموعة مستأجرين لعين مشتركة بعقد واحد

(١) د. فتحي والي، الوسيط، ص ٣٧٥- د. وجدي راغب فهي، ص ٤٧٧.

(٢) د. محمود هاشم، قانون القضاء المدني، ١٩٨١م، ج ٢٣٦/٢.

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٣٧٥.

(٤) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٣٧٦- د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٤٧٩.

على المالك بطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وكما لو رفعت دعوى من جانب مجموعة من المشترين لمال على الشيوع بعقد واحد بطلب فسخ هذا العقد ورد ما دفعوه من ثمن^(١).

والتعدد الإجمالي قد يكون بنص القانون، وقد يكون بغير نص:

١- فقد ينص القانون على وجوب اختصام جميع أطراف الحق الموضوعي المرفوع به الدعوى، وذلك كما في الدعوى غير المباشرة، ودعوى قسمة المال الشائع، ودعوى الشفعة. إذ يجب في هذه الدعاوى رفع الدعوى على مدعى عليهم متعددون.

٢- وقد لا ينص القانون على وجوب اختصام جميع أطراف الحق، إلا أن موضوع الخصومة لا يقبل التجزئة، قياساً على الحالات التي نص عليها القانون، وهنا يجب اختصام جميع الأطراف على الرغم من عدم النص على ذلك، إذ لا يتصور الفصل في موضوع لا يقبل التجزئة إلا في مواجهة جميع أطرافه. ومن أمثلة هذه الدعاوى، دعوى تقرير أو نفي حق ارتفاق لصالح عقار شائع أو عليه إذ يجب أن ترفع من -أو على- جميع المالك على الشيوع، وكذلك دعوى بطلان عقد أو صورته، إذ يجب أن توجه إلى جميع أطراف العقد^(٢).

ويجب على المحكمة في حالة التعدد الإجمالي أن تفصل في موضوع الدعوى بحكم واحد بالنسبة لجميع الخصوم، وذلك لعدم استقلال المراكز القانونية للخصوم ولأن الموضوع غير قابل للتجزئة. كما أن عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة إذا رفعت دون اختصام من يجب اختصامه في حالة التعدد الإجمالي^(٣).

المطلب الثاني

تعديل نطاق الخصومة من حيث أشخاصها

قد يحدث تعدد الخصوم قبل بدء الخصومة على النحو الذي تحدثنا عنه، وقد يحدث هذا التعدد بعد بدء الخصومة، بحيث يتعدل بمقتضاه نطاق الخصومة من حيث أشخاصها، وهو ما نتناوله في هذا المطلب، والتعدد بعد بدء الخصومة قد يحدث بإرادة الشخص وبناء على طلبه بأن يتدخل في الدعوى، فيصبح طرفاً فيها بإرادته واختياره، وهذا هو التدخل، وقد يحدث رغماً عن الشخص وبغير إرادة منه، وإنما بناء على طلب أحد خصوم الدعوى الأصليين أو أمر المحكمة، وهذا هو الاختصام، وبناء على إحدى هاتين الصورتين يتم تعديل نطاق الخصومة من ناحية الخصوم بالتدخل أو الإدخال، ونتناول هاتين الصورتين في فرعين على النحو الآتي:

(١) د. عبيد محمد القصاص، قانون المرافعات، دراسة موجزة، مرجع سابق، ص ٤٢٩.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٣٧٧-٣٧٦.

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٣٧٧. ويراعى حكم المادة (١١٥) مرافعات.

الفرع الأول التدخل في الخصومة

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط (مادة ١/١٢٦ مرافعات). ومعنى التدخل أن يطلب شخص من الغير أن يصبح طرفاً في خصومة قائمة^(١). فإذا علم شخص بدعوى قائمة وكان يعنيه أمر هذه الدعوى إلى الحد الذي يرى معه أن من الخير له أن يتدخل فيها، فقد أباح له القانون ذلك، وإن لم يكن أياً من الخصوم قد طلب منه أن يتدخل في الخصومة.

والتدخل في الخصومة نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص غريب عن الخصومة فيها للدفاع عن مصالحه، ويتميز التدخل عن الإدخال أو الاختصاص، في أن التدخل يحدث من تلقاء نفس المتدخل عندما يتبين له أن الخصومة قد تؤثر في مصلحته، في حين أن الاختصاص يتم جبراً وبغير إرادة من الخصم، إذ يجبر على الدخول في خصومة لم يرهو محلاً للزج بنفسه فيها^(٢).

ووفقاً لما قرره المادة (١/١٢٦) فإنه يشترط لقبول التدخل وصحته توافر شرطين:

الأول: أن تكون هناك مصلحة للمتدخل من وراء تدخله في الدعوى القائمة. وهذا الشرط إعمالاً لما قرره المادة الثالثة مرافعات، من عدم قبول أي طلب لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومن ثم فإن على القاضي إذا تبين عدم وجود مصلحة للمتدخل من وراء تدخله أن يحكم بعدم قبول التدخل.

والثاني: أن يتم التدخل بإحدى صورتين نص عليهما المشرع، وهما التدخل الانضمامي أو التدخل الاختصاصي، شريطة أن يكون التدخل الاختصاصي لطلب مرتبط بالطلب الأصلي في الدعوى.

والتدخل في الخصومة قد يكون لأحد غرضين، أولهما، الدفاع عن أحد طرفي الخصومة، ويسمى في هذه الحالة بالتدخل الانضمامي، وثانيهما، المطالبة بحق خاص في مواجهة طرفي الخصومة الأصليين ويسمى في هذه الحالة بالتدخل الاختصاصي.

(١) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص-٤٨٤.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ١٦٨/٣.

أولاً: صور التدخل في الخصومة بعد بدءها:

أ- التدخل الانضمامي:

يقصد بالتدخل الانضمامي تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة لكي يساعد أحد أطراف هذه الخصومة، وذلك بقصد تأييده في ادعاءاته دون أن يطالب لنفسه بحق مستقل، فالمتدخل في هذا النوع من نوعي التدخل لا يدعي لنفسه حقاً في مواجهة طرفي الخصومة أو أحدهما، وإنما ينضم لأحدهما دفاعاً عن حق هذا الأخير، وهو في انضمامه لا يحل محل من انضم إليه ولا يمثله، كما أنه ينضم لمصلحته هو وليس لمصلحة من انضم إليه^(١).

فالمتدخل انضمامياً يقصد من وراء تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه، كأن يتدخل الدائن في دعوى مدينه على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه، حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر لدائن على جميع أمواله^(٢).

وبدعي القول أن التدخل الانضمامي جائز سواء كان التدخل إلى جانب المدعي أم إلى جانب المدعى عليه، وأن نطاق هذا التدخل يتحدد بطلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى، فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا النوع من نوعي التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتفصل فيه، بل يظل الأمر مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى. فإذا رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها، فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه طعن على هذا الحكم^(٣).

ويشترط لصحة التدخل الانضمامي توافر المصلحة من وراء طلب التدخل، كما سبق أن أشرنا، وأن يتم التدخل قبل قفل باب المرافعة، سواء كان التدخل أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الدرجة الثانية^(٤)، إذ التدخل الانضمامي لأول مرة جائز أمام هذه الأخيرة (مادة ٢٣٦/٢).

ومن أمثلة هذا النوع من نوعي التدخل: تدخل الدائن في الدعوى المرفوعة على مدينه من الغير للدفاع عن حقوق مدينه حتى لا يتأثر الضمان الذي للدائن على أموال مدينه، وتدخل الضامن في منازعة الضامن مع الغير لمساعدة صاحب الضمان حتى لا يخسر الدعوى

(١) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٣٨٣.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٦٢٩.

(٣) نقض: الطعن رقم ٦١٦ لسنة ٤٥ قضائية - جلسة ١٩٨٢/٢/١٠م.

(٤) د. عبدالقواب مبارك، مرجع سابق، ص ٣٩٤.

فيرجع على الضامن، وتدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشتري، وتدخل شركة التأمين في دعوى التأمين المرفوعة على المستأمن، وتدخل المصنع في دعوى مرفوعة ضد محل تجاري لعب في آلة من الآلات التي ينتجها هذا المصنع^(١).

ويلاحظ أن جميع هذه الأمثلة وغيرها تشير إلى وجود مصلحة للغير- المتدخل- من وراء تدخله، وهي هنا مصلحة وقائية تقوم على الضرر المحتمل، ولذا يسمى هذا التدخل بالتدخل التحفظي أيضا كما يسمى بالتدخل الانضمامي.

ب- التدخل الاختصامي:

هذه الصورة من صورتي التدخل تختلف عن التدخل الانضمامي في أن المتدخل اختصاصيا هنا، لا يقصد من وراء تدخله الانضمام إلى أحد الخصوم لمساندته في طلباته ومؤازرته في دفاعه، وإنما يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. وهو عبارة عن طلب عارض يتمسك فيه المتدخل بحق أو مركز قانوني في مواجهة الخصوم الأصليين أو أحدهم^(٢).

ولذلك يمكن القول أن التدخل الاختصامي، هو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة لكي يتمسك في مواجهة أطرافها بحق خاص مرتبط بهذه الخصومة أو بمحلها. ومن ثم يكون هذا التدخل هجوميا لأنه يقوم على مهاجمة من يتم التدخل ضدهم. كأن تكون هناك خصومة أمام القضاء حول ملكية عقار أو منقول بين مدع ومدعى عليه، فيتدخل شخص آخر مطالبا بملكية هذا العقار لنفسه في مواجهة طرفي الخصومة الأصليين^(٣). ومن أمثلته أيضا أن ترفع دعوى بشأن تنفيذ عقد البيع بين البائع والمشتري، فيتدخل من عمل سمسارا في هذا العقد ليطالب الطرفين أو أحدهما بعمولته^(٤).

والأصل أن الحكم الصادر في الخصومة دون هذا التدخل الاختصامي لا يحتج به على الغير، إذ يكفي هذا الغير الاحتماء وراء قاعدة نسبية آثار الأحكام، ومع ذلك أجاز له القانون أن يتدخل في الخصومة القائمة تيسيرا له وتوفيرا لوقت القضاء من تعدد الخصومات، إذ بغير ذلك يضطر إلى رفع دعوى خاصة به وبإجراءات أصلية، وهذا يترتب عليه ضياع الوقت والجهد واحتمال تعارض الأحكام، ولذلك أجاز له المشرع التدخل الاختصامي باعتباره علجا وقائيا^(٥).

(١) د. محمد عبد النبي غانم، قانون المرافعات، مرجع سابق، ج ٢/٧٦٣.

(٢) د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٤٨٨.

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٣٧٩-٣٨٠.

(٤) د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٤٨٩.

(٥) د. الكوني على أعبوده، مرجع سابق، ص ١١٤- د. وجدي راغب فهي، ص ٤٨٩.

ولا يكفي لصحة التدخل الاختصامي توفر المصلحة وأن يتم التدخل قبل قفل باب المرافعة، وإنما يشترط أن تكون الخصومة أمام محكمة أول درجة، إذ لا يجوز التدخل اختصامياً لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية أو أمام محكمة النقض.

ثانياً: إجراءات التدخل:

لا تختلف إجراءات التدخل في أي من صورتيه، فسواء كان التدخل انضمامياً أم اختصامياً، فإنه يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم، شريطة أن يتم التدخل قبل إقفال باب المرافعة. ومن ثم فإن التدخل في الدعوى يتم بإحدى وسيلتين (مادة ١٢٦/٢ مرافعات):

الوسيلة الأولى: تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي تنعقد أمامها الخصومة المطلوب التدخل فيها، ووفقاً لما أوجبه المادة (٦٣) مرافعات، وتعلن هذه الصحيفة للخصوم، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى الأصلية.

الوسيلة الثانية: تقديم طلب التدخل شفاهة أثناء انعقاد الجلسة، في حضور الخصوم الأصليين، مع إثباته في محضر الجلسة، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الإجراءات قبل قفل باب المرافعة. على أنه إذا كان أحد الخصوم غائبا فإن التدخل لا يصح في مواجهته إلا بطريق الدعوى العادية^(١).

ثالثاً: آثار التدخل:

يترتب على التدخل بنوعيه أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيه حجة له وعليه، فيجوز له الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة^(٢). إلا أن آثار التدخل لا تتوقف على مجرد حجية الحكم الصادر في الدعوى والطعن فيه، وإنما يترتب على كل صورة من صورتها التدخل بعض الآثار كما يلي:

أ- آثار التدخل الانضمامي:

يترتب على التدخل الانضمامي أن يصبح المتدخل طرفاً في الخصومة، غير أنه يكون تابعاً للخصم الذي انضم إليه، ومن ثم^(٣):

(١) التدخل الحاصل في غيبة أحد الخصوم لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى... ومخالفة ذلك يترتب عليه بطلان العمل الإجرائي، وهذا البطلان من النظام العام. الطعن رقم ١٢٩٦ لسنة ٤٨ قضائية - جلسة ١٩٨٢/٤/١٨ م.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٦٣١.

(٣) د. الكوني على أعبوده، مرجع سابق، ص ١١٩ - د. فتحي والي الوسيط، ص ٣٨٣ - د. عبد التواب مبارك، ص ٣٩٤-٣٩٥.

- يكون له حق تسيير الخصومة ومباشرة أي عمل إجرائي يحول دون سقوطها أو انقضائها بمضي المدة.
- لا يجوز له أن يتقدم بطلبات مغايرة لطلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، وإنما يجوز له أن يبدي من الدفوع وأوجه الدفاع ما يؤيد طلباته.
- يسري في مواجهته ما يكون قد تحقق في الخصومة قبل دخله من سقوط لحق أو إجراء لمن تدخل منضمًا إليه.
- إذا كان متدخلًا إلى جانب المدعى عليه فإن له أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة محلًا إذا لم يكن قد سقط حقه في الإدلاء به.
- ليس للمتدخل انضمامًا للقيام بما يقوم به صاحب الحق من التنازل عن الحق المطلوب حمايته أو إبرام صلح أو ترك الخصومة أو قبول تركها.
- إذا تنازل المدعي عن الخصومة الأصلية بالترك أو تصالح مع المدعى عليه أو تنازل عن الحق الذي يدعيه فإن ذلك يترتب عليه انقضاء التدخل.
- يتحمل مصاريف دخله حتى وإن حكم لصالح من انضم إليه.
- يحوز الحكم الصادر في الدعوى، الحجية في مواجهته، ويكون له حق الطعن في الحكم الصادر ضد من انضم إليه، حتى ولو لم يطعن فيه هذا الأخير.

ب- آثار التدخل الاختصامي^(١):

- يترتب على التدخل الاختصامي أن يصبح المتدخل طرفًا في الخصومة كالأطراف الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بما يترتب على هذا المركز من سلطات وأعباء. ومن ثم يكون له:
- إبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع التي يكون لكل مدع ابداءها، غير مقيد في ذلك بما أبداه الخصوم الأصليين في الدعوى.
- لا يحتج في مواجهته بالأحكام التي صدرت في الخصومة قبل دخله إذا كانت تتعارض مع مصالحه.
- للمتدخل كافة حقوق المدعي بما في ذلك تعديل الطلبات أو التنازل عنها وتوجيه اليمين الحاسمة وحلفها أو ردها، بل له ترك الخصومة والصلح.

(١) انظر المراجع المشار إليها في الهامش السابق.

- إذا زالت الخصومة الأصلية وكان سبب زوالها تركها من جانب المدعي الأصلي، أو تسليم المدعى عليه الأصلي بطلبات المدعي فيها، فإن هذا الزوال لا يؤثر في بقاء طلب المتدخل الاختصامي في مواجهتهما.
- إذا كان سبب زوال الخصومة بطلان صحيفتها أو بطلان إجراء فيها؛ فإن زوالها يؤدي إلى زوال التدخل الاختصامي، ما لم يكن التدخل قد تم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى وكانت المحكمة مختصة به.

رابعاً: الحكم في قبول التدخل وموضوعه:

تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بالتدخل، ولا يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم. وتحكم المحكمة في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه (مادة ١٢٧ مرافعات). ومن ثم فإن المحكمة تحكم أولاً في قبول التدخل من عدمه قبل الفصل في موضوعه فإذا تبين لها توافر شروطه فإن عليها أن تقضي بقبوله، وحكمها بقبول التدخل من عدمه قضاء قطعي لا تملك الرجوع فيه.

وقد حرص المشرع على ألا يترتب على التدخل إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للفصل فيها؛ فنص على أن تفصل المحكمة في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت طلب التدخل لتفصل فيه بعد تحقيقه. وتجب ملاحظة أن طبيعة التدخل الانضمامي تحول دون إمكانية الفصل فيه مستقلاً عن موضوع الدعوى الأصلية، إذ الحكم الصادر فيها يكون فصلاً في طلب التدخل.

الفرع الثاني

اختصام الغير (الإدخال)

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها (مادة ١١٧ مرافعات). وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة (مادة ١١٨).

فاختصام الغير عبارة عن إجبار شخص من الغير أن يصبح طرفاً في خصومة قائمة، أو على أن يكون ماثلاً فيها، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بأمر تصدره المحكمة من تلقاء نفسها^(١).

(١) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٤٩٢.

ويهدف نظام اختصاص الغير إلى تحقيق أغراض متعددة، فقد يكون الهدف منه الحكم على المختص بالطلبات الأصلية المرفوعة بها الدعوى أو غيرها من الطلبات والتي قد توجه إليه بصفة خاصة، أو يكون الهدف منه جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة على الشخص المختص، فلا يمكنه بعد ذلك أن ينكر حجتيه أو يعترض عليه باعتراض الخارج عن الخصومة بحجة أنه لم يكن طرفاً فيها أو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه، أو لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده^(١). ويتميز اختصاص الغير عن التدخل في الخصومة في كون الاختصاص يتم رغم إرادة الغير، إذ يجبر على الدخول في خصومة لم ير هو محلاً للزج بنفسه فيها، بينما التدخل في الخصومة يحدث من تلقاء نفس الغير بإرادته عندما يتبين له أن ثمة تأثيراً للخصومة في مصلحته.

واختصاص الغير إما أن يكون بناء على طلب أحد الخصوم الأصليين، أو بناء على أمر المحكمة، كما أن الاختصاص إما أن يجعل الغير طرفاً في الخصومة، وهذا هو الاختصاص بالمعنى الدقيق، وإما أن يؤدي إلى مثلث الغير في الخصومة دون أن يصبح طرفاً فيها، ولا يعد هذا اختصاصاً إلا على سبيل التجاوز^(٢):

أولاً: اختصاص الغير بناء على طلب أحد الخصوم:

وفقاً لنص المادة (١١٧) مرافعات، فإن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصاصه فيها عند رفعها. ويعتبر اختصاص الغير بناء على طلب أحد الخصوم طلباً عارضاً يقدمه الخصم في مواجهة الغير، وقد يؤدي إلى أن يصبح الغير طرفاً في الخصومة، وهذا هو الاختصاص بالمعنى الدقيق، وقد يقتصر على إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في الخصومة.

ويشترط لاختصاص الغير بناء على طلب أحد الخصوم، أن يقدم طلب الاختصاص من أحد خصوم الدعوى سواء كان المدعي أو المدعى عليه، وأن يكون من الجائز اختصاص الخصم في الأصل عند رفع الدعوى، إذ لا يجوز أن يكره على الدخول في الدعوى إلا من كان في الإمكان اختصاصهم عند رفعها، كما يشترط أن يكون هناك ارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه إلى الغير، وهذا الشرط تقتضيه القواعد العامة. وفضلاً عن ذلك يشترط توافر الشروط العامة لقبول الدعوى (بأن يكون للغير المراد اختصاصه صفة في الاختصاص، وأن تتوافر فيه الأهلية اللازمة، وأن تكون هناك مصلحة من الإدخال في الدعوى)^(٣).

(١) د. عبد المنعم الشرقاوي، مرجع سابق، ص ٣٨٣.

(٢) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٤٩٣.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، التعليق، مرجع سابق، ص ٦٠٧-٦٠٨. أحمد مليجي، الموسوعة، ج ١٧/٣.

هذا ويلاحظ أن المشرع لم يحدد حالات معينة لاختصاص الغير، وإنما وضع قاعدة عامة يجوز بمقتضاها لأي خصم أن يدخل في الخصومة من يرى أن في مصلحته إدخاله. كما أن المشرع لا يجيز إدخال الخصوم إلا أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا يجوز أمام محكمة الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم ينص القانون على غير ذلك (مادة ٢٣٦ مرافعات)، لما في ذلك من مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين، كما لا يجوز أمام محكمة النقض اختصاص من لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه^(١). وأهم صور اختصاص الغير بناء على طلب أحد الخصوم، إدخال الضامن (دعوى الضمان الفرعية)، وإلزام الغير بتقديم ورقة أو عرض شيء تحت يده، وذلك كما يلي:

١- اختصاص الضامن (دعوى الضمان الفرعية):

ويقصد بدعوى الضمان الفرعية، اختصاص شخص من الغير يلتزم بضمان في مواجهة أحد أطراف خصومة قائمة، ونظراً لأهمية هذه الصورة من صور الاختصاص فإن المشرع نظمها بالمواد (١٢٢-١١٩) مرافعات^(٢).

ومعنى الضمان في قانون المرافعات أوسع من معناه في القانون المدني، فهو يشمل كل حالة يكون فيها للملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر لمطالبته بكل أو بعض ما أداه للدائن، فضلاً عن أن الضمان في المرافعات يشمل أيضاً حالته في المدني^(٣).

ومثال دعوى الضمان أن ترفع دعوى من الغير على المشتري باستحقاق المبيع، فيقوم المشتري باختصاص البائع (الضامن) في هذه الدعوى، فإذا صدر حكم ضد المشتري، أمكنه الحصول في نفس الخصومة بموجب دعوى الضمان الفرعية- على حكم ضد البائع (الضامن) برد الثمن والتعويض.

ويجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال الضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى. وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال ضامن جوازي للمحكمة. ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (مادة ١١٩ مرافعات). وعلى المحكمة أن تقضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية (مادة ١٢٠ مرافعات).

(١) د. عبدالتواب مبارك، مرجع سابق، ص ٣٩٩-٤٠٠.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٣٩١.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٦١٣.

٢- إلزام الغير بتقديم ورقة أو عرض شيء تحت يده:

أجازت المادة (٢٦) إثبات، للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال التي يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده (مادة ٢٠ إثبات)^(١). كما أوجبت المادة (٢٧) إثبات على كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به، متى كان الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه.

وفي هذه الحالة لا يعتبر الغير خصما بمعنى الكلمة وإنما هو أقرب إلى الشاهد منه إلى الخصم ويقتصر دوره على تقديم الدليل وفقا للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات^(٢).

ثانيا: اختصاص الغير بناء على أمر المحكمة:

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة (مادة ١/١١٨ مرافعات). حيث قرر المشرع بهذا النص قاعدة عامة تقضي بمنح المحكمة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى، وذلك لتحقيق أحد غرضين: الأول مصلحة العدالة، والثاني إظهار الحقيقة؛ إذ يجوز للمحكمة أن توجه طلبات الخصوم نحو الغير لتحقيق أحد هذين الغرضين.

فإذا قدرت المحكمة ضرورة إدخال شخص من الغير، فإنها تأمر الخصم الذي ترى أن إدخال الغير في صالحه باختصاصه، وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (م ٢/١١٨).

(١) يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في حالات ثلاث: ١- إذا كان القانون يجيز مطالبة بتقديمه أو تسليمه. ٢- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزامهما وحقوقهما المتبادلة. ٣- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

(٢) د. وجدي راغب فهبي، مرجع سابق، ص ٤٩٩.

المطلب الثالث

النطاق الموضوعي للخصومة

تفتتح الخصومة القضائية بصحيفة الدعوى التي يودعها المدعي قلم كتاب المحكمة المختصة متضمنة الطلبات التي يدعيها قبل خصمه، والأصل أن تظل هذه الطلبات محلاً أساسياً للإجراءات حتى يصدر الحكم المنهني للخصومة، باعتبار أن هذه الطلبات -الأصلية- هي التي تحدد نطاق الادعاء الأصلي موضوعاً وسبباً وخصوماً، وهذا يوجب على الخصوم والقاضي الالتزام بنطاق هذه الطلبات وعدم الخروج عليها أو تعديلها تحقيقاً لمبدأ ثبات النزاع، والذي يعني بقاء عناصر الطلب الأصلي كما هي دون تعديل حتى يفصل فيها بالحكم القضائي. غير أن فكرة ثبات النزاع تقيد الخصوم بقيد يتعذر معه مواجهة ما قد يستجد من عناصر جديدة يقتضي الأمر طرحها على المحكمة للفصل فيها رغم ما قد يكون بينها وبين الطلب الأصلي من ارتباط، ومن ثم جاءت نظرية الطلبات العارضة لتدخل شيئاً من المرونة على نظرية ثبات النزاع، وللتوفيق بين اعتبارين:

أولهما: احترام ما نص عليه المشرع في المادة (٦٣) مرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على طلبات المدعي وأسانيدها حتى يتمكن خصمه من تحضير دفاعه والرد على هذه الطلبات، وحتى يتمكن القاضي من نظر الدعوى على ضوء ما ورد في صحيفة، ولئلا تتعقد الإجراءات كل حين بطلبات يقدمها الخصوم بعد بدء الدعوى، ولكي لا يفاجئ الخصم خصمه بطلب لم يعد دفاعه للرد عليه.

وثانيهما: إعمال فكرة الاقتصاد في إجراءات التقاضي وجمع شتات الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي في خصومة واحدة، يفصل فيها بقرار قضائي يحول دون تعدد الخصومات برفع دعاوى مستقلة بكل طلب، وهو ما يؤدي إلى تعدد الدعاوى وتناقض الأحكام وزيادة العبء على القضاة وتضييع وقت المتقاضين وجهدهم^(١).

وللتوفيق بين هذين الاعتبارين حرص المشرع على ألا يظل محل الخصومة جامداً أو ثابتاً طوال سير الخصومة، وإنما أجاز للمتقاضين تعديل نطاق الخصومة في حدود معينة بتقديم طلبات عارضة أو دفع، وبهذا لا يقتصر نطاق الخصومة على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المفتحة للخصومة، وإنما يتسع ليشمل ما يقدم فيها من طلبات عارضة أو دفع.

ولما كنا قد فصلنا الحديث عن صحيفة الدعوى، وما يجب أن تشتمل عليه من بيانات، فإننا نتناول في هذا المطلب الحديث عن الطلبات العارضة والدفع، وذلك في فرعين على النحو الآتي:

(١) د. أحمد السيد صاوي، ص ٢٨٧- م. سيد البغال، ص ٤٨٣، د. عبد التواب مبارك، ص ٤٠٥.

الفرع الأول

الطلبات العارضة

الطلبات العارضة هي التي تتناول بالتعديل موضوع الطلب أو سببه أو أطرافه، وهي تقدم من المدعي أو المدعى عليه أو الغير، وتطرح في خصومة تولدت عن طلب أصلي افتتحت به الخصومة.

وتتميز الطلبات العارضة عن المسائل العارضة الأخرى التي تنعقد بها إجراءات الدعوى أو تحقيقها أو الحكم فيها دون أن تؤثر مباشرة في موضوع النزاع أو سببه أو أطرافه، ومثالها الدفوع والمنازعات المتعلقة بالإثبات وانقطاع الخصومة وقفها وطلب الحكم بسقوطها. كما تختلف عن الطلبات الاحتياطية والتي تقدم إلى جانب الطلبات الأصلية، في أن المدعي يهدف طلبه الاحتياطي الحكم له إما بالطلب الأصلي وإما بالطلب الاحتياطي، في حين أنه يستهدف بالطلب العارض الحكم له بالطلب الأصلي معدلاً بالطلب العارض أو الحكم بالطلب الأصلي والطلب العارض في نفس الوقت^(١).

وتختلف تسمية الطلبات العارضة بحسب مقدمها، فإذا كانت مقدمة من المدعي سميت بالطلبات الإضافية، وإذا كانت مقدمة من المدعى عليه سميت بدعوى المدعى عليه، وإذا كانت مقدمة من الغير سميت بالتدخل الاختياري، وإذا قدمت من الخصوم في مواجهة شخص خارج عن الخصومة سميت باختصام الغير.

وقد سبق أن بينا حالات التدخل والإدخال في الخصومة عند حديثنا عن تعديل نطاق الخصومة من حيث أشخاصها، ومن ثم يقتصر حديثنا هنا على الطلبات العارضة من جانب المدعي والطلبات العارضة من جانب المدعى عليه.

أولاً: الطلبات العارضة من المدعي (الطلبات الإضافية):

لئن كان المشرع قد تشدد في أخذ المدعي بواجب أن يبين في صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانا وافيا (مادة ٦٣) فإن علة هذا التشدد لا تبدو في كمالها إلا على اعتبار أن هذا البيان يحدد دعوى المدعي تحديداً إن لم يكن نهائياً فهو تحديد ثابت لخطوط الدعوى الرئيسية ووجهتها العامة ليستطيع المدعى عليه أن يرتب في نطاقه الخطوط الرئيسية لدفاعه أمناً من أن يفاجأ بضرورة تغييره كلما لاح للمدعي أن يربكه بإدخال تعديل جوهري على دعواه، وليستطيع في ظله القاضي أن يصرف قدرته على التوجيه وهو مطمئن إلى ثبات معالم الدعوى ثباتاً نسبياً

(١) المستشار. سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص ٤٨٤-د. عبد المنعم الشرقاوي، سابق، ص ٣٦٥.

لا يمنعها من الانكماش والاتساع والتطور بحسب ما تمليه ظروف المتقاضين ومصلحة التقاضي ولا يسمح بأن تصبح الخصومة صراعاً مائعاً يطول أجله ولا يسهل فضه على أن التسليم بنسبية هذا الثبات فيه تسليم بقدر من التغيير يجوز أن يلحق مقومات الدعوى ضرورة أو لمنفعة ولذا رأى في الوقت ذاته أن الضرورات العملية تقتضي أن يسمح للمدعي بقدر من الحرية في تغيير موضوع الطلب الأصلي لضرورة أو منفعة، وألا يحرم من فرصة تصحيح طلباته أو تعديل سببها بما يتفق مع مستنداته ووسائل إثباته وما يستجد من وقائع أثناء سير الدعوى^(١)، ولذلك نص في المادة (١٢٤) مرافعات على حق المدعي في أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي:

١- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى (١/١٢٤).

ذلك أن المدعي قد يتبين بعد رفع الدعوى من مراجعة مستنداته أو ما أسفر عنه تحقيق الدعوى أنه أخطأ في تحديد طلباته على النحو الذي ذكره في صحيفة الدعوى فيكون له أن يعدل موضوع الدعوى من حيث مقداره أو حدوده أو بدايته أو نهايته فينزل به إلى طلب أقل أو يرتفع به إلى طلب أكثر ما دامت عناصر الطلبين متداخله وما دام الطلبان يستندان إلى نفس السبب وبين نفس الخصوم^(٢).

ومثال تصحيح الطلب الأصلي أن يطالب المدعي بدين معين، ثم يتبين له أنه يستحق مبلغ أكبر فيطالب به، ومثال تعديل موضوع الطلب الأصلي الانتقال من طلب فسخ العقد إلى طلب تنفيذه أو العكس^(٣).

٢- ما يكون مكملًا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة (٢/١٢٤).

ومثال ذلك أن يطالب المدعي بفوائد الدين إذا كان الطلب الأصلي بقيمة الدين، أو أن يطالب بثمار العين إذا كان الطلب الأصلي بالملكية، وكذلك كل طلب يتعلق بتوابع الطلب الأصلي كالفوائد والربح والتسليم والإزالة، ويعتبر في حكم التوابع مما يجوز طلبه في صورة طلب عارض كل طلب تربطه بالطلب الأصلي صلة لا تقبل الانفصال^(٤).

(١) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بشأن المادة ١٥١ والمطابقة للمادة ١٢٤ من القانون الحالي.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٣/ ١٢٠.

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٢٥.

(٤) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق.

٣- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله (٣/١٢٤)^(١).

ووفقا لهذه الحالة فإن للمدعي أن يضيف سببا جديدا لطلبه أو يغير السبب، ما دام لا يعدل في محل الطلب، فإذا كان المدعي قد طالب بملكية شيء مستندا إلى عقد فله أن يعدل هذا السبب مضيفا إليه التقادم الخمسي بحسن نية أو أن يستبدل به التقادم الطويل، ولمن يطالب بدين على أساس أساس عقد قرض معين أن يستبدل بهذا السبب عقد قرض آخر. ومن ثم فإنه إذا لم يتمكن المدعي من الحصول على حكم بطلبه الذي يبنيه على سبب معين، فليس ثمة ما يمنعه من الإضافة إلى سبب الدعوى أو المطالبة به بناء على سبب آخر بطلب عارض، بدلا من رفع دعوى أخرى بالسبب الجديد.

٤- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقفي (٤/١٢٤).

ومثال ذلك مطالبة المدعي بتعيين حارس قضائي على الأرض محل النزاع، أو أن يطالب بتحديد نفقة مؤقتة له إلى أن يفصل في أصل الدين، ويختص قاضي الموضوع بالفصل في هذا الطلب إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (٤٥)، استثناء من الأصل العام في الاختصاص بنظر الإجراءات الوقفية أو التحفظية والذي ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة وحده (٤٥) مرافعات، باعتبار أن طلب الإجراء الوقفي طلبا عارضا بالنسبة لطلب الحكم في الموضوع.

٥- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي (٥/١٢٤).

وتختلف هذه الحالة عن الحالات السابقة في أن محكمة الموضوع لا يكون لها سلطة الحكم بعدم قبل الطلب العارض في الحالات الأربع الأولى، لأن الارتباط بين الطلبات المقررة في هذه الحالات وبين الطلب الأصلي مفترض بنص القانون، بينما في هذه الحالة الأخيرة وضع المشرع قاعدة عامة تجيز للمدعي أن يقدم أي طلب عارض شريطة أن تأذن المحكمة بتقديمه إذا رأت توافر الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي. فتقدير توافر الارتباط في هذه الحالة متروك لسلطة المحكمة، والتي يكون لها رغم توافر هذا الارتباط أن ترفض قبول الطلب العارض متى تبين لها أن المدعي قصد من وراءه العنت بخصمه.

(١) الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبدائه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي. نقض رقم ١٢٢٢ لسنة ٦٠ قضائية جلسة ١/١/١٩٩٥.

جواز إبداء الطلب الاحتياطي كطلب عارض^(١):

يجوز إبداء الطلب الاحتياطي مع الطلب الأصلي، كما يجوز إبداءه كطلب عارض بعد رفع الدعوى الأصلية، ومثال ذلك قيام مشتري العقار برفع دعوى على البائع طالبا فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له، فيتدخل آخر في الدعوى طالبا رفضها على سند من أنه المالك للمبيع، فالمشتري هنا أن يبدي طلبا احتياطيا بأن يحكم له في حالة عدم إجابته لطلبه الأصلي لعدم ثبوت ملكية البائع للمبيع بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد ثمن المبيع الذي قبضه.

ثانيا: الطلبات العارضة من المدعي عليه (دعوى المدعى عليه):

إذا كان من حق المدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما ورد النص عليه في المادة (١٢٤) مرافعات على النحو السابق بيانه، فإنه ينبغي ألا يحمل المدعى عليه على التزام موقف الدفاع في كل الأحوال، فقد يعرضه ذلك لضرر يلحقه أو منفعة تفوت عليه... ولذا فإن الرأي المعول عليه في الفقه الحديث أن ثمة حالات يتحتم فيها على القاضي قبول طلبات المدعى عليه وذلك حين يطلب المقاصة القضائية، وحين يكون الطلب دفاعا في القضية الأصلية، وحين يكون الطلب تعويضا عن ضرر أصاب المدعى عليه من الدعوى أو من إجراء فيها، وأن ثمة حالات يجوز فيها للقاضي قبول هذه الطلبات أو تكليف المدعى عليه برفعها بصفة أصلية وذلك حين يكون المبرر لتقديمها هو مجرد الارتباط^(٢). ولذلك أجاز المشرع للمدعى عليه الحق في تقديم طلبات عارضة في الدعوى.

وحتى لا يتخذ المدعى عليه هذه الطلبات وسيلة لتعقيد القضية أو تأخير الفصل في دعوى المدعي، أو مخالفة قواعد الاختصاص، أو وسيلة يتمكن بها من تهديد المدعي وحمله على التنازل عن دعواه، فإن المشرع قيد حقه في هذه الطلبات بالنص على نوعين من الطلبات العارضة التي يمكن له تقديمها في الدعوى (م ١٢٥ مرافعات):

النوع الأول: حالات محددة افترض فيها المشرع وجود ارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي^(٣):

وفي هذا النوع لا يكون للقاضي سلطة تقدير وجود الارتباط، وإنما عليه أن يحكم في الطلب العارض على أساس أن الارتباط مقرر بنص القانون، وهذه الطلبات هي:

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٢٤/٣.

(٢) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق عن المادة ١٥٢ والمطابقة للمادة ١٢٥ من القانون الحالي.

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٢٩.

١- طلب المقاصة القضائية (١/١٢٥).

فإذا رفع المدعى دعوى دائنية ضد المدعى عليه، فإن للمدعى عليه أن يرفع دعوى دائنية له في مواجهة المدعى بوسيلة الدعوى الفرعية، ويطلب من المحكمة إجراء المقاصة القضائية بينهما، ولا يشترط الارتباط بين الدينين فيمكن أن يكون سببهما مختلفاً^(١).

٢- طلب المدعى عليه الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها (١/١٢٥).

حيث أعطى المشرع للمدعى عليه الحق في تقديم طلب عارض رداً على الدعوى الأصلية تأسيساً على طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء الدعوى الأصلية إذا ما ترتب عليها بذاتها ضرراً أصاب المدعى عليه أو كان الضرر ناتجاً عن إجراء من إجراءاتها، شريطة أن تكون الدعوى الأصلية قائمة. وانعقاد الاختصاص بنظر الطلب العارض هنا مبني على أن المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية هي أقدر المحاكم على تقدير الضرر الذي لحق المدعى عليه جراء دعوى المدعى^(٢).

٣- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلانته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه (٢/١٢٥).

ومثال ذلك طلب فسخ عقد أو بطلانه إذا كانت الدعوى الأصلية بتنفيذه، وكالمطالبة بدفع تكاليف بناء إذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة بملكية الأرض المقام عليها البناء. وأساس جواز الطلبات العارضة في هذه الحالة أنها من مقتضيات حق الدفاع لأنها تنطوي على وسائل دفاع تؤدي إذا أجيبت إلى تجنب الحكم على المدعى عليه، ولكنها أبعد أثراً من مجرد الدفع، فإذا رفع بائع دعوى على مشتر بطلب ثمن المبيع فرد عليه المشتري بطلب فسخ البيع،

(١) د. محمد محمود إبراهيم: النظرية العامة للطلبات العارضة، دار الفكر العربي ١٩٨٤، ص ٢٩٩.

والعلة في استلزام طرح طلب المقاصة القضائية بشكل الدعوى أيما كانت (دعوى أصلية أو فرعية) أن مقتضيات المقاصة القانونية متخلفة، كما لو كان دين المدعى عليه ليس خالياً من النزاع من حيث الوجود أو المقدار، لأنه إذا توافرت شروط المقاصة القانونية المنصوص عليها في المادة (١/٣٦٢) مدني، فإنها تتم بقوة القانون بمجرد دفع المدعى عليه بها دون حاجة لحكم من القضاء. بينما الفرض هنا في الحالة الماثلة، تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية فيطلب المدعى عليه من محكمة الموضوع أن تقضي له بدينه بعد حسمه بإنهاء النزاع حوله ليصبح صالحاً لأن يتقاص مع دين المدعى، وتسعى المقاصة في هذه الحالة بالمقاصة القضائية لكونها تمت بحكم قضائي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الموضوع لا تملك إثارة طلب المقاصة القضائية من تلقاء نفسها، كما لا يجوز طلب هذه المقاصة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتباره يشكل طلباً جديداً، ويجوز طلب المقاصة القانونية لأول مرة أمامها.

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٢٩١. د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ١٥٥/٣- د. محمد محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص ٣١١.

فإن إجابة المشتري إلى طلبه سترتب عليها عدم الحكم للبائع بالثمن، فضلا عن دفع أي دعوى يوجهها أحد العاقلين إلى الآخر بناء على العقد الذي حكم بفسخه^(١).

وبلاحظ على نص هذه الفقرة أنها تضمنت ثلاث معايير في الطلبات العارضة وهي معايير مضادة للدعوى الأصلية، وهذه المعايير هي: الأول ألا يحكم للمدعي بكل طلباته، والثاني أن يحكم للمدعي ببعض طلباته وترفض الطلبات الأخرى، والثالث أن يحكم للمدعي بكل أو ببعض طلباته مع الحكم بقيد ما لمصلحة المدعى عليه^(٢).

والطلب الذي يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها يسمى بدعوى التقرير الفرعية، وصورة هذه الدعوى أن يقوم المدعى عليه بإنكار وجود رابطة قانونية أوسع من تلك التي يتمسك المدعي بوجودها تستند هذه الأخيرة إليها، ومثالها أن يرفع المدعي دعوى مطالبا المدعى عليه بالأجرة، فلا يدفع المدعى عليه الدعوى بسبق الوفاء بالأجرة، وإنما يتمسك ببطلان عقد الإيجار، أو يتمسك برابطة قانونية تعتبر متعارضة مع تلك التي يتمسك بها المدعي، كأن يطلب المدعي استرداد العقار باعتباره مالكا له، فيتمسك المدعى عليه بأن له رهنا حيازيا على العقار يخوله الاحتفاظ به^(٣).

٤- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة (٣/١٢٥).

قلنا إن الدعوى الفرعية تطرح بمناسبة الدعوى الأصلية، وأن وجه قبولها هو وجود ارتباط بينها وبين الدعوى الأصلية، كمقاصة قضائية، أو طلب تعويض عن ضرر من الدعوى الأصلية، ويكفي لقيام الدعوى الفرعية واعتبارها طلبا عارضا توافر الحد الأدنى من الارتباط، والذي يترتب على فقده انفصام الرابطة القانونية التي تجمع بين الدعويين وتجعلنا أمام دعويين أصليتين لا دعوى أصلية وأخرى فرعية، ومن ثم تزول الحكمة التشريعية من وجود الدعوى الفرعية.

والمشروع لم يقف عند هذا الحد في بيان مفهوم الدعوى الفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية وإنما ارتقى بفكرة الارتباط إلى معيار إجرائي آخر، فنص في المادة (١/١٢٥) على قبول الطلب العارض إذا كان متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة، فسمح للمدعى عليه بذلك بتقديم طلبات عارضة بلا تحديد مسبق من المشروع لنوع هذه الطلبات أو مضمونها، شريطة أن تكون هذه الطلبات مرتبطة بالطلب الأصلي ارتباطا لا يقبل التجزئة، وهو ارتباط كلي يختلف

(١) د. رمزي سيف، مرجع سابق، ص ٣٤٦.

(٢) د. محمد محمود إبراهيم، النظرية العامة للطلبات العارضة، مرجع سابق، ص ٣١٦ وما بعدها.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ١٥٦/٣.

عن الارتباط المكفول للمدعي بنص المادة (١/١٢٤) والذي يكون له بمقتضاه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مكملًا للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلًا به اتصال لا يقبل التجزئة. فالطلب المكمل والطلب المترتب لا يكون إلا للمدعي أما الطلب المتصل فهو ملك لكل من المدعي والمدعى عليه^(١).

ومثال الطلب العارض المقدم من المدعى عليه والذي لا يقبل التجزئة، أن تكون الدعوى بالتعويض عن حادثة تصادم، فيطلب المدعى عليه تعويضه هو عن نفس الحادثة، أو أن تكون الدعوى بطلب امتداد العلاقة الإجارية عن الشقة فيطلب المدعى عليه إخلاء الشقة، أو أن يطالب شخص بملكية عين فيطالب خصمه بالملكية لنفسه. وتقبل مثل هذه الطلبات تجنبًا لتضارب الأحكام في المنازعات المرتبطة^(٢).

النوع الثاني: الطلبات العارضة التي لم يفترض المشرع فيها الارتباط بينها وبين الدعوى الأصلية، وإنما ترك للمحكمة سلطة تقدير مدى توافر هذا الارتباط.

فنص في الفقرة الأخيرة للمادة (١٢٥) على حق المدعى عليه في أن يقدم من الطلبات العارضة ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية، فتقدير الارتباط هنا متروك لمحكمة الموضوع، ولها حال ذلك الإذن بتقديم الطلب العارض. ومثال هذه الطلبات: أن يرفع البائع دعوى بطلب ثمن المبيع، فيرد عليه المشتري بطلب الحكم له بتسليم العين المباعة. وكأن يطالب الموكل الوكيل بتقديم حساب بمناسبة الوكالة فيطالبه الوكيل بمصاريفه وأتعابه. ويكفي لقبول الطلب العارض في هذه الحالة أن يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي، ولو كان مغايرًا له في سببه وموضوعه^(٣).

ثالثًا: النظام الإجرائي للطلبات العارضة:

١ - كيفية تقديم الطلب العارض:

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو كطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها (مادة ١٢٣ مرافعات).

(١) د. محمد محمود إبراهيم، النظرية العامة للطلبات العارضة، مرجع سابق، ص ٣٦٥-٣٦٦.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٣/١٥٧.

(٣) المرجع السابق، ج ٣/١٥٧.

ووفقا لما قرره المادة المشار إليها فإن الطلب العارض يقدم إلى المحكمة سواء أكان من المدعي أم المدعى عليه بأحد طريقتين:

الأول: تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، شريطة أن تشتمل الصحيفة على البيانات التي نص عليها المشرع في المادة (٦٣) مرافعات، وأن يراعى في ذلك ميعاد الحضور المقرر.

الثاني: تقديم الطلب العارض شفاهة في الجلسة، على أن يثبت في محضرها، ويشترط في هذه الحالة حضور الخصم الآخر الذي يقدم الطلب العارض في مواجهته، والذي يكون له الحق في طلب مهلة للرد على الطلب العارض، وعلى المحكمة أن تجيبه إلى ذلك إحتراما لحق الدفاع (مادة ٩٧ مرافعات)^(١).

وفي جميع الأحوال يشترط توافر المصلحة لقبول الطلب العارض، إعمالا لما تقضي به المادة (٣) مرافعات، من عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.

كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة (١٢٦ مكرر) مرافعات، من عدم قبول الطلب العارض إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.

٢ - ميعاد تقديم الطلب العارض:

يجوز تقديم الطلب العارض في أية مرحلة كانت عليها الإجراءات إلى ما قبل قفل باب المرافعة، وذلك حتى لا يترتب على الطلب تأخير الفصل في الدعوى الأصلية بعد أن تهيئت للحكم فيها بقفل باب المرافعة.

ولا يحول قفل باب المرافعة دون طلب الخصوم من المحكمة فتحه من جديد لتقديم طلباتهم العارضة، وللمحكمة السلطة التقديرية الكاملة في إجابة هذا الطلب أو رفضه، حسبما تستبين من جديته ولزومه لصحة الفصل في الدعوى. على أن باب المرافعة لا يعد مقفلا إذا كانت المحكمة قد صرحت للخصوم بأجل لتقديم مذكرات بعد حجز الدعوى للحكم، فلهم في هذا الأجل تقديم ما يرونه من الطلبات العارضة، شريطة أن يمكن الخصم الذي قدمت هذه الطلبات في مواجهته من الإطلاع والرد عليها، وإلا كان ذلك إخلالا بحقه في الدفاع^(٢).

(١) فإذا كان الخصم المراد تقديم الطلب في مواجهته غائبا عن الجلسة، فلا يجوز تقديم الطلب شفاهة، ولكن لصاحب الطلب العارض أن يطلب تأجيل الدعوى لتقديم طلبه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوع الشاملة، مرجع سابق، ج ٣/١٠١.

٣- المحكمة المختصة بالطلبات العارضة:

تقدم الطلبات العارضة بمناسبة قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة، ومن ثم تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بنظر الطلب العارض توحيدا لجمع شتات المسائل المرتبطة، وحتى لا تتفرع الخصومات والمنازعات فتتعارض الأحكام، وقد نص المشرع على اختصاص محكمة الموضوع بنظر الطلب العارض، غير أنه اشترط في هذا الصدد أن تكون هذه المحكمة مختصة نوعيا بنظره إن قدم إليها على استقلال. ومن ثم تجب التفرقة بين فرضين:

الفرض الأول: إذا كانت المحكمة التي تنظر الطلب الأصلي هي المحكمة الابتدائية: وفي هذا الفرض تكون المحكمة الابتدائية مختصة بنظر الطلب العارض في جميع الأحوال وأيا كانت قيمته؛ باعتبارها صاحبة الاختصاص العام، وإعمالا لما قرره المادة (١/٤٧) مرافعات بنصها على أنه "كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي، مهما تكون قيمتها أو نوعها".

الفرض الثاني: إذا كانت المحكمة التي تنظر الطلب الأصلي هي المحكمة الجزئية: فإنه تجب التفرقة في شأن اختصاصها بنظر الطلب العارض من عدمه بين حالتين:

الأولى: إذا كان الطلب العارض يدخل - بحسب قيمته أو نوعه- في اختصاصها، فإنها تختص بنظره.

والثانية: إذا كان الطلب العارض -بحسب قيمته أو نوعه- لا يدخل في اختصاصها وإنما يكون الاختصاص به منعقدا للمحكمة الابتدائية، فإن على المحكمة الجزئية في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى الأصلية وحدها وتحيل الطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية المختصة به. إعمالا لما أوجبه المادة (٤٦) مرافعات بنصها على أنه "لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة..."

أما إذا كان يتعذر الفصل بين الطلب العارض والطلب الأصلي بأن كان الحكم في أحدهما يتوقف على الحكم في الآخر، أو كان لا يصح الحكم على كل منهما استقلالا عن الآخر، فإن على المحكمة الجزئية في هذه الحالة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن (مادة ٤٦ مرافعات).

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون المحكمة التي تنظر الطلب الأصلي مختصة بنظر الطلب العارض من جميع الوجوه، فيجوز لها نظره وإن لم تكن مختصة محليا بنظره إن قدم إليها على استقلال، باعتبار أن قواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام العام، وعلاقة الارتباط بين الطلب الأصلي والعارض تبرر مخالفة هذه القواعد.

٤- الحكم في الطلب العارض:

تحكم المحكمة في كل نزاع متعلق بقبول الطلب العارض أولا، ثم تنتقل بعد ذلك للحكم في موضوع هذا الطلب. وقد نصت المادة (١/١٢٧) مرافعات على ضابط عام يجب مراعاته عند الحكم في الطلبات العارضة، وهو ألا يترتب عليها إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها. وإعمالا لهذا الضابط نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، فإذا لم يمكن ذلك استبقت المحكمة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

وتظل هذه المحكمة مختصة بالطلب العارض في حالة فصلها في الدعوى الأصلية والإبقاء على الطلب العارض للفصل فيه مستقلا فيما بعد وإن لم تكن مختصة به في الأصل لو قدم استقلالا، وإذا انقضت الخصومة بغير حكم في موضوعها، كما لو حكم ببطلان صحيفة الدعوى أو باعتبار الخصومة كأن لم تكن أو بسقوطها، فإن ذلك يؤدي إلى زوال الطلب العارض بالتبعية، إلا إذا كان قد قدم بالطريق المعتاد لرفع الدعوى وكانت المحكمة مختصة به من جميع الوجوه فيبقى لتنظره وتفصل فيه كطلب أصلي^(١)

(١) د. عيد محمد القصاص، قانون المرافعات، ص ٥٠٢-٥٠٣. د. عبد التواب مبارك، ص ٤١٥-٤١٦.

الفرع الثاني الدفع

تعريفها:

الدفع هي الوسائل التي يتمسك بها الخصم لتفادي الحكم بطلبات خصمه أو تأخير هذا الحكم. أو هي الوسائل التي يرد بها المدعى عليه على طلبات المدعي حتى لا يحكم عليه بها؛ فهي لا تهدف إلى الحكم لصالح المتمسك بها بشيء على خصمه؛ وإنما تهدف فقط إلى منع الحكم لهذا الخصم بطلباته أو تأخير هذا الحكم^(١).

وتختلف فيما بينها بحسب موضوع كل منها، والغرض المقصود بها، والنتيجة التي يؤدي إليها الحكم بقبولها^(٢). فإذا رفع شخص دعوى على آخر يطالبه بمبلغ معين باعتباره ثمنًا لعين اشتراها المدعى عليه، فإن المدعى عليه قد يدفع هذه الدعوى بإحدى ثلاث صور^(٣):

الأولى: أن يدفع الدعوى منازعا في الحق الذي يدعيه المدعي، بأن ينكر واقعة الشراء كلية أو يزعم بطلان البيع لأنه شابه سبب مبطل له، وقد لا ينكر نشوء الحق في ذمته صحيحا ولكنه يزعم انقضاءه بسبب من الأسباب التي تنتهي بها الحقوق بعد نشوئها كالوفاء أو المقاصة أو التقادم.

والثانية: أن يدفع الدعوى دون أن ينازع في الحق المدعى به، ولكنه يدفعها بدفع يطعن به في صحة الخصومة، كما لو دفع الدعوى بأنها رفعت إلى محكمة غير مختصة، أو أن الإجراء الذي رفعت به باطل.

والثالثة: أن يدفع الدعوى بدفع لا يتعرض به للحق المدعى به من حيث نشوئه أو من حيث صحته أو من حيث بقائه قائما حتى رفع الدعوى، ولا يطعن به على صحة الخصومة، وإنما يدفعها بدفع ينازع به في حق المدعي في رفع الدعوى، أن يزعم المدعى عليه ألا مصلحة للمدعي في الدعوى فلا حق له في رفعها، أو أن يزعم ألا حق له في الدعوى لفوات الميعاد الذي يجب رفعها فيه.

(١) أستاذي د. حامد أبوطالب، مرجع سابق ص ٥٥٢- د. عبد التواب مبارك، مرجع سابق، ص ٤١٧.

والدفع بمعناه الواسع يطلق على كافة الوسائل التي يتيحها المشرع لأحد الخصوم في دحض ادعاء خصمه، بغية عدم إجابة المحكمة لطلباته، وهو حق المدعى عليه باعتباره الوجه المقابل للدعوى المرفوعة عليه، كما أنه حق للمدعي في الرد على الطلبات العارضة أو الدفع المقدمة من المدعى عليه. وبهذا المعنى فإن الدفع يعد وسيلة دفاع سلبية، وإن كان يحدد نطاق أو محل الخصومة. (د. محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٦٥٩).

(٢) أستاذي د. حامد أبوطالب، مرجع سابق ص ٥٥٢.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٨٧٢/٢.

الدفع ثلاثة أنواع:

الأولى: دفع شكلي، يطعن بها على صحة الخصومة أو شكلها، والثانية: دفع موضوعية، ينازع بها المدعى عليه في الحق المدعى به، والثالثة: دفع بعدم القبول، متعلقة بشروط قبول الدعوى. ويشترط لقبول أي منها توافر المصلحة.

النوع الأول

الدفع الشكلي أو الإجرائية

وهي الدفع المتعلقة بإجراءات الدعوى، ولذا يطلق عليها الدفع الإجرائية، ويعد الدفع شكلياً إذا كان يرمي إلى تعطيل النظر في القضية لسبب يتعلق باختصاص المحكمة أو بإجراءات الخصومة. ويعرفها الفقه القانوني بتعريفات متعددة، يمكننا من خلالها تعريف الدفع الشكلي بأنه، الدفع الذي يوجه إلى إجراءات الخصومة بغرض استصدار حكم ينهيها دون الفصل في موضوعها، أو يؤدي إلى تأخير الفصل فيها، وذلك بغير مساس بأصل الحق المدعى به، كالدفع بعدم اختصاص المحكمة، أو ببطالان صحيفة الدعوى.

والدفع الشكلي لا ترد تحت حصر معين، بل تشمل سائر الدفع التي تستهدف الإجراءات، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء، والدفع ببطالان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي، أو ببطالان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب، أو بسقوط أمر الأداء لعدم إعلانه في الميعاد، أو بسقوط الخصومة أو بانقضائها، وغيرها من الدفع التي تنصب على الإجراءات ولا تمس أصل الحق المدعى به.

ومما يميز بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي، وجوب توافر المصلحة والصفة في الدفع الموضوعي، أما في الدفع الشكلي فيفترض فيه توافر المصلحة والصفة دائماً، لأن المشرع حدد سلفاً شكل الإجراءات لتحقيق مصالح معينة قدر أنها ستضار بمجرد الإخلال بالقواعد التي تنظم الإجراءات^(١).

أولاً: القواعد التي تحكم الدفع الشكلي:

تحكم الدفع الشكلي مجموعة من القواعد، ورد النص عليها في المادة (١٠٨) مرافعات، وهذه القواعد هي:

(١) للمؤلف: نظرية القرائن في قانون المرافعات، مرجع سابق، ج١/٤٩٦.

القاعدة الأولى: وجوب إداؤها قبل الكلام في الموضوع أو الدفع بعدم القبول:

وهو ما عبر عنه المشرع في المادة (١٠٨) مرافعات بوجوب إبداء الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيه. وهذه القاعدة قيد الحق في إبداء الدفع الشكلي بتقديمه قبل واقعة معينة، وهي التكلم في الموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول، فإذا تحققت الواقعة قبل تقديم الدفع، سقط الحق فيه.

وعلة ذلك ألا تبقى الإجراءات مهددة بدفوع شكلية يملكها الخصم ويبدئها وقتما يعن له ذلك، وبما قد يؤدي إلى مفاجأة المحكمة بدفع يترتب عليه زوال الخصومة أمامها قبل الفصل في موضوعها بعد أن تكون قد سارت شوطا كبيرا في تحقيقها وأوشكت على الفصل فيها، فضلا عما يعنيه ذلك من بقاء الخصم مهددا طيلة مراحل الدعوى بما قد يثيره خصمه من دفوع شكلية^(١).

ويعتبر أي طلب أو دفاع من المدعى عليه مما يتعلق بالموضوع مسقطا للحق في الدفوع الشكلية، سواء أبادي الطلب أو الدفاع شفاهة أو في مذكرة مكتوبة، وسواء تضمن اعتراضا على ادعاء المدعي أم لا^(٢).

ومن قبيل هذا التكلم في الموضوع المسقط للحق في الدفع الشكلي، طلب رفض طلبات الخصم أو مجرد المنازعة فيها، أو إبداء طلب عارض، أو طلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة نفي أو طلب وقف الدعوى اتفاقا أو لحين الفصل في مسألة أولية، أو إجابة بعض طلبات المدعي^(٣)، إلى غير ذلك مما يعد تكلمًا في الموضوع.

غير أنه لا يعتبر كلاما في الموضوع مسقطا للدفع الشكلي مجرد التعرض للموضوع بصفة عامة غير محددة بعبارات ذات طابع شكلي محض، كالقول بأن "الادعاء لا أساس له على أية حال"، إذ لا يعد ذلك طلب أو دفاع أو دخولا في موضوع القضية. والمقصود بالدفع بعدم القبول الذي يجب أن تبدي الدفوع الشكلية قبله، هو الدفع بعدم القبول الموضوعي، فلا تنطبق القاعدة على عدم القبول المتعلق بالإجراءات^(٤).

(١) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٣١١.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٤٩.

(٣) د. محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٦٦٤.

(٤) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٤٩.

وأما عن طلب التأجيل، فتجب التفرقة في شأنه بين حالتين: الأولى، أن يكون الطلب قد بني على سبب موضوعي، كالتأجيل لإدخال ضامن، أو لتقديم مستند، أو للصلح، وهذا يعد كلاماً في الموضوع يسقط الحق في الدفع الشكلي. والثانية: طلب التأجيل غير المبني على سبب موضوعي، كالتأجيل للاطلاع على المستندات أو لمجرد الاستعداد، فهذا لا يسقط الحق في الدفع الشكلي^(١).

ولا يسقط حق الخصم في الدفع الإجرائي إذا قدم مذكرة به وتضمنت المذكرة كلاماً في الموضوع، ولو كان ترتيب الكلام سابقاً على الدفع الشكلي في المذكرة، كما لا يسقط بما يبيده غيره من طلبات أو دفع موضوعية. واعتبار ما أبداه الخصم كلاماً في الموضوع أو عدم اعتباره كذلك، مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض^(٢).

القاعدة الثانية: يجب إبداء الدفوع الشكلية معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها:

فإذا أراد الخصم التمسك بأكثر من دفع شكلي فعليه تقديمها معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، فتقديم دفع شكلي يترتب عليه سقوط الحق في تقديم دفع شكلي آخر، ولو لم يحدث كلام في الموضوع، فلا يستطيع الخصم إبداء دفع بعدم الاختصاص، ثم يبدي بعده دفعا ببطالان صحيفة الدعوى، وإنما عليه أن يتمسك بهما معاً.

القاعدة الثالثة: يجب إبداء جميع الوجوه التي يبني عليها الدفع معاً وإلا سقط

الحق فيما لم يبد منها:

وذلك حتى لا تتعطل الإجراءات كل حين بإبداء أسباب جديدة للدفع الشكلي الذي سبق الدفع به، ولهذا فإذا بني الدفع على أكثر من وجه، وجب تقديمها جميعاً معاً وقبل التكلم في الموضوع، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، فإذا دفع الخصم بطلان صحيفة الدعوى مثلاً لعيب شكلي، فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بالبطلان لهذا العيب بسبب آخر لم يسبق له تقديمه^(٣).

القاعدة الرابعة: يجب إبداء الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن، وإلا سقط الحق فيها:

فإذا غاب المدعى عليه عن حضور جلسات الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لبطلان إعلانه بها، وصدر الحكم عليه في موضوعها بناء على هذا الإعلان الباطل، جاز له الطعن في

(١) د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٥١٠ وما بعدها. د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٤١٩.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٥٠. د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٤١٩.

(٣) د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٢٣٧.

الحكم بناء على بطلان إعلانه، غير أن حقه في التمسك بهذا الدفع يسقط بعدم إبداءه في صحيفة الطعن^(١). والأمر ذاته إذا كان الحكم مشوباً بعيب شكلي، فإن التمسك بهذا العيب يجب إبداءه في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق فيه، وهذا ما قرره المادة (١٠٨) مرافعات بنصها على أن "يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن".

ثانياً: الإستثناء من هذه القواعد:

يستثنى من القواعد السابقة نوعين من الدفوع الشكلية، لا يخضعان لهذه القواعد، هما:

الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام: ومثالها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولأثنا أو نوعياً أو قيمياً، أو الدفع ببطلان عمل إجرائي لمخالفته مقتضى يتعلق بالنظام العام، فمثل هذه الدفوع يجوز إبدائها ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، كما لا تسقط بالتكلم في الموضوع، وذلك لأن الدفع بها متعلق بالنظام العام، تأثيره المحكمة وتحكم به من تلقاء نفسها، ولا يعدو تمسك الخصم بالعيب كونه تنبيهاً للقاضي للقيام بواجبه، فلا يتصور سقوطه بمخالفة القواعد السابقة^(٢).

الدفوع الشكلية التي ينشأ سببها بعد الكلام في الموضوع: فمثل هذا الدفع لم يكن قد قام موجبه قبل الكلام في الموضوع، فلا يتصور التمسك به قبل ذلك، ومثاله سقوط الخصومة بعد أن قطعت المحكمة في نظرها شوطاً، فلا يسقط حق الخصم في التمسك بالسقوط هنا إلا إذا تكلم في الموضوع من جديد بعد قيام سبب الدفع^(٣).

ثالثاً: الحكم في الدفع الشكلي:

الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي على استقلال قبل النظر في موضوع الدعوى، لأن ذلك قد يغنيها عن الفصل في الموضوع إذا ما ترتب على الحكم في الدفع انقضاء الخصومة أمامها، كما لو حكمت بعدم اختصاصها أو بسقوط الخصومة. غير أن ذلك ليس واجباً عليها، فلها أن تبقي الفصل في الدفع الشكلي للفصل فيه مع موضوع الدعوى، فقد أجاز لها المشرع ذلك حين يتطلب الفصل في الدفع تحديد الموضوع، بنصه في المادة (١٠٨) على أن "يحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما

(١) د. وجدي راغب فهبي، مرجع سابق، ص ٤١٩.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٤٩.

(٣) د. وجدي راغب فهبي، مرجع سابق، ص ٤٢٠.

حكمت به في كل منها على حدة". ويتضح من هذا النص أن سلطة المحكمة في الضم مقيدة بقيدين^(١):

الأول: تمكين الخصوم من تقديم دفاعهم الموضوعي، وعليها أن تنبهم إلى الضم خشية أن يمتنعوا عن الدفع الموضوعي انتظاراً للفصل في الدفع الإجرائية، ثم يفاجأوا بحكمها في الموضوع، وفي هذا من الإخلال بحقوق الدفاع ما يبطل الحكم.

والثاني: أنه يجب على المحكمة حين تقضي في الموضوع أن تبين ما حكمت به في كل من الدفع الإجرائي والموضوع على استقلال، وهذا يقتضي تسبيب حكمها في كل منهما على حدة، وهي في هذا الصدد قد لا تقضي في الموضوع رغم الضم، إذا تبينت عدم اختصاصها بناء على الدفع وحكمت به.

رابعاً: الأثر المترتب على الحكم في الدفع الشكلي:

الحكم الصادر في الدفع الشكلي هو حكم إجرائي، لا يمس أصل الحق، ولا تستنفد به المحكمة ولايتها، ولا يحوز حجية الأمر المقضي، ويترتب على ذلك ما يلي^(٢):

- ١- إذا حكمت المحكمة في الدفع الشكلي حكماً منهيًا للخصومة أمامها، فإن ذلك يعد إنهاء إجرائياً دون حكم في موضوعها، ومن ثم يجوز تجديد الخصومة ذاتها أما المحكمة ذاتها مرة أخرى، ما لم يكن الحق الموضوعي قد انقضى بالتقادم^(٣). غير أنه يعد حكماً قطعياً يستنفد سلطة المحكمة بالنسبة للمسألة الإجرائية التي فصل فيها داخل الخصومة نفسها.
- ٢- إذا طعن الخصم في الحكم بالاستئناف فإنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا الخصومة في الدفع، فإذا حكمت بإلغائه، فإنها لا تتصدى للموضوع، بل يجب عليها أن تعيد النزاع إلى محكمة أول درجة لتفصل فيه من جديد، لأنها لم تستنفد ولايتها بالنسبة للموضوع، ومن ثم يكون تصدي محكمة الاستئناف للفصل فيه سبباً في تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم ومخالفاً لمبدأ التقاضي على درجتين.

(١) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٥٤- د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٤٢٠.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٨٧٧/٢- د. عبدالنواب مبارك، مرجع سابق، ص ٤٢٩- وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٤٢١.

(٣) وتجب الإشارة إلى أنه إذا انقضت الخصومة بحكم إجرائي مبني على عدم اختصاص المحكمة ولائياً أو نوعياً أو قيمياً، فلا يجوز تجديد الخصومة أمامها مرة أخرى، ولا تنظر النزاع إلا إذا طعن في هذا الحكم وألغته محكمة الاستئناف.

النوع الثاني

الدفع الموضوعية

الدفع الموضوعي هو الذي يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفض الدعوى كلياً أو جزئياً^(١). فهو دفع يوجه إلى ذات الحق المدعى به كأن ينكر وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاءه، كالدفع ببطلان سند الدين أو بتزويره، والدفع بانقضاء الدين بالوفاء. فالدفع الموضوعية إذا تشمل كل دفع يترتب على قبوله رفض طلب المدعى، ولهذا لا يتصور حصرها، ومن ناحية أخرى، هذه الدفع تتعلق بأصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق^(٢).

ويعد هذا الدفع الوجه المقابل للدعوى، ولهذا يجب فيه ذات الشروط الواجب توافرها في الطلب الموضوعي، كالمصلحة والصفة، ويختلف الدفع الموضوعي عما يكون للمدعى عليه من دعاوى، حيث لا يرمي إلا لمجرد تفادي الحكم للمدعي بطلباته^(٣). والمدعى عليه في سبيل الحصول على حكم برفض الدعوى، قد يقوم بما يأتي^(٤):

١- إنكار الواقعة المنشئة التي تمسك بها المدعي كأساس لطلبه، أو إنكار الآثار القانونية التي ينسبها المدعي إلى هذه الوقائع، وتسمى هذه بالدفع السلبية.

مثل إنكار الخطأ أو الضرر في دعوى التعويض عن الفعل الضار، أو إنكار التوقيع على العقد المقدم دليلاً في دعوى مرفوعة بتنفيذ العقد، أو إنكار أن عقد البيع المبرم بين الطرفين يرتب إلزاماً بالضمان في دعوى الضمان.

٢- التمسك بواقعة معاصرة لنشأة الواقعة التي يتمسك بها المدعي، من شأنها منع هذه الأخيرة من انتاج كل أو بعض آثارها القانونية، كما لو تمسك المدعى عليه بصورية العقد الذي يستند إليه المدعي في دعواه، أو بإبطاله لعيب في الإرادة.

٣- التمسك بواقعة منبهة للحق المدعى به، بأن يتمسك المدعى عليه بواقعة من شأنها إنهاء آثار الواقعة المنشئة التي تمسك بها المدعي، كالتمسك بالوفاء أو بالمقاصة أو بالتقادم.

وتختلف الحالين الأخيرتين عن الأولى، في أن الدفع فيهما دفع إيجابي، يجب على الخصم في أيهما أن يثبت الوقائع التي يدعيها باعتباره يتمسك بواقعة جديدة تحتاج إلى دليل عليها، بخلاف الحالة الأولى - والدفع فيها سلبية - فإنه لا يقع على المتمسك بها إثبات إنكاره للوقائع، وإنما يجب على المدعي إثبات الوقائع التي يدعيها.

(١) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٤١٤.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٥٠٩.

(٣) د. محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٦٧٥.

(٤) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٤٤-د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٤١٥.

الدفع بالمعنى الضيق والواسع:

يرى الفقه أن الوقائع المانعة أو المنهية التي يتمسك المدعى عليه بها تنقسم إلى طائفتين^(١):
الأولى: وقائع لا يشترط تمسك الخصم بها، وإنما يجب على القاضي أخذها في اعتباره من تلقاء نفسه مادامت قد طرحت عليه، ولا يمنعه من ذلك تنازل الخصم عنها فهذه ترتب آثارها بقوة القانون، ومثالها واقعة عدم مشروعية السبب أو واقعة الوفاء بالدين، وتمسك المدعى عليه بهذه الواقعة ليس أكثر من مجرد لفت انتباه القاضي إلى واجبه في الخصومة، ومن ثم فهي لا تحتاج من الناحية القانونية لفكرة الدفع، وهذه الحالات هي:

- إذا كانت المسألة متعلقة بالنظام العام، كبطلان العقد لعدم مشروعية سببه.
- ارتباط الدفع بفكرة الإثبات، والتي توجب على المدعي إثبات ما يدعيه وإلا حكم القاضي برفض ادعائه.

- يثير القاضي من تلقاء نفسه أي مسألة قانون.

والثانية: وقائع يتوقف أثرها في الدعوى على تمسك الخصم بها، فإن لم يفعل، فلا تكون ذات أثر في الدعوى، أما إذا تمسك بها؛ حكم القاضي برفض الدعوى نتيجة لاستعمال حق محدد للمدعى عليه، وهذا هو الدفع الموضوعي بالمعنى الضيق.

أحكام الدفع الموضوعية:

- ١- الدفع الموضوعية يجوز إبدائها في أية حالة كانت عليها الإجراءات، كما يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
- ٢- لا يتقيد المدعى عليه في إبداء هذه الدفع بترتيب معين، وإذا أبدى دفعا منها فإنه لا يسقط حقه في إبداء غيره من الدفع الموضوعية، ما لم يتنازل عنه صراحة. غير أنه لا يجوز التمسك بهذه الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
- ٣- الحكم الصادر في الدفع الموضوعي يحوز حجية الأمر المقضي باعتباره فاصلا في الموضوع. حيث يترتب على قبوله إنهاء النزاع، ومن ثم يحول إلى عرض النزاع على المحكمة مرة أخرى، وإذا قدم دفع موضوعي أمام محكمة أول درجة وفصلت فيه بحكم ألغته محكمة الاستئناف، فإنها لا تعيد النزاع مرة أخرى إلى محكمة أول درجة، بل تفصل فيه لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها بشأن النزاع^(٢).

(١) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٤٢٠.

(٢) د. محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٦٧٧.

النوع الثالث

الدفع بعدم القبول

قلنا إن الدفع الشكلي يوجه إلى صحة الخصومة وإجراءاتها، وأن الدفع الموضوعي يوجه إلى الحق موضوع الدعوى، وكلاهما يختلف عن الدفع بعدم القبول، إذ في هذا الأخير يوجه الدفع إلى حق المدعي في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق - الموضوعي - الذي ترفع به الدعوى، ويعد طعنا بعدم توافر شرط من شروط قبول الدعوى، وسواء كان الشرط عاما في كل دعوى أم خاصا بالدعوى محل الدفع^(١).

فهذا الدفع يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى، فهو يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه وما إذا كان من الجائز استعمالها أم أن شرط الاستعمال غير جائز^(٢). وبهذا المعنى يمكن تعريفه بأنه "الوسيلة الإجرائية التي حددها المشرع للتمسك بتخلف الشروط القانونية الواجب توافرها في الدعوى القضائية، والتي تكون لازمة لقبول هذه الدعوى"^(٣).

طبيعته:

عدم القبول بهذا المعنى هو تكييف قانوني لإعلان رغبة مقدم إلى المحكمة يترتب عليه امتناعها عن النظر في الدعوى^(٤) لتخلف شرط من شروط قبولها. وهو بذلك ليس دفعا موضوعيا أو دفعا شكليا محضا وليس دفعا مختلطا يجتمع فيه خصائص الدفع الشكلي والدفع الموضوعي، إنما هو طائفة مستقلة من الدفوع الموجودة في قانون المرافعات، يتوجه إلى الحماية القضائية المطلوبة بهدف إنكار حق طالها فيها^(٥)، وتؤثر طبيعته في نظامه القانوني.

أمثلته:

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، أو لعدم اختصاص من يجب اختصاصه فيها، أو لرفعها من غير ذي صفة، أو بعد فوات الميعاد، أو لسبق الفصل فيها، والدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وعدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف^(٦).

(١) المرجع السابق، ص ٦٧٨.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ١٠٩٧/٢.

(٣) د. مصطفى هرجه: الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، ١٩٩٥م، ج ٨٣/١.

(٤) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٥٥.

(٥) د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٢٤٠.

(٦) د. عبدالنواب مبارك، مرجع سابق، ص ٤٣٠.

أحكام الدفع بعدم القبول:

يحكم الدفع بعدم القبول مجموعة من القواعد، منها ما قد يتفق أو يختلف مع القواعد التي تحكم الدفوع الشككية، والموضوعية، وذلك على النحو الآتي:

القاعدة الأولى: الدفع بعدم القبول يجوز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى:

وهذه القاعدة ورد النص عليها صراحة في المادة (١١٥) مرافعات، بنصها على أن "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبدائه في أية حالة تكون عليها"، ومن ثم فلا يتقيد بترتيب معين، ولا يسقط بالكلام في الموضوع، ولا بالدفوع السابقة عليه، ولا أن تقدم الدفوع بعدم القبول معاً، بل يجوز تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، غير أنه لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام، كالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مشروعيتها، أو لسبق الفصل فيها^(١)، والدفع به يسقط الحق في الدفوع الشككية، وليس العكس، فيجوز إبدائه بعد أي دفع شكلي أو موضوعي^(٢).

القاعدة الثانية: تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها، ما لم يكن متعلقاً بمصلحة خاصة:

فإذا كان متعلقاً بالنظام العام، كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، أو لسبق الفصل فيها، فإن على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، دون حاجة لانتظار دفع به من الخصوم، أما إذا تعلق بمصلحة خاصة، كالدفع بعدم قبول دعوى الدائن على الكفيل العيني قبل رجوعه على المدين^(٣)، فلا تقضي به المحكمة إلا إذا تمسك به الخصم صاحب المصلحة في الدفع به^(٤).

القاعدة الثالثة: الحكم فيه لا يستنفذ ولاية المحكمة بنظر الموضوع:

على عكس ما ذهبت إليه محكمة النقض، بأن الفصل في الدفع بعدم القبول مما تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع أمام محكمة الاستئناف^(٥)، فإن جمهور الفقه القانوني^(٦) يذهب إلى أن الدفع بعدم القبول لا يعد قضاء في موضوعا الدعوى، وإنما يهدف إلى

(١) نقض: الطعن رقم ٢٠٨٢ لسنة ٥٣ قضائية - جلسة ٢٧ مارس ١٩٨٤.

(٢) د. محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٦٨٢.

(٣) مادة ٧٨٨ مدني.

(٤) د. عبدالتواب مبارك، مرجع سابق، ص ٤٣٢.

(٥) نقض: الطعن رقم ٧٥٨ لسنة ٤٨ قضائية - جلسة ١٨/٥/١٩٨٩.

(٦) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٣٥١ - فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٦٥ - د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٤٢٥.

الحصول على حكم بعدم قبول النظر في الطلب أو الطعن المقدم إلى المحكمة، فلا تستند به ولايتها، وعلى محكمة الاستئناف متى ألغته أن تعيد إليها الدعوى لتفصل في موضوعها.

القاعدة الرابعة: الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول لا يحوز حجية الأمر المقضي:

لأنه لا يعد حكماً في دفع موضوعي، ومن ثم فالحكم بقبوله لا يحوز حجية الأمر المقضي، ويجوز بعده تجديد النزاع مرة أخرى أمام المحكمة، فيكون للمدعي الحق في رفع الدعوى مرة ثانية أمام نفس المحكمة متى توافرت شروطها^(١). أما إذا كان قضاء المحكمة مبنياً على عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، أو عدم قبول الطعن لفوات ميعاده؛ فمثل هذا الحكم لا يجوز معه تجديد الدعوى أمام المحكمة^(٢).

القاعدة الخامسة: لا تلزم المحكمة بالفصل في الدفع بعدم القبول على استقلال:

فللمحكمة أن تقضي في الدفع على استقلال، ولها أن تأمر بضمه إلى الموضوع للفصل فيه مع الحكم المنهي للخصومة، بل إن للمحكمة إذا تبين أن الدفع على غير أساس أن تغضله متى كان لا يحوي ما يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى^(٣).

القاعدة السادسة: الدفع بعدم القبول لعيب في صفة المدعى عليه يقتضي التأجيل لإعلان ذي الصفة:

وذلك إعمالاً لما قضت به المادة (١١٥) مرافعات، ولها في هذه الحالة أن تحكم على المدعي بالغرامة المقررة في المادة ذاتها؛ يستوي في ذلك أن يكون الدفع بانعدام الصفة من تلقاء المحكمة أو بناء على دفع من الخصوم، وهذا بخلاف ما إذا كان انعدام الصفة راجع إلى المدعي، فإن على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

(١) د. محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٦٧٧.

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٣٥١.

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٦٢.

المطلب الرابع

التقييد بنطاق الدعوى

تحدثنا فيما سبق عن نطاق الخصومة أمام المحكمة، وقلنا إن هذا النطاق يتحدد بما يطلبه المدعي في صحيفة دعواه من طلبات، وبما يقدمه الخصوم بعد ذلك من طلبات عارضة ودفع أثناء نظر النزاع، وبهذا يتحدد النطاق الموضوعي للخصومة، كما يتحدد سببه بالسبب القانوني الذي يستند إليه الخصوم في المطالبة بالحقوق المتنازع عليها، ويتحدد أشخاصها بالخصوم في صحيفة الدعوى، وبما يحدث بعد ذلك من تدخل أو إدخال في الخصومة، فإذا ما تم ذلك؛ فإن الخصومة يكون قد تحدد نطاقها أمام المحكمة، أشخاصا، ومحلا، وسببا.

وحين يتحدد نطاق الخصومة على هذا النحو؛ فإنه يكون ملزما للمحكمة، وللخصوم، ويجب التقييد به، وعدم الخروج عليه، وذلك على النحو الآتي^(١):

أولا: التزام المحكمة بنطاق الدعوى:

يجب على القاضي في نظره للدعوى أن يتقيد بنطاقها أشخاصا، ومحلا، وسببا، ولا يجوز له الخروج على ذلك، وفي هذا الصدد:

- ١- لا يجوز للقاضي إغفال الفصل في طلب من الطلبات المعروضة عليه، وإذا ما عن له رفض طلب منها؛ فإن عليه أن يبين ذلك وسببه، ولا يكتفي بتجاهله، كما يجب عليه أن ينظر إلى كل ما يقدمه الخصم من طلبات في الخصومة ما لم يعدل عن طلب منها أو بعضها.
- ٢- لا يجوز للقاضي أن يتجاوز نطاق الخصومة المعروضة عليه، فليس له الفصل في غير ما قدم إليه من طلبات، وليس له استحداث طلبات جديدة لم يطلبها الخصوم، ولا أن يغير السبب القانوني الذي استندوا إليه، ولا أن يقضي في مواجهة من لم يختصم في الدعوى. وكل ما للمحكمة في هذا الصدد هو إعطاء الدعوى وصفها وتكييفها القانوني الصحيح.

ثانيا: التزام الخصوم بنطاق الدعوى:

لا يجوز لأي خصم أن يخرج عن نطاق الطلبات المطروحة على المحكمة في أي عنصر من عناصرها، ويمتد هذا المنع إلى كل ما يتعلق بأوجه الدفاع أو الدفع أو تقديم أدلة الإثبات؛ إذ يجب أن يكون كل ذلك متعلقا بما قدم من طلبات في الخصومة، سواء كانت طلبات أصلية أم عارضة.

(١) المستشار. سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص ٧٤٣ وما بعدها.

ثالثاً: سلطة المحكمة في تكييف الدعوى:

التكييف هو إعمال القاعدة القانونية وإرساؤها على ما ثبت من وقائع الدعوى، أو هو وصف هذه الوقائع وإبرازها كعناصر أو شروط أو قيود للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق عليها. وهناك مجموعة من القواعد التي يجب على القاضي أن يلتزم بها في تكييف الدعوى، أهمها^(١):

- ١- يجب تكييف الدعوى وفق الوصف المقرر لها في القانون، ولا يعتد بتكييف الخصوم لها إذا كان خاطئاً لا يتمشى مع القانون.
- ٢- يجب تكييف الدعوى في حدود طلبات الخصوم ودفعوهم، فلا تطبق إلا القاعدة القانونية اللازمة للحكم فيها، والعبرة بحقيقة المقصود من طلباتهم الجازمة، لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات.
- ٣- تعتبر القواعد القانونية الصرفة قائمة في الدعوى، ومن عناصرها، وعلى المحكمة أن تطبقها من تلقاء نفسها وبغير حاجة إلى التمسك بها من صاحب المصلحة. والتكييف مسألة قانونية يلتزم القاضي بها من تلقاء نفسه، غير متقيد في ذلك بتكييف الخصوم، فالمدعي الحق أن يكيف دعواه، من حيث الشكل أو الموضوع، بحسب ما يرى، وللمدعى عليه الحق في كشف خطأ هذا التكييف، والقاضي يهيمن على هذا وذاك من حيث انطباق هذا التكييف على الواقع أو عدم انطباقه، ثم يطبق القانون على ما يثبت لديه^(٢).

المطلب الرابع

تنظيم المرافعة

يقتضي الحديث عن تنظيم المرافعة، أن نتحدث أولاً عن حق الخصوم في إثبات الصلح، وفي تقديم المستندات، وفي المرافعات الشفوية والمكتوبة، ثم الحديث عن سلطة المحكمة في قفل وفتح باب المرافعة، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: إثبات الصلح:

وفقاً لما قرره المشرع في المادة (١٠٣) مرافعات، فإنه يجوز للخصوم:

- ١- أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع منهم أو من وكلائهم.

(١) د. أحمد أبو الوفا: نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، ٢٠٠٧، ص ٢٩٨.

(٢) نقض: الطعن رقم ٨٦ لسنة ٣ قضائية - جلسة ١٩٣٣/٥/٢.

- ٢- إذا كان الخصوم قد كتبوا ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة، وأثبت محتواه فيه.
- ٣- يكون لمحضر الجلسة في الحالتين السابقتين قوة السند التنفيذي.
- ٤- تعطى للخصوم صورة من محضر الجلسة المشار إليه باعتباره سندا تنفيذيا، وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام.
- ٥- فإذا كان طلب الخصوم متعلق بإثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه -كتابة أو شفاهة- بمحضر الجلسة؛ إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق.

ثانيا: الحق في تقديم المستندات:

نظم المشرع حق الخصوم في تقديم المستندات إلى المحكمة في المواد (٦٥ و٩٥ و٩٧ و١٦٨) مرافعات، وقد سبق أن تناولنا واجبات المدعي في تقديم المستندات رفق صحيفة دعواه عند قيدها في قلم الكتاب، وواجب المدعى عليه في تقديم مستنداته قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام، كما تناولنا بيان سلطة المحكمة في قبول مستندات الخصوم في الجلسة الأولى، وما يترتب على تقديم الخصم في هذه الجلسة لمستند كان يجب عليه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (٦٥)، فضلا عن ذلك

فإن المشرع بعد أن نص في المادة (٩٥) على أنه لا يجوز للخصوم في الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفاً منضمماً، أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة، بعد تقديم النيابة أقوالها وطلباتها، سمح لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة، وأجاز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية بعد تقديم النيابة لأقوالها، أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة، على أن تكون النيابة آخر من يتكلم.

كما حظر المشرع على المحكمة أثناء المداولة، أن تسمع أحد الخصوم، أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلا (مادة ١٦٨ مرافعات).

وفي كل ذلك أوجب على المحكمة أن تطلع على المستندات التي قدمها الخصوم في الدعوى والتي اعتمدت عليها في حكمها؛ إذ يجب عليها أن تمحص هذه المستندات وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى المطروحة عليها، وهي في ذلك ملزمة بالاطلاع على كافة المستندات التي يقدمها

الخصوم إليها حتى ولو كانت هذه المستندات لن يكون لها أثر في تكوين عقيدتها، ذلك أن هذا الاطلاع هو الذي سيمكنها من القول بما لهذه الأوراق من أثر في الحكم من عدمه.

وإذا كانت للمحكمة سلطتها التقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة وطرح ما عداها، إلا أن هذه السلطة لا تعفى المحكمة من واجب الاطلاع على كافة المستندات التي تقدم إليها، إذ أنها ملزمة بالاطلاع على هذه المستندات، ثم يكون لها بعد ذلك أعمال سلطتها التقديرية والأخذ بها أو عدم الأخذ بها.

وجوب الاطلاع على المستندات المقدمة في كافة مراحل الدعوى :

واطلاع المحكمة على مستندات الدعوى لا يعنى به هنا تلك التي يقدمها المدعي وفق صحيفة دعواه وفقا للمادة (٦٥) مرافعات، وتلك التي يقدمها المدعى عليه ردا على هذه المستندات، أو تلك التي يتبادلها الخصوم خلال جلسات المرافعة وفقط، وإنما يجب على المحكمة أن تطلع على كافة المستندات التي يتقدم بها الخصوم حتى في فترة حجز الدعوى للحكم مادامت المحكمة قد صرحت للخصوم بتقديم هذه المستندات، وتقدم الخصوم بها في الميعاد الذي حددته المحكمة، وتم إعلان الخصم الآخر بها (مادة ١/١٧١ مرافعات).

أما إذا قدمت مذكرة من أحد الخصوم لا تحمل أي بيان يفيد سبق إعلانها للخصم أو اطلاعه عليها، فإن هذه المذكرة تعتبر غير قائمة قانونا أمام المحكمة، ومن ثم فلا ينال من الحكم التفاته عن الرد عليها.

ولم يوجب المشرع على المحكمة أن تطلع على المستندات المقدمة إليها في مواجهة الخصوم، وإنما يجوز للمحكمة أن تطلع على هذه المستندات سواء في حضور الخصوم أو في غيبتهم؛ ذلك أن اطلاع المحكمة على المستندات لا يعد إجراء من إجراءات التحقيق بحيث يتحتم حصوله في حضورهم، ومن ثم فليس للخصم أن ينعى على الحكم بالبطلان لأن المحكمة اطلعت على المستندات في غيبته^(١).

ثالثا: الحق في المرافعات الشفوية والمكتوبة:

من المبادئ الأصلية في النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية، أو بمذكرات مكتوبة، وأن الخصوم إذا طلبوا من المحكمة الاستماع إلى مرافعتهم، فلم تمكنهم من ذلك؛ فإنها تكون قد أخلت بحقهم في الدفاع^(٢)، وإعمال حق الدفاع يقتضي أن يكون للخصوم ومحاميهم الحق

(١) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني، العيوب المبطللة للحكم، مرجع سابق، ص ٢١٦.

(٢) نقض: الطعن رقم ١٩٢٥ لسنة ٤٩ قضائية - جلسة ١٩٨٤/٥/٩.

في إبداء أقوالهم بالجلسة، وألا تقاطعهم المحكمة، إلا لضرورة يقتضيها تنظيم حق الدفاع، أو لاستيضاح أمر تحتاجه المحكمة.

ويعد حق الدفاع من أهم حقوق المتقاضين، وسمة أساسية ومهمة من سمات قانون المرافعات، إذ يمكن الخصم من أن يبدي دفاعه على الوجه الذي يريده، ويكفي لضمان حقه أن يمكن من إبداءه^(١).

ويقصد به حق الخصم في أن يبدي للمحكمة أوجه الدفاع والدفع التي يستند إليها وأن تستمع المحكمة إلى وجهة نظره وتمكنه من الرد على ما يقدمه خصمه من دفاع في القضية حتى يتمكن من تنفيذ حجج خصمه وإقناع القاضي بالحكم لصالحه.

ويجب على المحكمة أن تحترم هذا الحق في أية حالة تكون عليها الإجراءات، فعليها أن تستمع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تقاطعهم إلا في حالة خروجهم عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها، كما أن عليها أن تفسح لهم المجال لاستعمال حقهم في الدفاع، ولا تأتي بأي إجراء من شأنه انتهاك هذا الحق (م ١٠٢).

تنظيم المشرع لحق الدفاع :

وضع المشرع فيما يتعلق بحق الدفاع قواعد تحقق صيانة هذا الحق، وتمكن الخصوم من إبداء دفاعهم، وفي الوقت ذاته تحول دون إضاعة وقت المحاكم وإضافة أعباء إضافية إليها، وتحول أيضا دون مباغته الخصم الآخر الذي قد يطلب التأجيل مما يعطل الفصل في الدعوى^(٢)، وهذه القواعد ورد النص عليها في المواد (٦٥) و (٩٧) و (١٧١) من قانون المرافعات. ولا يحول حق الدفاع دون تنظيم المحكمة لممارسته، إذ أن للمحكمة أن تنظم مباشرة حق الدفاع أمامها بما يحول دون إطالة أمد النزاع وتأخير الفصل في الدعوى، وفي الوقت ذاته بما يحمي حق الخصوم في إبداء دفاعهم.

رابعا: قفل باب المرافعة وفتحه:

بعد انتهاء المرافعات، واتضح الحقيقة للمحكمة، يأمر رئيس الهيئة بقفل باب المرافعة، أي بانتهاء مرحلة الدفاع في القضية، تمهيدا لإصدار الحكم، وبالعبرة الشائعة، يأمر بحجز القضية للحكم^(٣). فتنتقطع صلة الخصوم بالقضية ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٢ / ٨١٥ - أستاذي د. حامد أبوطالب، مرجع سابق، ص ٤٦ .

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق ج ٢ / ٨١٦.

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق ص ٥٤١.

المحكمة، بما يترتب على ذلك من آثار، وسيأتي بيان ذلك تفصيلاً عن حديثنا عن قواعد إصدار الحكم القضائي.

ويقصد بفتح باب المرافعة أن الدعوى لم تعد صالحة للفصل فيها بعد حجزها للحكم لظهور وقائع معينة من شأنها التأثير على الفصل فيها، فتقرر المحكمة طرح الموضوع من جديد على الخصوم للمناقشة وإبداء دفاعهم ودفعهم وتقديم ما يعن لهم من مستندات ومذكرات^(١).

باعتبار أن قرار قفل باب المرافعة سواء كان صريحاً أو ضمناً لا يعد حكماً ولا يحوز الحجية، ومن ثم فلا تنقيد به المحكمة، بل لها أن تعيد الدعوى للمرافعة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. ومتى أعيدت الدعوى للمرافعة، فإنه يترتب على ذلك أن تعاد الدعوى للمناقشة فيها من جديد وتصبح بين يدي الخصوم بعد أن انقطعت صلتهم بها بإقفال باب المرافعة فيها، فيحق لهم تقديم ما يشاؤون من دفع ودفاع ومستندات ومذكرات وطلبات عارضة، كما كان الشأن قبل قفل باب المرافعة^(٢).

وإذا أمرت المحكمة بفتح باب المرافعة فيجب أن يكون ذلك في حضور أطراف الخصومة، فإذا كان بعضهم غائباً، فإنها تأمر الحاضر من الخصوم بإعلان الغائبين، فإذا صدر القرار في غيبة جميع الخصوم، كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلانهم^(٣).

(١) د. محمد سعيد عبد الرحمن: الحكم القضائي، دار النهضة العربية، ٢٠٠٢م، ص ١٩٦.

(٢) وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه "... يترتب على فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم والذي أشارت إليه المادة ١٧٣ مرافعات، أن يعود للخصوم حقهم في إبداء ما يعن لهم من دفاع أو دفع موضوعية لم يسبق لهم إبدائها أمام المحكمة، أو دفع شكلي لم يسقط حقهم في التمسك بما فاتهم عرضها عليها". (الطعن رقم ٧٦٦ لسنة ٦٢ قضائية - جلسة ١٩٨٨/٦/٤).

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥٤٢.

الفصل الثالث

عوارض الخصومة

الخصومة المدنية مجموعة من الأعمال الإجرائية التي تسير نحو تحقيق غاية الدعوى، بالفصل فيها بحكم قضائي، يحسم النزاع حول المراكز القانونية المتنازع عليها، والأصل في الخصومة متى بدأت، أن تسير سير طبيعياً حتى تصل إلى غايتها، وهي حسم النزاع على الحق.

وإذا كان هذا هو الأصل، فإن الواقع قد يكون غير ذلك، فالخصومة لا تنتهي دائماً نهاية طبيعية بحكم في موضوعها؛ وإنما قد تنتهي نهاية غير طبيعية قبل صدور هذا الحكم؛ فمن الوارد أن تعترضها عوارض تمنع السير فيها، وهذه العوارض منها ما يمنع السير في الخصومة بشكل مؤقت، ومنها ما يمنع السير فيها بشكل نهائي.

فالأولى: عوارض تؤدي إلى ركود الخصومة ركوداً مؤقتاً، قد يزول بزوال العارض، وتستأنف الخصومة سيرها بعد ذلك، وقد يؤدي إلى انتهاء الخصومة، إذا لم يزول العارض أو لم يتحقق ما أوجبه المشرع للسير في الخصومة بعد زوال العارض. والثانية: عكس ذلك، فهي عوارض لا تؤدي إلى ركود الخصومة ركوداً مؤقتاً؛ وإنما تؤدي إلى زوالها زوالاً نهائياً، دون حكم في موضوعها.

فعوارض الخصومة إذا نوعان، الأول: عوارض تؤدي إلى ركودها، وهي: الوقف، والانقطاع، والثاني عوارض تؤدي إلى انتهائها دون حكم في موضوعها، وهي: السقوط، والتقادم، واعتبار الخصومة كأن لم تكن، وترك الخصومة. ولكل نوع من هذين النوعين شروط وإجراءات وآثار تترتب عليه، وهذه الآثار قد تختلف من عارض إلى آخر، وقد تتشابه في أكثر من عارض.

ونتناول هذه العوارض في مطلبين، نتحدث في الأول منهما عن العوارض التي تؤدي إلى ركود الخصومة، وفي الثاني، العوارض التي تؤدي إلى انقضاء الخصومة بغير حكم في موضوعها.

المبحث الأول

العوارض المؤدية إلى ركود الخصومة

المطلب الأول

وقف الخصومة

وقف الخصومة معناه عدم السير فيها -لأجل معين- بناء على اتفاق الأطراف، أو حكم المحكمة، أو حكم القانون^(١). بحيث تقف فترة من الزمن إذا اعتراها سبب من أسباب الوقف، مع بقاءها قائمة منتجة لآثارها^(٢).

والوقف يكون لأحد أسباب خمسة، أولها يرجع إلى إرادة الخصمين، وذلك حين يتفقان على وقف الدعوى مدة محددة، والثاني يرجع إلى إرادة المشرع، وذلك حين يوجب القانون وقف سير الدعوى لأسباب خاصة؛ كرد القاضي، والثالث: يرجع إلى إهمال المدعي حين يتخلف عن إيداع مستنداته، ويرجع الرابع والخامس، إلى سلطة القاضي التقديرية. وذلك حين يرى تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وحين يرى أن وقف سير الخصومة يحقق حسن سير العدالة وتفاديا لصدور أحكام لا تتوافق فيما بينها^(٣).

أنواع الوقف:

الوقف ثلاثة أنواع، الأول: وقف اتفاقي (يرجع إلى اتفاق الخصوم، وتحكم به المحكمة)، والثاني: وقف قضائي (يتم بحكم المحكمة)، والثالث: وقف قانوني (يتم بقوة القانون).

الفرع الأول: الوقف الاتفاقي

يقصد بالوقف الاتفاقي للخصومة، اتفاق المدعي مع المدعى عليه - إنفراداً، أو تعدد أحدهما أو كلاهما- على وقف الإجراءات القضائية أمام المحكمة المرفوع إليها الدعوى خلال مدة معينة^(٤). فالخصوم قد تعرض لهم أسباب تدعو إلى إرجاء النظر في الدعوى مدة كافية تبيح لهم تحقيق مشروع صلح لإنهاء نزاعهم ودياً أو أي غرض آخر مشترك، فبدلاً من تكرار التأجيل الذي

(١) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٥٤٤. ويلاحظ أن حالة الوقف إنما ترد على خصومة الدعوى الموضوعية دون الدعوى المستعجلة، التي تتناقى بطبيعتها مع التأخير الذي تستلزمه، وذلك فيما عدا حالات الوقف بقوة القانون، والتي ترد على كافة الدعاوى. (المرجع السابق، ص ٥٤٥).

(٢) د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٣٧٢.

(٣) قريب من هذا المعنى: د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، مرجع سابق، ص ٧٥٢.

(٤) د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٦٣٧.

قد لا يوافقهم القاضي على منحه، أباح لهم القانون الاتفاق على وقف الدعوى مدة معينة، وأجاز للمحكمة أن تقر اتفاقهم متى توافرت الشروط التي نص عليها القانون^(١).

فنص في المادة (١/١٢٨) مرافعات، على أنه "يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما". والوقف الاتفاقي يعد تصرفاً قانونياً إجرائياً ملزماً لأطرافه، ولكنه غير ملزم للمحكمة، والتي يكون لها رغم وجود هذا الاتفاق أن تلتفت عنه وتستمر في نظر الدعوى، إذا رأت ما يبرر ذلك^(٢).

مدة الوقف الاتفاقي وسلطة المحكمة بشأنه:

وفقاً لنص المادة (١/١٢٨) مرافعات، فإنه يشترط ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي على ثلاثة أشهر، وهذه المدة هي الحد الأقصى للوقف الاتفاقي، وليس له حد أدنى، فيجوز للخصوم الاتفاق على مدة أقل - أياً كانت- إذ شرط هذا النوع من أنواع الوقف، ألا تزيد مدته على ثلاثة أشهر.

وهذا الوقف كما ذكرنا يتم بإرادة الخصوم واتفاقهم، بشرط إقرار المحكمة لهذا الاتفاق، ومن تاريخ حكم المحكمة به، تبدأ مدة الوقف، إذ المدة لا تبدأ من تاريخ اتفاق الخصوم، وإنما من تاريخ حكم المحكمة بالوقف.

والمحكمة ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الوقف متى اتفقوا عليه، وإنما لها رغم وجود هذا الاتفاق أن تستمر في نظر الدعوى، أو أن تجيبهم إلى اتفاقهم، فإذا أقرت اتفاقهم؛ فإن قرارها بإقرار اتفاق الخصوم على الوقف يعد عملاً من أعمال الإدارة القضائية وليس حكماً قضائياً؛ فلا يقبل الطعن فيه بأي طريق؛ إلا إذا أخطأت المحكمة وقررت الوقف

(١) د. ماهر إبراهيم السداوي، مرجع سابق، ص ١٢٢.

ويشبه وقف الخصومة تأجيلها، إذ كلاهما مبناه قيام أسباب موجبة لعدم الفصل فيها، ولكن يختلفان من عدة نواح، أولها: أنه يتعين أن يتحدد في القرار الصادر بالتأجيل تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية، أما بالنسبة للوقف فلا تتحدد غالباً مدته، وبالتالي لا يعرف تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية. وثانيها: أن لا يتصور أن يتم التأجيل إلا بقرار من المحكمة، في حين قد تقف فيه الخصومة بغير حكم. وثالثها: أنه يجوز تأجيل الخصومة كلما اقتضت الظروف ذلك وفقاً لتقدير المحكمة، في حين أن الوقف غير جائز إلا لأسباب على سبيل الحصر (د. أحمد أبو الوفا: نظرية الدفع، مرجع سابق، ص ٧٤٧-٧٤٨). ورابعها: أن التأجيل لا يؤدي إلى ركود الخصومة، في حين يؤدي الوقف إلى ركودها، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء خلال مدة الوقف (د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٢٠٦/٣).

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص ٦٣٧.

استجابة لطلب أحد الخصوم فقط؛ فحكمها في هذه الحالة يعد حكماً قطعياً صادراً قبل الفصل في الموضوع، ويقبل الطعن المباشر إعمالاً لنص المادة (٢١٢) مرافعات^(١).

شروط الوقف الاتفاقي:

يشترط لوقف الخصومة وقفاً اتفاقياً، توافر ثلاثة شروط، هي:

١- اتفاق جميع الخصوم: فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالوقف ما لم يتفق عليه جميع الخصوم، لأن المشرع أجاز له ليحقق غرضاً مشتركاً بينهم، فلا يجوز لأحدهم الانفراد بطلبه دون موافقة باقي الخصوم، بل يجب اتفاقهم جميعاً عليه، يستوي في ذلك أن يتم الاتفاق بين الخصوم أنفسهم، أو بين وكلائهم من المحامين، دون حاجة في ذلك إلى توكيل خاص^(٢). وإذا تعدد الخصوم وجب اتفاقهم جميعاً على الوقف، إلا إذا كانت الخصومة قابلةاً للتجزئة؛ فيجوز الوقف الاتفاقي بين بعض الخصوم دون البعض الآخر، فإن لم يكن الموضوع قابلاً للتجزئة؛ فلا وقف إلا باتفاق الخصوم جميعاً^(٣).

٢- ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر: تبدأ كما قلنا من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاق الخصوم، فإن اتفق الخصوم على ما يزيد على ذلك؛ وجب على المحكمة إنقاص المدة إلى ثلاثة أشهر. هذا وتجب الإشارة إلى أنه وإن كان يشترط ألا تزيد المدة على ثلاثة أشهر؛ إلا أن المشرع لم يمنع الخصوم من الاتفاق مجدداً على وقف الدعوى مرة أخرى بعد تعجيلها؛ بشرط ألا تزيد المدة الجديدة على ثلاثة أشهر^(٤).

٣- أن تقر المحكمة الاتفاق على الوقف: فلا تقف الخصومة بمجرد اتفاق الخصوم على ذلك، وإنما لابد أن تقر المحكمة هذا الاتفاق وتحكم به، ومن تاريخ حكمها يسري الوقف ويرتب آثاره. ونرى مع جانب من الفقه^(٥) أن للمحكمة سلطة تقديرية في إقرار هذا الاتفاق، فليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم، بل لها أن ترفض هذا الاتفاق لأسباب هامة، كما لو تبينت أن المقصود منه إطالة أمد الخصومة.

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٦٣٨.

(٢) د. إبراهيم السداوي، مرجع سابق، ص ١٢٢ - د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٣/ ٢٠٧.

(٣) د. أحمد أبو الوفا: التعليق على قانون المرافعات، ص ٦٣٩، د. إبراهيم نجيب سعد، ص ١٠٧.

(٤) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ١٠٨.

(٥) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٥٩ - د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ١٠٨. وعكس هذا الرأي يذهب د. عبدالباسط جيمي إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب الوقف متى اتفق عليه الخصوم، وعليها أن تجيبهم إليه (انظر لسيادته، مبادئ المرافعات، ص ٣٠٨-٣٠٩).

كيفية تقديم طلب الوقف الاتفاقي:

لم يحدد المشرع وسيلة معينة لتقديم طلب الوقف؛ ومن ثم يمكن تقديمه كتابة أو شفاهة، ولا يشترط أن يتضمن الطلب سببا معيناً للوقف، وإنما للخصوم أن يتفقوا عليه دون تحديد سببه^(١). وهذا الوقف جائز أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، ولكن لا يجوز أمام محكمة النقض، لاختلاف الإجراءات أمامها^(٢).

الآثار المترتبة على الوقف الاتفاقي:

يترتب على الوقف الاتفاقي ثلاثة آثار، هي^(٣):

الأول: اعتبار الخصومة قائمة رغم وقفها: فتظل منتجة لكافة الآثار القانونية المترتبة على إيداع صحيفتها، سواء كانت هذه الآثار إجرائية أو موضوعية. كما تبقى جميع الأعمال الإجرائية اللاحقة على إيداع الصحيفة قائمة منتجة لآثارها، فإذا انتهت حالة الوقف بسير الخصومة، فإنها تعود للسير من النقطة التي وقفت عندها، مع الاعتداد بكافة الإجراءات السابقة.

الثاني: ركود الخصومة رغم قيامها: فتكون الخصومة طوال مدة الوقف في حالة ركود وسكون، وتقف جميع الإجراءات السارية، ويمتنع على القاضي والخصوم اتخاذ أي إجراء يقصد به موالاة سير الخصومة، وكل إجراء يتخذ فيها خلال مدة الوقف يكون باطلا، إلا إذا كان الإجراء المتخذ إجراء وقتيا أو مستعجلا في الخصومة^(٤).

الثالث: وقف المواعيد الإجرائية: والمقصود بها المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها أي جزاء، أما المواعيد الحتمية، فتظل سارية رغم الوقف الاتفاقي، فلا يؤثر هذا الوقف في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما (مادة ١/١٢٨).

مصير الخصومة الموقوفة:

لا تظل الخصومة موقوفة أبدا؛ وإنما يكون مصيرها أحد أمرين: إما أن تعجل وتستأنف سيرها، وإما أن تنتهي المدة المقررة لتعجيلها، دون أن يقوم الخصم بتعجيلها، فتنتضي دون حكم في موضوعها، وذلك على النحو الآتي:

(١) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ١٠٨.

(٢) د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، ص ٣٧٥ - د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط، ص ٦٣٧.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٢١١/٣ - د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط، ص ٦٣٩ - د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٥٤٩.

(٤) د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٥٥٠.

١- تعجيل الخصومة من الوقف الاتفاقي:

أوجب القانون على الخصوم تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل المتفق عليه للوقف، وهذا الميعاد حتمي يتعين اتخاذ إجراء التعجيل خلاله، فإن لم يتم مراعاته، اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه (مادة ٢/١٢٨ مرافعات). ويتم تعجيل الخصومة بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصم بها، خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف، ويشترط لصحة التعجيل أن يتم الإجراءان - تحديد الجلسة، وإعلان الخصم بها- في الميعاد المقرر، يستوي في ذلك أن يكون تاريخ الجلسة في خلال الأيام الثمانية أو بعد ذلك، فكل ما يشترط هو تحديد الجلسة وإعلان الخصم بها في هذا الميعاد، حتى وإن وقعت بعد ذلك.

وتعجيل الخصومة قد يكون من المدعي وقد يكون من المدعى عليه، وإن كان الغالب أن يقوم به المدعي لأنه المكلف بعبء تسيير الخصومة، ولا يشترط أن يتم التعجيل بعد انتهاء مدة الوقف، وإنما يجوز للخصوم الاتفاق على التعجيل قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة. إلا أن الرأي الغالب في الفقه -والذي نرجحه- أنه ليس للمدعي وحده تعجيل الدعوى قبل انتهاء مدة الوقف، وإنما لابد من موافقة المدعى عليه على ذلك.

٢- انقضاء الخصومة الموقوفة دون حكم في موضوعها:

إذا لم يتم تعجيل الخصومة في الميعاد المحدد في المادة (٢/١٢٨)، فإن المشرع رتب على ذلك جزاء صارما، وهو اعتبار المدعي تاركا دعواه، والمستأنف تاركا استئنافه، فتنتضي الخصومة دون حكم في موضوعها^(١).

الفرع الثاني: الوقف القضائي

الأصل أن دور المحكمة، سرعة الفصل في الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون، ليتحقق بذلك ثبات المراكز القانونية وتستقر الحقوق لأصحابها، ومن ثم فعلى المحكمة أن تبذل الجهد نحو تحقيق هذه الغاية، فلا توقف الخصومة وقفا يؤدي إلى تأخير الفصل فيها، ومع ذلك أجاز المشرع للمحكمة أن تقرر وقف الخصومة في بعض الحالات كلما قدرت ذلك، وهي حالات نص عليها المشرع في نصوص محدودة، بمقتضاها أعطى للمحكمة سلطة وقف الخصومة، فلا يجوز لها وقفها في غيرها.

(١) وللفقه في هذه المسألة رأيان، أحدهما: أن انقضاء الخصومة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه، والثاني: أن عدم التعجيل قرينة بسيطة على نزول المدعي عن الدعوى (مؤلفنا: نظرية القرائن ج١/٤٩٨).

وسلطة المحكمة في وقف الخصومة، تتنوع إلى نوعين من الوقف، أولهما: وقف جزائي، مقرر كجزاء على واقعة معينة حددها المشرع، وثانيهما: وقف تعليلي، بمقتضاه تعلق المحكمة الفصل في الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى.

أولاً: الوقف الجزائي:

وهو الوقف الذي تحكم به المحكمة على المدعي إذا تراخى في إيداع مستند أو القيام بإجراء كلفته به، وهو جزاء يوقع عليه بعد سماع أقوال المدعي عليه^(١).

ذلك أن القانون يوجب على الخصوم إيداع مستنداتهم في الدعوى في أقرب فرصة ممكنة، ويوجب عليهم الامتثال لأمر المحكمة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات معينة، ولا بد لهذا الوجوب من جزاء يحميه من المخالفة، ومن ثم رتب المشرع نوعين من الجزاءات توقع المحكمة الأنسب أو الأجدي منهما، هما: الغرامة، ووقف الخصومة^(٢).

فنص في المادة (٩٩) مرافعات، على سلطة المحكمة في الحكم بغرامة^(٣) على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع مستند أو عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات. وإذا كان من تخلف عن إيداع المستند أو عن القيام بالإجراء هو المدعي، فلها أن تحكم -بدلاً من الغرامة- بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي.

فالوقف في هذه الحالة، جزاء يوقع على المدعي فقط^(٤)، فلا يجوز توقيعه على المدعي عليه، بل إنه خشية أن يتضرر المدعي عليه من الوقف، أوجب القانون أن تسمع المحكمة أقواله قبل الحكم بالوقف، يستوي في ذلك أن يوافق عليه أم لا؛ لأن المشرع لم يتطلب موافقته، وإنما أوجب فقط سماع أقواله، تاركاً للمحكمة السلطة التقديرية الكاملة في الحكم بالوقف كجزاء أو عدم الحكم به.

(١) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ١١٣.

(٢) المستشار. سيد حسن البغال، مرجع سابق، ص ٥٤١.

(٣) لا تقل عن عشرين جنهما، ولا تزيد عن مائتي جنيه.

(٤) ونقصد بالمدعي هنا: كل من يشغل مركز المدعي، سواء أكان هو المدعي الأصلي أو المتدخل إلى جانبه، أو المتدخل اختصاصاً، أو المختصم إلى جانب المدعي. غير أنه مما تجب ملاحظته في هذا الصدد أنه إذا تعدد المدعين، وأهمل أحدهم إهمالاً يستوجب الجزاء المقرر، فإنه يصعب هنا وقف الدعوى، لأن توقيع هذا الجزاء على المهمل، قد يؤدي إلى الإضرار بغير المهمل، إلا إذا كانت طلبات كل مستقلة عن طلبات الآخر. (د. أحمد أبو الوفا، التعليق، ص ٤٨٥).

شروط الوقف الجزائي:

يشترط للوقف الجزائي توافر أربعة شروط، هي^(١):

- ١- إهمال المدعي: فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى وقفا جزائيا إلا إذا وقع إهمال من المدعي، وصورته: أن يتخلف عن إيداع المستندات، أو عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة في الميعاد الذي حددته^(٢).
- ٢- أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه: إذ يوجب القانون على المحكمة ألا تحكم بالجزاء إلا بعد سماع أقواله، دون نظر إلى موافقته من عدمها^(٣).
- ٣- ألا تزيد مدة الوقف عن شهر: وهو الحد الأقصى للوقف الجزائي، فلا يجوز للمحكمة تجاوزه، وإنما لها أن تحكم بمدة أقل^(٤).
- ٤- أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى: إذ لا يترتب الوقف الجزائي بقوة القانون، بمجرد حدوث الواقعة الموجبة له، وإنما لا بد له أن تحكم المحكمة به، ولها في ذلك مطلق السلطة في الحكم به أو الحكم بالغرامة المقررة في المادة (٩٩).

مصير الخصومة بعد الوقف الجزائي:

- ١- لا يجوز تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي قبل انتهاء مدته ولو استكمل المدعي مستنداته أو قام بالإجراء الذي وقع الوقف بسببه، وإنما يشترط أن يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائي (مادة ٣/٩٩)، وذلك بإيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة وإعلانها للخصوم، شريطة أن يتم الإعلان خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف.
- ٢- إذا انتهت مدة الوقف ولم يعجل المدعي الخصومة في الخمسة عشر يوما التالية، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، فإنه يترتب على ذلك جزاء آخر، وهو اعتبار الخصومة كأن لم تكن، وتحكم المحكمة بهذا الجزاء، وهو مقرر لمصلحة المدعى عليه، كما أنه جوازي

(١) د. وجدي راغب فهبي، مرجع سابق، ص ٥٤٦.

(٢) كما لو كلفته بإعلان خصمه بالحضور، أو بإدخال خصم في الدعوى، فلم يفعل.

(٣) ونرى مع جانب من الفقه (د. أحمد أبو الوفا، التعليق، ص ٤٨٥) أن القاضي لا يجوز له الحكم بالوقف إذا عارض فيه المدعى عليه، وإلا أصبح الحكم به عقوبة على المدعى عليه أيضا.

(٤) ويجوز للمحكمة أن توقف الدعوى مرة أخرى، لمدة شهر آخر، إذا تخلف المدعي عن إيداع مستند أو القيام بإجراء آخر كلفته به، فليس ثمة مانع يمنعها أن تفرض هذا الجزاء من جديد إذا ما وقع من المدعي ما يستدعي إيقاعه بعد استئناف الدعوى سيرها.

للمحكمة، فليس للمدعى عليه أن يعارض في نظر المحكمة للدعوى بالرغم من إهمال المدعي، وإنما يكون لمحكمة الدرجة الثانية أن تعمل سلطتها بمراقبة حكم الدرجة الأولى^(١). ويترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، زوال الخصومة وسائر إجراءاتها والآثار المترتبة عليها، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، بغير مساس بأصل الحق، فيجوز تجديد طلبه بدعوى جديدة، ما لم يسقط بالتقادم، ولا ولا يؤثر هذا الحكم على ما يكون قد صدر في الدعوى من أحكام قطعية^(٢).

ثانيا: الوقف التعليقي:

وهو النوع الثاني من نوعي الوقف القضائي، ومناطه، أن ترى المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم، بشرط أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة وظيفيا أو نوعيا^(٣).

فقد يحدث أثناء نظر الدعوى أن يبدي أحد الخصوم دفعا يثير موضوعا لا تختص المحكمة بالفصل فيه، ويكون الفصل فيه لازما للفصل في المسألة المعروضة على المحكمة، كما لو أثير أمام المحكمة الجزئية، في دعوى قسمة عقار تنظرها، نزاع على الملكية، وكانت قيمة العقار تزيد عن نصابها، أو أثير نزاع حول إثبات النسب في دعوى ميراث، وكانت المحكمة لا تختص بالفصل في مسألة إثبات النسب، أو نزاع حول عدم دستورية نص أو قانون.

فمثل هذه الدفوع لا تدخل في اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع الأصلي، وظيفيا أو نوعيا، فإذا رأت في مثل هذه الدفوع وغيرها، مما يثير مسألة أولية لا تدخل في اختصاص المحكمة، أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها، يحتاج أولا إلى الفصل في المسألة الأولية من الجهة أو المحكمة المختصة، فإن لها أن تأمر بوقف الدعوى الأصلية وقفا تعليقيا لحين الفصل في المسألة الأولية.

والوقف هنا جوازي للمحكمة، فقد نص المشرع في المادة (١٢٩) مرافعات، على أن للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

شروط الوقف التعليقي:

يشترط للوقف التعليقي، توافر الشروط الآتية:

(١) نقض: الطعن رقم ٥٠٨ لسنة ٤٣ قضائية - جلسة ١٩٧٧/٤/٢٦.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، ص ٤٨٦.

(٣) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٦٥٩.

١- أن تثار مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة: فلا يكفي للحكم بوقف الدعوى مجرد قيام ارتباط بين موضوعها، والفصل في دعوى أخرى، طالما كان هذا الارتباط ليس من شأنه عدم إمكانية الفصل في الدعوى التي تنظرها المحكمة^(١).

ولا يكفي مجرد الارتباط بين موضوع الدعوى والمسألة الأولية اللازم الفصل فيها للفصل في الدعوى؛ وإنما يشترط فضلا عن ذلك، أن يكون الفصل في موضوع الدفع مما يخرج عن اختصاص محكمة الدعوى، سواء أكان هذا الاختصاص وظيفيا أو نوعيا، لتعلقهما بالنظام العام^(٢). ويستوي أن تكون الدعوى بالمسألة الأولية مرفوعة فعلا أمام هذه المحكمة أم لم ترفع بعد^(٣). أما إذا كانت المسألة الأولية مما يدخل في اختصاص المحكمة فيجب عليها الفصل فيها دون أن تحكم بوقف الدعوى.

٢- أن تكون المسألة الأولية مسألة جدية ولازمة للفصل في الدعوى الأصلية: فإذا لم تكن كذلك وتبينت المحكمة عدم جديتها، أو تبين أنها مجرد ادعاء قصد به تعطيل الفصل في الدعوى وإطالة أمدها، فإن عليها أن تستمر في نظر الدعوى^(٤).

وللمحكمة سلطة تقدير جدية المنازعة في المسألة الأولية التي تثار أمامها حتى لا يصبدها ذلك عن ممارسة اختصاصها، وهذا التقدير يقتضي حتما بحث أوجه المنازعة ووزن أسانيدها لا للفصل في موضوعها وإنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل في الدعوى الأصلية أو الاستمرار في نظرها، ولها في ذلك أن تستنبط من القرائن القضائية ما يعينها على تقدير جدية المنازعة في المسألة الأولية، فلها أن تأخذ من سلوك الخصم أثناء نظر الدعوى وما يقدمه من طلبات قرينة على جدية المسألة الأولية التي يدفع بها، أم أنه يتخذ من ذلك زريعة للحيلولة دون سرعة الفصل في الدعوى، فإذا ما دفع أحد الخصوم بعدم دستورية القانون الذي يحكم النزاع طالبا وقف الدعوى حتى يرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، المختصة وحدها بذلك^(٥)، فإنه يجوز للمحكمة أن تستنبط من القرائن ما يعينها على جدية طلب الوقف من عدمه، فإذا تبين لها أن هذا الدفع لا يقوم على سند من الجد وأنه ظاهر الفساد فإن عليها أن تلتفت عنه وتستمر في نظر الدعوى، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تشير في حكمها إلى هذا الطلب وسبب عدم إجابته.

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٢٢٩/٣.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، مرجع سابق، ص ٧٥٤.

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٥٥-٦٥٦.

(٤) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٦٥٩.

(٥) د. أحمد السيد صاوي، ص ٦٦١- د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٢٣٩/٣.

٣- أن تأمر المحكمة بوقف الخصومة الأصلية: فالوقف لا يتم بقوة القانون بمجرد الدفع بالمسألة الأولية أو إثارتها أمام المحكمة، بل يجب لكي يتحقق أن تحكم به المحكمة، وهو أمر يخضع لتقديرها.

فوقف الدعوى وفقا للمادة (١٢٩) مرافعات أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبين من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها، فللمحكمة التي تأمر بالوقف السلطة الكاملة في تقدير جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها، ومن ناحية أخرى فإن تقدير لزوم الفصل في المسألة الأولية قبل الفصل في الدعوى يرجع لتقدير المحكمة الذي لا يخضع لرقابة محكمة النقض مادام قد بني على أسباب سائغة، على أن سلطتها التقديرية تقف عند هذا الحد، فليس للمحكمة أن تأمر بالوقف إلا إذا قدرت وجود ارتباط بين الدعوى الأخرى والدعوى التي تنظرها على نحو يجعل الفصل في الأولى مفترضا ضروريا للفصل في الثانية، إذ بغير هذا الارتباط لا نكون أمام مسألة أولية بالمعنى الصحيح^(١).

٤- أن يبقى بعد الفصل في موضوع الدفع نزاع أمام محكمة الدعوى الأصلية، فإذا كان الفصل في الدفع يحسم كل نزاع بين الخصوم: فلا محل لوقف الدعوى^(٢).

مصير الخصومة بعد الوقف التعليقي:

نصت المادة (٢/١٢٩) مرافعات، على أنه "وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى، ومن ثم يتحدد مصير الخصومة بعد الوقف التعليقي وفقا للآتي:

١- إذا قام الخصم بعد الحصول على حكم في المسألة الأولية، بتحديد جلسة، وأعلن خصمه بها؛ فإن الخصومة الموقوفة تعود إلى السير مرة أخرى، ولم يحدد القانون ميعادا معيناً يجب أن يتم التعجيل فيه، ومن ثم يجب أن يتم التعجيل قبل انقضاء ست أشهر، من تاريخ الحكم في المسألة الأولية، وإلا سقطت الخصومة^(٣).

٢- إذا لم يحصل الخصم على حكم في المسألة الأولية في الميعاد الذي حددته المحكمة-إن كانت قد حددت ميعادا- فإن الخصومة تسقط بانقضاء ستة أشهر على هذا الميعاد، وبانقضاء المدة ذاتها من تاريخ الوقف إن لم تكن حددت ميعادا.

(١) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٥٦- د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ١١٥.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٥١.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، مرجع سابق، ص ٧٥٦.

الفرع الثالث

الوقف القانوني

ويكون الوقف قانونيا، أي يترتب بقوة القانون دون حاجة إلى أن تقضي به المحكمة. في الحالات التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة لأسباب تتحقق معها غايات معينة من الوقف، وليس للمحكمة إزاء هذا النوع سلطة تقديرية، ولا يعدو عملها فيه أن يكون تقرير لأمر واقع، فيبدأ الوقف من تاريخ تحقق سببه وليس من تاريخ الحكم به^(١).

ومن أمثلة الوقف القانوني:

- ١- ما نصت عليه المادة (١٦٢) مرافعات من أنه، يترتب على تقديم طلب رد القاضي، وقف الدعوى الأصلية، إلى أن يحكم فيه.
- ٢- نص المادة (٢١٢) مرافعات، على أنه يجب وقف الخصومة في الدعوى الأصلية حتى يفصل في الطعن المرفوع ضد الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة.
- ٣- نص المادة (٣/٣١) من قانون المحكمة الدستورية، على أنه يترتب على تقديم طلب تعيين الجهة المختصة في حالة التنازع الإيجابي في الولاية، وقف الدعوى حتى الفصل في الطلب. ويترتب على هذا الوقف الآثار التي تترتب على غيره من أنواع، كما سبق أن أشرنا، كما تقف جميع المواعيد، حتمية كانت أم تنظيمية.

مصير الخصومة بعد الوقف القانوني:

- ١- إذا زال سبب الوقف القانوني، عادت الخصومة إلى السير مرة أخرى، شريطة تحديد جلسة يعلن بها الخصوم. ولم يحدد المشرع ميعادا معيناً لتعجيل الدعوى بعد الوقف القانوني.
- ٢- إذا لم تعجل الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه، ومضت ستة أشهر كاملة من تاريخ آخر إجراء صحيح، سقطت الخصومة في الدعوى الأصلية.

(١) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ١١٢-د. رمزي سيف، مرجع سابق، ص ٥٦٥.

المطلب الثاني

انقطاع الخصومة

تعريفه وأسبابه:

انقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون لتصدع ركنها الشخصي^(١). إذ القاعدة أنه يشترط لصحة الخصومة، وجود أطرافها، وصلاحية كل طرف للقيام بالإجراءات، وهذا شرط لأي إجراء قضائي من إجراءات الخصومة، فإذا توافر في بداية الخصومة ثم تخلف بعد ذلك، فإنها تظل قائمة باعتبارها بدأت صحيحة، غاية ما هنالك أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء فيها إلا إذا اشترك فيها من يقوم مقام الخصم المعيب، ويمتنع السير فيها حتى يتحقق ذلك^(٢). وأسباب انقطاع الخصومة ورد النص عليها في القانون على سبيل الحصر، وهي ثلاثة أسباب، أولها: وفاة أحد الخصوم، وثانيها: فقد الخصم أهلية الخصومة، وثالثها: زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن الخصم. (مادة ١٣٠ مرافعات).

فإذا توافر سبب من هذه الأسباب انقطعت الخصومة وامتنع السير فيها، حتى يزول سبب الانقطاع بحلول من يقوم مقام الخصم الذي توافر فيه سبب الانقطاع، وهو وقف بقوة القانون يحتاج إلى حكم لتقريره لا لإيقاعه، فلكي يثبت الخصم الانقطاع لابد له من الحصول على حكم يقرره، وترتد آثار الانقطاع في هذه الحالة إلى تاريخ حدوث الواقعة التي أدت إليه وليس إلى تاريخ التمسك به أو تاريخ صدور الحكم التقريري^(٣).

شروط انقطاع الخصومة:

يشترط لانقطاع الخصومة توافر الشروط الآتية:

- ١- أن يتحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة: وهي واردة في القانون على سبيل الحصر، كما ذكرنا، وهذه الأسباب هي:
- السبب الأول: وفاة أحد الخصوم^(٤): إذ الأصل في الخصومة أنها لا تنعقد إلا بين الأحياء، فلا يجوز رفع الدعوى على متوفى، ولا يتصور رفعها منه، وإلا كانت منعدمة لا ترتب أثرا.

(١) د. أحمد مسلم، مرجع سابق، ص ٥٣٦.

(٢) د. وجدي راغب فهيم، مرجع سابق، ص ٥٥٣.

(٣) د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٥٥.

(٤) يأخذ حكم الوفاة زوال الشخص الاعتباري الذي يكون طرفا في الخصومة، أثناء سيرها، كما لو حلت الشركة أو أدمجت في غيرها، إذ انقضاء الشخص الاعتباري معناه انتهاء شخصيته وصلاحيته كمركز قانوني صالح للحقوق والالتزامات. (د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ١٢٣). ويأخذ حكم الوفاة أيضا، الموت الحكي، كما إذا اعتبر المفقود ميتا. (د. أحمد مليجي، ج ٢٨٩/٣).

غير أنه قد يحدث أن تنعقد الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء، ثم يتوفى خصم من الخصوم أثناء سيرها، وهنا يجب القانون أن تنقطع الإجراءات، حتى لا يضار ورثة الخصم، والذين قد يجهلون قيام الخصومة. يستوي في ذلك أن يكون هذا الخصم مدعياً أو مدعى عليه، أو أحد المدعين أو المدعى عليهم، أصلياً كان هذا الخصم أو مختصماً أو متدخلاً في الدعوى^(١). وإذا تعدد الخصوم في أحد طرفي القضية، وقام سبب الانقطاع في أحدهم دون بقية الخصوم، فإن الخصومة تنقطع بالنسبة له فقط، وتستمر صحيحة بالنسبة لغيره، إلا إذا كان موضوعها لا يقبل التجزئة، فتتقطع بالنسبة للجميع^(٢).

السبب الثاني: فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي: وهي صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء، فإذا فقد أحد الخصوم أهليته لوجود عارض من عوارض الأهلية أو مانع من موانعها، كالجنون أو السفه أو العته أو الغفلة، فإن ذلك يؤدي إلى انقطاع سير الإجراءات^(٣). فهذه الأمور العارضة تؤثر في قدرة الإنسان في الدفاع عن مصالحه، أو تمنعه من مباشرة حقوقه الإجرائية، فيجب وقف سير الخصومة^(٤).

السبب الثالث: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم: كأن يرفع شخص دعوى بصفته ولي أو وصي على القاصر ثم تزول هذه الولاية أو الوصاية بعزله أو ببلوغ القاصر سن الرشد، فيؤدي زوال الصفة هنا إلى انقطاع الخصومة^(٥)، بقوة القانون حتى تعجل في مواجهة الخصم الأصيل أو ممثله القانوني الجديد، يستوي في ذلك أن يكون زوال الصفة للنائب القانوني أو الاتفاقي، للمدعي أو المدعى عليه^(٦).

الصفة في التقاضي والصفة في الدعوى وصفة الوكيل بالخصومة:

ينبغي التمييز بين هذه الصفات الثلاث، فالأولى فقط هي ما يترتب على زوالها انقطاع الخصومة، أما زوال الصفة في الدعوى، فيؤدي إلى عدم قبولها، أو إلى التأجيل لإعلان ذي الصفة (مادة ٢/١١٥ مرافعات) وليس إلى انقطاع الخصومة. كما أن زوال صفة الوكيل بالخصومة (المحامي) لا تنقطع به الخصومة، سواء في ذلك أكان سبب زوالها وفاته، أو انقضاء

(١) يلاحظ أن الموت في بعض الدعاوى لا يؤدي إلى الانقطاع، وإنما يؤدي إلى انقضاء الخصومة، لأهمية الاعتبار الشخصي في القضية، كدعوى التطليق مثلاً. (المرجع السابق، هامش ص ١٢٢).

(٢) د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٦٥٢.

(٣) وإذا كان الخصم تاجراً وحكم بشهر إفلاسه، فإنه يعد فاقداً للأهلية بالنسبة لأموال التفليسة.

(٤) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ١٢٤.

(٥) أستاذي د. حامد أبو طالب، مرجع سابق، ص ٥٧٦.

(٦) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ص ٢٩٣.

وكالته بالعزل أو التنحي، وكل ما يرتبه القانون على ذلك، تخويل المحكمة سلطة منح الخصم أجلاً مناسباً، بشرط أن يكون قد بادر بتعيين وكيل جديد في الخمس عشرة يوماً التالية لزوال الصفة في الوكالة^(١).

٢- أن يتحقق سبب الانقطاع بعد بدء الخصومة: إذ إن وفاة أحد الخصوم قبل رفع الدعوى يؤدي إلى انعدام المطالبة القضائية، كما تؤدي المطالبة من خصم أو في مواجهة خصم فاقد الأهلية أو الصفة في التقاضي إلى بطلانها، وهذا يؤدي إلى زوال الخصومة^(٢).

٣- أن يتحقق سبب الانقطاع قبل أن تصبح الدعوى مهياً للفصل في موضوعها؛ وهي تعتبر كذلك، متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة، قبل الوفاة، أو فقد الأهلية، أو زوال الصفة (مادة ١٣١ مرافعات).

الأثر المترتب على انقطاع الخصومة:

يترتب على توافر سبب من أسباب انقطاع الخصومة، أثرين مهمين، ورد النص عليهما في المادة (١٣٢) مرافعات، هما:

الأثر الأول: وقف جميع المواعيد السارية في حق من قام به سبب الانقطاع: أما الخصم الآخر فتستمر المواعيد الخاصة به في سريانها، فمثلاً، إذا شطبت الدعوى لتخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور، وبقيت مشطوبة ستين يوماً، اعتبرت الخصومة كأن لم تكن، فإذا توفي المدعي بعد شطب الدعوى وقبل انقضاء هذه المدة وقف سريانها^(٣). وكذلك إذا توفي المحكوم عليه بعد صدور الحكم أو بعد إعلانه، فإن مواعيد الطعن تقف في حقه^(٤).

وإذا كان يترتب على الانقطاع وقف المواعيد لمن قام سبب الانقطاع في حقه، فإن ذلك لا يؤثر في بقاء الخصومة ذاتها، فتظل قائمة منتجة لكافة آثارها القانونية المترتبة على إيداع صحيفتها، سواء كانت موضوعية أو إجرائية، كما تظل جميع الأعمال الإجرائية التي اتخذت في الخصومة قبل انقطاعها صحيحة ومنتجة لآثارها^(٥)، فإذا انتهت حالة الانقطاع فإن الخصومة تعاود سيرها من النقطة التي وقفت عندها، مع الاعتداد بكل الإجراءات السابقة^(٦).

(١) د. وجدي راغب فهبي، مرجع سابق، ص ٥٥٥-٥٥٦.

(٢) د. عبدالباسط جميعي، مرجع سابق، ص ٣١٦- د. وجدي راغب فهبي، مرجع سابق، ص ٥٥٦.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، مرجع سابق، ص ٧٦٢.

(٤) د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٥٧.

(٥) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٣/٣٢٣.

(٦) د. وجدي راغب، مرجع سابق، ص ٥٥٧.

الأثر الثاني: عدم جواز اتخاذ أي إجراء أثناء فترة الانقطاع: فبمجرد قيام سبب الانقطاع تقف إجراءات الخصومة بقوة القانون، ولا يجوز مباشرة أي إجراء في الخصومة وإلا كان باطلاً. والبطالان المترتب على الانقطاع بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته، تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه، وحتى لا تتخذ الإجراءات في غفلة منه^(١).

مصير الخصومة بعد الانقطاع:

قبل الحديث عن مصير الخصومة بعد الانقطاع، يجب أن نشير إلى أن المشرع أوجب على المحكمة، إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، أن تكلفه بإعلان خصمه خلال أجل تحدده، ولا يجوز لها حينئذ أن ترفض هذا الطلب وتقضي بانقطاع الخصومة، فإذا لم يقوم الخصم بالإعلان في الأجل المحدد دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع الخصومة منذ تحقق سببه (مادة ١٣٢/٢).

ومتى حكمت المحكمة بانقطاع الخصومة، سواء بعد طلب الأجل وعدم القيام بالإجراء، أو في حالة عدم طلبه، فإن الخصومة التي حكم بانقطاعها، يكون مصيرها أحد أمرين:

أولهما: استئناف سيرها: ويكون ذلك بأحد طريقتين:

١ - تعجيل الخصومة: بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن من الشخص الذي قام مقام من تحقق به سبب الانقطاع.

٢ - إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها، وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة، وباشراً سيرها.

وبدهي أن هذا يفترض قيام سبب الانقطاع في الفترة الواقعة بين جلستين، فإذا حضر من يقوم مقام الخصم المعيب الجلسة التالية مباشرة لتحقق سبب الانقطاع، عادت الخصومة المنقطعة للسير من جديد.

وثانيهما: أن الخصومة المنقطعة إذا لم تعاود سيرها من جديد بالتعجيل أو الحضور، فإنها تظل في حالة ركود، يقودها إلى الانقضاء، فتطبق عليها قواعد سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة، فتتقضي دون حكم فاصل في موضوعها، إذا لم تعجل خلال ستة أشهر، وإلا فإنها تنقضي بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها^(٢).

(١) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ١٢٨.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٣/٣٣٦.

المبحث الثاني

العوارض المؤدية إلى انقضاء الخصومة بغير حكم

المطلب الأول

سقوط الخصومة

تعريفه وأساسه وحكمته ونطاقه:

سقوط الخصومة هو زوالها واعتبارها كأن لم تكن لعدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي يكون قد اتخذ فيها^(١). وهو جزء إجرائي يؤدي إلى وضع حد للخصومة بما تم فيها من إجراءات قبل بلوغها غايتها^(٢)، ويتم بقوة القانون بمجرد حدوث ما قرره المشرع لهذا السقوط.

وقد اختلف الفقه القانوني الفرنسي في أساس السقوط، وذلك على ثلاثة اتجاهات، الأول: أن السقوط مبني على مراعاة المصلحة العامة، حتى لا تتراكم القضايا فتتأثر العدالة، في حين اتجه فريق ثان، إلى أن تأسيس السقوط على فكرة رعاية مصلحة المدعي عليه، لأن الإبقاء على الخصومة التي قصر المدعي في موالاتها يعني الإبقاء على حالة القلق وعدم الاستقرار الناجمة عن الخصومة، لذلك حماه المشرع بفرضه السقوط إذا طلبه، بينما ذهب رأي ثالث: إلى أن أساس السقوط ومبناه، معاقبة المدعي على إهمال السير في دعواه، بسقوط الخصومة، لأن المشرع ربط السقوط بإهمال المدعي في القيام بالنشاط المطلوب في الخصومة^(٣).

ويذهب الفقه القانوني المصري إلى أن السقوط جزء يوقعه القانون على المدعي نتيجة لإهماله في مباشرة نشاطه في الخصومة، ويرمي إلى حثه على السير في الخصومة، حتى لا تبقى مجرد وسيلة تهديدية بغرض الكيد بخصمه^(٤).

وهناك جانب من الفقه يؤسس السقوط على اعتباره جزءاً علي قرينة ترك المدعي لدعواه وعدم رغبته السير فيها، والبعض يؤسسه على فكرة رعاية المدعي عليه، إذ القانون يجيز له طلبه ولو عجل المدعي دعواه بعد انقضاء مدة الوقف^(٥).

(١) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٦٧٥.

(٢) د. إبراهيم أمين النفيائي، الإخلال بالواجب الإجرائي، مرجع سابق، ص ٣٢٥.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، ص ٥٥١- د. الكوني علي أعبوده، ص ٣٠٨- د. إبراهيم أمين النفيائي، ص ٣٢٦.

(٤) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ٦٦٦- د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٥٦٤.

(٥) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، مرجع سابق، ٥٥٦.

ومن جانبنا، نرى أن السقوط وفي ضوء حكمته والغاية من النص عليه، مبني على فكرتين، الأولى: معاقبة المدعي على إهمال دعواه وعدم السير فيها المدة التي نص عليها القانون، والثانية: مراعاة جانب المدعى عليه حتى لا يظل مهددا قلقا بدعوى أهمل خصمه متابعتها والسير فيها، ودليل ذلك أن المشرع أعطى للمدعى عليه الحق في طلب سقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح تم فيها.

وحكمة السقوط وعلته تدل على ذلك؛ إذ الحكمة من النص على السقوط، معاقبة للمدعي على إهمال السير في دعواه، لحمله على مولاة السير فيها، والتخلص من الدعاوى التي يهمل الخصم السير فيها حتى لا تترك الدعاوى أمام القضاء^(١)، وحتى لا تبقى هذه الدعاوى مجرد وسيلة تهديدية الغرض منها الكيد بالمدعى عليه ومشاكسته^(٢).

وأما نطاق السقوط، فيتحدد من زاويتين، الأولى: من حيث الخصومات التي يسري عليها، وهو في ذلك يسري على كافة الدعاوى التي تدخل في ولاية القضاء المدني أيا كانت طبيعتها، وأمام جميع المحاكم أيا كانت درجتها، باستثناء خصومة الطعن، فلا يسري عليها نظام السقوط، لاختلاف طبيعة الإجراءات أمامها^(٣). والزاوية الثانية: من حيث الأشخاص الذين يسري السقوط في مواجهتهم، وهو في ذلك يشمل جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.

الطبيعة القانونية لسقوط الخصومة:

السقوط جزاء إجرائي، يترتب على مخالفة المدعي لواجب تسيير الخصومة، ومعنى ذلك، أنه لا يمكن الحكم به إلا عليه، وفي حال إهماله لواجب تسيير الخصومة، وانقضاء المدة المقررة قانونا على آخر إجراء صحيح تم في فيها، ومعنى كون السقوط جزاء للمدعي على إهمال دعواه، ألا يفاد منه، فلا يكون له التمسك به^(٤).

من له الحق في التمسك بالسقوط:

قلنا إن مفاد كون السقوط جزاء للمدعي، ألا يكون له حق التمسك به، ومن ثم يبقى الحق في التمسك بالسقوط كجزاء على إهمال المدعي في دعواه، للمدعى عليه؛ إذ له وحده دون غيره

(١) د. رمزي سيف، الوسيط، مرجع سابق، ص ٥١٥.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٣/٣٤٩- د. وجدي راغب فهد، ص ٥٦٤.

(٣) قضت محكمة النقض بأن قواعد سقوط الخصومة لا تطبق في الطعن بالنقض، لأن سير الإجراءات في النقض لا يعتمد على نشاط الخصوم. (الطعن رقم ٢٩٥ لسنة ٥١ قضائية جلسة ٢٥/٣/١٩٨٢م).

(٤) د. إبراهيم أمين النفاوي، الإخلال بالواجب الإجرائي، مرجع سابق، ص ٣٢٨.

أن يتمسك به. وعبرة المشرع في المادة (١٣٤) مرافعات "لكل ذي مصلحة من الخصوم" تنصرف فقط إلى المدعى عليه، ومن يقف موقفه في الخصومة، كالخصم المتدخل انضماماً إلى جانب المدعى له، أو المختصم في الخصومة.

سلطة المحكمة في الحكم بالسقوط:

ينبغي على خلاف الفقه القانوني حول أساس السقوط، وكونه غير متعلق بالمصلحة العامة، ألا تكون للمحكمة سلطة الفصل فيه من تلقاء نفسها، لتعلقه بحق المدعى عليه، فهو مقرر لمصلحته، وله وحده الحق في طلبه والتمسك به، ومن ثم لا يكون لمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بغير طلب من المدع عليه، وحكمها في هذا الشأن ليس سوى حكم تقريري، يؤكد السقوط الذي تم بقوة القانون، ولا ينشئه.

قابلية السقوط للتجزئة:

سقوط الخصومة يقبل التجزئة، بالنسبة للمدعى عليهم، فإذا تعددوا، وتمسك أحدهم بالسقوط، لم يحكم به إلا لمصلحته فقط دون أن يستفيد من ذلك بقية المدعى عليهم، وشرط ذلك أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، وإلا فلا تصح تجزئة السقوط. أما بالنسبة لتعدد المدعين، فإن سقوط الخصومة بالنسبة لهم لا يقبل التجزئة، فيجب توجيه طلب السقوط إليهم جميعاً، وإلا كان غير مقبول (مادة ١٣٦/٣ مرافعات).

شروط التمسك بسقوط الخصومة:

يشترط للتمسك بسقوط الخصومة توفر الشروط الآتية:

١- عدم السير في الخصومة:

فينبغي للحكم بالسقوط أن يكون سير الخصومة قد وقف المدة التي نص عليها المشرع؛ إذ السقوط جزاء مقرر على عدم السير في الدعوى، فلا يتم الحكم به إلا إذا تحققت الواقعة المؤدية إليه، بحيث تصبح الخصومة في حالة ركود، ولا يوجد فيها أي نشاط، كأن تستبعد القضية من جدول القضايا لعدم سداد الرسوم، ولا يتخذ فيها إجراء بعد ذلك، أو أن يحكم بوقف الخصومة أو انقطاعها، أو أن يحكم بإحالة القضية من محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف، ولا يتخذ فيها إجراء بعد ذلك^(١).

(١) د. عبدالنواب مبارك، مرجع سابق، ص ٥١٦- د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٥٦٥.

٢- أن يرجع سبب عدم السير في الخصومة إلى إهمال المدعي:

لا يكفي للحكم بسقوط الخصومة، عدم السير فيها المدة المقررة، وإنما يجب أن يكون عدم سيرها راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه، بأن يكون مسئولاً عنه وكان يمكن تجنبه بالسير في الدعوى، فإن حال مانع قانوني دون ذلك، فلا تسقط الخصومة^(١).

وعلى ذلك؛ فإنه إذا ثبت أن عدم السير في الخصومة، مرده واقعة لا يد للمدعي فيها، بأن استحال عليه متابعة الإجراءات بسبب حالة حرب، أو وقوع انقلاب، أو حدوث فيضان، أو غير ذلك من الموانع المادية التي تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم، أو استحالة الانتقال لمباشرة الإجراء، فلا تسقط الخصومة لهذا السبب، وإنما توقف حساب مدة السقوط حتى يزول المانع^(٢). ذلك أن عدم السير في الخصومة المؤدي إلى السقوط، مبني على افتراض إهمال المدعي. ويجب أن نشير في هذا الشأن، إلى أن هناك حالات يكون عدم السير في الخصومة فيها سببه حدوث واقعة لا يد للمدعي فيها، ومع ذلك يسأل عنه، وتسقط الخصومة رغم ذلك؛ وذلك إذا كانت عودة السير في الخصومة متوقفة على فعل المدعي أو امتناعه، ولم يرقم بذلك، كما في حالة وفاة المدعى عليه التي تؤدي إلى انقطاع الخصومة ووقف السير فيها بقوة القانون، وكذلك حالة الوقف بقوة القانون، أو الوقف التعليقي، فجميع هذه الحالات يرجع سبب وقف الخصومة فيها إلى سبب لا يد للمدعي فيه، وإنما يقع عليه واجب إجرائي في اتخاذ الإجراء اللازم لعودة السير في الخصومة، فإن لم يفعل، سقطت الخصومة جزاء إهماله^(٣).

٣- أن يستمر ركود الخصومة مدة ستة أشهر^(٤):

والركود يعني توقف الخصومة عن السير دون أن تكون هناك جلسة محددة لنظرها^(٥) ولا يكفي لسقوط الخصومة أن يحدث هذا الركود بإهمال المدعي، وإنما يجب أن يستمر مدة ستة أشهر، وهي المدة التي قررها القانون لسقوط الخصومة، ويبدأ حسابها من تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ فيها (مادة ١٣٤ مرافعات). ولا عبرة بشخص القائم بهذا الإجراء الأخير، فيستوي في

(١) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، مرجع سابق، ص ٥٧٣.

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٦٧٦.

(٣) المستشار. سيد حسن البيغال، المطول، مرجع سابق، ص ٦١٨-٦١٩.

(٤) وهذه المدة معدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وكانت قبل تعديلها، سنة، فأُنقصها التعديل المشار إليه إلى ستة أشهر. وذلك رغبة من المشرع في تقصير مواعيد بعض الجزاءات الإجرائية تحقيقاً للسرعة في فصل الخصومات القضائية. (المذكرة الإيضاحية لقانون بشأن تعديل المادة).

(٥) د. إبراهيم أمين النفاوي، الإخلال بالواجب الإجرائي، مرجع سابق، ص ٦١٨-٦١٩.

ذلك أن يكون القائم به هو المدعي أو المدعى عليه أو القاضي أو أحد أعوانه^(١)، إذ شرط هذا الإجراء أن يكون صحيحا أيا كان القائم به.

ويجرى حساب مدة الستة أشهر وفقا للقواعد العامة في حساب المواعيد، فلا يدخل في حسابها اليوم الذي تم فيه الإجراء، وإنما تبدأ من اليوم التالي له، كما تحسب المدة بالشهور لا بالأيام، وبغض النظر عن عدد أيام الشهر، كما يضاف إليها ميعاد المسافة بين مقر المحكمة التي قدمة إليها صحيفة التعجيل، وموطن من يراد إعلانه. فإذا انقضت هذه المدة دون تعجيل الخصومة، فإن الخصومة تسقط بقوة القانون، وتزول كافة إجراءاتها، وتعتبر كأن لم تكن^(٢).

٤- ألا يتخذ خلال مدة السقوط أي إجراء يقصد به مwalاة السير في الخصومة:

ذلك أن السقوط مبني كما ذكرنا على إهمال المدعي في دعواه، بحيث يتوقف سيرها بسبب ذلك مدة ستة أشهر دون اتخاذ إجراء فيها، فإن اتخذ غجرا في الخصومة خلال هذه المدة، فإنه يكون قاطعا لمدة السقوط ومانعا منه، شريطة أن يتوافر فيه ما يأتي^(٣):

- أن يكون صادرا من أحد طرفي الخصومة: ولا يلزم في ذلك أن يكون الإجراء صادرا من المدعي، بل يرتب الإجراء هذا الأثر ولو كان صادرا من المدعى عليه في مواجهة المدعي كما لو أبدى طلبات موضوعية في الخصومة، كما يرتب الإجراء أثره في قطع مدة السقوط، إذا كان صادرا من المتدخل اختصاصيا، أو ممن أدخله أحد الخصوم ضامنا له، أو المتدخل انضماميا إلى جانب المدعي.
- أن يتخذ الإجراء في مواجهة الخصم الآخر: كأن يتخذه المدعي في مواجهة المدعى عليه أو العكس، أما إذا كان الإجراء من مدعى عليه في مواجهة مدعى عليه آخر، فإنه لا يحول دون سقوط الخصومة.
- أن يتعلق الإجراء بالخصومة: فلا يقطع مدة السقوط إجراء غير قضائي، أو إجراء من خصم في مواجهة خصمة في خصومة أخرى، أما إذا كان الإجراء هو إقامة الدعوى أمام محكمة أخرى إعمالا لحكم الوقف التعليقي، فإنه يكون قاطعا لمدة السقوط.
- أن يكون المقصود بالإجراء السير نحو الفصل في الدعوى: كالطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بوقفها، وكتبادل المستندات بين الخصوم.
- أن يكون الإجراء صحيحا: فإن كان باطلا، فإنه لا يرتب أثرا.

(١) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٦٩.

(٢) د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٤١٩.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، ص ٥٨٦ وما بعدها- د. أحمد مليجي، الموسوعة، ج ٣/٣٦٣.

٥- أن يتم التمسك بسقوط الخصومة من صاحب المصلحة:

وهو كما أسلفنا، المدعى عليه، ومن في حكمه، وسواء في ذلك انفرد المدعى عليه، أو تعدد المدعى عليهم وتمسك به أحدهم، وكذلك كل ذي مصلحة في التمسك بالسقوط، كورثة المدعى عليه، ودائنيه، والسنديك نيابة عن المدعى عليه المفلس، ومن أدخله المدعى عليه ضامناً له، والمتدخل اختصاصياً للمطالبة بذات الحق موضوع النزاع، وكذلك المتدخل انضمامياً إلى جانب المدعى عليه^(١).

والرأي الراجح في الفقه القانوني- ونؤيده- أنه لا يجوز للمدعي أن يتمسك بسقوط الخصومة، لأن السقوط جزاء مقرر على إهماله، فلا يجوز أن يفاد من خطئه^(٢).

كيفية حساب مدة السقوط في حالي الوقف والانقطاع:

قلنا إن مدة السقوط ستة أشهر، تبدأ كقاعدة عامة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة. أي كان شخص القائم به، وأياً كانت طبيعة الخصومة أو نوعها -باستثناء خصومة النقض- وأياً كان الخصوم في الدعوى.

غير أن حساب هذه المدة يختلف في حالي الوقف والانقطاع، إذ لكل منهما طريقة مختلفة في احتساب المدة وبدايتها، على النحو الآتي:

أولاً: بالنسبة للوقف: نفرق بين أنواع الوقف على النحو الآتي:

- **الوقف الاتفاقي:** تنقضي الخصومة فيه إذا لم تعجل في الأيام الثمانية التالية لانتهاء مدة الوقف، ومن ثم فلا مجال فيه لإعمال فكرة سقوط الخصومة.
- **الوقف الجزائي:** لا تبدأ مدة الستة أشهر إلا من تاريخ انتهاء المدة المقررة للوقف الجزائي، لأن المدعي لا يستطيع مباشرة أي إجراء في الخصومة خلال هذه المدة.
- **الوقف التعليقي:** يعد مانعاً قانونياً يحول دون موالاة السير في الخصومة، ومن ثم فلا تبدأ مدة السقوط إلا من تاريخ الفصل في المسألة الأولية.
- **الوقف بقوة القانون:** كما في وقف الدعوى للفصل في طلب الرد، فإن المدة تبدأ من تاريخ زوال سبب الوقف.

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٣/٣٦٥.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط، مرجع سابق، ص ٦٧٣.

عكس هذا الرأي، ذهب الدكتور أحمد أبو الوفا، إلى أنه يجوز للمدعي أن يتمسك بسقوط الخصومة رغم أن السقوط جزاء مقرر على خطئه. (لسيادته: نظرية الدفع، مرجع سابق، ص ٥٩٧ وما بعدها).

ثانياً: بالنسبة للانقطاع:

فإن مدة السقوط تبدأ في حالة الإنقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بالسقوط بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي (مادة ١٣٥ مرافعات). وذلك خشية أن يكون ورثة المتوفى، أو من يقوم مقام الخصم الذي فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت صفته جاهلين بقيام الخصومة فتسقط في غفلة منهم^(١)، ولذلك لا تبدأ مدة السقوط إلا من تاريخ إعلانهم.

وهذا الحكم مقرر في حالة تحقق سبب الانقطاع في جانب المدعي، أم إذا كان سبب الانقطاع قد تحقق في جانب المدعى عليه، فإن حساب المدة يكون وفقاً للقاعدة العامة، من تاريخ آخر إجراء صحيح في الخصومة؛ لأن السقوط جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه، جراء إهمال المدعي في دعواه.

كيفية تقديم طلب الحكم بالسقوط والمحكمة المختصة به:

سقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام، ولا تملك المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها، وإنما لا بد أن يتمسك به صاحب المصلحة فيه (مادة ١٣٤ مرافعات)، وقد بينت المادة (١٣٦) كيفية التمسك بالسقوط، والمحكمة المختصة به. فأجازته بإحدى وسيلتين:

الأولى: الدعوى الفرعية بسقوط الخصومة: فيجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الخصومة بدعوى فرعية ترفع إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، بعد انتهاء المدة المقررة لسقوط الخصومة.

والثانية: الدفع بسقوط الخصومة: ويكون ذلك في حالة تعجيل المدعي للدعوى بعد انقضاء أجل السقوط؛ إذ يكون للمدعى عليه في هذه الحالة أن يدفع بسقوط الخصومة، ولما كان السقوط متعلقاً بمصلحة المدعى عليه وليس بالمصلحة العامة، فإن الدفع به، وهو دفع إجرائي، يخضع للقواعد المقررة للدفع الإجرائية، فيجب إبداءه قبل الكلام في الموضوع بعد تعجيل الخصومة، وإلا سقط الحق فيه، إلى غير ذلك من قواعد الدفع الإجرائية التي سبق بيانها.

وفي كلتا الحالتين -الدعوى الفرعية، أو الدفع- فإن التمسك بالسقوط يجب أن يتم أمام نفس المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المطلوب إسقاطها، ولو كانت محكمة الاستئناف، بالنسبة لخصومة الاستئناف، فالاختصاص بنظر طلب السقوط ينعقد لذات المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، أي كانت وسيلة التمسك به (مادة ١٣٦ مرافعات).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٣/٣٩٧.

آثار الحكم بسقوط الخصومة:

نظم المشرع الآثار المترتبة على سقوط الخصومة بالمادتين (١٣٧ و ١٣٨)، وهذه الآثار منها ما تشترك فيه خصومة محكمة الدرجة الأولى وخصومة الاستئناف، ومنها ما تنفرد به الخصومة أمام محكمة الاستئناف، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: آثار سقوط الخصومة أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية:

قلنا إن سقوط الخصومة يترتب بقوة القانون بمجرد تحقق سببه وتوافر شروطه، والحكم الصادر بالسقوط حكماً تقريرياً وليس منشئاً، ومن ثم ترتد آثار السقوط إلى لحظة تحقق مفترضاته، وليس لحظة الحكم به^(١).

ويترتب على سقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها، فتعتبر كأن لم تكن^(٢)، وتزول كافة الآثار التي نشأت عن إعلانها، وتعود العلاقة بين الخصوم إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى، فتسقط جميع الطلبات العارضة، ويعتبر التقادم كأن لم ينقطع^(٣).

غير أن زوال الخصومة لا يؤثر على الحقوق الموضوعية التي أقيمت الدعوى من أجلها، فلا يحول الحكم بسقوط الخصومة دون رفع دعوى جديدة بنفس الحقوق ما لم تسقط، أو تنقضي بسبب خاص بها.

الاستثناء من أثر السقوط:

استثنى المشرع من أثر سقوط الخصومة، بعض الأعمال التي تمت صحيحة فيها؛ وذلك إعمالاً لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات، وهذه الأعمال هي:

- الأحكام القطعية الصادرة في الخصومة، والإجراءات السابقة عليها؛ ويقصد بها تلك التي تحسم بعض طلبات الخصوم وتحوز الحجية، أو التي تصدر في طلب من الطلبات حاسمة نقطة من نقاط النزاع، ولو لم تحز الحجية بالمعنى الصحيح، وسواء تعلقت هذه الأحكام بشق موضوعي، أو بشق إجرائي، كالحكم بقبول الدعوى، والحكم بالاختصاص. فالحكم بسقوط الخصومة لا يؤثر في هذه الأحكام، ولا فيما بنيت عليه من إجراءات.

(١) د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٤٢٧.

(٢) يستوي في ذلك الإجراءات التي قام بها الخصوم، أو التي صدرت عن المحكمة، كالأحكام التمهيدية والتحضيرية، كالحكم بالإحالة على التحقيق، وكذلك الأحكام غير القطعية، كالأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، ص ٦١٧- د. أحمد مليجي، ج ٣/٤٢٤- د. نبيل عمر، الوسيط ٦٧٥.

- الإقرارات الصادرة من الخصوم والأيمان التي حلفوها: فلا تتأثر هذه بسقوط الخصومة، وإنما تبقى قائمة مرتبة لآثارها ومحتفظة بقوتها في الإثبات.
- إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت صحيحة في الخصومة: فهذه الأعمال تبقى قائمة مرتبة لآثارها، ولا تزول بزوال الخصومة وسقوطها، إلا إذا كانت هذه الأعمال باطلة في ذاتها.

ثانياً: أثر سقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف:

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف، أثر خاص، وهو ان يصبح الحكم المستأنف انتهائياً، فيسقط الحق في استئنافه، وشرط ذلك أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى باقياً على حاله، ولم تتناوله محكمة الاستئناف بأي تعديل أو إلغاء قبل سقوط الخصومة، أما إذا كان هذا الحكم قد عدل في الاستئناف، فإنه يزول في حدود ما لحقه من تعديل أو إلغاء في الاستئناف. وقد نص المشرع على هذا الحكم لمواجهة الحالة التي يكون فيها ميعاد الاستئناف ممتداً.

المطلب الثاني

انقضاء الخصومة بمضي المدة

(تقادم الخصومة)

تعريفه وحكمته ونطاقه:

انقضاء الخصومة معناه، زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها لعدم قيام الخصوم بأي نشاط إجرائي فيها خلال سنتين متتاليتين دون انقطاع، أي كان السبب الذي أدى إلى ركودها^(١). وهو جزء إجرائي يقع بقوة القانون متى توافرت مفترضاته.

وترجع الحكمة من تقرير هذا الطريق من طرق إنهاء الخصومة، إلى رغبة المشرع في التخلص من القضايا المهملة، والتي قد لا يتوافر بشأنها مفترضات السقوط أو اعتبار الخصومة كأن لم تكن. فأراد بهذا الطريق أن يضع حداً أقصى لبقاء الخصومة الموقوفة قائمة لدى القضاء، أي كان سبب وقوفها أو المسئول عن عدم السير فيها. فنص في المادة (١/١٤٠) مرافعات على أنه "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها".

(١) د. محمود نجيب سعد، مرجع سابق، ص ١٦٦.

ويتسع نطاق الانقضاء ليشمل من ناحية الموضوع جميع الخصومات التي تدخل في ولاية القضاء المدني، أي كان نوعها أو طبيعتها، وأيا كانت درجة التقاضي التي تنظر فيها الخصومة، ويشمل من ناحية الخصوم، جميع الخصوم في الدعاوى التي يسري عليها الانقضاء ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.

ولا يستثنى من هذا النطاق إلا ما قرره المشرع بشأن خصومة النقض، حيث نص في الفقرة الثانية للمادة (١٤٠) مرافعات على أنه، "ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على طريق الطعن بالنقض". ومن ثم فإن خصومة الطعن بالنقض لا تخضع لأحكام الانقضاء، أو التقادم بمضي المدة المقررة في المادة (١٤٠) مرافعات.

ويشترك انقضاء الخصومة بالتقادم مع سقوطها في أنهما يرميان إلى حمل الخصوم على مواصلة السير في الدعوى، منعا لتراكم القضايا أمام القضاء، إلا أنهما يختلفان من عدة وجوه، أهمها: أن السقوط جزاء مقرر على إهمال المدعي لمواصلة السير في دعواه، أما الانقضاء، فهو مقرر في جميع أحوال عدم السير في الخصومة المدة المقررة، وسواء كان ذلك بفعل المدعي أو امتناعه، أو فعل المدعي عليه أو امتناعه، أو غير ذلك من الأسباب. كما أن التمسك بالسقوط حق للمدعي عليه ومن في حكمه، أما الانقضاء فجائز لكل خصم أن يتمسك به^(١).

شروط الحكم بانقضاء الخصومة:

الحكم بانقضاء الخصومة هو حكم مقرر لحالة الانقضاء وليس منشئا لها؛ إذ يقع الانقضاء بقوة القانون بمجرد قيام سببه، ويشترط للحكم به توافر ثلاثة شروط، هي:

١- عدم السير في الخصومة: فلا يجوز الحكم به إذا كانت الخصومة مستمرة في سيرها أمام القضاء ولم يوقف سيرها، أما إذا وقف السير فيها وانتهت المدة المقررة في القانون للحكم بالانقضاء، فإن المحكمة تحكم به، يستوي في ذلك أن يكون عدم السير فيها راجعا إلى المدعي أو المدعى عليه، أو غير ذلك من الأسباب^(٢).

(١) د. أحمد مليحي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٤٤٩/٣.

(٢) ذهبت محكمة النقض في حكم لها صدر عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية إلى تفسير جديد لعبارة "في جميع الأحوال" التي وردت بالمادة (١٤٠) مرافعات، مؤداه أن هذه العبارة تنصرف فقط إلى الحالات التي يكون فيها عدم مواصلة السير في الخصومة مرجعه مطلق لإرادة الخصوم أو قلم كتاب المحكمة، ورتب على ذلك؛ وقف هذه المدة إذا قام مانع مادي يعد من قبل القوة القاهرة، كحالة الحرب، بحيث يستحيل معه على الخصم مواصلة السير فيها، أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها، كوقف السير في الدعوى المدنية إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية نهائيا (مادة ١/٢٦٥ إجراءات

٢- أن تمضي مدة التقادم: وهي مضي سنتين على آخر إجراء صحيح تم في الخصومة، وهذه المدة واحدة في جميع الدعاوى، فلا تختلف بين دعوى وأخرى.

٣- أن يطلب أحد الخصوم السير في الخصومة: فالانقضاء وإن كان يقع بقوة القانون إلا أن المحكمة لا تملك الحكم به من تلقاء نفسها، وإنما لابد أن يتمسك به صاحب صاحب المصلحة، فإن تمسك به وجب على المحكمة أن تقضي به، ما لم يكن حقه في التمسك به قد سقط بتعرضه للموضوع.

والشرط الأخير مقرر لدى أغلب الفقه القانوني، وإن كنا نرى مع جانب من الفقه^(١)، غير ذلك، وهو أن الدفع أو تقرير انقضاء الخصومة بمضي المدة من الأمور التي تتصل بالنظام العام، ما دامت تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم تحكم المحكمة بالانقضاء من تلقاء نفسها متى توافرت شروطه، كما يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد التعرض للموضوع.

كيفية تقديم طلب الحكم بالانقضاء والمحكمة المختصة به.

يتم التمسك بانقضاء الخصومة بإحدى وسيلتين، الأولى: دعوى مبتدأة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، والثانية: الدفع بالانقضاء إذا عجلت الدعوى بعد انقضاء مدة التقادم. وتختص بنظر الدعوى، أو الدفع، المحكمة المقام أمامها الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها.

الأثر المترتب على انقضاء الخصومة:

يترتب على انقضاء الخصومة ذات الآثار التي تترتب على سقوطها، فتزول الخصومة وتلغى جميع إجراءاتها، كما تزول الآثار المترتبة على قيامها، بما في ذلك قطع التقادم، وسريان الفوائد التأخيرية، وتبقى قائمة ومرتببة لآثارها الأحكام القطعية والإجراءات التي بنيت عليها، إلى غير ذلك من الآثار التي سبق الحديث عنها.

والحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف يترتب عليه اعتبار الحكم المستأنف نهائياً من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه، أو من تاريخ الحكم بالانقضاء، إذا كان ميعاد الاستئناف لم ينقضي بعد^(٢).

جنائية)، وكذلك وقف السير في الدعوى إلى حين الفصل في دستورية نص قانوني. (الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٥٦ قضائية - جلسة ١٩٨٨/٣/٢، الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية).

(١) د. إبراهيم نجيب سعد، ونؤيده في هذا الرأي، لأسبابه. أنظر في عرضه لهذا الرأي وأسبابه، ص ١٦٩ وما بعدها.

(٢) نقض: الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٤٢ قضائية - جلسة ١٩٧٦/٣/١٥.

المطلب الثالث

اعتبار الخصومة كأن لم تكن

تعريفه وحكمته:

اعتبار الخصومة كأن لم تكن جزءاً إجرائياً، يؤدي إلى انقضاء الخصومة إجرائياً، لعدم قيام المدعي بإجراء معين نص القانون على القيام به خلال مدة زمنية محددة، من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات وتتابعها^(١).

فالمشرع في سبيل حرصه على حماية المدعى عليه، وعدم تركه عرضةً للتهديد بدعوى خصمه، لم يكتف بقواعد الوقف والسقوط والتقادم، التي سبق ذكرها، وإنما رأى أن إهمال المدعي في اتخاذ بعض إجراءات معينة في خلال أجل معين يفصح في ذاته عن عدم جدية دعواه: فيكون غير جدير بنظرها، ويوجب الرعاية للمدعى عليه، وكلما بدا إهمال المدعي جسيماً كلما ازداد حرص المشرع على حماية المدعى عليه وأفرط في هذه الحماية^(٢).

وإعمالاً لهذه الحماية، قرر المشرع جزءاً اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهو صورة خاصة من صور سقوط الخصومة، يترتب على سكون الخصومة فترة من الزمن، بسبب من الأسباب الموجبة لهذا الجزء، ومقتضاه تنتهي الخصومة في الدعوى القائمة أمام المحكمة، بغير فصل في موضوعها^(٣).

والأسباب الموجبة لهذا الجزء ترجع جميعها إلى علة واحدة تشتبه مع علة السقوط، وهي إهمال المدعي في دعواه، وهي أسباب ثلاثة، يرجع الأول منها إلى إهمال المدعي في تكليف خصمه بالحضور، ويرجع الثاني إلى إهماله في تعجيل القضية المشطوبة، أما الثالث، فيرجع إلى عدم امتثاله لما أمرته به المحكمة.

حالات اعتبار الخصومة كأن لم تكن:

اعتبار الخصومة كأن لم تكن، جزءاً مقرر على إحدى ثلاث حالات نص عليها المشرع في قانون المرافعات، وهي:

(١) د. عبدالنواب مبارك، مرجع سابق، ص ٥٣٠.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، مرجع سابق، ص ٦٥٢.

(٣) د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٤٤٤.

١- إهمال المدعي في تكليف خصمه بالحضور (مادة ٧٠ مرافعات):

لسنا بحاجة إلى تكرار القول بأن المدعي مكلف بواجب إعلان خصمه بالدعوى وتكليفه بالحضور. وبغير هذا التكليف لا تنعقد الخصومة في مواجهة المدعى عليه، فإذا أهمل المدعي في هذا الواجب، ولم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب؛ فإن للأخير أن يطلب من المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ويشترط لإعمال الجزاء في هذه الحالة خمسة شروط، الأول: ألا يتم تكليف المدعى عليه بالحضور، الثاني: أن تمضي ثلاثة أشهر على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب، الثالث: أن يكون عدم التكليف راجعاً إلى فعل المدعي، الرابع: أن يطلب المدعى عليه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، الخامس: أن تحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ إذ السلطة في الحكم جوازية لها ومتروكة لتقديرها، حتى مع توافر الشروط.

٢- إهمال المدعي في تعجيل الخصومة المشطوبة (مادة ٨٢ مرافعات):

والشطب كما أسلفنا جزاء مقرر على الغياب عن الجلسة الأولى لنظر الدعوى، ولكنه جزاء مؤقت ولمدة حددها المشرع، وهي ستين يوماً، فإذا انقضت؛ فيجب النظر في أمر الخصومة، إما بعودة سيرها ونظرها من قبل المحكمة؛ إذا عجلها أحد الخصوم خلال مدة الشطب، وإما باعتبارها كأن لم تكن، إذا انقضت مدة الشطب، وأهمل المدعي في تعجيلها، وكذلك إذا عجلت ولم يحضر الطرفان بعد السير فيها.

ويشترط هنا لإعمال جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة، توافر خمسة شروط، الأول: أن تكون الدعوى مشطوبة أمام المحكمة، والثاني: أن ينقضي ستون يوماً على شطبها، والثالث: ألا تعجل من أحد الخصوم، أو كانت قد عجلت ولم يحضر الخصوم بعد التعجيل، والرابع: أن يطلب المدعى عليه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، والخامس: أن تحكم المحكمة بهذا الجزاء.

واعتبار الدعوى كأن لم تكن، في هذه الحالة، جزاء يقع بقوة القانون، وحكم المحكمة مقرر له وليس منشئاً، ولا سلطة تقديرية لها تجاهه، فعليها أن تقضي به بمجرد التمسك به من صاحب المصلحة فيه، وهو المدعى عليه، فإن لم يتمسك به، فليس لها أن تقضي به من تلقاء نفسها؛ لعدم تعلقه بالنظام العام.

٣- عدم امتثال المدعي لأمر المحكمة (مادة ٩٩ مرافعات):

قلنا إن الوقف الجزائي، جزاء مقرر على عدم امتثال المدعي لما أمرته به المحكمة، ويجب ألا تزيد مدته على شهر، فإذا انقضى الشهر ولم يقيم المدعي بما أمرته به المحكمة، أو لم يطلب السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

فالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة، جزاء للمدعي على إهمال السير في دعواه، ويشترط لإعماله توافر خمسة شروط، الأول: أن تكون الخصومة موقوفة وقفًا جزائيًا، والثاني: أن تنقضي مدة الوقف بكاملها، والثالث: ألا ينفذ المدعي ما أمرته به المحكمة، أو لم يطلب السير في الدعوى في خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الوقف، والرابع: أن يطلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن، والخامس أن تحكم به المحكمة.

والحكم بالجزاء في هذه الحالة وإن كان واجب على المحكمة، إلا أنها لا تقضي به من تلقاء نفسها، لعدم تعلقه بالنظام العام.

آثار الحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن:

يترتب على هذا الحكم اعتبار الدعوى كأن لم ترفع، فتزول، وتزول كافة الآثار التي ترتبت على رفعها، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، وإن كان ذلك لا يؤثر على الحق الموضوعي فيها، ولا على الحق في تجديد المطالبة به، فيجوز رفع دعوى مبتدأة به، ما لم يسقط بالتقادم، أو ينقضي بسبب خاص به.

المطلب الرابع

ترك الخصومة

تعريفه وطبيعته وحكمته ونطاقه:

لفظ الترك في اللغة يعني التنازل، وهو المعنى الذي يستعمله الفقه القانوني للتعبير عن ترك الخصومة. فترك الخصومة معناه، تنازل المدعي عنها وعن كافة إجراءاتها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها، وهو تصرف قانوني إجرائي يتم بالإرادة المنفردة للمدعي، ويترتب عليه عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى، بأن تلغى كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الخصومة. دون الفصل في موضوعها، أو انتظار الحكم فيها، وذلك متى تم الترك بالشكل والشروط التي يتطلبها القانون^(١).

والترك كما قلنا تصرف قانوني إجرائي، يتم بإرادة منفردة للمدعي، وهو لا يتصور إلا منه، وهو مظهر من مظاهر سلطان إرادة الخصوم في الدعوى، وحكمته ترجع إلى أن المدعي، وهو رافع الدعوى، والمتكبد لنفقاتها، وصاحب المصلحة فيها، قد يطرا له بعد رفع الدعوى، ما يجعل له مصلحة في تركها والنزول عنها دون حكم في موضوعها، كما لو تبين له تعجله فر رفعها قبل أوانه، أو قبل اكتمال أدلتها لديه، فيرى أن تركها خير له من الاستمرار فيها وخسارتها، بما يحول دون رفعها من جديد^(٢).

ويتسع نطاق الترك ليشمل كافة الدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء المدني، دون تمييز بينها، إلا أن يتعلق بالدعوى حق للغير، أو كانت مرفوعة من النيابة في مسألة متعلقة بالنظام العام، فحينئذ لا يجوز النزول عنها.

ميعاد ترك الخصومة:

لم يحدد المشرع ميعادا محددا لترك الخصومة، ولم يقيد به بمرحلة معينة في إجراءاتها، فاللمدعي الحق فيه في أية مرحلة كانت عليها الإجراءات، منذ انعقاد الخصومة، إلى حين صدور الحكم فيها، وسواء قبل قفل باب المرافعة أو بعده، كما يجوز ولو بعد صدور أحكام متعلقة

(١) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع، ص ٦٧٢- د. الكوني على أعبودة، ص ٣٠٠- د. وجدي راغب فهد، ص ٥٧٤.
والترك لا يعني التنازل عن الحق الموضوعي، وإنما يظل للمدعي الحق فيه، والمطالبة به، فلا يمنع الترك من إعادة المطالبة به بدعوى جديدة، وفي مواجهة نفس الخصم في الدعوى التي تم فيها الترك، فهو لا يتنازل إلا عن مجموعة الإجراءات التي باشرها في سبيل الحصول على الحق، ويظل محتفظا بالحق ذاته رغم الترك.

(٢) د. أحمد هندي، أصول المرافعات، مرجع سابق، ص ٤٣١.

بسير الخصومة أو إثباتها، بل في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ولو أمام محكمة الاستئناف، أو محكمة النقض^(١).

شروط ترك الخصومة:

يشترط لصحة الترك وقبوله، توافر أربعة شروط، هي:

١ - حصوله ممن له الحق فيه:

والترك حق للمدعي فقط^(٢)، فهو صاحب الحق فيه، ولا يجوز من المدعي بطبيعة الحال، إذ هو المواجه بالدعوى، المطالب بالحق، فلا يحق له تركها، وإنما يجوز ذلك للمدعي فقط، شريطة أن يعبر عن إرادته في الترك، لأن هذا التعبير هو الذي يدل على رغبته في التخلي عن الخصومة والتنازل عنها.

والترك كتصرف قانوني إجرائي، يلزمه إرادة صحيحة، فلا يجوز ممكن تعيبت إرادته بعيب من العيوب، ولا ممن ليس أهلا له؛ إذ يجب في التارك توافر الأهلية للتقاضي، كما يجب أن تكون هذه الإرادة دالة على الرغبة في الترك دون قيد أو شرط؛ إذ لا يصح أن يكون الترك معلقا على شرط أو مقرونا بأي تحفظ.

كما يجب صدوره من المدعي نفسه، أو ممن فوضه في ذلك تفويضا خاصا؛ إذ هو من التصرفات القانونية التي اشترط المشرع لها تفويضا خاصا (مادة ٧٦)، فلا يغني عنه التوكيل العام بالخصومة. ويجوز للولي أو الوصي ترك الخصومة التي رفعها باسم القاصر، وللقيم كذلك ترك الخصومة التي أقامها باسم المحجور عليه.

وإذا عبر المدعي عن إرادته بترك الخصومة، وأراد الرجوع عن ذلك، جاز له ذلك صراحة أو ضمنا، شريطة ألا يكون المدعى عليه قد قبل الترك.

٢ - أن يكون التعبير عن الترك صريحا:

وهذا شرط يراه الفقه القانوني، وإن لم يكن المشرع قد نص عليه صراحة، فإعلان المدعي رغبته في ترك الخصومة يجب أن يتم بشكل صريح، إذ لا مجال للإرادة الضمنية للتارك^(٣). ونرى أن الترك قد يكون صريحا، بإحدى الوسائل التي أوجبها المشرع في المادة (١٤١) مرافعات، وقد يكون ضمنيا، كما في نص المادة (١٢٨) مرافعات؛ إذ جعل المشرع من عدم تعجيل المدعي للدعوى في خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف الاتفاقي قرينة على ترك

(١) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، مرجع سابق، ص ٦٧٦.

(٢) إذا تعلق الترك بخصومة الطعن، فيجب أن يصدر من الطاعن..

(٣) د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ٧٣٩-د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط، ٦٨٤.

الدعوى، فنص على أنه "وإذا لم تعجل الدعوى في الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه". فاتخذ من عدم تعجيل المدعي للدعوى في الميعاد قرينة قانونية على نزوله عنها، وبالتالي تركه إياها^(١).

٣- أن يتم الترك في الشكل الذي أوجبه المشرع:

يجب أن يتم بالشكل القانوني الذي نص عليه القانون، حيث نص المشرع في المادة (١٤١) على طرق الترك، وهي ثلاثة طرق:

- أن يتم الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر.
- أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله، مع اطلاع خصمه عليها.
- إبداء الترك شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها.

٤- أن يقبل المدعى عليه ترك الخصومة:

فقد يكون له مصلحة في استمرار الخصومة، فلم يجعل القانون تركها معلقا في كل الأحوال على محض إرادة المدعي، تفاديا لما قد يضار به المدعى عليه.

وقبول المدعى عليه للترك تصرف قانوني يعلن فيه عن إرادته المنفردة التنازل عن مركزه في الخصومة وعن حقه في التمسك بالسير فيها، ولذلك يجب أن يكون خاليا من عيوب الإرادة، وأن تتوافر في المدعى عليه أهلية التنازل عن هذا المركز القانوني، ولا يشترط للتنازل شكل خاص، فيجوز أن يكون صريحا أو ضمنيا^(٢).

غير أن شرط قبول المدعى عليه للترك، مقيد بقيدين، الأول: أن يكون قد أبدى طلباته في الخصومة، فإن لم يكن أبداها؛ فلا يشترط قبوله. والثاني: ألا يكون قد أبدى طلبا أو دفعا يقصد من ورائه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى، كالدفع بعدم اختصاصها، أو بالإحالة، أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو اعتبارها كأن لم تكن، فإن كان شيء من ذلك فلا يشترط قبوله، (مادة ١٤٢).

آثار ترك الخصومة:

لا تحكم المحكمة بالترك إلا إذا تحققت من توافر شرطه، فإذا تحققت من ذلك، حكمت به، وحكمها في ذلك حكما تقريريا وليس منشئا، كما أسلفنا القول، وهذا يعني أن ترك الخصومة يرتب آثاره من وقت تحقق شروطه، لا من وقت الحكم به.

(١) للمؤلف، نظرية القرائن، مرجع سابق، ج ١/٤٩٨.

(٢) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٥٧٧.

وقد نص المشرع على هذه الآثار في المادة (١٤٣) مرافعات، بنصه على أنه "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".

ووفقا لذلك فإن آثار الترك، تتشابه مع آثار سقوط الخصومة، وتتمثل في الآتي:

- ١- إلغاء جميع إجراءاتها، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها، فتعود العلاقة بين الخصوم إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى.
 - ٢- سقوط جميع الطلبات العارضة التي تقدم بها المدعي أو المدعى عليه.
 - ٣- سقوط الدفوع المقدمة من المدعي أو المدعى عليه أثناء سير الدعوى.
 - ٤- يتحمل المدعي مصاريف الخصومة، تأسيسا على أنه رافعها، وليس على خسارتها.
- ويراعى في ذلك ما نص عليه المشرع في المادة (٧١) مرافعات، من أنه إذا كان ترك الخصومة قد وقع في الجلسة الأولى لنظر الدعوى، فلا يستحق على الدعوى إلا ريع الرسم المسدد.
- ٥- يترتب على ترك الخصومة في الاستئناف، زوال صحيفة الاستئناف، وكافة الإجراءات التي اتخذت أمام محكمة الاستئناف. غير أن ترك خصومة الاستئناف لا يمنع بحسب الأصل من رفع استئناف جديد، ما لم يكن الحق في الاستئناف قد سقط بزول صاحبه عنه، أو بفوات ميعاده^(١).

وتجب الإشارة إلى أن الترك لا يمس الحق المدعى به، فيبقى قائما، وتجوز المطالبة به، رغم ترك الخصومة، بدعوى مبتدأة، ما لم يكن قد انقضى بسبب آخر، كالتقادم. كما لا يؤثر الترك في الأحكام القطعية التي صدرت في الخصومة قبله، فهذه تبقى ولا تسقط به، إلا إذا قصد التارك التنازل عن الخصومة وما صدر فيها من أحكام قطعية، فيترتب على ذلك اعتبار الخصومة كأن لم تكن بما صدر فيها من أحكام قطعية^(٢).

قابلية الترك للتجزئة:

ترك الخصومة يقبل التجزئة، فإذا تعدد المدعون في خصومة جاز لبعضهم تركها، فتتقضي بالنسبة إليهم، وتظل قائمة بالنسبة إلى البعض الآخر، فالخصومة في الترك تقل التجزئة متى كان موضوعها قابلا للتجزئة بطبيعته^(٣)، وينصرف أثر الترك إلى التارك ومن حصل التنازل في

(١) د. رمزي سيف، مرجع سابق، ص ٦٠٦.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع، مرجع سابق، ص ٧٢١.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٤٧١/٣.

مواجهته، وتظل الخصومة قائمة بالنسبة لباقي الخصوم الأصليين، وبالنسبة لمن تدخل فيها على التفصيل الآتي:

- إذا كان التدخل انضماميا، مقتصرًا على مجرد تأييد أحد طرفي الخصومة الأصليين، فإن ترك الخصومة يستتبع سقوط التدخل^(١)، ولو لم يقبله المتدخل.
 - أما إذا كان التدخل اختصاميا، يطالب المتدخل فيه لنفسه بحق في مواجهة طرفي الخصومة، فإن ترك الخصومة الأصلية لا يؤدي إلى انقضاء خصومة التدخل، فتبقى قائمة، مادامت المحكمة مختصة بها من جميع الوجوه، وكان طلب التدخل مستوفيا شروط قبوله^(٢).
- ترك إجراء من إجراءات الخصومة:

نظم المشرع في المادة (١٤٤) مرافعات، نزول الخصم عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات، بنصه على أنه "إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن"^(٣).

وبمقتضى هذا النص يجوز للخصم، مع بقاء الخصومة قائمة، أن يتنازل عن إجراء فيها، أو ورقة من أوراق المرافعات التي قدمت فيها، وهو ما يعبر عنه بالتنازل الجزئي، فينصرف أثر التنازل إلى الإجراء أو الورقة، وتعتبر كأن لم تكن، وتبقى الخصومة قائمة مرتبة لأثارها. ومثال ذلك: تنازل الخصم عن طلب ندب خبير، أو دفع بتزوير مستند، أو سحب مستند منها، أو العدول عن طلب سماع شاهد، أو تنازله عن إعلان قام به، أو سحب طلب المقاصة القضائية^(٤).

ومثل هذا التنازل جائز من الخصم، أو من وكيله دون اشتراط توكيل خاص، ولا يشترط له شكل معين، كما في التنازل عن الخصومة، وإنما يجوز أن يكون صريحا أو ضمنيا، شفاهة أو كتابة. كما يجوز أمام أي درجة من درجتي التقاضي، فكما يجوز التنازل الجزئي أمام محكمة

(١) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، مرجع سابق، ص ٧٢٢.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفع، مرجع سابق، ص ٧٢٣.

(٣) هذه المادة مطابقة للمادة (٣١١) من القانون السابق، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية عن هذه المادة الأخيرة، أنه "قد تناول القانون الجديد في مادة مستقلة الكلام عن ترك إجراء من إجراءات الخصومة مع بقاءها قائمة، وذلك لينبه إلى الفارق بين هذا الترك وبين ترك الخصومة برمتها وعلى اختلاف الحكم في الحالتين".

(٤) د. أحمد هندي، أصول المرافعات، ص ٤٤١- د. محمود مصطفى يونس، ص ٧٤٧.

الدرجة الأولى، يجوز كذلك أمام محكمة الاستئناف. وهذا التنازل على عكس ترك الخصومة ذاتها، لا يشترط قبوله من الخصم الآخر^(١).

النزول عن الحكم:

خص المشرع النزول عن الحكم القضائي بقاعدة خاصة، تضمنتها المادة (١٤٥) مرافعات، بنصها على أن "النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به".
إذ الحكم وإن كان ورقة من أوراق المرافعات، وكان مقتضى أعمال القواعد العامة في ترك ورقة من أوراق المرافعات، يؤدي إلى التنازل عنه، دون أن يؤثر ذلك على الحق الموضوعي الذي قضى به؛ فإن ذلك أمر لا يستقيم مع طبيعة الحكم وما يجب له من حجية، لذلك خصه المشرع بقاعدة مؤداها أن النزول عنه يستتبع حتما النزول عن الحق الثابت به.

فإذا تنازل الخصم عنه فإنه لا يترتب على ذلك مجرد سقوطه، وإنما أيضا سقوط الحق الثابت به، فتزول الخصومة التي صدر فيها، ويمتنع على صاحب الحق أن يجدد المطالبة به. ونزول الخصم عن الحكم قاصر على ما قضى به هذه الحكم له من حقوق، أما ما قضى به عليه، فلا يشمل التنازل، فيبقى قائما ولا يتأثر بالنزول عن الحكم^(٢)، كما لو تضمن الحكم إلزام المحكوم له بالمصاريف. وإذا تعدد المحكوم لهم فتنازل بعضهم عن الحكم، فإن هذا التنازل لا يؤثر في حقوق المحكوم لهم الآخرين^(٣) وكما يجوز التنازل عن الحكم، يجوز التنازل عن الطعن فيه، شريطة أن يكون صريحا.

(١) وفي ذلك قضت محكمة النقض أن "للخصم النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراق المرافعات، بغير حاجة لنزول الخصم الآخر، وأثر ذلك اعتبار الإجراء كان لم يكن" (الطعن رقم ٢٥٣ لسنة ٦١ قضائية - جلسة ١٩٩٥/١١/٢٠).

(٢) د. رمزي سيف، مرجع سابق، ص ٦٠٧.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٣/٥٣٦.

الباب الثالث

التقاضي بوسيلة العريضة

الدعوى ليست الوسيلة الوحيدة لاقتضاء الحق عن طريق القضاء، وإنما أوجد المشرع إلى جانبها وسيلة أخرى تمكن الشخص من اللجوء إلى القضاء بغير إجراءات الدعوى العادية، وهي وسيلة العريضة. ذلك أن المشرع قدر أن هناك حالات قد يحتاج الشخص فيها إلى تدخل القاضي بمقتضى سلطته الولائية أو القضائية لإصدار أمر في مسألة لا تتطلب سلوك سبيل الدعوى بإجراءاتها العادية. إما لأنها تستوجب اتخاذ إجراء سريع ومباغت للخصم، دون مساس بأصل الحق، وهذا الإجراء لا يتفق وإجراءات الدعوى العادية، وإما لأن الحق المطلوب بها ثابت ومحدد بشكل يغلب معه عدم منازعة المدين فيه وفي استحقاقه، ومن ثم لا تكون هناك حاجة لدعوة هذا الخصم للحضور أمام القاضي وسماع أقواله. ومن هنا أنشأ المشرع نظاما خاصا بهذه المسائل يعد بديلا عن الدعوى بإجراءات المعتادة والتي تحتاج إلى وقت وجهد ونفقات كثيرة، وهو نظام التقاضي بالعريضة.

وذلك بأن يتقدم الخصم إلى القاضي بعريضة يبين فيها مطلوبه وما يستند إليه ويرفق بها المستندات التي تطلبها المشرع في هذه الحالات، فإذا رأى القاضي توافر هذه الشروط أصدر أمره على العريضة في غيبة الخصم الآخر ودون إعلانه، والذي يكون له بعد ذلك التظلم من هذا الأمر.

والأوامر التي يصدرها القاضي نوعان، الأول أوامر تصدر بمقتضى سلطته الولائية وتسمى الأوامر على العرائض، والثاني أوامر تصدر بمقتضى سلطته القضائية وتسمى أوامر الأداء. ونتناول هذين النوعين من الأوامر في فصلين:

الفصل الأول: الأوامر على العرائض.

الفصل الثاني: أوامر الأداء.

الفصل الأول

الأوامر على العرائض

ليست كل القرارات التي تصدرها المحاكم أحكاماً فاصلة في خصومات قائمة أمامها، بل هناك قرارات يصدرها القاضي أو تصدرها المحكمة في ظروف معينة وإجراءات خاصة يرسمها القانون^(١)، تسمى بالأوامر على العرائض، وهي لا تعد أحكاماً قضائية، بل مجرد قرارات تصدرها المحكمة بموجب سلطتها الولائية.

إذ الحماية الولائية صورة من صور النشاط القضائي التي تصدر في شكل الأمر على عريضة، بناء على طلب من صاحب المصلحة دون مواجهة مع الطرف الآخر، بقصد الحصول على إذن من القاضي بعمل أو إجراء قانوني معين أو اتخاذ إجراء تحفظي^(٢).

فكما يتم اللجوء إلى القضاء بوسيلة الدعوى، فإنه قد يتم أيضاً بوسيلة العريضة، ليس لغرض استصدار حكم قضائي، وإنما بغرض استصدار أمر على هذه العريضة، بموجب السلطة الولائية للقاضي، وفي غير مواجهة بين الخصوم^(٣). ويعتبر الأمر على عريضة الصورة العادية التي تصدر فيها أهم الأعمال الولائية التي تقوم بها المحاكم^(٤).

ونتحدث عن الأوامر على العرائض في مبحثين، نتناول في الأول منهما، ماهية الأوامر على العرائض ومجالاتها، وفي الثاني، النظام القانوني للأوامر على العرائض. وذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول

ماهية الأوامر على العرائض ومجالها

يقتضي الحديث عن ماهية الأوامر على العرائض ومجالاتها؛ أن نبين تعريفها وطبيعتها وتمييزها عن الحكم القضائي وأشخاصها (مطلب أول)، ثم نبين صورها (مطلب ثان). وذلك على النحو الآتي:

(١) د. عبد المنعم الشرقاوي، مرجع سابق، ص ٤٩٩.

(٢) د. إبراهيم أمين النفيوي، أصول التقاضي، مرجع سابق، ص ٢٤٢.

(٣) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات، مرجع سابق، ج ٥٠٦/٢.

ذلك أنه إذا كان للقضاة سلطة قضائية تتمثل كقاعدة في إصدار الأحكام واستثناء في أوامر الأداء والتقدير، فإن لهم بالإضافة إلى ذلك سلطة ولائية تتمثل في إصدار الأوامر على العرائض، وهذه السلطة قد تكون سابقة على السلطة القضائية، كما في أوامر حجز التحفظي والوقفي، أو معاصرة لها، كالإعلان في غير الميعاد، أو لاحقة عليها، كأوامر تنفيذ الأحكام، أو مجردة عنها، كالأوامر بصدد المواد الحسبية. (د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٦١١).

(٤) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٩١٨.

المطلب الأول

ماهية الأوامر على العرائض

أولاً: تعريفها:

يمكن تعريف الأوامر على العرائض بأنها القرارات التي تصدر عن قاضي الأمور الوقتية على الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن في شكل عرائض دون أية مواجهة، بقصد الإذن بعمل أو إجراء قانوني معين^(١).

فالأوامر على العرائض وفقاً لهذا التعريف، هي الأوامر التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية بما له من سلطة ولائية، بناء على طلب يقدم من الخصم على عريضة ليصدر القاضي أمره عليها في غيبة الخصوم، دون تسبب، بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي طبيعتها السرعة أو المباغتة، دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه، ولا تحوز حجية الأمر المقضي، ولا يستنفذ القاضي الوقتي سلطته بإصدارها، فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب.

ومثال الأوامر على العرائض: الإذن بإجراء الإعلان أو التنفيذ في غير المواعيد المبينة في المادة (٧) مرافعات، والأمر بإعلان ورقة أو بعدم إعلانها (مادة ٨ مرافعات)، والأمر بإنقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج، أو مد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة (مادة ١٧ مرافعات). وقد نظم المشرع الأوامر على العرائض في الباب العاشر من قانون المرافعات (المواد ١٩٤-٢٠٠)، فتسري أحكام هذه المواد على كافة الأوامر على العرائض، ما لم يقرر القانون أحكاماً خاصة بنوع منها^(٢).

المطلب الثاني

صور الأوامر على العرائض ومجالها

نصت المادة (١/١٩٤) مرافعات على أنه "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى".

ووفقاً لهذا النص فإن المشرع قد حسم الخلاف حول سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة إذا لم يرد نص في القانون بذلك، فلم يجزله ذلك، بالنص على أن الأمر على عريضة لا

(١) د. الكوني على أعبوده، مرجع سابق، ص ٣٨٨.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٩١٩.

يصدر إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر، ومن ثم فلا يجوز للقاضي أن يصدر أمراً على عريضة في حالة لم يرد النص عليها في قانون المرافعات أو في غيره من القوانين.

أولاً: صور الأوامر على العرائض:

إذا كان المشرع قد حدد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة، بالنص على الحالات التي يجوز فيها إصدار هذا الأمر على سبيل الحصر، فإنه لم يورد هذه الحالات في موضع واحد أو في قانون واحد، وإنما وردت في مواضع متفرقة وفي قوانين متعددة، غير أن هذه الأوامر بشكل عام تصدر في صورة من ثلاث صور، على النحو الآتي:

الأولى: إصدار أمر أو إذن من القاضي:

والأمر هو الطلب الجازم بفعل أو كف عن فعل أو اتخاذ تدبير معين عندما يوجد مقتضى لذلك، كالأمر بإعلان ورقة أو بعدم إعلانها (مادة ٨ مرافعات)، والأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي (مادة ٣٠٠ مرافعات)، والأمر باختصاص الدائن بعقارات مدينه (مادة ١٠٨٩ مدني).

أما الإذن، فيتحقق حيث يكون عمل القاضي هو إزالة عائق يمنع صاحب الشأن من اتخاذ إجراء معين أو إبرام تصرف فيلجأ للقاضي ليصرح له بذلك^(١)، كالإذن بإجراء الإعلان أو التنفيذ في غير المواعيد المبينة في المادة (٧) مرافعات، والإذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه (مادة ٢/٣٥٦ مرافعات).

الثانية: التوثيق والتصديق لبعض الإقرارات والتصرفات^(٢):

والتوثيق هو إسباغ الصفة الرسمية على إعلان إرادة الأفراد بمعرفة الموظف العام يعطها الصفة الرسمية لكافة البيانات الواردة بالورقة سواء كانت التزامات أو توقيعات بالإضافة إلى التوثيق (١٠٣) مرافعات. أما التصديق فهو يتضمن صدق التوقيع على الورقة دون مضمونها ومحتوياتها الأخرى، كالأمر بالتصديق على الإشهاد بالنسب.

الثالثة: التعيين:

وهي أوامر للمحافظة على أموال القصر وناقصي أو عديمي الأهلية، من تعيين الأوصياء أو عزلهم أو مراقبتهم، أو الأمر بتعيين من يقوم بالبيع للأسهم والحصص.

(١) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٦٢٣-٦٢٥.

(٢) المرجع السابق، ص ٦٢٣.

ثانيا: مجال الأوامر على العرائض :

مجال أعمال نظام الأوامر على العرائض قاصر على الحالات التي ورد النص عليها في القانون على سبيل الحصر^(١)، وذلك إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة (١٩٤) مرافعات، إلا أنه مما ينبغي بيانه، أن حالات إصدار الأوامر على العرائض لم ترد فقط في قانون المرافعات، وإنما وردت في هذا القانون وفي قوانين أخرى،

المبحث الثاني

النظام القانوني للأوامر على العرائض

المطلب الأول

إجراءات استصدار الأمر على عريضة

أولا: قواعد الاختصاص بشأن طلب الأمر على عريضة:

يختلف الاختصاص بالأمر على العريضة باختلاف حالتين:

الحالة الأولى: الاختصاص بالأمر إذا لم تكن هناك دعوى منظورة أمام القضاء:

يتضح من نص الفقرة الأولى للمادة (١٩٤) مرافعات أن الاختصاص بالأوامر على العرائض في حالة عدم وجود نزاع أمام القضاء، ينعقد لقاضي الأمور الوقفية في المحكمة المختصة، ووفقا لنص المادة (٢٧) مرافعات، فإن قاضي الأمور الوقفية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك، وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضها. فالاختصاص هنا ينعقد لقاضي فرد سواء أكان قاضي المحكمة الجزئية أو رئيس المحكمة الابتدائية، ويعد ذلك مظهرا من مظاهر التبسيط في نظام الأوامر على العرائض^(٢).

(١) ينتقد بعض الفقه (د. أحمد السيد صاوي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٧٥٩) حصر حالات الأوامر على العرائض، ويعتقد في ذلك أن المشرع قد جانبه الصواب بتحديد وحصر الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار أمر على عريضة، لأن ذلك يتنافى مع طبيعة هذه الأوامر التي لا تقبل الحصر، ويصعب سلفا توقع ما قد يجد بعد صدورها نتيجة التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي يمر بها المجتمع، كما أن هذا الحصر يحرم المتقاضين من أسلوب قضائي يسير يواجه مشاكل الحياة العملية المتغيرة، هذا فضلا عن أن هذا التحديد يقلص من دور القاضي في إدارة حركة الدعوى، وهو ما يخالف أحد الاتجاهات الأساسية التي عنى بها المشرع عند صدور قانون المرافعات الحالي رقم ١٣ لسنة ١٩٨٦.

(٢) د. وجدي راغب فهبي، مرجع سابق، ص ٧٠٣.

ويقصد بعبارة المحكمة المختصة الواردة في المادة (١٩٤)، تلك التي تختص نوعياً ومحلياً بنفس نوع المنازعات التي يستصدر الأمر بصددتها، وعلى ذلك تتحدد المحكمة سواء كانت جزئية أو ابتدائية وفقاً لقواعد النصاب أو موضوع الطلب، كذلك يتحدد الاختصاص المحلي وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي الواردة في المواد (٤٩-٦٢).

ويتحدد الاختصاص النوعي بنظر الأمر على عريضة وفقاً للقواعد العامة المقررة بشأن هذا الاختصاص، فإذا كان موضوع الأمر متعلق بدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية، انعقد الاختصاص بإصدار الأمر للقاضي الجزئي، وإذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة الابتدائية وجب تقديم العريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بها. كما أن الاختصاص القيمي يتحدد وفقاً للقواعد العامة في هذا الشأن، غير أنه قد توجد بعض النصوص التي تقرر اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية بصرف النظر عن قيمة النزاع، كما هو الشأن بالنسبة للدائن الذي يطلب أخذ اختصاص على عقارات مدينه (مادة ١٠٨٩ مدني)^(١).

ويجب مراعاة أنه إذا تعلق الأمر بمسألة من مسائل التنفيذ، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ وليس لقاضي الأمور الوقتية، وذلك إعمالاً لنص المادة (١/٢٧٥) مرافعات، والتي تنص على أنه "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتهما".

الحالة الثانية: الاختصاص بالأمر إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام القضاء:

إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة أمام القضاء، فإن الاختصاص بنظره ينعقد لرئيس الدائرة التي تنظر الدعوى، ذلك إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية، فإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة الجزئية، فإن الاختصاص بنظر الأمر يكون لقاضي الأمور الوقتية بهذه المحكمة على سبيل الانفراد، باعتبار أن هذه المحاكم تشكل من قاضي فرد، وليس من هيئة قضائية يرأسها قاضي^(٢).

وإذا كان الاختصاص واضحاً فيما يتعلق بالأمر على عريضة في دعوى منظورة أمام المحكمة الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية، فإن التساؤل يثور إذا كانت الدعوى منظورة أمام محكمة الطعن، والتي لم يحدد المشرع قاضي الأمور الوقتية بها، ولذلك يجب الرجوع إلى عبارة رئيس الهيئة الواردة بالمادة (١٩٤) وإسناد الاختصاص بالأمر إلى رئيس الهيئة التي تنظر الطعن^(٣).

(١) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٦٢٨.

(٢) د. نبيل اسماعيل عمر، الأوامر على عرائض ونظامها القانوني، مرجع سابق، ص ٩٦.

(٣) المستشار. سيد حسن البغال، المطول، مرجع سابق، المجلد الأول، ص ٧٨٥.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد يرد النص بتحديد الاختصاص بإصدار الأوامر على العرائض في نصوص خاصة، سواء في قانون المرافعات أو قانون آخر، كالاختصاص بإصدار الأمر التحفظي الذي يسبق أمر الأداء، فإنه يصدر من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء بدلا من قاضي التنفيذ أو من قاضي الأمور الوقفية على وجه العموم، وفي مثل هذه الحالات يجب احترام النص الخاص في النطاق الوارد به^(١).

ثانيا: تقديم العريضة وإصدار الأمر :

تتضمنت المادة (٢/١٩٤) مرافعات إجراءات تقديم العريضة والبيانات التي يجب أن تشمل عليها، فنصت على أن يقدم الطلب في شكل عريضة من نسختين متطابقتين إلى القاضي المختص. ويجب أن تشمل العريضة على بيانات محددة، وهي:

١- بيانات أطراف الطلب: وهذا البيان وإن لم يرد النص عليه صراحة إلا أنه يفهم بداهة من مجمل النصوص الواردة في باب الأوامر على العرائض، ومن اشتراط البيان الخاص بتحديد موطن مختار للطالب^(٢).

٢- وقائع الطلب وأسانيده: فيجب أن تشمل العريضة على موضوع الطلب وأسبابه، أي الأساس القانوني الذي يؤسس عليه الطالب طلبه.

٣- موطن مختار للطالب: وذلك بأن يذكر الطالب موطنه مختارا له في البلدة التي بها مقر المحكمة، فإذا كان موطنه الأصلي في هذه البلدة، فإنه يكفي ذكره، فإذا أغفل ذكر هذا البيان، كان للمطلوب ضده أن يعلنه في قلم كتاب المحكمة (مادة ١٢).

ويجب أن ترفق بالعريضة، فضلا عن تضمينها هذه البيانات، المستندات المؤيدة لها. ويعتبر الطلب قد قدم بتسليمه إلى قلم كتاب محكمة القاضي المختص دون حاجة إلى إعلانه للطرف الآخر، لأن الطلب يقدم وينظر في غيبته لعدم اشتراط المواجهة^(٣).

إصدار الأمر:

ينظر القاضي طلب استصدار الأمر على عريضة في غرفة المشورة، في غيبة الأطراف، وفي غير مواجهة، وفي غير جلسة، إذ لا يدعو الطالب من يريد استصدار الأمر عليه للحضور أمام قاضي الأمور الوقفية لسماع دفاعه، بل إن القانون يحرص في بعض الأحوال على أن يصدر الأمر على العريضة في غيبة الخصم وأن يكون تنفيذه مفاجئا له، حتى لا يستطيع أن يهرب أمواله، كما

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق، ص ٩٧.

(٢) د. الكوني على أعبوده، مرجع سابق، ص ٣٩٦.

(٣) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٦٣٠.

هو الشأن في الأمر بتوقيع حجز تحفظي على منقولات المستأجر بالعقار لمصلحة المؤجر استيفاء للأجرة^(١). كما لا يشترط في نظر الطلب حضور كاتب المحكمة، لأن حضوره لا يطلب إلا في الجلسات، والطلب هنا ينظر في غير جلسة^(٢).

ويتمتع القاضي في نظره للعريضة بالسلطة التقديرية الكاملة في قبول المطلوب كلياً أو جزئياً أو رفضه، حسب ما يظهر له من وقائع الطلب وأسبابه وأدلة الإثبات المقدمة من الطالب، على أنه يجب على القاضي عند قبول الطلب أن يستظهر رجحان وجود الحق أو المركز القانوني الذي يتعلق به الأمر المراد إستصداره، وأن يكون المطلوب مجرد اتخاذ إجراء وقفي أو تدبير تحفظي، لا يمس أصل الحق^(٣).

ويجب على القاضي أن يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة، سواء بقبول الطلب كلياً أو جزئياً أو برفضه، دون أي تحقيق حول وجود المركز القانوني أو الحق الموضوعي الذي يتصل به الأمر، ومعنى وجوب صدور الأمر كتابة أنه لا يجوز للقاضي إصداره بشكل شفهي بل لابد أن يكون مكتوباً^(٤). وتحفظ النسخة المدون عليها الأمر بقلم الكاتب، بينما تسلم النسخة الثانية من العريضة إلى طالب الأمر بعد أن تكتب عليها صورة الأمر.

ميعاد إصدار الأمر:

أوجبت المادة (١٩٥) مرافعات على القاضي أن يصدر أمره على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، وهذا الميعاد ميعادا تنظيميا لا يترتب على مخالفته أي بطلان أو سقوط، غير أن المشرع استهدف بهذا الميعاد حث القاضي على الإسراع في إصدار الأمر، حتى لا تفوت الفائدة من إصداره.

تسبب الأمر:

الأصل في الأوامر على العرائض عدم تسببها، إذ لا يلزم تسبب الأمر الصادر على العريضة، حيث نصت المادة (٢/١٩٥) على أنه "ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر آخر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً"^(٥).

(١) د. عبد المنعم الشرقاوي، شرح المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص ٥٠١.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٩٢٠.

(٣) نقض: الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٥٣ قضائية - جلسة ١٩٨٧/١٢/٢١ م.

(٤) د. عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص ١٧١.

(٥) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٩٢٠.

ووفقا لهذا النص فإن قاضي العرائض غير ملزم بذكر أسباب الأمر الذي يصدره، إذا كان هذا الأمر هو الأول بالنسبة للطالب، وليس معنى كونه غير ملزم بالتسبيب بطلان الأمر إذا قام القاضي بتسبيه، فهو حر في ذلك، غير أنه يلزم تسبيب الأمر إذا كان مخالفا لأمر آخر سبق صدوره، فتسبيب الأمر الثاني أمر لازم طالما صدر مخالفا للأول^(١).

تسليم نسخة العريضة للطالب:

يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر (مادة ١٩٦ مرافعات). والمقرر أن هذا الميعاد ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان^(٢).

ثالثا: آثار الأمر على عريضة:

لا يستنفذ الأمر على عريضة سلطة القاضي الذي أصدره، فيجوز له دائما تعديله أو تغييره أو إصدار أمر جديد مخالف للأمر السابق، شريطة عدم المساس بحقوق الغير حسن النية وأن يكون الأمر الثاني مسببا^(٣). كما أن الأمر الصادر على عريضة لا يحوز حجية الأمر المقضي، ومن ثم يجوز للخصم طلب إصدار أمر جديد في ذات الموضوع، كما يجوز عرض النزاع الذي صدر فيه الحكم على محكمة الموضوع لتفصل فيه بقضاء جديد غير مقيدة بما تضمنه الأمر الصادر من القاضي الأمر.

رابعا: النفاذ المعجل للأمر على عريضة:

وفقا لنص المادة (٢٨٨) مرافعات، فإن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أي كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم، أو الأمر على تقديم كفالة.

خامسا: سقوط الأمر:

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد (مادة ٢٠٠ مرافعات). ويستثنى من ذلك الأوامر على العرائض التي ينص القانون على عدم سقوطها، ومثالها، أمر تقدير المصاريف (مادة ١٨٩ مرافعات).

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، الأوامر على عرائض ونظامها القانوني، مرجع سابق، ص ١٢٦.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٤/٤٠.

(٣) نقض: الطعن رقم ١٠٦٥ لسنة ٥٣ قضائية - جلسة ١٢/٢١/١٩٨٧م.

المطلب الثاني

الطعن في الأوامر على العرائض

الطعن في الأوامر على العرائض مقرر بموجب المواد (١٩٧-١٩٩) مرافعات، وطرق الطعن التي قررتها هذه المواد للطعن في الأوامر على العرائض، هي التظلم، والاستئناف.

الفرع الأول

التظلم من الأوامر على العرائض

أجاز المشرع رفع التظلم من الأمر على العريضة إلى المحكمة المختصة (مادة ١٩٧)، أو تبعا للدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظرها (مادة ١٩٨)، أو أمام القاضي نفسه الذي أصدر الأمر المطعون فيه (مادة ١٩٩). ونبين ذلك فيما يلي:

أولاً: التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة:

وفقا للمادة (١٩٧) مرافعات، يجوز التظلم من الأمر الصادر على عريضة، إلى المحكمة المختصة (إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك)، وتتحدد هذه المحكمة بأنها المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي صدر الأمر تمهيدا له أو بمناسبته، فقد تكون هي المحكمة الجزئية أو الابتدائية بحسب ما إذا كان الأمر صادرا من قاضي المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور الوقفية بالمحكمة الجزئية في حدود اختصاصه^(١).

يستوي في ذلك أن يكون المتظلم من الأمر هو الطالب (الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا)، أو من صدر ضده الأمر، أو الغير الذي أضر من الأمر، فلا يمتنع الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ووفقا للمادة (١٩٧) يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أمامها التظلم، غير أن المشرع أوجب هنا أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا، فيجب على المتظلم أن يضمن التظلم الأسانيد التي يستند إليها بأسباب واضحة. فيتعين أن ينطوي التسبب على أسباب واضحة ومحددة يبين فيها المتظلم أوجه تظلمه وأسانيده وما يأخذه على الأمر من الناحية القانونية والموضوعية، ولا يكفي في هذا الصدد ذكر عبارات عامة، تصلح لكل تظلم كأن يقال أن الأمر صدر على خلاف القانون أو صدر مجحفا بحقوق المتظلم^(٢).

(١) د. نبيل اسماعيل عمر، الأوامر على عرائض ونظامها القانوني، مرجع سابق، ص ١٥٦.

(٢) المستشار. عز الدين الدناصوري، وأحمد عكاز، مرجع سابق ص ٧٦٩.

هذا ويعتبر التظلم في هذه الحالة خصومة بالمعنى الصحيح، فيجوز تقديم طلبات عارضة فيها وتعديل الطلبات والتدخل والإدخال وغير ذلك، شأنه في ذلك شأن أية دعوى أخرى^(١).

ميعاد التظلم من الأمر على عريضة :

حدد المشرع ميعاد التظلم من الأمر على عريضة في المادة (١٩٧) مرافعات، بأن جعله عشرة أيام (يضاف إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة ١٦ مرافعات عملاً بالقواعد العامة) ويسرى هذا الميعاد على التظلم أياً كانت الجهة التي تنظره، وقد نص المشرع على ثلاث حالات يبدأ ميعاد التظلم عند أي منها، وهذه الحالات هي^(٢):

- ١- تاريخ صدور الأمر برفض الطلب: والمتظلم هنا بطبيعة الحال هو الطالب الذي رفض طلبه، ومن ثم يسري الميعاد في حقه من تاريخ صدور الأمر برفض طلبه.
 - ٢- تاريخ البدء في تنفيذ الأمر: وهذا الميعاد يسري في حق من صدر الأمر ضده، والغير الذي أضره صدور الأمر.
 - ٣- تاريخ إعلان الأمر الصادر على عريضة.
- وللمحكمة التي تنظر الأمر، أن تحكم بإصداره في حال سبق رفضه، أو تحكم بتأييد الأمر السابق صدوره، أو تعدل هذا الأمر وفق ما يتراءى لها، أو تحكم بإلغائه.

ثانياً: التظلم من الأمر تبعاً للدعوى الأصلية:

وفقاً لما قرره المادة (١٩٨) مرافعات، فإنه يجوز للمتظلم من الأمر الصادر على العريضة، بدلاً من رفع تظلمه إلى المحكمة المختصة، كما في الحالة السابقة، أن يرفع هذا التظلم إلى تبعاً للدعوى الأصلية، أي أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية التي صدر الأمر بمناسبتها أو تمهيداً لها، وفي أية حالة تكون عليها الإجراءات، ولو أثناء المرافعة بالجلسة.

ثالثاً: التظلم من الأمر لنفس القاضي الأمر:

يجوز المشرع لذوي الشأن، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة، الحق في التظلم من الأمر إلى القاضي الأمر نفسه، ولا يحول دون ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة المختصة. ويرفع التظلم إلى القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي بصحيفة تودع قلم الكتاب، تعلن إلى الخصم ويتم تكليفه بالحضور، ويجب أن تشتمل الصحيفة على الأسباب التي بني عليها التظلم وأسانيده، فضلاً عن البيانات التي أوجبها المشرع في صحف الدعاوى. ولا يحول

(١) د. أحمد مليجي، الموسوع الشاملة، مرجع سابق، ج ٤٤/٤.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوع الشاملة، مرجع سابق، ج ٤٢/٤.

دون التظلم بهذه الطريقة قيام النزاع الأصلي أمام المحكمة المختصة به، فقيام النزاع أمام المحكمة المختصة لا يمنع اختصاص القاضي الأمر بنظر التظلم^(١).

ولا تقتصر سلطة القاضي الأمر في نظر التظلم على تأييد الأمر أو الغائه وإنما يملك تعديل الأمر السابق صدوره وفقا لما يترأى له في نظر التظلم من الأمر السابق صدوره، والقرار الصادر منه في التظلم لا يعتبر أمرا جديدا، وإنما يعد حكما يخضع لطرق الطعن في الأحكام.

الفرع الثاني

استئناف الحكم الصادر في التظلم

وفقا لهذا النص المادة (١٩٩): فإن الحكم الصادر في التظلم يعتبر حكما صادرا من المحكمة التي يتبعها القاضي الأمر، وإن كان يحوز حجية مؤقتة، وبالتالي فإنه يقبل الطعن بالاستئناف تبعا لنصاب الاستئناف، إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، أو إلى محكمة الاستئناف، تبعا لما إذا كان القاضي الأمر المتظلم أمامه هو قاضي الأمور الوقفية بالمحكمة الجزئية أو بالمحكمة الابتدائية^(٢). ويلاحظ في هذا الشأن^(٣):

- ١- إذا كان الأمر على العريضة يعتبر أمرا وقتيا، فإن الحكم الصادر في العريضة يعد أيضا حكما وقتيا، ولذا يجوز الطعن فيه بالاستئناف مهما كانت قيمة الطلب، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- ٢- أن الحكم الصادر في التظلم من المحكمة أو من القاضي يعتبر صادرا من المحكمة التابع لها هذا القاضي، فإذا كان قاضيا للأمور الوقفية بالمحكمة الابتدائية فإن الطعن بالاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف العالي. وإذا كان قاضيا بالمحكمة الجزئية فإن الاستئناف يكون أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.
- ٣- ميعاد الطعن بالاستئناف خمسة عشر يوما تبدأ كقاعدة عامة من تاريخ صدور الحكم، ويرفع الاستئناف بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف.
- ٤- يجوز طلب وقف نفاذ الحكم في التظلم باعتباره حكما مستعجلا أمام محكمة الاستئناف.
- ٥- الحكم الصادر من محكمة الاستئناف حكما نهائيا يحوز قوة الأمر المقضي ويحوز القوة التنفيذية التي تقتضي تنفيذه نفاذا عاديا، أي الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وسبق إجراء مقدمات التنفيذ (المواد ٢٨٠ وما يليها من قانون المرافعات).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٤/٥٤.

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ج ٤/٥٥.

(٣) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٦٣٨-٦٣٩.

الفصل الثاني

أوامر الأداء

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره، أو كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، فإن الخصم لا يسلك طريق الدعوى للمطالبة بالحق، وإنما يلجأ إلى القاضي لاستصدار أمر أداء بهذا الحق.

وفكرة نظام أوامر الأداء تتمثل في أنه إذا كان الأصل ألا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى ترفع إلى القضاء بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة، يطرح فيها المدعي طلباته وأسانيدها في مواجهة خصمه، بقصد الحصول على حكم ينهي النزاع على الحق. إلا أن المشرع قدر بالنسبة لبعض الديون أن تحقيقها لا يحتاج إلى مواجهة بين الطرفين، لأن المدين ليس لديه ما يعارض به في ادعاء الدائن، لثبوت الدين بالكتابة، ومن ثم فإن تكليف الدائن برفع دعوى للمطالبة بالحق بالإجراءات المعتادة فيه من البطء والتعقيد ما لا داعي له بالنسبة لهذه الحقوق الواضحة، فاستحدث نظام أوامر الأداء لما يتميز به من السرعة واليسر في استيفاء هذه الديون.

فعلى الدائن في هذه الحالات إذا شاء اقتضاء حقه أن يتقدم إلى القاضي المختص بعريضة يبين فيها طلباته وأسانيدها، ويرفق بها ما يثبت تكليف المدين بالوفاء، فإذا رأى القاضي أن يجيب الطالب إلى كل طلباته، أصدر أمره بالأداء المطلوب^(١).
ونبين ماهية أوامر الأداء ونظامها القانوني في مبحثين على النحو الآتي:

المبحث الأول: ماهية أوامر الأداء ومجالها.

المبحث الثاني: النظام الإجرائي لأوامر الأداء.

(١) المستشار. فتح الله خلاف، أحكام أوامر الأداء، منشأة المعارف بالإسكندرية، ٢٠٠٠م، ص ١٢.

المبحث الأول

ماهية أوامر الأداء ومجالها

نتناول بيان ماهية أوامر الأداء وشروطها في مطلبين، نوضح في الأول منهما ماهية أوامر الأداء من خلال تعريفها وبيان فكرتها، وحكمتها، وتنظيمها التشريعي، وطبيعتها، والتميز بينها وبين الحكم القضائي، وفي الثاني نتناول الشروط التي أوجبها المشرع لإصدار أمر الأداء، والأثر المترتب على توافر هذه الشروط أو عدم توافرها.

المطلب الأول

ماهية أوامر الأداء

أولاً: تعريف أوامر الأداء وحكمتها وتنظيمها التشريعي:

عمد المشرع إلى الأخذ بنظام أوامر الأداء رغبة منه في تيسير الإجراءات والحد من ظاهرة بطء التقاضي، حيث رأى أن هناك طائفة من الديون لا تحتاج إلى الفصل فيها بطريق الدعوى العادية، لأن تحقيقها لا يحتاج إلى مواجهة بين الطرفين، فأنشأ نظام أوامر الأداء بديلاً عن الدعوى بما تستوجبه من تكليف المدعى عليه بالحضور أمام القضاء، وذلك متى كان الدين ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به الدائن ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره، أو كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم.

فنظام أوامر الأداء بهذا الشكل هو نظام استثنائي للقضاء الموضوعي، لا يقتضي اتباع الإجراءات المعتادة للخصومة، بل يستلزم اتباع إجراءات مختصرة شبيهة بنظام الأوامر على العرائض، حيث يصدر الأمر بناء على عريضة تحرر من نسختين متطابقتين يقدمها الدائن أو وكيله إلى القاضي المختص، ويرفق بها سند الدين، وما يثبت حصول التكليف بوفائه، فإذا تحقق القاضي من توافر شروط استصدار الأمر فإنه يصدر أمره على إحدى نسختي العريضة وفقاً للإجراءات التي حددها المشرع.

وإذا رأى من صدر ضده الأمر التظلم منه فعليه أن يقدم تظلمه إلى المحكمة المختصة ابتداء بنظر الدعوى وذلك في الميعاد الذي حدده المشرع، وينظر التظلم وفقاً للإجراءات المعتادة للخصومة^(١).

(١) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٥٥٢.

ويمكن تعريف أمر الأداء بأنه: القرار القضائي الصادر في الموضوع المنصب على ديون محلها نقوداً أو منقولات معينة بالذات أو بالنوع والمقدار متى كانت ثابتة بالكتابة ومعينة المقدار وحالة الأداء وسبق أن كلف الدائن مدينه بالوفاء بها، وهذا القرار القضائي يصدر من قاضي الأداء على عريضة من الدائن لكي يأمر مدينه بأدائه^(١).

وقد حقق نظام أوامر الأداء نجاحاً كبيراً منذ صار واجب الاتباع في الحالات التي أوجب القانون اتباعه فيها، حيث تدل الإحصائيات على أن الغالبية العظمى من طلبات أوامر الأداء قد قبلت ولم يتم التظلم منها إلا في نسبة ضئيلة، كما أن نسبة الأحكام الصادرة في هذه التظلمات بإلغاء الأمر كانت قليلة، ولا شك أن هذا النجاح ترتب عليه سرعة البت في المنازعات وعدم تكدس الجلسات بقضايا لم تكن هناك ضرورة تستوجب عرضها على المحاكم، مما أدى إلى تخفيف العبء عن القضاة^(٢). وحكمة هذا النظام تتمثل في أن هذه الديون (النقود أو المنقولات)، لا يوجد نزاع حول وجودها أو مقدارها يتطلب عرضها على المحاكم بالإجراءات المعتادة للدعوى.

المطلب الثاني

مجال أوامر الأداء

طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء لا يجوز التوسع فيه، ولا يجوز سلوكه إلا إذا توافرت الشروط التي تحدد مجاله، وهي ثلاثة أنواع من الشروط، الأول يتعلق بإثبات الحق، والثاني يتعلق بطبيعة هذا الحق، والثالث خاص بديون الأوراق التجارية^(٣). ونتناول هذه الشروط فيما يلي:

أولاً: الشرط المتعلق بإثبات الحق محل أمر الأداء: ثبوت الحق بالكتابة:

مقتضى المادة (١/٢٠١) مرافعات أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة، أي بورقة عليها توقيع المدين أو امضائه أو بصمة أصبعه، يستوى في ذلك أن تكون هذه الورقة رسمية أو عرفية، مكتوبة بخط المدين أو بخط غيره، باليد أو بالكمبيوتر، باللغة العربية أم بلغة أخرى^(٤).

(١) المرجع السابق، ص ٥٥٣.

(٢) المذكرة الإيضاحية بشأن تعديل المادة (٢٠١) مرافعات بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢م.

(٣) د. الكوني على أعبوده، مرجع سابق، ص ٤٠٦.

(٤) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص ١٤٥ - د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٥٧٢.

ثانيا: الشروط المتعلقة بطبيعة الحق:

الشرط الأول: أن يكون مبلغا من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو بذاته:

فيجب في الحق محل أمر الأداء أن يكون نقوداً أياً كانت قيمتها، أو منقولاً معين بنوعه ومقداره، أو بذاته. والمقصود بكون الحق المطلوب مبلغاً من النقود، أن يكون التزام المدين أي الأداء الذي يجب أن يقوم به لصالح الدائن هو دفع مبلغ من النقود، فإذا كان المدين ملتزماً بأن يؤدي للدائن مبلغاً نقدياً، فإن على الدائن إذا أراد المطالبة بهذا الدين أن يسلك طريق أمر الأداء، مهما بلغت قيمة هذا المبلغ، يستوى أن يكون الدين مدنياً أو تجارياً، كما يستوي أي سبب منشئ للحق، وأياً كان نوع العملة، ومثال ذلك: مطالبة البائع للمشتري بثمن المدين، والمقرض للمقرض بقيمة القرض، والمضروب للمسنول بالتعويض المستحق له، والمؤجر للمستأجر بالأجرة، وغير ذلك^(١).

والمقصود بالمنقول المعين بنوعه ومقداره، أن يكون هذا المنقول من الأشياء المثلية، وهي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة عند التعامل مع الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن (مادة ٨٥ مدني)، ومن ثم فالأشياء المثلية هي التي لها نظائر متماثلة في الأسواق، فلا تتفاوت أحادها تفاوتاً يعتد به، ولذلك يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، كالنقود والكتب من طبعة واحدة والقماش من نوع ولون واحد والحبوب من نفس الصنف والجودة والقطن من نفس الصنف والرتبة^(٢).

والمقصود بالمنقول المعين بالذات، الأشياء القيمية المعينة بالذات والتي تتفاوت أحادها تفاوتاً يعتد به، فلا يقوم غيرها مقامها عند الوفاء، كتسليم سيارة معينة أو لوحة فنية معينة أو غير ذلك، وفي هذه الحالات لا تبرأ ذمة المدين إلا إذا سلم عين المنقول المتفق عليه، فلا يجوز تسليم منقول غيره ولو كان أفضل منه^(٣).

الشرط الثاني: أن يكون حال الأداء:

إذ القاعدة أنه لا تجوز المطالبة قضاء بحق لم يحل أجله، ومن ثم فلا تجوز المطالبة عن طريق أمر الأداء بدين معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل، لأن مثل هذا الحق لا تجوز المطالبة به أمام القضاء^(٤). وشرط حلول الأداء واستحقاق الحق المطلوب شرطاً موضوعياً باعتباره

(١) المستشار. سيد حسن البغال، المطول، ج ١/٨٥١- المستشار، فتح الله خلاف، سابق، ص ٣١.

(٢) المستشار. فتح الله خلاف، مرجع سابق، ص ٣٢.

(٣) المرجع السابق، ص ٣٢.

(٤) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٦٧/٤ - د. محمد مصطفى يونس، سابق، ص ١١٦٨.

لازما لاتباع طريق أوامر الأداء، أي متعلقا بالحق موضوع الأداء، ويترتب على عدم استحقاق الدين امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء وإنما يصدر أمرا بالرفض وتحديد جلسة لنظر الموضوع^(١).

الشرط الثالث: أن يكون الحق معين المقدار:

فإذا كان المطلوب مبلغا نقديا، فيشترط أن يكون مبلغا محددا من النقود، وهو يعتبر كذلك ولو تطلب عملية حسابية بسيطة، وكذلك إذا كان المطلوب منقولاً معيناً فإنه يجب أن يكون معين المقدار سواء بالوزن أو بالكيل أو بالمقاس، فإن لم يكن الحق معين المقدار، فلا يتبع نظام أمر أداء بشأنه، وإنما يجب اتباع طريق الدعوى العادية. وعلة هذا الشرط أن الحق غير معين المقدار قد ينازع المدين في مقداره، وهذه المنازعة تطلب المواجهة بين الخصوم والجوء إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

ثالثا: الشروط الخاصة بديون الأوراق التجارية:

وفقا لنص المادة (٣/٢/٢٠١) مرافعات، فإن أحكام أوامر الأداء تتبع أيضا إذا كان صاحب الحق دائما بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى. ومن ثم فإنه يشترط لاتباع أمر الأداء وفقا لهذه الحالة توافر شرطين^(٢):

- ١- أن يكون صاحب الحق دائما بورقة تجارية.
- ٢- أن يقتصر رجوع الدائن على المدين الأصلي، حيث قصر المشرع حق رجوع الدائن على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، باعتبار أن الساحب هو المدين الأصلي بقيمة الشيك أو الكمبيالة إذا لم يقبلها المسحوب عليه، كما أن المحرر هو المدين الأصلي في السند الإذني وكذلك الحال بالنسبة للمسحوب عليه القابل والضامن الاحتياطي للمدين فهو يعد في مركز المدين.

أثر توافر شروط أوامر الأداء:

سلوك طريق أمر الأداء لم يعد اختياريا لصاحب الحق، بحيث يختار إذا شاء بينه وبين سبيل الدعوى العادية إذا أراد اقتضاء حقه، وإنما هو طريق إجباري، يجب على الدائن الالتجاء إليه إذا أراد اقتضاء حقه متى توافرت فيه شروط أمر الأداء.

(١) المستشار. سيد حسن البغال، المطول، المجلد الأول، مرجع سابق، ٨٦٣.

(٢) المستشار. فتح الله خلاف، مرجع سابق، ص ٥٤.

غير أن اتباع طريق أوامر الأداء لا يجب -عند تحقق شروطه- إلا حين تكون المطالبة بالحق ابتداء وفقاً لما نصت عليه المادة (٢٠١) مرافعات، بقولها، استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية. ومن ثم فهذا الطريق لا يكون وجوبياً على الدائن إلا إذا أراد المطالبة بالحق ابتداء، فلا يجوز له المطالبة به بطريق الدعوى العادية، بل يلزم باتباع طريق أمر الأداء.

والسبب الذي دفع المشرع إلى اعتبار هذا الطريق إلزامياً على طالب الحق، هو الرغبة في إشاعة هذا النظام من ناحية، ومن ناحية أخرى رغبته في التخفيف عن المحاكم، بالحد من دعاوى لا توجد ضرورة لرفعها، لثبوت الحق فيها وإمكانية اقتضائه بطريق يسير وبإجراءات مبسطة وأقل كلفة وفي وقت أسرع.

ويتربط على اعتبار طريق أمر الأداء وجوبياً حين تتحقق شروطه، عدم قبول الدعوى التي ترفع للمطالبة بحق يجب استصدار أمر أداء به، أما إذا توافرت شروط استصدار أمر الأداء، ولكن المطالبة به لم تكن بصورة مبتدأة وإنما كانت في صورة طلب عارض في دعوى مرفوعة أمام القضاء، فإن ذلك يكون جائزاً.

المبحث الثاني

النظام الإجرائي لأوامر الأداء

المطلب الأول

الاختصاص بنظر الطلب وإجراءاته والفصل فيه

أولاً: الاختصاص بنظر طلب أمر الأداء وإجراءاته:

أ- الاختصاص الولائي بنظر طلب أمر الأداء: القاضي المختص بنظر أمر الأداء يعتبر فرعاً من جهة القضاء العادي، ومن ثم فإنه يختص وظيفياً بنظر طلبات استصدار أمر الأداء في كل حالة يثبت فيها الاختصاص للقضاء العادي، سواء نص القانون على ذلك صراحة، أم لا، لعدم توافر شروط اختصاص القضاء الإداري.

ومن ثم فإن نظام أوامر الأداء لا يسري على النقود التي تكون المطالبة بها من اختصاص القضاء الإداري، ولو توافر في الدين شروط استصدار أمر الأداء، وعلى الدائن حينئذ أن يطالب بحقه برفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة^(١).

(١) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٤/٨٧.

ب- الاختصاص القيمي بنظر الطلب:

يتضح من نص المادة (٢٠٢) مرافعات أن قواعد الاختصاص القيمي التي تطبق على الدعاوى العادية، هي ذات القواعد التي تطبق على الاختصاص بنظر طلب أمر الأداء، حيث قضت هذه المادة بأن أمر الأداء يستصدر من قاضي المحكمة الجزئية التابع لها موطن المدين، أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال.

ومن ثم ينظر إلى قيمة الحق المطلوب استصدار أمر أداء به، فإذا كان لا يجاوز أربعين ألف جنهما، اختص به قاضي المحكمة الجزئية، وإذا كان يزيد عن ذلك فينقل الاختصاص لرئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية.

ج- الاختصاص النوعي بنظر الطلب:

يراعى في تحديد الاختصاص النوعي بنظر طلب أمر الأداء، القواعد التي قررها المشرع بشأن تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية، فيختص القاضي الجزئي بنظر طلبات أمر الأداء عن المسائل التي تختص بها نوعياً المحكمة الجزئية ولو زادت قيمتها عن اختصاصها القيمي. فمثلاً يختص القاضي الجزئي نوعياً بإصدار أمر الأداء إذا تعلق بالمطالبة بالأجور والمرتبات وفقاً للبند ٤ من المادة (٤٣) ولو زادت قيمة الحق عن الاختصاص القيمي له. وكذلك يراعى الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بنظر بعض المسائل ولو كانت قيمتها أقل من اختصاصها القيمي، فيختص رئيس الدائرة بنظر طلبات أمر الأداء عنها^(١).

وقواعد الاختصاص القيمي والنوعي لنظر طلب أمر الأداء من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وعلى القاضي إذا تبين عدم اختصاصه بنظر الأمر أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسته لنظر الدعوى أمام المحكمة، مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها^(٢).

د- الاختصاص المحلي بنظر طلب أمر الأداء:

أخضع المشرع أوامر الأداء للقواعد العامة بشأن الاختصاص المحلي، ومن ثم ينقل الاختصاص المحلي بنظر طلب استصدار الأمر لمحكمة موطن المدين، ما لم ينص القانون أو يتفق الخصوم على غير ذلك.

ومن ثم فإنه يجوز للخصوم الاتفاق على اختصاص محكمة أخرى بنظر الطلب غير محكمة موطن المدين، وذلك لعدم تعلق قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام.

(١) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٥٨٠-٥٨١.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، مرجع سابق، ص ١٦٦.

ثانياً: إجراءات طلب أمر الأداء:

تضمنت المادة (٢٠٣) في فقرتها الأولى والثانية إجراءات طلب أمر الأداء، وذلك بنصها على شروط وبيانات عريضة أمر الأداء ومرفقاتها، ووضح من النص السابق ذكره أن إجراءات طلب أمر الأداء تبدأ بتكليف المدين بالوفاء في ميعاد محدد، ثم يلي هذا التكليف تقديم عريضة استصدار أمر الأداء إلى القاضي شريطة أن تكون مستوفية لشروطها وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها. ونتناول ذلك فيما يلي :

أ- تكليف المدين بوفاء الدين:

أوجبت المادة (٢٠٢) مرافعات على الدائن أن يكلف مدينه بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء. ومعنى تكليف المدين بالوفاء هو دعوته من قبل الدائن أن يفي بالدين الذي حل أجله. فالدائن هو المكلف باتخاذ هذا الإجراء، سواء قام به بنفسه أو قام به وكيله وهو إجراء واجب عليه لا يجوز استصدار الأمر دون القيام به، والمدين هو المخاطب بمقتضى هذا التكليف بوفاء الدين الذي حل أجله.

ولم يشترط القانون حصول التكليف بالوفاء بموجب إنذار على يد محضر وإنما يكفي في ذلك أن يحصل التكليف بكتاب مسجل مع علم الوصول، شريطة أن يكون لدى الدائن الإيصال الدال على تسلم الخطاب في موطن مدينه منه أو ممن يمثله^(١). إذ لا يمكن إثبات حصول التكليف بالوفاء إلا بإبراز علم الوصول المشتمل على توقيع المستلم^(٢). وليس هناك ما يمنع من حصول التكليف بالوفاء على يد محضر وفي هذه الحالة يكون أصل الإعلان دليل حصوله^(٣)، بل يستصوب البعض^(٤) ذلك، لأنه كثيراً ما يتأخر تسليم الدائن مرسل الخطاب، الكتاب المسجل مع علم الوصول إلى وقت قد يستطيل كثيراً مما يعطل إمكانية التقدم بطلب استصدار أمر أداء نظراً لوجوب تقديم علم الوصول مع سند الدين رفق عريضة طلب الأداء.

وفقاً لما قرره المشرع في المادة (٢/٢٠٢) مرافعات، فإن بروتستو عدم الدفع يقوم مقام التكليف بالوفاء، ذلك أن المادة (١٦٢) من القانون التجاري السابق تلزم حامل الورقة التجارية بعمل البروتستو لإثبات الامتناع عن الدفع.

(١) د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٨٣٧.

(٢) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، مرجع سابق، ص ١٥٨-١٥٩.

(٣) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، مرجع سابق، ص ١٥٩.

(٤) المستشار. سيد حسن البغال، المطول، المجلد الأول، مرجع سابق، ص ٨٧٢.

منازعة المدين في صحة الدين:

نتفق مع ما ذهب إليه بعض الفقه^(١) من أنه إذا أجاب المدين على تكليف دائنه، منازعا في صحة الدين أو ثبوته أو قدره، امتنع استصدار الأمر، ووجب على الدائن حينئذ رفع دعوى بالإجراءات المعتادة، ولو كانت منازعة المدين بكتاب موصى عليه، ولأي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدين كله أو بعضه.

ميعاد التكليف بالوفاء:

أوجب المشرع على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل قبل استصدار الأمر (مادة ٢٠٢ مرافعات)، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يكون الميعاد أقل من ذلك، ولا يصح طلب أمر الأداء قبل انقضاء هذا الميعاد بالكامل، لأنه من المواعيد الكاملة.

بيانات التكليف بالوفاء:

لم ينص المشرع على بيانات محددة يجب أن يشتمل عليها التكليف بالوفاء، غير أنه بالنظر إلى اعتبار التكليف بالوفاء دعوة من الدائن إلى المدين بالوفاء بما عليه من التزامات، فإنه يجب أن يشتمل على عدة بيانات تدل على جديته وتحقق الغرض منه:

- ١- تاريخ اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التكليف.
- ٢- اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الدائن والمدين.
- ٣- بيان سند الدين وتاريخ استحقاقه.
- ٤- تحديد محل التزام الدين المطلوب الوفاء به تحديدا نافيا للجهالة.
- ٥- ما يعبر بوضوح عن رغبة الدائن في أن يفي المدين بالتزامه، وعزمه في حالة عدم الوفاء على استصدار أمر أداء بالحق المطلوب^(٢).

ب- تقديم العريضة ومرفقاتها:

يقدم طلب أمر الأداء إلى القاضي المختص بعريضة من نسختين متطابقتين يقدمها الدائن أو وكيله، دون أن تعلن للمدين ودون أن يعلم بها، وتعد بديلا لصحيفة الدعوى، بالنظر إلى أن أوامر الأداء هي إحدى الحالات التي قضى فيها القانون بالخروج على القواعد العامة في رفع دعاوى ابتداء بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة^(٣).

(١) د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، مرجع سابق، ص ١٤٦.

(٢) المستشار. فتح الله خلاف، مرجع سابق، ص ٨١.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج ٩٥/٤ - د. الكوني على أعبودة، مرجع سابق، ص ٤١٣.

ويجب أن تكون العريضة من نسختين متطابقتين، يصدر على أحدهما الأمر، وتسلم الأخرى وعليها صورة الأمر للدائن^(١). وأن تشتمل العريضة على البيانات التي أوجبها المشرع، وهذه البيانات هي: اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، وتعيين موطن مختار للطالب في دائرة اختصاص المحكمة، واسم المدين كاملاً ومحل إقامته. وتاريخ تقديم العريضة لقلم الكتاب، عملاً بما قرره المادة (٦٣) مرافعات، ووقائع الطلب وأسانيده، وذلك بتحديد ما يطلبه الدائن من نقود وبيان أصلها وفوائدها ومصاريدها، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره، وتحديد الوقائع التي يستند إليها في طلبه، ولا يغنى عن ذلك إرفاق سند الدين بالعريضة. وبعد هذا البيان بمثابة الأسباب التي يبني عليها أمر الأداء. ويدخل في مدلول عبارة وقائع الطلب طلب الدائن شمول الأمر بالنفذ المعجل.

وقد أوجب المشرع في المادتين (٢٠٣ و ٢٠٨)، أن ترفق بالعريضة، سند الدين، والمستندات المؤيدة للعريضة، وما يثبت حصول تكليف المدين، وما يدل على دفع الرسم كاملاً. ويترتب على تقديم عريضة أمر الأداء وإيداعها قلم كتاب المحكمة، اعتبار الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها، ومنها قطع التقادم الساري لمصلحة المدين في مواجهة الدائن، وسريان الفوائد التأخيرية في حالة المطالبة بالدين النقدي، كما تترتب عليها كافة الآثار الإجرائية التي تترتب على تقديم صحيفة الدعوى.

ثالثاً: الفصل في طلب أمر الأداء وآثاره:

ووفقاً لنص المادتين (٣/٢٠٣) و (١/٢٠٤) مرافعات، فإنه تجب التفرقة في شأن الفصل في طلب أمر الأداء بين حالتين:

الحالة الأولى: إصدار الأمر:

إذا رأى القاضي أن يجيب الطالب إلى طلبه فإن عليه أن يصدر أمره على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، وهذا الميعاد ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان الأمر الصادر على العريضة^(٢).

وعلى القاضي في هذه الحالة أن يبين المبلغ الواجب أدائه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول معين بذاته أو بنوعه ومقداره، وكذا المصاريف.

(١) ويجب أن تكون العريضة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية إذا كانت مقدمة إلى رئيس الدائرة بها. أما إذا كانت مقدمة إلى قاض المحكمة الجزئية، فيلزم توقيعها من محام إذا كان الحق المطلوب بها يجاوز خمسون جنهما، وفقاً لنص المادة (٥٨) من قانون المحاماة.

(٢) د. رمزي سيف، الوسيط، مرجع سابق، ص ٤٠٥.

ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه، إلا أنه لا يمكنه قبول الطلب بشكل جزئي، إذ تقتصر سلطته في قبول الطلب على إصدار أمره بكل مطلوب الطالب، أما إذا رأى إجابة الطالب إلى بعض طلباته دون البعض الآخر، فإن عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر ويحدد جلسة يكلف الطالب خصمه بالحضور إليها^(١).

الحالة الثانية: الامتناع عن إصدار الأمر:

إذا كانت سلطة القاضي في إصدار الأمر قاصرة على حالة إجابة الطالب إلى كل طلباته، فإنه إذا رأى ألا يجب كل هذه الطلبات فإن عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وعليه حينئذ أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها. وذلك منعاً للقاضي من القضاء برفض بعض طلبات المدين من غير مراعاة^(٢). فليس له أن يجيب الطالب إلى بعض طلباته ويرفض البعض الآخر^(٣). فإذا كان امتناع القاضي سببه عدم اختصاصه أو بسبب عيب شكلي في الطلب، فإن للدائن أن يعيد تقديم طلبه إلى القاضي المختص أو بعد تصحيح الشكل المعيب.

إعلان أمر الأداء وسقوطه:

يجب على الدائن أن يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بعريضة أمر الأداء والأمر الصادر ضده بالأداء، وذلك لإعلامه بمضمون ما ألزمه به الأمر الذي صدر في غيبته، حتى يمكنه الطعن فيه إذا شاء، كما أن إعلان الأمر في الميعاد يحميه من السقوط المنصوص عليه في الفقرة الثانية للمادة (٢٠٥) مرافعات.

وإذا لم يتم إعلان العريضة والأمر الصادر عليها، فإن المشرع رتب على ذلك جزاء يتمثل في سقوط العريضة والأمر معاً، فنص في المادة (٢/٢٠٥) على أنه "وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر.

وبعني اعتبار العريضة والأمر الصادر عليها كأن لم يكونا، أن عدم الإعلان في الميعاد لا يؤدي فقط إلى سقوط الأمر، بل يؤدي إلى سقوط العريضة كذلك، ويزول ما ترتب على العريضة والأمر من آثار، على أن هذا السقوط يجب التمسك به من المدين فليس للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

(١) د. الكوني على أعبوده، مرجع سابق، ص ٣٩٧- د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٥٩٣.

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٧٨٤.

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، سابق، ص ٩٣٩- د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٧١٥.

المطلب الثاني

الطعن في أوامر الأداء

نظم المشرع طرق الطعن في أوامر الأداء في المادة (٢٠٦) مرافعات، فأجاز للمدين الصادر ضده الأمر الطعن فيه بأحد طريقين، الأول، التظلم من الأمر أمام المحكمة الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال، والثاني، استئناف الأمر أمام المحكمة المختصة.

الفرع الأول

التظلم من أمر الأداء

يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر ضده خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه، ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال، وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا (مادة ٢٠٦/٢/١ مرافعات)^(١).

فاللمدن وحده (دون الدائن الذي رفض إصدار الأمر لصالحه) أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة التابع لها القاضي الأمر، وهي المحكمة التي تختص بالدعوى وفقا للقواعد العامة^(٢)، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات التي نص عليه المشرع في المادة (٦٣) مرافعات، كما يجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا (مادة ٢٠٦/٢)، ويقبل التظلم من المدين بصرف النظر عن قيمة الحق أو نوعه، فشرطه الوحيد هو تخلف شرط من شروط إصدار الأمر^(٣)،

وميعاد التظلم من الأمر عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان العريضة والأمر الصادر عليها لشخص المدين أو في موطنه، ويسقط حق المدين في التظلم إذا لم يراعي هذا الميعاد، وعلى المحكمة أن تحكم بعدم قبول التظلم إذا تم بعد الميعاد، ويعتبر ميعاد التظلم مرعيا بإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة ولو تراخى إعلانها إلى ما بعد ذلك^(٤).

(١) حكم بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من قصر الحق في التظلم من أوامر الأداء أو استئنافه على المدين دون الدائن طالب الأمر، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد (٥١) مكرر في ٢٠/١٢/٢٠٠٩ م.

(٢) د. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٦٠٢.

(٣) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٩٤٦.

(٤) نقض: الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٤٣ قضائية - جلسة ١٩٧٧/٦/٧.

ويقوم قلم المحضرين بإعلان صحيفة التظلم إلى المتظلم ضده خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر التظلم جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد، فعندئذ يجب أن يتم هذا الإعلان قبل الجلسة، مع مراعاة مواعيد الحضور.

وتطبق على صحيفة التظلم جميع القواعد والإجراءات المقررة لصحيفة الدعوى بما في ذلك المادة (٧٠) مرافعات المتعلقة بالجزاء على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب^(١).

ولمحكمة التظلم السلطة الكاملة في الفصل في الدعوى، وهي تستطيع أن تؤيد الأمر فيما قضى به من إلزام، أو تؤيده في جزء منه، كما أنها تستطيع أن تلغي الأمر، وهي إذا ألغت الأمر، سواء لعدم توافر شروط الحق أو لأنه باطل لعيب في الإجراءات أو في الأمر نفسه أو لاعتباره كأن لم يكن، فإنها لا تقتصر على الإلغاء، بل عليها أن تصدر حكماً في موضوع الدعوى^(٢).

ويعتبر المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى. وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن (م ٢٠٧ مرافعات).

الفرع الثاني

استئناف أمر الأداء

يجوز الطعن بالاستئناف في أمر الأداء وفقاً للقواعد العامة في الاستئناف، سواء من حيث نصابه أو إجراءاته أو ميعاده، وذلك إذا كان مما يجوز استئنافه، أي حسب قيمة الدعوى أو نوعها التي صدر بشأنها، فلا يجوز استئناف الأمر إذا صدر في حدود النصاب النهائي للمحكمة^(٣).

وعلى ذلك يكون لمن صدر ضده الأمر الخيار، إما أن يتظلم منه، أو أن يرفع استئنافاً عنه إلى المحكمة الأعلى درجة من المحكمة التي أصدر قاضياً الأمر، وتختص بنظر استئناف أمر الأداء الصادر من القاضي الجزئي، المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، كما تختص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الأمر الصادر من رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية^(٤). ويتربط على استئناف أمر الأداء مباشرة سقوط الحق في التظلم منه (مادة ٢٠٦/٤) مرافعات.

(١) نقض: الطعن رقم ٣٣٠ لسنة ٤٧ قضائية - جلسة ١٩٧٩/١/١.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٩٤٧.

(٣) د. محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ١١٨٥.

(٤) د. أحمد مليجي، الموسوع الشاملة، مرجع سابق، ج ٤/١٤٦.

ويخضع استئناف أمر الأداء لميعاد وإجراءات وقواعد استئناف الأحكام، على أنه يلاحظ أن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن (مادة ٣/٢٠٦)، وهذا يعني أنه يجوز استئناف أمر الأداء خلال خمسين يوماً من تاريخ إعلانه للمدين^(١).

وتكون للمحكمة الاستئنافية نفس السلطة التي لها عندما تنظر استئنافاً عن حكم، فلها أن تؤيد الأمر، كما أن لها أن تلغيه، وإذا ألغته فإنها تنظر موضوع القضية، أو لا تنظره وتقتصر على الإلغاء حسب ما إذا كان قاضي الأداء قد استنفد ولايته أو لم يستأنفها^(٢).

(١) د. وجدي راغب فهي، مرجع سابق، ص ٧١٧.

(٢) د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٩٤٨.

الباب الرابع

الحكم القضائي وطرق الطعن فيه

تمهيد وتقسيم :

الحكم هو الحل الذي يعلنه القاضي في نطاق خصومة قضائية متبعا في ذلك شكلية معينة بقصد حسم مركز خلافي ناتج عن تطبيق القانون في الحياة العملية. وتمثل مرحلة إصدار الحكم القضائي المرحلة الأساسية في الخصومة القضائية، لأن الحكم هو خاتمة المطاف في العمل القضائي، وهو قصد المدعي من رفع الدعوى القضائية، وهدف المدعى عليه كذلك من وراء تقديم طلباته ودفعه^(١).

وبشكل الحكم أهم وسائل القضاء في تحقيق وظيفته، وذلك لما يحيط إصداره من ضمانات تجعله عنوانا للحقيقة القانونية بشأن الحقوق والمراكز المطروحة على القضاء، ونظرا لأهمية الحكم القضائي في الدعوى فإن المشرع أحاط إصداره بمجموعة من الضمانات الهامة، والتي تؤدي إلى تحقيق الغاية التي يستهدفها الخصوم من الدعوى، ومن ثم تطبيق القانون وبما يحقق استقرار المراكز القانونية. فالمشرع - مثلا - يشترط في الحكم أن يصدر بعد قفل باب المرافعة وبعد المداولة فيه وفي أسبابه بين القضاة الذين أصدروه، وأن يكون مكتوبا في ورقتين، الأولى هي مسودة الحكم التي يجب أن تشتمل على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين أصدروه، والثانية هي نسخة الحكم الأصلية والتي يجب أن تشتمل على بيانات محددة نص عليها المشرع في المادة (١٧٨) مرافعات، وأن ينطق به في جلسة علنية.

إلا أنه لما كان القاضي لا يسلم من الخطأ شأنه شأن أي إنسان، ولا تسلم نفوس المتقاضين من الضغائن والأحقاد، وكانت الأحكام من أعمال الإنسان التي يرد عليها الخطأ أو السهو ويفسدها الغرض أو الجهل^(٢)، فإن المشرع أتاح للخصوم فرصة الطعن في الحكم لإصلاح العيوب التي تضمنها، وذلك من خلال طرق الطعن التي ورد النص عليها في القانون. ونتناول في هذا الباب بيان ماهية الحكم القضائي، وأقسامه، وقواعد إصداره، ثم الطرق المقررة للطعن فيه، وذلك في فصلين على النحو التالي:

الفصل الأول: الحكم القضائي وقواعده وآثاره.

الفصل الثاني: طرق الطعن في الحكم القضائي.

(١) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ١٨٩ - د. محمود السيد التحيوي: النظرية العامة لأحكام القضاء، دار

الفكر الجامعي ٢٠٠٧م، ص ٢.

(٢) د. أحمد هندي، أصول المرافعات، مرجع سابق، ص ٣٠٧.

الفصل الأول

الحكم القضائي وقواعده وآثاره

الحكم هو الغاية الطبيعية التي يهدف إلى تحقيقها كل خصم بأن يحاول إقناع القاضي بمنحه الحماية القضائية بمقتضاه^(١). و المشرع لا يعترف بالحكم الصادر في الدعوى على أي وجه كان، وإنما لابد لصحة الحكم أن تتوفر أركانه وشروطه وأن يصدر وفق ضوابط معينة، وهو في ذلك ليس ذا طبيعة واحدة، وإنما تختلف طبيعته وفقاً لعدة أقسام، كما يختلف الأثر المترتب عليه بحسب طبيعة الحكم الصادر في الدعوى. ونتناول بيان ماهية الحكم القضائي وأقسامه، ثم قواعد إصداره، وتسبب الأحكام، في ثلاثة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول

ماهية الحكم القضائي وأقسامه

المطلب الأول

ماهية الحكم القضائي

أولاً: تعريف الحكم القضائي:

تعددت تعريفات الحكم القضائي وإن كانت جميعها لا تخرج عن معنى كونه قراراً صادراً من سلطة الحكم للإعلان عن إرادتها في الدعوى المطروحة عليها باعتبارها محكمة تابعة للقضاء تصدره بما لها من سلطة قضائية في خصومة مطروحة عليها بالشكل الذي قرره المشرع.

فالحكم إعلان لفكر القاضي في استعماله لسلطته القضائية، أي كان مضمونه، وأيا كانت المحكمة التي أصدرته، فهو الشكل الإجرائي العام الذي يصدر فيه القرار القضائي^(٢) إلا أنه ليست جميع القرارات الصادرة عن القاضي أحكاماً قضائية، فالقرار الذي يصدر عن القاضي قد يكون حكماً وقد يكون أمراً، ذلك أن للقاضي وظيفتين: وظيفة قضائية يمارسها بما يصدره من أوامر أو قرارات تسمى بالمعنى العام بالأحكام، ووظيفة ولائية أو إدارية، والأوامر التي يصدرها منها ما يعتبر بمثابة حكم كأمر الأداء، لصدوره عن القاضي بموجب سلطته القضائية، ومنها ما لا يعتبر حكماً لصدورها من القاضي بموجب سلطته الولائية، كالأمر على عريضة.

(١) د. أحمد هندي: قانون المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ٤٢٥.

(٢) د. أحمد هندي، قانون المرافعات، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ٤٢٥-٤٢٦.

وينطوي تعريف الحكم على عنصرين: عنصر موضوعي هو أن الحكم قرار صادر في منازعة بين خصمين أو أكثر، وعنصر شكلي وهو أنه يجب مراعات أوضاع وإجراءات معينة عند إصدار الأحكام^(١).

وتتمثل أهمية الحكم في أنه الغاية الطبيعية التي يهدف إلى تحقيقها كل خصم بأن يحاول إقناع القاضي بمنحه الحماية القضائية بمقتضاه، وعندما ينطق القاضي بحكمه فإنه يقرر الحق محل النزاع أو يؤكد أو يعدل في المراكز القانونية للخصوم، فضلا عما يترتب أحيانا على حكمه من إلزام أحد الخصوم بأداء معين أو الامتناع عنه، فالحكم يحقق الغاية الطبيعية للخصومة ويحسم النزاع ويؤدي إلى تطبيق القانون^(٢).

ولكي يعتبر القرار حكما يجب أولا أن يصدر في خصومة، أي منازعة معينة قامت ونشأت بين شخصين أو أكثر، وهذا ما يميز الحكم عن العمل التشريعي باعتباره أن هذا الأخير قرار له صفة العمومية والشمول لا يقصد به أن يطبق على حالات معينة أو معروضة فعلا في الحياة الواقعية. وعن القرار الإداري، إذ أن عمل الإدارة لا يفترض وجود منازعة، كما أن الإدارة تتصدى من تلقاء نفسها لتسيير المرافق العامة بينما القاضي لا يتدخل للفصل في المنازعة إلا بناء على طلب، كما أن وجود منازعة تبرر صدور حكم هو الذي يميز الحكم كعمل قضائي عن أوامر الأداء والأوامر على العرائض، ولابد من صدور الحكم وفقا لأشكال معينة، وأن يصدر عن محكمة تتبع القضاء وفقا لأوضاع وإجراءات معينة تتمثل في المرافعة والمواجهة وحجز القضية للحكم والمداولة وإصدار قرارا مكتوبا مسببا متضمنا بيانات معينة^(٣).

وبصدور الحكم وفقا لهذه الأشكال والإجراءات يكون القاضي قد أنزل الحماية القضائية على المركز المطلوب حمايته، سواء كانت هذه الحماية موضوعية متعلقة بأصل الحق، أم وقتية متعلقة بالإجراءات التحفظية.

ثانيا: أركان الحكم القضائي:

الركن ما توقف الشيء على وجوده، فلا يكون للشيء وجود إلا بتوافر أركانه، بحيث إذا فقدها أو فقد بعضها كان منعوما؛ والحكم يكون منعوما إذا تجرد من أركانه الأساسية، بحيث

(١) د. أحمد مليجي: محاضرات في قانون المرافعات، ص ٣٠٤. ويتميز الحكم بأنه: يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية، ويصدر بما للمحكمة من سلطة قضائية، أي يصدر في خصومة، ويكون مكتوبا شأنه في ذلك شأن أية ورقة من أوراق المرافعات.

(٢) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ١٨٧-١٨٨.

(٣) د. أحمد هندي، قانون المرافعات، الجزء الثاني، ص ٤٢٦.

يفقد صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره، فلا يستنفذ القاضي سلطته، ولا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي، ولا يرد عليه التصحيح، لأن التصحيح لا يمكن رأب صدعه؛ إلا أن الصعوبة تكمن في تحديد ما يعتبر ركنا في الحكم وما يعتبر شرطا لصحته؛ وأركان الحكم تنوع إلى أركان موضوعية، وأركان شكلية، ويعبر بعض الفقه عن الأركان الموضوعية للحكم بالأركان الداخلية، وعن الأركان الشكلية بالأركان الخارجية^(١).

ويجمل بعض فقهاء القانون هذه الأركان في أربعة أركان على النحو التالي:

- ١- صدور الحكم القضائي من محكمة تابعة لجهة قضائية.
 - ٢- أن يصدر الحكم منها في حدود ولايتها القضائية.
 - ٣- صدور الحكم القضائي في خصومة منعقدة
 - ٤- أن يصدر الحكم في الشكل المقرر قانونا للأحكام.
- في حين يفصل البعض الآخر هذه الأركان إلى أركان موضوعية، وأركان شكلية، وركن شخصي.
- أ- أركان الحكم الموضوعية:

باعتبار الحكم عملا قانونيا فإنه يجب أن تتوافر فيه ثلاثة أركان موضوعية، وهذه الأركان هي الإرادة، والمحل، والسبب.

ب - الأركان الشكلية:

لا يكفي لوجود الحكم القضائي والاعتداد به وترتيب آثاره القانونية أن تتوافر أركانه الموضوعية التي سبق الإشارة إليها، وإنما يجب أن تتوافر في الحكم أركان شكلية أوجها المشرع ونص عليها، وهذه الأركان هي صدور الحكم في خصومة منعقدة، ووجود ورقة الحكم.

ج - الركن الشخصي:

لا تقتصر أركان الحكم القضائي على الأركان الموضوعية والشكلية؛ وإنما يشترط فضلا عن ذلك توافر الركن الشخصي للحكم القضائي، ذلك أن الحكم لا تقوم له قائمة إلا بوجود أشخاص الخصومة الذين هم أشخاص الحكم، وأشخاص الحكم القضائي هم العضو القضائي الذي أصدر الحكم، والخصوم الذين صدر الحكم لصالحهم أو ضدهم.

(١) يميز الفقه والقضاء بين أركان الحكم ومقومات وجوده وبين مقتضيات صحته، فأركان الحكم وهي أركان موضوعية أو داخلية تتعلق بمضمون الحكم (وهي الإرادة والمحل والسبب) وأركان شكلية أو خارجية (وهي القاضي والمطالبة القضائية وشكل الحكم) هي أساس وجوده وبدونها يتجرد الحكم من العناصر الجوهرية اللازمة لتكوينه ويفقد صفته كحكم وهو ما يعني انعدامه. أما مقتضيات صحة الحكم فهي الشروط التي يستلزم القانون توافرها في هذه الأركان، فإذا شاب الحكم عيب يلحق بمقتضيات صحته فإنه لا يؤثر في وجوده كحكم ولا يحول دون أدائه لوظيفته ولا يؤدي إلى انعدامه، ويرتب كافة آثاره إلى أن يقضى بطلانه عن طريق الطعن فيه.

المطلب الثاني

أقسام الحكم القضائي

الأحكام التي تصدر في القضايا ليست متماثلة، وإنما تختلف من نواح متعددة، ويمكن تقسيم الأحكام تقسيمات متعددة تختلف باختلاف المعيار الذي تقوم عليه.

فمن حيث معيار قابلية الحكم للطعن فيه: تنقسم إلى أحكام ابتدائية ونهاية وباتة: والحكم الابتدائي: هو الحكم الذي يصدر من محكمة الدرجة الأولى ويقبل الطعن فيه بالاستئناف، والحكم النهائي: يشمل الحكم الذي يصدر من محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي، ويشمل الحكم الذي يقرر المشرع عدم قابليته للطعن فيه بالاستئناف بصرف النظر عن قيمة النزاع، كما يشمل الحكم الذي يصدر من محكمة الدرجة الثانية، أما الحكم البات فهو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.

وتنقسم الأحكام من حيث قوتها: إلى أحكام حائزة لحجية الأمر المقضي وأحكام حائزة لقوة الأمر المقضي^(١):

والحكم الحائز لحجية الأمر المقضي هو الحكم الذي يقبل الطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية، أما الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي، فهو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية، وإن كان يقبل الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر.

وتنقسم الأحكام من حيث سلطة المحكمة في الرجوع إلى المسألة التي فصلت فيها: إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية:

والحكم القطعي: هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته، أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه، وذلك بالفصل فيه فصلاً حاسماً من جانب المحكمة، وعلى ذلك فالحكم القطعي هو الذي يفصل في الطلبات الموضوعية، أو في جزء منها، أو في مسألة أثرت أثناء سير الخصومة سواء كانت مسألة موضوعية أو إجرائية، بحيث يمتنع معه على المحكمة أن تعدل عن قرارها لخروج

(١) ومعنى حجية الأمر المقضي: أن للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلاً وسبباً، وهذه الحجية تثبت لكل حكم قضائي يفصل في الخصومة بصفة قطعية، ولو كان قابلاً للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية. أما قوة الأمر المقضي: فهي مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف وإن كان قابلاً للطعن بطريق من طرق الطعن غير العادية (النقض والتماس إعادة النظر). فقوة الأمر المقضي وصف للحكم النهائي الذي لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية، وهي المعارضة، والاستئناف. وثبوت هذه القوة للحكم لا يمنع من إمكانية الطعن عليه بطريق غير عادي.

هذه المسألة عن ولايتها، واستنفاد سلطتها بشأنها، ويحوز الحكم القضائي القطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه، والحجية تمنع الخصوم الذين صدر الحكم القطعي في مواجهتهم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم^(١).

كما يمتنع على المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر فيما قضى فيه، ولا يجوز ذلك لغيرها من المحاكم إلا إذا كانت هي المحكمة المختصة بنظر الطعن في الحكم، ومن المعلوم أن هذه الحجية مؤقتة، تقف بمجرد رفع استئناف عن الحكم، وتظل هذه الحجية موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف، إما بإلغاء الحكم فتزول الحجية عنه، وإما بتأييده فتتأكد للحكم حجيته. ويشترط في هذا الحكم القطعي أن يبت في الخصومة على وجه حاسم، إذ الأحكام القطعية التي لا تبت في الخصومة على وجه حاسم لا تحوز حجية الأمر المقضي، ومثالها الأحكام التهديدية، فالحكم الصادر بغرامة تهديدية لا يحوز الحجية، لأن للمحكمة التي أصدرته أن تعيد النظر فيه بالزيادة أو الإنقاص أو الإلغاء^(٢).

أما الحكم غير القطعي: فهو حكم لا يحسم موضوع النزاع لا كله ولا جزء منه، كما لا يحسم مسألة فرعية متفرعة عنه، حيث يتعلق بتنظيم إجراءات الخصومة وتحقيقها. ومثال هذا الحكم: الحكم بضم دعويين، أو بانتقال المحكمة لمعاينة الشيء المتنازع عليه، أو سماع شاهد، ولا تستنفذ المحكمة ولايتها بإصدار الحكم غير القطعي، كما لا يحوز حجية الأمر المقضي، فللمحكمة أن تعدله أو تلغيه دون تقييد بما سبق لها أن أصدرته من أحكام غير قطعية.

(١) إذ يشترط لكي يحوز الحكم حجية الأمر المقضي أن يكون حكماً قطعياً يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في جزء منه، أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية، مثل الحكم للمدعى بطلباته أو الحكم بعدم الاختصاص. أما الأحكام التي لا تبت في موضوع الخصومة كلها أو بعضها فلا تحوز الحجية. ومثال الحكم القطعي في مسألة متفرعة عن النزاع، الحكم في الدفع بعدم الاختصاص، والحكم الصادر ببطالان صحيفة الدعوى، أو في طلب ببطالان إجراء من إجراءاتها، وكذلك الحكم في جواز الإثبات بالبينة في الدعوى، والحكم في إنكار ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى أو الادعاء بتزويرها، سواء كان بصحة الورقة أو بتزويرها، فلا يقتصر وصف الحكم بأنه قطعي على الحكم الأخير الذي يفصل في موضوع الدعوى، فقد يكون الحكم قطعياً، ولو كان صادراً قبل الفصل في الموضوع، كالحكم الصادر بجواز أو عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود.

(٢) والأحكام التهديدية تصدرها المحكمة ضد المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه، إذا كان محل الالتزام عملاً يقتضى تدخل المدين نفسه، فتحكم عليه المحكمة بغرامة تهديدية عن كل فترة من فترات التأخير وذلك لحمله على الوفاء، فمثل هذه الأحكام لا تحوز الحجية ويجوز للقاضي الذي أصدرها أن يعدلها ومثالها كذلك إذا حكم على شخص بتقديم حساب في وقت معين وإلا حكم عليه بغرامة عن كل يوم تأخير. والقانون المدني نص في المادة (٢١٤) على عدم حجية الأحكام التهديدية، بنصه على أنه "إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيًا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين".

وتتميز الأحكام غير القطعية عن الأحكام القطعية بأنها تتضمن اتخاذ إجراءات معينة يمكن من الوصول للفصل في موضوع النزاع، أو المحافظة على الحق المتنازع عليه، دون أن تنهى موضوع النزاع أو تفصل في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه، وهذه الأحكام لا تقيد المحكمة بشيء سواء بتنفيذها أو بنتيجتها، إذ هي متعلقة فقط بسير الخصومة أو بإجراءات الإثبات فيها، فللمحكمة أن تقضى بغيرها إذا ما تغيرت ظروف إصدارها، ذلك أنها لا تحوز أية حجية، وتسقط هذه الأحكام بسقوط الخصومة.

والأحكام غير القطعية على ثلاثة أنواع:

- إما أحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع ومقصود بها تهيئة القضية للمرافعة.
- وإما أحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع ومتعلقة بإجراءات الإثبات.
- وإما أحكام وقتية.

وتصدر هذه الأحكام قبل الفصل في الموضوع ولا تحوز حجية الأمر المقضي، ذلك وهي إما أن تكون: أحكاماً تحضيرية تسبق الحكم في الموضوع، وتعتبر تحضيراً له دون أن تبين رأى المحكمة في الموضوع، كالحكم الذي يصدر بإيداع المستندات أو الإطلاع عليها والحكم بإحالة القضية على التحقيق، والحكم بضم دعويين أو الفصل بينهما، ومثل هذه الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي. وإما أن تكون أحكاماً تمهيدية تسبق الحكم في الموضوع تمهيداً للحكم فيه، ولكنها تبين رأى المحكمة في موضوع النزاع، ومثالها، ما إذا أصدرت المحكمة قراراً بتعيين خبير لتقدير قيمة الضرر الذي أصاب المدعى فإن هذا الحكم يكشف عن نية المحكمة في الحكم بالتعويض، ولكنها لا تفصل في موضوع النزاع ولا تحوز حجية الأمر المقضي. أما الحكم الوقفي فهو الذي يصدر في طلب وقتي أو في طلب باتخاذ إجراء تحفظي، حيث يقوم القاضي من خلاله بتنظيم مراكز الخصوم تنظيماً مؤقتاً إلى أن يفصل في موضوع النزاع.

والغرض من الأحكام الوقتية، تفادي الضرر الناتج عن طول إجراءات الخصومة، وذلك باتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي يحمي مصلحة الخصوم أو يحفظ أموالهم بصورة وقتية إلى أن يتم حسم موضوع النزاع، وهذا الحكم يقوم على ظروف متغيرة تتضح من ظروف القضية المطروحة على القاضي، والأحكام الوقتية لا تحوز الحجية - حتى ولو كانت نهائية - لأنها تكفل حماية وقتية تزول بزوال الظروف التي صدرت من أجلها ويتفق فقهاء القانون على أن الحكم الوقفي لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه، إلا إذا تغيرت الظروف التي صدر من أجلها، فإذا ظلت هذه الظروف كما هي دون تغيير، أصبح للحكم الوقفي حجية الأمر المقضي مثله في ذلك مثل الحكم القطعي، غير أنه إذا كان الحكم الوقفي يحوز الحجية في الدعوى المستعجلة، فإنه لا يحوز الحجية في الدعوى الموضوعية ولا يقيد محكمة الموضوع بشيء.

وتنقسم الأحكام من حيث معيار حضور الخصوم أو غيابهم: إلى أحكام حضورية وأحكام غيابية:

ويعتبر الحكم حضورياً في حق الخصم إذا كان قد حضر جلسة من جلسات المرافعة أو قدم مذكرة بدفاعة في الدعوى، وكذلك إذا أجل القاضي الدعوى لإعادة إعلانه بها وتم إعلانه بها إعلاناً صحيحاً. أما الحكم الغيابي فهو الحكم الذي يصدر ضد خصم لم يسبق له الحضور في الدعوى أو إيداع مذكرة فيها ولم يعد إعلانه^(١).

وقد فرق المشرع في شأن حضور الخصم بين حالتين: الأولى، إذا كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه، فإن المحكمة تنظر الدعوى ولا تؤجلها لغياب المدعى عليه، فقد ثبت علمه فعلاً بقيامها. والثانية، إذا كانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخص المدعى عليه، وفي هذه الحالة يفترض جهل المدعى عليه بقيام الخصومة، ويجب تأجيل الدعوى لجلسة تالية يعلن المدعي بها المدعى عليه الغائب، وفي الجلسة الجديدة تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها ولو تغيب المدعى عليه، إذ تعتبر الخصومة حضورية في حقه^(٢).

وتنقسم الأحكام من حيث محلها: إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام صادرة قبل الفصل فيه، وأحكام صادرة بعد الفصل فيه:

والحكم الفاصل في الموضوع هو الحكم الذي يفصل موضوع الدعوى بأكمله أو شق منه ويمنح بذلك الحماية القضائية المرغوبة في صورة تقرير الحق أو المركز القانوني وتأكيده، أو في صورة تعديل المراكز القانونية القائمة وتغييرها، أو في صورة إلزام أحد الخصوم بأداء معين يقبل التنفيذ الجبري.

أما الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع فيشمل الأحكام الوقفية والمستعجلة^(٣)، والأحكام التمهيدية، والأحكام التحضيرية وهي التي تتعلق بسير الخصومة أو بتحقيقها. أما الأحكام

(١) د. علي بركات: الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، ٢٠٠٠م، ص ٢١.

وكانت أهمية التفرقة بين الحكم الحضوري والغيابي هي أن الحكم الغيابي يمكن المعارضة فيه، أما الآن فإن الأحكام الغيابية لا تجوز المعارضة فيها إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، ولهذا تضاءلت أهمية الأحكام الغيابية إذ لا مجال لإعمال الأحكام الغيابية. إذ أنه في القانون الحالي لا مجال للأحكام الغيابية إلا في الحوال الشخصية وهذه تجوز المعارضة فيها وفقاً لبعض نصوص القانون السابق، والتي نص القانون الحالي على استمرار العمل بها (د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص ٧١٠-٧١١).

(٢) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص ٦٧٣.

(٣) الحكم المستعجل هو: حكم يفصل فصل نهائي وبصفة مستعجلة في مسائل تتطلب حسماً قضائياً سريعاً دفعاً للخطر عن صاحب الحق الظاهري. وهذا الحكم ينظم مراكز الخصوم في الدعوى دون مساس بأصل الحق ودون أن يتقيد القاضي الموضوعي بشيء مما يقضى به الحكم المستعجل.

الصادرة بعد الفصل في الموضوع، فبعضها يصدر مع الحكم المنهي للخصومة أمام المحكمة كالحكم في مصروفات الدعوى، والبعض الآخر يصدر من ذات المحكمة بعد صدور الحكم المنهي للخصومة. ومنفصلاً عنه، كالحكم في طلب تفسير الحكم أو تصحيحه أو فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات موضوعية.

وتنقسم الأحكام من حيث مضمونها: إلى أحكام تقريرية وأحكام منشئة وأحكام إلزام^(١):

والحكم المقرر هو الحكم الذي يؤكد وجود حق معين أو عدم وجوده دون أن يقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء ما، وبهذا يزول الشك القائم حول هذا الوجود، وتسمى الدعوى التي تهدف إلى الحصول على الحكم التقريري بالدعوى التقريرية وهذه الأحكام لا تقبل التنفيذ الجبري لأنها تقتصر على تقرير حق دون إلزام بأداء معين. ومن أمثلة ذلك الحكم الصادر بصحة عقد البيع ونفاذه والحكم الصادر بصحة التوقيع أما الحكم الصادر بثبوت النسب وكذلك الحكم بثبوت الملكية أو ببراءة الذمة.

والحكم المنشئ هو الذي يقرر إنشاء أو إنهاء أو تعديل حق أو مركز قانوني معين، بحيث ينشأ عن هذا الحكم تغيير مركز قانوني سابق دون إلزام المحكوم عليه بأداء معين، وتسمى الدعوى التي تهدف إلى الحصول على القضاء المنشئ بالدعوى المنشئة. ومن أمثلة ذلك الحكم بالانفصال الجسدي بين الزوجين والحكم الصادر في دعوى القسمة والحكم بفسخ عقد من العقود والحكم بالإفلاس وكذلك الحكم بالشفعة والحكم بالتطليق.

ويحقق الحكم المقرر أو المنشئ الهدف منه كما يحقق الحماية القضائية الكاملة بمجرد صدوره دون حاجة إلى حماية تكميلية، إلا أن هذه الأحكام لا تصلح سنداً للتنفيذ الجبري سواء المباشر أو بطريق الحجز ونزع الملكية^(٢). أما حكم الإلزام فهو الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين يقبل التنفيذ الجبري.

أما الحكم الوقفي: فهو الذي يصدر في طلب وقفي أو في طلب باتخاذ إجراء تحفظي، حيث يقوم القاضي من خلاله بتنظيم مراكز الخصوم تنظيمًا مؤقتاً إلى أن يفصل في موضوع النزاع.

والأحكام التمهيدية هي التي تسبق الحكم في الموضوع تمهيداً للحكم فيه، ولكنها تبين رأى المحكمة في موضوع النزاع، ومثالها، ما إذا أصدرت المحكمة قراراً بتعيين خبير لتقدير قيمة الضرر الذي أصاب المدعى فإن هذا الحكم يكشف عن نية المحكمة في الحكم بالتعويض، ولكنها لا تفصل في موضوع النزاع ولا تحوز حجية الأمر المقضي.

(١) د. عبيد محمد القصاص، التنفيذ الجبري، ج ١، الجزء الثاني، ص ١٠٠.

(٢) د. أحمد مليحي: الموسوعة الشاملة، ج ٩١٦/٥ - د. أحمد هندي: أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٧م، ص ٢٣ - أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، دار الجامعة

المبحث الثاني

قواعد إصدار الحكم القضائي

"أحاط المشرع إصدار الحكم القضائي بمجموعة من الضمانات، التي يتعلق بعضها بشكل الحكم القضائي، والأخرى بمضمونه، سواء في المرحلة السابقة على إصداره، أو في المرحلة التي تلي إصداره، كما أوجب على المحكمة أن تصوغ حكمها في شكل معين، وأن تنطق به في جلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين اشتركوا في تحقيق الدعوى القضائية، وسمعوها المرافعة فيها، وجرت بينهم المداولة القضائية. كما أوجب المشرع ضرورة إيداع مسودة الحكم القضائي في ملف القضية وذلك عند النطق به، مع تمكين الخصوم من الاطلاع عليه، والوقوف على أسبابه عقب النطق به. وتلتزم المحكمة بعد النطق بالحكم القضائي، وإيداع مسودته، أن تحرر نسخة الحكم الأصلية، وتودعها ملف القضية، خلال فترة زمنية معينة"^(١).

وهذه الضمانات هي قواعد قانونية واجبة التطبيق في شأن إصدار الحكم، بحيث يبطل الحكم إذا صدر بالمخالفة لها، وهي إقفال باب المرافعة، والمداولة في الحكم، والنطق به في جلسة علنية، وإيداع مسودة الحكم، ثم تحرير نسخته الأصلية. ونتناول هذه القواعد فيما يلي:

أولاً: إقفال باب المرافعة :

ومعنى إقفال باب المرافعة أن تقرر المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم. فالمحكمة بعد أن تتصل بالدعوى وتستمع إلى أقوال الخصوم فيها وبعد اطلاعها على المستندات المقدمة في الدعوى، ومتى رأت أنها أفسحت المجال للخصوم بما يكفي لتقديم دقوعهم وأوجه دفاعهم بما يتضح معه وجه الحق في الدعوى، تقرر قفل باب المرافعة فيها. ويعد باب المرافعة مقفلاً بإصدار قرار من المحكمة، سواء كان هذا القرار صريحاً أو ضمنياً، ويكون ذلك إذا بدأت المحكمة المداولة في الدعوى بعد حجزها للحكم فيها. على أن

الجديدة، ٢٠٠٩م، ص ٢٨. إلا أن عدم قابلية الحكم المقرر أو المنشئ للتنفيذ الجبري لا يعنى أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي، فالحكم المقرر أو المنشئ يحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره رغم عدم قابليته للتنفيذ الجبري، وذلك لأنه لا يوجد تلازم بين حيابة الحكم للحجية وقابليته للتنفيذ الجبري، فقد يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري ولكنه لا يحوز الحجية كالحكم المستعجل، كما قد يحوز الحكم حجية الأمر المقضي ولكنه يكون غير قابلاً للتنفيذ الجبري كالحكم الابتدائي غير المشمول بالنفاذ المعجل والأحكام المقررة والمنشئة، وهذه الحجية لاتقف لمجرد قابلية الحكم للاستئناف، بل أنها لاتقف ولو كان طعن فيه بالاستئناف بالفعل ("أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: قانون التنفيذ الجبري، مطبعة حمادة الحديثة الطبعة الأولى ٢٠٠٩/٢٠١٠م، ص ١٦٩ هامش رقم ١٨٤).

(١) د. محمود السيد التحيوي، النظرية العامة لأحكام القضاء، مرجع سابق، ص ١٣.

حجز الدعوى للحكم مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم لا يعد إقفالا لباب المرافعة فيها؛ إذ لا يعد باب المرافعة مقفولا إلا بعد انتهاء الأجل المحدد للخصوم لتقديم هذه المذكرات أو المستندات.

ثانيا: المداولة في الحكم:

وتعرف المداولة بأنها: التشاور في الحكم بين أعضاء المحكمة إذا تعددوا، والتفكير في الحكم وتكوين الرأي فيه إذا كان القاضي واحدا. أو هي: التفكير والتدبير وعمليات المنطق والقياس والاستنتاج، والتأصيل والتحليل الذي يقوم به القاضي إزاء وقائع النزاع المطروحة عليه بواسطة الخصوم، وما يقبل الانطباق عليها من القواعد القانونية^(١).

والمداولة إجراء ضروري ومرحلة أساسية لا غنى عنها، فمن خلالها يقوم القضاة بالتشاور وتبادل الرأي، بعد فحص وتمحيص وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها، للوصول إلى الحل القانوني الواجب التطبيق على النزاع المطروح على المحكمة^(٢).

ولا يكفي أن يتداول القضاة في الحكم على أي وجه من الوجوه، وإنما يجب أن تتوافر في المداولة شروط عديدة ورد النص عليها في قانون المرافعات. فقد نص المشرع على اتباع قواعد محددة بشأن المداولة في الأحكام القضائية، وهي أن تتداول المحكمة في الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، وأن يشترك جميع قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم في المداولة، وألا يشترك غيرهم فيها، وأن تجرى المداولة سرا بين القضاة مجتمعين، وبعد إقفال باب المرافعة، وألا تستمع المحكمة إلى أحد الخصوم في غيبة الآخر، أو تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم لم يطلع عليها الخصم الآخر وتعتمد عليها في حكمها، وأن تجرى المداولة قبل إصدار الحكم وقبل التوقيع على المسودة.

ولم يحدد المشرع طريقا معينا لإجراء المداولة يلزم اتباعه ولا مكانا محددا تجرى المداولة فيه، فمثل هذه الأمور تترك للسلطة التقديرية للمحكمة حسب ظروف كل دعوى، كما لم يتطلب المشرع تضمين الحكم بيانا يفيد إجراء المداولة، وإنما كل ما أوجبه القانون في هذا الشأن هو صدور الحكم بعد المداولة.

(١) د. ماهر إبراهيم السداوي، نظرية الخصومة (د.ن)، ص ٢٠٦.

(٢) د. محمد سعيد عبدالرحمن، مرجع سابق، ص ٢٠٩.

ثالثا: النطق بالحكم^(١):

النطق بالحكم هو قراءته بصوت عال في الجلسة، ويكون ذلك بقراءة منطوقه من واقع مسودة الحكم، والأصل أن ينطق بالحكم رئيس الدائرة التي أصدرته، إلا أنه لا يوجد مانع من قيام أحد أعضاء الدائرة غير الرئيس من النطق به^(٢). وللحظة النطق بالحكم أهمية بالغة إذ قبل النطق بالحكم فإنه يكون غير موجود ولو كتبت مسودته، وبعد النطق به فإن القضية تخرج من ولاية المحكمة وينتهي دورها بحيث لا يجوز لها تعديل أو تبديل حكمها^(٣).

ولا يشترط أن يقرأ القاضي الحكم بالكامل، بل يكفي أن يقرأ منطوقه أو منطوقه مع أسبابه في الجلسة العلنية، ويكون النطق بالحكم من واقع مسودته لما يدل عليه ذلك من أن القضية قد تداولوا في الدعوى ووقعوا على مسودة الحكم المتضمنة أسبابه ومنطوقه ولما يبعثه ذلك من الثقة في نفوس الخصوم^(٤). ويشترط لصحة النطق بالحكم أن ينطق به في جلسة علنية، حتى ولو كانت المرافعة قد حصلت في جلسة سرية. وأن يحضر القضية الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. وأن تودع مسودة الحكم ملف الدعوى عند النطق به.

رابعا: كتابة الحكم:

يشترط في الحكم القضائي أن يكون مكتوبا، لأن الكتابة تعتبر عنصرا شكليا فيه، ولذلك يجب تحرير الحكم في ورقة تتضمن بيانات معينة، كما يجب الاحتفاظ بورقة الحكم، وذلك لأن ورقة الحكم هي الدليل على وجوده، وعدم كتابتها يؤدي إلى انعدام الحكم، كما أن فقدانها بعد كتابتها قد يؤدي في بعض الحالات إلى انعدام الحكم. ويوجب القانون أن تكتب مسودة الحكم أولا، ثم تكتب نسخة الحكم بعد النطق به.

أ- مسودة الحكم:

مسودة الحكم: هي ورقة لتحضير الحكم، تكتب عقب الانتهاء من المداولة وقبل النطق بالحكم، وتشتمل فقط على أسباب الحكم ومنطوقه، وأسماء القضاة الذين أصدروه. فيجب

(١) يوجب قانون المرافعات أن ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه. ويكون النطق في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلا. ويجب أن يحضر القضية الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودته. ويجب في جميع الأحوال أن تودع بقلم الكتاب مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا. (المواد ١٧٠ و ١٧٤ و ١٧٧ المرافعات).

(٢) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: قانون المرافعات، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ١٦٨.

(٣) د. إبراهيم نجيب سعد، مرجع سابق، ص ٢٢١.

(٤) د. محمد سعيد عبدالرحمن، مرجع سابق، ص ٢٤٣.

أن تشتمل المسودة على أسباب الحكم ويوقع عليها من الرئيس ومن جميع القضاة الذين أصدروا الحكم ويحدد بها تاريخ ايداعها، ولا يكفي في هذا الصدد أن يوقع رئيس الدائرة فقط على المسودة، وإنما يجب توقيع جميع القضاة الذين أصدروا الحكم، كما يجب أن تحرر المسودة بخط القاضي الذي أصدر الحكم، أو بخط أحد قضاة الدائرة، ويجوز أن يشترك جميع أعضاء الدائرة في كتابة المسودة، وذلك لأن هيئة المحكمة لا تتجزأ في صدد تحرير المسودة، كما يجوز كتابتها بخط اليد أو على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة، ثم توقع من أعضاء الدائرة، إلا أنه لا يجوز أن يشترك في كتابة المسودة شخص آخر غير قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم، وإذا ثبت ذلك فإن الحكم يكون باطلاً.

ب- النسخة الأصلية للحكم:

العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس المحكمة، إذ المسودة لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم، والتوقيع على نسخة الحكم هو إقرار بما حصل ودليل على صدوره من المحكمة والعبرة هي بتوقيع رئيس الجلسة وإلا كان الحكم باطلاً، أما إهمال الكاتب في توقيع الحكم فلا يترتب عليه البطلان، ولا يشترط توقيع بقية أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم، بل يكفي مجرد توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية، واختصاص رئيس المحكمة بالتوقيع على الحكم ليس إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده، فإذا عرض له مانع قهري، فإنه يجوز لأي عضو من أعضاء المحكمة أن يوقع على الحكم^(١). وقد أوجب المشرع أن تشتمل النسخة الأصلية للحكم على بيانات محددة ورد النص عليها في المادة (١٧٨) مرافعات^(٢)، وهذه البيانات هي:

(١) د. عبدالحكم فوده، المرجع السابق، ص ٢١٢-٢١٣. نصت المادة (١٧٩) مرافعات على أنه "يوقع رئيس الجلسة وكتابتها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة، وسبعة أيام في القضايا الأخرى، وإلا كان المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويضات".

(٢) نصت المادة (١٧٨) مرافعات على أنه "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم".

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفعهم ودفاعهم الجوهرية، ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم".

- ١- المحكمة التي أصدرت الحكم.
- ٢- مادة النزاع الذي فصل فيه الحكم وهل هي مادة تجارية أو مستعجلة.
- ٣- تاريخ إصدار الحكم.
- ٤- مكان إصدار الحكم.
- ٥- أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وتخلفوا عن الحضور في جلسة النطق به، وإثبات اشتراكهم في المداولة وتوقيعهم على المسودة.
- ٦- اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان .
- ٧- الوقائع: ويقوم القاضي من خلالها بتسجيل وقائع الخصومة بحيث تتضمن عرضاً لموضوع النزاع، حيث يقوم القاضي بسرد مختصر لوقائع النزاع المعروض على المحكمة، وبيان طلبات الخصوم في الدعوى.
- وهي تشتمل على بيان بأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن كانوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأي النيابة.
- ٨- أسباب الحكم: وهي الأسانيد التي يستند إليها قرار القاضي فهي الدعامة التي يقوم عليها المنطوق، حيث لا يكفي في الحكم أن يكون قد ورد في المنطوق صريحاً أو ضمناً وإنما يجب أن يستند هذا المنطوق إلى أسباب تقويه وتدعمه ليعرف من خلالها حقيقة ما توصل إليه القاضي وما دعاه إلى إصدار هذا الحكم، وفهمه للنزاع وللوقائع المعروضة عليه والأدلة الجوهرية التي استند إليها الخصوم وردده على الدفع التي أبداهما الخصوم في الدعوى، وصحة تطبيق القانون على الوقائع محل النزاع.
- ٩- منطوق الحكم: وهو القرار الذي يصدره القاضي في الدعوى أو في جزء منها.
- بحيث يشتمل هذا الجزء من أجزاء الحكم على قضاء المحكمة الحاسم في النزاع الذي ثار بين الخصمين وكان مطروحا على المحكمة لإصدار حكمها فيه، فهو خلاصة رأى المحكمة الملزم في النزاع المعروض عليها، والقاضي يعبر في المنطوق عما حكم به بألفاظ صريحة واضحة وهذا الجزء هو أهم أجزاء الحكم حيث تحسم فيه المحكمة النزاع وتؤكد به حقوق الخصوم.
- ١٠- توقيع رئيس الجلسة وكتابتها .
- وقد رتب المشرع البطلان كجزاء للقصور في أسباب الحكم الواقعية، أو النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم (مادة ١٧٨ مرافعات).

المبحث الثالث

تسبيب الأحكام

يجب لسلامة الحكم ألا يصدر على أساس فكرة مهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها، وإنما يجب أن يؤسس على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم، ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية، وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت، وذلك تمكينا لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره^(١).

ذلك أن احتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها يؤدي إلى بث الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين فيعرف كل متقاضي على أي أساس صدر الحكم، فإن كان له على الحكم مأخذ استخدم حقه في الطعن فيه، وبذا تتمكن محكمة الدرجة الثانية من مراقبة أحكام محاكم الدرجة الأولى، كما تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون من محكمتي الدرجة الأولى والثانية، وفي ذلك ضمان لسلامة تطبيق القانون وتفسيره، فضلا عن أن لتسبيب الحكم أهمية كبرى باعتباره مظهرا لقيام القاضي بما عليه من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي تفصح عنها أحكامه، وبه وحده يسلم من مظنة التحكم والاستبداد، ويرتفع عن الشك والريب والشبهات، ويحملة على العناية بحكمه وتوخي العدالة في إصدار أحكامه كما يضمن حيطة القاضي وعدم تحيزه.

أولا: ماهية التسبيب وأهميته:

يقصد بالتسبيب بيان الأدلة الواقعية والأسانيد القانونية التي اعتمدتها المحكمة وأقامت عليها قضائها واقتنعت بها وجعلتها تصدر حكمها على النحو الذي صدرت به. ويقصد بالأسباب الواقعية: بيان الوقائع والأدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود أو عدم وجود الواقعة أو الوقائع الأساسية للحكم. أما الأسباب القانونية: فيقصد بها بيان القاعدة القانونية أو المبدأ القانوني الذي يصدر الحكم تطبيقا له، وتشتمل على الحجج القانونية التي يستند إليها الحكم.

وتكمن أهمية تسبيب الأحكام القضائية في اعتبارات هامة ترجع إلى ثلاثة أفكار رئيسية، هي: حماية الأفراد وحماية المجتمع وحماية القضاة. ذلك أن التسبيب يحقق في الواقع أهداف عدة، أهمها: أنه يعد أداة فعالة في إبراز عدالة الأحكام وصحتها، كما أنه يعد وسيلة فعالة نحو حماية

(١) نقض: الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٤١ قضائية - جلسة ١٩٧٦/٣/٢٢.

القاضي مما يواجهه من ضغوط أو توجهات لإصدار حكمه على نحو لا يتفق مع العدالة، ويكشف عن الدوافع والمبررات التي دفعت القاضي لإصدار حكمه على نحو معين، وبالتالي يدفع عنه أي شك أو ريبة، كما أنه يقف حجر عثرة في مواجهة أي انحراف من القاضي، ويجعل من الحكم وسيلة إقناع، كما يعد أداة فعالة في تحقيق جدية نظام الطعن في الأحكام وفعاليتها^(١).

ثانياً: الأسباب الواقعية والقانونية التي يؤسس عليها الحكم:

يجب أن يبين الحكم الأسباب الواقعية (الوقائع ووسائل الدفاع والأدلة) التي يستند إليها في تقرير إثبات أو نفي الواقعة الأساسية التي تعتبر العنصر الواقعي الذي يفترض وجوده لتطبيق القاعدة القانونية. كما يجب أن يتضح من الأسباب أن الوقائع اللازمة لتطبيق القاعدة القانونية قد توافرت في الدعوى، ونوقشت وأثبتت بمعرفة الخصوم، أما إذا ظهر أن أسباب الحكم لا تسمح بذلك لخلوها أو قصورها عن إيراد العناصر الواقعية اللازمة لتبرير ما طبقه الحكم من القواعد القانونية كان الحكم معيباً في تسببه، بما يؤدي إلى بطلانه.

كما يجب أن يشتمل الحكم على بيان القاعدة القانونية التي يصدر القاضي حكمه تطبيقاً لها بعد تكييفه للوقائع وبحته عن الوقائع اللازمة لتطبيق هذه القاعدة القانونية. ومن ذلك يتضح لنا أن الحكم القضائي يجب أن يشتمل على نوعين من الأسباب، الأولى الأسباب الواقعية، والتي يؤدي قصورها فيها إلى بطلان الحكم، وفقاً لنص المادة (١٧٨) مرافعات، والثانية هي الأسباب القانونية والتي يعنى بها القاعدة القانونية التي استند إليها القاضي في تكييف الوقائع.

أ- الأسباب الواقعية:

وتعني أسباب الحكم الواقعية وجوب سرد وقائع الدعوى دون خطأ أو تحريف، وهذه الوقائع تشتمل على بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم، وعرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفعهم ودفاعهم الجوهرية. ويشترط في ذلك أن تقوم المحكمة بسرد هذه الوقائع دون خطأ أو تحريف، وإلا كان الحكم باطلاً متى تأثر بهذا الخطأ أو التحريف، غير أنه إذا ورد خطأ أو تحريف في واقعة من وقائع الدعوى، وكان هذا أو ذاك لا يؤثر في سلامة الحكم وفي النتيجة التي انتهت إليها والتي تبررها أسباب تستقيم معها، فإن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم وصحته.

(١) د. عبدالحكم فوده: موسوعة الحكم القضائي، ص ٢٢٣-٢٢٤ - د. عزمي عبدالفتاح، مرجع سابق، ص ٨٥ وما بعدها.

وعلى المحكمة في سردها للأسباب الواقعية أن تقوم بعرض مجمل الوقائع الضرورية التي يستلزمها الفصل في الدعوى بالإضافة إلى أوجه الدفاع والدفع. بأن تبين الوقائع الأساسية وطلبات الخصوم وما جد أو طرأ على تلك الطلبات من تعديلات وما لحق الخصومة من تغييرات خاصة بالنسبة لأطرافها، مثل الإدخال والطلبات العارضة والتدخل.

ب- الأسباب القانونية:

لا يكفي أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية على النحو الذي بيناه، وإنما يشترط فضلاً عن ذلك أن يتضمن القواعد والمبادئ والحجج والأسانيد القانونية التي بنى عليها القاضي حكمه، والتي أعمل بشأنها التكييف القانوني الصحيح، ويكفيه في ذلك بيان القاعدة القانونية دون الإشارة إلى النص التشريعي الذي يتضمنها.

والقصور في الأسباب الواقعية فقط هو ما يؤدي إلى بطلان الحكم وفقاً لنص المادة (١٧٨) مرافعات، أما القصور في أسباب الحكم القانونية فإنه لا يعيب الحكم مادامت الأسباب الواقعية صحيحة، والعلة في ذلك أن محكمة النقض عندما تمارس رقابتها على الأحكام القضائية، يكون لها تكملة الأسباب القانونية اللازمة أو أن تدرك ما وجد في الأسباب من أخطاء قانونية، مادامت النتيجة التي وصل إليها الحكم صحيحة، وأنه ركن إلى القاعدة القانونية واجبة التطبيق على الوقائع المعروضة، غير أن ذلك لا ينفي أن الارتباط بين أسباب الحكم الواقعية وأسبابه القانونية جد وثيق، إذ يؤدي الخطأ في أسباب الحكم الواقعية إلى خطأ مماثل في الأسباب القانونية وبالتالي يؤدي إلى خطأ في تطبيق القانون، إلا أن المشرع قرر البطلان على القصور في الأسباب الواقعية فقط.

ثالثاً: ضوابط تسبيب الأحكام:

تسبيب الأحكام لا يصح على أي وجه كان، وإنما لا بد له من ضوابط وشروط حتى يكون صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية، ومن ذلك:

- أن تتضمن الأسباب سرد الوقائع الكاملة المكونة للدعوى وأن يكون سرد هذه الوقائع دون خطأ أو تحريف. دون التزام على المحكمة بأن تتعقب حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً، بل يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه وتكفي لحمل قضائه.
- والقاضي ملزم بالرد على الطلبات والدفع والدفاع والأدلة التي يقدمها له الخصوم بطريقة صحيحة وقانونية ومنتجة في الدعوى.

- والتزيد في التسبب لا يعيب الحكم، سواء كانت الأسباب الزائدة صحيحة أم غير صحيحة بأن كان بها قصور، وسواء جاء التزيد في الأسباب الواقعية أم القانونية، ما دمت الأسباب الواقعية الأخرى كافية لحمل قضاء الحكم.
 - والحكم يكون وحدة واحدة في أسبابه، ومن ثم يجب أن ينظر إلى الأسباب كوحدة واحدة في مجموعها قبل تقرير خلو ورقة الحكم عن الأسباب الخاصة ببعض أجزاء الحكم.
- فالتسبب يجب أن يكون مستوفيا لشروط صحته سليما من العيب الذي قد يبطله، وشروط صحة التسبب وفقا لما استقر عليه الفقه ثلاثة شروط، هي: وجود أسباب الحكم، وأن تكون الأسباب التي بني عليها الحكم كافية لحمل قضائه، ومنطقية الأسباب التي بني عليها الحكم.

رابعاً: عيوب التسبب:

تتمثل أهم عيوب التسبب التي تصيب الحكم تتمثل فيما يلي:

أ- انعدام التسبب (خلو ورقة الحكم من الأسباب التي بني عليها):

ويكون الحكم خاليا من الأسباب في حالات ثلاث:

- الأولى: عدم تأسيس الحكم على أي سبب أي الغياب الكلي للأسباب.
- الثانية: تناقض الأسباب مع بعضها بحيث تهافت ويهدم كل منها الآخر.
- الثالثة: عدم رد المحكمة على طلب أو وجه دفاع أو دفاع جوهري، وهو ما يؤدي إلى الانعدام الجزئي.

ب- الخطأ في تطبيق القانون (مخالفة القانون):

وتتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نطاقا معيناً لسريان النص القانوني فتجاوزته المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع، وهي بذلك تخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن هذا التجاوز من مسائل القانون. فمخالفة القانون تعد سببا من أسباب الطعن بالنقض، ويقصد بها انكار القاضي قاعدة قانونية موجوده أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجوده، سواء كانت القاعدة من القواعد الموضوعية أو الإجرائية.

ج- القصور في التسبب:

يكون الحكم مشوبا بعيب القصور في التسبب إذا لم تحط المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة، وتمحص الوقائع والدفعات والدفاعات وترد عليها بما يفندها، ويتحقق هذا القصور إذا كانت الأسباب التي بني عليها الحكم غير كافية، أو كانت المحكمة قد أخلت بحقوق الخصوم في الدفاع، أو وقع تناقض بين أسباب الحكم بما يؤدي إلى تهافتها وتنافرها، وذلك على النحو الآتي:

١- القصور لعدم كفاية الأسباب:

يختص عيب عدم كفاية الأسباب أو القصور فيها بالأسباب الواقعية فقط دون الأسباب القانونية، ويقصد بهذه الأسباب العناصر الواقعية اللازمة لتطبيق القانون، أي كافة الوقائع وأوجه الدفاع والأدلة الأساسية التي يستخدمها القاضي، وعدم كفاية الأسباب الواقعية يرجع إلى عدم اشتمال الحكم على العناصر الواقعية الأساسية التي تصلح كمفترضات لتطبيق القاعدة القانونية، وهو ما يعجز محكمة الطعن عن رقابة صحة تطبيق القانون. ويأخذ عدم كفاية الأسباب الواقعية للحكم إحدى صورتين^(١)؛ الأولى: الإثباتات الواقعية المنقوصة، والثانية: الإثباتات الواقعية غير المحددة.

٢- القصور للاخلال بحق الدفاع:

يكون التسبب قاصرا أيضا إذا أخلت المحكمة بحق الدفاع، ذلك أن القانون ألزمها بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، وهي في هذا الصدد تمحص كل دفاع جوهري تضمنته المرافعة الشفوية أو المكتوبة أو دلت الخصم عليه بمستند تقدم به وكان منتجا في الدعوى، ويترتب على الالتفات عن ذلك بطلان الحكم لقصوره في أسبابه الواقعية.

٣- التناقض بين الأسباب:

فإذا كان هناك تناقض بين أسباب الحكم بحيث تتماهى هذه الأسباب وتهاثر فلا يعرف على أيها أقامت المحكمة قضاءها ولا يكون للمنطوق قائمة بعد أن خلا من الأسباب التي يمكن أن تحملها ولا يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به فإن هذا التناقض يبطل الحكم. ويتحقق التناقض بين الأسباب عندما تتضمن اتجاهين متضادين بحيث يتفق أحدهما مع المنطوق الذي يعتبر مبنيا على هذا الاتجاه ولا تقوم له قائمة بدونه، بينما يكون الاتجاه الآخر مناقضا ومغايرا تماما للاتجاه الأول، بحيث إذا اقتضت الأسباب على الاتجاه الآخر لكانت منبئة الصلة بالمنطوق وليس من شأنها إقامته بل على العكس تؤدي إلى منطوق مضاد لمنطوق الحكم.

د- الفساد في الاستدلال:

تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك

(١) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: العيوب المبطللة للحكم، مرجع سابق، ص ١٨٨ وما بعدها.

العناصر التي ثبتت لديها، وبهذا يتضح أن صور الخطأ في تفسير الوقائع التي تؤدي إلى الفساد في الاستدلال ثلاث صور، هي:

الأولى: أن يقع الخطأ في أمر يتعلق بالدليل الذي ثبتت به الوقائع، كعيب مخالفة الثابت بالأوراق، أو الخطأ في الإسناد. الثانية: أن يقع الخطأ في الوقائع الثابتة بدليل صحيح لأمر يتعلق بعدم فهم المحكمة لها، كما لو فهمت المحكمة واقعة ما فهمًا خاطئًا، وترتب على هذا الفهم الخاطئ نتائج خاطئة تشوب الحكم بالفساد في الاستدلال. الثالثة: عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم، كما لو استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها^(١).

خامسا : الجزء المترتب على تعيب أسباب الحكم:

لم يرتب المشرع البطلان صراحة في المادة (١٧٨) مرافعات، إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم.

(١) د. عبدالحكم فوده: أسباب صحيفة الاستئناف، مرجع سابق، ص ٣٦٠ - د. ياسر عبدالفضيل عمران، مرجع سابق، ص ٢٠٠ وما بعدها.

الفصل الثاني

الطعن في الأحكام القضائية

نظم المشرع طرق الطعن في الأحكام في الباب الثاني عشر من قانون المرافعات (المواد ٢١١-٢٧٣)، بحيث أصبحت هذه الطرق هي الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر، والتي بمقتضاها يتمكن الخصم من التظلم من الحكم الصادر ضده بقصد إعادة النظر فيه، وقد هدف المشرع من وراء ذلك التوفيق بين اعتبارات العدالة التي تقتضي وجود وسيلة لمراقبة صحة الأحكام وبين الحاجة إلى استقرار الحقوق والمراكز القانونية، فنظم طرق الطعن في الأحكام للتوفيق بين هذه الاعتبارات المتعارضة ونظرا لما تتمتع به مرحلة الطعن في الحكم من أهمية تفوق مرحلة إصدار الحكم ذاته، فإن المشرع كان شديد الحرص في تنظيم طرق الطعن وإجراءاته ومواعيده وضمائنه إصداره في هذه المرحلة.

فإذا كان المشرع أجاز الطعن في الحكم القضائي، فإنه في الوقت ذاته حدد وسيلة هذا الطعن ووضع ضوابط ومواعيد محددة لاستعمالها، فأعطى للخصم الحق في أن يعيد طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة كي تعيد النظر فيما فصل فيه حكم أول درجة في حدود طلبات الخصوم أمامها، ولكن من خلال الوسائل التي نظمها المشرع وبالإجراءات والمواعيد التي نص عليها.

وطرق الطعن في الأحكام ليست واحدة، وإنما تتنوع إلى طرق عادية وهي المعارضة (قبل إلغائها) والاستئناف، وأخرى غير عادية، وهي التماس إعادة النظر والنقض، وقد نص المشرع على أحكام خاصة بكل طريق من هذه الطرق، سواء العادية أو غير العادية، كما قرر قواعد عامة بشأن الطعن في الأحكام بصفة عامة أيا كان طريق الطعن بالنقض.

ونتناول الطعن في الأحكام في مبحثين، الأول: القواعد العامة للطعن في الأحكام، والثاني: طرق الطعن في الأحكام.

المبحث الأول

القواعد العامة للطعن في أحكام القضاء

نتحدث عن القواعد العامة للطعن في الأحكام من خلال تعريف الطعن، ثم نبين قواعد الطعن من حيث الأحكام القابلة للطعن، والخصوم فيه، ومواعيده، وإعلانه، وذلك على النحو التالي :

أولاً: تعريف طرق الطعن في الأحكام :

طرق الطعن في الأحكام هي الوسائل القضائية التي حددها القانون لمراقبة صحة الأحكام ومراجعتها، وبها يتمكن المحكوم عليه في الحكم القضائي من إصلاح الأخطاء المحتملة من القاضي الذي أصدره أثناء النزاع^(١).

وقد جعل المشرع وسيلة مراجعة الأحكام هي الطعن فيها، سواء كان الخطأ الذي وقع فيه القاضي يتعلق بالإجراءات أو يتعلق بالتقدير، لذلك منع مراجعة الأحكام عن طريق رفع دعوى مبتدأه ببطالان الحكم، مقررًا بذلك قاعدة هامة من قواعد التقاضي، وهي قاعدة لا دعاوى بطلان ضد الأحكام.

ثانياً: قواعد الطعن:

تتعلق هذه القواعد بالأحكام القابلة للطعن، وبالخصوم في الطعن، وبمواعيد الطعن، وإعلانه، وذلك على النحو التالي:

١- الأحكام القابلة للطعن:

تقضي القاعدة العامة أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها^(٢)، فالأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة دون أن تنها كلها سواء تعلقت بالإجراءات كالحكم برفض الدفع بطلان صحيفة الدعوى، أو بمسألة فرعية متعلقة بالإثبات كالحكم الذي يفصل في الادعاء الفرعي بالتزوير، أو بجواز قبول الدعوى كالحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو بموضوع النزاع كالحكم بتحديد القانون الواجب التطبيق، لا يجوز الطعن الفوري عليها وإنما يمكن الطعن فيها مع الحكم المنهي للخصومة (مادة ٢١٢ مرافعات).

(١) د. محمود السيد التحيوي: الطعن في الأحكام القضائية ، مرجع سابق، ص ١.

(٢) نقض: الطعن رقم ٧٤٤ لسنة ٧١ قضائية - جلسة ٢٨/١٠/٢٠٠٣م.

الاستثناءات على القاعدة العامة: بعد أن نص المشرع على جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الحكم المنهي للخصومة، أورد عدة استثناءات على ذلك، وهذه الاستثناءات هي: الأحكام الوقتية والمستعجلة، والأحكام الصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة.

٢- الخصوم في الطعن:

الخصوم في الطعن هما الطاعن والمطعون ضده، وكلاهما يجب أن تتوافر فيه عدة شروط حتى يصح اعتباره طرفاً في خصومة الطعن، ووفقاً لنص المادة (٢١١) مرافعات فإنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ولذلك يشترط في الطاعن: أن يكون طرفاً في الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه، وأن يكون الطاعن محكوماً عليه، كما يشترط في الطاعن ألا يكون قد قبل الحكم.

كما يشترط في المطعون ضده توافر أربعة شروط:

- أن تكون له صفة في الطعن بأن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم.
- أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني المطعون فيه.
- أن تتوافر في حقه أهلية التقاضي وقت رفع الطعن.
- ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه، حيث تنعدم مصلحة الطاعن في مقاضاته^(١).

٣- مواعيد الطعن:

يقصد بمواعيد الطعن الأجل الذي حددها القانون للطعن في الحكم والتي بانقضائها يسقط الحق في الطعن، وهذه المواعيد تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها، ويجوز الدفع بانقضائها في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها^(٢).

(١) ويقبل الطعن الموجه إلى من تنازل عن الحكم إذا استند الطعن إلى مجرد مصلحة أدبية تبرر إلغاء الحكم، كما لو أضر الحكم بشرف الطاعن وسمعته التجارية وتعلقت مصالحة الأدبية بإلغائه. (د. أحمد أبو الوفا: نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ص ٨٣٧-٨٤٠. والتنازل عن الحكم ليس مجرد تنازل عن ورقة من أوراق المرافعات، وإنما هو تنازل عن الحق الموضوعي الثابت بهذا الحكم، فلا يجوز أن ترفع الدعوى به من جديد. (أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: التنازل عن الحق في الدعوى) مرجع سابق، ص ٣٦.

(٢) د. علي بركات: الوجيز، مرجع سابق، ص ٢٥١ - د. ماهر إبراهيم السداوي، ص ٢٦١.

ويبدأ ميعاد الطعن كقاعدة عامة من تاريخ صدور الحكم وذلك باعتبار أن المحكوم عليه طرفاً في الخصومة ويفترض فيه متابعتة لها وما يتم فيها من إجراءات وأهمها الحكم الصادر فيها، وذلك باستثناء الحالات التي نص عليها المشرع والتي يبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم.

٤- إعلان الطعن:

أوجب المشرع بعد رفع الطعن أن يتم إعلانه إلى المطعون ضدهم، وذلك كما هو الحال بالنسبة لإعلان صحيفة الدعوى، ويخضع إعلان الطعن للقواعد العامة المنظمة للإعلان، والمنظمة لإعلان صحيفة الدعوى، فضلاً عن خضوعه للقاعدة الخاصة المنصوص عليها في المادة (١/٢١٤) مرافعات.

ذلك أن المشرع أخضع إعلان الطعن لقاعدة خاصة نص عليها في هذه المادة، وتقضي هذه القاعدة بأن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه، وذلك لضمان وصول صحيفة الطعن إلى المطعون ضده، ومن ثم فلا يجوز إعلان الطعن في الموطن المختار المبين في صحيفة الدعوى، لاحتمال انقطاع صلة المطعون ضده بهذا الموطن بعد صدور الحكم في الدعوى^(١)، إلا إذا كان المطعون ضده هو المدعي في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يكن قد بين في صحيفة دعواه سوى موطنه المختار.

(١) د. علي بركات: الوجيز في شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٢٦٣ .

المبحث الثاني

طرق الطعن في الأحكام

تنقسم طرق الطعن في الأحكام إلى طرق عادية وأخرى غير عادية، وأساس هذا التقسيم أن المشرع لم يحصر أسباب الطرق العادية ولم يحدد حالاتها، بحيث يجوز للطاعن بطريق عادي أن يبني طعنه على ما يشاء من الأسباب والعيوب التي تعيب الحكم المطعون فيه، سواء أكانت هذه الأسباب ترجع إلى ما يشوب الحكم من عيب في إجراءاته، أم خطأ في تطبيق القانون، أم من حيث فهم المحكمة للوقائع وتقديرها وتحصيل النتائج منها. بينما حصر أسباب طرق الطعن غير العادية وحدد حالاتها، بحيث لا يجوز قبول الطعن إلا لعيب من العيوب التي نص عليها المشرع.

ونتناول طرق الطعن في الأحكام في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: طرق الطعن العادية.

المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية.

المطلب الأول

طرق الطعن العادية

في ظل قانون المرافعات الملغي رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ كانت هناك وسيلتان من الوسائل العادية للطعن في الأحكام القضائية. الأولى: المعارضة، والثانية: الاستئناف، وقد تم إلغاء نظام المعارضة في الأحكام المدنية في قانون المرافعات الحالي، ومن ثم؛ فإن طريق الطعن العادي في الأحكام المدنية هو الاستئناف.

الاستئناف

أولاً : فكرة الاستئناف والتعريف به:

أ- التعريف بالاستئناف والمحاكم التي يناط بها نظره:

الاستئناف هو طريق طعن عادي في الأحكام الابتدائية التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى، وهو يرفع إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي، أصدرت الحكم، بهدف إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله. وفيه ينظر ذات النزاع من قاضي أعلى درجة ممن فصل فيه لأول مرة، ويتم فيه إعادة نظر النزاع في الواقع وفي القانون ولقاضي الاستئناف ذات سلطات قاضي أول درجة^(١).

(١) د. نبيل إسماعيل عمر: نطاق الطعن بالاستئناف، دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٨م، ص ٧.

والمحاكم التي يناف بها نظر الاستئناف هي محاكم الدرجة الثانية عموما وتسمى بمحاكم الاستئناف، وهي:

١- المحاكم الابتدائية المنعقدة بهيئة استئنافية: وهذه المحاكم تستأنف أمامها الأحكام الابتدائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم الجزئية، أو من قاضي الأمور المستعجلة (مادة ٤٧/٢). كما تستأنف أمامها أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية والوقفية أي كانت قيمتها (مادة ٢٧٧).

٢- محاكم الاستئناف (العالي): وتختص بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية (مادة ٤٨). كما تختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات التي رفعت إليها بصفة أصلية، وفقا للمادة (٤٣/٦).

ثانيا: الأحكام الجائز استئنافها، وغير الجائز استئنافها:

أ- القاعدة العامة:

هي أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك^(١). وقد نص المشرع على نصاب معين للأحكام الجائز استئنافها، فالأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى التي تزيد عن نصابها الانتهائي تكون ابتدائية وقابلة للطعن بالاستئناف، أما الأحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تزيد عن النصاب الانتهائي فإنها تكون انتهازية غير قابلة للاستئناف. والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن نصابها الانتهائي تكون ابتدائية وقابلة كذلك للطعن بالاستئناف، وعلى العكس من ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في دعوى لا تزيد قيمتها عن نصابها الانتهائي يكون انتهازيا وغير قابل للاستئناف^(٢).

وبهذا يتضح أن للاستئناف نصاب معين، وأن الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا بلغت نصابه، فالمشرع قدر أن مصلحة الخصوم تقتضي في بعض الحالات منع الاستئناف وليس إجازته، كما أن حسن سير القضاء يستلزم أحيانا قصر التقاضي على درجة واحدة، لا سيما في الدعاوى قليلة القيمة أو قليلة الأهمية والتي لا تحتمل مصاريف التقاضي على درجتين.

(١) د. فتحي والي، مرجع سابق، ص ٧٨٤.

(٢) هناك أحكاما يجوز استئنافها بصرف النظر عن قيمة الدعوى، وأهمها: الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (مادة ٢٢٠ مرافعات)، والأحكام الصادرة بصفة انتهازية والتي يشوبها بطلان سواء لعب ذاتي فيها أو لعب في الإجراءات أدى إلى بطلانها (مادة ٢٢١ مرافعات)، والحكم الصادر بصفة انتهازية على خلاف حكم سابق لم يحز بعد قوة الأمر المقضي (مادة ٢٢٢ مرافعات). (د. فتحي والي، الوسيط، مرجع سابق، ص ٧٨٨-٧٨٩).

(ب) الأحكام التي يجوز استئنافها استثناءً:

استثناء من القاعدة العامة التي سبق بيانها؛ فإن هناك أحكاماً قرر المشرع قابليتها للاستئناف، وإن لم تكن في حدود نصاب الاستئناف، وهذه الأحكام هي:

- ١- الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة.
- ٢- الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
- ٣- الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
- ٤- الأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.

(ج) الأحكام التي لا يجوز استئنافها استثناءً:

هناك أحكاماً لا يجوز استئنافها أياً كانت قيمتها، وهذه الأحكام نص عليها المشرع في عدة مواضع، مقررراً عدم جواز الطعن فيها بالاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى التي صدر فيها الحكم، ولو كانت صادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم، وقد قصد المشرع من ذلك تقصير أمد النزاع وعدم إطالة الفصل في الدعوى بإعادة نظرها أمام محكمة الاستئناف، ومن أمثلة هذه الأحكام:

- ما نصت عليه المادة (٢/٤٦) من عدم قابلية الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، للاستئناف.
- وما نصت عليه المادة (١/٢٩٥) من أن الحكم الصادر من قاضي التنفيذ في المنازعة في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما أودع خزانة المحكمة من نقود أو أوراق مالية على ذمة الكفالة. يكون انتهائياً وغير قابل للاستئناف.
- وما نصت عليه المادة (٤٥٦) من أنه لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة بإيقاف البيع أو المضي فيه، وذلك في دعوى الاستحقاق الفرعية.

(د) الاتفاق على عدم استئناف الحكم:

أوردت الفقرة الثانية من المادة (٢١٩) مرافعات حكماً خاصاً بشأن جواز التنازل عن الحق في استئناف الحكم، فنصت على أنه "يجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً".

ثالثاً: إجراءات الاستئناف:

يرفع الطعن بالاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن بالاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشمل هذه الصحيفة-فضلاً عن البيانات الواجبة في صحيفة الدعوى- على بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف (مادة ٢٣٠ مرافعات).

بيانات صحيفة الطعن بالاستئناف:

صحيفة الاستئناف شأنها شأن جميع الأوراق التي تعلن بواسطة المحضرين يتعين أن تشمل على جميع بيانات أوراق المحضرين المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون المرافعات إضافة إلى استكمالها للبيانات المنصوص عليها في المادة (٦٣) مرافعات، وبالإضافة إلى البيانات التي خصتها بها المادة (٢٣٠) مرافعات، وهي:

- ١- بيان الحكم المستأنف وتاريخه: حيث يجب أن تشمل صحيفة الاستئناف على بيان المحكمة التي أصدرت الحكم، ورقم القضية الصادر فيها الحكم، وتاريخه، وذلك بقصد بيان الحكم المطعون فيه على نحو ناف للجهالة^(١) ولا يشترط في ذلك أن ترد هذه البيانات بشكل معين، وإنما المقصود أن يرد هذا البيان بطريقة تؤدي إلى عدم التجهيل بالحكم المستأنف^(٢).
- ٢- أسباب الاستئناف: والمشرع لم يقيد المستأنف - كأصل عام - بأسباب معينة يبديها في صحيفة استئنافه، لأن الاستئناف كطريق عادي من طرق الطعن يتسع لأي سبب من الأسباب سواء كان هذا السبب يتعلق بالقانون أو بالشكل أو بالموضوع، والقصد من البيان الخاص بأسباب الاستئناف ضمان جدية الاستئناف، ولا يتقيد المستأنف بالأسباب التي ذكرها في صحيفة استئنافه أثناء نظر النزاع، فله أن يعدل عنها إلى غيرها من الأسباب أو يتنازل عن بعضها أو يضيف إليها^(٣).
- ٣- طلبات المستأنف: وذلك بتحديد الحكم القضائي الذي ينعي عليه المستأنف، ليتحدد بذلك نطاق الطعن بالاستئناف^(٤)، فإذا اشتمل الحكم القضائي المستأنف على عدة أجزاء لغير صالح

(١) د. أحمد السيد صاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٨٧٦.

(٢) "مجرد الخطأ في تاريخ الحكم المستأنف أو في رقم الدعوى الصادر فيها هذا الحكم لا يكون مدعاة للتجهيل بموضوع الاستئناف مادامت البيانات الأخرى التي تضمنتها الصحيفة تكفي - بما لا يدع مجالاً لأي شك - في تعيين الحكم المطعون فيه" (الطعن رقم ٧٢٥ لسنة ٤٠ قضائية - جلسة ١٩٧٥/٢/٢٦).

(٣) د. أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص ٨٧٧.

(٤) د. نبيل إسماعيل عمر: الطعن بالاستئناف وإجراءاته، منشأة المعارف، ١٩٨٠م، ص ٣١٥.

المستأنف، وأشار المستأنف إلى بعضها فقط في صحيفة الطعن بالاستئناف، فإن ذلك يعد قبولاً منه بالأجزاء الأخرى من الحكم. أما إذا لم يشر المستأنف إلى جزء محدد من الحكم فإنه يعتبر طاعناً بالاستئناف في جميع أجزاء الحكم القضائي التي تكون في غير صالحه^(١).

ويتربط على إغفال أي بيان من هذه البيانات الثلاثة بطلان صحيفة الاستئناف، حيث نصت على البطلان صراحة المادة (٢٣٠) مرافعات بنصها على أنه "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة".

٤- توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف: حيث يجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وإلا كانت الصحيفة باطلة، ولم يرد النص على هذا البيان في المادة (٢٣٠) مرافعات وإنما ورد النص عليه في المادة (٥٨) من قانون المحاماة المصري، والغرض من هذا البيان رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص للمتقاضين في ذلك الوقت، لأن إشراف مثل هذا المحام على صحيفة الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها^(٢).

ويتربط على عدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع أمامها الطعن بالاستئناف، بطلان صحيفة الطعن بالاستئناف، وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. على أنه يجوز تصحيح هذا البطلان باستيفاء التوقيع في الجلسة خلال ميعاد الاستئناف.

ميعاد الطعن بالاستئناف:

ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى العادية، وخمسة عشر يوماً بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، ويكون الميعاد ستين يوماً بالنسبة للاستئناف المرفوع من النائب العام (مادة ٢٢٧ مرافعات).

وتجدر الإشارة إلى أن ميعاد الاستئناف يبدأ طبقاً للقواعد العامة في الطعن من تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى "المستأنف"، إلا إذا نص المشرع على بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم، في الحالات المنصوص عليها في المادة (٢١٣) مرافعات.

وصحيفة الاستئناف يتبع بشأنها ذات القواعد المقررة لصحيفة الدعوى، وهذه القواعد توجب إعلان الصحيفة إلى المستأنف، باعتبار الإعلان هو الإجراء الذي تنعقد به الخصومة.

(١) د. محمود السيد التحيوي: الطعن في الأحكام القضائية، مرجع سابق، ص ٧٠.

(٢) د. أحمد السيد صاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٨٧٧.

رابعاً : نطاق القضية في الاستئناف:

يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفع وأوجه دفاع، لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء^(١). وتتقيد محكمة الاستئناف عند نظرها للقضية بثلاثة قيود: هي: التقيد بنطاق خصومة أول درجة من حيث الخصوم والموضوع، وأن تتقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاستئناف فقط^(٢)، وألا يترتب على رفع الاستئناف الإساءة لمركز المستأنف.

(أ) نطاق خصومة الاستئناف من حيث الخصوم:

إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين، فإنه لا يجوز في خصومة الاستئناف إدخال شخص لم يكن طرفاً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وإلا فوت في حق هذا الشخص درجة من درجات التقاضي، فنصبح القضية أمام محكمة الاستئناف تضم خصوما تمتعوا بحقهم في التقاضي على درجتين، وآخرين حرّموا من إحدى درجتي التقاضي، وهو ما لا يجوز، لما يمثله ذلك من إخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء.

(ب) نطاق خصومة الاستئناف من حيث الموضوع:

ثمة قواعد هامة تحكم نطاق الاستئناف من حيث موضوعه أمام المحكمة الاستئنافية. وهذه القواعد هي:

القاعدة الأولى: قاعدة الأثر الناقل للاستئناف:

نصت المادة (٢٣٢) مرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط". وهذا النص يقرر قاعدة مهمة من قواعد المرافعات، وتعرف بالأثر الناقل للاستئناف، ومفاد هذا الأثر أو هذه القاعدة، أن الاستئناف ينقل النزاع إلى المحكمة الاستئنافية بكل ما اشتمل عليه من مسائل واقعية وقانونية، فينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف بما سبق وأن أبدي من دفع وأوجه دفاع وطلبات أمام محكمة الدرجة الأولى، وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، وبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني في هذا الموضوع على ضوء ما قدم أمام محكمة أول درجة^(٣).

(١) د. أحمد السيد صاوي: الوسيط في شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ٨٨٣.

(٢) نقض: الطعن رقم ٨٥٠٥ لسنة ٦٥ قضائية - جلسة ٢٠٠٨/٢/٢٦ م.

(٣) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، ج٤/٩٧٠- المستشار. سيد البغال، المطول، ج٣/٣١٨.

القاعدة الثانية: لا ينقل الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه:

فالاستئناف لا ينقل إلى المحكمة الاستئنافية سوى الطلبات الموضوعية التي فصلت فيها محكمة أول درجة واستنفدت ولايتها بشأنها، ومن ثم لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في طلبات لم تكن مطروحة على محكمة أول درجة حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي^(١).

ولذلك فإنه إذا أغفلت محكمة أول درجة الفصل في بعض الطلبات، فلا يجوز طرح هذه الطلبات على محكمة الاستئناف، كما أنه إذا قدم إلى محكمة أول درجة طلب أصلي وآخر احتياطي، ففصلت في الطلب الأصلي ولم تتعرض للطلب الاحتياطي، فإن على محكمة الاستئناف إذا ما ألغت الحكم، أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلب الاحتياطي، وإذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، فإن على محكمة الاستئناف إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لتفصل في موضوعها^(٢).

القاعدة الثالثة: جواز تقديم أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف:

ومقتضى هذه القاعدة أنه يجوز للخصوم أمام محكمة الاستئناف تقديم أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة غير التي قدمت أمام محكمة أول درجة، وعلى المحكمة أن تنظرها وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى. وهذه القاعدة قررتها المادة (٢٣٣) بنصها على أنه "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى".

وإعمال هذه القاعدة يقتضي أمرين: الأول: ألا يكون الحق في التمسك بأوجه الدفع والدفاع قد سقط أمام محكمة أول درجة. والثاني: ألا يتضمن الدفع أو الدفاع الجديد طلباً جديداً لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة.

القاعدة الرابعة: عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف:

مفاد نص المادة (٢٣٥) مرافعات أنه لا يجوز إضافة أي طلب جديد لم يكن قد أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى، لما في ذلك من إهدار لمبدأ التقاضي على درجتين بتفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم الموجهة إليه هذه الطلبات، ولأن الطلبات الجديدة لم تطرح على

(١) د. محمد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص ١٠٣٦.

(٢) د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص ٨٨٤ - د. عبد التواب مبارك، مرجع سابق، ص ٥٩٧.

محكمة الدرجة الأولى، حتى يتظلم منها أمام محكمة الاستئناف. مع مراعاة الاستثناءات على هذه القاعدة.

سادسا: الحكم في الاستئناف:

يسري على الاستئناف القواعد التي تنظم الحكم في أول درجة، سواء من حيث إصداره أو شكله أو تصحيحه أو تفسيره (مادة ٢٤٠ مرافعات). وتجب التفرقة في شأن حكم الاستئناف بين حالتين:

الأولى: إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في موضوع الدعوى، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل أو أن البطلان في الإجراءات مما أثر في الحكم، فإن عليها أن تتصدى للموضوع وتفصل فيه بقضاء جديد، ولا تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، لاستنفاد ولايتها بالفصل في الموضوع.

الثانية: إذا لم تكن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في الموضوع، وإنما انصب قرارها على إصدار حكم إجرائي غير فاصل في موضوع الدعوى، كالحكم بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى، أو بسقوط الخصومة، أو باعتبارها كأن لم تكن، ورأت محكمة الاستئناف غير ذلك، فإنها تلغي الحكم، وتعيد القضية لمحكمة أول درجة لتفصل في الموضوع، لعدم استنفاد ولايتها بالحكم الإجرائي الذي سبق وأصدرته.

المطلب الثاني

طرق الطعن غير العادية

حصر المشرع أسباب طرق الطعن غير العادية وحدد حالاتها، بحيث لا يجوز قبول الطعن إلا لعيب من العيوب التي نص عليها، وهناك وسيلتين من الوسائل غير العادية للطعن في الأحكام القضائية، الأولى التماس إعادة النظر، والثانية الطعن بالنقض. ونتحدث عن الطعن بالتماس إعادة النظر في فرع أول، ثم نتحدث عن الطعن بالنقض في فرع ثان، على النحو التالي:

الفرع الأول

التماس إعادة النظر

أولاً: ماهية التماس إعادة النظر:

التماس إعادة النظر "طريق غير عادي للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون على سبيل الحصر، ولا يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه، ولكنه يستهدف محو هذا الحكم، ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره، ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد"^(١).

المحكمة المختصة بنظر التماس إعادة النظر:

ويرفع التماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك لأن الالتماس يبني على أسباب غابت عن هذه المحكمة لسهو غير متعمد أو فعل يرجع إلى أحد الخصوم، ولو أنها تنهت إليه لتغير حكمها، فيكفي تنبيهها إلى ذلك لتتدارك ما وقع في الحكم من خطأ متى تبينت سببه^(٢).

ويوجه التماس إعادة النظر إلى الأحكام النهائية، سواء كانت هذه الأحكام صادرة من محاكم الدرجة الثانية، أو محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي، بل يجوز الطعن في حكم النقض بالتماس إعادة النظر عندما تتصدى للموضوع وتفصل فيه.

ثانياً: أسباب التماس إعادة النظر:

لما كان المشرع قد نص على التماس إعادة النظر كطريق غير عادي للطعن في الأحكام، وأناط الاختصاص به إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، قاصداً من ذلك تمكين المحكوم عليه من

(١) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: الطعن بالنقض أمام المحاكم العليا، مرجع سابق، ص ٥٢٣.

(٢) د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص ٩.

فرصة أخيرة لإصلاح صور خاصة من الخطأ الذي تقع فيه المحاكم في أحكامها النهائية الصادرة في حدود نصائها النهائي، فإنه قد ذكر أسباب الالتماس على سبيل الحصر، وهذه الأسباب هي:

السبب الأول: وقوع غش من الخصم أثر في الحكم :

يشترط وفقاً للفقرة الأولى من المادة (٢٤١) مرافعات للطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر، أن يكون قد وقع من الخصم غشاً، كان من شأنه التأثير في حكم المحكمة الذي صدر بصفة انتهائية.

والغش الذي يجيز التماس إعادة النظر "هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به خفاء أمره عليه"^(١). وهو يشمل كافة أنواع التدليس والمفاجأة والوسائل التي تستعمل بواسطة خصم في مواجهة خصم آخر بقصد تضليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ.

ويشترط في الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر في الأحكام توافر أربعة شروط، هي:

- ١ - حصول غش من أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى باستعمال طرق احتيالية لإخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة.
- ٢ - أن يكون الغش مجهولاً من الخصم أثناء المرافعة في الدعوى.
- ٣ - أن يحصل الغش خفية بحيث يستحيل على الخصم دفعه سواء أكانت الاستحالة مادية أو أدبية.
- ٤ - أن يكون الغش قد أثر على المحكمة في حكمها^(٢).

ومن أمثلة الغش: قيام الخصم بمنع وصول الإعلان إلى خصمه، أو أن يستعمل الخصم ضد خصمه وسيلة أو أكثر من وسائل الإكراه ليمنع خصمه من أن يبدي دفاعه في القضية. أو أن يتفق الخصم مع محامى خصمه على اتخاذ إجراء يضر بموكله. أو أن يقوم الخصم بالتأثير على الشهود بطرق فيها احتيال أو إغواء أو إكراه، لإنكار الحقيقة أو الشهادة بغيرها^(٣).

السبب الثاني: صدور الحكم بناء على أوراق مزورة :

ويشترط لقبول التماس إعادة النظر لصدور الحكم بناء على أوراق مزورة :

- ١ - ثبوت تزوير الأوراق التي استند إليها الحكم، سواء أكان ذلك بإقرار الخصم، أو ممن حرر الورقة، أو كان بحكم قضائي بالتزوير مدنياً كان هذا الحكم أم جنائياً.
- ٢ - أن يثبت تزوير الأوراق بعد صدور الحكم الملتمس فيه، وقبل رفع الالتماس عنه.
- ٣ - أن يكون الحكم قد بنى على هذه الأوراق.

(١) الطعن رقم ٥٢٩٣ لسنة ٦٢ قضائية - جلسة ١٩٩٤/٤/٢١ .

(٢) د. أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص ٢٣.

(٣) د. أحمد هندي: قانون المرافعات المدنية والتجارية، الخصومة والحكم والطعن، ص ٧٠٢.

السبب الثالث: إذا كان الحكم قد بنى على شهادة مزورة :

ويشترط لقبول الالتماس بناء على هذه الحالة، توافر الشروط الآتية :

- ١- أن يبنى الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد: وذلك بأن تكون لهذه الشهادة تأثير كلى على المحكمة في إصدار الحكم، بمعنى أن يكون مبنياً على هذه الشهادة ومؤسساً عليها.
- ٢- أن يصدر حكم قضائي يثبت تزوير هذه الشهادة؛ ويستوى أن يكون هذا الحكم صادراً من القضاء المدني أو القضاء الجنائي.
- ٣- أن يصدر الحكم القضائي بعد صدور الحكم الملتمس فيه وقبل رفع الالتماس.

السبب الرابع : حصول الملتمس على أوراق قاطعة في الدعوى :

ويشترط لقبول الالتماس وفقاً لهذا السبب توافر الشروط الآتية :

- ١- أن تكون الورقة التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى.
- ٢- أن تكون الورقة قد حجزت أثناء نظر القضية بفعل الخصم الآخر.
- ٣- ألا يكون الخصم على علم بوجود الورقة تحت يد خصمه.
- ٤- أن يحصل الملتمس بعد صدور الحكم على الورقة.

السبب الخامس: إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه:

إذا قضت المحكمة في حكمها بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، كان للخصم أن يطلب من ذات المحكمة بطريق التماس إعادة النظر العدول عما قضت به. ويجب أن يكون قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم في الدعوى القضائية أو بما يجاوز طلباتهم القضائية نتيجة سهو غير متعمد، أو خطأ غير مقصود منها، وذلك حتى لا يكون هناك حرج في طرح النزاع عليها بطريق التماس إعادة النظر^(١).

السبب السادس: إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

إذا جاء منطوق الحكم مناقضاً بعضه بعضاً، بأن كان يستحيل التوفيق بين أجزاء المنطوق ويستحيل تنفيذها معاً، فإنه يجوز الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر. والتناقض الذي يصلح سبباً للطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر، هو التناقض بين أجزاء المنطوق، أما التناقض بين الأسباب بعضها مع البعض الآخر، فلا يصلح سبباً للالتماس.

السبب السابع : صدور الحكم على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى:

ويقصد بهذا السبب من أسباب التماس إعادة النظر، حالة المحكوم عليه في الحكم إذا كان شخصاً اعتبارياً ولم يمثل في الدعوى ممن له سلطة تمثيله قانوناً، أو كان تمثيله غير صحيح

(١) د. محمود السيد التحيوي: الطعن في الأحكام القضائية، مرجع سابق، ص ١٦٠.

وكذلك إذا كان المحكوم عليه شخصا طبيعيا ولم يتم تمثيله في الخصومة، كما لو كان قاصرا ولم يمثله وليه أو وصيه، أو كان تمثيله في الخصومة غير صحيحا، ففي هذه الحالة يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر وفقا لما ورد بالفقرة السابعة من المادة ٢٤١ مرافعات.

السبب الثامن: صدور الحكم على شخص لم يمثل في الدعوى ويعتبر حجة عليه:

يواجه هذا السبب من أسباب التماس إعادة النظر حالة من صدر ضده حكم، يعتبر حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل في الدعوى، لأنه يعتبر ممثلا في الدعوى وأن لم يكن خصما ظاهرا فيها، وإنما كان تمثيله في الخصومة بواسطة غيره.

ثالثا: عودة النزاع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم عند توافر أحد هذه الأسباب :

إذا توافر سبب من هذه الأسباب والتي ورد النص عليها في المادة (٢٤١) مرافعات كان للمتمس في خلال أربعين يوما من صدور الحكم - عدا في الحالات الأربع الأولى والتي يبدأ فيها ميعاد الالتماس من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، وكذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة والتي يبدأ فيها الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا، وكذلك من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم في السبب الثامن^(١) - أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إعادة النظر فيما فصلت فيه على الرغم من حيازة الحكم السابق صدوره لحجية الأمر المقضي.

رابعا: أثر رفع الالتماس على تنفيذ الحكم المطعون فيه:

وفقا لنص المادة (٢٤٤) مرافعات فإنه لا يترتب على رفع التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.

(١) الطعن رقم ١٣٣٥٨ لسنة ٧٨ قضائية - جلسة ٢٠١١/٦/٤١ م.

الفرع الثاني الطعن بالنقض

أولاً: ماهية الطعن بالنقض وميعاده:

الطعن بالنقض طريق غير عادي للطعن في الأحكام القضائية الصادرة بصفة نهائية، لا يطرح على محكمة النقض النزاع برمته، وإنما يطرح عليها الحكم القضائي المطعون فيه بطريق النقض، لتراقب ما يشوبه من عيوب معينة وردت على سبيل الحصر في المواد (٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠) من قانون المرافعات^(١).

"والفكرة الأساسية للنقض هي إيجاد محكمة عليا على قمة جهة القضاء تتولى رقابة الأحكام الصادرة من محاكمها من الناحية القانونية، وذلك بإتاحة الفرصة لذي الشأن بالطعن أمامها في هذه الأحكام على أساس ما يشوبها من عيوب قانونية سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية"^(٢).

والقاعدة العامة أنه لا يطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أي كانت طبيعتها وفي حدود النصاب المقرر لطعن وفقاً للمادة (٢٤٨) مرافعات، واستثناء من ذلك يجوز الطعن في أي حكم انتهائي أي كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلاف حكم قضائي آخر، سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

والمقرر قانوناً أن محكمة النقض لا تعتبر درجة ثالثة لنظر النزاع (إذ التقاضي في مصر على درجتين فقط)، فهي لا تعيد النظر في وقائع النزاع التي فصل فيها الحكم، وإنما تقتصر وظيفتها على مراقبة القانون ومدى صحة تطبيقه من قبل محكمة الموضوع على واقعات النزاع؛ فالطعن بالنقض ليس امتداداً للخصومة الأولى، ولا درجة من درجات التقاضي، حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتها، من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل؛ إنما هو خصومة خاصة حرم فيها المشرع على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، إلا على النحو المبين في القانون، وجعل مهمتها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية، من حيث أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون، فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع^(٣).

(١) د. محمود السيد التحيوي (الطعن في الأحكام القضائية)، مرجع سابق، ص ١٠٧.

(٢) د. وجدي راغب فهد، مرجع سابق، ص ٦٦٣.

(٣) نقض: الطعن رقم ٩٧٣ لسنة ٥١ قضائية- جلسة ١٩٨٥/٣/٢٧.

ميعاد الطعن بالنقض:

ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما، وهذا الميعاد من المواعيد الناقصة بمعنى أن ينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه، ويخضع هذا الميعاد للقواعد العامة للطعن، من حيث بدئه ونهايته وحسابه ووقفه^(١)، ويستثنى من ميعاد الطعن بالنقض، الطعن بالنقض لمصلحة القانون والذي يقوم به النائب العام فهو لا يتقيد بميعاد (مادة ٢٥٢ مرافعات).

ثانيا: مستندات الطعن بالنقض:

وفقا لما نصت عليه المادة (٢٥٥) مرافعات، فإن مستندات الطعن بالنقض، التي يجب على الطاعن تقديمها، هي: أصل وصور صحيفة الطعن بالنقض بقدر عدد المطعون ضدهم، وصوره لقلم الكتاب، وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن بالنقض، ومذكرة شارحة لأسباب الطعن بالنقض، والمستندات المؤيدة للطعن بالنقض، ما لم تكن مودعة ملف القضية الموضوعية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت: صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه، وصوره من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، وإلا حكم بعدم قبول الطعن.

ووفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها، إذا كانت صحيفة الطعن بالنقض قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.

ثالثا: بيانات صحيفة الطعن بالنقض:

يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض (مادة ١/٢٥٣ مرافعات). ووفقا للمادة ٢/٢٥٣ مرافعات فإن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على البيانات الآتية:

(١) استثناء من القاعدة العامة، لا يتقيد الطعن الانضمامي بميعاد الطعن بالنقض، والطعن الانضمامي هو ما نصت عليه المادة (٢/٢١٨) مرافعات بنصها "على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصاص أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصاصه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصاص الباقي ولو بعد فواته بالنسبة إليهم".

ووفقا لهذا النص فإن الطعن الانضمامي يستثنى من القاعدة العامة في ميعاد الطعن بالنقض في ثلاث حالات: ١- صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. ٢- الالتزام بالتضامن. ٣- في دعوى يوجب القانون فيها اختصاص أشخاص معينين.

١- أسماء الخصوم: يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم^(١). والهدف من هذا البيان إعلان ذوي الشأن بمن رفع الطعن بالنقض من خصومهم في الدعوى القضائية حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ولا بد من ورود هذا البيان في الصحيفة ذاتها فلا يغني عن ذلك وروده في مستند آخر. ويترتب على خلو الصحيفة من هذا البيان بطلان الصحيفة بطلانا نسبيا غير متعلق بالنظام العام، ولا يتمسك به غير من شرع البطلان لمصلحته^(٢).

٢- بيان الحكم المطعون فيه: فيجب على الطاعن أن يذكر البيانات الخاصة بالحكم المطعون فيه، فيذكر منطوقه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره^(٣). بحيث ترد هذه البيانات بشكل كاف ترفع أي تجهيل بالحكم المطعون فيه. والحكمة من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه أن تتمكن محكمة النقض من رفع الطعن في الميعاد.

٣- أسباب الطعن بالنقض: حيث أوجبت المادة (٢٥٣) مرافعات أن تتضمن الصحيفة أسباب الطعن بالنقض، أي الأوجه التي ينعي بها الطاعن على قضاء الحكم المطعون فيه بالنقض^(٤). والحكمة من هذا البيان مراقبة ما إذا كان الطعن قد بني على أحد الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر حتى يتسنى قبول الطعن أو عدم قبوله وحتى لا يتمسك الطاعن بغيرها من الأسباب التي لا تتعلق بالنظام العام، وحتى يكون المطعون ضده على علم بأوجه الطعن فيتسنى له تحضير دفاعه. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

٤- بيان طلبات الطاعن: ويجب على الطاعن بالنقض أن يبين الجزء من الحكم القضائي المطعون فيه بالنقض، فإذا لم يحدد هذا الجزء اعتبر الطعن منصبا على جميع أجزاء الحكم المطعون فيه.

٥- توقيع محام على صحيفة الطعن بالنقض: حيث أوجبت المادة (٢٥٣) مرافعات أن تكون صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض، ويعد هذا التوقيع شرطا من شروط صحة وقبول الصحيفة. بأن يكون المحامي الموقع على عليها مقيدا بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.

(١) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: الطعن بالنقض أمام المحاكم العليا، مرجع سابق، ص ٢٥٧.

(٢) د. محمود السيد التحيوي: الطعن في الأحكام القضائية، مرجع سابق، ص ١١٨.

(٣) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني المرجع السابق، ص ٢٥٧.

(٤) د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة، الجزء الخامس، ص ٤٢٦.

الجزء المترتب على إغفال بيان هذه البيانات :

المتفق عليه أنه إذا لم يحصل الطعن بالنقض على الوجه الذي قرره المادة (٢٥٣) مرافعات بإيداع صحيفته قلم الكتاب - أو بتقرير وفقا لما جرى عليه قضاء النقض - فإن الطعن يكون باطلا، حيث نصت المادة المذكورة صراحة على البطلان في هذا الصدد. أما فيما يتعلق ببيانات الصحيفة فقد اختلف الفقه في شأن البطلان كجزاء على إغفال أحد هذه البيانات إلى رأيين^(١) :

الأول: أن البطلان نسبي لا يجوز أن يدفع به إلا من تقرر لمصلحته. الثاني: أن البطلان هنا بطلان مطلق تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالمادة (٢٥٣) مرافعات . وقد ذهب محكمة النقض في هذا الصدد إلى التفرقة بين نوعين من البيانات، الأول: البيانات المتعلقة بمصلحة الخصوم كأسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم، فقررت أن البطلان في هذه الحالة بطلان نسبي لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به الخصوم. الثاني: البيانات الأخرى، كبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الطعن، فإنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها لتعلق البطلان هنا بالنظام العام^(٢).

رابعاً: شروط الطعن بالنقض^(٣):

يشترط لصحة الطعن بالنقض وقبوله، توافر عدة شروط على النحو التالي:

- ١- أن ترد الأسباب في ذات صحيفة الطعن.
- ٢- أن تندرج الأسباب تحت إحدى حالات الطعن.
- ٣- التزام الأسباب نطاق الطعن بالنقض من حيث الموضوع والأشخاص.
- ٤- أن ترد أسباب الطعن في الصحيفة بوضوح.
- ٥- أن يرد النعي على محل من الحكم المطعون فيه.
- ٦- أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة.

النصاب القيمي للطعن بالنقض: اختصاص محكمة النقض وفقاً للمادة (٢٤٨) مرافعات يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى على النحو المنصوص عليه في المادة ذاتها، أو كانت غير مقدرة القيمة.

(١) المرجع السابق، ص ٤٣٤-٤٣٥.

(٢) د. أحمد مليجي، المرجع السابق، ص ٤٣٥.

(٣) د. محمد المنجي: الطعن بالنقض المدني، منشأة المعارف، ٢٠١٤م، ص ٥٠٨ وما بعدها.

خامسا: أوجه الطعن بالنقض:

الوجه الأول: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله:

١- مخالفة القانون:

يجب على المحكمة عند نظرها النزاع المطروح أمامها، أن تلتزم أحكام القانون سواء في ذلك الأحكام الموضوعية أو الإجرائية، فإن خالفها، كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون، ويقصد بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه الأعم، فيدخل فيه أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية.

ويقصد بمخالفة القانون في هذا الوجه من أوجه الطعن بالنقض أن تقوم المحكمة بإنكار قاعدة قانونية موجودة، أو تطبيق قاعدة غير موجودة، سواء في ذلك القواعد الموضوعية أم الإجرائية كما أشرنا.

والعبرة في مخالفة الحكم للقانون من عدمه بما ورد في منطوق الحكم لا بأسبابه، ذلك أن منطوق الحكم إذا صدر موافقا لصحيح القانون، فلا يضره ما قد يرد في الأسباب من تقارير قانونية خاطئة، إذ العبرة بالنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها^(١).

٢- الخطأ في تطبيق القانون:

تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نطاقا معيناً لسريان النص القانوني فتجاوزته المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع، كما لو طبقت المحكمة على الواقعة المطروحة عليها قاعدة قانونية لا تنطبق عليها، أو طبقتها على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة للنتائج المستهدفة من هذه القاعدة، أو رفضت تطبيق قاعدة على واقعة تنطبق عليها. ومثال ذلك أن يخطئ القاضي في تكييف الوقائع، فيؤدي به ذلك إلى تطبيق قانون آخر غير القانون الواجب التطبيق، كما لو أخطأ في تكييف عقد البيع على أنه هبة، وقام بتطبيق أحكام الهبة بدلا من أحكام البيع على النزاع الذي ينظره.

٣- الخطأ في تأويل القانون:

وتأويل القانون هو تفسيره وبيان مراد المشرع منه، وهو ما يوجب على المحكمة أن تسعى إلى الوقوف على معنى النص وما تغياه الشارع منه^(٢).

والخطأ في التأويل أو التفسير لا يتضمن مخالفة لنص القانون، وإنما يتضمن مخالفة لروح القانون بتفسيره على غير معناه الحقيقي، بأن يكون النص القانوني الذي أعمله القاضي محل

(١) نقض مدني ١٩٧١/٣/٢٥، مجموعة محكمة النقض ١-٢٢-٤١١-٦٤.

(٢) المستشار. أنور طلبه: شرح قانون المرافعات، الجزء الثالث، طبعة المركز القومي، ص ٤٤١.

خلاف في الحياة العملية، فيتبنى الحكم تفسيراً تراه محكمة النقض لا يتفق مع التفسير الصحيح^(١).

الوجه الثاني: إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم:

١- وقوع بطلان في الحكم:

والمقصود بوقوع بطلان في الحكم، أن يشوب الحكم - كعمل إجرائي- عيب البطلان سواء لعيب جوهري في إصداره أو النطق به أو تدوينه أو التوقيع عليه أو إيداعه، وسواء لعيب في أسبابه الواقعية كالقصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو التناقض في الأسباب التي بني عليه الحكم.

٢- وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم:

بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم معناه أن يكون هناك عيب شاب إجراء من إجراءات الدعوى، وأن تكون هناك صلة وثيقة بين هذا العيب، وبين الحكم الصادر في الدعوى، ومثاله صدور الحكم رغم عدم انعقاد الخصومة لعدم إعلان صحيفة أو بطلان هذا الإعلان، أو صدور الحكم في استئناف رفع من بعض المحكوم عليهم في موضوع لا يقبل التجزئة، دون أن تأمر المحكمة باختصاص باقي المحكوم عليهم.

الوجه الثالث: إذا صدر الحكم الانتهائي فاصلاً في نزاع على خلاف حكم آخر، سبق

أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي:

إذا صدر حكم قضائي مخالفاً لحكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي، فإن هذا الحكم يكون قابلاً للطعن عليه بطريق الطعن المناسب، أما إذا كان هذا الحكم انتهائياً فإنه يقبل الطعن بالنقض لمخالفته حكماً سابقاً حائزاً لقوة الأمر المقضي.

وقد عالجت المادة (٢٤٩) هذه الحالة أو هذا الوجه من أوجه الطعن بالنقض وطبقاً لهذه المادة فإنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة في حالة واحدة فقط، هي أن تكون هذه الأحكام مخالفة لحكم سابق حائزاً لقوة الأمر المقضي به. وذلك لأن قوة الأمر المقضي به من النظام العام، فما سبق الفصل فيه، لا يجوز الفصل فيه مرة أخرى. "يستوى في ذلك أن يكون حكم أول درجة صادراً من المحكمة الجزئية، أو من المحكمة

(١) د. محمد المنجي، مرجع سابق، ص ٦٣٤.

الابتدائية، أو من محكمة متخصصة، كما لو كان صادرا من قاضى التنفيذ، أو من المحاكم العمالية، أو من محاكم الأسرة، أو حتى صادرا من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية^(١).

ويشترط للطعن بالنقض وفقا لهذه الحالة توافر الشروط الآتية:

- ١- أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر انتهايا .
- ٢- أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي .
- ٣- وحدة الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين الصادر فيهما الحكمين .
- ٤- أن يكون هناك تناقض بين الحكمين.

سادسا: أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم المطعون فيه:

وفقا لنص المادة (٢٥١) مرافعات، فإنه لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا توافرت عدة شروط، وهي:

- ١- أن يطلب الطاعن وقف تنفيذ الحكم من محكمة النقض في صحيفة الطعن، بأن تشمل الصحيفة ذاتها على طلب وقف التنفيذ، فلا يجوز أن يأتي هذا الطلب مستقلا في ورقة أخرى ولو كانت مرفقة بصحيفة الطعن بالنقض.
- ٢- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
- ٣- أن يتبين لمحكمة النقض رجحان نقض الحكم المطعون فيه.

سابعا: الحكم في الطعن بالنقض:

يترتب على نقض الحكم المطعون فيه زواله واعتباره كأن لم يكن، وتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره، ويقتصر هذا الأثر على الحكم المنقوض، فلا يمتد إلى الخصومة ذاتها أو إلى الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الأولى، فتظل الخصومة قائمة أمام محكمة الاستئناف بكل ما ترتب عليها من آثار. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن (مادة ٢٧٢ مرافعات).

(١) أستاذي د. الأنصاري حسن النيداني: الطعن بالنقض أمام المحاكم العليا، مرجع سابق، ص ٣٥.

فهرس الموضوعات

١٧	<u>القسم الأول: النظام القضائي ونظرية الاختصاص:</u>	١
١٨	الباب الأول : النظام القضائي، ويشتمل على ثلاثة فصول :	٢
١٩	الفصل الأول : المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام القضاء .	٣
٣٦	الفصل الثاني : ترتيب المحاكم وتشكيلها .	٤
٥٢	الفصل الثالث : العاملون بالقضاء .	٥
١١١	الباب الثاني : نظرية الاختصاص والإحالة، ويشتمل على ستة فصول :	٦
١١٤	الفصل الأول : الاختصاص الولائي .	٧
١١٨	الفصل الثاني : الاختصاص النوعي .	٨
١٣١	الفصل الثالث : الاختصاص القيمي .	٩
١٤٨	الفصل الرابع : الاختصاص المحلي .	١٠
١٦٣	الفصل الخامس : مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام .	١١
١٧١	الفصل السادس : الإحالة .	١٢
١٨٣	<u>القسم الثاني: نظرية الدعوى وإجراءات التقاضي:</u>	١٣
١٨٧	الباب الأول: الدعوى القضائية.	١٤
١٨٧	الفصل الأول: عناصر الدعوى وشروط قبولها.	١٥
١٩٩	الفصل الثاني: تقسيمات الدعاوى.	١٦
٢٢٣	الباب الثاني: إجراءات التقاضي بوسيلة الدعوى.	١٧
٢٢٥	الفصل الأول: رفع الدعوى وقيدها وانعقاد الخصومة.	١٨
٢٦٧	الفصل الثاني: إجراءات نظر الدعوى.	١٩
٣٣٤	الفصل الثالث: عوارض الخصومة.	٢٠
٣٦١	الباب الثالث: التقاضي بوسيلة العريضة.	٢١
٣٦٢	الفصل الأول: الأوامر على العرائض.	٢٢
٣٧٣	الفصل الثاني: أوامر الأداء.	٢٣
٣٨٧	الباب الرابع: الحكم القضائي وطرق الطعن فيه.	٢٤
٣٨٨	الفصل الأول: الحكم القضائي وقواعده وآثاره.	٢٥
٤٢٧	الفصل الثاني: طرق الطعن في الحكم القضائي.	٢٦